

Alberto Briceño Ruiz

*D*erecho de la seguridad social



OXFORD

ALBERTO BRICEÑO RUIZ



Licenciado en Derecho. Presidente de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social, A.C. y de la Comisión de Seguridad Social del Foro Permanente de Legisladores.

Miembro de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Previsión Social, la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, la Academia de Derecho Procesal del Trabajo y el Instituto Latinoamericano de Derecho del Trabajo.

Director fundador del Bufete Briceño Ruiz.

Desde 1972, maestro titular en las materias Derecho del Trabajo y Derecho de la Seguridad Social en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)—decano en esta materia—, y a partir de 1994 en la Universidad del Mayab. También ha sido maestro en la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Panamericana, Universidad de Hidalgo, Universidad de Guanajuato, Universidad Anáhuac del Sur y Universidad La Salle.

Presidente de la Comisión dicraminadora de la *Ley Federal del Trabajo*.

Autor del anteproyecto de la *Ley del ISSSEAM*.

Abogado y asesor del Instituto Mexicano del Seguro Social (1965-1982).

Diputado de la XLVII Legislatura del Congreso de la Unión (1967-1970).

Secretario de la Cámara de Diputados por el segundo y tercer años de la legislatura.

Oficial Mayor de la H. Cámara de Senadores (1976-1982).

Asesor del secretario de Marina (1985) y del Secretario de la Contraloría General de la Federación (1986-1988).

Presidente del Comité Directivo de Asuntos Jurídicos de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (1983-1995).

Gerente jurídico laboral de Sidermex (1985).

Subprocurador Federal del Consumidor (1988-1990).

Notario público del Estado de México (1991-2002).

Autor de *Derecho individual del trabajo*, *Derecho mexicano de los seguros sociales*, *Reformas al seguro social*, *Golpe parejo* y *La renovación moral de la sociedad 1982-1988*, así como de artículos en *Revista Laboral*; coautor de *Obra conmemorativa de los 70 años del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa*.

Derecho de la seguridad social

OXFORD

UNIVERSITY PRESS

Derecho de la
seguridad social

Alberto Briceño Ruiz

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

OXFORD
UNIVERSITY PRESS

OXFORD

UNIVERSITY PRESS

Oxford University Press es un departamento de la Universidad de Oxford, el cual promueve los objetivos de excelencia en la investigación, el aprendizaje y la educación de la Universidad mediante publicaciones en todo el mundo. Oxford es una marca registrada de Oxford University Press en el Reino Unido y en algunos otros países.

Publicado en México por
Oxford University Press México, S.A. de C.V.
Antonio Caso 142, Col. San Rafael, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06470, México, D.F.

D.R. © Oxford University Press México, S.A. de C.V., 2010

Se han hecho valer los derechos morales del autor

DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Primera edición publicada en 2010

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, o guardada en algún sistema de recuperación, o puede ser transmitida en cualquier forma o por cualquier medio, sin la autorización previa, por escrito, de Oxford University Press México, S.A. de C.V., o como expresamente sea permitido por la ley, por licencia o bajo los términos acordados con la organización apropiada de derechos de reprografía. Deben enviarse las solicitudes de información acerca de reproducciones fuera del alcance de lo mencionado anteriormente al Departamento de Derechos de Autor de Oxford University Press México, S.A. de C.V., a la dirección mencionada arriba.

Usted no debe hacer circular esta obra en cualquier otra forma
y debe imponer esta misma condición a cualquier comprador.

Textos Jurídicos Universitarios

ISBN 978-607-426-095-3

Primera reimpresión

Se usaron tipos ITC Clearface (9, 11, 14, 16 y 18 pts.) y Kudos (7, 10 y 11 pts.),
sobre papel Bond Editor Alta Opacidad de 68 g
Se terminó de imprimir en Repro-flo, S.A. de C.V.,
Calle Chipiona núm. 115, Col. Cerro de la Estrella, C.P. 09880, México, D.F.

Impreso en México

Julio de 2011

El tiraje fue de 1 000 ejemplares

Créditos:

Autor: Alberto Briceño Ruiz

Commissioning editor: Flor María Díaz Soto

Dirección editorial, diseño y producción: Matío Andrés Aliaga Valenzuela

Gerente editorial del área de derecho: Lilia Guadalupe Aguilar Iriarte

Edición: José Luis García Herrera

Gerente de producción: Paula Sosa Jiménez

Supervisión de producción: Guillermo González Dorantes

Portada: Brenda Reyes Coix

Si algún tercero considera que parte del contenido de esta publicación, viola sus derechos de propiedad intelectual, puede enviar una notificación al domicilio arriba citado, indicando los datos personales del titular de los derechos supuestamente infringidos.

Oxford University Press México, S.A. de C.V., no se responsabiliza de los contenidos de las páginas Web enlazadas o referenciadas en esta publicación.

Índice de contenido

.....

Prólogo	XI
Primera parte. Principios estructurales	1
1. Aspectos conceptuales	3
Seguridad	3
Noción de <i>seguridad</i>	4
Inseguridad	6
Seguro	8
Seguridad social y seguro social	10
Conceptos	12
Fundamentos del Seguro Social	17
Elementos	17
Sujetos	20
Solidariohabiente	21
Regímenes de Seguro	22
Seguro obligatorio	22
Seguro voluntario	22
Seguro facultativo	23
Seguro adicional	23
Seguros del Seguro Social	24
Prestaciones	24
Prestaciones económicas	25
Prestaciones médicas	25
Prestaciones sociales	26
Solidaridad social	26

Organización	26
Reformas de la reforma	27
Segunda parte. Antecedentes	29
2. Conformación de derechos	31
Antigüedad	31
Edad Media	33
Origen de los seguros privados	34
Primeras teorías	39
Ley de distribución de probabilidades	39
Ley de los grandes números	40
Seguro de vida	41
3. Antecedentes del Seguro Social	43
El seguro social en Alemania	43
Congresos socialistas	46
Primeras leyes de seguro social	47
Encíclica <i>Rerum Novarum</i>	49
El seguro social en Inglaterra	50
Plan Beveridge	53
Expansión en el mundo	54
Evolución de la seguridad social en Europa	68
El seguro social en América	69
Conferencia Interamericana de Seguro Social	70
Modificación al sistema de pensiones	72
República de Chile	72
Reforma en Argentina	74
Situación en Brasil	75
4. El Seguro Social en México	79
Primeras garantías sociales	79
<i>Constitución de 1917</i>	80
Legislaturas de los estados	82
Primeras disposiciones a favor de los servidores públicos	83
Reforma constitucional de 1929	84
Tercera parte. Las leyes del Seguro Social	87
5. Primeras leyes	89
Principios de la Ley de 1943	91
Reformas a la Ley de 1943	94
La Ley de 1973	95
Reformas a la Ley de 1973	98
Diagnóstico de 1995	100

6.	Fundamentos de los seguros sociales	113
	<i>Ley del Seguro Social</i>	113
	Exposición de motivos	113
	Condición de asegurados y beneficiarios	118
	Organismo fiscal	119
	Tipos de seguro	120
	Régimen obligatorio	120
	Régimen voluntario	120
	Régimen facultativo	121
	Régimen adicional	122
	Seguros del Seguro	122
	Personas	123
	Derechohabientes	124
	Sujetos obligados	127
	Afiliación	127
	Sanción	128
7.	Salario base de cotización y cuota	131
	Concepto	131
	Exclusiones al salario base de cotización	133
	Trascendencia del salario base de cotización	138
	Salario fijo	138
	Salario variable	138
	Salario mixto	139
	Ausencias del trabajador	139
	Modificación de los salarios	140
	Modificación con un patrón	140
	Existencia de varios patrones	141
	Contrato colectivo	141
	Naturaleza de la cuota	141
	Organismo descentralizado	143
	Pago de las cuotas	144
	Sustitución patronal	144
	Caducidad y prescripción	145
	Cuarta parte. Los seguros del Seguro Social	147
8.	Riesgos de trabajo	149
	Teorías del riesgo	150
	Teoría de la culpa subjetiva	150
	Teoría del riesgo creado o contractual	151
	Nueva actitud	152
	Regulación en el Derecho Mexicano	152
	Mandato constitucional	153
	Ordenamientos civiles	155
	Orígenes del riesgo de trabajo	158
	Excepciones al riesgo de trabajo	160

Efectos del riesgo de trabajo	162
Indemnización en la <i>Ley Federal del Trabajo</i>	164
Prestaciones en la <i>Ley del Seguro Social</i>	166
Subsidio	166
Pensión	167
Indemnización	171
Incremento de las pensiones	181
Incompatibilidad	181
Ayuda para gastos de defunción	183
Aviso del patrón	184
Accidente imputable al patrón	184
Inconformidad del asegurado	185
Régimen financiero en el seguro de riesgos de trabajo	186
Monto de la prima	189
Revisión anual	193
 9. Enfermedad y maternidad	 195
Conceptos	198
Sujetos	198
Prestaciones médicas	200
Forma de prestar los servicios médicos	200
Medicina subrogada	203
Convenios con los patrones	209
Financiamiento del Banco Mundial	212
Documento en español	213
Operatividad	217
Subrogación parcial e integral	219
Documento en inglés	222
Cuadro básico de medicamentos	227
Prestaciones en dinero	229
Maternidad	229
Ayuda para gastos de defunción	231
Régimen financiero del seguro de enfermedad y maternidad	231
Sujetos del régimen voluntario	233
Cooperativas	234
 10. Invalidez y vida	 237
Condiciones previas	237
Invalidez	238
Seguro de vida	239
Pensión de viudez	240
Pensión de orfandad	241
Pensión de ascendientes	242
 11. Capitales constitutivos	 243
Supuestos	244

Elementos	245
Momento del fincamiento	246
Otorgamiento de las prestaciones	247
Integración	247
Liberación al patrón	253
Capital constitutivo en enfermedad y maternidad, e invalidez y vida	254
Derechos del trabajador	256
 12. Guarderías y prestaciones sociales	 259
Guarderías	259
Prestaciones sociales	262
Régimen financiero	264
 Quinta parte. El derecho mercantil regulador del seguro social	 265
 13. Las sociedades mercantiles en el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez	 267
Administración compartida	267
De las pensiones	273
Seguro de retiro	274
Seguros de cesantía en edad avanzada y vejez	276
Gasto público	283
Propiedad del trabajador	284
Cálculo de las pensiones	285
Cuenta individual	285
Cuenta concentradora	292
Transferencia de cuentas individuales	294
Condiciones para el otorgamiento de la pensión	296
Pensión garantizada	300
Conservación de derechos	302
Ayuda para gastos de matrimonio	303
 14. Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) y Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro (Siefore)	 305
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar)	305
<i>Ley del Seguro Social</i>	305
Competencia de la Consar	308
<i>Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro</i>	309
Órganos de gobierno	309
Obligaciones de la Consar	314

Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore)	314
Responsabilidades de las Afore	316
Facultades y prohibiciones de las Afore	319
Organización y autorización	320
Capital mínimo y reservas	321
Adquisición de acciones	322
Órganos de las Afore	323
Comisiones	326
Contrato con la Afore	329
Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro (Siefore)	341
Prohibiciones de las Siefore	347
Liquidación de las Afore y de las Siefore	349
Empresas operadoras	350
 Sexta parte. Organización del Instituto Mexicano del Seguro Social. Medios de defensa	 363
 15. Organización y facultades del IMSS	 365
Atribuciones y responsabilidades	365
Órganos de gobierno	369
Consejo Técnico	370
Comisión de Vigilancia	372
Dirección General	373
El IMSS como organismo fiscal autónomo	374
Presupuesto	378
Trabajadores de confianza	382
 16. Medios de defensa contra el IMSS	 385
Naturaleza jurídica de la cuota	385
Cédulas de determinación	386
Cédulas de liquidación	387
Prórroga	388
Recurso administrativo	389
Juicio fiscal	393
 Bibliografía	 403
Índice onomástico	405
Índice analítico	409

Prólogo

.....

En la obra *Derecho de la seguridad social*, del maestro Alberto Briceño Ruiz, se afirma con certeza que México fue el país pionero en el mundo en elevar a rango constitucional los derechos sociales. En efecto, como resultado de las aspiraciones sociales del pueblo mexicano, que fueron el motor del enorme movimiento armado de inicios del siglo XX, la Constitución del 5 de febrero de 1917 incluyó en su articulado una amplia gama de estos derechos.

A la luz de esta nueva filosofía, el texto de nuestra Ley Superior dio especial importancia a las normas reguladoras del trabajo y de la seguridad social, apegándose a la avanzada ideología revolucionaria que entendía al Estado como agente privilegiado del desarrollo y bienestar de los grupos sociales y de sus integrantes, especialmente al establecer reglas de protección al trabajo personal, a la organización colectiva de los trabajadores y a los mecanismos de seguridad social indispensables para lograr la superación y mejora de sus condiciones de vida.

De esa manera, la Revolución Mexicana y su renovado marco legal venían a dar un perfil diferente al papel del poder público, diseñando para el Estado una serie de tareas inéditas que ahora debía asumir en la atención de los retos que la modernidad social exigía en su realización inaplazable. El impulso revolucionario institucionalizó esas demandas en distintas fracciones del art. 123 de la Constitución, como base estructural de las relaciones laborales del país.

En materia de seguridad social el país fue gestando un conjunto de instituciones y normas legales que resumían las más importantes y aventajadas teorías y prácticas de aquellos años, como los conceptos relativos al *Estado de bienestar* o al *Estado providencial*, que predominaban en distintas naciones europeas, en especial Alemania, Francia y Gran Bretaña. Es así como en 1943

finalmente se aprobó la *Ley del Seguro Social* (LSS), por lo que al año siguiente entró en funcionamiento el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para dar operatividad a la seguridad social generalizada para los trabajadores.

Paralelamente a estos acontecimientos, por aquellos años se fueron haciendo realidad los esfuerzos de una pléyade de notables juristas nacionales que aportaban sus ideas sobre el Derecho del Trabajo y el Derecho de la Seguridad Social, dando contenido y método a estas nuevas ramas de la ciencia jurídica. Recordamos, entre otros, a los distinguidos maestros Mario de la Cueva, Salomón González Blanco, Jesús Castorena, Alberto Trueba Urbina, Maclovio Castorena, Alfredo Sánchez Alvarado, Guillermo Hori Robaina, Gustavo Arce Cano y Ángel Guillermo Ruiz Moreno.

De manera especial debo mencionar a Don Ignacio García Téllez, notable abogado guanajuatense, quien ocupó relevantes cargos públicos en el gobierno federal y quien fuera el primer rector de la Universidad Nacional cuando ésta obtuvo su autonomía. A García Téllez correspondió presidir la Comisión que redactó la LSS, cuya iniciativa fue presentada al Congreso por el presidente Lázaro Cárdenas en 1938. De igual forma, correspondió a García Téllez ser el segundo Director General del naciente IMSS.

Queda claro que en nuestro país la seguridad social ha sido preocupación tanto de la administración pública como del sector académico, que mucho ha aportado para su mejor concepción y funcionamiento. En este marco aparece la presente obra titulada *Derecho de la seguridad social*, de la autoría de Don Alberto Briceño Ruiz, distinguido catedrático universitario, quien desde hace casi 40 años ha impartido la asignatura en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en donde cuenta con la categoría de profesor titular nivel "C". Briceño Ruiz es, además, presidente de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social, que fundó hace poco más de 10 años. El autor ya nos ha brindado anteriormente su experiencia en esta disciplina con un magnífico texto denominado *Derecho mexicano de los seguros sociales*, publicado en 1985, *Reformas al Seguro Social*, de 1993, y varias obras donde es coautor, entre ellas la publicación del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, conmemorativa de sus 70 años. Cabe destacar que el maestro Briceño ha participado intensamente en el análisis y estudio de las muchísimas modificaciones que ha tenido el Derecho de la Seguridad Social en México y en el mundo.

El texto que ahora sale a la luz consta de seis partes temáticas en las que el autor expone, de manera erudita pero ágil y notablemente didáctica, los aspectos sustanciales del Derecho de la Seguridad Social. En la primera de ellas aborda los principios estructurales de la disciplina, explicando con minuciosidad los conceptos que más utiliza esta rama del Derecho, como seguridad, inseguridad, seguro, seguro social, régimen del seguro y seguros del seguro social.

La segunda parte del texto está dedicada a exponer los antecedentes de la seguridad social. Nos recuerda el autor que desde los tiempos antiguos hasta

hoy, la sociedad se ha preocupado, en mayor o menor medida, por combatir la inseguridad que enfrenta la existencia humana. Expone algunos antecedentes de los pueblos antiguos, así como de Grecia y Roma. Señala que en la Baja Edad Media surgieron una serie de agrupaciones de defensa y asistencia de sus integrantes, como los gremios de mercaderes, las cofradías de artesanos y las guildas. Más tarde aparecerían los seguros privados, que a partir del siglo XVI contaron con amplia legislación, sobre todo en asuntos de riesgos marítimos.

En este repaso de los antecedentes de la seguridad social nos lleva el autor por otros importantes pasajes, para precisar la génesis de estas instituciones. Afirma que no fue sino hasta finales de siglo XIX cuando el llamado *Mariscal de Hierro*, Otto von Bismarck, ministro del viejo Kaiser Guillermo I, creó en Alemania un sistema de seguridad social con el fin de contrarrestar al poderoso movimiento socialista que se incrustaba en los más amplios espacios de Europa.

En los años iniciales del siglo XX se fueron consolidando de manera más firme las legislaciones relativas a los seguros de orden social, tanto en Alemania como en Inglaterra. En 1907 la legislación inglesa contó con una *Ley de Reparación de Accidentes de Trabajo*, a más de un sistema de asistencia para ancianos. Pocos años después, a instancias de David Lloyd George, el Parlamento británico habría de aprobar una ley de seguridad social denominada *National Insurance Act*, que abarcaba ramos asegurados muy diversos, como enfermedad, invalidez, paro voluntario y previsión de desempleo.

En este orden de ideas, indica el maestro Briceño, en 1942 surgió en Inglaterra el Plan Beveridge, que debió su nombre a Sir William Beveridge, quien contó con el respaldo de Winston Churchill, y que tuvo como fin concentrar todas las experiencias obtenidas en materia de combate a la miseria, así como las prestaciones diversas por riesgos de trabajo y la asistencia de los seguros sociales, ubicando a ese país como el más desarrollado en materia de seguridad social.

Destaca el autor, en este apartado de su texto, cómo los diversos congresos de trabajadores europeos de filiación socialista fueron pugnando por la extensión generalizada de las normas de seguridad social. Al surgir la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se fueron elaborando y suscribiendo importantes instrumentos legales sobre la materia de seguridad social. Ha correspondido al Convenio 102 de esa Organización establecer las bases mínimas para que se brinde la seguridad social, que de acuerdo con dicho ordenamiento habrá de contener cuando menos los aspectos relativos a asistencia médica, así como prestaciones por enfermedad, desempleo, vejez, en caso de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales, maternidad e invalidez.

Partiendo de esos antecedentes, el autor presenta también un panorama resumido, pero aleccionador, del surgimiento de la seguridad social en América, haciendo especial referencia a los casos de Chile, Argentina y Brasil.

De forma particular se dedica el capítulo 4 al análisis del surgimiento de la seguridad social en nuestro país. Rememora el autor los antecedentes humanistas que en materia de protección a los individuos dictaron Don Miguel Hidalgo al abolir la esclavitud, y Don José María Morelos en los principios que contienen los *Sentimientos de la Nación*. Como antes he señalado, fue la nueva Constitución de 1917 la que determinó la vigencia de una serie de derechos en materia de protección laboral y de seguridad social.

La tercera parte del texto inicia con el análisis de las diversas leyes que han regido al Seguro Social en México, como la de 1943, la de 1973 y las trascendentales transformaciones que se dieron en 1995 al ordenamiento. La primera de ellas, que dio nacimiento al IMSS, fue propuesta mediante iniciativa del presidente Manuel Ávila Camacho, otorgando al Instituto la calidad de órgano público descentralizado. La creación del IMSS fue un avance fundamental para el país, toda vez que sería el marco normativo que habría de dar cabida a otros instrumentos e instituciones sobre seguros sociales, como los que protegen a los servidores públicos (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE) o a las fuerzas armadas y, más tarde, al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

En 1973 se expidió una nueva *Ley del Seguro Social* a iniciativa del presidente Luis Echeverría. El ordenamiento mejoró diversas áreas de la seguridad social. Se reiteraron los seguros existentes, aumentándose otros, como el seguro de guarderías, y se estableció el régimen voluntario. Esta nueva Ley también se distinguió por haber contemplado una cobertura para los grupos campesinos organizados al instituir el Programa de Solidaridad Social IMSS-Coplamar, administrado por el Instituto. Con la Ley de 1973 se estaba logrando la realización del justo anhelo de los mexicanos por contar con un sistema de seguridad social integral.

La larga vigencia de esta Ley de 1973 propició que la misma contara con múltiples reformas y adiciones. Fue en 1995 cuando se expidió la Ley vigente en materia de seguro social a propuesta del presidente Ernesto Zedillo, misma que apareció publicada en el *Diario Oficial de la Federación* el día 21 de diciembre de ese año, para entrar en vigor el 1 de enero de 1997, prorrogándose finalmente el inicio de su vigencia al 1 de julio de 1997. Indica el autor del libro que el contenido y las tendencias técnicas de esa Ley se debían a un diagnóstico sobre la crisis financiera que de años anteriores venía enfrentando el IMSS. Se concluía en esa apreciación que esta crisis obedecía al tipo de sistema pensionario derivado del modelo de *reparto solidario* o *fondo común* con pensiones predefinidas en la Ley. Por ello se propuso el cambio al sistema de *fondos personales* o de *capitalización individualizada*, asunto que hasta la fecha sigue generando grandes polémicas en muchos sectores nacionales, en donde se cuestionan las bondades que se dijeron tendría ese nuevo sistema pensionario.

Más adelante, analiza el maestro Briceño de manera muy pormenorizada los diversos tipos de seguros que ampara el sistema de seguridad social mexica-

no. En primer término, dedica un amplio apartado a tratar el seguro por riesgos de trabajo, las teorías que los contemplan, sus efectos, las prestaciones que en estos casos deben cubrirse, ya sea por vía del subsidio, la pensión o las indemnizaciones por muerte, viudez u orfandad. Asimismo, trata en ese contexto lo relativo a las ayudas de gastos funerarios y otros de esta gama asegurada.

Igualmente destina el autor un capítulo para tratar lo correspondiente al tema de enfermedades y de maternidad. Detalla los principales conceptos de estas cuestiones para su correcto manejo, los sujetos que intervienen, las prestaciones médicas, la medicina subrogada y los convenios con los patrones. La experiencia del autor en el enfoque de estos temas queda de manifiesto cuando en este apartado diserta sobre la marcada influencia del financiamiento del Banco Mundial en asuntos de seguridad social, así como cuando expone lo relativo al cuadro básico de medicamentos con el que opera el IMSS y que a todas luces se aprecia como francamente insuficiente y desactualizado.

Los seguros por invalidez y vida a cargo del IMSS se analizan en el capítulo 10; los capitales constitutivos son tratados en el capítulo 11, y las guarderías y prestaciones sociales en el 12. Sin duda, el análisis que presenta el maestro Briceño sobre estos puntos no sólo nos orienta en los aspectos técnico-jurídicos de los mismos, sino que también nos brinda una opinión muy calificada para ayudarnos a dimensionar la problemática que actualmente enfrenta el IMSS en su operación y tratamiento. Basta recordar los lamentables hechos recién ocurridos en una guardería "subrogada" en la ciudad de Hermosillo, Sonora, en la que por desgraciada perdieron la vida varias decenas de infantes.

El apartado más novedoso del texto en comentario, es el contenido en la quinta parte, a la que el autor titula "El derecho mercantil regulador del Seguro Social", que abarca dos capítulos. Como marco general de la exposición se entiende que a más de las disposiciones que rigen en la actividad propia del IMSS, así como del ISSSTE e incluso el Infonavit, las reglas pensionarias se encuadran también en la *Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro*, así como un buen número de normas contenidas en otros ordenamientos de tipo mercantil, como la *Ley de Instituciones de Crédito*, la *Ley del Mercado de Valores*, la *Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros*, la *Ley para Regular las Agrupaciones Financieras* e, incluso, la *Ley de Protección al Consumidor*.

Al entrar en materia, de inicio expone el autor las maneras y los mecanismos en los que las sociedades mercantiles están interviniendo de forma compartida con el IMSS, en los seguros de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Sigue con la exposición de las bases en que bajo estas nuevas reglas se calculan las pensiones para integrarse a las cuentas individualizadas. Termina con la selección de la Administradora de Fondos para el Retiro (Afore) por parte del trabajador, lo relativo a las cuentas concentradoras, las transferencias de las cuentas individualizadas, la pensión garantizada, la conservación de derechos y la ayuda para gastos de matrimonio.

Agrada el tratamiento ágil y didáctico que se da en el texto al estudio de las instituciones y los procedimientos bajo los que opera este nuevo sistema pensionario, de por sí complejo y sumamente técnico, porque facilita su mejor entendimiento para el lector no especializado. En efecto, analiza el autor cada una de estas nuevas figuras, su organización, sus órganos operativos, sus obligaciones, su capital y reservas, sus comisiones a cobrar, sus prohibiciones y su liquidación. Así lo hace, en lo conducente, con la Comisión Nacional de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (Consar), las Afore y las Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos de Retiro (Siefore).

La sexta y última parte del texto contiene la parte administrativa y de organización del IMSS. Detalla y analiza las atribuciones y responsabilidades del Instituto, los órganos de gobierno, como Director General, Consejo Técnico y Comisión de Vigilancia. Diserta con argumentos bien fundados sobre la autonomía de la Institución y sus facultades para fijar créditos y exigir cobros por la vía ejecutiva de orden administrativo.

El capítulo 16, con el que concluye el texto, contiene un sustancioso estudio de los medios de defensa en contra de las determinaciones del IMSS. Detalla al efecto las diversas posiciones teóricas en torno a la naturaleza jurídica de las cuotas que se pagan al Instituto, las cédulas de determinación, las cédulas de liquidación, las prórrogas y los recursos administrativos internos que se pueden hacer valer. Trata además, de manera general pero clara, el juicio fiscal que se puede interponer en contra de las determinaciones del IMSS.

Reitero lo que señalé al inicio del prólogo, en el sentido de que esta nueva publicación del prestigiado jurista y maestro universitario Don Alberto Briceño Ruiz sobre el Derecho Mexicano de la Seguridad Social es bienvenida en la academia y en los sectores sociales del país. Las aportaciones del texto se verán fructificadas en cada alumno que lo siga, en cada maestro que lo explique y en cada lector que lo aproveche. La seriedad y experiencia de Briceño son garantía de la excelente factura y del rico contenido del libro en comentario.

Una reflexión que finalmente nos deja el libro de Don Alberto Briceño Ruiz es la de pensar con sensatez y compromiso social, si estos nuevos procesos, mecanismos e instituciones en las que se soporta el nuevo modelo pensionario, son los más adecuados, los más útiles y sobre todo los más justos para la sociedad mexicana. O si por el contrario, como mucho se ha discutido en muy diversos foros, la seguridad social se está dejando hoy en día bajo la regulación de aquellos principios que soportan más a los procesos mercantiles y que son propios del Derecho Privado, con meros afanes de competencia, especulación y lucro. El tiempo nos dará las respuestas.

México, D.F., febrero de 2010

LIC. PEDRO OJEDA PAULLADA

Primera parte

Principios estructurales

1 Aspectos conceptuales

Seguridad

La variedad de actividades que desempeñamos tienen como denominador común la búsqueda de la seguridad, cuando no se han adquirido aún los medios necesarios de supervivencia o cuando se han perdido, así como el incremento de esa seguridad, una vez alcanzados los satisfactores indispensables.

Las épocas de crisis afectan los espacios de seguridad, personal y social; por lo que las medidas tomadas y hasta los planes de choque buscan restablecer el bienestar como condición de equilibrio. El marco que integra la seguridad se amplía o restringe conforme a las cualidades individuales, los aspectos sociales e incluso de acuerdo con la situación imperante en el ámbito internacional; también varía a través de las distintas épocas de la humanidad.

No existe, pues, la misma seguridad en Europa, África, América o en los países neosocialistas o neoliberales. Felipe González señala —al prologar el libro de François Mitterrand *Aquí y ahora*— “la necesaria diferencia entre el socialismo francés y el español, por razón de simple aplicación geográfica”.¹

El término seguridad es muy amplio; se ve afectado por todo quehacer de los grupos humanos y aun del individuo. Hay autores que sostienen que el marco individual debe supeditarse al social; otros, a la supremacía de un sector sobre los individuos, y, en fin, quienes sitúan en la cima a la sociedad representada por el Gobierno.

Las personas trabajan para adquirir satisfactores o servicios que incrementen la seguridad, al igual que se estudia, escribe, roba, mata o se mantiene la vida. Justificamos la política, la ciencia, la técnica, el arte, la guerra o la religión.

1 François E. Mitterrand, *Aquí y ahora*, Argos Vergara, Barcelona, 1982, p. 10.

San Agustín escribió: "Nos hiciste para Ti Señor, e inquieto está nuestro corazón hasta no descansar en Ti. Sólo en Dios halla el hombre la perfecta seguridad, y sólo Él remedia plenamente la total inseguridad humana."²

Mucho se ha hablado de armas defensivas, de la fuerza militar como garantía de democracia, de Dios como seguridad absoluta en esta vida y en la vida futura. Se hace la guerra para disminuir la inseguridad, lo mismo que se abren mercados o diversifican cultivos y fuentes de trabajo. En este sentido Coppola afirma que "la seguridad no es un hecho psicológico, más bien es un sentimiento".³

El ser humano debe estar seguro no sólo frente a la adversidad sino en todos sus actos. En cada esfuerzo buscamos estabilidad, posibilidad de trabajo, aumento en las percepciones, descanso y esparcimiento, al igual que recuperación de la salud, pensión en la adversidad y protección para la familia. José Ortega y Gasset expresaba que los hombres "partimos a la conquista de una seguridad radical que necesitamos, porque precisamente lo que por lo pronto somos, aquello que nos es dado al nacer dada la vida, es radical inseguridad".⁴

Noción de *seguridad*

Por la amplitud de la materia, es difícil y resulta de poca claridad elaborar un concepto que abarque las muy variadas acciones que se refieren a la seguridad social, que se clasifica de la manera siguiente:

Seguridad biológica, como los medios para preservar las formas diversas de vida.

Seguridad ecológica, como elemento esencial del equilibrio de la naturaleza, que evite niveles de contaminación y mantenga zonas necesarias o convenientes para cualquier tipo de vida.

Seguridad económica, como la dotación de los medios de aprovechamiento de recursos materiales, humanos y naturales en beneficio de una comunidad, para el incremento de satisfactores.

Seguridad educativa, conformada con la instalación de aulas y planteles, pero de manera primordial con calidad en la enseñanza que la haga menos teórica y más pragmática.

Seguridad física, integrada por el conjunto de elementos naturales que hacen posible la existencia y el desarrollo social, además de permitir la previsión de ciertos fenómenos naturales, ajenos al quehacer humano.

2 Alberto Briceño Ruiz, *Derecho mexicano de los seguros sociales*, Harla, México, 1987, p. 5.

3 Gustav Radbruch, *Los fines del derecho*, UNAM, México, 1981, p. 19.

4 Alberto Briceño Ruiz, *op. cit.*, p. 6.

Seguridad jurídica, derivada del orden normativo; de garantías de seguridad, para impedir extremos de autoridad.

Seguridad laboral, consistente en el desarrollo de una infraestructura que permita hacer del trabajo la fuente primordial de sostén de la familia.

Seguridad médica, para mantener la salud, prevenir enfermedades, dotar de medios de curación y prolongar las expectativas de vida.

Seguridad militar, para preservar, con sentido nacionalista, las instituciones del país y la paz interior, dentro de los preceptos de ley.

Seguridad pública, que dé al ser humano y a la sociedad los elementos de tranquilidad para la realización de las diversas actividades.

Seguridad religiosa, como el justo equilibrio de paz interior, para que el ser humano pueda trascender su situación biológica.

El origen de toda seguridad es el derecho, ya que regula, norma y controla los demás aspectos de seguridad; por ello, no podemos hablar de un derecho de la seguridad social, sino de un derecho a la seguridad social, en sentido genérico que comprenda a todas las demás.

Gramaticalmente, *seguridad* se define como:

1. Calidad de seguro. Fianza u obligación de indemnidad a favor de uno. Prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades crónicas que pueden derivarse de la naturaleza o las condiciones del mismo. Está íntimamente ligada con la higiene del trabajo. Prevención del paro, la invalidez, la vejez, etc., de los trabajadores mediante el desarrollo del mutualismo y de los seguros sociales.⁵
2. Medios de los que se vale el Poder Público para readaptar a la sociedad a aquellas personas que sin ser culpables han cometido un delito, o las que sin haberlo cometido, presentan una peligrosidad que hace temer de ellas una actuación delictiva.⁶

En este sentido, la seguridad es tan amplia que no puede contenerse en una ciencia y, mucho menos, en una disciplina jurídica autónoma.

Jurídicamente, la seguridad tiene dos connotaciones:

- Por una parte, permite eliminar la inseguridad proveniente de la adversidad y las contingencias a que estamos expuestos; éste es su aspecto negativo.

5 *Diccionario Enciclopédico Universal*, t. VIII, CREDSA, Barcelona, p. 3897.

6 *Gran Enciclopedia del Mundo*, t. XVII, Durvan, Bilbao, 1973, p. 17.

- Por otra, con un criterio positivo, proporciona al ser humano los elementos necesarios para la subsistencia, conforme a sus fuerzas y aptitudes, sin más limitación que el respeto al recíproco derecho de los demás.

La sociedad, al procurar los medios para el desarrollo de la existencia, no debe limitarse a curar en caso de enfermedad, sino a prevenir la contingencia; en lugar de menospreciar a los ignorantes, ha de promover la educación para el desempeño; de igual forma, el desempleo sólo puede abatirse con adecuados planes y programas de desarrollo económico.

La amplitud del término *seguridad* abarca tanto la actividad como el conocimiento acumulado por el ser humano. Desde la labor del campesino o artesano hasta la del científico, no existen límites para la seguridad, como no los hay para el conocimiento y las aspiraciones.

Inseguridad

En la obra *México y la seguridad social*⁷ se considera que la inseguridad social depende de manera general de las realidades concretas dentro de las cuales se desenvuelve el proceso social, y en este sentido puede haber factores de inseguridad que obedecen a:

Causas biológicas, que son el contenido de lo que comúnmente se designa como inseguridad social.

Causas físicas, vinculadas al proceso de evolución económica.

Causas sociales, mediante la creación de estructuras de defensa colectiva, vinculadas al Estado, convirtiéndose en una función de autoridad o de soberanía.

Este criterio limitaría nuestro estudio a las causas biológicas, las que no podemos aislar sin encontrar la interdependencia entre todos los factores señalados.

Es importante mencionar factores de seguridad y analizar las causas que deben atenderse; sin embargo, resulta imposible elaborar una lista de contingencias que irían desde la función pública hasta la preservación del empleo, y donde se abarcarían aspectos de ingresos, mercados, producción, moral, arte, derecho, etcétera.

7 *México y la seguridad social*, Stylo, México, 1952, p. 6.

Para cualquier clasificación es conveniente considerar que

... la Seguridad Social es, pues, una proyección de futuro que se refiere a una sociedad en movimiento, no a una sociedad estática. La Seguridad Social es eso: un estado de equilibrio de fuerzas sociales, físicas, biológicas y psíquicas, representado intelectualmente, deseado a consecuencia de un juicio de valor positivo, querido de manera consciente.⁸

Lo cierto es que:

Esta inseguridad en que el hombre se halla inmerso no comprende sólo un determinado sector o área de la vida humana, sino que ocupa la totalidad de la propia existencia del hombre, inseguridad que, siendo total, impulsa la actividad humana en orden a ponerle coto igualmente, en un sentido total, por lo que el hombre combate a la inseguridad, o cuando menos así lo pretende, en tantas direcciones cuantas ella toma en relación con la vida.⁹

Las causas o fuerzas sociales, físicas, biológicas y psicológicas integran la seguridad social. Como afirma Agustín Basave: "Ante la amenaza de la muerte, respirar es ganar una batalla; ante la inestabilidad producida por la curiosidad, raciocinar es conquistar una batalla."¹⁰

El campo de comprensión de la seguridad social es tan amplio, que toda ciencia, arte, técnica y conocimiento humanos forman parte de ella. La seguridad social es un marco que por la disminución o eliminación de riesgos propicia el desarrollo de la existencia individual y comunitaria: a menor riesgo, mayor seguridad. La amplitud de este marco está constituida por un estado de equilibrio de fuerzas que permite la proyección a futuro, en una sociedad dinámica.

Para Gustav Radbruch,

... el valor de la Seguridad, resulta, sin embargo, de su utilidad para el bien común tomado en un sentido más amplio. Esta utilidad para el bien común ha sido subrayada de la manera más impresionante por Jeremías Bentham, quien es, con Ludwig Kuapp, el más grande panegirista de la seguridad. Bentham reconocía en la Seguridad el seguro decisivo de la civilización, la marca distintiva entre la vida de los hombres y la de los animales. Es ella la que nos permite formar proyectos para el porvenir, trabajar y hacer economías; es ella sola la que hace que nuestra vida no

⁸ *Ibidem*, p. 365.

⁹ Miguel A. Sierra López, "Inseguridad, seguridad jurídica y seguridad social", en *Boletín de Información Jurídica*, IMSS, núm. 15, septiembre-octubre de 1985.

¹⁰ Alberto Briceño Ruiz, *op. cit.*, p. 24.

se disuelva en una multitud de elementos particulares, sino que esté asegurada de una continuidad. Es la Seguridad la que une nuestra vida presente y nuestra vida futura por un lazo de prudencia y de previsión y perpetúa nuestra existencia en las generaciones que nos siguen.¹¹

Exposición al riesgo

Atención a la contingencia o adversidad



Seguro

La connotación de *seguro* es más limitada y, me atrevo a decir, menos pretenciosa: una simple noción de seguro nos brinda la idea de protección.

La *protección* supone un riesgo y éste la necesidad de atender una contingencia. Así como se ha visto la conveniencia de precisar el concepto de seguridad social, existe la preocupación de que la denominación de seguro no comprenda la trascendencia de esta disciplina.

Los pocos autores y el reducido número de maestros en esta materia no hemos unificado criterios en cuanto al concepto de seguridad social. Todos, sin embargo, entendemos que tiende a proteger al ser humano desde su nacimiento, con los mínimos adecuados frente a las contingencias que se le presentan para mantener la salud, el ingreso económico, la educación, el esparcimiento, como medios para que mantenga y supere su nivel de vida.

El seguro social no protege a todos los individuos sino sólo a ciertos grupos sociales. La protección varía conforme a la actividad que desarrollan, bien por mantener la capacidad económica de la persona, como para preservar su capacidad y fuerza de trabajo.

El seguro social tampoco puede cubrir todas las contingencias. Éstas, como se ha visto, son tan variadas que sería imposible comprenderlas, pues

¹¹ Gustav Radbruch, *op. cit.*, p. 66.

implicaría garantizar sistemas económicos, políticos, religiosos, sociales, educativos, de trabajo, etc., de acuerdo con las aspiraciones de cada individuo. Desde luego, en esta disciplina lo individual es condicionante de lo común y el bienestar personal es un supuesto necesario del colectivo. "La insuficiencia de los métodos tradicionales para cubrir adecuadamente los riesgos sociales, principalmente de las clases más necesitadas, trajo consigo a fines del siglo pasado el nacimiento de un nuevo sistema: el de los seguros sociales."¹²

Hablar de protección implica la necesidad de otorgar prestaciones adecuadas a las contingencias, y como los riesgos varían conforme a la actividad y el seguro social, para mantener lo atractivo de sus prestaciones debe manejarse con criterios de elevada calidad.

La palabra *seguro* significa "libre y exento de todo peligro o daño". Seguro es "previsión al azar mediante la subdivisión del riesgo". El seguro es una institución jurídica de naturaleza económica, mediante la cual las adversidades personales o patrimoniales se transfieren del particular a un grupo. Esta transferencia tiene como contraprestación el pago de una cuota, llamada *prima*, y a cambio el grupo emite un contrato de cobertura, conocido como *póliza*. El total de las primas pagadas al grupo por los contratantes de las pólizas constituye el fondo de reserva que sirve para cubrir las pérdidas individuales.

A fin de que un seguro sea económicamente factible se requieren cinco condiciones fundamentales:

1. Existir un peligro real.
2. El asegurado debe estar interesado en el bien que asegura.
3. El valor del bien ha de ser suficiente para justificar la creación y el mantenimiento del contrato del seguro.
4. Ser posible calcular la frecuencia de pérdidas y su gravedad, de acuerdo con normas predeterminadas.
5. Existir un número elevado de personas interesadas en suscribir y mantener la póliza a fin de que se produzca una debida distribución.

El seguro social se propone proteger a ciertas personas, consideradas como integrantes de grupos económicos activos, frente a determinadas contingencias que pueden disminuir o extinguir su capacidad orgánica funcional. Los grupos permiten fijar cuotas, que son recursos para financiar las prestaciones que deben brindar los organismos encargados de administrarlos. Las contingencias serán aquellas que por su importancia resulte atractivo prevenir y remediar en beneficio de los asegurados, conforme a su incidencia y gravedad.

12 Alfredo Bowen Herrera, *Introducción a la seguridad social*, 3ª ed. actualizada, Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 1992, p. 33.

Un seguro social no puede limitarse a establecer un catálogo de amenazas y fórmulas de prevención; su función es más trascendental: ser un instrumento ágil, real, eficaz y permanente que organice programas para que los individuos logren e incrementen su bienestar. Ese "estar bien" es el objeto del seguro social, es una condición de quien tiene garantizados sus ingresos, capacitación y esparcimiento, en un medio que permita el desarrollo de la existencia en condiciones de salud.

Este aspecto presenta el gran reto, difícil de vencer cuando se anteponen otros valores a los que constituyen los seguros sociales. Desde su creación ha sido atractivo crecer en forma horizontal, aun cuando se olvide el verdadero propósito de hacerlo en forma vertical. El orgullo de llegar a los más de 49 millones de derechohabientes y 11 millones de solidariohabientes se contraría con la difícil situación financiera de la institución y las pobres prestaciones que se entregan a los beneficiarios. Es igual de importante crecer en forma vertical que horizontal. Respecto de la salud, debe cuidarse la calidad del servicio en relación con el número de pacientes.

El seguro social obliga a señalar objetivos, crear instituciones, atender estudios económicos adecuados, mantener cálculos actuariales que permanentemente determinen costos y posibilidades de crecimiento, elaborar normas claras y accesibles, configurar prestaciones de calidad que atiendan de manera eficiente las necesidades previstas, instrumentar acciones de prevención; todo ello con el objeto de atender a los grupos sociales destinatarios de los beneficios. El crecimiento horizontal debe cuidar los aspectos financieros del desarrollo económico; es decir, sólo ofrecer mayores y mejores ventajas en atención a estadísticas, incidencias y posibilidades derivadas de cálculos actuariales para que no peligre ni disminuya la calidad en los servicios.

Asimismo, en la medida de su eficacia y cuidadosa administración, el seguro social es un instrumento de paz social, especialmente en esta época en la que los problemas internos se han hecho evidentes con mayores índices de inseguridad.

Seguridad social y seguro social

La existencia de la seguridad social supone y condiciona al seguro social; el crecimiento del seguro social amplía el marco de la seguridad social. La seguridad es el género; el seguro social, su instrumento. Desde luego, diversas disciplinas como la medicina, ergonomía, economía, estadística y matemática guardan relación con la seguridad y gravan o benefician su desarrollo, dependiendo, en buena parte, de la eficacia del seguro social.

La relación entre seguridad social y seguro social, con sus distinciones, se presenta en el cuadro siguiente:

Seguridad social

Protección al ser humano

Cubre todas las contingencias

Se relaciona con todas las actividades

El Estado es el sujeto obligado

Su costo está cubierto por la nación

Sólo es socialmente exigible

El gobierno estructura programas de protección

Seguro social

Protección a grupos humanos

Cubre determinadas contingencias

Se refiere sólo a las actividades que son materia de aseguramiento

Se atiende por organismos administradores

Su costo se cubre con cuotas

Genera derechos que pueden reclamarse ante los tribunales

Los organismos administradores instrumentan los programas

La seguridad social está vinculada con la satisfacción de necesidades permanentes. La materia y el objeto del seguro social lo constituyen las necesidades contingentes, que son condición para satisfacer de manera normal las permanentes. De lo contingente a lo permanente, en gradación; del seguro social a la seguridad social por coordinación.

La seguridad social incluye a todos los seres humanos, en beneficio de la humanidad y las sociedades, cualesquiera que sean el lugar y el tiempo de su existencia. El seguro social asume la función *particular*, no general, sino precisada y referida a grupos determinados, como imperativo funcional, de estructura, de un organismo especializado.

La seguridad social es total, obligatoria y humana. El seguro social es un mecanismo que produce un resultado previsto y deseado, como fenómeno técnico objetivo.

La generalidad de la seguridad social, el reconocimiento universal de su propósito demuestra, más que una acción general, una apreciación común y una coincidencia de objetivos. El seguro social responde a fenómenos técnicos objetivos que producen un resultado previsto y deseado; para ello consta de sistemas, prestaciones y organización. Su aspecto particular permite la concreción en los conocimientos, aplicación de políticas y determinación de resultados. El seguro social integra normas jurídicas con autonomía; por esto podemos hablar de un *Derecho del seguro social*, con instituciones jurídicas

propias, exigibilidad de los sujetos beneficiados por la norma para con la organización obligada, y de la institución administradora para con los sujetos públicos o particulares que deben cumplir lo estatuido.

Conceptos

La seguridad social es tan antigua como la humanidad. Me atrevería a sostener que se remonta al momento mismo de la creación, en que el universo y los sistemas de planetas son producto de una armonía de fuerzas.

El seguro social nació a fines del siglo XIX por la acción decidida de los gobiernos europeos, casi al tiempo que se estructura el derecho del trabajo, sin contar con su dinámica. Las publicaciones al respecto son escasas y su vinculación con la legislación laboral persiste hasta nuestros días.

Las definiciones de seguro social y seguridad social que ofrecen los diversos autores son, en muchos casos, confusas y hasta contradictorias, por lo que debemos estudiarlas con afán de investigación, pero con la debida reserva.

Presentaré dos grupos:

Conceptos de seguridad social

No consideran al seguro social

Conceptos de seguro social

Se refieren tanto a la seguridad social como al seguro social

Para Miguel A. Cordini,¹³ la seguridad social es el conjunto de principios y normas que, en función de solidaridad social, regula los sistemas y las instituciones destinados a conferir una protección jurídicamente garantizada en los casos de necesidad bioeconómica determinados por contingencias sociales.

Dino Jarach¹⁴ la considera como el conjunto de medidas que tienden a asegurar un mínimo de rédito a toda persona, cuando la interrupción o pérdida de su capacidad de trabajo le impidan conseguirlo con sus propios medios.

Marcos Flores Álvarez la entiende como "la organización, dirección de la convivencia económica por los Estados, con el fin de eliminar las causas de perturbación del organismo social, derivadas de la insatisfacción de las necesidades básicas de sus componentes o de su satisfacción de forma lesiva para la dignidad humana".¹⁵

13 Miguel A. Cordini, *Derecho de la seguridad social*, Eudeba, Buenos Aires, 1966, p. 9.

14 Dino Jarach, *Problemas económico-financieros de la seguridad social*, p. 196.

15 Marcos Flores Álvarez, *Actas del Primer Congreso Iberoamericano de Seguridad Social*.

El objeto de la seguridad social está señalado por Miguel García Cruz¹⁶ como la prevención y el control de los riesgos comunes de la vida, para cubrir las necesidades, cuya satisfacción vital para el individuo es, al mismo tiempo, esencial a la estructura de la colectividad, para atender, como dice Moisés Poblete Troncoso,¹⁷ la protección adecuada del elemento humano y ponerlo al cubierto de los riesgos profesionales y sociales, que le permitan una mayor vida cultural, social y del hogar.

De esta forma, la seguridad social nace, como escribe Ramón Gómez,¹⁸ de las realidades sociales y de necesidades económicas del individuo, para traducirse en una entidad universal de protección biosocioeconómica; en un sistema general y homogéneo de prestaciones, de derecho público y supervisión estatal, que tiene como finalidad garantizar el derecho humano a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, mediante la redistribución de la riqueza, especialmente dirigida a corregir supuestos de infortunio.¹⁹ Las ideas anteriores se identifican con el concepto contenido en el art. 2 de la *Ley del Seguro Social* (LSS):

Artículo 2. La Seguridad Social tiene por finalidad garantizar el derecho humano a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo...

La seguridad social se constituye como garantía del derecho humano tanto a la salud como a la obtención de los medios y elementos que permitan el mayor bienestar. La garantía se expresa por medio de:

- Asistencia médica.
- Protección a los medios de subsistencia.
- Servicios sociales.

El objeto de la seguridad social es alcanzar el bienestar individual y colectivo mediante las normas y los principios que regulen los sistemas

16 Miguel García Cruz, *La seguridad social*, México, 1951, pp. 30 y 33.

17 Moisés Poblete Troncoso, *El derecho del trabajo y la seguridad social en Chile*, Editorial Jurídica de Chile. Santiago de Chile, 1949, p. 10.

18 Ramón Gómez, *Convivencias Interamericanas de Reciprocidad de Prestaciones de Seguridad Social. Contribución a la Tercera Reunión de la Conferencia Internacional de Seguridad Social*, México, 1951, p. 9.

19 Eduardo Macías Santos *et al.*, *El sistema de pensiones en México dentro del contexto internacional*, Themis, México, 1993, p. 1.

e instituciones de protección integral, en función de la solidaridad social. Para el logro de su objetivo, como afirma José González Gales:

La Seguridad Social emplea los mismos métodos del Seguro, pero su campo de acción es mucho más vasto. La enfermedad, el accidente, la invalidez, la vejez, la muerte, siguen mereciendo su vigilante atención. Pero su vida es y debe ser, ante todo y sobre todo, salud, trabajo, alegría, cultivo de la inteligencia, convivencia y amor. Y la Seguridad Social se empeña en llevar, hasta donde sea posible, todo eso a cada hogar. Por ello, sin descuidar a los enfermos, trata, en primer término, de prevenir la enfermedad: antes que a fundar orfanatos, hospitales y asilos, tiende a dar a los propios padres los medios de sacar adelante a sus hijos, dentro del hogar, haciendo llegar a él, el aseo, la higiene, la abundancia; en suma, las comodidades elementales que contribuyen a mantener la salud física y moral. Y a la concesión de subsidios a los parados que, por supuesto no niega, antepone la obtención de trabajo para todo el mundo.²⁰

En esta amplia acepción, como afirma Francisco José Martone, la seguridad social:

... es sinónimo de bienestar, de salud, de ocupación adecuada y segura; de amparo contra todos los infortunios y previsión. Es lucha contra la miseria y la desocupación. En fin, es la elevación de la personalidad humana en todo su complejo psicofísico, amparando a todos los riesgos fundamentales: pérdida de salud, pérdida de capacidad de trabajo (enfermedad, vejez, accidente), pérdida del salario (paro forzoso, invalidez); procurando proteger la integridad físicoorgánica de los hombres, conservándola o recuperándola, cuando se ha perdido; manteniendo en lo posible la capacidad de ganancia.²¹

Con base en lo anterior, podemos afirmar que:

La Seguridad Social es el conjunto de instituciones, principios, normas y disposiciones que protege a todas las personas contra cualquier contingencia que pudieran sufrir y las previene, a fin de permitir su bienestar mediante la superación de aspectos psicofísico, moral, económico, social y cultural.

20 José González Gales, *Previsión social*, Academia de Ciencias Económicas, Ediciones Especiales, núm. 11, Losada, Buenos Aires, 1964, p. 119.

21 Francisco José Martone, *Seguro social obligatorio*, Buenos Aires, 1951, p. 17.

El tratadista Ángel Guillermo Ruiz Moreno reconoce que:

... ante las confusiones que todo esto provoca –pues pareciera a veces que no hablamos el mismo lenguaje o que abordamos tópicos distintos–, para allanar dificultades y con el objetivo específico de unificar criterios en esta materia de tanta trascendencia nacional y mundial, la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT), ha ofrecido al mundo entero en su publicación “Seguridad Social: Guía de educación obrera”, la siguiente definición: “... definiremos la ‘seguridad social’ como la protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales que de no ser así ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte; y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos”.²²

Esta transcripción confirma lo señalado en torno a la seguridad social al tener por objeto la protección a la sociedad, mediante las acciones de política pública. Como veremos, las disposiciones legales en nuestro país alejan esa aspiración.

La seguridad social y el seguro social están indisolublemente unidos. Como afirma Máximo Daniel Monzón, “el seguro social constituye una etapa legislativa y doctrinaria que supera al Derecho del Trabajo y alcanza su máxima expresión en la seguridad social”.²³ O como señala Boris Acharan Balv, la seguridad social es “el mecanismo destinado a corregir por medio del Seguro Social, la desigual distribución de la riqueza para asegurar la cobertura de los riesgos a que todos los componentes del grupo social se encuentran expuestos”.²⁴ En este sentido, las leyes del Seguro Social de 1973 y la de 1997 determinan en su art. 4:

Artículo 4. El Seguro Social es el instrumento básico de la Seguridad Social, establecido como un servicio público de carácter nacional en los términos de esta ley, sin perjuicio de los sistemas instituidos por otros ordenamientos.

Es evidente que el seguro social va conformando un sistema consecuente con la estadística, donde se precisan los elementos esenciales. Mediante la

22 Ángel Guillermo Ruiz Moreno, *Nuevo Derecho de la seguridad social*, Porrúa, México, 1997, p. 42.

23 Máximo Daniel Monzón, “El seguro social moderno”, en *Revista del Instituto Nacional de Previsión Social*, núm. 3, diciembre de 1946, p. 49.

24 Boris Acharan Balv, *La evolución de la seguridad social*, vol. II de *Memorias de Derecho del Trabajo*, Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 1950, p. 272.

legislación se crea un instituto obligado, facultado para el cobro de cuotas cuyo efecto es garantizar la protección a grupos sociales determinados, que son, en primer lugar, los trabajadores y sus familiares, a quienes otorga los servicios médicos y en dinero.

De lo anterior, podemos concluir:

1. El objeto de la actividad humana es disminuir elementos de inseguridad. La vida en sociedad sólo puede llevarse a cabo si contamos con los elementos indispensables que permitan la atención a las necesidades mínimas y los instrumentos para mantener y acrecentar los niveles de existencia.
2. La seguridad social tiene la pretensión de ser una disciplina jurídica y, por tanto, integrar una disciplina autónoma, para proteger a todas las personas frente a cualquier adversidad y permitir que el ser humano lleve a cabo los objetivos sin mayor límite que el derecho de los demás.
3. La institución jurídica creada en Alemania a fines del siglo pasado da origen de manera concreta a los seguros sociales, que toman la experiencia de los seguros privados para conformar sistemas de protección. El constituyente de 1916 en México determina la creación de cajas de seguros populares, y la reforma de 1929 reconoce el interés público en la conformación de la LSS.
4. El seguro social como conocimiento ordenado, sistematizado, permite la formulación de principios; sus normas jurídicas dan lugar a instituciones de Derecho; así es como conforma su autonomía, con claro y limitado ámbito de aplicación.

El seguro social cuenta con un programa técnico elaborado con base en estudios actuariales y económicos, donde toma en cuenta los aspectos siguientes:

- Una colectividad de cotizantes (patrones, asegurados).
- El monto de las aportaciones.
- La precisión de los derechohabientes, destinatarios de las prestaciones (asegurados, pensionados, familiares, dependientes).
- La protección contra determinadas contingencias que ponen en peligro los ingresos y la salud.
- La conformación de instituciones públicas que lleven a cabo la administración con base en la estadística para hacer efectivas las cuotas y las prestaciones.

El derecho del seguro social lo defino como:

El conjunto de normas e instituciones jurídicas que se propone la protección de los grupos sociales que limitadamente se establecen en ley, frente a la ocurrencia de ciertas contingencias previamente determinadas, que afecten su situación económica o su equilibrio psicobiológico.

Fundamentos del seguro social

El estudio del seguro social comprende dos grandes campos de conocimiento:

- Las finanzas
 - Los grupos sociales
1. Mediante las *finanzas* importa captar recursos y otorgar prestaciones, de tal suerte que los ingresos deben ser suficientes para:
 - a) Atender las contingencias tuteladas, mediante prestaciones.
 - b) Los gastos de administración.
 - c) Las instalaciones necesarias.
 - d) Las reservas financieras que garanticen el cumplimiento de sus objetivos.

Los recursos económicos sólo pueden obtenerse de aquellos lugares que cuentan con desarrollo económico estable, para generar ingresos permanentes.

2. Los *grupos sociales* deben reunir ciertas características, conforme la naturaleza del seguro social:
 - a) Interés de la sociedad en su atención.
 - b) Capacidad económica generada mediante ingresos permanentes.
 - c) Condiciones similares para atender la uniformidad del seguro social.

Por su parte, los organismos administradores que manejan los fondos que son propiedad de los derechohabientes deben estar regulados por principios de:

- Transparencia
- Unidad
- Simplicidad
- Modernidad

Para el cumplimiento de sus fines, el seguro social debe apoyarse, en mayor o menor medida, en disciplinas que le son conexas. En forma somera, me referiré a las más importantes:

- La *economía* permite, mediante la aplicación de sus principios, el crecimiento horizontal sin descuidar aspectos de calidad, productividad, mercado de los insumos necesarios, así como da las bases para estimar los ingresos y los gastos que pueden efectuarse; considera el desarrollo regional y aprecia los estímulos adecuados.
- La *estadística* confiere bases confiables para la operatividad; los índices de frecuencia y de gravedad son la base para estimar costos y prestaciones.
- La *actuaría* da solidez y certeza, pues por la dinámica de la ley y de las instituciones, se requiere de una valuación permanente que haga factible determinar bases financieras, como condición para determinar avances, desviaciones y retrocesos.
- El análisis de las comunidades humanas, con sus elementos integradores compete a la *sociología*. El estudio de los grupos integrantes de una comunidad hace posible respetar sus intereses, formas de conducta y estilos de vida.

Los principios del seguro social requieren de homologación de las normas legales, lo que no puede lograrse mientras se carezca de una disposición conceptual que ubique lo establecido en el art. 123 constitucional, en el Apartado A, en las fraccs. XII, XIV y XXIX, y en el Apartado B, en las fraccs. XI, XIII, XIII bis y XIV, así como diversos sistemas que parten desde leyes de naturaleza diversa hasta contratos colectivos de trabajo.

El seguro social debe ser una unidad armónica, en la que sus elementos se entrelacen para integrar un sistema; sin embargo, las distinciones entre los diversos grupos de población a los que protege impide su concreción: trabajadores, con sus matices; servidores públicos, los que se contemplan en el Poder Judicial, las instituciones públicas y privadas de crédito y hacienda, y los integrantes de las Fuerzas Armadas. Esta diversidad contempla las circunscripciones territoriales, Federación, estados o municipios, así como las contingencias y condiciones para el otorgamiento de los servicios.

Los aspectos que el seguro social debe atender conllevan a la adopción de elementos similares. No es válido estimar que en razón a los grupos que se tutelan, por la naturaleza jurídica de la institución o por cualquier otra razón, los principios reguladores y los conceptos sean diversos. La naturaleza jurídica del seguro social debía ser la misma, tratándose del Apartado A, del Apartado B del art. 123 constitucional, de los militares, de los institutos estatales o municipales, de los contratos colectivos de trabajo o de determinaciones que otorguen beneficios diversos.

Contar con un sinnúmero de disposiciones diversas entre sí ha dado lugar a conformar sistemas complejos, alejados unos de otros. Para algunos autores, las prestaciones médicas son atendidas por seguros privados de gastos médicos mayores, mediante pensiones que van del último ingreso y se incrementan en forma dinámica, algunas veces sin tomar en cuenta el tiempo de prestación de servicios; para la gran mayoría se requiere contar con una edad y tiempo de cotización, con cantidades que apenas alcanzan un salario mínimo.

La resistencia a unificar criterios y coordinar esfuerzos ha resultado demasiado costosa, lo cual se traduce en una reducción de los índices de eficiencia. El intercambio de recursos y experiencias amplía el criterio de solidaridad y propicia la complementación de servicio entre los organismos administradores.

Tan sólo en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) las disposiciones de la Ley de 1997, con sus continuas reformas de 2001, 2004, 2005 y 2006, han variado la filosofía. Lo mismo acontece con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Los ordenamientos legales dan un enfoque diverso al permitir, con la *Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro*, que la administración de los recursos de pensiones sean regulados por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) e invertidos y pagados por sociedades anónimas de capital variable, con intervención de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); con estas disposiciones, el Derecho Mercantil va desplazando al Derecho Social.

Elementos

A pesar de la complejidad y disparidad de los sistemas, a continuación trataré de presentar los elementos comunes al seguro social; para ello, parto de dos grandes rubros:

- Los sujetos que forman la población derechohabiente.
- Los organismos encargados de la administración.

De ahí surgen los tipos de seguros, la obligatoriedad y las cuotas. En nuestro país, los sujetos protegidos por las entidades públicas, encargadas de la prestación de los servicios son los siguientes:

Organismos	Sujetos
Instituto Mexicano del Seguro Social Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de las Fuerzas Armadas Mexicanas Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores Institutos de seguridad de los estados	Trabajadores, miembros de sociedades cooperativas, campesinos, no asalariados Servidores públicos de la Administración Pública Federal, Congreso de la Unión, Poder Judicial Federal Miembros del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada nacionales Trabajadores del Apartado A del art. 123 constitucional Servidores públicos de las entidades y los municipios

Sujetos

La población comprendida por los seguros sociales tiene a su favor derechos que puede reclamar ante los tribunales; el término genérico para distinguir es el de *derechohabiente*. Además, comprende a las personas que tienen el peso de cumplir la obligación de aportar: registrarse, inscribir, dar avisos de cambios de salario y de baja, y efectuar las retenciones y los pagos. Los derechohabientes comprenden tanto a los asegurados como a sus beneficiarios, que integran el núcleo familiar.

Sujetos obligados

La relación que mantienen las leyes de Seguro Social con los ordenamientos laborales imponen a los patrones las principales obligaciones de cotización. Las leyes del Seguro Social de 1973 y de 1977, en la fracc. II del art. 12, determinan que las cooperativas tienen las obligaciones que se consignan a los patrones. En una situación muy discutible, la Ley de 1977 confiere la facultad al Presidente de la República, en la fracc. III de este numeral, de emitir decretos para incorporar al régimen obligatorio a grupos de personas sin precisarlos.

Derechohabientes

Estos sujetos se caracterizan por generar derecho a través de tres aspectos jurídicos relevantes:

- Cotizan al seguro social por sí mismos y tienen a su favor las aportaciones de los sujetos obligados.
- Tienen las prestaciones que consigna la Ley.
- No están condicionados en el ejercicio de sus derechos, pero sí lo están para recibir las prestaciones.

Los derechohabientes son *asegurados y beneficiarios*; los primeros, generalmente, son los trabajadores, aun cuando con limitaciones comprende a los campesinos y a los no asalariados; los segundos integran en núcleo familiar a cónyuge, concubino(a), hijos y ascendientes.

Pensionados

Las personas que generan el derecho a pensión deben cumplir los periodos de espera, edad o cierta condición médica, así como en el caso de los comprendidos en la LSS y en la *Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado* (LISSSTE). Los fondos pensionarios se ubican en cuentas individuales –Administradora de Fondos para el Retiro (Afore) o PensionISSSTE– y el pago se confía a una aseguradora privada seleccionada por el pensionado sujeta a dos contratos mercantiles, de renta vitalicia y de sobrevivencia. Esta prestación es generalmente vitalicia, sujeta en nuestras leyes a modalidades, en caso de recuperación de la salud o de reingreso a una actividad laboral.

El monto de la pensión suele ser insuficiente para atender las necesidades mínimas de una persona; su cálculo se hace sobre bases de promedios de los últimos años cotizados y según el monto acumulado en la cuenta individual.

Solidariohabiente

Las leyes del Seguro Social de 1973 y de 1977 incluyen la solidariohabiencia, con prestaciones limitadas al aspecto médico: atención de consulta, farmacia y hospitalaria, para atender a zonas social y económicamente marginadas, que determine el Presidente de la República. Se instrumentaron programas de alcance nacional, hasta llegar a la cifra de atención de 11 millones de personas. Los costos se distribuyen entre aportaciones del Gobierno Federal y los recursos del IMSS determinados por la Asamblea General.

Los beneficiados por estos servicios contribuyen con aportaciones en efectivo o la realización de trabajos personales a favor de las comunidades; no

generan derechos a su favor, por lo que se trata más de un servicio de beneficencia, que corresponde a la Secretaría de Salud y compite con el llamado "Seguro Popular".

Regímenes de Seguro

En el art. 6 de la Ley de 1997 se reproduce el criterio de los ordenamientos anteriores y el seguro social comprende dos tipos de régimen: obligatorio y voluntario.

Seguro obligatorio

El seguro social se impone a la voluntad de los particulares. Es suficiente que una persona se encuentre en el supuesto de la disposición legal para que nazca la obligación, la cual involucra a terceras personas:

- Patrones, personas físicas y morales
- Cooperativas
- Asociaciones
- Uniones

En caso de incumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley, serán objeto de una sanción, independientemente de las responsabilidades que alguna contingencia pudiera depararles. Los sujetos no podrán separarse del sistema mientras subsista la causa que originó su inscripción. Los patrones —y quienes se encuentren en situación similar— deben registrarse, incorporar a sus trabajadores, pagar cuotas y retener las que correspondan a los asegurados.

Seguro voluntario

El seguro voluntario es la primera forma que surge en el mundo con los seguros privados; fue rechazada en la estructura de los seguros sociales. Por tanto, en el seguro social, esta figura sólo puede entenderse como de excepción, cuyo efecto limita o disminuye los beneficios que se otorgan a los asegurados.

Se limita en cuanto a los sujetos que protege y a los tiempos de protección; además de que reduce las ventajas del seguro obligatorio.

Este tipo de seguro permite:

- Captar ingresos adicionales mediante aportaciones diversas a las del régimen obligatorio.
- Facultar al Instituto administrador para incorporar a otros grupos sociales, ajenos a los trabajadores.

- Facilitar la atención a diversos grupos, de manera más flexible a la del régimen obligatorio.

No obstante, tiene los inconvenientes:

- Generalmente se incorporan las personas que requieren atención inmediata.
- Las cuotas resultan muy elevadas en relación con las aportaciones.
- Sólo por excepción generan derecho a una pensión.

Este seguro hace posible otorgar prestaciones a:

Grupos de no asalariados: vendedores, ambulantes, aseadores de calzado, taxistas, etcétera.

Campesinos: ejidatarios, colonos, comuneros, pequeños propietarios y trabajadores asalariados del campo.

Profesionales.

Estudiantes.

Patrones: personas físicas.

Sin embargo, no reciben las mismas prestaciones ni cotizan de igual manera, por lo que están en desventaja frente a los asegurados del régimen obligatorio. Los gastos médicos por su atención representan una carga que gravita a los sujetos obligados y los asegurados, sin contar con beneficios adecuados a su actividad económica.

Seguro facultativo

El seguro facultativo da al asegurado en el régimen obligatorio la posibilidad de incorporar al sistema del seguro social a familiares o personas que no tienen el carácter de beneficiarios, mediante convenios que al respecto celebren. Representa una facilidad para el asegurado, al poder inscribir a personas que dependen de él, con la facilidad de inscribirlos y poder darlos de baja, sin mayor trámite.

La LSS de 1997 sustituyó la figura del seguro facultativo por el seguro de salud para la familia.

Seguro adicional

Este tipo de seguro no tiene vida autónoma; depende del obligatorio o del voluntario. En la LSS se ha creado para facilitar el mejoramiento vertical, condicionado a la existencia de convenios obrero-patronales que incrementen prestaciones o disminuyan requisitos para su otorgamiento. Esta forma de

seguro, al estar vinculada con el seguro obligatorio o con el voluntario, guarda una condición de dependencia, de tal forma que la extinción del principal ocasiona la de éste.

<i>Ley del Seguro Social</i>	<i>Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado</i>
I. Riesgos de trabajo II. Enfermedad y maternidad III. Invalidez y vida IV. Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez V. Guarderías y prestaciones sociales	I. Riesgos de trabajo II. Enfermedad y maternidad III. Invalidez y vida IV. Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez V. Guarderías y prestaciones sociales

Seguros del Seguro Social

Insisto en que en México estamos cada vez más alejados de contar con una seguridad social y que, de acuerdo con las normas constitucionales, lo que tenemos son variados sistemas de seguros sociales. La LSS y la LISSSTE conforman, a su vez, seguros; en torno a ellos se determinan sujetos, cuotas, condiciones y prestaciones. En términos generales, los seguros responden a contingencias, sin que se avizore un mejor o un mayor servicio que atienda a las personas comprendidas con prestaciones prontas y efectivas.

Prestaciones

Las prestaciones son los beneficios a que tienen derecho los asegurados, pensionados o familiares, derivados de una contingencia que altere la salud, sus posibilidades de trabajo y los ingresos económicos, así como las pensiones que se deben por años cotizados o edad de los derechohabientes.

Una prestación debe ser otorgada adecuada y oportunamente. Es defecto grave de las instituciones negar un servicio o no brindarlo con la calidad o la celeridad que amerita. En este sentido, la atingencia en las instituciones es base de sustentación para su confiabilidad. Los derechohabientes pueden reclamar legalmente de las instituciones administradoras el cumplimiento de las obligaciones y el reconocimiento de derechos. Conviene que las leyes del Seguro Social contengan recursos para agilizar procedimientos de manera

clara, sencilla y efectiva. A este respecto, la LSS en sus arts. 294 y 295 consigna el recurso de inconformidad; la LISSSTE no establece recurso alguno.

A continuación nos referimos a los diversos tipos de prestaciones.

Prestaciones económicas

Tienen por objeto mantener la capacidad económica de la persona, en forma inmediata y acorde con los ingresos del asegurado en que se fundamenta la aportación.

Subsidio. Prestación más próxima que se otorga cuando ocurre una contingencia, enfermedad, accidente o maternidad. Está limitada a los asegurados del régimen obligatorio y sólo por convenio se otorga a los del régimen voluntario.

Ayudas. Prestaciones ocasionales, limitadas a personas o condiciones especiales. Las más importantes son la ayuda para gastos de matrimonio, ayuda para gastos de defunción y ayuda asistencial. No se pretende cubrir una necesidad sino atenuar los efectos de una contingencia.

Asignación. En la LSS se establece como la cantidad adicional que se otorga al pensionado por las personas que dependen económicamente de él, cónyuge, concubina, hijos y de manera excepcional ascendientes o una persona ajena a la familia cuando por razones médicas se justifique el cuidado que debe tener (ayuda asistencial).

Pensión. Constituye la prestación de máxima importancia, limitada a la cantidad acumulada en la cuenta individual.

Indemnización. Un término desafortunado que se emplea en el Seguro Social. Indemnizar es resarcir de un daño o perjuicio; el Seguro Social no repara daños, sino atiende contingencias. Sin embargo, en la práctica se limita a situaciones de excepción.

Finiquito. Prestación económica que se otorga en un solo pago, cuando termina la pensión de viudez o de orfandad.

Retiros programados. Forma determinada por el sujeto con derecho a pensión o sin él, que permite obtener el saldo acumulado en su cuenta individual.

Prestaciones médicas

Implican la atención integral de la salud del individuo, que puede alterarse a causa de un proceso más o menos lento, pero continuo, manifestado a través de una enfermedad o por una acción repentina externa como un accidente. Las causas, los orígenes y los responsables son secundarios, sin restarles importancia. Lo que preocupa en primer lugar es la salud, entendida en su integridad, como el mantenimiento del equilibrio, base del bienestar.

Las prestaciones más importantes son: asistencia médica (consulta, diagnóstico, curación, atención), quirúrgica, hospitalaria, farmacéutica, obstétrica, ginecológica y, en algunos casos, los aparatos de prótesis y ortopedia, además de procedimientos para la rehabilitación.

Prestaciones sociales

Las prestaciones sociales tienen un triple objetivo:

- Colaborar a la adopción de medidas preventivas para incrementar niveles de salud.
- Capacitar a la población para el trabajo, en forma especial a los derechohabientes.
- Fomentar la recreación sana de la comunidad, con base en la unidad familiar.

Solidaridad social

En la LSS los servicios de solidaridad social se reducen a proporcionar prestaciones médicas para los núcleos económicamente marginados. Las personas protegidas dan como contraprestación una cuota reducida, un pago en especie o un servicio a favor de la comunidad. Esta figura que se incluyó en la Ley de 1973 desapareció con el mal llamado “Seguro Popular”.

Organización

La administración de recursos de los seguros sociales debe establecerse como garantía de su correcto manejo. Ésta debe ser prudente, en cuanto lo requiere la eficaz atención a los derechohabientes. La honradez es fundamental, así como la conveniencia de crear servicios especializados no sólo desde el punto de vista médico, sino también en cálculos actuariales, programación, planeación, aplicación e interpretación de normas jurídicas, proposición de reformas, etcétera.

Una adecuada organización hace atractiva la intervención de los elementos que conforman la vida de la institución, obligados y asegurados fundamentalmente, sin olvidar las organizaciones que agrupan o representan a no asalariados, ejidatarios, pequeños propietarios y minusválidos.

La participación del Gobierno está determinada por el interés social. El Seguro Social debe fundamentarse legalmente para vincular bienes con servicios en la atención de contingencias.

La participación se motiva con:

- Una efectiva acción decisoria en los órganos de gobierno.
- El respeto a la determinación de las mayorías.
- La disminución de influencia del poder público, al grado de permitir que los funcionarios respondan a los intereses de la institución.
- Dejar en manos de las representaciones la dirección y vigilancia de las acciones.
- Mantener la participación económica de todos los grupos interesados sin dejar a un sector -el patronal- el principal cargo del pago de las cuotas.

La consolidación de la nueva estructura, que se inició a partir de las reformas de 1992 con el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), ha logrado su máxima expresión en las nuevas leyes, en vigor a partir del 1 de julio de 1997 y el 1 de abril de 2007. Debe tomarse en cuenta la doble intención de la reforma:

- Reforzar el ahorro interno, del que se hace depender el desarrollo económico.
- Dar capital fresco a las instituciones financieras privadas, bancos, seguros y casas de bolsa.

Estas intenciones han resultado lesivas para las garantías de los derechohabientes y el objeto de las instituciones.

Reformas de la reforma

El sistema de cuentas individuales instaurado por primera vez en la República de Chile (por Decreto 3, 100 de 1980) y en México, iniciado con la reforma de 1992 a la LSS, cuya culminación en ese ordenamiento se da con la Ley de 1997 y en 2007 con la LISSSTE, consiste básicamente, como veremos en el desarrollo de esta obra, en eliminar los principios de solidaridad y de reparto de los institutos oficiales de seguro social (IMMS e ISSSTE).

Segunda parte

Antecedentes

2 Conformación de derechos

Antigüedad

El ser humano vive bajo la amenaza ineluctable de la inseguridad. El temor une a las personas y las identifica, mediante el parentesco, como la primera organización social, controlada por los más ancianos, en lo que suele denominarse *gerontocracia*. En los albores de la humanidad, el mal se atribuía a los demonios, a quienes se debía expulsar; pero cuando el individuo era el poseso, había que exorcizarlo.

En *La Ilíada* se cuenta que los griegos mueren a causa de una enfermedad epidémica, la peste, representada por las flechas de Apolo. Y entonces había que hacer sacrificios a los dioses para volverlos propicios, ofrendarles víctimas expiatorias, humanas o animales. Eran muchas y portentosas las gracias que el hombre primitivo o el grupo tribal esperaba de los dioses, y terroríficos los daños a que estaban expuestos.

El hechicero deviene en sacerdote, en rey; el jefe carismático —que también actúa como el primitivo médico— está representado en Egipto por los *pastofers* y, entre los caldeos, por los *kakamin*, conjuradores y teósofos.

Por su parte, Grecia, al evolucionar el espíritu de su civilización, fue conducida por su propio genio a la “ruptura con el mito”, como en expresión elocuente dijera Jacobo Burckhardt, tanto que cuando se quería perder a un filósofo, por cualquier razón política, se iniciaba el proceso de asebia (impiedad, irreligiosidad). Conservamos como testimonios las acusaciones y condenas en contra de Anaxágoras, Pitágoras y Sócrates.

La medicina de los griegos no seguía el procedimiento mágico o la imposición del tabú. No se concebía a la enfermedad como obra de la maligna influencia de dioses o demonios; esto es, de seres sobrenaturales. Los griegos

fueron objetivando el mal y el sistema médico llegó a fundarse en la observación acumulada, en forma sistemática.

Herófilo, médico y filósofo, escribió con acierto: "la ciencia y el arte no tienen nada que enseñar; el ánimo es incapaz de esfuerzo, la riqueza inútil y la elocuencia ineficaz, si falta la salud". Sin embargo, según testimonios históricos, en aquella sociedad no se registran instituciones encaminadas a remediar los daños sociales y las eventualidades del ser individual.

Las clases superiores no llegan a sentir —aunque no estén necesariamente libres de los riesgos— el flagelo de la angustia del mañana; por el contrario, las clases serviles, asimiladas al trabajo dependiente, pueden sentirla pero no remediarla.

La solución utópica a los males sociales la imagina Platón en *La República*: un Estado es una integración de quienes tienen necesidades y de quienes aportan los medios de satisfacerlas. Si las necesidades elementales del hombre en la primera sociedad son el alimento, la habitación, el vestido y el calzado, se impondrá entonces la existencia de un agricultor, un albañil, un tejedor y un zapatero. En la cúspide del Estado platónico, los gobernantes serían escogidos de entre quienes demostraran mayores deseos de hacer sólo lo que redundará en bien común y de no tolerar algo contra sus intereses; deben ser, pues, los mejores individuos de la sociedad, porque mientras los reyes no sean filósofos o los filósofos reyes, nunca concluirán las miserias de las ciudades ni la raza humana será feliz.

Los guardianes, cuidadosamente seleccionados, serían dueños de provisiones y de una situación que no los distinguiría mucho de los veteranos; y así, acostumbrados a privaciones, comerían y vivirían en común como soldados en el campamento, ya que si poseyeran casas y tierras, o moneda, se convertirían en mayordomos y labradores y, en lugar de ser aliados de los ciudadanos, devendrían en sus enemigos, odiarían y serían odiados, conspirarían y serían atacados, con lo que pasarían su vida entre temores de los de fuera y de los de dentro; habría de llegar la hora de su ruina y la destrucción del Estado.

En su obra *Los sistemas socialistas*, Vilfredo Pareto califica de socialismo utópico esta concepción platónica. En realidad, filosófica y etimológicamente, es más socialista que el socialismo moderno, ya que, en esta utopía, la sociedad es el fin último al cual se subordina el individuo. El principio que informa el pensamiento de Platón, y en general de todos los utópicos, es satisfacer las necesidades humanas en la medida en que se presentan en su totalidad, contrario a lo que impone la realidad objetiva, donde la satisfacción de la necesidad se ve medida y limitada por las posibilidades.

En el Derecho Romano, el poder autocrático del *pater familiae* sobre las personas y los bienes de sus hijos fue decreciendo por medidas legales, como la de Caracalla, que prohibió la venta de los hijos, salvo en caso de extrema miseria. Adriano castigaba los abusos del derecho del padre a matar a sus hijos.

La teoría de la culpa aquiliana atribuye al patrón o empresario la compensación del riesgo profesional, aunque posteriormente aparezca el concepto de la responsabilidad objetiva del riesgo.

Con criterio protector, Antonino Pío reguló el ejercicio de la medicina al limitar el número de médicos que podrían ser nombrados por las ciudades, según el censo de habitantes, con goce de exención de cargas municipales.

No faltaron en Roma instituciones que, de manera directa o indirecta, organizaron la ayuda, mediante acciones sistemáticas, con objeto de mitigar los efectos de la inseguridad. Mommsen estima que los colegios romanos fueron, en cierto sentido, sociedades de socorros mutuos; J.P. Waltzing, por su parte, reduce esta actividad a los funerales y exequias, siendo la asistencia mutua general una excepción;¹ considera a las diaconías, en los albores de la nueva religión, como el primer testimonio de la sociedad de socorros mutuos en la historia. La sociedad de socorros mutuos tenía como propósito la práctica de la caridad. Una nueva moral, trascendente y religiosa, impulsa a la solidaridad humana, lo que obliga a proporcionar alimento y enterrar a los muertos pobres, proteger a los indigentes y huérfanos, y auxiliar a los ancianos.

Edad Media

La caída gradual de la influencia política de Roma en Occidente no implicó la total desaparición de las formas de la civilización romana, sino solamente su gradual empobrecimiento, que hubiera terminado en desaparición absoluta de no mediar la hegemonía de la Iglesia católica. El feudalismo fracasa en estructurar sistemas de protección general.

La ayuda al prójimo (concretamente, la ayuda al necesitado y al desvalido) se materializa en el ejercicio de la caridad, concepción y norma moral de tipo religioso, trascendente, desinteresada en lo terrenal y merecedora de una recompensa celestial. Iglesia, obispos y párrocos, conventos y monasterios, crean establecimientos para socorrer las necesidades humanas, escuelas para enseñar al ignorante, hospitales para la cura de los enfermos, casas de caridad destinadas al cuidado y la educación de los huérfanos, organizaciones para la asistencia domiciliaria de los necesitados y dolientes.

La beneficencia de tipo eclesiástico la organiza y presta directamente la jerarquía de la Iglesia o el monasterio, pero también el socorro es prestado por el seglar, señor o vasallo, artesano, grupo de individuos particulares, corporación o asociación laica.

¹ J.P. Waltzing, *Estudios históricos de las corporaciones profesionales entre los romanos*, t. 1, pp. 300-322.

En las organizaciones de caridad existen personas que prestan materialmente el servicio, y tanto las que lo sufragan con su dinero o con sus propiedades como las que lo organizan y dirigen, trabajan y se sacrifican sin la esperanza de premio en la vida terrenal; es la virtud la que mueve el amor al prójimo y el anhelo de recompensa en la "otra" vida. Quien recibe el beneficio, el asistido o socorrido, es conceptualmente un favorecido y nunca puede presentarse como el sujeto activo de un derecho.

En el medievo se imaginó y reguló considerar como titulares de los bienes adscritos en los hospitales o refugios a los enfermos mismos, a los pobres, a los leprosos, y en varios documentos encontramos estas donaciones *pauperius*, en virtud de las cuales se organizan corporativamente nombrando comisiones para administrar. En la mayoría de los casos, el hospital era donado a un santo; hacia el siglo XII, se refería a las órdenes religiosas.

En ciudades de origen germano aparecen las guildas, asociaciones de defensa y asistencia. Las comidas en común con participación de los pobres, propias de una fraternidad; la asistencia mutua en caso de enfermedades, la solidaridad defensiva de los cofrades ante agresiones, son sus normas típicas. Estas organizaciones se extendieron en Alemania, Dinamarca e Inglaterra; los estatutos más antiguos datan del siglo XI. Las cofradías de artesanos tuvieron su origen en Italia, en las organizaciones religiosas que fueron conocidas con el nombre de *Scholae*, que eran agrupaciones dedicadas a la misma actividad e identificados en el deseo de practicar colectivamente el culto. Desde 1271, las corporaciones de artesanos entregaban a los socios pobres y enfermos parte de sus rentas en forma de subsidios en lazareto.

Las órdenes mendicantes fundadas por San Francisco de Asís y San Benito, durante el mandato del papa Inocencio III, se dedicaban a atender a los menesterosos. Francisco, hijo del mercader de paños Pedro Bernardone, desposó con la pobreza. Se le revelaron las palabras del Evangelio: "Id y predicad que el Reino de los cielos se está acercando. Curad a los enfermos, resucitad a los muertos, limpiad a los leprosos y echad a los demonios, hacedlo de gracia, como de gracia lo habéis recibido. No llevéis oro, ni plata, ni cobre en los bolsillos. Ni dos túnicas ni zapatos, ni calzado. Pedid y se os dará." Los franciscanos no esperan al pobre, a quien llaman hermano; conviven con los miserables, dan el consejo y otorgan la ayuda.

Origen de los seguros privados

Las sociedades de capitales aparecieron en Roma con las sociedades arrendatarias de tributos y en la Edad Media con las empresas colonizadoras. La creación de las sociedades mercantiles responde en gran parte a la intuición de los riesgos. Los riesgos propiamente mercantiles se van repartiendo entre los socios; la tendencia es distribuir el riesgo total.

El seguro marítimo es la primera forma de seguros que aparece y de él nacen las demás aplicaciones. En 1309, en un decreto dictado por el Dux de Génova, se emplea por primera vez la palabra *aseguramentum*; en los libros de la casa de Francisco del Bene aparece un asiento que anota gastos por dos actas que se hicieron para la seguridad de unos fardos, y se registran también a favor de Lepo y Dosso de Bardi 505 florines y nueve sueldos por el riesgo de unos paños que habían sido transportados a Francia y a Florencia; asimismo, en el Archivo de Génova se conservan contratos que dan idea del desarrollo del seguro marítimo.

Según Benítez de Lugo, la primera norma jurídica escrita, obligatoria, que regula cabalmente los riesgos, está contenida en los capítulos de las Cortes de Tortosa en 1412, convocados por el rey Fernando, en los cuales se establece y regula el seguro contra la huida de esclavos. Son características del aseguramiento la obligatoriedad en cuanto a los esclavos mayores de 10 años, con valor fijado por su dueño en el momento de iniciarse el seguro por inscripción en el registro, pagando por los asegurados una prima anual por semestres, proporcional a la estimación registrada. En caso de siniestro; esto es, si ocurría el riesgo previsto de la fuga del esclavo y no se le restituía al poder de su dueño en el plazo de dos meses, el seguro pagaba al propietario el importe del valor asegurado. Es el primer ejemplo de un seguro a prima fija, que se aplicará inmediatamente al seguro de mar.

En 1435, un edicto de los magistrados de Barcelona precisa y regula el seguro de mar, siendo obvio que, conocida la formación consuetudinaria del derecho marítimo, recogía los usos y las costumbres más antiguos, normativos del seguro en aquel puerto; la forma de seguro regulada en este Edicto es de prima fija. Esta disposición fue incluida en el libro *Consulado del Mar* (1494), con las rúbricas de las buenas costumbres y los buenos usos del mar.

Podríamos citar sobre esta materia las Ordenanzas emitidas por el Gran Consejo de Venecia en 1468; los Estatutos de Florencia de 1522, en los que figuran formularios para la redacción de pólizas y los de Génova de 1588.

En el seguro marítimo se define el concepto de riesgo y se inicia la técnica del aseguramiento contra el mismo; con el seguro contra las pérdidas por huida de esclavos, como hemos visto, aparecen el aseguramiento por prima fija, que los propios catalanes inventaron con la técnica del seguro marítimo. Luego, irá extendiéndose el aseguramiento y su técnica será aplicada a otras clases de riesgo.

La ciudad de Burgos sigue a Barcelona en la iniciativa de legislación sobre el seguro. Los comerciantes obtuvieron en 1494 la jurisdicción consular para la materia mercantil, publicando en el Consulado varias regulaciones confirmadas por don Carlos y doña Juana en pragmática del 18 de septiembre de 1538, con el título "Ordenanzas hechas por el Prior y Cónsules de la Universidad de la Contratación de este M.N.I.M.L., ciudad de Burgos, por sus magistrados confirmados, para los negocios y cosas tocantes en su jurisdicción y juzgado".

Posteriormente, en 1554 se aprobaron las ordenanzas para el Prior y Cónsules y mercaderes de la ciudad de Sevilla. Este Consulado publicó en 1555 las ordenanzas para los seguros marítimos. Felipe II dictó unas ordenanzas especiales para la casa de Contratación en Sevilla, en las que trata de los seguros en los párrafos 161 y 162, prescribiéndose para evitar los muchos abusos que se cometían y asegurando algunas personas su hacienda, en secreto o en confianza, con diversos aseguradores que cobran después dos o tres veces el valor de lo que se perdió. En adelante, todo seguro será público y nulo si no cumple con este requisito; en el caso de navíos, no pueden asegurarse por más de dos terceras partes de su valor, corriendo el asegurado el riesgo de la diferencia. De ello se infiere que el seguro se había extendido a riesgos distintos de los marítimos. El Cuaderno de Alcabalas, dispuesto por los Reyes Católicos en 1491, Ley 135, mandaba que los aseguradores no recibieran más de la vigésima parte de la libranza, al llevar estas rentas de un lugar a otro.

En los Países Bajos, en 1594, se publicaron unas ordenanzas estudiadas previamente por una comisión nombrada al efecto, en virtud de reclamaciones y quejas debido a la frecuencia y el aumento de los siniestros marítimos, encaminadas a poner límite a los fraudes, cuyas anomalías estudiaba la comisión, y que podían ser originadas en el mayor valor con que se hacían los seguros de navíos y mercancías. Tienen gran importancia las Ordenanzas Amberes, promulgadas por Felipe II en Bruselas, en las que se nulificaban todos los contratos de seguros contrarios a las normas y se asentaba que los seguros sobre mercaderías serían según costumbre de la Bolsa de Amberes y con arreglo a la póliza, cuyo modelo establecía; además, señalaba que una vez firmado el contrato, estaba prohibido el cambio de ruta, fijando las reglas que habrían de seguirse para valorar los efectos del seguro del casco del buque, de los aparejos y de las mercaderías. También de esta época son de interés las Ordenanzas de los Cónsules de España, en Brujas.

Las ordenanzas de 1570 dictadas por Felipe II y publicadas por el duque de Alba, gobernador de los Países Bajos, previeron la intervención del Estado en los seguros y se nombró comisario a Diego González de Gante. Estas ordenanzas prohibían el seguro sobre la vida, pero hay indicios de que se practicaba.

En el siglo XVI Tomás Moro, humanista, miembro de la corte y consejero de Enrique VIII, escribió *Utopía*, texto en el que da cuenta sobre los males sociales y denuncia la miseria del pueblo, al tiempo que se producía un cambio en las condiciones económicas: las industrias de tejidos de lana se habían desarrollado, especialmente en Flandes.

Harry Elmer Barnes y Howard Becker² han resumido lo esencial de la teoría de Moro:

2 Harry Elmer Barnes y Howard Becker, *Historia del pensamiento social*, t. 1, Fondo de Cultura Económica, México, p. 322.

1. Abolición de la propiedad privada.
2. División del trabajo según método de sentido común y general adaptabilidad.
3. Conservación de la vida familiar como unidad de la organización social, idea con la que difiere notoriamente de Platón.
4. Abolición del dinero como "raíz de todo mal".
5. Reducción de la jornada de trabajo a seis horas, tomándose las medidas adecuadas para asegurar el recreo, la educación y la protección contra lo que Moro consideraba como vicio.
6. Libertad de creencias religiosas.
7. Gobierno de forma monárquica, con elección del monarca por el pueblo, mediante procedimiento indirecto.

Claro que la *Utopía* de Moro, como todas las concepciones análogas, anteriormente *La República* de Platón, y en la misma época, *La Nueva Atlántida*, de Francis Bacon, y *La Ciudad del Sol*, de Tommaso Campanella, no ofrecen soluciones pragmáticas ante la inseguridad social. Si variando la estructura social y, como corresponde al gobierno, los daños desaparecen, no tiene sentido que se ofrezcan medios singulares para combatir dichos daños.

El gobierno inglés hubo de asumir la función que había sido cumplida en parte por las instituciones de caridad. En 1531, Enrique VIII promulgó un estatuto especial donde disponía que alcaldes, jueces y otros funcionarios locales practicasen una búsqueda e investigación de indigentes, de personas ancianas o incapaces para el trabajo, quienes debían subsistir mediante la limosna. Es entonces cuando se consigna un registro especial con el fin de otorgar a las personas afectadas una cédula de identidad con autorización para solicitar caridad. Eduardo II reanuda la legislación en 1552, siguiendo la línea trazada por Enrique VIII, hasta la *Ley de Pobres* de 1561 del periodo isabelino, que permanecería vigente por espacio de 300 años.

Con la *Real Cédula* de 1511 –que se hiciera extensiva a los mercaderes de la Villa de Bilbao– nacieron las ordenanzas de Bilbao, que regirían en España, casi hasta la publicación del *Código de Comercio* de 1829. En el capítulo 22 se regulan los seguros y se define el contrato; se tipifican las pólizas, con dos formularios, uno para mercaderías y otro para los navíos; por primera vez (número XLII) se autoriza y reglamenta el reaseguro; se dan normas para la prescripción de las acciones que dimanaron de la póliza y, en último término, se autoriza el seguro para navegantes y viajeros, en previsión de caer cautivos, sin derecho para los sucesores de cobrarlos en caso de fallecimiento.

Carlos I y Felipe II en España dictaron leyes sobre mendicidad; las cortes de Valladolid de 1555 solicitaron al rey que las leyes sobre mendigos crearan en todos los pueblos un Padre de Pobres, encargado de buscar una ocupación remunerada a los que careciesen de ella.

El padre Mariana sostiene que la autoridad civil debe intervenir primero en la distribución de la riqueza natural; segundo, en la producción de los mantenimientos mediante la labor del suelo, y, tercero, en la subsistencia de los desvalidos y menesterosos. El Estado debe asistir a los humildes en los casos de riesgo; es propio de la piedad y de la justicia amparar a la miseria de los desvalidos y los indigentes, criar a los huérfanos, auxiliar a los necesitados. Éste es el principal y más sublime oficio del soberano.

Cristóbal Pérez de Herrera destaca la necesidad de proteger a la niñez abandonada mediante su colocación en familias o en asilos; la reforma de las mujeres vagabundas y delincuentes; la invalidez de los militares con un sistema de pensiones a cargo del Estado. Cada necesidad demanda su alivio; todo problema apremia y requiere solución. Propone que se funde en Madrid una casa "en donde acudan y se reciba a todos los inútiles y estropeados en la guerra, o que por vejez no puedan estar en el servicio".³

A partir de la segunda mitad del siglo XVII se organizan, regulan y favorecen las cajas de pensiones y los seguros privados. Por medio de ambas instituciones los individuos tienen la posibilidad de poner en práctica su propia previsión, de forma directa o mediante instituciones privadas. En Londres, después de una larga experiencia a través de las estipulaciones de la Royal Exchange, y de los contactos cotidianos entre ellos, en el café de Pascua Rosse di Ragusa —en Saint Michael's Alley Cornhill—, los aseguradores iniciaron en 1771 el famoso organismo de Lloyd's, fundación promovida mediante suscripción de un grupo de aseguradores, corredores o comerciantes. De esta sede, en 1774 la corporación fue trasladada al Palacio Real Exchange, con la idea de superar la crisis causada por las graves pérdidas marítimas surgidas como consecuencia de las guerras anteriores y contemporáneas al periodo napoleónico, las cuales produjeron enorme alza de primas.

Una ley emitida en 1871 reconocía a Lloyd's personalidad jurídica como corporación. Lloyd's no es propiamente una sociedad de seguros sino de aseguradores, cuyos miembros son individuos responsables ilimitadamente o sociedades afiliadas. Se trata de una especie de bolsa, en cuyo seno el comité administra los intereses comunes de sus afiliados, aseguradores o no. Esta corporación recoge las fianzas para garantía de los asegurados en casos de insolvencia del asegurador y, por otra parte, cumple las funciones de las empresas de seguros, especialmente en lo que respecta a informaciones y preparación técnica.

El seguro de vida tenía mala fama; sin embargo, se siente su necesidad y ello ofrece coyuntura para la creación de montepíos que otorgan pensiones de supervivencia. El seguro se institucionaliza finalmente en Inglaterra, en las postrimerías del siglo XVIII.

3 Alberto Briceño Ruiz, *Derecho mexicano de los seguros sociales*, Harla, México, 1987, p. 58.

Primeras teorías

Ley de distribución de probabilidades

El seguro de vida demanda la perfección del cálculo de probabilidades. Blas Pascal formula la primera exposición del principio de recurrencia, en el folleto que titula *Triángulo Aritmético*, publicado en 1654.

John H. Megee ofrece el siguiente resumen de esta teoría:

La teoría desarrollada ha demostrado ser, en el campo del seguro, un instrumento de incalculable importancia. La medida de las probabilidades se expresa algebraicamente por medio de un quebrado cuyo numerador es el número de posibilidades favorables (o desfavorables), y cuyo denominador representa todos los casos posibles. Usando la rotación siguiente, en la que representa el número de formas como un hecho puede ocurrir, a las formas que deben ser consideradas como favorables y b como desfavorables, entonces, la probabilidad de p resultado favorable, puede expresarse como $p = a$ y la probabilidad del resultado desfavorable como $p' = b$. Un ejemplo sencillo de esta fórmula puede encontrarse en el experimento de echar una moneda a cara o cruz. La probabilidad de que caiga de cara se encuentra utilizando el número de posibles casualidades favorables como numerador del quebrado y el número total de casualidades como denominador, con lo que tendremos la probabilidad de obtener cara, representada por $1/2$. La probabilidad de que salga cruz es la misma. El valor de la teoría de las probabilidades para la ciencia del seguro, como fácilmente se comprende, depende del cuidado con que se reúnan los datos estadísticos.⁴

Al superar las fórmulas combinatorias, Pascal resolvió un gran número de problemas de cálculo de probabilidades; una de las fórmulas que descubrió es conocida con el nombre de *Ley de distribución de probabilidad*, análoga a la *Ley fundamental de probabilidades* de Isaac Newton.

La estadística se inicia en Londres en 1562, cuando se recogen datos en forma masiva con motivo del terror de la Peste Negra. En 1671 el gobierno de los Países Bajos crea un sistema de rentas vitalicias. John Dewitt presenta un informe en el que aplica la doctrina de las probabilidades en relación con las rentas. John Graunt analizó las listas de mortalidad en un trabajo editado en 1661. La primera tabla que al respecto se formuló se debe a Edmund G. Halley.

En la ciudad de Breslau, en Silesia, se habían llevado registros bastante completos que contenían, entre otros datos, la edad en la que había muerto cada persona. Esto era precisamente lo que necesitaban los hombres de ciencia para el estudio de las expectativas de vida. Se obtuvieron copias de estos registros

4 John H. Megee, *Seguros generales*, t. 1, pp. 135 y 136.

y Halley, reputado como el más brillante matemático y astrónomo de su época, fue designado para trabajar con estos materiales; el resultado de sus trabajos se difundió en 1693 en documento sometido a la Royal Society: "Un cálculo de los grados de la mortalidad del género humano, sacado de las curiosas tablas de nacimiento y funerales de la ciudad de Breslau, primer intento para averiguar el precio de las anualidades sobre vidas". Posteriormente se formularon otras tablas, como las de Kerseboom (1738), Johann Peter Süssmilch (1741) y Antoine Desparcieux (1746), referidas a la mortalidad en los conventos de París y a las experiencias sobre las agrupaciones de sociedades tontinas.⁵

Ley de los grandes números

La experiencia sobre la acumulación de datos estadísticos muestra que ciertos acontecimientos surgidos aparentemente de la casualidad, por ser considerados como ejemplos aislados acaecen, no obstante, con una regularidad sorprendente al ser observados en su conjunto. La regularidad del hecho aumenta a medida que los casos observados se incrementan. La posibilidad de predecir un hecho particular se desvanece y origina la probabilidad cuando se observa una serie sucesiva de posibilidades. En la aplicación concreta sobre la estadística de mortalidad de un país, cabe destacar las tendencias constantes, que no aparecen si la observación se limita a una determinada familia o grupo concreto de individuos.

La teoría y práctica del seguro están basadas fundamentalmente en la obra de Jacob Bernoulli, *Ars Conjectandi*, publicada en 1711, en la que además de tratar sistemáticamente la teoría de las probabilidades, se comprueba por primera vez la ley de los grandes números, que hace posible la aplicación del cálculo de probabilidades a los fenómenos empíricos, estimados como causales, tendiendo de esta manera un puente entre la teoría y la práctica, que logra la aplicación de este cálculo al seguro privado y social.

Otra obra fundamental que estudia la aplicación del cálculo de probabilidades al seguro es la del matemático francés Pierre-Simon Laplace, *La teoría de la probabilidad*, donde formula importantes aplicaciones a problemas del seguro.

En la ley de los grandes números, el valor de la prima es inversamente proporcional al número de los riesgos asegurados. La contribución puede, al ser calculada, comprender el riesgo, los gastos generales y la utilidad.

La cobertura es sólida y cada vez más segura al aplicar esta técnica que perfeccionan las empresas de seguros en el seguro marítimo, de transportes, incendios y, en general, en el de daños. El costo es la base del precio de venta,

5 De Lorenzo Tonti, banquero italiano del siglo XVII. Las sociedades integraban un fondo para repartirlo con sus intereses en cierta época, sólo entre los asociados sobrevivientes y que seguían perteneciendo a la asociación.

que debe ser suficiente para cubrir íntegramente a aquél y permitir además una utilidad, por lo que la cobertura constituiría un factor del costo recuperable por medio del precio o, lo que es lo mismo en última instancia, pagada por el consumidor: de esta manera, el seguro grava el consumo.

Seguro de vida

El seguro de vida con capitales pagaderos a la muerte del asegurado comenzó en 1762, organizado por la Equitable Society for Assurance on Lives and Survivorship. Por primera vez se fijaron primas diferenciadas según la edad, fundadas en la tabla de mortalidad de Prece. Las primas iniciales resultaban tan altas que tuvieron que ser revisadas y rebajadas en tres ocasiones. En 1827, este ejemplo inglés se extendió por el continente europeo gracias al Banco de Seguros de Gotha. Las primeras tablas para el seguro de enfermedad se dedujeron de las experiencias de las Friendly Societies inglesas, en 1824, y las tablas de invalidez de las experiencias de las cajas de los mineros y ferroviarios.

El seguro privado se generaliza, tanto por el de daño en las cosas como a personas. La vida económica y social del mundo sufre una honda transformación que se refleja en los movimientos sociales de 1848, en los adelantos del socialismo como fuerza política y en la llamada revolución industrial. Simboliza los juicios de la nueva era, la alianza entre el capital industrial y el científico, como aconteciera en la sociedad formada en 1775 por Mateo Boulton y James Watt.

Tomas Chalmers y Octavia Hill distinguen los casos de quienes necesitan ayuda y aquellos en que ésta era demandada. Chalmers cree que el costo de la asistencia se reducirá, tanto si se financia mediante impuestos como si se sufragaba por aportaciones voluntarias, obligando a la investigación concreta al estimar su resultado.

Hill subrayó la importancia de la investigación con el propósito de ahondar en las causas profundas de la carencia de recursos y proyectar los medios de evitarla. Estimó estos remedios más eficientes que las dádivas no amables, con la pretensión de comprender la necesidad de la persona, a efecto de proporcionarle un auxilio eficaz. En Inglaterra se creó la Fabian Society, inspirada en un socialismo humanista.

El socialismo de Estado, también conocido como socialismo de cátedra, fue apoyado por destacados profesores como Schaffle, Wagner y Schmoller en Alemania; por Bougle y Gide en Francia, Webb y Hobson en Inglaterra, y por Small y Patten en Estados Unidos de América. De aquí que se infiera cuán profundamente había llegado a penetrar en la conciencia de las personas la urgencia de hallar remedios y ponerlos en práctica, sobre todo a favor de los más débiles y por ello los más afligidos, que con dramático acento ponía de manifiesto la relevancia crítica que del estado liberal formularan los socialistas de todos los matices.

3

Antecedentes del seguro social

Cualquier intento de sintetizar la evolución histórica de una institución jurídica es siempre incompleta, por lo que debe tomarse con las debidas reservas. Desde luego, estimo que debe pugnarse por establecer, conforme a las características de cada país, la seguridad social integral, con el objeto de proteger a las personas desde su nacimiento frente a los embates o infortunios que la vida presenta. Sin embargo, nuestro país y los de América Latina se encuentran en la fase de los seguros sociales, con sistemas donde la privatización se ha fortalecido y las legislaciones se han modificado para dar entrada a sociedades anónimas. Al confiar la administración e inversión de los recursos pensionarios a estas sociedades, el Derecho Mercantil, parte del Derecho Privado, ha desplazado al Derecho Social y las garantías de los derechohabientes están sujetas a contratos por adhesión que elaboran las financieras, reguladas por disposiciones que atienen al mercado de valores. A continuación presento la evolución de los seguros sociales, para observar que mientras que en Europa se avanzó en la conformación de la seguridad social, nuestros pueblos retroceden o se estacan en los seguros sociales.

El seguro social en Alemania

Los avances del capitalismo trajeron consigo el invento de las máquinas movidas por fuerzas físicas: las de vapor primero, y más tarde las de electricidad y de motores de combustión interna; pero al mismo tiempo su uso desplazaba a una buena parte de quienes en calidad de oficiales y aprendices laboraban en los antiguos talleres. Quienes lograban ingresar a las fábricas carecían de

derechos derivados de la inestabilidad en el empleo, con míseros salarios determinados a conveniencia del patrón. Numerosos grupos se aglutinaban en las puertas de los centros laborales a la espera de alguna oportunidad para trabajar. Aumentó el desempleo y los desocupados, lanzados a la indigencia, vieron en la máquina el enemigo a vencer. El descontento social, por la angustia de las familias, fue creciente. Los factores negativos debían modificarse; sin embargo, los detentadores del poder económico se resistían a los cambios, y con ello los trabajadores quedaban sometidos a las exigencias de los poderosos.

La conjunción de los factores económicos negativos en los países industrializados, unido a la miopía de los gobernantes, ocasionaron la multiplicación de movimientos sociales en contra de los detentadores del poder público y de las fuerzas económicas. Una vez más, como había sucedido en otras épocas, desde la sublevación de la gleba o el retiro de los plebeyos al monte Aventino en Roma, se hizo patente la lucha de clases en los movimientos carlistas de Inglaterra; más aún, no hubo país de Europa exento de una creciente inconformidad. El liberalismo que proclamó la igualdad y la libertad no culminó en la fraternidad. Fracasaban las ideas de los enciclopedistas y la utopía de Tomás Moro, lo que conducía a la ruptura del contrato social que había proclamado Jean-Jacques Rousseau. A la fuerza de los estados modernos se unía el poder moral y económico de la Iglesia de Roma, que mediante la sumisión proclamaba el reino de los cielos para los pobres. El crecimiento de las ciudades fortaleció a los reinos, los más fuertes buscaban crear imperios y crecer económicamente con base en la explotación de los pueblos.

A este respecto, el ilustre doctor en historia y catedrático Francesc Ll. Cardona menciona en el estudio preliminar de *El manifiesto comunista* de Karl Marx y Friedrich Engels:

El maquinismo hizo aumentar enormemente el proceso de división del trabajo, el obrero asalariado fue desplazando poco a poco a los artesanos y trabajadores a domicilio. Pero el obrero se vio como un elemento aislado que no podía captar el sentido total de aquel proceso. Kuczynski refleja cómo los trabajadores eran considerados simples apéndices de las máquinas y se encontraban alineados de las posibilidades intelectuales del trabajo... las ciudades y zonas industriales habían crecido de forma rápida y desmesurada tan solo bajo el empuje de la industrialización y sin ninguna planificación ni servicios elementales de limpieza, abastecimiento de agua, sanidad y vivienda adecuadas para la clase trabajadora, de regreso a su hogar los obreros tenían que soportar alojamientos lúgubres e insanos, deficiente alimentación y un cúmulo de problemas familiares entre los que eran moneda corriente la enfermedad y el consiguiente bajo rendimiento o pérdida de empleo, ya que el desamparo más absoluto se desataba ante la enfermedad, el paro o la vejez... en la Monografía Estadística de la clase obrera de Barcelona (1856) el creador del Ensanche de la Ciudad Condal, Ildefonso Cerdá, llegó a la conclusión después de un minucioso análisis de los costes de la vivienda,

utillaje mínimo, atenciones médicas, partos, entierros, etc., de que sobre un total de 333 categorías profesionales, sólo a once le será posible alimentar como era debido a sus familias y eso en el entonces raro supuesto de que sólo tuviera dos hijos y de que la mujer también trabajara.¹

Unos cuantos años antes, Laureano Figueroa (que sería ministro de Hacienda tras la Revolución de 1868) había estudiado la vida media de los barceloneses entre 1837 y 1847 basándose en las partidas de defunción de los registros municipales. A la vista de estos descorazonadores resultados, Cerdá comentaba:

... causa en verdad penosa sensación ver cómo la vida se acorta y se extingue a proporción que las escaseces aumentan, de modo que para el nacido de la clase jornalera, en el lote de la vida le está tasada una cantidad próxima a la mitad de la que disfruta el que nació en primera clase...

La realidad que estas cifras y hechos permite vislumbrar es uno de los factores que explican el gran número de afiliados con que, pese a la represión de la época, contaba el asociacionismo obrero en Cataluña y singularmente en Barcelona, que se manifestara en la primera gran huelga general desencadenada en 1855 contra las máquinas textiles denominadas *selfactinas* (del inglés *self* y *acting* = que se mueven por sí mismas). Esta tradición asociacionista será decisiva después de 1868 en la introducción primero del anarquismo y más tarde del socialismo.²

Las circunstancias políticas y económicas conducían a una nueva lucha que combatiera las ideas fracasadas del liberalismo, incapaz de atender a los más pobres. Como primeros pasos había que combatir con ideas para lograr, mediante la unidad de los trabajadores, los pobres y los campesinos, el cambio social que pudiera lograr la "transformación revolucionaria de toda la sociedad o el hundimiento de las clases beligerantes",³ como proclamó Karl Marx en *El manifiesto comunista*, quien aprovechó los defectos para dar la pelea. Este manifiesto convocaba a la unión de los desamparados, pugnaba por la transformación de la sociedad, donde los detentadores de la fuerza de trabajo dejaran de ser condicionados y se convirtieran en condicionantes de la vida de las naciones.

Estos obreros, obligados a venderse al detalle, son una mercancía como cualquier otro artículo de comercio, sujeta, por tanto, a todas las vicisitudes de la

1 Karl Marx y Friedrich Engels, *El manifiesto comunista*. Antología de *El Capital*, Edicomunicación, Barcelona, 1999, pp. 22 y sigs.

2 *Ibidem*, pp. 21 y sigs.

3 *Ibid.*, p. 102.

competencia, a todas las fluctuaciones del mercado... los gastos que supone hoy en día el obrero se reduce poco más o menos a los medios de subsistencia indispensables para vivir y para perpetuar su raza... los salarios son cada vez más fluctuantes; el constante y acelerado perfeccionamiento de las máquinas coloca al obrero en situación cada vez más precaria... Los obreros empiezan a formar coaliciones contra los burgueses y actúan en común para la defensa de sus salarios. Crean organizaciones permanentes para asegurarse los medios necesarios, en previsión de estos choques circunstanciales. De tanto en tanto la lucha estalla en sublevación.⁴

Marx propone para los países industrializados la adopción de 10 puntos, entre los que destaca la abolición del trabajo de los niños "en las fábricas tal como se práctica hoy; régimen de educación combinada con la producción material". El Manifiesto de 1872 fue reeditado con prólogos de Friedrich Engels en 1883, 1890, 1892 y 1893.

Congresos socialistas

El Partido Popular fue fundado en Darnstadt en septiembre de 1865 y definitivamente organizado en el Congreso de Stuttgart, en septiembre de 1868. Era un partido de la pequeña burguesía sobre todo del sur de Alemania. Oponía los principios pequeñoburgueses del federalismo a la política bismarckiana que buscaba la unificación de Alemania bajo la hegemonía de la Prusia de los Junkers. El Congreso pangermano de los socialdemócratas de Alemania, Austria y Suiza, celebrado en Eisenach del 7 al 9 de agosto de 1869, formó el Partido Social Demócrata Obrero Alemán, conocido después como el partido eisenachianos. El Congreso de la I Internacional, celebrado en La Haya en septiembre de 1872, se desarrolló bajo el signo de la lucha contra los bakuninistas. La mayoría del Congreso se pronunció a favor del Consejo General, dirigido por Marx. Mijaíl Bakunin fue expulsado de la Internacional.

El Primer Congreso Socialista, celebrado en la ciudad alemana de Gotha del 22 al 27 de mayo de 1875, fue convocado por las dos organizaciones obreras alemanas: el Partido Obrero Socialdemócrata (los eisenachianos), dirigido por Leibknecht y Bebel, y la Unión General de Obreros Alemanes, organización lassalleana liderada por Hasenclever, Hasselman y Tolcke, con la idea de formar una organización única: el Partido Socialista Obrero de Alemania. El Programa del Partido Obrero Alemán parte de que "el trabajo es la fuente de toda riqueza y de toda cultura, y como el trabajo útil sólo es posible dentro de la sociedad y a través de ella, todos los miembros de la sociedad tienen igual derecho a percibir el fruto íntegro del trabajo".⁵ También precisa que "en la sociedad

4 *Ibid.*, pp. 102, 104, 105 y 107.

5 Carlos Marx y Federico Engels, *Obras escogidas*, t. II, Progreso, Moscú, 1995, pp. 10 y sigs.

actual, los medios de trabajo son monopolio de la clase capitalista, el estado de dependencia de la clase obrera que de esto se deriva es la causa de la miseria y de la esclavitud en todas sus formas”, y reconoce que “la emancipación del trabajo tiene que ser obra de la clase obrera, frente a la cual todas las otras clases no forman más que una masa reaccionaria”, por lo que exige una “educación popular general e igual a cargo del Estado, asistencia escolar obligatoria para todos. Instrucción gratuita”, así como la “restrcción del trabajo de la mujer y prohibición del trabajo infantil”, lo mismo que la “inspección por el Estado de la industria en las fábricas, en los talleres y a domicilio”.

Karl Marx, quien no participó en el Congreso, glosa el Programa en escrito de mayo de 1875, publicado, con ciertas omisiones, en la revista *Die Neue Zett*, Bd. 1, 2^a,⁶ señala que “como el trabajo es la fuente de la riqueza, nadie en la sociedad puede adquirir riqueza que no sea producto del trabajo. Si, por tanto no trabaja él mismo, es que vive del trabajo ajeno y adquiere también su cultura a costa del trabajo de los otros”; que la instrucción gratuita existe incluso en Alemania y la obligatoria “en Suiza y en los Estados Unidos... lo que hay que hacer es substraer la escuela a toda influencia por parte del Gobierno y de la Iglesia”; que “la reglamentación de la jornada de trabajo debe incluir ya la restricción del trabajo de la mujer en cuanto se refiere a la duración, descanso, etc., de la jornada; de no ser así, sólo puede equivaler a la prohibición del trabajo de la mujer en las ramas de producción que sean especialmente nocivas para el organismo femenino o inconvenientes, desde el punto de vista moral, para este sexo”; en cuanto a los infantes afirma que “la combinación del trabajo productivo con la enseñanza desde una edad temprana es uno de los más potentes medios de transformación de la sociedad actual”. Concluye su glosa sosteniendo:

... al hablar de la jornada normal de trabajo, no se ha tenido en cuenta la parte de la legislación fabril que se refiere a las medidas sanitarias y medios de protección contra los accidentes, etc. La ley de responsabilidad civil sólo entra en acción después de infringidas estas prescripciones.- En una palabra, también el apéndice se caracteriza por su descuidada redacción.- *Dixit et salvavi animam meam* (He dicho y salvado mi alma).

Primeras leyes de seguro social

En 1878, frente a la fuerza del socialismo y después de dos atentados frustrados contra la vida del viejo kaiser Guillermo I, unificador de Alemania, su canciller, Otto von Bismarck, concibe un plan para ahogar el poderoso

movimiento socialista, mediante una legislación de emergencia: la ley contra las tendencias de la social democracia, consideradas peligrosas para la comunidad y, asistido por los economistas Adolfo Wagner y Schaffle, adecua los principios de los seguros privados para implantar el seguro a favor de los trabajadores en 1879 contra las enfermedades, al reconocer que los obreros y sus familias estaban expuesto con mayor frecuencia. El canciller afirma "Hay que realizar todo aquello que se ajuste y pueda llevarse a cabo dentro de los límites de la organización del Estado" (conversaciones con Fernando Lasalle) y justifica con visión la creación del seguro en 1881:

El Estado que puede reunir más dinero fácilmente debe ser el que tome el asunto en sus manos. No como limosna, sino como derecho a recibir ayuda, cuando las fuerzas se agoten, y a pesar de la mejor voluntad, no se pueda trabajar más... Este asunto acabará por imponerse, tiene porvenir...; todo aquel que vuelva a patrocinar estas ideas, tomará el timón de la nave (la del Estado). El que tiene pensión para su vejez está mucho más contento y es mucho más fácil de tratar. Aunque se precisase mucho dinero para conseguir el contento de los desheredados, no será nunca demasiado caro: sería, por el contrario, una buena colocación de dinero, pues con ello evitaríamos una revolución que consumiría cantidades muy superiores.⁷

La primera ley fue la del seguro obligatorio de enfermedades, establecida el 13 de junio de 1883; la segunda, el 6 de julio de 1884, sobre seguro de accidentes de trabajo de los obreros y empleados de las empresas industriales; y otra más el 22 de junio de 1889, con el seguro obligatorio de invalidez y de vejez. Si un trabajador caía enfermo, el seguro de enfermedad le proporcionaba atención médica y ayuda financiera; cuando sufría un accidente, el fondo de compensación sufragaba todos los gastos médicos; cuando quedaba total o parcialmente incapacitado, inválido, habiendo cumplido los 65 años y estando cesante, recibía una pensión que le permitiera vivir decorosamente. Los gastos del seguro de accidente eran sufragados por el patrón; los del seguro de enfermedad se repartían entre la empresa y el empleado, así como los de vejez e invalidez. El Reich fue desde el principio el tercer participante de estas dos últimas ramas. Con ajuste al monto de sus participaciones, tanto patronos como trabajadores intervenían en la administración autárquica del seguro social.

Estas leyes delinean el sistema de seguro social en lo futuro, cuyas características principales son:

- a) Participación del trabajador en el costo del seguro, salvo en el de accidentes de trabajo, íntegramente sostenido por el patrón, con ajuste

primero a la doctrina romana de la culpa extracontractual, aquilina, y después por la teoría de la responsabilidad objetiva del riesgo creado.

- b) Participación del Estado, en representación de la sociedad interesada en el sostenimiento de los seguros de invalidez, vejez, enfermedades y maternidad.
- c) Administración autárquica del sistema de seguros, con intervención de los destinatarios del servicio, patrones y trabajadores.

El Congreso del Partido Social Demócrata de Alemania celebrado en Halle, el primero después de la derogación de la ley contra los socialistas, acordó, el 6 de octubre de 1890, a propuesta de W. Liebknecht, principal redactor del programa de Gotha, preparar un proyecto de nuevo programa para el siguiente Congreso del Partido. El programa fue aprobado en octubre de 1891, en el Congreso de Erfurt.

Encíclica *Rerum Novarum*

Debido a la necesidad que sentían Alemania y los países de Europa de frenar el auge del comunismo que rápidamente se extendió, se unen a la Iglesia católica con el propósito de que condene las nuevas doctrinas. El papa León XIII expide el 15 de mayo de 1891 la Encíclica *Rerum Novarum* (De las cosas nuevas) para definir su posición social. En ella, el Papa reconoce que los socialistas “pretenden que es preciso acabar con la propiedad privada y sustituirla por la colectiva para procurarse alguna cosa y poseerla como suya como derecho propio y personal... Luego, si gastando poco de este salario, ahorra algo, y para tener más seguro este ahorro, fruto de su parsimonia, lo emplea en una finca, síguese que tal finca no es más que aquel salario bajo esta forma”. Advierte que los patrones “no deben tener a los obreros por esclavos, que deben respetar la dignidad de la persona”, pues “una excesiva duración o lo gravoso del trabajo, y la idea de que el jornal es corto, dan no pocas veces a los obreros motivo para alzarse en huelga”, por lo que reconoce “la necesidad de descansar de las obras o trabajos... En general debe quedar establecido que a los obreros se les ha de dar tanto descanso cuanto compense las fuerzas gastadas en el trabajo”; deben crearse “asociaciones de socorros mutuas; los múltiples seguros que la previsión de los particulares puede establecer para atender a las necesidades de los obreros, a la viudez de su esposa, a la orfandad de sus hijos, en casos de repentinas desgracias o de enfermedad o de otros accidentes, a que está expuesta la vida humana”.⁸

En 1900, los seguros sociales alemanes se enfocan con mayor amplitud y se procede a la unificación de accidentes, que en 1905 se extiende a tres aspectos: accidentes, enfermedad e invalidez.

Sin embargo, esta tendencia no se completa hasta 1911 con la promulgación del *Código Federal de Seguros Sociales* y la *Ley de Seguros de Empleados Particulares*. El sistema de seguros de Bismarck, que abarcaba salud, vejez, enfermedades y accidentes, tenía la deficiencia de no incluir la previsión del desempleo, impuesto en Inglaterra desde 1911 e incorporado en Alemania hasta 1926, donde fracasó debido al desempleo.

El art. 161, título v, de la *Constitución de Weimar* de 1918, declaraba:

El Reich creará un amplio sistema de seguros para poder, con el concurso de los interesados, atender a la conservación de la salud y de la capacidad para el trabajo, a la protección de la maternidad y a la previsión de las consecuencias económicas de la vejez, de la enfermedad y de las vicisitudes de la vida.

Los seguros sociales alemanes estaban integrados en la forma siguiente:

1. Seguro obligatorio de accidentes y enfermedades profesionales.
2. Enfermedad y maternidad.
3. Seguro obligatorio de invalidez, vejez y muerte:
 - a) Seguro de los obreros.
 - b) Seguro de los empleados.
 - c) Seguro de los mineros.
4. Seguro contra el paro involuntario.

La Ley del 5 de julio de 1934 reorganiza la administración de los seguros sociales, autorizando al gobierno para dictar las disposiciones pertinentes.

El seguro social en Inglaterra

Las causas que originan el establecimiento del seguro social en Inglaterra son diversas: van de la atención a los pobres, a la Revolución Industrial y a los movimientos sociales que no se atrevieron a alterar sus estructuras. Las leyes de pobres, los movimientos cartistas, el aislamiento de la gran isla y el crecimiento de las fábricas, configuran un sistema de indiscutible efectividad, muy distinto del alemán.

En Inglaterra el seguro social obedece a la iniciativa gubernamental —con gran contenido político— de instaurar los seguros, anticipándose a las reivindicaciones que pudieran imponer los socialistas revolucionarios. El seguro privado de principios del siglo XIX permitía adaptar sus principios al seguro social.

Las ideas de David Lloyd George y de Winston Spencer Churchill iniciaron el camino. Lloyd George había señalado en 1906:

No quiero decir que la riqueza de este país hubiera de distribuirse por igual entre todos sus habitantes lo que afirmo es que la ley, al proteger a algunos hombres en el disfrute de sus inmensas propiedades, debe procurar que quienes producen la riqueza, sean protegidos con su familia, en lo precario de su situación. Actualmente no pueden adquirir los artículos de primera necesidad para la vida, a causa de circunstancias ajenas a su alcance. Pero esto tampoco significa que las personas con menos recursos, hubieran de acogerse a la lamentable y humillante condición de pobres, oficialmente considerados. Simplemente que la riqueza esparcida por este país debería, como condición previa para el disfrute de sus poseedores, contribuir a la subsistencia honorable de quienes estén en imposibilidad para mantenerse por sí mismos.⁹

Churchill expresaba el 11 de octubre del mismo año:

... ningún proyecto de sociedad puede considerarse completo si no comprende entre sus finalidades la organización colectiva y el incentivo individual. Toda la tendencia de la civilización se dirige, empero, a la multiplicación de las funciones colectivas de la sociedad. Las siempre crecientes complicaciones de la civilización crean para nosotros nuevos servicios que han de ser emprendidos por el Estado y significan la expansión de los servicios existentes.¹⁰

En 1870, el sacerdote de la Iglesia anglicana, William Lewery Blackley, propuso un sistema de seguros contra la vejez y las enfermedades. Estas ideas motivaron a Joseph Chamberlain a elaborar un plan de seguro voluntario para la vejez con aportaciones del Estado, lo que suscitó diversas sugerencias, como la de Charles Booth en su programa relativo al pago de una pensión de cinco chelines semanales a cada persona, después de los 65 años de edad, con cargo a fondos procedentes de contribuciones, sin tomar en cuenta la condición de necesidad y la contribución previa.

En 1893 se nombró una comisión para estudiar el problema de la ancianidad desvalida. En su informe destacaba que el ahorro personal, las sociedades de socorros mutuos y de beneficencia bastaban para resolver el problema.

En 1899 la Cámara de los Comunes designó una nueva comisión para el estudio del problema de los ancianos pobres, que se pronunció a favor de un sistema de pensiones; en dicha comisión se encontraba David Lloyd George.

⁹ Alberto Briceño Ruiz, *Derecho mexicano de los seguros sociales*, Harla, México, 1987, p. 70.

¹⁰ *Ibidem*, p. 71.

Se expidieron disposiciones legales de previsión y seguridad social, destinadas a proteger el derecho al trabajo y la tutela de los trabajadores:

- 1907. Ley sobre educación, inspección médica, cuidado de la salud y condición física de los menores, en escuelas públicas elementales.
- 1908. Ley de pensiones para la vejez y Ley reguladora del trabajo en las minas de carbón, con una jornada de ocho horas.
- 1909. Ley de Bolsas de Trabajo, con un sistema contra el paro forzoso; Ley de proyectos Ciudades, para proporcionar casas baratas a los obreros, y Ley de juntas de trabajadores.
- 1911. Primera legislación de seguros sociales, con intervención de Lloyd y Churchill. Lloyd estaba interesado en el seguro de enfermedad, habiéndose inspirado en Alemania. Churchill, ministro de comercio, conjuntamente con el secretario permanente del ministerio, Hubert Llevellyng Smith y William Beveridge, proyectaron la Ley de 1911. Esta disposición se limitaba a cubrir las enfermedades de invalidez, ya que el seguro de vejez, viudez y orfandad no aparece hasta 1925.

Las leyes de vejez de 1908 condicionaban sus prestaciones a los ingresos y propiedades del solicitante, de ahí que no se diferencien de la beneficencia pública. El financiamiento de los seguros contra la enfermedad y el desempleo se integraba con aportaciones del Estado, patrones y trabajadores; es decir, gravitaban sobre el consumo. La administración confiaba el seguro contra enfermedad a sociedades sin fines de lucro, organizadas por las agrupaciones de socorros mutuos o por las propias uniones obreras, o a sociedades consideradas adjuntas a las compañías de seguros comerciales. El seguro contra el paro se manejaba mediante un sistema nacional de Bolsas de Trabajo.

El 1925, después de reformarse en 1920 el campo de aplicación del seguro contra el paro, se extendió el principio del seguro a los riesgos de vejez y muerte.

Las leyes de pensiones para viudas, huérfanos y ancianos disponían el pago de estas pensiones a las viudas de los asegurados y establecían subvenciones a los hijos menores y huérfanos. Los asegurados y sus esposas adquirían el derecho a la pensión al cumplir 65 años.

El 1 de junio de 1941, Arthur Greenwood, ministro sin cartera, formuló ante la Cámara de los Comunes el anuncio del nombramiento de una Comisión parlamentaria encargada del estudio de los seguros sociales.

Plan Beveridge

El gobierno de guerra presidido por Churchill, junto con William Beveridge, integró la comisión con representaciones de 11 departamentos. El informe Beveridge¹¹ examina programas e ideas, incluso reiteró la idea de Bismarck en relación con el Estado de bienestar; toma como fundamento el ingreso básico mínimo que todo inglés debe percibir. El monto de este ingreso resultó de una investigación sobre el nivel de vida mínimo, costo de vestido y habitación, cálculo de calorías y de otros factores del presupuesto familiar. Aunque tal base haya sido abandonada, queda de ella el principio de cuotas fijas, independientes del salario.

El plan de Beveridge se sustentaba fundamentalmente en lograr el objetivo de destruir la ociosidad, esto es el poder otorgar ocupación a la gran mayoría de la mano de obra existente, pues valiéndose los trabajadores de un ingreso es que se podría partir en la contribución para el sostenimiento de su régimen financiero, complementado por las aportaciones patronales y del Estado, afirmaba categórico: "No podemos suprimir la indigencia a menos de asegurarnos de que todo el que quiera trabajo, todas las personas que están expuestas a accidentes individuales y a desgracias que puedan interrumpir sus ingresos, tengan siempre, para hacer frente a todas sus responsabilidades, los ingresos necesarios".¹² Se pronunciaba también para garantizar a todos un ingreso mínimo.

Como se puede apreciar, el multicitado plan de seguridad social formaba parte de toda una estrategia del Gobierno Inglés con objeto de prevenir los grandes males que en la paz afectan a toda sociedad y evitar en lo posible sus efectos, contribuyendo a una mejor redistribución del ingreso.¹³

El Plan Beveridge¹⁴ reconoce la importancia de la salud, tanto para la familia como para la nación; se encomienda su protección a un servicio de salubridad que asegure cualquier tratamiento médico. A la mujer casada se le reconoce una serie de primas o compensaciones, en razón de su estado económico y social: una división total proporcional al número de cuotas pagadas antes del matrimonio, hasta la cantidad de 10 libras. Tendrán una prestación económica por maternidad; si trabajan percibirán una prima por dicha maternidad durante 13 semanas. A la viuda se le pagará pensión de 24 chelines por

11 El Plan Beveridge, aceptado por el gobierno inglés, se publica en dos libros blancos en 1944 con el nombre *Seguros Sociales. Primera Parte*.

12 William Beveridge, *Las bases de la seguridad social*, Fondo de Cultura Económica, México, 1987, p. 37.

13 Gustavo Cazares García, *Derecho de la seguridad social*, Porrúa, México, 2007, p. 21.

14 William Beveridge, *op. cit.*

retiro; si tiene más de 60 años, pensión de 36 chelines a la semana durante seis semanas, para cubrir un periodo de adaptación. Si tiene hijos que dependan de ella, se establece un subsidio de tutoría de 24 chelines a la semana, más una cantidad adicional media de ocho chelines por cada hijo. Además, se otorgan subsidios por cada hijo, después del tercero.¹⁵

Expansión en el mundo

En el Congreso Internacional Socialista, reunido en Amsterdam en agosto de 1904, se acordó una resolución en la que:

Los trabajadores de todos los países deben exigir instituciones propias para prevenir en cuanto sea posible la enfermedad, los accidentes y la invalidez, para darles, mediante leyes de seguro obligatorio, el derecho de obtener suficientes medios de vida y de asistencia durante el tiempo en que no les sea posible aprovechar su fuerza de trabajo por razón de enfermedad, de accidente, de invalidez, de vejez, de embarazo, de maternidad o de parto. Los gastos de los seguros y, en primer término, los de invalidez y de vejez, así como los de viudez y orfandad, se obtendrán mediante impuestos sobre el capital, la renta y las sucesiones. Donde esto no sea posible, los gastos de seguro recaen sobre el salario del obrero e incluso aunque los patrones aporten. Es, pues, deber de los obreros reparar la pérdida de salarios reforzando sus organizaciones sindicales. Los trabajadores deben exigir que las instituciones de seguros sean confiadas a la administración de los propios asegurados y que se concedan las mismas ventajas a todos los obreros del país y a los extranjeros que residan en él.¹⁶

El Congreso francés celebrado en Lille en 1923 recomienda:

... convendría no ilusionarse sobre la capacidad de protección de las organizaciones sindicales. A pesar de los socorros considerables que pueden distribuir, jamás desempeñarán el papel eminente del Estado, en materia de Seguro Social. Por ello el Partido Político de los Trabajadores, el Partido Socialista, formuló desde su nacimiento, una de las reivindicaciones esenciales del proletariado, al pedir que la sociedad se hiciese cargo de los ancianos y de los inválidos del trabajo. Y luego, cuando más tarde, ingresado al Parlamento, propuso por el órgano de sus elegidos, la institución de Seguros obreros más o menos extendidos. Tenemos el deber de rendir aquí homenaje a los esfuerzos perseverantes de nuestro ilustre camarada Edouard Vaillant quien, en nombre del socialismo, presentó en diciembre de 1900

¹⁵ *Plan Beveridge*, CIESS, México, 2008.

¹⁶ Otto Kuusinen *et al.*, *Manual de marxismo leninismo*, Grijalbo, México, 1966, p. 297.

una proposición de ley encaminada al establecimiento de un sistema completo de Seguros Sociales.¹⁷

Los anteriores han sido los principales movimientos que dieron lugar a las disposiciones expedidas en todos los países para reconocer el interés de la sociedad y del mundo en brindar niveles de protección al ser humano. La presión ejercida por las organizaciones de trabajadores obligaron a los gobiernos a integrar la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y posteriormente la Asociación Internacional de Seguridad Social. Los convenios, los acuerdos y las recomendaciones ocupan grandes volúmenes, con el propósito de consignar disposiciones, obligatorias en algunos casos, que debían observar los signatarios. El acta de la OIT elaboró el convenio 102, relativo a la norma mínima de la seguridad social, en vigor a partir del 27 de abril de 1955.¹⁸ Este documento, regulador de los sistemas de seguridad social, contiene los apartados siguientes: Disposiciones generales, Asistencia médica, Prestaciones monetarias de enfermedad, Prestaciones de desempleo, Prestaciones de vejez, Prestaciones en caso de accidente del trabajo y de enfermedad profesional, Prestaciones familiares, Prestaciones de maternidad, Prestaciones de invalidez, Prestaciones de sobrevivientes, Cálculo de los pagos periódicos, Igualdad de trato a los residentes no nacionales, Disposiciones comunes, Disposiciones diversas, Disposiciones finales y Clasificación internacional tipo, por industria, de todas las ramas de la actividad económica.

La Conferencia fue convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 4 de junio de 1952 en su trigésima quinta reunión; adopta, con fecha 28 de junio de 1952, el siguiente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952:

En el art. 7 dispone que el país miembro

... deberá garantizar a las personas protegidas la concesión, cuando su estado lo requiera, de asistencia médica, de carácter preventivo o curativo; ésta comprenderá todo estado mórbido cualquiera que fuere su causa, el embarazo, el parto y sus consecuencias. En las categorías de asalariados, por lo menos, el 50 por ciento de todos ellos, así como a las cónyuges y a los hijos; para la población económicamente activa, por lo menos, el 20 por ciento de todos los residentes, así como a las cónyuges y a los hijos de los miembros de esas categorías. Las prestaciones deberán comprender, por lo menos: a) en caso de estado mórbido: i) la asistencia médica general, comprendida la visita a domicilio; ii) la asistencia por especialistas, prestada en

17 Alberto Briceño Ruiz, *Derecho mexicano de los seguros sociales*, Harla, México, 1987, p. 75.

18 *Convenios y recomendaciones internacionales del trabajo. 1919-1984*, OIT, 1985, pp. 867 y sigs.

hospitales a personas hospitalizadas o no hospitalizadas, y la asistencia que pueda ser prestada por especialistas fuera de los hospitales; iii) el suministro de productos farmacéuticos esenciales recetados por médicos u otros profesionales calificados; y iv) la hospitalización, cuando fuere necesaria; y b) en caso de embarazo, parto y sus consecuencias: i) la asistencia prenatal, la asistencia durante el parto y la asistencia puerperal prestada por un médico o por una comadrona diplomada; y ii) la hospitalización, cuando fuere necesaria. La asistencia médica prestada de conformidad con este artículo tendrá por objeto conservar, restablecer o mejorar la salud de la persona protegida, así como su aptitud para el trabajo y para hacer frente a sus necesidades personales. Las prestaciones mencionadas deberán concederse durante todo el transcurso de la contingencia cubierta, sin que puedan suspenderse mientras continúe pagándose una prestación monetaria de enfermedad, y deberán adoptarse disposiciones que permitan la extensión del límite antes mencionado, cuando se trate de enfermedades determinadas por la legislación nacional para las que se reconozca la necesidad de una asistencia prolongada.

En términos del art. 13, cada país deberá garantizar la concesión de prestaciones monetarias de enfermedad a las personas protegidas, cuando entrañe la suspensión de ganancias, según la defina la legislación nacional, mediante un pago periódico, por lo menos a las personas protegidas que hayan cumplido el periodo de calificación que se considere necesario para evitar abusos durante el transcurso de la contingencia, a reserva de que su duración podrá limitarse a 26 semanas en cada caso de enfermedad, con la posibilidad de no pagarse la prestación por los tres primeros días.

La Parte IV se refiere a las prestaciones de desempleo; el país que así lo determine garantizará a las personas protegidas la concesión de prestaciones de desempleo. La contingencia cubierta deberá comprender la suspensión de ganancias, según la defina la legislación nacional, ocasionada por la imposibilidad de obtener un empleo conveniente, en el caso de una persona protegida que sea apta para trabajar y esté disponible para el trabajo. Las personas protegidas podrán ser de las categorías prescritas de asalariados, cuando no sean más de 50% de todos los asalariados. Dicha prestación consistirá en un pago periódico calculado de conformidad con las disposiciones del Convenio (arts. 65 a 67). Esta prestación deberá garantizarse, en la contingencia cubierta, por lo menos a las personas protegidas que hayan cumplido el periodo de calificación que se considere necesario para evitar abusos, durante todo el transcurso de la contingencia; su duración podrá limitarse, cuando comprenda a categorías de asalariados, a 13 semanas en el transcurso de un periodo de 12 meses; cuando comprenda a todos los residentes cuyos recursos durante la contingencia no excedan de límites prescritos, a 26 semanas en el transcurso de un periodo de 12 meses.

La legislación nacional puede establecer que la duración de la prestación varíe de conformidad con el periodo de cotización o con las prestaciones re-

cibidas anteriormente en el transcurso de un periodo prescrito, o con ambos factores a la vez, si el promedio de duración comprende, por lo menos, 13 semanas en el transcurso de un periodo de 12 meses, sin que pueda ser pagada por un periodo de espera fijado en los siete primeros días en cada caso de suspensión de ganancias, contando como parte del mismo caso de suspensión de ganancias los días de desempleo antes y después de un empleo temporal que no exceda de una duración prescrita. Cuando se trate de trabajadores de temporada, la duración de la prestación y el periodo de espera podrán adaptarse a las condiciones de empleo.

La Parte V del Convenio se dedica a las prestaciones de vejez, e impone a todo miembro para el cual esté en vigor esta parte del Convenio, garantizar a las personas protegidas la concesión de prestaciones de vejez; la edad prescrita no deberá exceder de 65 años. Sin embargo, la autoridad competente podrá fijar una edad más elevada, teniendo en cuenta la capacidad de trabajo de las personas de edad avanzada en el país de que se trate. La legislación nacional podrá suspender la prestación si la persona que habría tenido derecho a ella ejerce ciertas actividades remuneradas prescritas, o podrá reducir las prestaciones contributivas cuando las ganancias del beneficiario excedan de un valor prescrito, y las prestaciones no contributivas, cuando las ganancias del beneficiario, o sus demás recursos, o ambos conjuntamente, excedan de un valor prescrito. La prestación consistirá en un pago periódico que deberá garantizarse a las personas protegidas que hayan cumplido, antes de la contingencia, de conformidad con reglas prescritas, un periodo de calificación que podrá consistir en 30 años de cotización o de empleo, o en 20 años de residencia; cuando en principio estén protegidas todas las personas económicamente activas, a las personas protegidas que hayan cumplido un periodo de calificación prescrito de cotización y en nombre de las cuales se hayan pagado, durante el periodo activo de su vida, cotizaciones cuyo promedio anual alcance una cifra prescrita. La concesión de la prestación mencionada puede estar condicionada al cumplimiento de un periodo mínimo de cotización o de empleo, si las personas protegidas cumplieron, antes de la contingencia, de conformidad con reglas prescritas, un periodo de calificación de 15 años de cotización o de empleo; o un periodo de calificación prescrito de cotización y en nombre de las cuales se haya pagado, durante el periodo activo de su vida, la mitad del promedio anual de cotizaciones. Podrá efectuarse una reducción proporcional, cuando el periodo de calificación correspondiente a la prestación del porcentaje reducido sea superior a 10 años de cotización o de empleo, pero inferior a 30 años de cotización o de empleo; cuando dicho periodo de calificación sea superior a 15 años, se concederá una pensión reducida.

Cuando la concesión de la prestación mencionada esté condicionada al cumplimiento de un periodo mínimo de cotización o de empleo, deberá garantizarse una prestación reducida, en las condiciones prescritas, a las personas protegidas que, por el solo hecho de la edad avanzada a que hubieren

llegado cuando las disposiciones que permitan aplicar esta parte del Convenio se hayan puesto en vigor, no hayan podido cumplir las condiciones prescritas, a menos que se conceda una prestación a tales personas a una edad más elevada que la normal.

La Parte VI se refiere a las prestaciones en caso de accidente del trabajo y de enfermedad profesional, e impone a los países miembros, adheridos a esta parte del Convenio, el deber de garantizar a las personas protegidas la concesión de prestaciones en caso de accidente del trabajo y de enfermedad profesional. La asistencia médica comprenderá la general y la especializada a personas hospitalizadas o no hospitalizadas, incluidas las visitas a domicilio; la asistencia odontológica; la asistencia por enfermeras, a domicilio, en un hospital o en cualquier otra institución médica; el mantenimiento en un hospital, centro de convalecencia, sanatorio u otra institución médica; el suministro de material odontológico, farmacéutico, y cualquier otro material médico o quirúrgico, comprendidos los aparatos de prótesis y su conservación, así como los anteojos; y la asistencia suministrada por miembros de otras profesiones reconocidas legalmente como conexas con la profesión médica, bajo la vigilancia de un médico o de un dentista.

La asistencia médica prestada tendrá por objeto conservar, restablecer o mejorar la salud de la persona protegida, así como su aptitud para el trabajo y para hacer frente a sus necesidades personales.

El art. 36 establece que a la incapacidad para trabajar o la pérdida total de capacidad para ganar, cuando es probable que sea permanente, a la disminución correspondiente de las facultades físicas o a la muerte del sostén de familia, la prestación deberá consistir en un pago periódico; en caso de pérdida parcial de la capacidad para ganar, cuando es probable que sea permanente, o en caso de una disminución correspondiente de las facultades físicas, la prestación consistirá en un pago periódico que represente una proporción conveniente de la prestación prevista en caso de pérdida total de la capacidad para ganar o de una disminución correspondiente de las facultades físicas.

Los pagos periódicos podrán sustituirse por un capital pagado de una sola vez, cuando el grado de incapacidad sea mínimo; o cuando se garantice a las autoridades competentes el empleo razonable de dicho capital. Estos pagos deberán garantizarse, por lo menos a las personas protegidas que estuvieran empleadas como asalariados en el territorio del miembro en el momento del accidente o en el momento en que se contrajo la enfermedad; y si se trata de pagos periódicos resultantes del fallecimiento del sostén de familia, a la viuda y a los hijos de aquél, durante todo el transcurso de la contingencia; sin embargo, con respecto a la incapacidad para trabajar, la prestación podrá no pagarse por los tres primeros días en cada caso de suspensión de ganancias.

Conforme al art. 39, el país miembro deberá garantizar a las personas protegidas la concesión de prestaciones familiares; éstas comprenderán un pago periódico concedido a toda persona protegida y se garantizarán, por lo

menos, a las personas protegidas que hayan cumplido, durante un periodo prescrito, un periodo de calificación que podrá consistir en tres meses de cotización o de empleo, o en un año de residencia, según se prescriba.

El valor total de las prestaciones concedidas a las personas protegidas deberá ser tal que represente 3% del salario de un trabajador ordinario no calificado adulto de sexo masculino, por el número total de hijos de todas las personas protegidas; o 1.5% del salario susodicho, multiplicado por el número total de hijos de todos los residentes. Cuando las prestaciones consistan en un pago periódico, deberán concederse durante todo el transcurso de la contingencia.

En cuanto a la maternidad, la protección comprenderá el embarazo, el parto y sus consecuencias, y la suspensión de ganancias resultantes de los mismos, según la defina la legislación nacional. Las personas protegidas serán las mujeres que pertenezcan a categorías prescritas de asalariados, categorías que en total constituyan, por lo menos, 50% de todos los asalariados, y, en lo que concierne a las prestaciones médicas de maternidad, también a las cónyuges de los hombres comprendidos en esas mismas categorías. También podrá comprender a las mujeres que pertenezcan a categorías prescritas de la población económicamente activa, categorías que en total constituyan, por lo menos, 20% de todos los residentes, y, en cuanto a las prestaciones médicas de maternidad, también a las cónyuges de los asalariados comprendidos en esas mismas categorías.

Respecto del embarazo, el parto y sus consecuencias, las prestaciones médicas de maternidad comprenderán la asistencia prenatal, la asistencia durante el parto y la asistencia puerperal prestada por un médico o por una comadrona diplomada, así como la hospitalización, cuando fuere necesaria.

La asistencia médica a la mujer tiene por objeto conservar, restablecer o mejorar la salud de la mujer protegida, así como su aptitud para el trabajo y para hacer frente a sus necesidades personales. Las instituciones o los departamentos gubernamentales que concedan las prestaciones médicas de maternidad deberán estimular a las mujeres protegidas, por cuantos medios puedan ser considerados apropiados, para que utilicen los servicios generales de salud puestos a su disposición por las autoridades públicas o por otros organismos reconocidos por las autoridades públicas.

Además, como resultante del embarazo, del parto y de sus consecuencias, se otorgará a las mujeres un pago periódico que podrá variar en el transcurso de la contingencia, el cual debe garantizarse por lo menos a las mujeres pertenecientes a las categorías protegidas que hayan cumplido el periodo de calificación que se considere necesario para evitar abusos; las prestaciones mencionadas también se otorgarán a las cónyuges de los trabajadores de las categorías protegidas, cuando éstos hayan cumplido el periodo de calificación previsto. Los pagos periódicos podrán limitarse a 12 semanas, a menos que la legislación nacional imponga o autorice un periodo más largo de abstención del trabajo, en cuyo caso los pagos no podrán limitarse a un periodo de menor duración.

La Parte IX se refiere a las prestaciones de invalidez, la que comprende la ineptitud para ejercer una actividad profesional, en un grado prescrito, cuando sea probable que esta ineptitud será permanente o cuando la misma subsista después de cesar las prestaciones monetarias de enfermedad. La prestación consiste en un pago periódico para las personas protegidas que hayan cumplido, antes de la contingencia, según reglas prescritas, un periodo de calificación que podrá ser de 15 años de cotización o de empleo o de 10 años de residencia; o cuando en principio todas las personas económicamente activas estén protegidas, a las personas protegidas que hayan cumplido un periodo de tres años de cotización y en nombre de las cuales se haya pagado, en el transcurso del periodo activo de su vida, el promedio anual prescrito de cotizaciones.

En el caso de un periodo mínimo de cotización o de empleo, deberá garantizarse una prestación reducida a las personas que hayan cumplido, antes de la contingencia, según reglas prescritas, un periodo de cinco años de cotización de empleo; o en el supuesto de que las personas económicamente activas estén protegidas, a aquellas que hayan cumplido un periodo de tres años de cotización y en nombre de las cuales se haya pagado en el transcurso del periodo activo de su vida la mitad del promedio anual prescrito de cotizaciones. Podrá efectuarse una reducción proporcional en el porcentaje, cuando el periodo de calificación correspondiente a la prestación de porcentaje reducido sea superior a cinco años de cotización o de empleo, pero inferior a 15 años de cotización o de empleo. Estas prestaciones deberán concederse durante todo el transcurso de la contingencia o hasta que sean sustituidas por una prestación de vejez.

La Parte X se dedica a las prestaciones de sobrevivientes y comprende la pérdida de medios de existencia sufrida por la viuda o los hijos como consecuencia de la muerte del sostén de familia. En el caso de la viuda, el derecho a la prestación podrá quedar condicionado a la presunción, según la legislación nacional, de que es incapaz de subvenir a sus propias necesidades. La legislación nacional podrá suspender la prestación si la persona que habría tenido derecho a ella ejerce ciertas actividades remuneradas prescritas, o se podrá reducir cuando las ganancias del beneficiario excedan de un valor prescrito, y las prestaciones no contributivas, cuando las ganancias del beneficiario, o sus demás recursos, o ambos conjuntamente, excedan de un valor prescrito.

Además de los cónyuges, se protege a los hijos que hayan perdido el sostén de la familia. La prestación consiste en un pago periódico que se otorgará cuando el sostén de familia haya cumplido, según reglas prescritas, un periodo de calificación que podrá consistir en 15 años de cotización o de empleo o en 10 años de residencia; o cuando haya cumplido un periodo de tres años de cotización, a condición de que se haya pagado en nombre de este sostén de familia, en el transcurso del periodo activo de su vida, el promedio anual prescrito de cotizaciones.

En el supuesto de que la concesión de la prestación esté condicionada al cumplimiento de un periodo mínimo de cotización o de empleo, deberá garantizarse una prestación reducida a las personas protegidas cuyo sostén de familia haya cumplido, según reglas prescritas, un periodo de cinco años de cotización o de empleo; o cuando haya cumplido un periodo de tres años de cotización.

Para que una viuda sin hijos, a la que presuma incapaz de subvenir a sus propias necesidades, tenga derecho a una prestación de sobreviviente, podrá prescribirse una duración mínima del matrimonio.

La Parte XII del Convenio, relativa a la igualdad de trato a los residentes no nacionales, establece que se reconozcan los mismos derechos que a los residentes nacionales, de acuerdo con el art. 68. Sin embargo, podrán prescribirse disposiciones especiales para los no nacionales y para los nacionales nacidos fuera del territorio del miembro, en lo que respecta a las prestaciones o partes de prestaciones financiadas exclusivamente o de manera preponderante con fondos públicos, y en lo que respecta a los regímenes transitorios.

En los sistemas de seguridad social contributivos cuya protección comprenda a los asalariados, las personas protegidas que sean nacionales de otro miembro que haya aceptado las obligaciones de la parte correspondiente del Convenio deberán tener, respecto de dicha parte, los mismos derechos que los nacionales del miembro interesado. Sin embargo, la aplicación de este párrafo podrá estar condicionada a la existencia de un acuerdo bilateral o multilateral que prevea la reciprocidad.

Las partes XIII, XIV y XV se refieren a disposiciones comunes, disposiciones diversas y disposiciones finales. La primera prevé que una prestación a la cual tendría derecho una persona protegida, podrá ser suspendida, en la medida en que pueda ser prescrita:

- a) Tanto tiempo como el interesado no se encuentre en el territorio del miembro.
- b) Tanto tiempo como el interesado esté mantenido con cargo a fondos públicos o a costa de una institución o de un servicio de seguridad social; sin embargo, si la prestación excede del costo de esa manutención, la diferencia deberá concederse a las personas que estén a cargo del beneficiario.
- c) Tanto tiempo como el interesado reciba otra prestación, en dinero, de seguridad social, con excepción de una prestación familiar, y durante todo periodo en el transcurso del cual esté indemnizado por la misma contingencia por un tercero, a condición de que la parte de la prestación suspendida no sobrepase la otra prestación o la indemnización procedente de un tercero.
- d) Cuando el interesado haya intentado fraudulentamente obtener una prestación.

- e) Cuando la contingencia haya sido provocada por un crimen o delito cometido por el interesado.
- f) Cuando la contingencia haya sido provocada por una falta intencionada del interesado.
- g) En los casos apropiados, cuando el interesado no utilice los servicios médicos o los servicios de readaptación puestos a su disposición, o no observe las reglas prescritas para comprobar la existencia de la contingencia o la conducta de los beneficiarios de las prestaciones.
- h) Respecto a las prestaciones de desempleo, cuando el interesado deje de utilizar los servicios del empleo disponibles.
- i) En cuanto a las prestaciones de desempleo, cuando el interesado haya perdido su empleo como consecuencia directa de una suspensión de trabajo debida a un conflicto profesional o haya abandonado su empleo voluntariamente sin motivo justificado.
- j) En lo que se refiere a las prestaciones de sobrevivientes, tanto tiempo como la viuda viva en concubinato.

El solicitante deberá tener derecho a apelar, en caso de que se le niegue la prestación o en caso de queja sobre su calidad o cantidad. Cuando las reclamaciones se lleven ante tribunales especialmente establecidos para tratar de los litigios sobre seguridad social y en ellos estén representadas las personas protegidas, podrá negarse el derecho de apelación.

En el art. 71 se consigna que el costo de las prestaciones concedidas en aplicación del presente Convenio y los gastos de administración de estas prestaciones deberán ser financiados colectivamente por medio de cotizaciones o de impuestos, o por ambos medios a la vez, en forma que evite que las personas de recursos económicos modestos tengan que soportar una carga demasiado onerosa y que tenga en cuenta la situación económica del miembro y la de las categorías de personas protegidas.

Además, el total de cotizaciones de seguro a cargo de los asalariados protegidos no deberá exceder de 50% del total de recursos destinados a la protección de los asalariados y de los cónyuges y de los hijos de éstos. Para determinar si se cumple esta condición, todas las prestaciones suministradas por el país miembro, en aplicación del presente Convenio, podrán ser consideradas en conjunto, a excepción de las prestaciones familiares y en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, si estas últimas dependen de una rama especial.

El país miembro deberá asumir la responsabilidad general respecto al servicio de prestaciones concedidas en aplicación del presente Convenio y adoptar, cuando fuere oportuno, todas las medidas necesarias para alcanzar dicho fin; deberá garantizar, cuando fuere oportuno, que los estudios y cálculos actuariales necesarios relativos al equilibrio se establezcan periódica y, en todo caso, previamente a cualquier modificación de las prestaciones, de la tasa de las

cotizaciones del seguro o de los impuestos destinados a cubrir las contingencias en cuestión.

Por su parte, el art. 72 establece el supuesto de que la administración no esté confiada a una institución reglamentada por las autoridades públicas o a un departamento gubernamental responsable ante un parlamento, representantes de las personas protegidas deberán participar en la administración o estar asociados a ella, con carácter consultivo, en las condiciones prescritas; la legislación nacional podrá prever asimismo la participación de representantes de los empleadores y de las autoridades públicas.

El país miembro asumirá la responsabilidad general de la buena administración de las instituciones y los servicios que contribuyan a la aplicación del presente Convenio.

Las disposiciones diversas señalan que el Convenio no se aplicará:

- a) A las contingencias sobrevenidas antes de la entrada en vigor de la parte correspondiente del Convenio para el miembro interesado.
- b) A las prestaciones concedidas por contingencias que hayan sobrevenido después de la entrada en vigor de la parte correspondiente del Convenio para el miembro interesado, en la medida en que los derechos a dichas prestaciones provengan de periodos anteriores a la fecha de dicha entrada en vigor.

Este Convenio no revisa ninguno de los convenios existentes. Cuando un convenio adoptado posteriormente por la Conferencia, relativo a cualquier materia o materias tratadas por el presente Convenio así lo disponga, las disposiciones de éste que se especifiquen en el nuevo convenio cesarán de aplicarse a todo miembro que lo hubiere ratificado, a partir de la fecha de entrada en vigor para el miembro interesado.

Todo miembro que ratifique el presente Convenio se obliga a incluir en la memoria anual que habrá de presentar sobre la aplicación del Convenio conforme al art. 22 de la Constitución de la OIT:

- a) Información completa sobre la legislación que dé efecto a las disposiciones del Convenio.
- b) Pruebas de haber observado las condiciones estadísticas especificadas en:
 - i) los arts. 9º a), b), c) o d); 15 a), b) o d); 21 a) o c); 27 a), b) o d); 33 a) o b); 41, a), b) o d); 48 a), b) o c); 55 a), b) o d); 61 a), b) o d), en cuanto al número de personas protegidas;
 - ii) los arts. 45, 65, 66 o 67, en cuanto a la cuantía de las prestaciones;
 - iii) el párrafo 2 del art. 18, en cuanto a la duración de las prestaciones monetarias de enfermedad;

- iv) el párrafo 2 del art. 24, en cuanto a la duración de las prestaciones de desempleo, y
- v) el párrafo 2 del art. 71, en cuanto a la proporción de los recursos que provengan de las cotizaciones del seguro de los asalariados protegidos.

Hasta donde sea posible, estas pruebas deberán suministrarse de conformidad, en cuanto a su presentación, a las sugerencias formuladas por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, con objeto de dar mayor uniformidad a este respecto.

Todo miembro que ratifique el presente Convenio informará al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, a intervalos apropiados, conforme lo decida el Consejo de Administración, sobre el estado de su legislación y su aplicación en lo que concierne a cada una de las partes II a X, que no hayan sido especificadas ya en la ratificación del miembro en cuestión o en una notificación hecha posteriormente, en virtud del art. 4°.

1. Este Convenio no se aplica a la gente de mar ni a los pescadores de alta mar; las disposiciones para la protección de la gente de mar y de los pescadores de alta mar fueron adoptadas por la Conferencia Internacional del Trabajo en el Convenio sobre la seguridad social de la gente de mar, 1946, y en el Convenio sobre las pensiones de la gente de mar, 1946.
2. Todo miembro podrá excluir a la gente de mar y a los pescadores de alta mar del número de asalariados, de personas de la población económicamente activa o de residentes, considerado en el cálculo del porcentaje de asalariados o residentes protegidos en aplicación de cualquiera de las partes II a X cubiertas por la ratificación.

Las disposiciones finales se refieren a las ratificaciones formales del presente Convenio, las cuales serán comunicadas, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. El Convenio obligará únicamente a aquellos miembros de la OIT cuyas ratificaciones haya registrado el Director General y entrará en vigor 12 meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos miembros hayan sido registradas por el Director General. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada miembro, 12 meses después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación.

Conforme al art. 80, las declaraciones comunicadas al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, de acuerdo con el párrafo 2 del art. 35 de la Constitución de la OIT, deberán indicar:

- a) Los territorios respecto de los cuales el miembro interesado se obliga a que las disposiciones del Convenio o de cualquiera de sus partes sean aplicadas sin modificaciones.
- b) Los territorios respecto de los cuales se obliga a que las disposiciones del Convenio o de cualquiera de sus partes sean aplicadas con modificaciones, junto con los detalles de dichas modificaciones.
- c) Los territorios respecto de los cuales es inaplicable el Convenio y los motivos por los cuales es inaplicable.
- d) Los territorios respecto de los cuales reserva su decisión en espera de un examen más detenido de su situación.

Las obligaciones a que se refieren los apartados *a)* y *b)* del párrafo 1 de este artículo se considerarán parte integrante de la ratificación y producirán sus mismos efectos.

Todo miembro podrá renunciar, total o parcialmente, por medio de una nueva declaración, a cualquier reserva formulada en su primera declaración, en virtud de los apartados *b)*, *c)* o *d)* del párrafo 1 de este artículo.

Durante los periodos en que este Convenio pueda ser denunciado de conformidad con las disposiciones del art. 82, todo miembro podrá comunicar al Director General una declaración por la que modifique, en cualquier otro respecto, los términos de cualquier declaración anterior y en la que indique la situación en territorios determinados.

Las declaraciones comunicadas al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, de conformidad con los párrafos 4 y 5 del art. 35 de la Constitución de la OIT, deberán indicar si las disposiciones del Convenio, o de cualquiera de las partes aceptadas en la declaración, serán aplicadas en el territorio interesado con modificaciones o sin ellas; cuando la declaración indique que las disposiciones del Convenio o de cualquiera de sus partes serán aplicadas con modificaciones, deberá especificar en qué consisten dichas modificaciones.

El miembro, los miembros o la autoridad internacional interesados podrán renunciar, total o parcialmente, por medio de una declaración ulterior, al derecho a invocar una modificación indicada en cualquier otra declaración anterior.

Durante los periodos en que este Convenio pueda ser denunciado de conformidad con las disposiciones del art. 82, el miembro, los miembros o la autoridad internacional interesados podrán comunicar al Director General una declaración por la que modifiquen, en cualquier otro respecto, los términos de cualquier declaración anterior, y en la que indiquen la situación en lo que se refiere a la aplicación del Convenio.

Todo miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciar el Convenio, o una o varias de las partes II a X, a la expiración de un periodo de 10 años, a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor.

mediante un acta comunicada, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que se haya registrado.

Asimismo, todo miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un año después de la expiración del periodo de 10 años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo periodo de 10 años, y en lo sucesivo podrá denunciar el Convenio o cualquiera de las partes II a X a la expiración de cada periodo de 10 años, en las condiciones previstas en este artículo.

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los miembros de la OIT el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y denuncias le comuniquen los miembros de la Organización.

Al notificar a los miembros de la OIT el registro de la segunda ratificación que le haya sido comunicada, el Director General llamará la atención de los miembros sobre la fecha en que entrará en vigor el presente Convenio.

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad con el art. 102 de la *Carta de las Naciones Unidas*, una información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes.

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre la aplicación del Convenio, y considerará la conveniencia de incluir en el orden del día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o parcial.

En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una revisión total o parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario:

- a) La ratificación, por un miembro, del nuevo convenio revisor implicará, *ipso jure*, la denuncia inmediata de este Convenio, no obstante las disposiciones contenidas en el art. 82, siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor.
- b) A partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente Convenio cesará de estar abierto a la ratificación por los miembros.

Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido actuales, para los miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor.

En la última parte, el Convenio contiene una clasificación internacional tipo, por industria, de todas las ramas de la actividad económica.

Lista de divisiones y grupos principales

División 0. Agricultura, silvicultura, caza y pesca:

01. Agricultura y ganadería.
02. Silvicultura, tala y corta.
03. Caza, caza mediante trampas y repoblación.
04. Pesca.

División 1. Explotación de minas y canteras:

11. Extracción de carbón.
12. Extracción de minerales metálicos.
13. Petróleo crudo y gas natural.
14. Extracción de piedra, arcilla y arena.
19. Extracción de minerales no metálicos y explotación de canteras clasificadas en otra parte.

División 2-3. Industrias manufactureras:

20. Industrias manufactureras de productos alimenticios (excepto industrias de bebidas).
21. Industrias de bebidas.
22. Industrias del tabaco.
23. Fabricación de textiles.
24. Fabricación de calzado, prendas de vestir y otros artículos confeccionados con productos textiles.
25. Industrias de la madera y del corcho, exceptuando la fabricación de muebles.
26. Fabricación de muebles y accesorios.
27. Fabricación de papel y productos de papel.
28. Imprentas, editoriales e industrias conexas.
29. Industria del cuero y productos de cuero, exceptuando del calzado.
30. Fabricación de productos de caucho.
31. Fabricación de sustancias y productos químicos.
32. Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón.
33. Fabricación de productos minerales no metálicos, exceptuando los derivados del petróleo y del carbón.
34. Industrias metálicas básicas.
35. Fabricación de productos metálicos, exceptuando maquinaria y equipo de transporte.
36. Construcción de maquinaria, exceptuando maquinaria eléctrica.
37. Construcción de maquinaria, aparatos, accesorios y artículos eléctricos.
38. Construcción de material de transporte.
39. Industrias manufactureras diversas.

División 4. Construcción:

40. Construcción.

División 5. Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios:

51. Electricidad, gas y vapor.

52. Abastecimiento de agua y servicios sanitarios.

División 6. Comercio:

61. Comercio al por mayor y al por menor.

62. Bancos y otros establecimientos financieros.

63. Seguros.

64. Bienes inmuebles.

División 7. Transportes, almacenaje y comunicaciones:

71. Transportes.

72. Depósito y almacenaje.

73. Comunicaciones.

División 8. Servicios:

81. Servicios gubernamentales.

82. Servicios prestados al público y a las empresas comerciales.

83. Servicios de esparcimiento.

84. Servicios personales.

División 9. Actividades no bien especificadas:

90. Actividades no bien especificadas.

Evolución de la seguridad social en Europa

Benjamín González Roaro, director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en su libro *La seguridad social en el mundo* analiza la situación de los países del viejo continente:

Algunos países han optado por consolidar sus legislaciones en un sistema único de seguridad social y, además, existe la tendencia de dar más competencias y responsabilidades financieras a las autoridades regionales y, particularmente, a las locales para administrar algunas áreas de la seguridad social, en especial las de salud y asistencia social. En otros países, se tiende a incrementar la universalización de las prestaciones financiándolas con los impuestos, siendo los pensionistas el principal objetivo.- En general, los países europeos han establecido una relación más estrecha entre las cotizaciones efectuadas y el nivel de las prestaciones que pueden otorgarse. Por otra parte, muchos han modificado sus sistemas para tratar de prevenir los riesgos sociales (desempleo, incapacidad laboral) y para restablecer al trabajador en su situación anterior mediante la búsqueda asistida de trabajo o la rehabilitación.- La política anterior, llamada "proactiva", se sigue con particular intensidad en países como Dinamarca, Finlandia y Reino Unido. Su resultado ha sido la disminución de la jubilación anticipada, el aumento de la edad de jubilación y requisitos más severos para el otorgamiento de las pensiones, como exigir un período de cotización o una vida laboral mayores (Bélgica, Italia, Finlandia y Portugal). Por otra parte se han incrementado las iniciativas para mejorar la oferta de empleo, especialmente para trabajo menos calificado y menos retribuido. A los

empleadores que proporcionen esos puestos de trabajo se les reducen las cotizaciones sociales. Por su parte, Dinamarca y Suecia han utilizado estímulos económicos para mantener a la población trabajando por más tiempo.¹⁹

Como reflexión final en cuanto a la seguridad social europea, el mismo autor escribe:

Del estudio emprendido, salta a la vista que en los países de la Unión Europea todos los rubros de la seguridad social están ampliamente cubiertos, sobre todo en cuanto a los derechohabientes del seguro social, y el resto de la población, mediante el sistema universal, ambos parte de la seguridad social. Entre los primeros, además de los asalariados, están incluidos trabajadores del mercado laboral independiente, trabajadores domésticos, estudiantes, aprendices, amas de casa, personas con discapacidad, desempleados por enfermedad o por falta de capacitación y trabajadores en el extranjero. Entre los segundos se encuentran personas de la tercera edad con bajos ingresos, indigentes, mujeres que por atender a los hijos no alcanzaron a reunir los requisitos para obtener una jubilación, mujeres solas de edad avanzada y residentes extranjeros.- No cabe duda de que una de las principales preocupaciones de los países industrializados es cómo hacer frente a las presiones ejercidas en los sistemas de ingresos para el retiro por la baja en el índice de natalidad (menos trabajadores en activo cotizantes) y la mayor longevidad (más años de pago de pensiones). Esto aunado al retiro anticipado.²⁰

Resulta importante analizar los diversos sistemas implantados en Europa, ajenos a las cuentas individuales, con presupuestos en seguridad social superiores e independientes de los presupuestos oficiales de los gobiernos. En Francia, a fines de 2007, el gobierno francés propuso una legislación para incrementar la edad de jubilación a los 65 años, con gran resistencia de los trabajadores que paralizaron los servicios públicos de algunas ciudades. En España, las Cortes determinaron incrementos en las pensiones por cada año en que los trabajadores continuaran laborando, sin aumentar las aportaciones.

El seguro social en América

En Estados Unidos de América, bajo la presidencia de Franklin Delano Roosevelt, en 1935 se aprobó el Social Security Act; por primera vez se usó el nombre de *seguridad social* para considerar, además de la atención a los riesgos a los trabajadores y su familia, que se habían difundido en Europa, disposiciones

¹⁹ Benjamín González Roaro, *La seguridad social en el mundo*, Siglo XXI, México, 2003, p. 55.

²⁰ *Ibidem*, p. 71.

sobre educación, vivienda, trabajo y desocupación en el trabajo, con un carácter universal para todas las personas y no sólo para los nacionales. “Este documento se constituyó en la base, a partir de la cual, se comenzaron a aplicar los subsidios para los desempleados, los cuales pasaron a integrar el New Deal, una suerte de nuevo Pacto Social, propuesto por dicho Presidente.”²¹ En efecto, como apunta el maestro Gustavo Cazares García:

En Estados Unidos de Norteamérica a raíz de la crisis económica de 1929, y juntamente con los pronunciamientos de la Carta del Atlántico de 1931, la Declaración de Filadelfia de 1944... la seguridad social se consolidó como el sistema de protección por excelencia de las consecuencias de los riesgos a que se encuentra expuesto el hombre en el transcurso de su vida y como uno de los principales instrumentos de la política social del Estado, al grado de darle el nombre de Estado benefactor, observando dicho sistema grandes progresos a nivel mundial, hasta la década de los años setenta del siglo pasado.²²

Conferencia Interamericana de Seguridad Social

En el empeño por seguir los pasos de Europa y extender los beneficios a los diversos y heterogéneos grupos sociales, para darles carácter de universalidad, los países de América, conformaron la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Antes de la reforma de 1995-1997 llevada a cabo en México, se celebraron 15 Conferencias Internacionales.²³ En 1942, en Santiago de Chile se estableció un programa “de acción concertada de los organismos de seguridad social, en resguardo del capital humano –garantía de la mayor integridad y defensa continental”. Este proyecto expresado en la creación de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social marca un hito en la evolución del seguro social en América, que “precede al establecimiento generalizado de los seguros sociales y proyecta en la actualidad la imagen de un organismo internacional vigoroso que agrupa a las instituciones de 33 países en el Continente”. En esta Conferencia se creó el Centro Interamericano de Seguridad Social. Con posterioridad, México ofreció la sede de ambos organismos y la Presidencia de la Conferencia se ha confiado al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social; para la Dirección del Centro se han elegido destacados especialistas en la materia.

21 Sergio Tomás Massa y Miguel A. Fernández Pastor, *De la exclusión a la inclusión social. Reformas de la reforma de la seguridad social en la República Argentina*, Telam, Prometeo Libros, Buenos Aires, 2007, p. 36,

22 Gustavo Cazares García, *op. cit.*, p. 22.

23 *50 Años de Resoluciones de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. 1952-1992*, Conferencia Interamericana de Seguridad Social, Documento Conmemorativo, 1992, p. 3.

La segunda Conferencia se celebró en Río de Janeiro, Brasil, en 1947; la tercera en Buenos Aires, Argentina, en 1951; la cuarta en México, en 1952; la quinta en Caracas, Venezuela, en 1955; la sexta en México, en 1960; la séptima en Asunción, Paraguay, en 1964; la octava en Panamá, en 1968; la novena en Quito, Ecuador, en 1971; la décima en San Salvador, en 1974; la decimoprimer en México, en 1974; la decimosegunda en Santo Domingo, República Dominicana, en 1980; la decimotercera en Panamá, en 1983; la decimocuarta en Managua, Nicaragua, en 1986; la decimoquinta en San José, Costa Rica, en 1989.

En la cuarta Conferencia, celebrada en México en 1952, se adoptaron diversas resoluciones; la relativa a la incorporación de los trabajadores del campo; así como a las prestaciones familiares, los problemas médico farmacéuticos, la terminología de la seguridad social, la incorporación de trabajadores organizados en forma comunitaria y la concesión del derecho de voto a los representantes obrero-patronales. En 1974, en la ciudad de México durante la decimoprimer Conferencia se reconoce: "Que la evolución de la seguridad social en las Américas, revela tendencias y logros en la búsqueda de mecanismos que permitan la incorporación voluntaria de sectores de la población con capacidad contributiva, la ampliación de la cobertura de aseguramiento hacia personas de escasos recursos, así como la introducción de programas de solidaridad social dirigidos a los marginados."²⁴ En la decimoquinta conferencia en San José, "reconoce que, no obstante el fortalecimiento de la Seguridad Social en América, aún persisten problemas que permiten apreciar que el horizonte del siglo XXI, seguirá recibiendo el impacto de distintas fuerzas económicas y sociales, caracterizando, la dimensión del reto a superar y poniendo a prueba la capacidad de respuesta de sus instituciones", por lo que "reitera que, nunca antes los retos fueron mayores ni las promesas más amplias, ya que las expectativas sobre la seguridad social, le confieren un gran compromiso para que el temor y la incertidumbre desaparezcan del horizonte de nuestras comunidades". Se insiste en que "la autonomía del Derecho de la Seguridad Social debe buscarse dentro de la unidad esencial del derecho partiendo del principio de que autonomía no es sinónimo de independencia de las otras ramas jurídicas. Asimismo la posibilidad de predicar esta disciplina jurídica, depende de que tenga contenido material propio, constituido por un conjunto orgánico de relaciones jurídicas que, por su naturaleza y los efectos que producen, se pueden reducir a unidad conceptual y por lo tanto no encuentran mejor definición en otras disciplinas jurídicas".²⁵ Es de destacar que las recomendaciones formuladas en las Conferencias se proponen la extensión de los seguros sociales, la unificación de los sistemas, la financiación de los programas, para lo cual se reconoce la eficacia de los procedimientos seguidos en México; el

24 *Ibidem*, p. 85.

25 *Ibid.*, p. 273.

especial cuidado a los estudios actuariales, la universalización de los cuidados a la salud y el fomento de la enseñanza generalizada de la seguridad social como una materia que debe implantarse en las universidades.

Las reuniones posteriores a 1980, año en que se implantó en Chile el sistema de cuentas individuales, hasta la Decimoquinta Conferencia, se abstuvieron de analizar ese sistema. La resolución número 112 adoptada en San José, Costa Rica en 1989, bajo la denominación "Retos y perspectivas económicas de la seguridad social", recomienda a los países miembros emprender "un decidido esfuerzo para extender la cobertura dentro de sus posibilidades, a la mayor población posible (*sic*), otorgando las prestaciones adecuadas" y dictar "las medidas correctivas para garantizar el equilibrio financiero de los programas", así como realizar "una decidida acción para la inversión más productiva de las reservas".

Modificación al sistema de pensiones

República de Chile

El Sistema de Fondos de Pensiones, establecido en la República de Chile por el Decreto Ley No. 3,500 del 13 de noviembre de 1980 y puesto en operación en mayo de 1981, por recomendación del Banco Mundial, establece el sistema de cuentas individuales; esto captó de inmediato la atención de los gobernantes de los países de economías emergentes, por la acelerada acumulación de recursos, frente a las débiles economías, lo que permitió su paulatina implantación. Eduardo Miranda Salas y Eduardo Rodríguez Silva, importantes funcionarios de la Superintendencia de Seguridad Social en Chile, escriben:

Sistema de Fondos de Pensiones, establecido en Chile por Decreto Ley No. 3,500 del 13 de noviembre de 1980 y puesto en operación en mayo de 1981... rompió el concepto tradicional chileno de Seguridad Social colectiva, para incorporarse al naciente modelo de economía de mercado, donde la capacidad del individuo para enfrentar los riesgos sociodemográficos depende, principalmente, de la generación de sus propios ingresos y del espíritu de ahorro y previsión para hacer frente al devenir.- Hemos tenido la oportunidad de conocer muy de cerca ambos sistemas: el de Seguridad Social, que por más de medio siglo estuvo asociado al desarrollo del país y de su población, y ahora el de Fondos Individuales de Pensiones, que además de responder a los principios de mercado, contribuye mediante sus mecanismos financieros a impulsar el ahorro y la inversión nacional.- Esta circunstancia favorable nos hace estar ubicados en una buena posición técnica para evitar todo sesgo de entusiasmo extremo, como el que con frecuencia se escucha o se lee en distintos medios, o exagerar críticas inmedatistas formuladas

por el solo hecho de que el nuevo sistema haya incorporado metodologías operacionales distintas y se le vea estrechamente vinculado al sector financiero.²⁶

Los distinguidos autores destacan:

El examen analítico del nuevo Sistema de Fondos de Pensiones muestra con claridad que, sin perjuicio de los muchos elementos favorables que contiene, le faltó una reflexión conceptual más profunda para prever las múltiples implicaciones riesgosas de orden social y financiero que el modelo adoptado conlleva. Todo hace pensar que la reforma de Seguridad Social fue incorporada a la legislación social sin un estudio actuarial acabado y sin ponderar suficientemente los aspectos socio-demográficos que fluyen de sus mecanismos operacionales. En todo momento primó lo financiero como rasgo distintivo de la relación afiliado-beneficio, sin tener debidamente en cuenta las características laborales, socioeconómicas, educativas y ambientales de la población. Esto hace que el sistema, transcurridos más de doce años desde su implantación, requiera de un reestudio técnico en lo financiero-actuarial y multisectorial en lo participativo. Este estudio, de realizarse, demandará una más amplia información estadística de la que está disponible por el momento, lo que exigirá se diseñe un sistema de información basado en objetivos y metodologías claras, que entregue datos útiles a estos propósitos... Sostiene el modelo que el desarrollo de la economía y el incremento constante de la productividad se traducen en una elevación del nivel de las remuneraciones del trabajo, lo que permite a los individuos precaverse contra sus propias necesidades. La calidad y cuantía de las prestaciones para resolver con efectividad las necesidades individuales se define que están en función de sus ingresos, de manera que sólo los rezagados en esta dinámica económica requieren de la contribución solidaria de la comunidad... El actual régimen de Fondos de Pensiones constituye, en el hecho, un seguro privado, aun cuando contiene aspectos que lo acercan ligeramente a un seguro social... Los Fondos de Pensiones son administrados por instituciones privadas que los invierten en el mercado financiero, de acuerdo a regulaciones establecidas por la ley, con el propósito de producir intereses y utilidades que vayan incrementándolos constantemente. Los ahorros acumulados en las cuentas personales que constituyen los fondos de pensiones son individuales y de propiedad del afiliado, aun cuando éste no puede utilizarlos sino en aquellos fines que autoriza la ley, esto es, las rentas previsionales. Existe, por tanto, una relación directa entre el fondo individual de pensión y el valor de la prestación futura, calculada de acuerdo a las reglas del mercado de los seguros privados.²⁷

26 Eduardo Miranda Salas y Eduardo Rodríguez Silva, *Análisis del sistema de fondos de pensiones. Perspectivas e interrogantes*, Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 1997, pp. 9 y sigs.

27 *Ibidem*, pp. 22 y sigs.

El sistema chileno motivó interés en los estudiosos de la seguridad social, y a los economistas y actuarios nos unimos los abogados; la bibliografía es numerosa. Se elaboraron proyectos de reformas legales y los parlamentos modificaron las normas para establecer, con las modalidades propias a sus condiciones, el sistema de cuentas individuales, atraídos por la ventaja de obtener recursos financieros. Los organismos internacionales privados, dueños de las aseguradoras y de los bancos, presionaron para administrar el capital pensionario de los trabajadores, con el señuelo de invertir una buena parte en la compra de papel gubernamental.

Reforma en Argentina

Es importante, a este respecto, la obra de los argentinos Sergio Tomás Massa y Miguel A. Fernández Pastor; el primero director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social, y el segundo, gerente de normatización de prestaciones y servicios de la Administración Nacional de la Seguridad Social, en relación con el sistema adoptado en Argentina. Estos autores, en el capítulo VI denominado "Un coctel explosivo", afirman:

Los sistemas previsionales son estructuras normativas complejas, razón por la cual no siempre una ley refleja en plenitud lo que se pretende. Se puede esperar un resultado y obtenerse uno distinto al pretendido. Por eso nunca se logra esa transformación, ya sea en un sentido o en otro, con una sola ley. Por ello, lo más importante cuando se quiere desandar el camino es desentrañar la "lógica" del sistema o el sentido profundo o teleológico de la ley que se intenta modificar.- La reforma de los '90 no escapó a esa lógica, no se hizo como algún distraído puede creer sólo con el dictado de la Ley 24.241. Formó parte de un proceso que incluyó además de dicha norma, a las Leyes 24.347 y 24.463, infinidad de decretos de necesidad y urgencia (DNU's) y decretos reglamentarios que, en vez de reglamentar, en verdad legislaron, incluso en contra de lo que decía la ley... La ley madre, como también éstas normas enunciadas, revelan con toda claridad la "lógica" de la reforma que no era otra que el abandono del Estado de la manda constitucional del Artículo 14 bis y por ende el traspaso de dicha obligación a manos privadas... Para instrumentar el traspaso tenía que superarse algunos "escollos". Entre ellos, cómo resolver lo que se dio en llamar el "stock" del sistema, que no era otra cosa que el pago de los beneficios de los jubilados anteriores a la reforma; cómo resolver la enorme litigiosidad que generaba la nueva ley al vulnerar los derechos adquiridos con prioridad a ella, y cómo resolver el enorme agujero financiero que generaba el cambio.- Para resolver estos dilemas, además de la creación de impuestos y del endeudamiento internacional consabido, descargó una serie de leyes, decretos, decretos de necesidad y urgencia, resoluciones y reglamentaciones que transformaron de cuajo el sistema... Como siempre, quienes perdieron fueron los más vulnerables, aquellos de menores recursos, ya que para acceder a la justicia son

necesarias tres condiciones: saber que se tiene derecho, tener capacidad económica para afrontar los gastos del juicio y que el reclamo tenga un contenido económico que haga que un profesional se interese en el caso... La privatización del sistema previsional argentino significó la transferencia del aporte personal de los trabajadores adheridos al régimen de capitalización desde el Estado hacia las AFJP... El déficit generado por el traspaso de los fondos públicos a las AFJP significó el crecimiento de la deuda pública, tanto externa como interna... Para ello se optó por presionar a las mismas para adquirir los bonos del Estado, fuesen éstos en pesos o en monedas extranjeras. De hecho, en el régimen de creación de las AFJP ya se habían establecido las normas por las cuales éstas podían colocar sus tenencias dinerarias en papeles públicos... Para las AFJP ello no implicó riesgo alguno, ya que las colocaciones no se hacían con los fondos propios sino con los correspondientes a las cuentas capitalizables de sus afiliados.²⁸

Situación en Brasil

A propósito de este país, el doctor Luis José Martínez Villalba, Director del Centro Interamericano de Seguridad Social, decía:

La reforma previsional en Brasil es una expresión de continuidad de todo un rico proceso político que en el siglo XX no ha estado, por cierto, exento de tormentas, de enfrentamientos fraticidas, de lutos y de dolores. Así fue y sí es ese Brasil vigoroso y fermental, ejemplificado en Getulio Vargas bajo cuya conducción se establecieron las primeras grandes políticas sociales del país. En los años treinta precisamente, la seguridad social brasileira se va constituyendo, y es para los años siguientes al 60 cuando se establecen las primeras legislaciones para los trabajadores del campo.- Toda esa evolución política, ideológica, sociológica, histórica, del Brasil trasciende en los tiempos actuales en la consolidación de su democracia. Allá por el 80 se funda el Partido de los Trabajadores y poco después la Central Única de Trabajadores del Brasil, y hoy un líder sindical salido de una fábrica paulista es el Presidente de la Nación. Aquel San Pablo industrial que en los sesenta incorporó la metalúrgica y la fabricación de automóviles a su tradicional industria textil, y que es también uno de los centros de mayor atracción y de mayor peso en el escenario económico y social del Continente.²⁹

28 Sergio Tomás Massa y Miguel A. Fernández Pastor, *op. cit.*, pp. 155 y sigs.

29 41 Aniversario 1963-2004. Conferencia Magistral Conmemorativa: "La reforma provisional en Brasil y los retos pendientes", 31 de mayo de 2004, Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social, p. 9.

En su conferencia magistral, el doctor Helmut Schwarzer, Secretario de Previsión Social de la República Federativa del Brasil, el 31 de mayo de 2004, recuerda:

Por nuestra parte, entendemos que no es bueno hacer innovaciones tan profundas. Nosotros aprovechamos de cierta forma también la experiencia de otros países de América Latina que implementaron regímenes basados en la capitalización individual, por ejemplo Chile y Argentina, también México, y donde hoy una gran parte de la discusión es sobre cuál es el rol del Estado en esos regímenes, cómo se puede incrementar la cobertura de esos regímenes y generalmente, la conclusión es: es necesario que exista un rol más activo del Estado. Nosotros queremos llegar a un modelo de previsión social donde tenemos un primer pilar básico de previsión pública que tenga una cierta fuerza, el tope tiene que ser representativo, no puede ser por ejemplo como en Argentina donde el tope de la pensión básica universal es extremadamente bajo, y exactamente eso es la discusión momentánea también en Argentina. Nosotros queremos en el pilar básico una administración cuatripartita del sistema, financiación por reparto y financiación mixta con contribuciones y recursos del presupuesto general, pues existen los elementos de redistribución del ingreso que tienen que ser mantenidos incluso en algunas situaciones profundizados, así como solidaridad e inclusión... Un segundo pilar... consiste en un sistema complementario basado en fondos privados, ya bastante amplio, que es voluntario. Tenemos entidades privadas y públicas en ese sector. Son fondos de pensiones complementarios basados en el régimen de capitalización donde la contribución es definida y la relación entre contribuciones y beneficios, es decir las prestaciones que se generan, es estrecha... Además, otras formas de complementación que sean voluntarias, y la asistencia social coordinada con ese sistema para las personas que la requieran, pensiones no contributivas para ancianos y portadores de deficiencia bajo la línea de la pobreza... Expandir la cobertura previsional, es decir un proceso de inclusión social, es un asunto sumamente importante en el programa de gobierno del Presidente Lula. A este respecto pensamos que una parte de las personas que no participan en la previsión social pero podrían hacerlo en función de su ingreso, tal vez no lo hagan pues no tienen información suficiente sobre la importancia de la previsión social y eso exige un programa de educación previsional. El segundo punto es la fiscalización, el control más riguroso sobre aquellos que no formalizan a sus empleados. El tercer punto es una consecuencia de las mejoras gerenciales que probablemente tendremos pronto, es el aumento de la credibilidad del sistema. Nosotros tenemos que reconocer que nuestros sistemas públicos de previsión podrían ser mejor administrados y necesitan por eso también una mayor credibilidad en la población. Finalmente, existen, en efecto, barreras cuya superación sólo se torna posible con cambios en reglas de acceso... Desafortunadamente no existe una sola propuesta mágica para hacer la inclusión social o para expandir la cobertura, eso también tiene que quedar claro para nosotros. El cambio de financiación puede ser uno de los instrumentos,

cambio que en la estructura de las contribuciones de los trabajadores por cuenta propia... Es necesario en ese caso asignar algún subsidio público, algo que estamos evaluando, estamos haciendo los cálculos, pero sabemos que hay que disminuir esa contribución a cargo del trabajador por cuenta propia.³⁰

El libro de González Roaro hace un análisis comparativo de la situación en los países de América, a propósito de las pensiones:

... algunos países registran diferencias en las edades de los hombres y las mujeres para ser acreedores a la pensión por vejez: la Argentina, el Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, El Salvador, Honduras, Jamaica, Panamá, el Perú y Venezuela. En estos, las edades fluctúan entre 55 y 60 años para las mujeres y 65 para los hombres. En cambio, los veintiséis restantes requieren la misma edad, entre 55 y 65, para ambos sexos. El monto de las pensiones por vejez se calcula, en la gran mayoría de los países, sobre las bases de un porcentaje del salario asegurable o del promedio de ingresos, condicionado a distintas modalidades en cuanto al tiempo de servicios o al número de cotizaciones. En el caso de los sistemas mixtos, se anota el porcentaje del régimen público, ya que en el privado se entrega el monto de las cotizaciones acumulados (suma global intereses). Se destaca que Chile y Bolivia son los países en los que únicamente funciona el sistema privado. Como casos excepcionales se encuentran la Argentina y el Canadá, cuyos montos varían según el régimen; los Estados Unidos, que se basan en el promedio de ingresos posteriores a 1950, hasta 62 años de edad o el fallecimiento; Bermudas y Jamaica, que sólo otorgan una cantidad fija semanal; y Venezuela, que, además del porcentaje, otorga también una cantidad fija mensual.³¹

Los países de América Latina se encuentran en revisión de sus sistemas de seguro social, ante el fracaso de las cuentas individuales, para conformar estructuras con base en diferentes pilares, sin desechar estas cuentas, pero en un reencuentro con los principios de solidaridad y de reparto. La situación económica actual impide generar empleos, incrementar salarios y, en consecuencia, disminuye o hace nugatoria la posibilidad de ahorro. Al respecto es importante tener en cuenta el estudio realizado por los argentinos Nelda E. Acuña, Pablo C. Arias, Axel Cantlon, Gustavo Daniel Gioia, Jorge Isaac D'Ángelo y Jorge Alfredo Gamietea, que resume la situación de estos países, en relación con el sistema de las cuentas individuales:

Paradójicamente, estas reformas no han solucionado ni modificado algunas cuestiones, que hacen a los factores de riesgo en la ss, como los postulados que indujeron aparentemente a la reforma:

30 *Ibidem*, p. 27.

31 Benjamín González Roaro, *op. cit.*, pp. 35 y sigs.

- 1) Cuando se planteó la libre opción al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, la intención fue conducir a los afiliados al régimen de capitalización en un marco privatizador, para disminuir el gasto público. Quedó evidenciada esa actitud manipuladora de la opinión pública, en el importante porcentaje de beneficiarios cautivos dentro del sistema de capitalización.
- 2) La multiplicidad de regímenes especiales no se ha eliminado, hay grupos de mayor fuerza de poder tales como los legisladores, jueces, Fuerzas Armadas en Seguridad y Defensa.
- 3) Los excluidos lo siguen estando ("cuenta-propistas", sector informal, amas de casa, etcétera). La posibilidad de acceder voluntariamente al sistema ya existía en anteriores sistemas, hoy estas expectativas se encuentran disminuidas por ubicarse la protección social en una posición cada vez más lejana del principio de universalidad.
- 4) La relación aportante-beneficiario se ve agravada por factores como el envejecimiento poblacional y el desempleo, sumando a esto la disminución de afiliados al sistema cotizante.
- 5) La evasión, la declaración de ingresos inferiores a los reales y la mora se han profundizado por el trabajo no registrado, además de la retención de aportes no transferidos a los entes recaudadores. En este caso el trabajador se muestra indiferente sobre el cumplimiento por parte del empleador por temor a represalias que incidan directamente en su relación laboral.
- 6) Por otro lado, en materia de recursos y financiamiento, las cargas sociales no afectan la competitividad de las empresas. En la actualidad se han hecho fuertes reducciones y la problemática del desempleo se agravó.³²

32 Antonio Ruezga (comp.), *El nuevo derecho de las pensiones en América Latina*, Biblioteca CIESS 3, México, 2005, p. 32.

4 El seguro social en México

Primeras garantías sociales

La lucha por la independencia se caracterizó por reconocer los derechos sociales. La influencia de los enciclopedistas franceses, cuya lectura se hacía con avidez en reuniones literarias, determinó que al proclamarse la lucha contra los españoles, al lado de las incipientes e improvisadas armas, se dictaran proclamas e intentos de constituciones, en cuyos textos observamos la mentalidad adelantada para establecer los primeros derechos de protección para los trabajadores, niños y mujeres.

El Bando de Hidalgo del 6 de mayo de 1810, expedido en la ciudad de Guadalajara, abolió la esclavitud. Ignacio López Rayón, con los Elementos Constitucionales de agosto de 1822, suprimió los exámenes de artesanos. José María Morelos presentó los *Sentimientos de la Nación* ante el Congreso Constituyente instalado el 14 de septiembre de 1813. Este Congreso expidió el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, que en su capítulo octavo “De las atribuciones del Supremo Congreso”, art. 118, consignó “aprobar los reglamentos que conduzcan a la sanidad de los ciudadanos, a su comodidad y demás objetos de policía”.

La lucha entre liberales y conservadores culmina en una primera etapa en la Constitución de 1857. Los diputados constituyentes retoman los principios de la de 1824, sin reconocer los derechos de los trabajadores.

Es digno de mención que en pleno gobierno del general Porfirio Díaz, algunos estados, bajo la influencia de los movimientos de trabajadores en Europa, de los escritos socialistas, conocedores del *Manifiesto del Partido Comunista* y de la *Encíclica Rerum Novarum*, se apresuraron a expedir leyes reguladoras del trabajo; la primera en 1905 en el Estado de México, gobernado por el general Villada, establece la protección de los trabajadores frente a riesgos de trabajo.

Después del movimiento social de 1910 se fueron consagrando las leyes garantizadoras del disfrute de derechos mínimos para los mexicanos. La economía presentaba características semif feudales: un territorio repartido entre los triunfadores de las guerras y los favorecidos por un régimen que prolongó en el mando a un dictador, convertido a su vez en eje de la vida nacional. Muchos años de vasallaje derivados del atraso y la ignorancia no podían hacerse a un lado ni siquiera por las convulsiones de una guerra. No se logró una mejor distribución de la riqueza y tampoco pudo elevarse el nivel de vida de la gran población que seguía marginada en la ciudad y en el campo.

El 12 de diciembre de 1912 el presidente Venustiano Carranza expidió un decreto en cuyo artículo segundo se ordenaba la promulgación y vigencia, durante la lucha, de leyes, disposiciones y medidas encaminadas a satisfacer las necesidades económicas, sociales y políticas del país, con las reformas que la opinión pública demandara, a efecto de establecer un régimen de igualdad entre todos los mexicanos.

En 1914, al triunfo de la Revolución, se establece el principio del estado de servicio social, reconociendo su capacidad y el deber de suplir la acción económica individual, sin menoscabo de la libertad del ciudadano y la obligación de organizar a la sociedad en una estructura que permitiera la protección de los débiles frente al libre juego de las leyes económicas.

En el estado de Yucatán se dictó la *Ley del Trabajo* en 1915, cuyo art. 135 establecía que el gobierno fomentaría una asociación mutualista en la que los trabajadores fueran asegurados contra los riesgos de vejez y muerte.

Constitución de 1917

En 1916 se convocó al Congreso Constituyente, integrado con representaciones de carácter no muy definido de todos los estados de la República. El propósito de Carranza era actualizar las normas de la Constitución expedida en 1857, cuyos efectos no se habían medido a causa de las luchas internas y las presiones del extranjero. En materia de trabajo, el proyecto se apegaba al art. 5º de la Ley fundamental anterior.

La comisión dictaminadora integrada por 18 diputados analiza el art. 5º relacionado con la garantía de trabajo y justa retribución; en sus deliberaciones se destacan las legislaturas de los estados y los avances logrados en Europa, para entender que las garantías al trabajo asalariado debían consignarse en la Constitución, con lo que evitaban que el Congreso Federal y las legislaturas estatales pudieran dictar normas en contravención a la estabilidad en el empleo, a la protección de las mujeres y los menores, a una jornada laboral superior a las ocho horas, al salario remunerador mínimo a pagar en cada empresa, al derecho de coalición y de huelga. En ese precepto se determinó la protección para el trabajador en caso de accidente o enfer-

medad de trabajo (fracc. XIV), así como en alguno de estos supuestos ajenos a la actividad laboral.

En uno de sus dictámenes, la comisión encarece

... a la sabiduría de este Congreso Constituyente la alta importancia de plantear en nuestra legislación los problemas relacionados con el contrato de trabajo, toda vez que una de las aspiraciones más legítimas de la revolución constitucionalista ha sido la de dar satisfacción cumplida a las urgentes necesidades de las clases trabajadoras del país, fijando con precisión los derechos que les corresponden en sus relaciones contractuales contra el capital, a fin de armonizar, en cuanto sea posible, los encontrados intereses de éste y del trabajo, por la arbitraria distribución de los beneficios obtenidos en la producción, dada la desventajosa situación en que han estado colocados los trabajadores manuales en todos los ramos de la industria, el comercio, la minería y la agricultura.

Este documento reconoce:

No tenemos la pretensión de que nuestro estudio sea un trabajo acabado y mucho menos de que venga a aliviar por completo los penosos males sociales que afligen a nuestro país, el que teniendo grandes recursos naturales para prometerse un porvenir envidiable de bienestar y prosperidad, ha tropezado con obstáculos en su desenvolvimiento económico y está perdiendo una riqueza considerable con la emigración creciente de trabajadores a la vecina República, entre otras causas, por la carencia de una saludable legislación sobre el trabajo... Nos satisface cumplir con un elemental deber como este, aunque estemos convencidos de nuestra insuficiencia, porque esperamos que la ilustración de esta honorable Asamblea perfeccionará magistralmente el proyecto y consignará atinadamente en la Constitución Política de la República las bases para la legislación del trabajo, que ha de reivindicar los derechos del proletariado y asegurar el porvenir de nuestra patria.

El dictamen del 13 de enero de 1917, suscrito por Pastor Rouaix, Victorio E. Góngora, E.B. Calderón, Luis Manuel Rojas, Dionisio Zavala, Rafael de los Ríos, Silvestre Dorador y Jesús de la Torre, propuso incluir la fracc. XXVII dedicada a las cajas de seguros populares; el dictamen del 23 de enero la ubicó como fracc. XXIX, que con modificaciones se conserva hasta la fecha.

El diputado José Natividad Macías pronunció un memorable discurso:

Cuando el jefe supremo de la Revolución se estableció en el puerto de Veracruz, su primer cuidado fue haber dado bandera a la nueva Revolución que entonces se iniciaba; y esa bandera queda perfectamente establecida en las adiciones que al Plan de Guadalupe se hicieron el 12 de diciembre de 1914. De entre las promesas que el jefe supremo de la Revolución hacía a la República, se hallaba la de que se darían

durante el período de lucha todas las leyes encaminadas a redimir a la clase obrera de la triste y miserable situación en la que se encontraba.¹

El art. 123, en su texto original, primer párrafo y fracc. XXIX, disponía:

El Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados deberán expedir leyes sobre el trabajo, fundadas en las necesidades de cada región, sin contravenir a las bases siguientes, las cuales regirán el trabajo de los obreros, jornaleros, empleados, domésticos y artesanos y, de manera general, todo contrato de trabajo:
[...]

XXIX. Se consideran de utilidad social: el establecimiento de cajas de seguros populares, de invalidez, de vida, de cesación involuntaria de trabajo, de accidentes y otros con fines análogos, por lo cual, tanto el Gobierno Federal como el de cada estado, deberán fomentar la organización de instituciones de esta índole, para infundir e inculcar la previsión popular.

La disposición era buena pero no efectiva; carecía del entorno económico necesario para su aplicación. Las cajas de seguros populares se establecieron en algunos estados, pero la situación de guerra hacía imposible la aplicación de las normas reguladoras del trabajo y, desde luego, la implantación de los seguros sociales.

Legislaturas de los estados

Las leyes que se expidieron en los estados, a pesar de sus avances en materia laboral, tuvieron efímera aplicación. En 1919 se formuló un proyecto de *Ley del Trabajo para el Distrito y Territorios Federales* que proponía la integración de cajas de ahorro para auxiliar a trabajadores desempleados; el fondo contenía la aportación de 5% de los salarios y, por parte de los patrones, 50% de la cantidad que correspondería a los asalariados por concepto de utilidades en las empresas.

En 1921, Álvaro Obregón ordenó la elaboración del Proyecto de Ley del Seguro Social que había de aplicarse en el Distrito Federal. La exposición de motivos reconoce que las desgracias que afligen a las clases trabajadoras no habrán de tener su origen en la falta de leyes, sino en las dificultades para su aplicación, lo que convierte a los derechos legales en simples derechos teóricos, porque dejan a los trabajadores la tarea de exigir su cumplimiento; la realización tiene que desarrollarse dentro de una legislación complicada, costosa y tardía. Este proyecto preveía un tipo de seguro voluntario.

1 *Los derechos del pueblo mexicano*, Porrúa, México, 1978, p. 75.

El *Código del Trabajo* de Puebla estableció que los patrones podían sustituir el pago de las indemnizaciones por riesgos profesionales mediante seguros contratados a sociedades legalmente constituidas y aceptadas por la sección del Trabajo y Previsión Social. Una disposición similar contiene el *Código Laboral* de 1924, de Campeche, en su art. 290.

En las *Leyes del Trabajo* de Tamaulipas y de Veracruz de 1925 se consigna la modalidad del seguro voluntario. Los patrones podían sufragar sus obligaciones en los casos de enfermedades o accidentes profesionales de los trabajadores, mediante un seguro contratado a su costa con sociedades que pudieran otorgar garantía con aprobación de los gobiernos estatales. Los patrones que optaron por asegurar a sus trabajadores no podían dejar de pagar las cuotas correspondientes sin causa justificada; así, los trabajadores y las aseguradoras tenían acción para obligar al patrón por medio de juicio sumario ante la Junta de Conciliación y Arbitraje.

Las leyes laborales de Aguascalientes e Hidalgo, expedidas en 1928, previeron la instauración de seguros. La de Hidalgo, en su art. 242 disponía: "Se declara de *utilidad pública* el establecimiento de instituciones, corporaciones o sociedades que tengan por objeto asegurar a los trabajadores contra los accidentes o enfermedades profesionales, y las autoridades deberán darles toda clase de facilidades para su organización y funcionamiento."

Primeras disposiciones a favor de los servidores públicos

Paralelamente a la expedición de leyes estatales, el gobierno federal llevó a cabo los primeros intentos por establecer un sistema de seguros para los trabajadores y empleados a su servicio. En 1925 se expide la *Ley General de Pensiones Civiles de Retiro*, conforme a la cual los funcionarios y empleados de la Federación, del Departamento del Distrito Federal y de los Gobiernos de Territorios Federales tenían derecho a recibir una pensión al llegar a los 55 años de edad con 30 de servicios o cuando quedaran inhabilitados para el trabajo. En el supuesto de muerte del trabajador se confiere derecho a pensión a los beneficiarios. El financiamiento de este seguro se cubría mediante aportación del Gobierno Federal y de los empleados que generaban una especie de fondo de ahorro con posibilidad de retirarlo al dejar de trabajar, lo que implicaba la pérdida de antigüedad y derechos adquiridos, salvo reintegro que se efectuara. Se creó un organismo administrador, desconcentrado de la Secretaría de Hacienda, denominado Dirección General de Pensiones Civiles y de Retiro.

El 13 de noviembre de 1928 se estableció el Seguro Federal del Maestro, por decreto del Ejecutivo Federal, donde se ordenaba la constitución de una mutualidad con el fin de auxiliar a los deudores de los asociados fallecidos.

Reforma constitucional de 1929

En 1929 se elaboró una iniciativa que obligaba a patrones y obreros a depositar en una institución bancaria de 2 a 5% del salario mensual, con el objeto de constituir un fondo de beneficio para los trabajadores. En ese año se presenta al Constituyente Permanente la iniciativa de reforma al art. 123 de la Constitución, para consignar como facultad exclusiva del Congreso de la Unión expedir las leyes reglamentarias en materia de trabajo para toda la República. El diputado Carlos Sánchez reclamó:

Si se les quita la facultad para legislar dentro de su soberanía y no se llega a dar el Código del Trabajo Federal, si no se expide ese Código que hace más de tres años duerme el sueño del justo en el Senado de la República, van a quedar sin ninguna legislación y no se conformarán los estados, porque dentro del artículo transitorio, o en el art. 11 de la Constitución, se supediten los derechos de los trabajadores en estados como Veracruz, Puebla, Tabasco y Jalisco. ¿Por qué castigar a aquellos estados que ya cumplieron su deber?

El texto de la fracc. XXIX del art. 123 quedó como sigue:

Se considera de utilidad pública la expedición de la Ley del Seguro Social y ella comprenderá los seguros de invalidez, de vejez, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes y otros con fines análogos.

La reforma de 1959 incluyó el Apartado B para regular las relaciones laborales entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores.

En el *Diario Oficial de la Federación* del 31 de octubre de 1974, después de expedida la ley que entró en vigor el 1 de abril de ese año, se modificó el texto constitucional para dar sustento a la nueva Ley, a fin de que otros grupos ajenos a los trabajadores fueran objeto de protección:

Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicio de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares.

En conclusión, dicha reforma:

- Amplía las contingencias protegidas.
- Rompe la estructura del art. 123 dedicado a regular las relaciones entre los patrones y los trabajadores.

El Apartado B, dedicado a normar las relaciones de trabajo con los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores, estructura los principios del seguro social, los cuales se han mantenido sin cambio, en la fracc. XI:

La Seguridad Social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas:

- a) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte;
- b) En caso de accidente o enfermedad, se conservará el derecho al trabajo por el tiempo que determine la ley;
- c) Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un mes de descanso antes de la fecha fijada aproximadamente para el parto y de otros dos después del mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el período de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno para alimentar a sus hijos. Además, disfrutarán de asistencia médica y obstétrica, de medicinas, de ayudas para la lactancia y del servicio de guarderías infantiles;
- d) Los familiares de los trabajadores tendrán derecho a asistencia médica y medicinas, en los casos y en la proporción que determine la ley;
- e) Se establecerán centros para vacaciones y para recuperación, así como tiendas económicas para beneficio de los trabajadores y sus familiares;
- f) Se proporcionarán a los trabajadores habitaciones baratas, en arrendamiento o venta, conforme a los programas previamente aprobados. Además, el Estado mediante las aportaciones que haga, establecerá un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de dichos trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas, o bien para construirlas, repararlas, mejorarlas o pagar pasivos adquiridos por estos conceptos.

Las aportaciones que se hagan a dicho fondo serán enteradas al organismo encargado de la seguridad social regulándose en su Ley y en las que corresponda, la forma y el procedimiento conforme a los cuales se administrará el citado fondo y se otorgarán y adjudicarán los créditos respectivos.

Tercera parte

Las leyes del Seguro Social

5 Primeras leyes

Los cambios frecuentes de los gobiernos a principios del siglo XX y las constantes luchas internas incrementaban la desconfianza y prefiguraban el mayor obstáculo para convencer a los particulares de que el gobierno sería un administrador capaz.

A pesar de ello, la implantación del Seguro Social debía interesar a los patrones, puesto que contribuía a la tranquilidad del obrero y al aumento de su capacidad de rendimiento, así como a propiciar un mejor entendimiento entre los factores de la producción.

En 1932, el Congreso de la Unión expidió un decreto que otorgaba facultades extraordinarias al Ejecutivo Federal, a fin de que en un plazo de ocho meses se expidiera la *Ley del Seguro Social* (LSS) obligatorio, que no se pudo cumplir debido al precipitado cambio de gobierno que tuvo lugar en ese año.

El Primer Plan Sexenal de Gobierno del Partido Nacional Revolucionario disponía:

Será capítulo final en materia de crédito dar los primeros pasos para la integración de un sistema de seguros que sustraiga del interés privado esta importante rama de la economía.

En el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas se discutió el problema del Seguro Social. El Departamento del Trabajo, el de Salubridad, la Secretaría de Gobernación y la Comisión de Estudios de la Presidencia elaboraron sus respectivos proyectos para establecer el Seguro Social.

La confusión que se produjo en torno a este proyecto motivó que la *Ley General de Sociedades de Seguros* estableciera en el art. 8 transitorio: "El

Ejecutivo de la Unión dictará las medidas complementarias de la Ley que sean procedentes para establecer el Seguro Social.”

Se fue creando un ambiente de convencimiento y el art. 305 de la *Ley Federal del Trabajo* (LFT) del 18 de agosto de 1931, dispuso que los patrones pudieran cumplir las obligaciones emanadas de los riesgos profesionales, asegurando a su costa al trabajador, en lugar de la indemnización que determinaba la fracc. XIV del art. 123.

El Segundo Plan Sexenal de Gobierno, formulado por el Partido de la Revolución Mexicana, estableció:

Durante el primer año de vigencia de este plan se expedirá la Ley de Seguros Sociales, que debe cubrir los riesgos profesionales y sociales más importantes, y en cuya organización y administración debe intervenir la clase obrera organizada.

El 1 de diciembre de 1940, en su discurso de toma de posesión, el presidente Manuel Ávila Camacho manifestó:

No olvidemos que nuestros ideales de justicia colectiva están muy lejos de haberse logrado: el desempleo y los bajos salarios que existen en nuestro país reclaman las oportunidades de vivir dignamente; el hombre que tiene trabajo, necesita la certidumbre de que los beneficios de sus contratos colectivos sean permanentes y, por otra parte, todos debemos unir desde luego el propósito de que un día próximo las leyes del Seguro Social protejan a todos los mexicanos en las horas de adversidad, en la orfandad, en el desempleo, en la vejez, para sustituir este régimen secular en que por la pobreza de la nación hemos tenido que vivir.¹

El 2 de junio de 1941, en el *Diario Oficial de la Federación* (DOF) el Ejecutivo Federal dictó un acuerdo mediante el cual se ordena a cinco secretarías la elaboración de estudios encaminados a establecer el Seguro Social:

Estos anhelos y obligaciones aparecen más amplios si se considera que todos los países de Europa y aproximadamente un 90 por ciento de los pueblos del Continente Americano poseen una legislación del Seguro Social, mientras que México constituye una excepción que no es acorde con el sentido social de su movimiento popular y su evolución política y legal, con la tendencia revolucionaria de proteger al pueblo productor.

En 1942 se envió al Congreso de la Unión el proyecto de ley, el cual aprobado, se publicó en el DOF el 19 de enero de 1943; estuvo vigente, con múltiples reformas, hasta el 1 de abril de 1973.

¹ *Diario de Debates de la Cámara de Diputados*, 1 de diciembre de 1940.

Principios de la Ley de 1943

En los considerandos de la Iniciativa del presidente Manuel Ávila Camacho, que concretan sus objetivos:

1. *Protección al salario.* El salario es "la única fuente de la que los trabajadores obtienen los recursos indispensables para la subsistencia de ellos y la de sus familiares; todo hecho que implica pérdida o disminución del mismo causa a todos ellos perjuicios trascendentales... El régimen del Seguro Social representa un *complemento del salario* en la medida en que otorga prestaciones que el obrero, de otra manera, tendría que obtenerlo de su único ingreso, por lo cual constituye un excelente vehículo para estabilizar el tipo de vida de la capa económica débil de la población, estabilización a la que debe aspirarse, tanto porque su logro vendría a satisfacer nobles aspiraciones de la convivencia humana, cuanto porque al elevar las condiciones de vida del sector mayoritario de la Nación, automáticamente se operaría un crecimiento vigoroso de la economía general del país".
2. *Teoría objetiva del riesgo.* "En el desempeño de sus labores, el obrero se halla constantemente amenazado por multitud de *riesgos objetivamente creados* por el equipo mecánico que maneja o por las condiciones del medio en que actúa; y cuando tales amenazas se realizan, causando accidentes o enfermedades acarrear fatalmente la destrucción de la base económica de la familia. Lo mismo ocurre con otros riesgos no considerados como profesionales, tales como las enfermedades generales, la invalidez, la vejez o la muerte prematura, que si bien a todo ser humano amenazan, es entre los trabajadores donde mayores estragos causan cuando se realizan, por cuanto a que el hombre que no tiene otro ingreso que la retribución del esfuerzo personal que desarrolla, todo acontecimiento que paralice su actividad aniquila sus posibilidades de adquisición."
3. *Interés social.* "Si desde el punto de vista del interés particular del obrero es legítima la implantación de un sistema como el Seguro Social, que está destinado a proteger su economía familiar, también y desde el más amplio punto de vista de los intereses de la sociedad, tal medida halla una plena justificación, porque con la misma se tiende a evitar que la miseria y la angustia azoten a grandes sectores de la población nacional."

4. *Interés público.* "El Seguro Social no considera el riesgo particular de cada persona que se asegura, sino que atiende a las condiciones económicas del sector de la colectividad que trata de asegurar. Debe destacarse también que como la protección impartida por el Seguro Social entraña una función de *interés público*, *no puede ser encomendada a empresas privadas*, sino que el estado tiene el deber de intervenir, en su establecimiento y desarrollo, porque quien sufre en última instancia los riesgos de la pérdida de capacidad de trabajo de los obreros, es la colectividad entera, que con motivo de esos acontecimientos ve trastornadas sus actividades y amplificadas muchos de sus problemas."
5. *Aplicación limitada.* "El régimen del Seguro Social no es susceptible de aplicarse de un *modo general o indeterminado* a todos los individuos de la sociedad, sino exclusivamente al sector de la población formado por las *personas que trabajan mediante la percepción de un salario o sueldo...* el Seguro Social limita la protección del capital humano a los seres mas débiles económicamente, quienes, como trabajadores, contribuyen directamente a la prosperidad del país, y esta protección se hace de forma proporcional al servicio creador prestado por ellos, o sea, en relación con el monto de su salario, su antigüedad, etcétera."
6. *Servicio público.* "Como en la conservación de las energías productivas no sólo va de por medio el derecho del asalariado, sino también el beneficio de los empresarios y el interés todo de la colectividad, compete al Estado encauzar el Seguro Social como un *servicio público* encomendado a un Instituto descentralizado que, con la aportación oficial, de los trabajadores y la de los patrones acuda prestamente a cumplir la responsabilidad económica que nace de la solidaridad nacional."
7. *Carácter obligatorio.* "Debe establecerse con el carácter de obligatorio, para garantizar la estabilidad y la permanencia del sistema, y también para extenderlo al mayor número posible de las personas que deben quedar comprendidas en él... El carácter obligatorio del Seguro Social hace imposible el hecho que la falta de previsión y, más concretamente, la falta de pago de primas, ocasione, como ocurre en los seguros privados, la pérdida de los derechos del asegurado, pues *el aseguramiento y el pago de cuotas es forzoso.*"
8. *Seguros.* "La iniciativa considera comprendidos dentro del Seguro Social los siguientes riesgos: accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, enfermedades generales y maternidad e invalidez, vejez y muerte. Igualmente considera asegurada, con las limitaciones a las que a su tiempo se hará referencia, la desocupación en edad avanzada."

9. *Facultad de Ejecutivo.* "... se deja al Poder Ejecutivo la *facultad de determinar las fechas y las circunscripciones territoriales* en que se implantarán los diversos ramos del seguro, así como los grupos de trabajadores a que se vaya haciendo extensivo. Tal determinación será hecha a propuesta del Instituto que especialmente se crea, según lo aconsejan las condiciones de situación geográfica, densidad de población asegurable, desarrollo industrial y posibilidad de establecer los servicios respectivos."
10. *Crecimiento.* "... comprenderá desde luego sólo a los trabajadores que presten servicios en empresas privadas estatales, de administración obrera o mixtas, a los miembros de sociedades cooperativas de producción y a los aprendices especiales contratados con ese carácter para extenderse posteriormente a los trabajadores del Estado, de empresas de tipo familiar y a domicilio, del campo, de los domésticos, los temporales y los eventuales."
11. *Cooperativas.* "Quedan incluidos los miembros de sociedades cooperativas de producción, porque aunque no tienen las características jurídicas de los obreros asalariados, sí pertenecen al mismo sector de los económicamente activos y, agrupados como están en unidades de trabajo establecidas para el aprovechamiento de una fuente de producción o para la transformación de materias primas en determinadas ramas industriales, no presentan las dificultades prácticas que otros trabajadores, colocados en diferente situación, ofrecerían al ser considerados, desde el primer momento, sujetos al sistema."
12. *Clasificación por riesgos.* "El elemento riesgo objetivo es primordial para hacer la fijación de las cuotas que deben cubrir los patrones... Este riesgo objetivo es determinado por el método y el procedimiento de trabajo de la empresa, por la maquinaria empleada y especialmente por los medios técnicos de protección y prevención de los accidentes. Esta inscripción hará posible una clasificación previa basada sobre experiencias mexicanas y extranjeras, tomadas del Seguro de Accidentes de otros países, especialmente sobre las experiencias de Chile. También puede ser aprovechado con mucha ventaja el material estadounidense y canadiense del Seguro Privado, y su análisis en los *Proceeding of Casualty Actuarial Society*. En ocasión de la clasificación debe ser fijada también la unidad de tarifa, con base en el nuevo material. Si se elige para la clasificación de los riesgos el método más empleado que da a la categoría de empresas más peligrosas el porcentaje 100, se clasifican las empresas normales de una clase por un porcentaje medio de esta clase, y solamente si hay condiciones anormales, ya sea en favor

de la empresa, ya sea por falta de medios para prevenir el accidente, pues hay circunstancias que aumentan o reducen el riesgo, se concede a las empresas un porcentaje o grado más alto o más bajo. En la primera formación de las clases y de los grados o porcentajes de riesgo, debe tenerse en cuenta el principio de que la empresa o la categoría de las empresas deben pagar aproximadamente una aportación total que cubra todas las obligaciones provenientes de accidentes, esto es, teniendo en cuenta la diferencia entre prestaciones temporales y rentas vitalicias. Con esto se consigue que haya un equilibrio entre las clases y grupos de empresas, y se impide que las clases o grupos que permanentemente son pasivas, trasladen una parte de su carga a las otras."

Reformas a la Ley de 1943

Los propósitos fundamentales de las reformas eran los siguientes:

- a) *Crecimiento horizontal.* El enemigo de la eficiencia es el crecimiento desmedido de la población protegida, sin contar con las bases suficientes para otorgar prestaciones y mantener niveles de calidad; en los primeros años el incremento de la población protegida se llevó a cabo mediante la incorporación paulatina de zonas, conforme a las posibilidades que la propia institución hacía factible.
- b) *Crecimiento vertical.* Se cuidó mejorar las condiciones para el otorgamiento de las prestaciones e incrementar el monto de las otorgadas a fin de mantenerlas atractivas, de tal forma que permitieran al imposibilitado para trabajar, a la viuda y a los huérfanos contar con recursos suficientes para atender sus necesidades de vida.
- c) *Adecuar grupos de cotización a las circunstancias económicas variables.* Con lo que se aumentaban las posibilidades financieras de la institución.

Algunas de las reformas más importantes que el Congreso de la Unión llevó a cabo fueron las siguientes:

- De diciembre de 1947 y 3 de febrero de 1949, promovidas por el presidente Miguel Alemán Valdés.
- De diciembre de 1956, presentada por el presidente Adolfo Ruiz Cortines.
- De diciembre de 1959, proyectada por el presidente Adolfo López Mateos.
- De diciembre de 1965, propuesta por el presidente Gustavo Díaz Ordaz.

Reformas constitucionales

Texto inicial 1917

Se considera de utilidad social: el establecimiento de cajas de seguros populares; de invalidez, de vida, de cesación involuntaria de trabajo, de accidentes y otros, con fines análogos, por lo cual, el Gobierno Federal como el de cada Estado, deberán fomentar la organización de instituciones económicas de esta índole, para infundir e inculcar la previsión popular.

Reforma 1929

Se considera de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes y otros con fines análogos.

Reforma 1974

Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicio de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares.

La Ley de 1973

Los 30 años del sistema de solidaridad y reparto permitieron la captación de importantes recursos; el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se convirtió en la primera institución médica del país, las clínicas y los hospitales estaban dotados de los instrumentos adecuados para otorgar servicio a los derechohabientes, su prestigio trascendía las fronteras y superaba a las organizaciones particulares; las prestaciones económicas eran adecuadas. Las guarderías atendían a los hijos de las mujeres trabajadoras; se habían creado centros de bienestar social y familiar, en los que además del esparcimiento, se impartían cursos de preparación técnica para el trabajo. La atinada dirección de Ignacio García Téllez en los años cuarenta, después del fracaso del primer responsable, Vicente Santos Guajardo, tuvo una adecuada continuidad con Antonio Ortiz Mena. Desde luego, la captación de recursos hacía atractiva su desviación, no siempre en obras de beneficio social y se convirtió en botín

político que hizo pensar a Benito Coquet en la posibilidad de buscar la Presidencia de la República; Saltiel Alatríste, efímero director del Instituto, en la década de los años sesenta pretendió poner orden en las finanzas y limitar las acciones a las directamente relacionadas con los objetivos, eliminando las obras suntuosas y las desviaciones, el problema político que generó obligó al presidente Gustavo Díaz Ordaz a sustituirlo con el doctor Ignacio Morones Prieto, en esa época embajador en Francia, quien llegó acompañado de un grupo de jóvenes, entre los cuales figuró como Secretario del Instituto Porfirio Muñoz Ledo; entre sus primeras medidas dictó la supresión del Departamento de Inspección y mantuvo el prestigio médico. Los que nos habíamos iniciado unos meses antes fuimos sometidos a una revisión rigurosa como condición necesaria para continuar; por mi parte, que había iniciado la labor en ese Departamento de Inspección, quedé adscrito en la Subdirección Jurídica, como dictaminador de pensiones, hasta mi elección, en 1967, como Diputado Federal.

En el gobierno del presidente Díaz Ordaz la situación del país presentaba un crecimiento sostenido promedio superior a 6%; el campo permitía la captación de ejidatarios, colonos, comuneros y pequeños propietarios; los no asalariados reclamaban el acceso a los servicios. En ese panorama, el presidente Luis Echeverría Álvarez dispuso la elaboración de estudios a fin de estructurar un sistema más amplio, basado en los principios de solidaridad y de reparto, que daban fortaleza al seguro social y permitían un crecimiento horizontal para atender a los grupos sociales de las ciudades y del campo en marginación económica y social, sin demérito de las prestaciones debidas a los trabajadores y a su familia.

El presidente Echeverría Álvarez confió la administración del Instituto a Carlos Galvez Betancourt, hombre de experiencia y visión política, quien con base en los estudios elaborados presentó a la cuadragésima octava legislatura del Congreso de la Unión la iniciativa de la LSS, en la cual incluyó las reformas que atenderían el reclamo de los grupos sociales ajenos a los trabajadores. Se amplió, en el art. 12 la obligatoriedad de inscripción a los trabajadores, al comprender a los miembros de sociedades cooperativas de producción y a los determinados en decretos presidenciales; se fortaleció el régimen voluntario, para los grupos campesinos, trabajadores domésticos, no asalariados y patrones personas físicas, quienes harían aportaciones adecuadas a su condición económica. Como una novedad incluyó la figura de los solidariohabientes a fin de brindar atención médica a los marginados, con la intención de incorporarlos al desarrollo general. Amplió las facultades fiscales de la Institución, de manera compartida con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dependencia que tendría a su cargo la atribución sancionadora. Sin embargo, se olvidó de ampliar el marco necesario en la Constitución, por lo que en diciembre de 1974 se envió el proyecto al Congreso para incluir, como se ha visto, a los grupos

sociales de campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares, en la forma actualmente vigente. Es lamentable que a pesar de las reformas no se contuvieran las atribuciones y obligaciones del Ejecutivo Federal, tanto administrativas como reglamentarias.

La exposición de motivos del presidente Echeverría señala:

El régimen del Seguro Social ha contribuido a la expansión económica mediante el mejoramiento de las condiciones de vida del trabajador y la reducción de las tensiones laborales y, asimismo, ha coadyuvado a disminuir los resultados negativos de la industrialización, en el seno de la sociedad aún altamente agrícola, en la medida en que es un instrumento redistribuidor del ingreso y un factor de integración nacional.

En relación con el crecimiento del seguro reconoce:

Aunque el régimen instituido por la fracc. XXIX del art. 123 constitucional tiene por objeto primordial establecer la protección del trabajador, su meta es alcanzar a todos los sectores e individuos que componen nuestra sociedad... Durante los últimos lustros hemos tenido un alto crecimiento económico pero ha sido inequitativa la distribución del producto nacional. Es por ello que el Gobierno de la República se esfuerza en reorientar la estrategia general del desarrollo sobre bases socialmente más justas... La seguridad social, como parte de esta política, precisa ampliarse y consolidarse, no sólo por el imperativo de propiciar el bienestar de la comunidad, sino como exigencia económica, pues la redistribución de la riqueza que promueve no frena el crecimiento, sino por el contrario, lo impulsa de manera real y sostenida. Mientras el hombre no disponga de elementos para superar sus limitaciones materiales y culturales no podrá alcanzar su plena productividad... Esta Iniciativa toma en consideración los distintos estudios técnicos que se han hecho para definir las necesidades y posibilidades de mejoramiento y expansión del sistema. Tiene por principales objetivos mejorar las prestaciones existentes e introducir otras; crear un nuevo ramo del seguro, el de guarderías, en beneficio de las madres trabajadoras; aumentar el número de asegurados; abrir la posibilidad para que nuevos sectores de la población se incorporen voluntariamente al régimen obligatorio; establecer servicios de solidaridad social sin comprometer los derechos de los asegurados; precisar diversos puntos controvertibles de la Ley vigente; reordenar preceptos dispersos que refieren a una misma materia y simplificar, para hacer expeditos diversos procedimientos... El proyecto que sirvió de base a esta Iniciativa fue ampliamente discutido por los representantes de los factores de la producción que concurren en la administración del Instituto. El hecho de que hayan coincidido en sus términos, revela el buen éxito de una política que busca reorientar el proceso del desarrollo sin afectar el consenso nacional y utilizando el diálogo como método de trabajo y entendimiento. Evidencia, además, la conciencia

alcanzada por los diversos sectores acerca de la magnitud del rezago social que afronta el país y la necesidad de imprimir un sentido humano al progreso.²

A lo largo de sus 24 años de vigencia este ordenamiento fue objeto de continuas modificaciones para adecuar sus prestaciones y servicios. Durante el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari se llevaron a cabo reformas que alteraron los principios y la administración del Instituto, y que fueron el antecedente de la privatización de los seguros sociales.

Reformas a la Ley de 1973

Las transformaciones de los seguros sociales en América Latina y las presiones del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional produjeron la captación de enormes recursos que aliviaron las deficientes económicas, con cargo a las aportaciones de los trabajadores, mediante el señuelo de que las cuentas individuales, administradas por los organismos financieros especializados, habrían de hacerlo con transparencia y evitarían desvíos. Los sindicatos en esos países veían en ello la posibilidad del mejoramiento anhelado frente al inadecuado manejo de los organismos públicos y, sin algún movimiento en contra, aceptaron las reformas. En Europa, los trabajadores, con mejor visión, se opusieron a estas reformas y llevaron a cabo movimientos que paralizaron a las empresas y a los servicios públicos.

El duro y hábil manejo del presidente Carlos Salinas de Gortari, unido al Consejo Coordinador Empresarial presidido por Nicolás Madaguar, aceptó la idea, a cambio de no incrementar el impuesto al activo de las empresas y convenció a las Cámaras empresariales. Los sindicatos fueron orientados con el argumento de que la aportación sería cubierta por los patrones, la posibilidad de que los trabajadores serían cuentahabientes y propietarios de esos fondos, de los que dispondrían en el momento de su pensión y, una parte, al quedar desempleados.

Así, se creó el proyecto de adiciones a la *Ley del Seguro Social* (LSS) y el presidente presentó al Congreso de la Unión la iniciativa para incluir en el art. 11 un ramo quinto de "retiro", modificar el art. 183 e incluir los arts. 183 A a 183 S. La administración del seguro se confía a uno de los bancos privados seleccionados por el patrón, sin cobro de comisión; los bancos que recibirían al pago del seguro social y de habitación individualizarían las cuentas a nombre de cada trabajador, conforme a las relaciones presentadas por el patrón. El art. 183 H ordenó que dentro de los cuatro días hábiles siguientes a su recepción trasladarían al Banco de México los recursos; esta institución abriría

2 *Ley del Seguro Social*, Alco, México, 1993, pp. 10 y sigs.

dos cuentas, una a nombre del IMSS y otra a nombre del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), y pondría los fondos del seguro de retiro a disposición del gobierno en forma de crédito, por medio de la SHCP. En el art. 246, fracc. V, se estableció un Comité Técnico del Sistema de Ahorro para el Retiro, dentro de los órganos de gobierno del Instituto, integrado por tres representantes de la SHCP, uno por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, dos por el Banco de México y tres por el IMSS (uno por cada uno de los sectores, patronal, obrero y del propio Instituto) (art. 258-F). Se cuidó que este Comité no tuviera relación de jerarquía que lo sometiera a la Asamblea General ni al Consejo Técnico. Este Comité fue el paso previo para la conformación en 1993 de la Comisión Nacional para la Coordinación de los Sistema de Ahorro para el Retiro y la *Ley para la Coordinación del Sistema de Ahorro para el Retiro*.

En las reformas a la LSS de 1992 se realizó una doble operación para:

- Incluir un quinto seguro de “retiro”.
- Excluir su administración de los organismos de gobierno del Instituto.

En la reforma del 20 de julio de 1993 se trasladan figuras del Derecho Fiscal para reafirmar la naturaleza de las cuotas y de las obligaciones. En el art. 9º se tiene el texto del art. 5º del *Código Fiscal de la Federación* (CFF) y se determina que es defraudación fiscal no incorporar a los trabajadores o no efectuar las aportaciones, así como se incrementan las facultades del IMSS para hacer exigibles los créditos. La exposición de motivos señala tres propósitos:

1. “*Consolidar el equilibrio financiero*, a fin de que el Instituto siga contando con los recursos suficientes que garanticen el cabal cumplimiento de los compromisos institucionales y *siga creciendo* al ritmo que la población lo requiere.”

De aquí podemos derivar que sin el incremento en las cuotas, el Instituto no podría atender sus compromisos con la población actualmente protegida. Su atención implica para el Ejecutivo Federal incrementar las cargas contra los patrones y, en consecuencia, contra los trabajadores mediante una modificación sustancial a sus aportaciones.

2. “*Modernizar y actualizar al Instituto* como organismo fiscal autónomo, haciendo congruente la Ley que lo rige con los diversos ordenamientos jurídicos de carácter tributario federal...”

Para cumplir con el objetivo se adiciona el art. 9º Bis, a fin de dar este aspecto impositivo a “las normas que se refieran a sujeto, objeto, base de cotización y tasa”, con lo que cualquier infracción u omisión podrá tener las sanciones contempladas en el CFF (hasta ser estimada la defraudación fiscal).

3. “*La precisión de conceptos jurídicos y de administración...*”

La reforma de 1994 crea la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), da base para la expedición de la *Ley para la Coordinación del Sistema de Ahorro para el Retiro* y consolida la separación entre el seguro de retiro y los otros seguros. Estas reformas prepararon el camino para la mayor reforma del seguro social.

Con las modificaciones sucesivas de 1992 a 1994 se determinó que los bancos recibieran los pagos del seguro de retiro y del Infonavit, sin intervención del IMSS; el patrón tuvo la facultad de elegir el banco conveniente para hacer el pago de 2% sobre su nómina; los bancos dentro del cuarto día hábil bancario siguiente al pago, transferían el monto al Banco de México, éste abría dos subcuentas, de vivienda y de retiro, a nombre del Infonavit y del IMSS y ponía el dinero a disposición del Gobierno Federal en forma de crédito.

Cuotas	Entero	Transferencias		Reclamación
Patrón 7%	Bancos	Banco de México	Gobierno Federal	Bancos
		Subcuenta Vivienda		
		Subcuenta Retiro		

Diagnóstico de 1995

Los pasos anteriores permitieron ampliar el marco de intervención de las financieras privadas, para lo cual el Ejecutivo Federal ordenó al Director General del Instituto la elaboración de un diagnóstico donde se presentara la visión general del seguro social, los problemas que en particular afrontaba y se apuntaran posibles soluciones. La instrucción era realizar un “diagnóstico objetivo, sereno, profundo y realista que permita acometer los nuevos retos de la seguridad social que demandan los mexicanos”,³ con cinco principios:

1. El sistema de seguridad social mexicano no se privatizará.
2. No debe haber más cargas a los trabajadores y las empresas en cuanto a sus aportaciones al IMSS.

3 *Diagnóstico. Instituto Mexicano del Seguro Social. Seguridad y Solidaridad Social*, marzo de 1995, p. 1.

3. Se deben explorar mecanismos para conciliar las finanzas sanas del Instituto con la viabilidad de los ramos de aseguramiento.
4. Se debe procurar la ampliación de la cobertura del Instituto y estimular su papel como promotor del empleo y la productividad.
5. El proyecto hacia la Nueva Era del IMSS debe contar con el consenso de la clase trabajadora del país.

En los apartados anteriores de este capítulo establecimos los elementos de conocimiento en relación con la Ley de 1943 y con la Ley de 1973. Este último ordenamiento representa la consolidación de la primera etapa del sistema, así como el antecedente, por las reformas llevadas a cabo del sistema de cuentas individuales, establecido primero en el IMSS y con posterioridad en el ISSSTE, hasta culminar con la LSS aprobada en 1995 y vigente en 1997, a la que habría de seguir la *Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado*, en vigor a partir de 2007.

En marzo de 1995 el IMSS presentó un documento oficial de 151 hojas, “las conclusiones a las que se lleguen derivadas de este proceso serán un firme sustento para emprender la Nueva Era del IMSS, fortalecida por la corresponsabilidad de sus trabajadores, beneficiarios y aportantes”.⁴ Su análisis permite comprender los objetivos de las nuevas leyes en el Seguro Social, de la LSS, en vigor a partir del 1 de julio de 1997 y de la *Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro* (LSAR) del 26 de mayo de 2006. Los sistemas de seguro social fueron concebidos en todo el mundo como instrumentos de protección, resarcidores de infortunios para los trabajadores y sus familias. Por ello, su método de financiamiento se ha vinculado a la nómina. El sistema mexicano no es la excepción. Hace más de 50 años fue creado bajo esos mismos principios y, no obstante que en 1973 se amplió la concepción hacia la “seguridad social” y se incluyeron algunos nuevos esquemas de financiamiento para ciertos grupos bajo la denominación de regímenes modificados, “en su mayor parte el IMSS se sigue financiando de las contribuciones sobre la nómina”.⁵

En 1995, el IMSS daba atención a 37 millones de personas en el régimen obligatorio, con más de 8.5 millones de trabajadores asegurados y 11 millones de solidariohabientes, que recibían servicio médico, lo que implicaba la protección mínima a 48 millones de personas. Los pensionados llegaban a 1 430 000.

La aportación mayoritaria del sector patronal y mínima del gobierno, con aportaciones promedio que afectan, cuando menos, al 26.5% del valor de la nómina de las empresas, además del 5% por Infonavit, que da un resultado de 31.5%. Las aportaciones se dividen en brutas y netas. De las primeras,

4 *Ibidem*.

5 *Ibid.*, p. 22.

corresponden al patrón 70%, al trabajador 25% y al Gobierno Federal 5%. En cuanto a las cuotas netas, corresponde al patrón 38.5%, al trabajador 32% y al Gobierno Federal 29.5%; "las empresas que contratan personal con salarios superiores a 10 salarios mínimos critican el hecho de que a partir de este salario podría resultarles conveniente hacerse cargo del seguro médico o contratar el servicio de un seguro privado en lugar del IMSS".⁶

Los esquemas modificados, donde se ubica a los asegurados del régimen voluntario, campesinos, no asalariados, cañeros, tabacaleros, trabajadores domésticos, representan 17% de los derechohabientes. Las bases de financiamiento al ser diferentes en cada caso, toman en cuenta situaciones políticas y sociales, por lo que estos esquemas "siguen siendo deficitarios en su operación. Lo anterior significa que los trabajadores asalariados subsidian"⁷ a esos grupos, sobre bases injustas para unos y otros.

El Diagnóstico reconoce la existencia de una aportación mayoritaria del sector patronal y mínima del gobierno, con aportaciones promedio que afectan, cuando menos, 26.5% del valor de la nómina de las empresas, además de 5% por Infonavit. Por cada \$1 000.00 de nómina se destina al Seguro Social \$315.00.

En relación con la situación financiera de la pensiones, el Diagnóstico señala:

... el IMSS ha elaborado proyecciones financieras y actuariales sobre la evolución del ramo de IVCM, conservando su actual esquema de beneficios y aportaciones (sin incrementar las pensiones como proporciones del salario mínimo), bajo un escenario caracterizado por los siguientes supuestos:

- 3% de incremento anual de asegurados.
- 2% de incremento real anual de salarios (por arriba del índice inflacionario).
- 3% de tasa de interés real para la inversión de reservas.
- 100% del remanente se destina a reservas financieras.
- 8.5% de cuota sobre el salario base de cotización.

Y concluye que:

... la proyección indica que para el año 2002 los egresos del ramo serán mayores a sus ingresos, teniendo que compensarse este déficit con las reservas financieras acumuladas en los años anteriores. El problema se agudiza en el año 2004, cuando las reservas se agotan y será entonces necesaria la canalización de recursos de otras fuentes para equilibrar las finanzas de IVCM.

⁶ *Ibid.*, p. 36.

⁷ *Ibid.*, p. 34.

A casi tres años de haberse instituido el seguro de retiro, el Diagnóstico da la razón a quienes hemos sido sus críticos, al señalar:

Desde su creación ha enfrentado problemas administrativos tales como trabajadores con diversos números de registro, falta de oportunidad y eficacia en el registro de las cuentas individuales, problemas de fiscalización y otros que ya se resuelven a través del nuevo organismo CONSAR. Por otra parte, para el sistema bancario resulta poco atractivo manejar cuentas de trabajadores de bajos ingresos ya que les genera muy poca utilidad.

Otro problema que enfrenta el SAR es que para alcanzar una pensión del 100% del último salario es necesario cotizar durante 40 años a una tasa de retorno real del 3%; equivalente al 24% del salario. Esto último resulta ser sumamente oneroso.

El Diagnóstico analiza la situación de cada seguro:

1. Para la atención en el seguro de enfermedad y maternidad, existían 1 700 unidades médicas: 1 495 unidades de primer nivel (Unidades de Medicina Familiar), 227 hospitales de segundo nivel (Hospitales Generales), 42 hospitales de tercer nivel (Hospitales de Alta Especialidad). El Instituto cuenta con una plantilla de 340 000 trabajadores, de los cuales 230 000 laboran en esas unidades, donde 6.7% son médicos generales, 6.6% especialistas, 33.4% enfermeras, 6.9% personal médico directivo y 46.4% auxiliares y otras modalidades. El IMSS tiene una asistencia promedio diaria de 700 000 personas;⁸ en un día típico 367 930 personas reciben consulta,⁹ se realizan 25 670 estudios de radiodiagnóstico, se cuentan 5 311 egresos hospitalarios y 3 452 intervenciones quirúrgicas; nacen 86 niños por hora y las guarderías tienen lugar para 61 000 infantes. El presupuesto de ingresos del Instituto para 1995 rebasaba los \$46 000 000 000.00, es decir, \$1 000.00 por cada persona cubierta.

El Diagnóstico precisa los aspectos negativos de este seguro:

- Existe un desequilibrio financiero en la prestación de los servicios médicos.
- El paulatino envejecimiento de la población, así como el incremento en su esperanza de vida, elevan los costos del sistema, haciendo más delicada la situación financiera.
- El sistema de financiamiento no estimula el crecimiento del empleo y los salarios. Asimismo, inhibe el crecimiento de la cobertura y permite

8 *Ibid.*, p. 4.

9 *Ibid.*, p. 28.

la subdeclaración, especialmente entre las empresas pequeñas, por su difícil fiscalización.

- Las cuotas están indizadas a los salarios y no al costo de los servicios.
- Los esquemas modificados han mostrado ser una carga financiera, que arrojan un déficit de N\$954 millones en 1994.
- Existe un esquema de trabajo que no propicia la superación del personal, lo que genera desmotivación e impide la mayor calidad y eficiencia del servicio, especialmente en el primer nivel. Por ejemplo, el médico que trabaja más y mejor no recibe ningún beneficio adicional de los que recibe el que no lo hace.
- El modelo de atención para la prestación de los servicios no favorece la relación cercana entre el médico y el paciente, en detrimento de la calidad de la atención y la confianza del usuario.
- El crecimiento centralizado de la Institución, aunado a la escasa capacidad de gestión de las unidades médicas ha rebasado el sistema de abasto, que es muy ineficiente y genera serios problemas de oportunidad en la prestación de los servicios.
- El diferimiento de servicios resultante de los diversos problemas se estima en horas o días para el primer nivel; días o semanas para el segundo nivel, y semanas e incluso meses en el tercer nivel de atención.
- El sistema de vigencia de derechos es obsoleto e ineficaz, y genera quejas constantes respecto a la oportuna prestación de los servicios o el otorgamiento de servicios a no derechohabientes, lo que afecta la operación de las unidades, así como las finanzas de la Institución.
- En lo referente a las unidades de segundo y tercer nivel, las decisiones administrativas se toman con escasa cercanía y coordinación con el lugar en que se originan los problemas, lo que conlleva múltiples costos como resultado de la rigidez del sistema y una inadecuada asignación de recursos.
- Las unidades de segundo y tercer nivel registran excesivas erogaciones en los servicios generales y auxiliares de diagnóstico, limitando las posibilidades de reinversión y actualización del equipo.
- Hay una creciente insatisfacción de los usuarios y de los prestadores de servicios, en particular en el primer nivel de atención.
- El diferencial de salarios entre las diversas categorías del personal institucional ha disminuido paulatinamente. Mientras que un médico gana mucho menos de lo que obtendría en el ejercicio privado, un trabajador de servicios auxiliares o generales gana casi el doble de su salario de mercado.
- Sobrecarga de personal en algunas áreas.¹⁰

¹⁰ *Ibid.*, pp. 31-33.

En cuanto al financiamiento, "las cuotas constituyen las fuentes primarias y únicas de financiamiento".¹¹ Parte importante de los recursos de este ramo han provenido de los ramos de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte (IVCM) y guarderías. Es "imposible el continuar financiando parte de la operación de este ramo con los excedentes de IVCM y Guarderías, ya que el número de pensionados y el número de mujeres trabajadoras por cada trabajador asalariado activo se va incrementando a un ritmo creciente".¹² El mecanismo "sustentado en la solidaridad entre generaciones, permitió en sus orígenes que aumentaran los beneficios sin modificar las cuotas y se utilizaran los excedentes del ramo para apoyar la construcción de infraestructura y coadyuvar a financiar la operación del seguro de Enfermedades y Maternidad".¹³

El Diagnóstico presenta las conclusiones siguientes:¹⁴

- a) "El ramo de Enfermedad y Maternidad debe tener la capacidad de crecer al menos al ritmo que la población lo hace, mejorar la calidad y oportunidad de la atención y reafirmar el sentido humano de la misma con un enfoque moderno."
 - b) "Las fortalezas de este ramo son extraordinarias, pero existen debilidades que generan inconformidad entre derechohabientes y prestadores de servicios. Esto, aunado a *la necesidad de garantizar su viabilidad financiera obligan a una transformación que preserve los derechos de los trabajadores de México y que les brinde una atención acorde a los principios que le dieron origen al Instituto.*"
 - c) "Debe quedar claro que los recursos con que actualmente cuenta este ramo son insuficientes para continuar dando el servicio con la cobertura y calidad adecuada. De no modificarse las condiciones actuales, se prevé un déficit permanente, lo que se acentúa ante la imposibilidad de que el ramo de IVCM continúe apoyando a Enfermedades y Maternidad."
 - d) "Lo anterior obliga a estudiar cambios de fondo que además de disminuir los costos, permitan terminar con el desequilibrio financiero en forma permanente."
2. En el seguro de IVCM, el Diagnóstico sostiene que en la actualidad todos los pensionados reciben, en términos reales, más de lo que aportaron,¹⁵ sobre todo cuando se trata de salarios elevados, donde a pesar de que el

11 *Ibid.*, p. 34.

12 *Ibid.*, p. 36.

13 *Ibid.*, p. 54.

14 *Ibid.*, p. 53.

15 *Ibid.*, p. 56.

documento no da cifras al respecto, un buen número de trabajadores gana salario mínimo.

Los recursos ascienden a 8.3% del salario de cotización, que se reparten en la forma siguiente:

- Invalidez y muerte, 3%
- Vejez y cesantía en edad avanzada, 2.8%
- Servicios médicos a pensionados, 1.5%
- Gastos de administración, 0.6%
- Prestaciones sociales, 0.4%

La estructura y la administración presentan problemas inadecuados que fomentan la evasión y la subdeclaración, por lo que reconoce las debilidades siguientes:¹⁶

- “Existe una cobertura muy limitada amparando únicamente a los asalariados formales.”
- “Presenta una estructura discriminatoria en contra de los trabajadores de bajos ingresos y de las mujeres, ya que son los sectores de la población que tienen mayor probabilidad de perder sus derechos por no cumplir los requisitos necesarios para recibir los beneficios del sistema.”
- “La inflación repercute negativamente en el valor de las pensiones, ocasionando pérdidas reales al trabajador en el momento del retiro.” El documento lo explica en la forma siguiente:

... para una trayectoria laboral en que un trabajador cotice 20 años en tres salarios mínimos (cercana al promedio actual), la pérdida de derechos se calcula en 7.4% para una inflación del 4% anual en los últimos 5 años; de 17.72% para el 20% anual; y 30.7% para el 100% de inflación. Es decir, un trabajador que en los 5 años previos a su retiro enfrenta una inflación anual del 20%, recibirá una pensión 17.7% menor que aquél trabajador con mismo salario, que en sus últimos 5 años laborables no enfrentó inflación alguna.

- “No se toma en cuenta toda la carrera salarial del trabajador para el cálculo del monto de la pensión.”
- “La estructura del tabulador de pensiones genera incentivos a la subdeclaración o a la evasión de cuotas.” Al respecto, el Dictamen señala:

¹⁶ *Ibid.*, p. 63.

... para los trabajadores del estrato mas bajo (nivel de salario mínimo), la diferencia en su pensión entre cotizar durante 10 años y durante 45 años es de sólo 14.7% (0.4% de incremento promedio por año adicional cotizado); para 2 s.m. es de 128.2% (2.4% anual); para 3 s.m. es de 241.5% (3.6% anual) y llega a 659.6% (6% anual) para 7 a 10 s.m.

- “Existen inequidades generadas por subsidios cruzados considerando estado civil y sexo.” Esto se trata en forma confusa:

Las cuotas son independientes de si el trabajador tendrá esposa o concubina durante el retiro, así como al número y las edades de los hijos que dependerán del pensionado. Considerando el mismo salario de cotización y la misma edad de incorporación al sistema, *contribuirán con la misma cuota los individuos solteros sin hijos y los casados, con hijos*. Este subsidio cruzado provoca inequidades, ya que es evidente que el monto de las pensiones por viudez y orfandad, así como el de las asignaciones familiares, depende de los aspectos mencionados.

Esta disposición tiende a favorecer a los individuos que cambian de pareja en edad avanzada e incluso abre la posibilidad de matrimonios ficticios y registro de hijos ajenos para heredarles una pensión a determinadas personas. Existe evidencia anecdótica de matrimonios en que estas posibilidades son de hecho aprovechadas por algunos asegurados.

Los subsidios cruzados en sí mismos *no son malos, ya que estos representan el componente solidario del grupo*. Sin embargo, cuando un subsidio cruzado afecta la conducta de los individuos, entonces pierde sus efectos benéficos, generando distorsiones. En el caso de IVCN, esto ha sido uno de los causantes de su desequilibrio financiero.¹⁷

En un último argumento al respecto, señala:

En referencia al sexo de los cotizantes, se ha detectado que en este ramo las asalariadas subsidian a los asalariados en virtud de que sus viudos o esposos no recibirán la pensión correspondiente para viudas o esposas. Asimismo, la limitación al monto acumulado de las pensiones que recibe una persona que es simultáneamente asegurada y beneficiaria discrimina a las esposas que continuaron trabajando después de casarse, debido a las limitaciones al monto acumulado de las pensiones que puede recibir una persona que es simultáneamente asegurada y beneficiaria.

- “Anomalías al otorgar pensiones de Invalidez.” El Dictamen presenta el argumento de apoyo siguiente:

El otorgamiento de las pensiones por Invalidez carece de control adecuado que permite que la corrupción atente contra el otorgamiento justo, y con equilibrio financiero, de este beneficio. Existe un ejemplo anecdótico de un deportista de prestigio internacional que tenía pensión de invalidez.¹⁸

- “Canalización de recursos a prestaciones sociales y a gastos de administración.”
- “Falta de vinculación entre aportaciones y beneficios.” En dos párrafos el Diagnóstico señala lo siguiente:

No existe total vinculación entre lo que se aportó y lo que se recibe como pensión en el ramo de IVCM. Por tanto, no se generan incentivos a aportar más, elevar la productividad y los niveles salariales.

La falta de vinculación entre aportación y beneficio también es en parte causa de las presiones políticas de los pensionados, ya que, al no haber claridad, siempre argumentan que están recibiendo mucho menos de lo que aportaron, aun cuando esto no sea cierto.¹⁹

El Diagnóstico toma en cuenta la reducción de semanas de cotización, que en un principio era de 700 en vejez y cesantía en edad avanzada, para quedar en 500, así como de 200 para invalidez y muerte, lo que ha quedado en 150. Además, las aportaciones se han aumentado ligeramente, sin que sus montos resulten suficientes para cubrir la cuantía de las pensiones.

Esto es suficiente. Para ilustrarlo es necesario tomar en cuenta que para garantizar la pensión mínima a un trabajador casado al momento del retiro, el monto de recursos que se deberían haber acumulado es el equivalente a 19 salarios mínimos anuales (s.m.a.). Haciendo los cálculos correspondientes a las cotizaciones actuales, resulta que el fondo acumulado es de solamente 0.33 s.m.a. si cotiza sobre un salario mínimo durante 10 años, y de 1.83 s.m.a. si lo hace durante 40 años. Mas aún, si se cotizara sobre 10 salarios mínimos el fondo creado se incrementa proporcionalmente, llegando a 3.3 s.m.a. para 10 años y 18.3 s.m.a. para 40 años. En consecuencia, en el sistema actual ni siquiera cotizando al tope máximo durante 40 años se logra formar un fondo suficiente para financiar la pensión mínima de un asegurado casado.

- “El número de pensionados está creciendo a mayor velocidad que los cotizantes, poniendo de manifiesto el envejecimiento de la estructura demográfica.”

¹⁸ *Ibid.*, p. 75.

¹⁹ *Ibid.*, p. 76.

Del análisis de esta parte del Diagnóstico puede concluirse que la desatención a la ley ha ocasionado el problema financiero que se confronta; sin embargo, existen reservas que se reconocen al señalar que el déficit tendrá que compensarse “con las reservas financieras acumuladas en los años anteriores”, por lo que a pesar de las disposiciones hacia otras áreas, aún existen reservas que podrían agotarse, de seguir con el sistema actual –y sus desviaciones– “en el año 2004”.

3. En cuanto al seguro de riesgos de trabajo: “Actualmente se tiene la infraestructura para otorgar la cobertura del Seguro de Riesgos de Trabajo a todas las empresas que lo requieran, además de no existir rezago en el cumplimiento de las obligaciones por parte del Instituto.”²⁰

El Diagnóstico menciona dos problemas estructurales:

I. Una situación de desequilibrio financiero generada por:

- El aumento en la esperanza de vida de los pensionados, lo que significa un incremento superior a 80% en relación con los cálculos actuariales originales, que datan de 1943.
- Los aumentos en prestaciones, incremento de pensiones, aguinaldo, finiquitos, extensión de beneficios para los huérfanos; así como disminución de condiciones de edad y de semanas de cotización, además de la inclusión de los accidentes de tránsito.

II. Una estructura que no ofrece incentivos para la modernización y reducción de riesgos en una empresa, lo que resulta inequitativo.

- El sistema de agrupar a las empresas por actividad conforme a clase y grado de riesgo es anacrónico, por lo que debe atenderse específicamente la condición de cada una para estimular las medidas propias adecuadas que ha de adoptar.
- Es necesario replantear la estructura de este ramo para que por la disminución de riesgos se reafirme financieramente, sin necesidad de incrementar cuotas.

4. Respecto al seguro de guarderías señala que “en 1994, el IMSS contaba con 455 guarderías infantiles, con un total de 61 737 lugares de capacidad instalada”. Se apuntan los principales problemas detectados:²¹

²⁰ *Ibid.*, p. 80.

²¹ *Ibid.*, p. 92.

- Alto ausentismo del personal operativo.
- No se sustituye el ausentismo programado del personal de guarderías.
- Se atiende en algunos casos a niños sin derecho por falta de control en la vigencia de tal derecho.
- La ubicación de algunas guarderías obedeció más a la disponibilidad de inmuebles y terrenos que a la demanda real en el esquema ordinario.

Reconoce que la población infantil captada es mínima: "Si analizamos a la población infantil desatendida, nos damos cuenta de que en el año de 1984 ésta asciende a cerca de 233 mil niños, pasando diez años después a ser de alrededor de 371 mil niños."²² Se dice que la brecha entre la demanda real y la demanda atendida es cada vez mayor, por lo cual más niños se encuentran fuera de servicio,

... lo que repercute negativamente en la incorporación equitativa de la mujer al mercado laboral que es la razón fundamental de la existencia de este servicio. No obstante que la cuota legal ha sido recaudada regularmente, no ha sido aplicada en su totalidad al Seguro de Guarderías, sino que ésta se ha empleado para cubrir el déficit de otros ramos del seguro, principalmente el de Enfermedades y Maternidad. Estas transferencias de fondos hechas desde el año de 1973 han significado, con excepción de cinco años, más del 50% de la cuota correspondiente al ramo de Guarderías.²³

La cobertura que ofrece actualmente el ramo es sumamente limitada, constituyéndose en un obstáculo para la incorporación equitativa de la mujer al mercado laboral. Esto se debe fundamentalmente al alto costo de algunos esquemas, así como al hecho de que el ramo canaliza recursos a Enfermedades y Maternidad, frenando las posibilidades de ofrecer el servicio a una creciente población que lo demanda.²⁴

En lo relativo a las prestaciones sociales, el Diagnóstico que se analiza no presenta cifras ni problemática en este aspecto, por la gravedad de la situación, tanto porque no puede atenderla, cuanto por las disímolas prestaciones que se otorgan.

Los actuarios, economistas, médicos, enfermeras y abogados del IMSS, además de cumplir la orden emitida por Genaro Borrego, Director General, pensaron de buena fe que, como había señalado el presidente Zedillo, el estudio formulado en poco tiempo, con base en la experiencia institucional, se mantendría el sistema sin alentar la privatización, que serviría de base para

²² *Ibid.*, p. 88.

²³ *Ibid.*, p. 92.

²⁴ *Ibid.*, p. 92.

revisar las aportaciones patronales y de los trabajadores, como necesidad de conciliar las finanzas a fin de dar viabilidad a los ramos de aseguramiento, que permitieran ampliar la cobertura del Instituto y estimular su papel como promotor del empleo y la productividad y, finalmente, que ello conduciría a conformar la Nueva Era, con el consenso de la clase trabajadora del país.

Los que así pensaron observaron, en pocos meses, las verdaderas intenciones de la Iniciativa de Ley, presentada por el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión, donde los resultados fueron adversos, ya que se amplió la participación de organismos privados para administrar los fondos pensionarios, se redujeron las aportaciones patronales, las finanzas impedirían dar viabilidad a los ramos de aseguramiento y se restringiría la cobertura del Instituto. El resultado sería estimular el desempleo y la productividad y, finalmente, la Nueva Era Privatizadora estaría alejada del consenso de la clase trabajadora.

6 Fundamentos de los seguros sociales

En México estamos muy alejados de conformar una seguridad social y, en consecuencia, un derecho de la seguridad social. Tenemos una complicada variedad de seguros sociales que van de porcentajes de más de 100% del último salario a un salario mínimo. Así, además de los organismos federales que cubren a la mayoría, como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), tenemos los hospitales militares y navales y los haberes de retiro; los contratos colectivos de trabajo; los convenios en las instituciones financieras públicas y privadas; los acuerdos que parten de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, así como los fondos integrados por otros servidores públicos para el supuesto de pensión o jubilación.

Ley del Seguro Social

Exposición de motivos

La *Ley del Seguro Social* (LSS) se fundamenta en la fracc. XXIX del Apartado A del art. 123 de la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*, tiene el carácter de obligatoria, es de aplicación general en la República y sus disposiciones, conforme a su art. 1, son de orden público y de interés social, lo cual impide dejar su interpretación o cumplimiento al libre criterio de los particulares. Únicamente las autoridades judiciales pueden determinar su validez y el apego de las normas a los mandatos constitucionales.

El Presidente de la República envió la iniciativa al Congreso de la Unión el 9 de noviembre de 1995. La exposición señala:

La estabilidad y el crecimiento económico sostenido son condiciones indispensables para el progreso social, por eso el Plan Nacional de Desarrollo establece la articulación de la política social con la fiscal y la financiera. La constitución de ahorro interno, indispensable para incrementar la inversión, se orienta a la generación creciente de empleos sobre bases sólidas para hacer posible el bienestar social perdurable.

La seguridad social es uno de los mejores medios para llevar a cabo los objetivos de la política social y económica del gobierno y satisfacer las legítimas demandas y aspiraciones de la población. Su materialización en el Instituto Mexicano del Seguro Social se ha destacado por los grandes beneficios proporcionados a los trabajadores, sus familias y a las empresas, así como por la promoción de la salud y el bienestar de la sociedad. El Instituto ha sido instrumento redistribuidor del ingreso, expresión de solidaridad social y baluarte auténtico de la equidad y la estabilidad en nuestro país. A través de los años ha quedado constatada su capacidad de brindar protección, certidumbre y justicia social para los mexicanos, contribuyendo notablemente al desarrollo de nuestra nación.

El IMSS es patrimonio del pueblo mexicano. Sus logros, a 52 años de su creación, así lo reflejan. Hoy en día, a través de su régimen obligatorio da cobertura a casi 37 millones de mexicanos, cuenta con una infraestructura superior a 1 700 unidades médicas; cubre 1 500 000 pensiones mensualmente; recibe en sus guarderías a cerca de 61 000 niños; asisten a sus instalaciones médicas diariamente más de 700 000 personas, y nace en ellas uno de cada tres mexicanos.

A pesar de sus realizaciones, se debe reconocer que para construir el sistema de seguridad social que requieren hoy los mexicanos y necesitará México en el siglo XXI, es indispensable corregir deficiencias, superar limitaciones y sentar bases sólidas para que la seguridad social sea, en mayor medida, la vía por la cual avancemos hacia la eficacia plena de los derechos sociales.

Por ello, la obligación estatal de contribuir de manera más efectiva al desarrollo nacional, a la generación del ahorro interno y al crecimiento del empleo, coincide con la necesidad de enfrentar las complejas circunstancias y de resolver urgentemente la crítica situación financiera por la que atraviesa el Instituto; de adecuarse al cambio demográfico; de responder a las crecientes demandas de mayor eficiencia en el uso de los cuantiosos recursos que se le confían para convertirlos en servicios y prestaciones; y de superar insuficiencias con la firme voluntad de dar plena vigencia a sus principios y filosofía originales de la seguridad social.

Si bien el pasivo contingente del IMSS es de largo plazo, sus efectos empezarían a sentirse en los próximos años. Aún con las proyecciones más optimistas en cuanto al crecimiento del empleo y el salario, y utilizando la información de los registros de cotizantes del IMSS, se tiene previsto que para el año de 1999 los

egresos de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte superarán sus ingresos, es decir, las cuotas que para este ramo están cubriendo los trabajadores en activo no alcanzarían para pagar la nómina de pensionados. Ante tal situación, se recurriría al uso de la reserva, que es mínima, la cual se agotaría en dos años. Este déficit crecería rápidamente año con año. Las consecuencias de ello serían irreversibles propiciando efectos sociales inaceptables.

... desde hace cinco décadas, los remanentes del seguro de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte fueron dedicados a subsanar dicho déficit, impidiéndose, por ello, que se generaran reservas monetarias para cubrir las pensiones. De igual forma, desde 1973, enfermedades y maternidad se ha financiado complementariamente con recursos provenientes del ramo de guarderías, lo que ha limitado considerablemente a éste su capacidad de crecimiento. Las circunstancias actuales obligan a que invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, y guarderías, ya no le transfieran recursos al de enfermedades y maternidad, por lo que urge una transformación que, sin incrementar cuotas a los obreros y patrones, permita garantizar de manera permanente la suficiencia financiera de este ramo.

Otro factor que ha contribuido al desfinanciamiento del ramo de enfermedades y maternidad son los esquemas modificados de aseguramiento, que en 1994 tuvieron un déficit de N\$954 millones. Estos esquemas, que se han ido añadiendo al IMSS paulatinamente, han permitido la incorporación de diversos grupos tales como: trabajadores estacionales del campo; miembros de sociedades locales de crédito ejidal; productores de caña de azúcar y sus trabajadores; henequeneros del estado de Yucatán; tabacaleros; algodóneros de la comarca lagunera; cafeticultores; billeteros de la lotería; candelilleros; etcétera. No obstante, por su condición irregular, ninguno de ellos cuenta con bases de financiamiento que los haga autofinanciables, lo cual, con sentido de equidad, se busca corregir en la presente iniciativa.

La problemática general anteriormente descrita, así como la específica de cada ramo de aseguramiento, fue dada a conocer públicamente a través de un diagnóstico elaborado por el propio Instituto Mexicano del Seguro Social. A partir de dicho diagnóstico se dio inicio a un amplio proceso de consulta y debate, contando con la participación de especialistas y numerosas organizaciones. Así, las propuestas presentadas son el resultado de múltiples foros realizados con organizaciones de todo el país, con expertos en la materia, y con los propios usuarios y prestadores de los servicios, el cual comprende también un ejercicio crítico de reflexión sobre las experiencias internacionales más recientes. Entre los foros destacan los de consulta para la formulación del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000.

Asimismo, se constituyó la Comisión Tripartita para el Fortalecimiento y Modernización de la Seguridad Social, integrada por representantes de los sectores obrero y patronal, así como del gobierno, quienes son los aportantes y beneficiarios directos de la institución. Después de analizadas las aportaciones recibidas

a lo largo de toda la consulta, dicha comisión arribó a un conjunto de conclusiones, mismas que en su momento me presentaron en el documento de "Propuesta de alianza obrero-empresarial para el fortalecimiento y modernización de la seguridad social."

Al presentar esta iniciativa a consideración de la representación nacional, comparto la convicción de que el actual, es el momento en que el Instituto debe emprender acciones profundas de reestructuración con la finalidad de renovarse para su fortalecimiento, y así, acrecentar su capacidad de proporcionar servicios y prestaciones como garantías de seguridad y bienestar para el pueblo de México. He coincidido con la Comisión Tripartita en que el Instituto Mexicano del Seguro Social debe consolidarse como instancia fundamental de protección y convertirse, además, en propulsor de procesos de trascendencia estratégica que nos permitan crecer con certidumbre y promover con mayor decisión el ahorro interno para la generación de empleos, lo cual es propósito intrínseco de la seguridad social mexicana.

La responsabilidad es actuar. Tenemos la oportunidad y debemos aprovecharla. Postergar su transformación implicaría abandonar los esfuerzos por ofrecer más seguridad y bienestar, y lo que sería muy grave, aceptar como una fatalidad la presencia de un colapso financiero con las consecuencias que se derivarían en cuanto al incumplimiento en las prestaciones, que traerían consigo afectaciones inaceptables en perjuicio de millones de familias y en indeseables y delicados desequilibrios sociales.

...el Instituto debe contribuir a incrementar el ahorro interno y promover con decisión la creación de nuevas fuentes de trabajo. Sin empleo no tiene sustento la seguridad social. Seguridad social y empleo son conceptos permanentemente vinculados, y es por ello que el crecimiento de este último es propósito central de esta iniciativa.

...El equilibrio financiero no es un fin en sí mismo, sino el medio imprescindible para alcanzar los elevados propósitos que la institución desde su origen tiene encomendados.

De los párrafos transcritos se pueden destacar las ideas siguientes:

Ahorro interno. Articula la política social con la fiscal y la financiera; considera elemento indispensable para incrementar la inversión la constitución de ahorro interno.

Política económica y social. Considera a la seguridad social como uno de los mejores medios para llevar a cabo los objetivos de estas políticas del gobierno.

Situación financiera. Es indispensable y urgente resolver la crítica situación financiera por la que atraviesa el Instituto, para que pueda responder a las crecientes demandas de mayor eficiencia en el uso de

los cuantiosos recursos que se le confían para convertirlos en servicios y prestaciones. Para ello debe superar limitaciones y sentar bases sólidas.

Desfasamiento a corto plazo. Aun con las proyecciones más optimistas, se tiene previsto que para 1999 los egresos de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte superarán sus ingresos.

Apoyo financiero. La causa principal del desfinanciamiento de la institución estriba en que desde hace cinco décadas las cuotas del seguro de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte (IVCM), y de guarderías, fueron dedicadas, en buena medida, a subsanar el déficit de enfermedades y maternidad.

Esquemas modificados. Otro factor que ha contribuido al desfinanciamiento son los esquemas modificados de aseguramiento, ya que ninguno cuenta con bases de financiamiento que los haga autofinanciables.

Objeto de la renovación. El Instituto debe emprender acciones profundas de reestructuración con la finalidad de renovarse para su fortalecimiento, y así acrecentar su capacidad de proporcionar servicios y prestaciones; debe consolidarse como instancia fundamental de protección y convertirse, además, en propulsor de procesos de trascendencia estratégica que nos permitan crecer con certidumbre y promover con mayor decisión el ahorro interno para la generación de empleos.

Por ello es relevante que conforme al art. 3 de la Ley se determine:

La realización de la seguridad social está a cargo de entidades o dependencias públicas, federales o locales y de organismos descentralizados, conforme a lo dispuesto por esta Ley y demás ordenamientos legales sobre la materia.

De la misma manera, el art. 2 es adicionado con una segunda parte que es conveniente destacar para estos propósitos:

La seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado.

Estas normas ponen en seria duda la participación, en cualquier forma de sociedades anónimas de capital variable, que son personas jurídicas colectivas, de naturaleza particular.

Los principios anteriores se complementan con lo ordenado por el art. 5 del mismo ordenamiento, que dispone:

La organización y administración del Seguro Social, en los términos consignados en esta Ley, están a cargo del organismo público descentralizado con personalidad y patrimonio propios, denominado Instituto Mexicano del Seguro Social, el que tiene el carácter de organismo fiscal autónomo, cuando así lo prevea la presente Ley.

En el sentido de las normas anteriores, el art. 7 señala:

El Seguro Social cubre las contingencias y proporciona los servicios que se especifican a propósito de cada régimen particular, mediante prestaciones en especie y en dinero, en las formas y condiciones previstas por esta Ley y sus reglamentos.

De estos preceptos podemos derivar lo siguiente:

1. Sólo el IMSS puede y tiene la obligación de organizar, administrar y cubrir las contingencias que la propia Ley establece.
2. No pueden intervenir, en forma alguna, organismos o personas ajenas a las entidades y dependencias de la administración pública.
3. Los órganos de gobierno sólo pueden intervenir conforme a las facultades legales que emanan de la Constitución Política.

Al respecto, Javier Moreno Padilla señala:

Las instituciones que se encargan de dar estos servicios en nuestro país aparte del Instituto Mexicano del Seguro Social son: el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, la Dirección de Pensiones Militares, las dependencias respectivas que tienen autonomía en estos servicios (clínicas para los trabajadores bancarios, petroleros, ferrocarrileros, etc.), así como las direcciones que se encargan de prestar servicios de seguridad social a los trabajadores que laboran en las oficinas gubernamentales locales de la mayor parte de los Estados de la República. La Secretaría de Salubridad otorga asistencia exclusivamente a los indigentes, pero no presta servicios de seguridad social.¹

Condición de asegurados y beneficiarios

A lo único que se obliga a los asegurados y a sus beneficiarios, “para recibir o, en su caso, seguir disfrutando de las prestaciones que esta Ley otorga”, es

¹ Javier Moreno Padilla, *Régimen fiscal de la seguridad social*, Themis, México, 1991, p. 27.

“cumplir con los requisitos establecidos en la misma y en sus reglamentos” (art. 8). Por tanto:

- Las disposiciones de carácter general que expida la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) no pueden afectar derechos de los asegurados y sus beneficiarios.
- Únicamente tienen que satisfacer las condiciones que se prevén en esta Ley.
- Ningún otro ordenamiento les es aplicable, como condición para el disfrute de las prestaciones consignadas a su favor.
- Las prestaciones de los trabajadores y sus beneficiarios, conforme al art. 10 de la Ley, son inembargables, excepto para el caso de pensiones alimenticias.

En consecuencia:

- Los asegurados y sus beneficiarios tienen el derecho de reclamar del IMSS las prestaciones y los beneficios que la Ley consigna a su favor.
- Limita la observancia obligatoria a la LSS y a sus reglamentos, sin dar cabida para la expedición o aplicación de cualquier otra ley, reglamento o disposición.

Organismo fiscal

La Ley tiene una marcada tendencia fiscalizadora al reiterar disposiciones incorporadas en las reformas de 1994 que ha tomado del *Código Fiscal de la Federación* (CFF) y de su Reglamento, como la contenida en el art. 5 del código mencionado, que transcribe como art. 9:

Código Fiscal de la Federación

Las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las que señalan excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta. Se considera que establecen cargas a los particulares las normas que se refieren al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa.

Ley del Seguro Social

Las disposiciones fiscales de esta Ley que establecen cargas a los particulares y las que señalan excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta. Se considera que establecen cargas las normas que se refieren al sujeto, objeto, base de cotización y tasa.

Por la naturaleza de la Ley que atiende principios de seguridad social (art. 4), para garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo (art. 2), debía precisarse que sólo las normas relativas al cobro de cuotas, capitales constitutivos, su actualización y los recargos (art. 287), tienen carácter fiscal, toda vez que únicamente para esos efectos se confiere al Instituto la categoría de organismo fiscal autónomo (art. 288). No se trata de un ordenamiento fiscalizador, sino prestador de servicios en beneficio de los asegurados y sus beneficiarios, en primer lugar, sin poder confundir su naturaleza y sus fines. Tan es así que la Ley confiere a sus créditos el rango de "preferentes a los fiscales" (art. 289).

Tipos de seguro

La LSS, a partir de su antecedente del 1 de abril de 1973, distingue dos tipos de seguro (art. 6): el obligatorio y el voluntario.

Régimen obligatorio

La obligatoriedad se refleja tanto en la inscripción como en el pago de cuotas. El art. 15 dispone que los patrones están obligados a registrarse e inscribir a sus trabajadores en el IMSS, en un plazo no mayor de cinco días, así como a enterar el importe de las cuotas obrero patronales. La omisión en el cumplimiento puede hacerlos objeto de sanciones y responsabilidades (art. 18).

Régimen voluntario

El régimen voluntario se refiere a:

- a) El seguro de salud para la familia, a favor de todos sus integrantes, que tienen derecho a un seguro de enfermedades y maternidad, mediante convenio (Capítulo I del Título Tercero).
- b) La seguridad social en el campo, tanto campesinos como trabajadores asalariados (arts. 234, 235 y 237).
- c) Los grupos de aseguramiento a que se refiere el art. 13: no asalariados, patrones personas físicas, trabajadores domésticos, cuya incorporación se deja como facultad discrecional del Instituto, por lo que hace a plazos, condiciones y modalidades.

Por tanto, en el sistema de la Ley la diferencia entre un seguro obligatorio y uno voluntario depende del trato que se da a los sujetos comprendidos en los

arts. 12 y 13. El supuesto jurídico era el mismo en la Ley vigente hasta junio de 1997, donde señalaba:

Artículo 12. Son sujetos de aseguramiento al régimen obligatorio.

Artículo 13. Igualmente son sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio...

El adverbio de modo que se empleaba en el segundo de los preceptos, "igualmente", significa: con igualdad, también, asimismo; esta palabra obligaba a dar el mismo trato y sujetar a iguales condiciones ambos supuestos, lo que no sucedía en la práctica. La nueva Ley, con mejor técnica señala:

Artículo 13. Voluntariamente, podrán ser sujetos de aseguramiento obligatorio...

Por otra parte, en el mismo artículo se pone fin a un precepto inconstitucional que daba facultades al Presidente de la República, cuando en el párrafo final señalaba: "El Ejecutivo Federal, a propuesta del Instituto, determinará por decreto, las modalidades y fecha de incorporación obligatoria... de los sujetos de aseguramiento comprendidos en este artículo..."

El art. 18 disponía que en tanto se expedieran los decretos, los sujetos de aseguramiento del art. 13 podrían ser incorporados en los términos previstos en el capítulo VIII de este Título, lo que implicaba una diferencia de fondo que dejaba sin efecto el adverbio "igualmente" del art. 13.

En la parte final del art. 13 se dispone:

Mediante convenio con el Instituto se establecerán las modalidades y fechas de incorporación al régimen obligatorio, de los sujetos de aseguramiento comprendidos en este artículo.- Dichos convenios deberán sujetarse al reglamento que al efecto expida el Ejecutivo Federal.

Si los sujetos pueden incorporarse y el Instituto está facultado para abrir lapsos de inscripción, no estamos ante un régimen obligatorio, sino ante un régimen *voluntario*. En el estudio de la Ley se observa la figura "de la continuación voluntaria en el régimen obligatorio", en la que "el asegurado... al ser dado de baja tiene el derecho a continuar voluntariamente en el mismo..." (art. 218) y donde esta continuación terminará por declaración expresa firmada por el asegurado, o por dejar de pagar las cuotas durante seis meses (art. 220), lo que significa que el asegurado se inscribe y da de baja a su conveniencia.

Régimen facultativo

La Ley permite al Instituto contratar con las familias que lo deseen un seguro de salud (art. 240), con características que son propias del seguro facultativo.

En éste, sólo se otorgan prestaciones en especie dentro del seguro de enfermedades y maternidad, tanto para los reconocidos por la Ley: cónyuge, concubino(a), descendientes y ascendientes, como para aquellos que dependen económicamente del asegurado (art. 241) y que no estén protegidos. Las modalidades que se convengan (art. 245) hacen posible establecer la forma de poner término al aseguramiento.

Régimen adicional

Los seguros adicionales también serán objeto de convenios (art. 246) para satisfacer las prestaciones económicas pactadas en los contratos ley o en los contratos colectivos de trabajo, superiores a los establecidos en el Seguro Social (art. 247). Al pactarse las condiciones puede convenirse sobre la forma de terminación.

Seguros del Seguro

Conforme a la determinación de la fracc. XXIX del art. 123 A constitucional, se establece un sistema de cinco seguros en el art. 11:

1. Seguro de riesgos de trabajo
 2. Seguro de enfermedades y maternidad
 3. Seguro de invalidez y vida
 4. Seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez
 5. Seguro de guarderías y prestaciones sociales
1. El *riesgo de trabajo* es al "que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo". Deja fuera a los miembros de sociedades cooperativas y a los sujetos del art. 13: campesinos, no asalariados, trabajadores domésticos y servidores públicos.
- Desde luego, con esta distinción se mantiene a los trabajadores en una situación de privilegio frente a los otros grupos sociales, lo que reafirma la idea de que el IMSS es un seguro de los trabajadores, donde las otras personas comprendidas tendrán beneficios sólo en forma accesorio.
- Esta distinción permite insistir en la reestructuración de los seguros para adecuarlos a todos los grupos sociales y proteger lo mismo al pequeño comerciante que se accidenta al trasladar su mercancía, al vendedor de billetes de lotería, al aseador de calzado, al ejidatario o a quien labore en un taller, una oficina o en una gran empresa. El supuesto que determina la incorporación es la actividad llevada a cabo por la persona; ese

desempeño le enfrenta a posibles contingencias contra las que se asegura; cuando ocurren, se le deben otorgar prestaciones adecuadas.

2. El *seguro de enfermedades y la maternidad* limita las prestaciones al no comprender expresamente al accidente. La *enfermedad* es un “estado patológico derivado de la acción continuada de una causa” (art. 43); el accidente es resultado de una “lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o posterior. . . producida repentinamente. . .” (art. 42). Sería más correcto denominar a este seguro como *seguro de salud* y comprender los supuestos del accidente, la enfermedad, la invalidez y la muerte, así como las consecuencias del embarazo.
3. El *seguro de invalidez y vida* toma parte del anterior de “invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte”; se distingue la invalidez de la incapacidad por riesgo de trabajo, aun cuando gramaticalmente tengan el mismo sentido. *Incapacidad* es la falta de aptitud para hacer una cosa; *inválido* se dice de la persona que adolece de un defecto físico o mental, ya sea congénito o adquirido, lo cual le impide o dificulta alguna de sus actividades. Ambos términos se refieren a la disminución orgánica funcional que padece un trabajador-asegurado.
4. El cuarto *seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez*, une el antiguo ramo quinto de retiro, que es más un seguro adicional integrado por un fondo que administran las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore). Para generar el derecho a la pensión por cesantía en edad avanzada y la vejez se exigen 1 250 semanas (más de 24 años de cotización).
5. En el *seguro de guarderías y prestaciones sociales*, las guarderías son, como se apuntó, prestaciones derivadas de la maternidad; las *prestaciones sociales* son de importancia, pero su otorgamiento queda condicionado a las posibilidades financieras del Instituto.

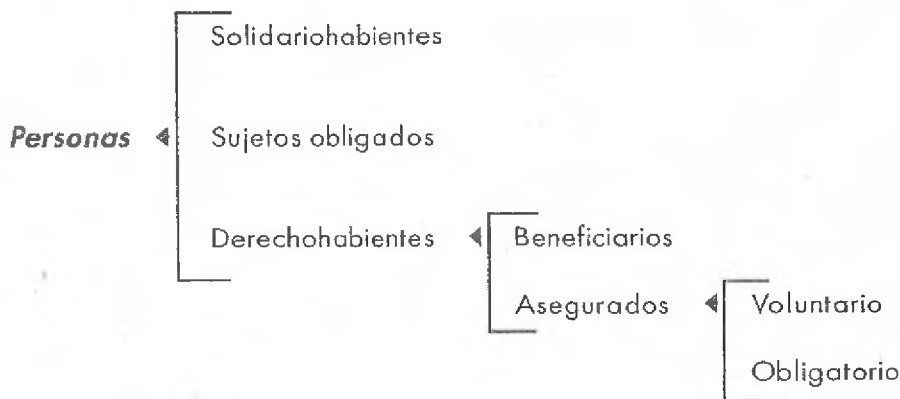
La adecuada distinción de los seguros del Seguro Social hace posible su comprensión, así como el otorgamiento de prestaciones.

Personas

Debemos distinguir la población derechohabiente en relación con la de solidariohabiente. Los primeros generan a su favor derechos que pueden hacer valer ante los tribunales; los segundos carecen de derechos concretos que puedan reclamar.

Los derechohabientes se subdividen en asegurados y beneficiarios. Los primeros pertenecen al régimen obligatorio o voluntario; los beneficiarios son el (la) cónyuge o concubino(a) y los familiares de los asegurados, que por ley tienen a su favor los servicios médicos y en algunos casos prestaciones económicas.

A continuación se presenta esquemáticamente la clasificación de las personas:



Derechohabientes

Asegurados

Los sujetos de aseguramiento que pertenecen tanto al seguro obligatorio como al voluntario se enlistan por grupos en los arts. 12 y 13. La nueva Ley, con una mejor redacción, mantiene el viejo error de no distinguir los tipos de seguro y pretender englobarlos dentro del seguro obligatorio. Además, aun cuando suprime la figura del decreto del Ejecutivo para la incorporación de los grupos mencionados en el art. 13, incluye ahora como tercera fracción del art. 12 a las personas que determine el Ejecutivo mediante decreto, sin establecer limitaciones o condiciones para dicha incorporación.

Artículo 12. Los grupos contenidos en este precepto corresponden al régimen obligatorio, sin condición; deben incorporarse o ser inscritos en el momento en que tengan el carácter que en cada caso determina la Ley. La falta de afiliación dará lugar a la aplicación de sanción.

Trabajadores. La fracc. I del art. 12 considera a las personas vinculadas a otras, de manera permanente o eventual, por una relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé origen y cualquiera que sea la personalidad jurídica o la naturaleza económica del patrón y aun cuando éste, en virtud de alguna ley especial, esté exento del pago de impuestos o derechos. Con este criterio evita que mediante un contrato de prestación de servicios, de comisión mercantil o cualquier otro acto, hasta por *outsourcing*, se eluda la obligación.

Miembros de sociedades cooperativas. A partir de la Ley de 1943 quedan incluidos como sujetos del régimen obligatorio, en los mismos términos y condiciones que los trabajadores, las cooperativas; además se complementa en el art. 19 de la Ley: "Las sociedades cooperativas de producción y las administraciones obreras o mixtas serán consideradas como patrones para los efectos de esta Ley." Sin embargo, es grave defecto considerarlas como patrones, con lo que se lesiona la naturaleza jurídica de la cooperativa; lo correcto sería señalar: "Las sociedades cooperativas de producción y las administraciones obreras o mixtas tendrán las obligaciones que señala el artículo 15."

Personas que determine el Ejecutivo Federal a través del Decreto respectivo, bajo los términos y las condiciones que señala esta Ley. El uso desmedido de esta facultad consignada en el art. 13 de la Ley de 1973 propició un crecimiento, con graves costos y prestaciones inequitativas.

Artículo 13. En este precepto se menciona a los grupos que deben ubicarse en el seguro voluntario, sin que sea adecuada la mención en el enunciado del precepto; "voluntariamente podrán ser sujetos de aseguramiento en el régimen obligatorio". Los términos *voluntariamente* y *podrán* implican que resulta de la voluntad de los sujetos y los grupos, aun cuando se advierta que los capítulos IX y X del Título Segundo establecen tanto las condiciones como los seguros que específicamente pueden en cada caso establecerse, de los arts. 222 al 239. En este régimen podrán incorporarse los trabajadores en industrias familiares y los no asalariados, los trabajadores domésticos, los campesinos, los patrones, las personas físicas y los trabajadores en administraciones públicas.

Las características de los grupos señalados en el art. 13 se indican en el último párrafo: "Mediante convenio se establecerán las modalidades y fechas de incorporación al régimen obligatorio, de los sujetos de aseguramiento comprendidos en este artículo."

No asalariados. Son las personas que desempeñan por propia cuenta una actividad económica que les permite obtener ingresos para atender sus necesidades, sin estar subordinados a alguna persona física o moral. En este rubro se incluyen lo mismo a los integrantes de industrias familiares –padres, cónyuges, ascendientes, descendientes–, profesionales, actores, artesanos, vendedores ambulantes, comerciantes en pequeño, taxistas, aseadores de calzado, billeteros, voceadores y a quienes realizan un sinnúmero de actividades más.

Algunas de estas personas se han integrado en sociedades y asociaciones de carácter civil, en uniones, federaciones y hasta en sindicatos (sin ser trabajadores), como los vendedores de billetes de la Lotería Nacional, los voceadores de periódicos y los taxistas. Estas

organizaciones convienen con el Seguro Social por razones políticas más que jurídicas o sociales en la incorporación y protección de sus afiliados; en la mayor parte de los casos, generalmente se les asegura en la rama segunda de enfermedades y maternidad, con prestaciones de carácter médico.

Ejidatarios, colonos, comuneros y pequeños propietarios. Los campesinos se distinguen en el capítulo de la seguridad social para el campo (arts. 234 a 239, LSS). La infraestructura del IMSS se ha conformado para atender a los trabajadores urbanos, por lo que es necesario que se estime la conveniencia de impulsar esta seguridad.

El art. 13 no distingue a los sujetos en cuanto a cuotas, prestaciones o modalidad de cualquier índole; para ello debemos remitirnos al art. 222, fracc. II, inciso a), cuyo esquema de aseguramiento comprende:

Para los sujetos a que se refieren la fracciones I y III del artículo 13 de esta Ley, las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad y las correspondientes de los seguros de invalidez y vida, así como de retiro y vejez, en los términos de los capítulos respectivos.

Patrones. Los patrones personas físicas son sujetos de incorporación (art. 13, fracc. IV), con las modalidades establecidas para los grupos de los campesinos.

Trabajadores domésticos. La incorporación queda sujeta a la determinación de los patrones, sin que las personas que laboran puedan incorporarse y obligar al patrón. Cuando son inscritos, el Seguro Social les da un trato y prestaciones en las mismas condiciones que a los no asalariados.

Beneficiarios

El Seguro Social ha protegido a las personas que supuestamente dependen del trabajador y de la trabajadora, en el ánimo de proteger a la familia como núcleo social. Se protege al o a la cónyuge, en su ausencia al concubino(a); a los hijos en todos los casos, y, en ausencia de los anteriores sujetos, a los ascendientes.

Cónyuge. A la cónyuge no se le condiciona para el otorgamiento de las prestaciones, salvo que entre la fecha del matrimonio y la del fallecimiento no hubieran transcurrido más de seis meses, cuando el cónyuge fuese mayor de 55 años en el momento del matrimonio y no hubiera transcurrido más de un año de la fecha de la muerte o cuando al contraer matrimonio el cónyuge fuese pensionado por invalidez, vejez y cesantía (esto último es un absurdo, pues para

recibir la pensión la vejez debe tener una edad mínima de 65 años y para la de cesantía de 60 años), a menos que hubiera transcurrido un año después del matrimonio. La concubina tiene limitaciones, como haber vivido cinco años en relación marital o haber procreado hijos. El cónyuge y el concubino tienen que depender económicamente de la mujer trabajadora.

Hijos. Tienen derecho en todos los casos, hasta que cumplan 16 años; después de esa edad, sólo los que estudien en algún plantel del sistema educativo nacional, hasta los 25 años y por todo el tiempo necesario en caso de incapacidad del huérfano y siempre que hayan dependido económicamente del trabajador asegurado fallecido.

Ascendientes. Tienen derecho por excepción, cuando no existan personas para gozar de pensión de viudez u orfandad, siempre que hayan dependido económicamente del trabajador asegurado fallecido, lo que es un requisito difícil de satisfacer, en muchos casos.

Sujetos obligados

Los sujetos obligados son el patrón, las sociedades cooperativas y otros no determinados.

El patrón es el primer obligado y aporta el mayor porcentaje de las cuotas en cada seguro. Para el concepto, el art. 5 A, fracc IV, remite a la *Ley Federal del Trabajo*, que en su art. 10 considera que patrón es la persona física o moral que recibe el beneficio derivado de la prestación de servicios de uno o varios trabajadores. La LSS equipara a las sociedades cooperativas con los patrones en sus arts. 19 y 26, al señalar que "las disposiciones de esta Ley, que se refieren a los patrones y a los trabajadores, serán aplicables, en lo conducente, a los demás sujetos obligados y de aseguramiento".

Las entidades con mayor número de patrones son el Distrito Federal, Jalisco y Nuevo León; los sectores que más se contemplan son los de servicios, comercio, industriales y agropecuario. El art. 16 obliga al patrón por el número de sus trabajadores, en los términos del CFF, a contar con un dictamen elaborado por contador público autorizado sobre sus estados financieros y presentar al Instituto copia con firma autógrafa del informe sobre su situación fiscal, con los anexos referentes a las contribuciones por concepto de cuotas obrero-patronales. Señala, además, que cualquier otro patrón podrá optar por dictaminar en la misma forma, sus aportaciones al Instituto, en términos del reglamento del CFF.

Afiliación

Desde el punto de vista gramatical, *inscripción*, *afiliación* y *registro* son voces afines:

Afiliar: juntar, asociar una persona a otras personas que forman una corporación o sociedad.

Inscribir: apuntar el nombre de una persona en una lista, para un fin determinado.

Registrar: inscribir, presentarse, matricularse.

Tanto *afiliar* como *inscribir* se usan indistintamente en relación con los asegurados y sus beneficiarios.

La ley reserva la palabra *registro* para los sujetos obligados (patrones), quienes deben incorporarse como condición previa a la inscripción de los asegurados. El art. 15 así lo determina al señalar: "Los patrones están obligados a: I. Registrarse e inscribir a sus trabajadores."

Los sujetos obligados tienen que registrarse y afiliar a los sujetos de aseguramiento dentro de un plazo no mayor de cinco días, conforme lo disponga el reglamento.

El *Reglamento de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización*, publicado en el *Diario Oficial de la Federación* el 1 de noviembre de 2002, en sus arts. 3º a 5º regula lo relativo al registro patronal y a la inscripción de los trabajadores, que deberán llevarse a cabo dentro de los cinco días siguientes al inicio de actividades o del ingreso del trabajador, como lo marca el art. 15, fracc. I de la Ley. El patrón debe observar, en relación con el plazo de cinco días, lo establecido en el penúltimo párrafo del art. 77, en donde se dispone:

Los avisos de ingreso o alta de los trabajadores asegurados y los de modificaciones de su salario, entregados al Instituto después de ocurrido el siniestro, en ningún caso liberarán al patrón de la obligación de pagar los capitales constitutivos, aun cuando los hubiese presentado dentro de los plazos que señalan los artículos 15 fracción I y 34 fracciones I a III de este ordenamiento legal.

Sanción

La omisión en el cumplimiento de los deberes impuestos en el art. 15 de la Ley, o la comisión de ciertas conductas, serán sancionadas conforme el art. 40 A con el cobro al patrón o al sujeto obligado, de la actualización y los recargos, en los términos del CFF, sin perjuicio de las sanciones que correspondan. El precepto nos remite a todo un catálogo de sanciones:

1. Multa de 40 a 100% de cuotas, capitales constitutivos, actualizaciones y recargos (art. 304).
2. Delito de defraudación fiscal, conforme a las penas establecidas por el CFF (arts. 305-319) por:

- 2.1. No cubrir el importe de las cuotas obrero-patronales, durante 12 meses o más.
- 2.2. No formular los avisos de inscripción o proporcionar al Instituto datos falsos evadiendo el pago o reduciendo el importe de las cuotas obrero-patronales, en perjuicio del Instituto o de los trabajadores, en un porcentaje de 25% o más de la obligación fiscal.

7

Salario base de cotización y cuota

Concepto

La *Ley del Seguro Social* (LSS) determina en el art. 5 A, fracc. XVIII, que se entenderá por salario “la retribución que la *Ley Federal del Trabajo* define como tal”. La *Ley Federal del Trabajo* (LFT), en el art. 82, define el salario como la remuneración que debe otorgar el patrón al trabajador por sus servicios. El art. 84 contiene los elementos integradores del salario. La LSS hace su propia integración del *salario base de cotización*, con el mismo texto del art. 84 de la ley laboral:

Para efectos de esta Ley, el salario base de cotización se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se integre al trabajador por su trabajo, con excepción de los conceptos previstos en el artículo 27 de la Ley.

La *Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado* (LISSSTE) de 2007, en su art. 17, limita el concepto de sueldo básico al sueldo tarifario; el anterior ordenamiento integraba el sueldo básico con el sueldo presupuestal, el sobresueldo y la compensación, tanto para efectos de aportación como de otorgamiento de prestaciones, incluida, desde luego, la pensión. La aportación en la LISSSTE resulta ajena a la consideración de contribución, al ser la administración pública, el Congreso de la Unión y el Poder Judicial los sujetos obligados como patrones.

En dichos ordenamientos se estima que la cuenta individual es propiedad del trabajador asegurado, así como que tiene derecho a determinar que su aportación en retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, pueda transferirse

a una cuenta individual y ser administrada por Pensionisste o una empresa privada (Administradora de Fondos para el Retiro, Afore) que seleccione al trabajador para su inversión en acciones mercantiles de una Sociedad de Inversión Especializada en Fondos para el Retiro –Siefore– (contrato con las Afore, cláusula quinta).

La LSS del 19 de enero de 1943 señalaba en su art. 135: “El título donde consta la obligación de pagar las aportaciones tendrá el carácter de ejecutivo”, con lo que se obligaba a la institución a acudir ante los tribunales civiles para demandar el pago, en caso de mora o de incumplimiento con la inscripción. Por reforma del Ejecutivo Federal, en uso de las facultades extraordinarias que le concedió el Congreso de la Unión el 1 de junio de 1942, se reformó este precepto el 24 de noviembre de 1944, para quedar como sigue:

La obligación de pagar las aportaciones tendrá el carácter de fiscal. Corresponderá al Instituto Mexicano del Seguro Social, en su carácter de Organismo Fiscal Autónomo, la determinación de los créditos y de las bases para su liquidación, fijar la cantidad líquida, su percepción y cobro de conformidad con la Ley del Seguro Social.

En el art. 5 A, fracc. XVIII, de la Ley de 1997 no se proporciona un concepto de salario, sino sólo de su forma de integración, lo que hace a la norma confusa y dificulta la interpretación para efectos fiscales, en cuanto a que es el fundamento para el cobro de la cuota, sobre todo cuando toma el texto del art. 84 de la LFT:

Ley Federal del Trabajo

Artículo 82. El salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo.

Ley del Seguro Social

Artículo 5 A, fracc. XVIII. ... Para los efectos de esta Ley, el salario base de cotización se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, y las gratificaciones, percepciones, alimentación, por sus servicios.

Para una interpretación adecuada del art. 82 de la LFT, las prestaciones normales, ordinarias y periódicas son las únicas que deben tomarse en cuenta para incrementar el salario base de cotización. Las prestaciones extraordinarias u ocasionales, tales como horas extras, premios, gratificaciones, estímulos, primas, no se toman en cuenta para el pago regular, semanal o quincenal que debe hacerse al trabajador, sino sólo se cuantifican para efectos de liquidación.

La jurisprudencia definida de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisa:

La Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social, aunque emanadas del mismo órgano legislativo, como lo es el Congreso de la Unión, fueron expedidas por éste con distinto ámbito competencial. En efecto, la primera se emitió en ejercicio de la facultad que el artículo 73 de la Constitución, en su fracción X, concede al Congreso de la Unión "para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123 de la Constitución" y en uso de dicha facultad el Congreso expidió la Ley Federal del Trabajo, que regula como materia privativa suya el contrato de trabajo, uno de cuyos elementos primordiales es el salario. En cambio, la Ley del Seguro Social, según la fracción XXIX, apartado A, del artículo 123 constitucional, "comprenderá seguros de invalidez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes y otros con fines análogos", de donde se sigue que esta última Ley presupone la existencia del contrato de trabajo, pero no lo regula, ni establece o define sus elementos integrantes, entre ellos el salario, pues todo ello corresponde a la Ley Federal del Trabajo. Sobre la base de que existe el contrato de trabajo, la Ley del Seguro Social desarrolla sus normas dentro del ámbito que le fija la fracción XXIX antes citada.- Séptima Época. Tercera parte.

Exclusiones al salario base de cotización

El art. 27 reproduce las exclusiones del art. 32, consignado en la Ley de 1973, por lo que son válidas las interpretaciones, muchas veces extralegales, que llevó a cabo el Consejo Técnico del IMSS en varios acuerdos de 1993. En relación con la ley anterior, el legislador hace pequeñas adecuaciones en las fraccs. III y VIII; en la primera para incluir, además del retiro, a la cesantía en edad avanzada y vejez; en la segunda, para mencionar a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), en sustitución de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por congruencia con las nuevas facultades. Lo más novedoso es la inclusión, conforme al criterio del Consejo Técnico, del pago de las horas extraordinarias, que había omitido la reforma de 1993 a la ley anterior.

Jorge Santamaría García atinadamente menciona:

El Consejo Técnico del IMSS carece de la facultad de reglamentar las leyes y los acuerdos que emite sobre la aplicación de la misma en materia fiscal, no son más que criterios que orientan la actuación de las dependencias del IMSS... pero que no son jurídicamente y formalmente reglamentos y por lo tanto no cuenta el particular con la absoluta seguridad ni de su permanencia ni de su aplicación por parte de las mismas autoridades del Seguro Social.

El art. 27 dispone que se excluyen como integrantes del salario base de cotización los conceptos siguientes:

- I. "Los instrumentos de trabajo tales como herramientas, ropa y otros similares."

La fracción pretende reglamentar lo que por naturaleza está excluido, ya que conforme a la LFT se requiere de la libre disposición de los elementos que integran al salario, conforme lo dispone el art. 98 de ese ordenamiento; por lo que hace a los instrumentos de trabajo, nunca cuenta con la libertad para disponer de ellos en la forma que mejor convenga a sus intereses.

- II. "El ahorro, cuando se integre por un depósito de cantidad semanal, quincenal o mensual igual del trabajador y de la empresa; si se constituye en forma diversa o puede el trabajador retirarlo más de dos veces al año, integrará salario; tampoco se tomarán en cuenta las cantidades otorgadas por el patrón para fines sociales de carácter sindical."

El Consejo Técnico señala: "... cuando el fondo de ahorro se integra mediante aportaciones comunes y periódicas, y la correspondiente al patrón sea igual o inferior a la cantidad aportada por el trabajador, no constituyen salario base de cotización; y si la contribución patronal al fondo de ahorro es mayor que la del trabajador, el salario base de cotización se incrementará únicamente en la cantidad que exceda a la aportada por el trabajador", es decir:

Concepto	No integra	Sí integra
Salario ordinario	N\$ 1 000.00	N\$ 1 000.00
Cuota de ahorro del trabajador	130.00	50.00
Cuota de ahorro del patrón	130.00	130.00
Parte que se integra al salario base de cotización	0.00	80.00

"La cantidad de \$80.00 corresponde al excedente entre el monto que aporta el trabajador y el que otorga el patrón.- En los términos de la ley, con aplicación estricta de la misma, resulta que debería integrarse en el segundo caso el 100% de la cuota patronal, es decir, en nuestro ejemplo: \$130.00.- Esta parte del acuerdo nos parece apropiada, porque de otra manera se provocarían injustas contribuciones por mínimos excedentes en el margen de aportación de cuotas de fondo de ahorro por parte del patrón."

- III. "*Las aportaciones adicionales* que el patrón convenga otorgar a favor de sus trabajadores por concepto de cuotas del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez."

Es un grave error de la Ley considerar como prestaciones excluyentes estas aportaciones que no reúnen las características que la LFT otorga a las que integran salario.

- IV. "... *las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las participaciones en las utilidades de la empresa.*"

Una vez más, incurre en el error al marcar como prestaciones excluyentes estas aportaciones que no reúnen las características que la LFT otorga a las que integran salario, como la libre disposición.

- V. "*La alimentación y la habitación* cuando se entreguen en forma onerosa a los trabajadores..."

Se entiende que son onerosas estas prestaciones cuando representen cada una de ellas, como mínimo, 20% del salario mínimo general diario que rija en el Distrito Federal. La disposición induce al patrón, en contra del interés del trabajador, a cobrar más por estos conceptos, sin efectuar distinción alguna. En el caso de restaurantes y lugares donde se expenden alimentos y cuando se trate de porteros y veladores a quienes se da habitación, así como con los trabajadores domésticos, habrá que cobrar más de 20% del salario mínimo, para que no se integre al salario. Desde luego, cuando se otorgue gratuitamente se incrementa el salario, por interpretación de la LFT, art. 334 relativo a los trabajadores domésticos.

- VI. "*Las despesas en especie o en dinero*, siempre y cuando su importe no rebase el cuarenta por ciento del salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal."

El acuerdo No. 495/93 del Consejo Técnico del IMSS, determina, sobre esta prestación:

Este Consejo Técnico, con fundamento en los artículos 240 fracciones I, IV y XIII, 252 y 253 fracción X Bis de la Ley del Seguro Social, con base en la resolución del Comité de Asuntos Jurídicos de este Cuerpo Colegiado, contenida en el Acta del 12 de agosto de 1993, y con el propósito de precisar el contenido y alcance de algunos de los conceptos regulados por el artículo 32 de la misma Ley, reformado por el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de julio del presente año, acuerda lo siguiente: I. DESPENSA. La fracción VI del artículo 32 determina que no integra salario base de cotización, la despesa en especie o dinero, hasta el 40% del salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal. Cuando este concepto otorgue en un porcentaje superior al señalado en el precepto citado, el excedente integrará el salario base de cotización. También se consideran como despesa los vales destinados para tal fin, que algunas empresas entregan a sus trabajadores. II. Hágase del conocimiento de las

diversas dependencias del Instituto para que se cumpla debidamente y difúndase adecuadamente, a fin de que los patrones y trabajadores tengan un conocimiento preciso al respecto.

Además de los criterios anteriores, vale la pena conocer el emitido al respecto por el Tribunal Fiscal de la Federación, del 30 de abril de 1996, por tratarse de una resolución posterior a la aprobación de las reformas que tienen esta modalidad limitada de exclusión de la despesa y cuya validez se mantiene con la expedición de la nueva Ley:

DESPENSAS. NO INTEGRAN EL SALARIO BASE DE COTIZACIÓN AUN Y CUANDO SE PROPORCIONEN GRATUITAMENTE. Si bien es cierto que en el inciso d) del artículo 32 de la Ley del Seguro Social vigente en 1990, se establece que no se tomarán en cuenta para integrar salario base de cotización, dada su naturaleza, los pagos realizados por concepto de alimentación y habitación que se proporcionen gratuitamente al trabajador, así como las despesas, también lo es que el legislador consideró a este último concepto como independiente de la alimentación y habitación de los trabajadores, sin distinguir si las mismas se otorgaban o no en forma gratuita, de ahí que con el solo hecho de otorgarse esta prestación de despesa, es suficiente para considerarla excluida del salario base de cotización.- Juicio de nulidad No. 100(14)570/94/12386/94.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, en sesión de 30 de abril de 1996, por unanimidad de 5 votos.- Magistrado Ponente: Alfonso Nava Negrete.- Secretaria: Lic. Rosa H. Cirigo Barrón. (Tesis aprobada en sesión de 28 de mayo de 1996).

- VII. "Los *premios por asistencia y puntualidad*, siempre que el importe de cada uno de estos conceptos no rebase el diez por ciento del salario base de cotización."

El Consejo Técnico del IMSS determina:

I. PREMIOS POR ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD. La fracción VII del citado Art. 32, dispone que estos conceptos no integran el salario base de cotización, cuando el importe de cada uno de ellos no rebase el 10% de dicho salario. Si se otorgan estas prestaciones en cantidad superior, para cada uno de los conceptos señalados, integrarán el salario base de cotización únicamente las sumas que excedan dichos topos.

- VIII. "Las cantidades aportadas para *finés sociales*, considerándose como tales las entregadas para constituir fondos de algún plan de pensiones establecido por el patrón o derivado de contratación colectiva. Los planes de pensiones serán sólo los que reúnan los requisitos que establezca la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro."

El desconocimiento del Derecho del trabajo lleva a estimar como exento de la cuota lo que está por propia naturaleza, conforme a la ley laboral, al no corresponder a los elementos esenciales de salario por la falta de disponibilidad del trabajador de estas cantidades.

- IX. "El *tiempo extraordinario* dentro de los márgenes señalados en la Ley Federal del Trabajo."

Una gran polémica ocasionó el no mencionar el pago de horas extraordinarias, de tal forma que el Consejo Técnico legisló al respecto mediante el acuerdo 497/93 del Consejo Técnico, donde consideraba que sólo eran de exentarse las horas que conforme a la LFT estuviesen permitidas: nueve a la semana. Este acuerdo ha quedado sin efecto, en virtud de la inclusión de esta fracción. Hay que reiterar que la LFT limita las horas en razón diversa a la integración del salario y establece como sanción contra el patrón y a favor del trabajador que se le cubra 200% de la hora normal en el supuesto de rebasar las nueve a la semana y sólo por las excedentes.

Finalmente, el art. 27 señala: "Para que los conceptos mencionados en este precepto se excluyan como integrantes del salario base de cotización, deberán estar debidamente registrados en la contabilidad del patrón."

Santamaría García formula las conclusiones siguientes:

No es deseable que las disposiciones fiscales queden incompletas, confusas e impensadas al momento que se integran en una modificación a la ley, porque es una cuestión de orden y de práctica y desde luego también de seguridad; nuestro sistema normativo tributario, dentro del entorno general de nuestro sistema jurídico, es un edificio bien construido: el poder legislativo hace las leyes y el poder ejecutivo las reglamenta (*sic*), esto es, emite normas que permitan a los particulares aplicarlas e interpretarlas con mayor exactitud, con precisión y eficacia. ¿Por qué no lograr la conservación de este sistema que da seguridad y es el adecuado para el bien gobernar y además, por si fuera poco, es el que dispone nuestra Constitución? No es posible que al emitir un criterio tan importante como el que orienta sobre la aplicación de la ley, el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social diga lo siguiente: "El criterio que se sustenta sobre horas extras tiene el carácter de provisional, por lo que podrá ser revocado en cualquier momento a juicio del Honorable Consejo Técnico."

Un interesante trabajo gráfico de Norahenid Amezcua culmina con un comentario final:

Estimamos que el IMSS debe revalorar algunos de sus criterios, que más de repercutir negativamente en su recaudación, son abiertamente inconstitucionales, destacando el tratamiento que da al tiempo extraordinario. Sobre el particular, agregamos, que este criterio del IMSS facilita prácticas de sobreexplotación, al

excluir de la integración salarial tiempo extraordinario que repetidamente las autoridades de amparo han calificado como fijo o permanente y por tanto factor de integración salarial.

Trascendencia del salario base de cotización

El art. 28 de la LSS dispone:

Los asegurados se inscribirán con el salario base de cotización que perciban en el momento de su afiliación, estableciéndose como límite superior el equivalente a veinticinco veces el salario mínimo general que rija en el Distrito Federal y como límite inferior el salario mínimo general del área geográfica respectiva.

La existencia de tres zonas con diverso salario mínimo resulta inequitativa, ya que las zonas B y C tienen una cantidad inferior y les afecta que la cotización en su nivel superior se refiera al Distrito Federal. Conforme al art. 36, el salario puede considerarse fijo, variable o mixto.

Salario fijo

El salario se fija por día, semana, quincena o mes (art. 29, fracc. II). La remuneración se dividirá, según el caso, entre siete, 15 o 30; si estuviese fijada por decena o cualquier otro periodo, procede una operación matemática similar. Cuando además de los elementos fijos, el trabajador perciba otras retribuciones periódicas de cuantía previamente conocida, éstas se sumarán a dichos elementos fijos (art. 30, fracc. I). Lo anterior significa que debe tratarse de *prestaciones periódicas*, es decir, que se entreguen al trabajador diariamente o con el pago normal del salario, en la forma convenida o acostumbrada, y de *prestaciones de cuantía previamente conocidas*, en cuanto a su monto, de tal manera que pueda tratarse de alimentos o de habitación; también el caso de los propineros, cuando se hubiese convenido o determinado por la inspección de trabajo.

Salario variable

El trabajador recibe cantidades variables que no pueden ser previamente conocidas. Éstas sumarán los ingresos totales percibidos durante el mes inmediato anterior y se dividirán entre el número de días de salario devengado. Si se trata de un trabajador de nuevo ingreso, se calculará el salario promedio que pudiera corresponderle en dicho periodo (art. 30, fracc. II).

En este supuesto se encuentran los destajistas o los vendedores que pueden contratarse por un porcentaje de las operaciones. Desde luego, debe observarse el problema de efectuar los avisos de modificación de salario y de acreditar la forma inicial de cálculo. Lo mismo se aplica a las empresas nuevas.

Salario mixto

El salario se integra con cuota fija y prestaciones variables, como sucede con muchos vendedores o agentes, que además de un salario previamente determinado, reciben comisión, primas o propinas (art. 30, fracc. III). Es común el caso de los meseros que tienen un salario fijo semanal, además de las propinas diarias que perciben.

En la reforma de 2001, en vista de la constitución de sociedades cooperativas, para eludir el pago del seguro o la presentación de salarios integrados conforme a la ley, se adicionó el art. 28 A para establecer que las cooperativas determinarán el salario base de cotización con el total de las percepciones que reciban por la aportación de su trabajo personal:

Artículo 28 A. La base de cotización para los sujetos obligados señalados en la fracción II del artículo 12 de esta Ley, se integrará por el total de las percepciones que reciban por la aportación de su trabajo personal, aplicándose en lo conducente lo establecido en los artículos 28, 29, 30, 32 y demás aplicables de esta Ley. (Estos preceptos son relativos a la forma de inscripción, de cálculo diario y periodos de pago de las cuotas).

Ausencias del trabajador

El art. 31 de la Ley establece la figura de *ausencias del trabajador*, que puede equipararse a la suspensión individual de la relación de trabajo. La razón que se toma en cuenta es la posibilidad de disminuir el monto de la cuota ajustándolo a los lapsos efectivamente laborados, suponiendo la continuación de la relación de trabajo. Se parte del supuesto de que el patrón no pague salarios en los casos siguientes:

1. Cuando las ausencias sean por *periodos de 15 días consecutivos o interrumpidos*, se pagará el importe de las cuotas que corresponda a la Rama II, de enfermedades y maternidad. Los patrones deberán presentar un escrito de aclaración en el que se indiquen los trabajadores y los días de ausentismo.
2. Si las ausencias del trabajador son por *periodos menores de 15 días consecutivos o interrumpidos*, se cotizará y pagará por dichos periodos

únicamente en el seguro de enfermedades y maternidad, para lo cual deberá exhibir las listas de raya o nóminas. Para este efecto, el número de días de cada mes se obtendrá al restar del total de días que contenga el periodo de cuotas de que se trate, el número de ausencias sin pago de salario correspondiente al mismo periodo.

3. Si las ausencias del trabajador son por *periodos de 15 días consecutivos o mayores*, el patrón quedará liberado del pago de las cuotas obrero-patronales, siempre que proceda dar el aviso de baja (art. 37). Para dar el aviso de baja deberá considerar si se trata de una rescisión o de una terminación de la relación laboral, en los términos de la LFT; de otra manera, se expone a que el trabajador lo demande por despido injustificado y presente como prueba el aviso de baja, lo que podría tomarse como una confesión del patrón.
4. En cuanto a las *ausencias temporales por incapacidades médicas* expedidas por el Instituto, no se cubrirán las cuotas obrero-patronales, excepto por lo que se refiere al *ramo de retiro* (art. 168, fracc. I), en cuyo supuesto la cuota a que se refiere es de 2% del salario base de cotización. Debería revisarse el precepto para determinar que se dejaría de cubrir la aportación por retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.

Además del caso de incapacidades, *no es recomendable dejar de cubrir el pago de la cuota*, por los problemas que implica acreditar los supuestos de suspensión, como el de arresto o prisión preventiva.

Modificación de los salarios

La insistencia en el uso de los términos *salario*, *patrón* y *trabajador* los hace limitativos y confusos cuando se aplican a los sujetos de cooperativas, así como a los del régimen voluntario y los otros grupos como los del seguro de salud para la familia. El salario base de cotización podrá modificarse:

- a) Cuando el asegurado esté prestando servicios a un patrón, por aumentos normales o extraordinarios;
- b) En el supuesto de que esté laborando para varios patrones al mismo tiempo.

Modificación con un patrón

Si el salario se modifica cuando el trabajador esté laborando para un solo patrón, el art. 34 obliga a éste a presentar los avisos de modificación en un plazo de cinco días, si es salario fijo; en los 15 días siguientes naturales del mes siguiente, si

el salario fuera variable. Cuando se trate de salario mixto, deberá observarse si el cambio es en el elemento fijo o en los elementos variables, para seguir el plazo de cinco o 15 días, establecido para cada supuesto.

Existencia de varios patrones

Si el asegurado presta sus servicios a varios patrones (art. 33), cada uno cubrirá por separado el importe de la cuota, conforme al salario que pague al trabajador. Cuando la suma de los salarios sea superior al máximo del salario base de cotización (25 veces el mínimo general), los patrones podrán solicitar efectuar el pago de la parte proporcional que les corresponda. Desde luego, resulta de difícil aplicación, por la falta de comunicación entre los patrones y el desconocimiento de la ley por parte de los trabajadores.

Contrato colectivo

Cuando la modificación tenga lugar por revisión del contrato colectivo, el aviso se presentará dentro de los 30 días naturales siguientes a su otorgamiento (art. 34, fracc. III, párrafo final).

Las modificaciones presentadas y las que deben hacerse por cambio de salario mínimo surtirán efecto a partir de la fecha en que ocurrió el cambio, tanto para la cotización como para el pago de las prestaciones (art. 35).

No se contempla el caso de una persona que sea, al mismo tiempo, trabajador y profesionista o no asalariado; es decir, sujeto al régimen obligatorio (art. 12) y con posibilidad de inscribirse en el régimen voluntario (art. 13), para incrementar el monto de sus prestaciones.

Naturaleza de la cuota

La naturaleza jurídica de la cuota es objeto de debate, ya que considerar que es una contribución (art. 2º, fracc. II, CFF) se contrapone con la propiedad que se reconoce del trabajador asegurado y la participación de empresas privadas que administran y la convierten en acciones mercantiles (contrato con las Afore, cláusula quinta).

La problemática del Seguro Social es muy compleja, como se puede derivar de lo estudiado hasta estas líneas, de tal forma que no se limita a una ley y sus repercusiones comprenden diversas ramas del derecho: trabajo, mercantil, fiscal, financiero y hasta penal. La complejidad se incrementa cuando se analiza la naturaleza de la cuota, que parte del salario base de cotización. La LSS no da una definición de la cuota que permita precisar sus características. A partir de 1943 los embates contra el Seguro Social se centraron a combatir

la cuota y su pago, así como la facultad del Instituto para el cobro y los procedimientos económico coactivos.

El Instituto debe contar, para la exigibilidad del pago, con los apoyos legales derivados de su propia naturaleza. Algunos autores dan a la cuota carácter fiscal, lo que obligaría a fundamentarla en la fracc. IV del art. 31 constitucional. Este precepto establece la obligación de los mexicanos a contribuir para los gastos públicos tanto de la Federación como del Distrito Federal o del Estado y municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes; las condiciones se dan en la propia Constitución, en forma clara y precisa. Contribuimos mediante el pago de impuestos, productos, derechos, aprovechamientos y cuotas que atiendan los gastos públicos en alguno de los tres niveles de la administración.

El art. 2º del *Código Fiscal de la Federación* (CFF) señala:

Las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, las que se definen de la siguiente manera: [...]

II. Aportaciones de seguridad social son las contribuciones establecidas en la ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de las obligaciones fijadas por la Ley en materia de seguridad social o a las personas que se benefician en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado.

El Seguro Social (art. 7º) cubre las contingencias y proporciona los servicios que se especifican a propósito de cada régimen particular, mediante prestaciones en especie y en dinero, en la forma y las condiciones previstas por la Ley y sus reglamentos. El Instituto está facultado (art. 251) lo mismo para recaudar las cuotas y percibir los demás recursos (fracc. XII), que para satisfacer las prestaciones establecidas en la Ley (fracc. II). Los recursos del Instituto se integran con las cuotas a cargo de los patrones, trabajadores y demás sujetos que señala la ley, así como con la contribución del Estado (art. 253, fracc. I). La Asamblea General (art. 261) discutirá anualmente para su aprobación o modificación, en su caso, el estado de ingresos y gastos, el balance contable y el presupuesto de ingresos y egresos para el año siguiente.

La suficiencia de los recursos (art. 262) deberá ser examinada periódicamente cada tres años, por lo menos, al practicarse el balance actuarial. En consecuencia, los gastos que efectúa el Instituto son prestaciones determinadas por su Ley conforme a los ingresos que en forma de cuotas paga la población obligada como contraprestaciones. La relación entre prestación y contraprestación es inmediata y directa; a mayor prestación del Instituto corresponde la aportación de una cuota más elevada. Además, el Instituto cuenta con su propio régimen de control, administración y revisión; los egresos se determinan en presupuestos anuales, mediante exámenes periódicos de suficiencia, con base en cálculos

matemático actuariales. Más aún, las cuotas se integran por cada seguro, se contabilizan en forma separada y su único destino es cubrir las prestaciones establecidas en cada seguro, sin que puedan tomarse recursos de uno para cubrir las prestaciones de otro. Así lo ordenan los arts. 70, 105, 146, 167 y 277 E de la LSS.

El gasto público lo realiza la administración pública y atiende necesidades generales; se encuentra en un presupuesto elaborado por el órgano ejecutivo del gobierno y sujeto a la aprobación de un elemento distinto, que es el organismo legislativo local o federal. Desde este punto de vista, por su naturaleza, elaboración, control y aprobación, el gasto del Seguro Social es ajeno al gasto público.

Organismo descentralizado

Ahora bien, hay que determinar si los actos del Instituto caen en la esfera de la administración pública. Corresponden al Ejecutivo los actos de la administración pública a cargo del Presidente de la República y comprende los organismos centralizados como las Secretarías de Estado, el Gobierno del Distrito Federal y los órganos desconcentrados. En otra esfera se ubican las empresas paraestatales, los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal.

En su art. 5 la Ley precisa que la organización y administración del Seguro Social está a cargo del *organismo público descentralizado* que se denomina Instituto Mexicano del Seguro Social. Es fácil entender la voluntad del legislador, al cuidar el interés público y prever las contingencias que motivan el funcionamiento del Seguro Social, al darle el carácter de organismo público descentralizado con elementos de personalidad y patrimonio propios. Es necesario revisar si todo organismo público descentralizado pertenece al ámbito del Ejecutivo Federal, conforme al mandato de la Constitución cuyo titular y responsable tiene atribuciones limitadas y explícitamente establecidas en la Constitución, de tal suerte que SÓLO puede llevar a cabo lo EXPRESAMENTE señalado en Ley Fundamental. El art. 89 constitucional consigna las principales facultades que el Ejecutivo Federal tiene asignadas; en la fracc. XX se precisa que tendrá, además, las que EXPRESAMENTE marquen otros artículos de la propia Ley Fundamental. La revisión de los preceptos constitucionales establece que la única disposición que funda la expedición de la LSS es la fracc. XXIX del art. 123 constitucional. Como lo preciso en la sexta parte de esta obra, acerca de la organización del Seguro Social, el Ejecutivo Federal no cuenta con facultades y obligaciones constitucionales. Los órganos de gobierno –asamblea general, consejo técnico, comisión de vigilancia y dirección general– conforman un marco que le da plena autonomía. El art. 258 lo confirma: “la autoridad suprema del Instituto es la asamblea general, integrada con treinta miembros...”

Con base en lo expuesto obtenemos las conclusiones siguientes:

1. La cuota no es contribución en los términos de la fracc. IV del art. 31 constitucional.

2. Mediante el pago de la cuota no se cubren servicios públicos, sino contraprestaciones.
3. La obligatoriedad de la cuota deriva:
 - a) Del carácter obligatorio del Seguro Social, en los términos de la fracc. XXIX del Apartado A del art. 123 constitucional.
 - b) De la voluntad de los asegurados, cuando queda a su potestad la incorporación al Seguro Social.

Pago de las cuotas

Las cuotas, las actualizaciones, los recargos y los capitales constitutivos tienen carácter fiscal (art. 287). Sólo para efectos de cobro de los conceptos limitadamente contemplados, el Instituto tiene el carácter de organismo fiscal autónomo (art. 288) y, en consecuencia, puede determinar créditos y bases de liquidación, fijarlos en cantidad líquida, cobrarlos y percibirlos.

El pago de las cuotas será por mensualidades vencidas (art. 39), a más tardar los días 17 de cada mes; los capitales constitutivos tienen el carácter de definitivos en el momento de notificarse y deberán pagarse al Instituto dentro de los 15 días hábiles siguientes (véase el capítulo 11: Capitales constitutivos). Lo anterior acaba con el sistema bimestral de pagos, así como con los pagos provisionales, establecidos en la ley anterior.

La falta de pago oportuno de créditos, por pago de cuotas o de capitales constitutivos (art. 40), implica cubrir, a partir de la fecha en que éstos sean exigibles, la actualización y los recargos correspondientes, en términos del CFF. Ante el supuesto de falta de pago o de pago incorrecto, el Instituto podrá determinar y fincar las cuotas en cantidad líquida (art. 39 C); además podrá conceder prórrogas solicitadas tanto por cuotas como por actualización, capitales constitutivos y recargos (arts. 40 C y 40 D); durante el plazo concedido, se causarán recargos sobre el saldo insoluto actualizado en términos del propio CFF. De las prórrogas que involucren al ramo de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, el Instituto deberá informar a la Consar.

Sustitución patronal

La Ley mantiene en sus términos esta figura contenida en la Ley de 1973, en su art. 290. La importante figura jurídica de la sustitución pertenece al ámbito laboral en cuanto a su concepto, regulación y efectos, por lo que la LSS debería respetarla, sin pretender ajustarla a reglas especiales, sobre todo al ampliar a dos años el derecho del Instituto de notificar al nuevo patrón el estado de adeudo del sustituido.

La LFT, en su art. 41, determina la solidaridad obligatoria del sustituido con el sustituto por el término de seis meses, contados a partir de la fecha en que se comuniquen dicha sustitución a los trabajadores o a su representación sindical. El objetivo de la solidaridad es responder a los trabajadores por las prestaciones que puedan adeudarse y evitar las ventas simuladas en perjuicio de los derechos laborales.

El art. 290 de la LSS establece una responsabilidad solidaria del sustituido en relación con el nuevo patrón hasta por el término de dos años, en relación con las obligaciones derivadas de esta Ley, y en forma total, antes de la fecha en que se avise al Instituto de la sustitución patronal fiscal que puede estimarse invasión a la competencia laboral. Dicho artículo considera "que hay sustitución de patrón en el caso de transmisión, por cualquier título, de los bienes esenciales afectos a la explotación, con ánimo de continuarla. El propósito de continuar la explotación se presumirá en todos los casos".

Al recibir el aviso el Instituto comunica al nuevo patrón las obligaciones que adquiere y el estado de adeudo del sustituido, en caso de haberlo. El objeto de esta sustitución es asegurar a favor del Instituto los créditos del anterior patrón adeudados, con anticipación a la cesión o venta.

Caducidad y prescripción

El art. 297 dispone que la caducidad para que el Instituto pueda hacer efectivos los créditos a su favor, es de cinco años a partir de la fecha en la que el patrón notifica la liquidación, o de la fecha en que el Instituto tenga conocimiento del hecho que generó la obligación. Esta disposición debe interpretarse con el art. 298, donde se determina la prescripción de la obligación del patrón de enterar las cuotas y los capitales constitutivos, en el término de cinco años:

Artículo 297. La facultad del Instituto de fijar en cantidad líquida los créditos a su favor se extingue en el término de cinco años no sujeto a interrupción, contado a partir de la fecha de la presentación por el patrón o por cualquier otro sujeto obligado en términos de esta Ley, del aviso o liquidación, o de aquélla en que el propio Instituto tenga conocimiento del hecho generador de la obligación.

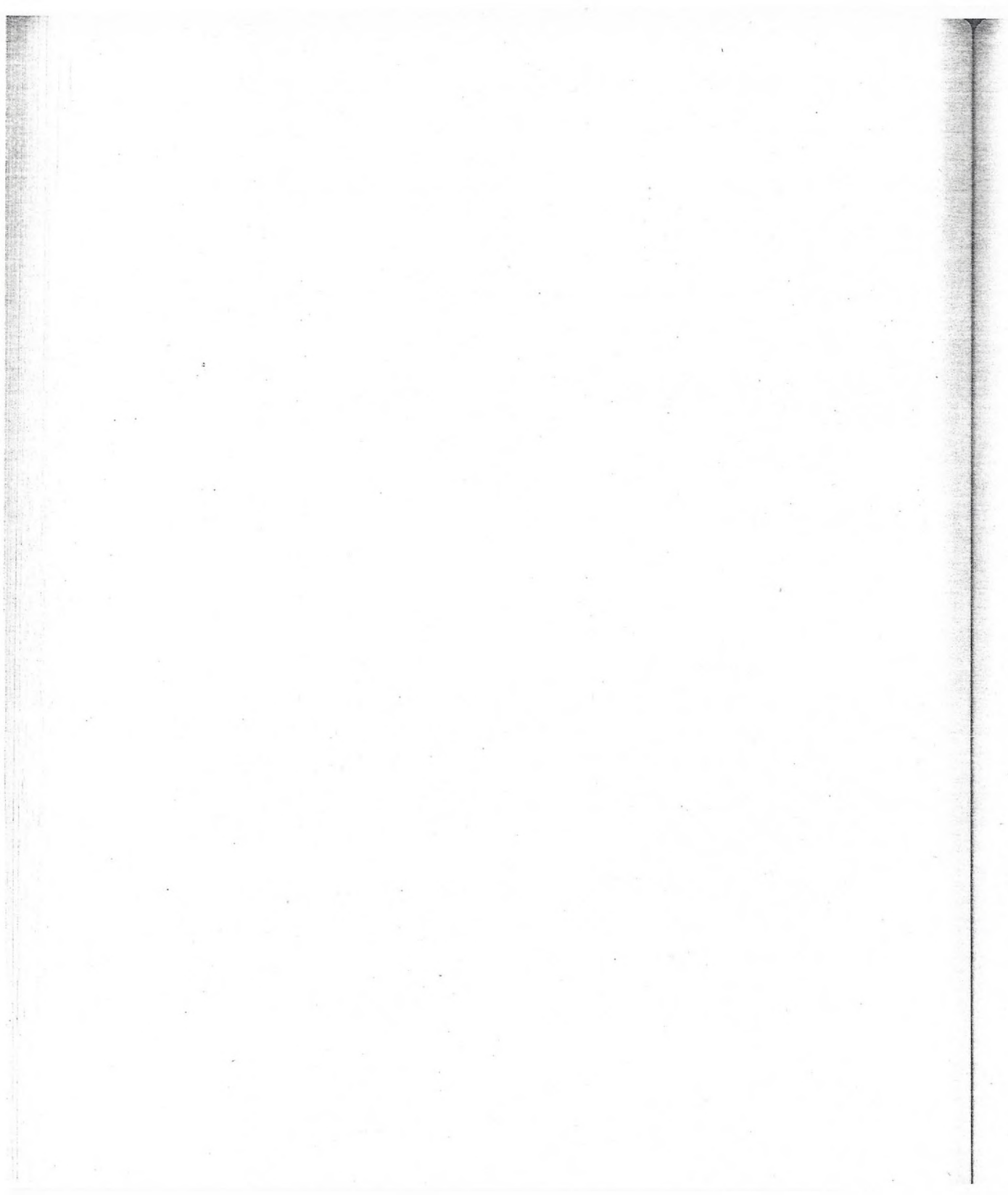
El plazo de caducidad señalado en este artículo sólo se suspenderá cuando se interponga en recurso de inconformidad o juicio.

Artículo 298. La obligación de enterar las cuotas y los capitales constitutivos, prescribirá a los cinco años de la fecha de su exigibilidad.

La prescripción se regirá en cuanto a su consumación e interrupción, por las disposiciones aplicables del Código Fiscal de la Federación.

Cuarta parte

Los seguros del Seguro Social



8 Riesgos de trabajo

El seguro más importante para la protección del trabajador, de la economía familiar, de la empresa y del desarrollo económico es, sin duda, el de los riesgos de trabajo. Esto justifica que las primeras normas, desde la época romana, le dieran importancia; fue desarrollándose conforme se protegía la estabilidad al empleo, la conformación de las fábricas y la especialización de los trabajadores. En las leyes y los códigos del Derecho Civil se regula la relación laboral antes de la expedición de los ordenamientos de trabajo, así como la responsabilidad patronal de atender las consecuencias de los accidentes y las enfermedades que podrían sufrir los obreros, derivados de la instalación de los centros fabriles. Las asambleas de los trabajadores, los congresos, los programas socialistas, los sindicatos y las encíclicas papales reclamaron su atención. Los ordenamientos laborales, las recomendaciones y los convenios internacionales obligan a la intervención de los gobiernos, por su trascendencia social.

Entre los romanos se habló de la *culpa aquiliana* con inversión del *onus probandi*, fundada en la presunción de la responsabilidad del propietario o de la persona que utiliza la cosa inanimada que hiere o mata, con prescindencia de toda idea de culpa, con lo que se origina la responsabilidad subjetiva del riesgo. Con la evolución de esta materia, la obligación del patrón implica tanto brindar atención médica como la reparación del daño. Al respecto, Rodolfo Nápoli escribió:

... en los albores del derecho social no existe ninguna legislación especial que reglamente los accidentes del trabajo, por lo que éstos tenían que regularse por los principios del Derecho civil o común, que sólo admitían la responsabilidad patronal cuando se probaba la existencia de culpa por parte del empresario, con la

limitación propia de ese derecho común, de que la prueba sobre la existencia de la culpa correspondía al obrero. Resultando de todo ello que, realmente el obrero carecía casi de todo derecho, quedando fuera de la protección legal los accidentes debidos a causas fortuitas, así como los debidos a imprudencia profesional del trabajador, y en los casos en que existiera esa repetida culpabilidad patronal, el obrero, carente de medios materiales, se veía imposibilitado de demostrarla.¹

En Inglaterra surge, por primera vez, en forma imperativa, la protección contra los accidentes de trabajo.

Es en Inglaterra donde aparece la primera Sociedad que practica públicamente el seguro de accidentes de trabajo: es la *Railway Passengers Company* que, como su título indica, no se refiere exclusivamente a los trabajadores al servicio de las compañías ferroviarias, sino que también comprendía a los usuarios del ferrocarril, limitándose el seguro a los casos de muerte. Esta Compañía nace en 1845, y un año después aparece otra Compañía también inglesa, que ya cubre todas las consecuencias de los accidentes.- Rápidamente se extiende este seguro a Francia, Alemania, Italia y finalmente al mundo entero, ya con el carácter amplio con que hoy se le conoce.- Legislativamente es también Inglaterra quien primeramente regula el seguro de accidentes del trabajo, organizándolo por la *Employer's Liability Act*, de 1880 y regulándolo con carácter obligatorio a partir de la *Workman's Compensation Act*.

Teorías del riesgo

La necesaria atención a los accidentes de trabajo y a las enfermedades profesionales provocó que los estudiosos del Derecho Civil, en atención a las condiciones históricas de protección a los trabajadores, elaboraran teorías con el fin de determinar, en primera instancia, la responsabilidad del patrón para hacer frente a las consecuencias. Se estima que éste es responsable cuando, mediante una conducta dolosa o culpable de su parte, se hubiera ocasionado accidente de trabajo o la enfermedad profesional. Las doctrinas evolucionaron para considerar primariamente la atención al riesgo creado.

Teoría de la culpa subjetiva

Esta teoría parte de la culpa o negligencia patronal e impone al patrón la obligación de indemnizar al trabajador por el riesgo sufrido. Para obtener el

1 Rodolfo Nápoli, *Derecho del trabajo y de la seguridad social*, La Ley, Buenos Aires, 1969, p. 550.

beneficio era necesario que el trabajador acreditara la responsabilidad expresa del patrón y acudiera a los tribunales civiles. El patrón podía alegar en su favor el principio de que a lo imposible nadie está obligado e incluso señalar que el accidente se debía a una falta inexcusable del trabajador.

Como escribe M. García Corachan:

... no siempre el accidente es debido a culpa o negligencia patronales, incluso se puede decir que hoy, las menos de las veces, el accidente laboral es debido a esas causas. En ocasiones ocurre a consecuencia de fuerza mayor, no imputables ni a la empresa ni al productor; otras veces es debido a la propia negligencia o culpa del mismo trabajador accidentado, quien, familiarizado con su cotidiana labor y llevado de la confianza que la misma le inspira, prescinde hasta de las más elementales precauciones en el desarrollo de su trabajo, y en otras ocasiones, las menos, el accidente reconoce como causa la falta de precaución del empresario.

Teoría del riesgo creado o contractual

Esta teoría se basa en la idea de que quien establece una empresa debe ser responsable de las consecuencias de los riesgos que se generen; lo cual lleva al absurdo de estimar que quien es causa de la causa es causa de lo causado. De esta forma, la incorporación de los trabajadores a la empresa obliga a cubrir todas las circunstancias que se originan de la relación laboral y, desde luego, los riesgos a los cuales se encuentran expuestos. Si bien hace a un lado la responsabilidad directa y acreditada del patrón, todavía deja abierta la posibilidad de que éste se liberara de responsabilidad mediante la prueba "de que no hubo ni culpa ni negligencia de su parte, o que el accidente se debió a caso fortuito —del cual nadie responde— o que se debió a culpa del obrero".

Saleilles y Josserand parten de la observación de que existen accidentes inevitables que constituyen peligros inherentes a la empresa y propios de determinadas industrias, con prescindencia de la voluntad y la aplicación de un principio de justicia, donde el titular de ella debe soportar los riesgos en cuyo interés funciona el organismo que él ha creado y toda vez que su funcionamiento no marcha sin inconvenientes y sin la posibilidad de ocasionar perjuicios. Atiende las consecuencias del riesgo y elimina la noción de que la responsabilidad del patrón deriva de culpa o dolo, para hacer recaer en la empresa la atención debida al trabajador, derivada de un accidente o de una enfermedad. De la misma forma en que se atiende a la reparación de los bienes necesarios para la producción o los servicios, donde no se determina al sujeto culpable —excepto en los casos de negligencia acreditada—, debe reponerse al trabajador como el factor más importante de la empresa.

Fusinato define al *riesgo profesional* como "el conjunto de causas de peligro permanente, superiores a toda cautela de seguridad, que residen en las

condiciones mismas de la industria y en las necesidades impuestas a su funcionamiento”.

Alejandro M. Unsain afirma al respecto: “la producción industrial expone al trabajador a ciertos riesgos e incumbe al patrono la obligación de indemnizar a la víctima, por ser él quien recoge el provecho de aquella producción”.

Nueva actitud

El derecho del seguro social tiene una intención más clara al determinar la protección del trabajador, en su calidad de ser humano, preservando su valor acorde con las estructuras del derecho del trabajo, para alejar la idea de que el trabajo pueda considerarse una mercancía y se respete la dignidad de quien lo realiza, en condiciones que pueda garantizar la subsistencia, la salud y con ellas el bienestar del trabajador y de su familia.

Para Unsain, estamos ante una teoría abiertamente opuesta a los sistemas de responsabilidad subjetiva, fundada en la culpa, sea delictual o contractual. Se elimina toda cuestión moral o de índole subjetiva; basta el elemento objetivo (daño) y un vínculo de conexión cualquiera, entre el hecho y el agente, o entre una cosa y el daño.

García Corachan reconoce:

... dentro de la vida laboral el seguro de accidentes del trabajo tiene una excepcional importancia. En primer lugar, de toda la gama de seguros sociales, es el que está más íntimamente relacionado con el trabajo y más estrechamente vinculado a él. En los demás seguros laborales se trata de prevenir unas circunstancias adversas, de más o menos importancia, que al privar al productor de sus normales medios de subsistencia podrían conducirle a una situación de miseria, hambre y desesperación, capaz de producir trastornos de tipo social, pero provenientes esas circunstancias, generalmente de causas extrañas al trabajo realizado por el obrero, y siendo el motivo existencial del seguro la debilidad económica del productor que le impide recurrir a otros medios —ahorro o seguro privado— distintos del seguro social para prevenir esas adversas coyunturas. En el seguro de accidentes de trabajo, aún siendo las consecuencias del siniestro iguales que en las demás, se trata, por el contrario, de unas circunstancias adversas, que tienen su origen o causa en el propio trabajo que el obrero realiza, y que se ocasionan, precisamente, por la realización de ese mismo trabajo.

Regulación en el Derecho Mexicano

En nuestro Derecho, las normas reguladoras de protección al trabajador emanan de los apartados A y B del art. 123 constitucional, sin que sus disposicio-

nes eliminen la posibilidad de atención al riesgo creado, reconocido por el Derecho Civil.

Mandato constitucional

La fracc. XIV del art. 123 A constitucional, vigente a partir del 5 de febrero de 1917, contiene la responsabilidad del empresario (patrón) de indemnizar al trabajador ante los infortunios de los riesgos de trabajo. La fracc. XXIX de este numeral no contiene explícitamente el supuesto de riesgo de trabajo.

XIV. Los empresarios serán responsables de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores, sufridas con motivo o en ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten; por lo tanto, los patrones deberán pagar la indemnización correspondiente, según que haya traído como consecuencia la muerte o simplemente incapacidad temporal o permanente para trabajar, de acuerdo con lo que las leyes determinen. Esta responsabilidad subsistirá aún en el caso de que el patrono contrate el trabajo por un intermediario.

[...]

XXIX. Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares.

El mismo art. 123, en su apartado B, relativo al seguro social de los servidores públicos, expresamente los protege contra los riesgos de trabajo.

XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas:

a) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte.

Los códigos civiles anteriores a la expedición de la *Ley Federal del Trabajo* (LFT) del 18 de agosto de 1931, consignan la responsabilidad civil del daño y obligan a su reparación mediante el pago de indemnización. Al expedirse los ordenamientos laborales se adecuan las normas, sin desestimar la figura de indemnización, cuyo cálculo en salarios es superior, aun cuando remiten a la ley laboral para estimar los días.

La LFT, en atención a la disposición constitucional, precisa la forma y los términos en que el patrón otorgará los servicios médicos y los diversos supuestos de indemnización, según el daño resentido.

La *Ley del Seguro Social* (LSS) establece, a partir del ordenamiento de 1943, el seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesional y, a partir

de la Ley de 1973, el seguro de riegos de trabajo, para que mediante la aportación de una cuota el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) proporcione servicios médicos y prestaciones económicas al trabajador.

Es importante considerar si la LSS puede liberar al patrón de una carga que le es impuesta por la Constitución y regulada por la LFT. La obligación del empresario de otorgar indemnización emana de la fracc. XIV del apartado A del art. 123 constitucional, por lo que sólo ésta podría eximir o condicionar su cumplimiento, a la observancia de la LSS.

La LSS, en sus arts. 53 y 78, determina lo siguiente:

- Artículo 53. El patrón que haya asegurado a los trabajadores a su servicio contra riesgos de trabajo, quedará relevado en los términos que señala esta Ley, del cumplimiento de las obligaciones que sobre responsabilidad por esta clase de riesgos establece la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 78. Los patrones que cubrieren los capitales constitutivos determinados por el Instituto, en los casos previstos por el artículo anterior, quedarán liberados, en los términos de esta Ley, del cumplimiento de las obligaciones que sobre responsabilidad por riesgos de trabajo establece la Ley Federal del Trabajo, así como de la de enterar las cuotas que prescribe la propia Ley, por el lapso anterior al siniestro, con respecto al trabajador accidentado y al seguro de riesgos de trabajo; subsistiendo para todos los efectos legales la responsabilidad y sanciones que en todo caso fijen la Ley y sus reglamentos.

No se trata, en el primer precepto, de una relevación absoluta, ya que usa los condicionales "que haya asegurado" y "que cubrieren", de donde resulta que subsiste la obligación para los patrones que no hayan asegurado a sus trabajadores o cuando no cubran el importe de capitales constitutivos. Esto significa que un patrón puede no asegurar a los trabajadores o no cubrir los capitales constitutivos y deberá pagar la indemnización, sin que el IMSS esté facultado para fincar las cuotas o los capitales no pagados. Por otra parte, al señalar "en los términos que señala esta ley", implica la subsistencia de la indemnización, cuando resulta una diferencia a favor del trabajador; se trata, en consecuencia, de una liberación limitada a "los términos de esta ley".

El patrón puede estimar que al pagar la cuota de riesgos de trabajo y los capitales constitutivos no tiene que hacer frente a la obligación laboral y enfrentarse a juicios laborales o civiles.

Los códigos civiles, federal y estatales, la LFT y la LSS imponen obligaciones distintas a los patrones, que permiten al trabajador el ejercicio de diversas acciones.

Ordenamientos civiles

Los códigos federal y locales mantienen, conforme a las teorías del riesgo, disposiciones que ordenan indemnizar a los trabajadores; por ello es necesario repasar los preceptos relativos:

- a) *Código Civil Federal*
- b) *Código Civil para el Distrito Federal*
- c) *Ley Federal del Trabajo*
- d) *Ley del Seguro Social*

Código Civil para el Distrito Federal

En sus arts. 1915, 1935, 1936 y 1937 establece la obligación indemnizatoria del patrón a favor del trabajador.

Artículo 1915. La reparación del daño debe consistir a elección del ofendido en el restablecimiento de la situación anterior, cuando ello sea posible, o en el pago de daños y perjuicios.- Cuando el daño se cause a las personas y produzca la muerte, incapacidad total permanente, parcial permanente, total temporal o parcial temporal, el grado de la reparación se determinará atendiendo a lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo. Para calcular la indemnización que corresponda se tomará como base el cuádruplo del salario mínimo más alto que esté en vigor en la región y se extenderá al número de días que para cada una de las incapacidades mencionadas señala la Ley Federal del Trabajo. En caso de muerte la indemnización corresponderá a los herederos de la víctima.- Los créditos por indemnización cuando la víctima fuere un asalariado son intransferibles y se cubrirán preferentemente en una sola exhibición, salvo convenio entre las partes.

Artículo 1935. Los patrones son responsables de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores sufridas con motivo o ejercicio de la profesión o trabajo que se ejecuten; por tanto, los patrones deben pagar la indemnización correspondiente, según que haya traído como consecuencia la muerte o simplemente la incapacidad temporal o permanente para trabajar. Esta responsabilidad subsistirá aún en el caso de que el patrón contrate el trabajo por intermediario.

Artículo 1936. Incumbe a los patrones el pago de la responsabilidad que nace de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales, independientemente de toda idea de culpa o negligencia de su parte.

Artículo 1937. El patrón no responderá de los accidentes de trabajo, cuando el trabajador voluntariamente (no por imprudencia) los haya producido.

Ley Federal del Trabajo

En atención a lo dispuesto por la fracc. XIV del Apartado A del art. 123 constitucional, regula el sistema de protección en el Título Noveno, dedicado a riesgos de trabajo:

Artículo 472. Las disposiciones de este Título se aplican a todas las relaciones de trabajo, incluidos los trabajos especiales, con la limitación consignada en el artículo 352.

Artículo 352. No se aplicarán a los talleres familiares las disposiciones de esta Ley, con excepción de las normas relativas a higiene y salud.

Artículo 483. Las indemnizaciones por riesgos de trabajo que produzcan incapacidades, se pagarán directamente al trabajador.- En los casos de incapacidad mental, comprobados ante la Junta, la indemnización se pagará a la persona o personas, de las señaladas en el artículo 501, a cuyo cuidado quede; en los casos de muerte del trabajador, se observará lo dispuesto en el artículo 115.

Artículo 484. Para determinar las indemnizaciones a que se refiere este Título, se tomará como base el salario diario que perciba el trabajador al ocurrir el riesgo y los aumentos posteriores que correspondan al empleo que desempeñaba, hasta que se determine el grado de la incapacidad, el de la fecha en que se produzca la muerte o el que percibía al momento de su separación de la empresa.

Artículo 485. La cantidad que se tome como base para el pago de las indemnizaciones no podrá ser inferior al salario mínimo.

Artículo 486. Para determinar las indemnizaciones a que se refiere este Título, si el salario que perciba el trabajador excede el doble del salario mínimo del área geográfica de aplicación a que corresponda el lugar de prestación del trabajo, se considerará esa cantidad como salario máximo. Si el trabajo se presta en lugares de diferentes áreas geográficas de aplicación, el salario máximo será el doble del promedio de los salarios mínimos respectivos.

Artículo 495. Si el riesgo produce al trabajador una incapacidad permanente total, la indemnización consistirá en una cantidad equivalente al importe de mil noventa y cinco días de salario.

Artículo 500. Cuando el riesgo traiga como consecuencia la muerte del trabajador, la indemnización comprenderá:

- I. Dos meses de salario por concepto de gastos funerarios; y
- II. El pago de la cantidad que fija el artículo 502.

Artículo 502. En caso de muerte del trabajador, la indemnización que corresponda a las personas a que se refiere el artículo anterior será la equivalente al importe de setecientos treinta días de salario, sin deducir la indemnización que percibió el trabajador durante el tiempo que estuvo sometido al régimen de incapacidad temporal.

Ley del Seguro Social

La LSS determina que los riesgos de trabajo (art. 41) son los accidentes y las enfermedades a que están expuestos los trabajadores, en ejercicio o con motivo del trabajo.

El patrón estima que al pagar la cuota de riesgos de trabajo y, en su caso, los capitales constitutivos no tiene que hacer frente a las obligaciones laboral y civil.

Materia civil

Riesgo → Responsable → Indemnización

Materia laboral

Riesgo → Responsable → Indemnización

Seguro Social

Riesgo → Prestaciones:

- En dinero
- En especie

Es necesario plantear la conveniencia de modificar la fracc. XIV del Apartado A del art. 123 constitucional, para que señale:

Los empresarios serán responsables de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores, sufridas con motivo o en ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten; por tanto, los patrones deberán pagar la indemnización correspondiente, según que haya traído como consecuencia la muerte o simplemente incapacidad temporal o permanente para trabajar, de acuerdo con lo que las leyes determinen. Esta responsabilidad subsistirá aun en el caso de que el patrono contrate el trabajo por un intermediario. Los patrones cumplirán con esta obligación mediante la incorporación de sus trabajadores en el seguro de riesgos de trabajo, en la forma y los términos que determine la Ley del Seguro Social.

Orígenes del riesgo de trabajo

Partimos, por razón de la materia, de las disposiciones contenidas en la LSS, ordenamiento que remite para su estimación conceptual a los preceptos de la LFT.

El art. 42 de la LSS define el accidente de trabajo de la manera siguiente:

Artículo 42. Se considera accidente de trabajo toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o posterior, o la muerte, producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo, cualquiera que sea el lugar y el tiempo en que se preste.

También se considerará accidente de trabajo el que se produzca al trasladarse el trabajador, directamente de su domicilio al lugar del trabajo, o de éste a aquél.

Sachet lo caracteriza como "un acontecimiento anormal, en general súbitaneo, o por lo menos de una duración corta y limitada que comporta una lesión a la integridad o a la salud del cuerpo humano".

Al eminente jurista italiano Carnelutti le debemos la clasificación de los accidentes en genéricos y específicos: "El trabajo, comienza diciendo, no puede ser nunca coeficiente del infortunio, porque jamás el trabajo es apto para producir en el curso ordinario de la naturaleza el efecto que se concreta en el infortunio. Se requiere siempre la intromisión de un elemento distinto, perturbador del desarrollo normal del trabajo, para que el infortunio suceda. Con lo que se puede decir que el infortunio sobreviene en ocasión del trabajo, toda vez que el trabajo determina el riesgo del cual fue consecuencia el infortunio. Agrega que hay riesgos que incumben en igual forma a todos los hombres, obreros o no, estén o no estén en contacto con una determinada industria, se muevan o no en su órbita. Hay otros riesgos, en cambio, a los cuales están expuestos solamente, o en medida mayor que otros hombres, aquellos que se encuentran en contacto con una industria determinada. Aquél es el riesgo genérico; éste, el riesgo específico. Es riesgo genérico el riesgo que, independientemente de su existencia como en su cantidad de las condiciones peculiares de la industria, grava al obrero como a todo ciudadano de idéntico modo. Por el contrario, es riesgo específico el que, derivando de su existencia o cantidad de las condiciones peculiares de la industria, grava exclusivamente a aquellos que están en contacto con la industria misma o por ésta, en medida mayor que los otros hombres."

De esa noción Carnelutti deriva la necesidad de distinguir aun la categoría de riesgo específico, según se desprenda de las condiciones peculiares de la industria en su existencia o sólo en su cantidad. Será así riesgo específico directo o propio el que, generado por las condiciones peculiares de la industria incumbe exclusivamente a las personas que entran en contacto con ella; riesgo específico indirecto

o impropio el que, independientemente de las condiciones peculiares de la industria, en cuanto se relaciona con su existencia, depende sin embargo de ellas en lo que respecta a su cantidad, es decir, que encuentra en aquellas condiciones la razón de la agravación o empeoramiento, en forma tal que, mientras que concernía a todos y no sólo a los que se encuentran en contacto con la industria, afecte sin embargo a éstos en mayor medida que a aquéllos.²

Por otra parte, en el art. 43 de la LSS se define *enfermedad de trabajo*:

Artículo 43. Enfermedad de trabajo es todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo, o en el medio en que el trabajador se vea obligado a prestar sus servicios. En todo caso, serán enfermedades de trabajo las consignadas en la Ley Federal del Trabajo.

Esta disposición remite a lo dispuesto por el art. 513 de la LFT. Éste amplía la protección al considerar el origen o motivo del riesgo en términos generales, hasta comprender el medio ambiente como causa para calificar de riesgo de trabajo el accidente o la enfermedad. El ambiente puede referirse al inmediato: estar en contacto con sustancias químicas, inhalar polvos, mantenerse en lugares húmedos; y a los aspectos ecológicos ajenos al asegurado, por ejemplo, el cambio a un lugar tropical, aun cuando sea temporal. Esta amplitud justifica la inclusión de los accidentes en tránsito, ocurridos en el traslado directo de la casa al centro de trabajo y viceversa.

En su aplicación se presentan muchas limitaciones y dudas. El Consejo Técnico, al contestar consulta de las delegaciones al respecto, dictó el acuerdo núm. 8498 del 2 de septiembre de 1981, válido en la actualidad, al mantener la disposición del ordenamiento abrogado:

- I. La regla general seguirá siendo la que establece el artículo 49 de la Ley del Seguro Social... de manera que no será admisible aceptar como profesional en tránsito, el accidente que ocurra dentro del domicilio.
- II. Los casos de excepción a la regla general aludida en el punto I quedan estrictamente restringidos a aquellos en que el trabajador no salga de su propio domicilio hacia el centro de trabajo, en razón de que lo haga de un domicilio transitorio en el que hubiera tenido necesidad urgente de pernoctar por razones o circunstancias que deberán acreditarse plenamente, como sería el caso de quien tuvo que velar a un ascendiente o a un hijo enfermo en el domicilio de éstos y de ahí salió para su centro de trabajo; o en el caso de que un trabajador que acude sucesivamente a distintos centros de trabajo en los que presta sus servicios, sufre el accidente en el trayecto entre el primero de ellos y el segundo.

2 E. Borrajo Dacruz, *Estudios jurídicos de previsión social*, Aguilar, Madrid, 1962, p. 144.

- III. También constituirán casos de excepción aquellos en los que el traslado del domicilio al trabajo o de éste a aquél no se efectúe directamente sino con una alteración habitual consistente en llevar a los hijos a la guardería o pasar por ellos de regreso. En todo caso, también estas circunstancias deberán probarse plenamente.
- IV. Cuando se trate de accidentes en tránsito, sobre los cuales no se realizaron actuaciones de policía ni de ministerio público, para precisar las circunstancias en que ocurrió el siniestro y en los que el Instituto tampoco tuvo oportunidad de aclarar dichas circunstancias, de manera que ante la afirmación del trabajador o de sus familiares de que el accidente acaeció en tránsito, el Instituto no puede negar la calificación de profesionalidad, por falta de elementos de juicio; o cuando exista duda deberá resolverse en el sentido que resulte más favorable al trabajador, pues no es admisible negar las prestaciones inherentes, con base en presunciones o en opiniones de carácter subjetivo.

La LSS, en su art. 45, estima: "La existencia de estados anteriores como discapacidad física, mental o sensorial, intoxicaciones o enfermedades crónicas, no es causa para disminuir el grado de la incapacidad temporal o permanente, ni las prestaciones que correspondan al trabajador." Al sujeto propenso a una enfermedad no evidente, debe protegerse sin importar la causa inmediata sino sólo la condición de asegurado.

Excepciones al riesgo de trabajo

El art. 46 de la LSS dispone que no se tratará como riesgo de trabajo —sino como enfermedad— el accidente ocurrido en alguna de las siguientes situaciones, similares a las del art. 488 de la LFT:

- I. Encontrándose el trabajador en estado de ebriedad.
- II. Cuando esté bajo la influencia de psicotrópico, narcótico o droga enervante, salvo que exista certificación médica y el trabajador la hubiera exhibido al patrón.
- III. Si el trabajador se ocasiona intencionalmente una incapacidad o lesión por sí o de acuerdo con otra persona.
- IV. Como resultado de riña o intento de suicidio.
- V. En caso de existir delito intencional, donde sea agente activo el trabajador.

Por una parte, la ley amplía ámbitos de protección, atiende al efecto más que a la causa y no busca sujetos responsables, superando las teorías relativas al riesgo creado; con el art. 46 da un paso atrás: mantiene las

excepciones de las leyes de 1943 y de 1973, así como del ordenamiento laboral, con aspectos subjetivos de difícil concreción y valoración.

Veamos en detalle cada supuesto:

- a) Es difícil acreditar la intencionalidad referida al aspecto subjetivo de buscar y querer el daño en la propia persona (art. 46, fracc. III). Además de la dificultad para acreditar este aspecto, se incurre con frecuencia en confundirlo con la falta irresponsable o la imprudencia, en perjuicio del asegurado. Es similar al intento de suicidio (art. 46, fracc. IV), por la dificultad de acreditar los elementos subjetivos que concurren en el deseo de privarse de la vida. La carga de la prueba corresponde al Instituto; en caso de duda, se favorecerá al asegurado (trabajador), sin tener valor como elemento en contra la declaración del patrón o el formulario del Instituto donde se asienten las circunstancias en que ocurrió el accidente. Será suficiente que el asegurado afirme su falta de intención, para poner en duda hasta el dicho de testigos.
- b) Los casos contenidos en las fraccs. I y II son similares; es fácil demostrar el estado del asegurado y determinar hasta el grado de alcohol o los efectos de una droga, psicotrópico o narcótico. Lo complicado es relacionar el accidente con el hecho de haber ocurrido por encontrarse precisamente bajo tales efectos. Además, podemos encontrarlos con que el asegurado no busque el daño ni lo desee, sino que puede resultar de un trastorno mental transitorio, fuera del control del asegurado. Con ello se contraría la doctrina del seguro, al contemplar al propio sujeto como el responsable del daño causado, con una tesis superada de aspecto subjetivo.
- c) La riña es sancionable al facultarse al patrón, por la ley específica, a rescindir la relación laboral. Esta disposición es más grave puesto que no se condiciona a alterar la disciplina, ni permite analizar las circunstancias que puedan haber concurrido.
- d) El último aspecto, la existencia de un delito intencional donde sea el agente activo el asegurado, debe verse con mucho cuidado; las circunstancias del delito deben ocasionar el accidente y opera la relación de causa efecto, con un sujeto responsable del daño.

La revisión de este precepto es importante para mantener aspectos conceptuales y de protección.

El art. 47 atiende los efectos de estos casos al disponer que el asegurado recibirá las prestaciones del ramo segundo, como enfermedad y, en su caso, si reúne las condiciones del ramo tercero, por invalidez. Si fallece, sus beneficiarios recibirán las pensiones asignadas a los riesgos de trabajo. Sin embargo, el art. 123 excluye el otorgamiento de la pensión de invalidez para el

asegurado que se hubiese provocado el daño intencionalmente, por sí u otra persona, así como al responsable de delito intencional y a quien padezca un estado de invalidez anterior a su afiliación al régimen del Seguro.

Artículo 47

En los casos señalados en el artículo anterior se observarán las reglas siguientes:

- I. El trabajador asegurado tendrá derecho a las prestaciones consignadas en el seguro de enfermedades y maternidad o bien a la pensión de invalidez señalada en esta Ley, si reúne los requisitos consignados en las disposiciones relativas, y
- II. Si el riesgo trae como consecuencia la muerte del asegurado, los beneficiados legales de éste tendrán derecho a las prestaciones en dinero que otorga el presente capítulo. Por lo que se refiere a las prestaciones en especie de enfermedades y maternidad, éstas se otorgarán conforme al capítulo IV de este Título.

Artículo 123

No se tiene derecho a disfrutar la pensión de invalidez, cuando el asegurado:

- I. Por sí o de acuerdo con otra persona se haya provocado intencionalmente la invalidez;
 - II. Resulte responsable del delito intencional que originó la invalidez, y
 - III. Padezca un estado de invalidez anterior a su afiliación al régimen obligatorio.
- En los casos de las fracciones I y II, el Instituto podrá otorgar el total o una parte de la pensión a los familiares que tuvieran derecho a las prestaciones que se conceden en el caso de muerte y la pensión se cubrirá mientras dure la invalidez del asegurado.

Es posible que el accidente se deba a una actitud del patrón, quien en forma dolosa o culposa, puede dar lugar al accidente y a la enfermedad. Así como la Ley sanciona al trabajador al desprotegerlo cuando el accidente se deba a su dolo o culpa, estima el incremento de la responsabilidad del patrón. Esta responsabilidad se consigna en la LFT y en la LSS.

Efectos del riesgo de trabajo

Con el objeto de conformar la terminología adecuada para nuestra materia es prudente seguir la terminología de la Ley y considerar como *incapacidad* la

imposibilidad temporal o definitiva de realizar el trabajo que motivó la afiliación, para distinguirla de *inhabilitación* cuando sea ajena al trabajo.

El riesgo de trabajo puede producir (art. 55):

- Incapacidad temporal
- Incapacidad permanente
 - Incapacidad permanente total
 - Incapacidad permanente parcial
- Muerte

La LSS, en el último párrafo del art. 55, remite a la LFT:

Se entenderá por incapacidad temporal, incapacidad permanente parcial e incapacidad permanente total, lo que al respecto disponen los artículos relativos de la Ley Federal del Trabajo.

El art. 478 de la LFT considera *incapacidad temporal* a “la pérdida de facultades o aptitudes que imposibilita parcial o totalmente a una persona para desempeñar su trabajo por algún tiempo”. La *incapacidad permanente parcial*, en los términos del art. 479, “es la disminución de las facultades o aptitudes de una persona para trabajar”. Como *incapacidad permanente total*, el art. 480 considera “la pérdida de facultades o aptitudes de una persona que la imposibilite para desempeñar cualquier trabajo por el resto de su vida”, precepto inadecuado para el Seguro Social.

Al ser inscrito en el Seguro Social, el trabajador precisa la naturaleza de los servicios y la empresa es calificada por la clase y el grado de riesgo conforme a la peligrosidad de su objeto. Esto significa que el trabajador se asegura como despachador, mecanógrafo, pintor, chofer, piloto, obrero en la multiplicidad de funciones, armador, maestro de escuela, mecánico, etcétera.

La incapacidad está en relación directa con las aptitudes para desempeñar esa actividad específica; ésta es causa de su incorporación y motivo de su accidente o enfermedad. La medida de la incapacidad no puede atender, en el Seguro Social, a la aptitud general para el desempeño de cualquier trabajo, sino la de continuar con aquella que originó su incorporación.

En consecuencia, es necesario considerar como incapacidad la pérdida o disminución de facultades o aptitudes del asegurado para continuar en el desempeño de los servicios que motivan su condición de asegurado.

Así, la mecanógrafa que pierda la movilidad de sus dedos será clasificada con una incapacidad *permanente parcial*, y su pensión se basará en los porcentajes dispuestos en el art. 514 de la LFT.

La LFT en su art. 493 considera:

Si la incapacidad parcial consiste en la pérdida absoluta de las facultades o aptitudes del trabajador para desempeñar su profesión, las Juntas de Conciliación y Arbitraje podrían aumentar la indemnización hasta el monto de la que correspondería por incapacidad permanente total, tomando en consideración la importancia de la profesión y la posibilidad de desempeñar una de categoría similar, susceptible de producirle ingresos semejantes.

La facultad que se confiere a las Juntas de Conciliación y Arbitraje permite al trabajador asegurado reclamar el incremento correspondiente. Debía poder hacerlo en un procedimiento especial, conforme el art. 892 de la LFT, por la similitud que tiene con ciertos preceptos, como el 503 —acción para reclamar el pago de la indemnización en los casos de muerte por riesgo de trabajo—; sin embargo, al no estar contemplado este supuesto, el trabajador deberá intentarlo en el procedimiento ordinario del art. 870.

Por otra parte, debía atenderse a la actividad del trabajador asegurado, como lo dispone el art. 119 de la LSS, en el seguro de invalidez:

... existe invalidez cuando el asegurado se halle imposibilitado para procurarse, mediante un trabajo igual, una remuneración superior al cincuenta por ciento de la remuneración habitual percibida durante el último año de trabajo y que esa imposibilidad derive de una enfermedad o accidente no profesionales.

Precisemos las prestaciones contenidas en cada uno de los ordenamientos legales.

Indemnización en la *Ley Federal del Trabajo*

Las prestaciones que establece este ordenamiento son:

- Indemnización
- Prestaciones médicas

El pago de la indemnización se otorga conforme a las reglas siguientes:

1. Si el riesgo produce una incapacidad permanente total, la indemnización consistirá en el pago de 730 días de salario íntegro (art. 502).
2. Se tomará como base el salario diario que perciba el trabajador al ocurrir el riesgo y los aumentos posteriores que correspondan al empleo que desempeña (art. 484).

3. Si el salario excede del doble del salario mínimo del área geográfica de aplicación a que corresponda el lugar de la prestación del trabajo, se considerará esa cantidad como salario máximo. Si el trabajo se presta en lugares de diferentes áreas geográficas de aplicación, el salario máximo será el doble del promedio de los salarios mínimos respectivos (art. 486).
4. La cantidad que se tome como base para el pago de las indemnizaciones no podrá ser inferior al salario mínimo (art. 485).

Si un empleado que sufre un riesgo de trabajo no puede desempeñar su labor, pero sí alguna otra, el patrón estará obligado a proporcionárselo, de conformidad con las disposiciones del contrato colectivo de trabajo (art. 499), susceptible de producirle ingresos semejantes (art. 493).

Las indemnizaciones por riesgos de trabajo que produzcan incapacidades se pagarán directamente al trabajador. En los casos de incapacidad mental, comprobados ante la Junta, la indemnización se pagará a la persona o las personas señaladas en el art. 501, a cuyo cuidado quede el trabajador. En caso de muerte del trabajador, se observará lo dispuesto en el art. 115, sin necesidad de juicio sucesorio (art. 483), y se generan las pensiones por viudez, orfandad o ascendientes (art. 501):

- a) La cónyuge o el cónyuge que hubiese dependido económicamente de la trabajadora y que tenga una incapacidad de 50% o más (fracc. I).
- b) Los hijos menores de 16 años y mayores si tienen una incapacidad de 50% o más (fracc. I).
- c) Los ascendientes concurrirán con las personas mencionadas, a menos que se pruebe que no dependían económicamente del trabajador (fracc. II).
- d) La persona con quien el trabajador vivió como si fuera su cónyuge durante los cinco años que precedieron inmediatamente a su muerte, o con la que tuvo hijos, siempre que ambos hubieran permanecido libres de matrimonio durante el concubinato (fracc. III).
- e) A falta de alguna de las personas anteriores, excepto la concubina, quienes hubieran dependido económicamente del trabajador, concurrirán con la concubina, en la proporción en que cada persona dependía de él (fracc. IV).
- f) A falta de las personas mencionadas en las fracciones anteriores, el IMSS (fracc. V).
- g) Además, los deudos del trabajador tendrán derecho a recibir (art. 500) dos meses de salario por concepto de gastos funerarios y el pago de la cantidad que fija el art. 502, en 730 días de salario íntegro, sin deducir la indemnización que recibió el trabajador, en su caso, por incapacidad temporal.

El procedimiento para el pago de la indemnización se realiza ante la Junta de Conciliación Permanente o la Junta de Conciliación y Arbitraje competente, conforme al domicilio del trabajador o del lugar donde prestó sus servicios, de acuerdo con los aspectos procesales contenidos en el art. 503 de la LFT.

Las prestaciones médicas que debe otorgar el patrón son las mismas que establece la LSS, por lo que nos remitiremos a lo señalado en ellas.

Prestaciones en la *Ley del Seguro Social*

Estas prestaciones se clasifican de la manera siguiente:

- En especie
- En dinero

Las prestaciones médicas que debe otorgar el IMSS (art. 56) son:

- Asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica
- Servicio de hospitalización
- Aparatos de prótesis u ortopedia
- Rehabilitación

Conforme al art. 60 de la LSS, el Instituto expedirá certificados de incapacidad temporal que acreditarán:

- La naturaleza de la incapacidad.
- La justificación de la ausencia en el trabajo.
- El derecho a recibir el pago del subsidio semanal.

Estos certificados reunirán los requisitos determinados por el reglamento.

Las prestaciones en dinero son:

- Subsidio
- Pensión
- Indemnización

Subsidio

Uno de los grandes avances de la Ley de 1973 fue superar las limitaciones que tenía la Ley de 1943, por lo que amplió la protección y otorgó prestaciones médicas ilimitadas y un subsidio de 100% del salario base, por el tiempo que subsistiera la posibilidad de recuperación (art. 65, fracc. I). La Ley de 1997

limita esta prestación al determinar, en la fracc. I del art. 58, que la declaración de incapacidad permanente “deberá realizarse dentro del término de cincuenta y dos semanas que dure la atención médica como consecuencia del accidente, sin perjuicio de que una vez determinada la incapacidad que corresponda, continúe su atención o rehabilitación conforme a lo dispuesto por el artículo 61 de la presente Ley”.

El trabajador mantiene su fuente de trabajo y el tiempo de la incapacidad se toma en cuenta como efectivamente laborado. Cuando un asegurado sea dado de alta (art. 62) y sufra una recaída, tendrá derecho a recibir el mismo subsidio y las prestaciones conforme a este capítulo. Tanto la acción del Instituto como el derecho del trabajador se limitan a un periodo de dos años para revisar la incapacidad, a fin de modificar el importe de la pensión –incrementándolo o disminuyéndolo–; transcurrido ese plazo, se otorgará la pensión definitiva.

Los subsidios se pagarán directamente al asegurado (art. 63). Podrán celebrarse convenios entre el Instituto y los patrones para facilitar el pago a los trabajadores en la empresa, recuperar el importe de los subsidios del Instituto y convenir un pago superior, cuando el salario rebase el tope de la suma de 10 veces el salario mínimo.

Pensión

La pensión se otorga, conforme a lo arts. 58, fraccs. II y III, y 64 de la LSS, en los casos siguientes:

- Incapacidad permanente total.
- Incapacidad permanente parcial, con una valoración superior a 50%.
- Muerte del trabajador asegurado.

La incapacidad permanente, parcial o total, genera derecho a la pensión conforme a las tablas de valuación de la LFT.

Incapacidad permanente total

La Ley hace una distinción entre accidente de trabajo y enfermedad profesional; para el primer supuesto, la pensión equivale a 70% del último salario base de cotización, y para el segundo se calcula el salario promedio de las últimas 52 semanas, o las que tuviera si el lapso de cotización resultara menor.

Accidente de trabajo

70% del último salario base de cotización

Enfermedad profesional

70% del salario promedio de las últimas 52 semanas cotizadas

Incapacidad permanente parcial

Para el cálculo de la pensión deben tomarse en cuenta estos elementos:

1. El monto correspondiente a la incapacidad permanente total, calculada con 70% del salario base de cotización (art. 58, fracc. III).
2. El porcentaje que determine la LFT, conforme la tabla de valuaciones contenida en el art. 514. Este porcentaje se calculará en relación con la incapacidad permanente total.
3. Cuando la valoración sea superior a 25%, el trabajador asegurado puede optar por la indemnización, siempre que la valoración no rebase 50%.

La pérdida de una mano se valora de 65 a 75%; la de un brazo, de 70 a 80%. En los casos en que la LFT marca porcentajes con mínimos y máximos, los índices varían aplicando lo dispuesto por la fracc. III del art. 58 de la LSS:

El monto de la pensión se calculará conforme a la tabla de valuación de incapacidad contenida en la Ley Federal del Trabajo, tomando como base el monto de la pensión que correspondería a la incapacidad permanente total. El tanto por ciento de la incapacidad se fijará entre el máximo y el mínimo establecidos en dicha tabla teniendo en cuenta la edad del trabajador, la importancia de la incapacidad, si ésta es absoluta para el ejercicio de su profesión aun cuando quede habilitado para dedicarse a otra, o que simplemente hayan disminuido sus aptitudes para el desempeño de la misma o para ejercer actividades remuneradas semejantes a su profesión u oficio.

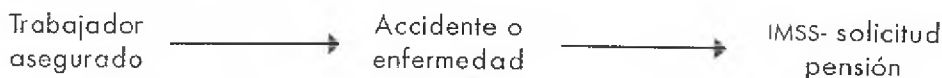
Esta disposición, donde se toma en cuenta las condiciones del asegurado, sería conveniente aplicarla a la incapacidad permanente total.

Podrán reunirse dos o más incapacidades parciales, sin que la suma de ellas exceda el monto total correspondiente a la incapacidad permanente total (art. 67).

Los pensionados tendrán derecho a recibir 15 días de pensión como aguinaldo anual, en los términos del art. 58 de la Ley.

Administración de las pensiones

El sistema vigente implementado desde la Ley de 1943 hasta el 30 de junio de 1997, era el siguiente:



La Ley en vigor a partir del 1 de julio de 1997 determina que el trabajador que sufra un riesgo de trabajo que haya sido calificado con incapacidad permanente, con derecho a recibir una pensión, deberá contratar un seguro de renta vitalicia y otro de sobrevivencia con una institución privada de seguros que elija, en los términos de la fracc. II del art. 58 y el segundo párrafo del art. 62:

Artículo 58.

... Igualmente, el incapacitado deberá contratar un seguro de sobrevivencia para el caso de su fallecimiento, que otorgue a sus beneficiarios las pensiones y demás prestaciones económicas a que tengan derecho en los términos de esta Ley.

La pensión, el seguro de sobrevivencia y las prestaciones económicas a que se refiere el párrafo anterior se otorgarán por la institución de seguros que elija el trabajador. Para contratar los seguros de renta vitalicia y sobrevivencia el Instituto calculará el monto constitutivo necesario para su contratación. Al monto constitutivo se le restará el saldo acumulado en la cuenta individual del trabajador y la diferencia positiva será la suma asegurada, que deberá pagar el Instituto a la institución de seguros elegida por el trabajador para la contratación de los seguros de renta vitalicia y de sobrevivencia. El seguro de sobrevivencia cubrirá, en caso de fallecimiento del pensionado a consecuencia del riesgo de trabajo, la pensión y demás prestaciones económicas a que se refiere este capítulo, a sus beneficiarios; si al momento de producirse el riesgo de trabajo, el asegurado hubiere cotizado cuando menos ciento cincuenta semanas, el seguro de sobrevivencia también cubrirá el fallecimiento de éste por causas distintas a riesgos de trabajo o enfermedades profesionales (*sic*).

Cuando el trabajador tenga una cantidad acumulada en su cuenta individual que sea mayor al necesario para integrar el monto constitutivo para contratar una renta vitalicia que sea superior a la pensión a que tenga derecho, en los términos de este capítulo, así como para contratar el seguro de sobrevivencia podrá optar por:

- a) Retirar la suma excedente en una sola exhibición de su cuenta individual;
- b) Contratar una renta vitalicia por una cuantía mayor; o
- c) Aplicar el excedente a un pago de sobreprima para incrementar los beneficios del seguro de sobrevivencia.

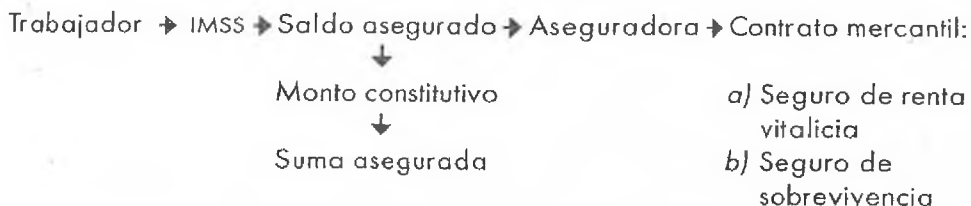
Los seguros de renta vitalicia y de sobrevivencia se sujetarán a lo dispuesto en el artículo 159 fracciones IV y VI de esta Ley.

Artículo 62. [...]

Cuando el asegurado al que se le haya declarado una incapacidad permanente total o parcial que le dé derecho a la contratación de la renta vitalicia y del seguro de sobrevivencia en los términos previstos en los artículos 58 fracciones II y III, 61 y 159 fracciones IV y VI de esta Ley, se rehabilite...

De los anteriores preceptos se deriva:

1. El trabajador asegurado deberá celebrar dos contratos de carácter mercantil, de renta vitalicia y de sobrevivencia, con la institución privada de seguros que estime conveniente.
2. El saldo acumulado en la cuenta individual del trabajador servirá de base para determinar los montos y derechos a la pensión.
3. El monto constitutivo es la cantidad determinada por el IMSS necesario para la celebración del contrato de seguro, de renta vitalicia o de sobrevivencia.



La *suma asegurada* será la que se obtenga de restar al monto constitutivo el saldo asegurado. Si la suma asegurada es la cantidad que deberá pagar el IMSS a la aseguradora, ¿cómo se garantiza la pensión en los términos de cálculo establecidos por la LSS, sobre la base de 70% del último salario base de cotización?

Como puede verse, la suma asegurada resulta de la "diferencia positiva" de restar al monto constitutivo el saldo asegurado, sin establecer el supuesto de que el resultado sea negativo si la cantidad acumulada en su cuenta individual es menor a la necesaria para integrar el monto constitutivo para contratar una renta vitalicia. En este caso, el trabajador deberá reclamar el porcentaje determinado en la LSS.

Cuando la cantidad acumulada sea superior a la requerida para integrar el monto constitutivo, podrá seguir alguna de estas opciones:

- Retirar la cantidad excedente, la cual le será pagada en una sola exhibición.
- Convenir con la aseguradora en el pago de una pensión por una cantidad mayor a la que resulte de aplicar los cálculos establecidos para riesgo de trabajo.
- Convenir con la aseguradora en pagos superiores a favor de sus beneficiarios en las pensiones correspondientes.

El último párrafo del art. 62 sujeta las pensiones a lo dispuesto por el art. 159, fraccs. IV y VI:

Artículo 159. Para efectos de esta Ley, se entenderá por:

[...]

IV. Renta vitalicia, el contrato por el cual la aseguradora a cambio de recibir los recursos acumulados en la cuenta individual se obliga a pagar periódicamente una pensión durante la vida del pensionado.

[...]

VI. Seguro de sobrevivencia, aquél que se contrata por los pensionados, por riesgos de trabajo, por invalidez, por cesantía en edad avanzada o por vejez, con cargo a los recursos de la suma asegurada, adicionada con los recursos de la cuenta individual a favor de sus beneficiarios para otorgarles la pensión, ayudas asistenciales y demás prestaciones en dinero previstas en los respectivos seguros, mediante la renta que se les asignará después del fallecimiento del pensionado, hasta la extinción legal de las pensiones.

El sistema es contradictorio y confuso con la propia Ley, lo que obliga a modificar los preceptos transcritos, para atender lo establecido por el art. 70:

Artículo 70. Las prestaciones del seguro de riesgos de trabajo, inclusive los capitales constitutivos de las rentas líquidas al fin de año y los gastos administrativos, serán cubiertos íntegramente por las cuotas que para este efecto aporten los patrones y demás sujetos obligados.

Las pensiones por riesgo de trabajo, calculadas conforme a la Ley, deben cubrirse única e íntegramente con las cuotas aportadas por el patrón; en todo caso, el monto de la pensión puede incrementarse, si así lo dispone el trabajador asegurado o sus beneficiarios, con el saldo de su cuenta individual.

Indemnización

El término *indemnización*, al ser un resabio de las teorías civiles, es incorrecto en vista de que no hay reparación de daño ni sujeto responsable. La indemnización se refiere a la prestación en dinero que, en sustitución de la pensión, se otorga al asegurado:

- a) En forma obligada, cuando se califique la incapacidad permanente parcial y su valoración sea de 25% o menos.
- b) De manera opcional, cuando el asegurado convenga en esta prestación, siempre que la valoración de la incapacidad sea de 25 a 50%.

La indemnización consiste en el pago en una sola entrega del importe de cinco anualidades de la pensión que podría corresponderle.

Ejemplo 1

<i>Daño:</i> pérdida de la flexión del dedo índice:	8% a 15% (99)
Salario base de cotización diario:	\$ 200.00
Base del cálculo (70% IP):	\$ 140.00 (diario)
Cuantificación del daño (10%):	\$ 14.00 (diario)
	\$ 420.00 (mensual)
Indemnización de 5 años (60 meses):	\$ 25 200.00

Ejemplo 2

<i>Daño:</i> mutilación de un pie con conservación del talón:	35 a 45% (148)
Salario base de cotización diario:	\$ 200.00
Base del cálculo (70% IP):	\$ 140.00
Cuantificación del daño (40%):	\$ 56.00 (diario)
Opciones:	
Pensión:	
• Pensión mensual:	\$ 1 680.00
• Pensión anual:	\$ 20 160.00
• Tiempo promedio estimado de vida (18 años):	\$362 880.00
Indemnización:	
• 5 años (60 mensualidades):	\$100 800.00

Pensión por muerte

En el supuesto de que el riesgo de trabajo produzca la muerte del asegurado, sus beneficiarios tendrán derecho a recibir una pensión. Esta prestación económica confiere la calidad de pensionado al beneficiario, con lo cual tiene derecho a las prestaciones en especie, consignadas para la Rama II: asistencia médica, quirúrgica, hospitalaria y farmacéutica.

En el supuesto de muerte del asegurado o del trabajador pensionado se determinan tres tipos de pensión: viudez, orfandad y ascendientes. Los dos primeros excluyen al tercero; es decir, se da pensión a los ascendientes sólo cuando no exista persona con derecho a recibir la de viudez u orfandad.

Pensión de viudez

Conforme a la fracc. II del art. 64, la pensión de viudez se otorga a la cónyuge, el cónyuge, la concubina o el concubinario (art. 65).

Ejemplo

Salario base de cotización:	\$ 200.00
Base del cálculo (70% IPT):	\$ 140.00
Pensión: diario $\times 40$	\$ 56.00
mensual	\$ 1 680.00

Cónyuges. La cónyuge tiene derecho a recibir la pensión sin condición alguna; en un monto equivalente a 40% de la pensión que le hubiese correspondido al trabajador asegurado fallecido, por incapacidad permanente total.

Concubinato. Los concubinos están protegidos en cuanto a sus derechos para recibir pensión, a pesar de que se condicione al concubinario en la parte final de la fracc. II del art. 64, a la dependencia económica que hubiese tenido de su cónyuge, lo que resulta violatorio del principio de igualdad jurídica que precisa el art. 4º constitucional: "El varón y la mujer son iguales ante la Ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia..."

El varón puede reclamar el pago de la pensión sin necesidad de acreditar la dependencia económica, en términos similares a los de la mujer; si le es negada, podrá recurrir al amparo por violación a la garantía de igualdad jurídica.

La concubina, conforme al art. 65, no tiene la limitante de la dependencia económica. Sin embargo, se establecen los supuestos siguientes:

- Que no exista esposa, lo que es un absurdo jurídico.
- Que haya vivido con el trabajador asegurado por un término de cinco años anteriores al fallecimiento.
- Que haya vivido con él, como si fuera su marido.
- Que ambos hubieran permanecido libres de matrimonio.
- Si hubiera tenido hijos con el trabajador asegurado, se eliminan los anteriores condicionantes, salvo el de la cónyuge.

Es conveniente tomar en cuenta las disposiciones relativas del *Código Civil para el Distrito Federal* (CCDF), por ser el ordenamiento específico que en sus arts. 302 y 1635 consigna la obligación de proporcionarse alimentos y los derechos sucesorios:

Ley del Seguro Social

Artículo 65. Sólo a falta de esposa tendrá derecho a recibir la pensión señalada en la fracción II del artículo anterior, la mujer con quien el asegurado vivió como si fuera su marido durante los cinco años que precedieron inmediatamente a su muerte o con la que tuvo hijos, siempre que ambos hubieran permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. Si al morir el asegurado tenía varias concubinas, ninguna de ellas gozará de pensión.

**Código Civil
para el Distrito Federal**

Artículo 302. ... Los concubinos están obligados, en igual forma, a darse alimentos si se satisfacen los requisitos señalados por el artículo 1635.

Artículo 1635. La concubina y el concubinario tienen derecho a heredarse recíprocamente, aplicándose las disposiciones relativas a la sucesión del cónyuge, siempre que hayan vivido juntos como si fueran cónyuges durante los cinco años que precedieron inmediatamente a su muerte o cuando hayan tenido hijos en común, siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. Si al morir el autor de la herencia le sobreviven varias concubinas o concubinarios en las condiciones mencionadas al principio de este artículo, ninguno de ellos heredará.

El precepto de la LSS podía quedar redactado en los términos siguientes:

Los concubinos tendrán derecho a recibir la pensión señalada en la fracción II del artículo anterior, si acreditan que vivieron, como si fueran cónyuges, durante los cinco años inmediatos que precedieron a la muerte del asegurado, o si de su relación procrearon hijos. Los cónyuges excluyen cualquier otro derecho. En caso de existir varios cónyuges o concubinos, el juez correspondiente determinará cuál de ellos tiene derecho a pensión.

Lo importante es preservar los recursos económicos para la subsistencia de la familia, sin necesidad de dar a la pensión un carácter ajeno a los fines del seguro social. También interesa, desde luego, el sostén tanto del cónyuge, varón

o mujer, como de la concubina o concubinario, cuidando, en su caso, la institución del matrimonio.

Es prudente insistir en la conveniencia de consignar el derecho del asegurado, cuando no tenga beneficiarios, para designar a cualquier persona como receptora de la pensión, sobre todo cuando en la LSS se señala expresamente la propiedad de la cuenta individual a favor del trabajador. Podría tratarse de un hermano, tíos, sobrinos, de quien lo hubiera asistido o de quien se hiciera cargo de los hijos. En todo caso, al ser parte del patrimonio del trabajador debe respetarse el principio de libre disposición estipulado en los arts. 1283 y 1295 del CCDF:

Artículo 1283. El testador puede disponer del todo o de parte de sus bienes. La parte de que no disponga quedará regida por los preceptos de la sucesión legítima.

Artículo 1295. Testamento es un acto personalísimo, revocable y libre, por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte.

El importe de la pensión se pagará durante toda la vida del pensionado, salvo que contraiga matrimonio. La pensión de viudez es compatible con el desempeño de un trabajo, a pesar de que en la nueva Ley ha desaparecido el capítulo de compatibilidad incluido en la Ley de 1973, por lo que puede tener el carácter de asegurado y eventualmente recibir dos pensiones: una generada por su propia situación de incapacidad, invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada y la otra de viudez.

Cuando la viuda (cónyuge o concubina) pensionada contraiga matrimonio, se extinguirá su derecho a pensión y recibirá, en un solo pago, el importe de tres anualidades (art. 66); a esta prestación se le llama finiquito. El precepto establece:

Artículo 66. [...]

Tratándose de la viuda o concubina o, en su caso, del viudo o concubinario, la pensión se pagará mientras no contraigan nupcias o entren en concubinato. Al contraer matrimonio, cualquiera de los beneficiarios mencionados recibirá una suma global equivalente a tres anualidades de la pensión otorgada...

Pensión de orfandad

El derecho se reconoce a “cada uno de los huérfanos”, sin distinción de origen, con las condiciones que la Ley determina (art. 64, fraccs. III a VI).

1. Es importante señalar los varios supuestos que pueden presentarse:
 - a) El huérfano de un padre asegurado, concurre con la madre, cónyuge o concubina.
 - b) El huérfano de un padre o madre asegurado, concurre solo, porque la madre haya fallecido o carezca de derecho.
 - c) El huérfano de un padre o madre, que después queda huérfano del otro progenitor:
 - Si el otro progenitor está asegurado, en caso de fallecer, el hijo tendrá derecho a recibir una segunda pensión, en los mismos términos que determina la Ley, con pago íntegro, pues son compatibles dos pensiones de orfandad.
 - En el supuesto de que el otro progenitor no tuviera calidad de asegurado y fallece, se incrementa la pensión de orfandad de 20 a 30%.
2. Las limitaciones para los hijos son por razón de edad o de su condición:
 - a) En cuanto a edad, se cubrirá la pensión a hijos menores de 16 años, sin limitación o condición (fracc. IV). A los mayores de esa edad se les protegerá hasta los 25 años, cuando se encuentren estudiando en planteles del sistema educativo nacional. Esto se refiere a las escuelas que pertenezcan directamente o estén reconocidas por la Secretaría de Educación Pública, los gobiernos de los estados o las universidades autónomas del país. Además, se requiere que no trabajen y tengan el carácter de asegurados.
 - b) Cuando se encuentren totalmente inhabilitados para desempeñar un trabajo remunerado, por toda la vida o, en su caso, hasta que se recuperen y se les declare aptos, o fallezcan.
 - c) Se otorgará como pensión de orfandad 20% del monto que hubiera correspondido al asegurado fallecido por incapacidad permanente total. Este porcentaje se incrementará a 30% cuando el pensionado quede huérfano de padre y madre y sólo uno de ellos estuviera asegurado. El porcentaje de 20% se manejará en forma independiente cuando falleciera el otro progenitor y estuviera asegurado.

El porcentaje fijo de 20% y 30% en los supuestos anotados debe tomar en cuenta lo dispuesto por el art. 66:

El total de las pensiones atribuidas a las personas señaladas en los artículos anteriores, en caso de fallecimiento del asegurado, no excederá de la que correspondería a éste si hubiese sufrido incapacidad permanente total. En caso de exceso, se reducirán proporcionalmente cada una de las pensiones.

El 100% corresponde al supuesto de la incapacidad permanente total:

- 40% a la pensión de la viudez
- 20% a cada uno de los hijos

La suma permite mantener este porcentaje, sin variación, hasta con tres hijos, para alcanzar el porcentaje total.

La reducción es proporcional de las pensiones de viudez y orfandad, por cada hijo adicional. Esto puede resultar conflictivo con descendientes que no sean de la misma pareja, debido al derecho de cada hijo.

Pensión de ascendientes

Esta es una pensión de excepción. Se otorga únicamente en el supuesto de no existir "viuda, huérfanos o concubina con derecho a pensión" (art. 66, párrafo tercero). La condición no toma en cuenta aspectos importantes, como cuando los abuelos deben hacerse cargo de los huérfanos. Debería limitarse a la existencia de viuda o concubina. Una segunda limitante del art. 66 establece la dependencia económica con el asegurado fallecido, sin marcar parámetros para determinar esa dependencia; lo deja al criterio del Instituto. En primer lugar, debería especificarse el tipo y grado de dependencia, pues se ha llegado al absurdo de condicionar que el padre o la madre vivan en la casa del asegurado fallecido. En algunos casos, donde el contrato de arrendamiento está a nombre del padre o de la madre, se niega la pensión al suponer que no había dependencia económica. Esta pensión debe otorgarse sin otro requisito que dar prioridad a la pensión de viudez.

El monto de la pensión de ascendientes equivale a 20% de la que hubiera correspondido al asegurado fallecido por incapacidad permanente total. En vista de que la Ley no habla de padres ni de parentesco en algún grado, puede comprenderse a todos los ascendientes en línea directa. En esta pensión también se otorga un aguinaldo equivalente al pago de 15 días del monto de la pensión, en diciembre.

Gráfica de las pensiones

Base: monto supuesto del salario base de cotización

\$ 3 000.00 mes

\$ 100.00 día

Accidente de trabajo

70% del salario base de cotización

\$ 2 100.00 mes

Enfermedad profesional

70% del salario promedio último año. Podría ser igual o inferior.

Incapacidad permanente total

Por ejemplo, un trabajador que sufre desviaciones persistentes de la cabeza con acentuado entorpecimiento de los movimientos (art. 514-399, LFT):

Valoración de 30 a 50%	
Salario base de cotización:	\$ 100.00 diarios \$ 3 000.00 mensuales
Pensión por incapacidad permanente total:	\$ 70.00 diarios
Valoración supuesta de 40%:	\$ 28.00 diarios
Cálculo mensual de la pensión (art. 58, fracc. II):	\$ 840.00
Diferencia en relación con el salario:	\$ 2 160.00 mes

Ejemplo 1. Concurren dos hijos solos

Incapacidad permanente total	\$ 2 100.00
Hijo 1 20%	\$ 420.00
Hijo 2 20%	\$ 420.00
Total de pensiones	\$ 840.00

Ejemplo 2. Tres hijos con viuda

Incapacidad permanente total	\$ 2 100.00
Viuda 40%	\$ 840.00
Hijo 20%	\$ 420.00
Hijo 20%	\$ 420.00
Hijo 20%	\$ 420.00
Total de pensiones 100%	\$ 3 000.00

Ejemplo 3. Cuatro hijos con viuda

Incapacidad permanente total		\$ 2 100.00
Viuda	33.34%	\$ 700.14
Hijo	16.66%	\$ 349.86
Hijo	16.66%	\$ 349.86
Hijo	16.66%	\$ 349.86
Hijo	16.66%	\$ 349.86
Total de pensiones	100%	\$ 2 099.58

Ejemplo 4. Cinco hijos con viuda

Incapacidad permanente total		\$ 2 100.00
Viuda	28.57%	\$ 599.97
Hijo	14.28%	\$ 299.88
Hijo	14.28%	\$ 299.88
Hijo	14.28%	\$ 299.88
Hijo	14.28%	\$ 299.88
Hijo	14.28%	\$ 299.88
Total de pensiones	100%	\$ 2 099.37

En el supuesto de que la viuda fallezca o pierda el derecho, se hará una nueva distribución entre los hijos, sin que la suma de las pensiones rebase 100% del cálculo efectuado por incapacidad permanente total.

Cuando alguno de los hijos pierda el derecho, el Instituto efectuará los ajustes necesarios entre la viuda e hijos, con los límites máximos señalados.

La operación de cálculo se efectúa de la manera siguiente, con la concurrencia de la viuda:

$$\begin{aligned} \text{Viuda} & 40 = x \\ \text{Número de hijos (20)} & 4 = x = \frac{100}{120} \\ & x = 0.8333\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (40) (0.8333) &= 33.3320\% \quad (2\,100) (33.3320\%) = \$700.14 \\ (20) (0.8333) &= 16.67\% \quad (2\,100) (16.67\%) = \$349.86 \end{aligned}$$

$$\text{Número de hijos (20)} - 5 = x = \frac{100}{140} = 0.7143\% \text{ (factor)}$$

$$\text{Número de hijos} \quad 6 = x = \frac{100}{160} = 62.50\% \text{ (factor)}$$

Número de hijos $7 = x = \frac{100}{180} = 55.55\%$ (factor)

Número de hijos $8 = x = \frac{100}{200} = 50\%$ (factor)

Ejemplo 5. Concurren hijos solos, huérfanos de padre y madre

Base por incapacidad permanente total \$2 100.00 mes monto máximo

3 hijos solos:

Hijo 1	30%	\$ 630.00
Hijo 2	30%	\$ 630.00
Hijo 3	30%	\$ 630.00
	90%	\$ 1 890.00

4 hijos solos:

Hijo 1	25%	\$ 525.00
Hijo 2	25%	\$ 525.00
Hijo 3	25%	\$ 525.00
Hijo 4	25%	\$ 525.00
	100%	\$ 2 100.00

5 hijos solos:

Hijo 1	20%	\$ 420.00
Hijo 2	20%	\$ 420.00
Hijo 3	20%	\$ 420.00
Hijo 4	20%	\$ 420.00
Hijo 5	20%	\$ 420.00
	100%	\$ 2 100.00

Cuando los hijos lleguen a la edad límite, fallezcan o se restablezca el inhabilitado, se hará una nueva distribución de porcentajes, sin ser mayores de las cuotas parciales ni del monto total de las pensiones, conforme al segundo párrafo del art. 66, en el momento en que se extingue el derecho del descendiente, se le otorga, en un solo pago, la cantidad equivalente a tres mensualidades de su pensión como *finiquito*, con base en el penúltimo párrafo del art. 64.

Los huérfanos recibirán un aguinaldo anual, equivalente a 15 días del importe de la pensión, en el mes de diciembre, conforme al último párrafo del art. 64.

Incremento de las pensiones

El art. 68 de la LSS establece las bases para la actualización anual de las pensiones por incapacidad permanente total en el mes de febrero, "conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al año calendario anterior".

En el art. 69 se consigna la revisión e incremento de las pensiones de viudez, orfandad y ascendientes, en la proporción que corresponda, con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor. La Ley anterior tomaba como base los incrementos al salario mínimo general del Distrito Federal y en la proporción resultante se incrementaban las pensiones, en cada ocasión en que variara el salario mínimo.

Incompatibilidad

La incapacidad permanente parcial supone una disminución en la aptitud para trabajar e incluso de desempeñar su misma actividad. La LFT (arts. 498 y 499) dispone que si no puede cumplir con la que le correspondía, el patrón resulta obligado a otorgarle otra que se adapte a su nueva condición, previo acuerdo con el sindicato.

¿Qué sucede en estos casos con el pago de la pensión?

Uno de los aspectos de mayor relevancia que desaparece de la Ley, a pesar de existir desde el ordenamiento de 1943, es el relativo a la compatibilidad de pensiones que se encontraba en los arts. 174 y 175 de la Ley de 1973, en cuyo primer precepto se disponía:

Artículo 174. Las pensiones a que se refiere este capítulo son compatibles con el desempeño de trabajos remunerados y con el disfrute de otras pensiones, según las siguientes reglas:

I. Las de invalidez, vejez y cesantía en edad avanzada, con:

{...}

b) El disfrute de una pensión por incapacidad permanente derivada de un riesgo de trabajo, con las limitaciones establecidas en el artículo 125 de esta Ley;

II. La de viudez con:

{...}

b) El disfrute de una pensión por incapacidad permanente;

III. La de ascendientes con:

a) El disfrute de una pensión de incapacidad permanente;

Estas disposiciones hacían compatible la pensión por incapacidad permanente con un trabajo remunerado y con el otorgamiento de otras pensiones, sin condicionarlo o limitarlo en cuanto al ingreso que recibiera.

La Ley de 1997 establece en el art. 62:

Artículo 62. Si el asegurado que sufrió un riesgo de trabajo fue dado de alta y posteriormente sufre una recaída con motivo del mismo accidente o enfermedad de trabajo, tendrá derecho a gozar del subsidio a que se refiere la fracción I del artículo 58 de esta Ley, en tanto esté vigente su condición de asegurado.

Cuando el asegurado al que se le haya declarado una incapacidad permanente total o parcial que le dé derecho a la contratación de la renta vitalicia y del seguro de sobrevivencia en los términos previstos en los artículos 58 fracciones II y III, 61 y 159 fracciones IV y VI de esta Ley, se rehabilite y tenga un trabajo remunerado que le proporcione un ingreso cuando menos equivalente al cincuenta por ciento de la remuneración habitual que hubiere percibido de continuar trabajando, dejará de tener derecho al pago de la pensión por parte de la aseguradora. En este caso, la aseguradora deberá devolver al Instituto y a la administradora de fondos para el retiro el fondo de reservas de las obligaciones futuras, pendientes de cubrir. La proporción que corresponderá al Instituto y a la administradora de fondos para el retiro del fondo de reserva devuelto por la aseguradora, será equivalente a la proporción que representó la suma asegurada y el saldo de la cuenta individual del trabajador en la constitución del monto constitutivo. La administradora de fondos para el retiro abrirá nuevamente la cuenta individual al trabajador con los recursos que le fueron devueltos por la aseguradora.

La situación del trabajador-asegurado-pensionado que sufra la mutilación de un pie sería la siguiente:

Con un salario base de cotización, de \$200.00 diarios	—————>	Salario mensual de \$6000.00
Tendría una valoración de 40% y su	—————>	Pensión mensual de \$1680.00
Lo que implica una disminución de sus ingresos al pensionarse por	—————>	\$4320.00

- Conforme a la Ley de 1973, el pensionado podía tener un trabajo remunerado sin que se afectara el monto de la pensión, independientemente del salario nuevo que percibiera.
- Con la Ley actual se limita el derecho a seguir percibiendo la pensión, si el nuevo salario es "cuando menos equivalente al cincuenta por ciento de la remuneración... que hubiere percibido de continuar trabajando, dejará de tener derecho al pago de la pensión".

Además, estaría generando nuevo derecho que podría incrementar o disminuir el importe de la pensión generada por riesgo de trabajo, sin que se tome en cuenta la incapacidad permanente.

En cambio, en el art. 116, del seguro de invalidez y vida (art. 125 de la Ley de 1973) se dispone:

Artículo 116. Si una persona tiene derecho a cualquiera de las pensiones de este capítulo y también a pensión proveniente del seguro de riesgos de trabajo, percibirá ambas sin que la suma de sus cuantías exceda del cien por ciento del salario mayor, de los que sirvieron de base para determinar la cuantía de las pensiones concedidas. Los ajustes para no exceder del límite señalado no afectarán la pensión proveniente de riesgos de trabajo.

Ayuda para gastos de defunción

Cuando el riesgo de trabajo traiga como consecuencia la muerte del trabajador, el IMSS efectuará pago, en una sola exhibición, a los beneficiarios de una cantidad equivalente a 60 días de salario mínimo que rija en el Distrito Federal. Esta ayuda se entregará de preferencia a un familiar del trabajador asegurado fallecido con la presentación del acta de defunción y el documento original de la cuenta de gastos del sepelio, a menos que otra persona los presente:

Artículo 64. Si el riesgo de trabajo trae como consecuencia la muerte del asegurado [...]

Las pensiones y prestaciones a que se refiere la presente Ley serán:

1. El pago de una cantidad igual a sesenta días del salario mínimo general que rija en el Distrito Federal en la fecha de fallecimiento del asegurado.

Este pago se hará a la persona preferentemente familiar del asegurado, que presente copia del acta de defunción y la cuenta original de los gastos de funeral.

Aviso del patrón

El art. 51 de la LSS determina que el patrón deberá dar aviso al Instituto del accidente o la enfermedad de trabajo, en los términos que señale el reglamento respectivo. El patrón que “oculte la realización de un accidente sufrido por alguno de sus trabajadores o lo reporte indebidamente como accidente en trayecto, se hará acreedor a las sanciones que determine esta Ley y el reglamento respectivo” (art. 52). La “sanción” se limita al cobro de prestaciones como capitales constitutivos y multa administrativa. El segundo párrafo del art. 51 limita la presentación del comunicado al patrón, a los beneficiarios o representantes.

Accidente imputable al patrón

La LSS contiene los supuestos de que el accidente ocurriera por motivación del patrón:

1. *Como consecuencia de un acto intencional del patrón*, producido por él, o por medio de tercera persona (art. 48). En este caso, el Instituto otorgará al asegurado las prestaciones en dinero y en especie conforme a la Ley y el patrón le restituirá su importe. Es necesario tomar en cuenta:
 - a) Que el Instituto acredite la intención, la conducta dolosa, caracterizada por querer el daño y, en consecuencia, que haya llevado a cabo los actos necesarios a este objeto.
 - b) Que el Instituto no cuenta, por lo general, con elementos para acreditar una situación tan subjetiva como la intencionalidad.
2. *Por falta inexcusable del patrón*, para lo que se requerirá que (art. 49) se atienda el supuesto contenido en el art. 490 de la LFT, el cual determina la relación entre el riesgo y la falta inexcusable del patrón.

Artículo 490. En los casos de falta inexcusable del patrón, la indemnización podrá aumentarse hasta en un veinticinco por ciento, a juicio de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Hay falta inexcusable del patrón:

- I. Si no cumple las disposiciones legales y reglamentarias para la prevención de los riesgos de trabajo;
- II. Si habiéndose realizado accidentes anteriores, no adopta las medidas adecuadas para evitar su repetición;

- III. Si no adopta las medidas preventivas recomendadas por las comisiones creadas por los trabajadores y los patrones, o por las autoridades del Trabajo;
- IV. Si los trabajadores hacen notar al patrón el peligro que corren y éste no adopta las medidas adecuadas para evitarlo; y
- V. Si concurren circunstancias análogas, de la misma gravedad a las mencionadas en las fracciones anteriores.

Se pide que se califique por la Junta de Conciliación y Arbitraje lo que supone el ejercicio de una acción en los términos del ordenamiento laboral, sin que dicho trámite pueda enmarcarse como procedimiento especial, para-procesal o voluntario.

La Junta de Conciliación y Arbitraje dictará laudo en el que, en su caso, condenará al patrón al pago del incremento y facultará al Instituto para hacerlo efectivo.

Si el asegurado demanda del patrón el incremento, en los términos del art. 49 de la LSS, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje podría:

- a) Condenar al patrón con fundamento en el art. 490 de la LFT y ordenar el incremento correspondiente en la indemnización.
- b) Condenar al patrón al pago de un incremento no calculado por el trabajador, para que se aumenten las prestaciones a que se refiere el art. 49, subsidio y pensión.

Inconformidad del asegurado

En el supuesto de que el asegurado no esté conforme con la resolución definitiva que califique el riesgo, deberá interponer el recurso de inconformidad ante el Consejo Técnico del Instituto, como lo ordena el art. 44, lo que contraviene lo dispuesto en el art. 295, que le faculta a acudir a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje sin necesidad de agotar el recurso de inconformidad, por lo que este último debe prevalecer. El derecho se extiende a los beneficiarios del asegurado, sobre todo cuando el asegurado se encuentre incapacitado o hubiere fallecido.

Durante la tramitación del recurso, el Instituto proporcionará al asegurado o a sus beneficiarios las prestaciones que la Ley determina, como riesgo ajeno al trabajo, sin demérito de proporcionar las diferencias de forma retroactiva, conforme determine la resolución del recurso interpuesto.

La Ley de 1973, en el art. 51 confería la facultad a que se refiere el art. 295.

Ley de 1973

Artículo 51. Cuando el trabajador asegurado no esté conforme con la calificación que del accidente o enfermedad haga el Instituto de manera definitiva, podrá ocurrir ante el Consejo Técnico del propio Instituto o ante la autoridad laboral competente, para impugnar la resolución.

En el supuesto a que se refiere el párrafo anterior, entre tanto se tramita el recurso o el juicio respectivo, el Instituto le otorgará al trabajador asegurado o a sus beneficiarios legales las prestaciones a que tuviere derecho en los ramos del seguro de enfermedades y maternidad o de invalidez, cesantía en edad avanzada y muerte, siempre y cuando se satisfagan los requisitos señalados por esta ley.

Ley actual

Artículo 44. Cuando el trabajador asegurado no esté conforme con la calificación que del accidente o enfermedad haga el Instituto de manera definitiva, podrá interponer el recurso de inconformidad. En el supuesto a que se refiere el párrafo anterior, entre tanto se tramita el recurso o el juicio respectivo (*sic*), el Instituto otorgará al trabajador asegurado o a sus beneficiarios legales las prestaciones a que tuvieran derecho en los seguros de enfermedades y maternidad o invalidez y vida, siempre y cuando se satisfagan los requisitos señalados por esta Ley. En cuanto a los demás seguros se estará a lo que se resuelva en la inconformidad o en los medios de defensa establecidos en el artículo 294 de esta Ley.

Régimen financiero en el seguro de riesgos de trabajo

El conflicto entre la fracc. XIV del art. 123 A constitucional y la *Ley Federal del Trabajo* (LFT) y el seguro de riesgos de trabajo, como se ha visto, se patentiza en la forma y los plazos de pago de la cuota patronal. Debemos tomar en cuenta que la *Ley del Seguro Social* (LSS) dispone que las prestaciones de cada seguro serán cubiertas íntegramente por las cuotas que aporten los patrones,

los trabajadores y el Gobierno Federal, lo que impide que puedan tomarse recursos de un seguro para transferirlos a otro, como lamentablemente aconteció y lo reconoce el dictamen de 1995.

En el seguro de riesgos de trabajo, las prestaciones —servicios médicos, pensiones, indemnizaciones y pensiones de viudez, orfandad y ascendientes— serán cubiertos íntegramente por las cuotas que aporten los patrones y demás sujetos obligados; esto incluye los capitales constitutivos de las rentas líquidas al fin de año y los gastos administrativos.

Las cuotas de este seguro se fijan conforme al porcentaje que se determina en la propia Ley, en relación con la cuantía del salario base de cotización y los riesgos inherentes a la actividad de la negociación de que se trate. Materia de discusión es si el pago puede tomar en cuenta las disposiciones relativas del *Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización* (art. 71).

El art. 73 de la LSS dispone que la empresa, al inscribirse por primera vez en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o al cambiar de actividad, cubrirá la prima media de la clase que conforme al Reglamento le corresponda, de acuerdo con la tabla siguiente:

Prima media	Porcentaje
Clase I	0.54355
Clase II	1.13065
Clase III	2.59840
Clase IV	4.65325
Clase V	7.58875

Esta tabla también se aplicará cuando el cambio de actividad de la empresa se origine por una sentencia definitiva o por disposición de esta Ley o de un reglamento.

La determinación de las clases comprenderá una lista de los diversos tipos de actividades y ramas industriales, catalogándolas en razón de la mayor o menor peligrosidad a que están expuestos los trabajadores, y asignando a cada uno de los grupos que formen dicha lista una clase determinada. Este supuesto sólo se aplicará a las empresas que se inscriben por primera vez en el Instituto o cambien de actividad (art. 75).

El *Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización* establece una serie de

disposiciones que merecen analizarse con mucho cuidado para señalar los aspectos donde rebase el marco legal y pueda incurrir en responsabilidad al invadir esferas reservadas al Congreso de la Unión.

Este Reglamento contiene un catálogo de actividades de las empresas, establecido conforme a la división económica, el grupo económico, la fracción y la clase que en cada caso les corresponda de acuerdo con su actividad. Las personas físicas o morales que mediante un contrato de prestación de servicios realicen trabajos con elementos propios en otro centro de trabajo, serán clasificadas con base en la actividad más riesgosa que desarrollen sus trabajadores, según lo consignado en el Catálogo de Actividades (art. 19). Cuando la actividad de una empresa no se señala en forma específica en el Catálogo, el patrón o el Instituto determinarán la clasificación considerando la analogía o similitud en la actividad, los procesos de trabajo y los riesgos de dicha actividad con los que se establecen en el Catálogo. Es una temeridad que en un ordenamiento fiscal se mencione la analogía o el parecido.

Cuando las empresas no cumplan con la autoclasificación, el Instituto de oficio las clasificará con fundamento en el Catálogo de Actividades, con base en la información que aquéllas proporcionen o la que se obtenga como resultado de la visita que realice para determinar la actividad a la que se dedican (art. 23). En estos casos la prueba queda a cargo del Instituto, lo que da acción al patrón para inconformarse o demandar por la vía fiscal el cobro excesivo.

El art. 26 del Reglamento establece una serie de medidas para la empresa que se registra por primera vez en el Instituto y aquella que cambie de actividad. Conforme al Catálogo de Actividades, se atenderá a lo siguiente:

- I. Si se trata de una empresa que realice varias actividades o que tenga diversos centros de trabajo en el territorio o jurisdicción de un mismo municipio o en el Distrito Federal, se le fijará una sola clasificación y no podrán disociarse sus diversas actividades o grupos componentes para asignar clasificación y prima diferentes a cada una, y
- II. Cuando una empresa tenga varios centros de trabajo con actividades similares o diferentes en diversos municipios o en el Distrito Federal, sus actividades o grupos componentes se considerarán como una sola unidad de riesgo en cada municipio o en el Distrito Federal y deberá asignarse una sola clasificación.

Por otra parte, el art. 27 parte del supuesto de que el patrón solicite al Instituto la asignación de un registro patronal único que sustituya los registros patronales con los que venía operando. En este caso se estará a lo siguiente:

- I. Si todos los registros patronales que se sustituyen están ubicados en la misma fracción y clase, la empresa será clasificada en dicha fracción y clase. La prima a cubrir será la que resulte de aplicar el procedimiento siguiente:

- a) Por cada registro patronal a sustituir, se multiplicará la prima asignada por el total de los salarios base de cotización de los trabajadores comprendidos en el mismo.
- b) Se sumarán los productos obtenidos conforme al inciso anterior y el resultado se dividirá entre la suma de los salarios base de cotización del total de los trabajadores comprendidos en todos los registros patronales a sustituir.
- c) La prima así obtenida se aplicará al registro patronal único y estará vigente hasta que entre en vigor la prima derivada de la revisión anual de siniestralidad a que se refiere el art. 32 de este Reglamento.

II. Si los registros patronales que se sustituyen tienen diferente fracción y clase, la empresa será clasificada en el grupo económico, la fracción y la clase de acuerdo con la actividad a la que se dedique, en términos del Catálogo de Actividades establecido en este Reglamento. Para efectos de la determinación de la prima a cubrir, se procederá conforme a la fracción anterior.

Monto de la prima

La remisión al Reglamento se hace menos viable si las empresas parten de la media señalada en la tabla transcrita. El art. 72 de la LSS ordena la forma en que deberán calcular sus primas, multiplicando la siniestralidad de la empresa por un factor de prima, y al producto se le sumará 0.005. La fórmula ha sido discutida por actuarios que determinan que no es correcta y atenta contra la economía de las empresas; por tanto, es discutible el resultado que podría ser la prima a aplicar sobre los salarios de cotización. Esta fórmula es de difícil comprensión para las empresas y dificulta su cumplimiento, pues está sujeta a interpretaciones:

$$\text{Prima} = [(S/365) + V * (I + D)] * (F/N) + M$$

donde:

- V = 28 años, duración promedio de vida activa de un individuo que no haya sido víctima de un accidente mortal o de incapacidad permanente total
- F = 2.3, factor de prima
- N = Número de trabajadores promedio expuestos al riesgo
- S = Total de días subsidiados a causa de incapacidad temporal
- I = Suma de los porcentajes de las incapacidades permanentes, parciales y totales, divididos entre 100
- D = Número de defunciones
- M = 0.005, prima mínima de riesgo

Para determinar la siniestralidad de las empresas no se tomarán en cuenta los accidentes que ocurran a los trabajadores al trasladarse de su domicilio al

centro de labores o viceversa, pero una defunción eleva peligrosamente la cuota y atenta contra la economía de la empresa al aplicarse al pago por cada trabajador.

El Reglamento establece (art. 35) que la siniestralidad de la empresa se obtiene al multiplicar el índice de frecuencia (If) por el de gravedad (Ig) del lapso que se analice, de acuerdo con la fórmula siguiente:

$$\text{Siniestralidad} = \text{If} * \text{Ig}$$

de la que se obtiene:

$$\text{Siniestralidad} = n / (N * 300) * 300 * [(S / 365) + V * (I + D)] / n$$

y, en forma simplificada:

$$\text{Siniestralidad} = [(S/365) + V * (I + D)] / N$$

Debido a que el grado de siniestralidad se conforma con base en la frecuencia y gravedad de los accidentes y las enfermedades de trabajo, así como con un factor de prima que garantiza el equilibrio financiero del ramo, se expresa de la manera siguiente:

$$\text{Grado de siniestralidad} = [(S/365) + V * (I + D)] * (F / N)$$

donde:

F = 2.3, factor de prima

El significado de las demás variables, constantes y símbolos se señala en los arts. 36 y 37 de este Reglamento.

Una vez obtenido el grado de siniestralidad, se sumará 0.005, que es la prima mínima de riesgo (M), para determinar la prima a cubrir por el seguro de riesgos de trabajo a que se refiere el art. 72 de la LSS.

El *índice de frecuencia* (art. 36) es la probabilidad de que ocurra un siniestro en un día laborable y se obtiene al dividir el número de casos de riesgos de trabajo terminados en el lapso que se analice, entre el número de días de exposición al riesgo, conforme a la fórmula siguiente:

$$\text{If} = n / (N * 300)$$

donde:

n = Número de casos de riesgos de trabajo terminados

/ = Símbolo de división

N = Número de trabajadores promedio expuestos a los riesgos

* = Símbolo de multiplicación

300 = Número estimado de días laborables por año

No se considerarán como casos de riesgos de trabajo terminados las recaídas y las revisiones de incapacidades permanentes parciales.

El número de trabajadores promedio expuestos al riesgo se obtiene al sumar los días cotizados por todos los trabajadores de la empresa, durante el año de cómputo, y dividir el resultado entre 365.

El número de días de exposición al riesgo se obtiene al multiplicar el número de trabajadores promedio expuestos a los riesgos, por el número estimado de días laborables por año.

El *índice de gravedad* (art. 37) es el tiempo perdido en promedio por riesgos de trabajo que produzcan incapacidades temporales, permanentes parciales o totales y defunciones. Este índice se obtiene al dividir los días perdidos para el trabajo debido a incapacidades temporales, permanentes parciales o totales y defunciones, entre el número de casos de riesgos de trabajo terminados en el lapso que se analice, conforme a la fórmula siguiente:

$$Ig = 300 * [(S / 365) + V * (I + D)] / n$$

donde:

- 300 = Número estimado de días laborables por año
- * = Símbolo de multiplicación
- S = Total de días subsidiados a causa de incapacidad temporal
- / = Símbolo de división
- 365 = Número de días naturales del año
- V = 28 años, duración promedio de vida activa de un individuo que no haya sido víctima de un accidente mortal o de incapacidad permanente total
- I = Suma de los porcentajes de las incapacidades permanentes, parciales y totales, divididos entre 100
- D = Número de defunciones
- n = Número de casos de riesgos de trabajo terminados

Para obtener los días perdidos para el trabajo, se tomarán en cuenta las consecuencias de los riesgos de trabajo terminados, las de los casos de recaída y los aumentos derivados de las revisiones a las incapacidades permanentes parciales, registrados en el lapso que se analice, aun cuando provengan de riesgos ocurridos en periodos anteriores.

El tiempo perdido se mide de la manera siguiente: si el riesgo de trabajo produce incapacidad temporal, se considerarán los días subsidiados; en caso de accidente mortal o de incapacidad permanente total, se tomará en cuenta la duración promedio de vida activa de un individuo de la misma edad que no

haya sido víctima de un accidente semejante, y en caso de los asegurados con incapacidad permanente parcial, se considerará el porcentaje correspondiente de acuerdo con la tabla de valuación de incapacidades contenida en la LFT.

Los días subsidiados por incapacidad temporal motivados por una recaída y los porcentajes derivados de las revisiones de incapacidades permanentes parciales deberán considerarse para efectos de la siniestralidad por la empresa en donde se originó el riesgo de trabajo, cualquiera que sea el lugar y el tiempo en que se dé.

No es un estímulo que el precepto considere que los patrones cuyos centros de trabajo cuenten con un sistema de administración y seguridad en el trabajo acreditado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, aplicarán un factor de prima (F) de 2.2.

Fuera de estas condiciones se encuentran las empresas con menos de 10 trabajadores, las cuales tienen la opción de presentar la declaración anual correspondiente o cubrir la prima media que les corresponda conforme al Reglamento.

El Consejo Técnico del Instituto tiene la facultad, cada tres años, de promover ante el Ejecutivo Federal y éste ante el H. Congreso de la Unión la revisión de la fórmula para el cálculo de la prima, a fin de asegurar que se mantenga o restituya, en su caso, el equilibrio financiero de este seguro, tomando en cuenta a todas las empresas del país. Para tal efecto se considerará la opinión que al respecto sustente el Comité Consultivo del Seguro de Riesgos de Trabajo, el cual estará integrado de manera tripartita. La Asamblea General puede autorizar al Consejo Técnico para promover en cualquier tiempo la revisión mencionada, con base en la experiencia adquirida (art. 76).

El Catálogo de Actividades del Reglamento (art. 196) incluye 99 grupos de éstas, varias de las cuales se ejemplifican en la tabla siguiente. Conforme a la clase de riesgo se pagarán las primas en los términos señalados en la Ley y el Reglamento.

Grupo	Fracción	Actividad	Clase de riesgo
02	021	Cría y explotación de ganado y otras clases de animales.	III
03	031	Explotación de bosques madereros; extracción de productos forestales no maderables y servicios de explotación forestal.	V

Grupo	Fracción	Actividad	Clase de riesgo
11	111	Extracción y beneficio de carbón mineral, grafito y minerales no metálicos en minas de profundidad.	V
12	121	Exploración y extracción de petróleo crudo y gas natural.	IV
20	2014	Elaboración, preparación, envasado y/o empaçado de productos alimenticios, sin maquinaria ni equipo motorizado.	II
24	241	Confección de prendas de vestir a la medida.	I

Revisión anual

En febrero de cada año, las empresas tienen la obligación de presentar al IMSS la revisión anual de su índice de siniestralidad, para determinar si permanecen en la misma prima, ésta disminuye o aumenta; la siniestralidad se fijará en los términos del Reglamento. La prima podrá ser modificada, aumentándola o disminuyéndola en una proporción no mayor a 1% con respecto a la del año inmediato anterior, tomando en consideración los riesgos de trabajo terminados durante el lapso que fije el Reglamento respectivo, con independencia de la fecha en que éstos hubieran ocurrido y la comprobación documental del establecimiento de programas o acciones preventivas de accidentes y enfermedades de trabajo. Estas modificaciones no podrán exceder los límites fijados para las primas mínima y máxima, que serán de 0.5% y 15% de los salarios base de cotización, respectivamente.

Para esta revisión se deberán aplicar las fórmulas del Reglamento transcritas. En las revisiones fiscales, el Instituto requiere la presentación de estas actualizaciones anuales, hasta por los últimos cinco años.

Soy partidario de una revisión completa, a fin de que con bases actuariales se determine una cuota accesible, como sucede en los otros cuatro seguros analizados en este libro. Por otra parte, es conveniente la adopción de estímulos que prevean accidentes y enfermedades, con el propósito de disminuir no sólo el grado sino incluso la clase de riesgo de cada empresa.

9 Enfermedad y maternidad

Los servicios médicos en cualquier sistema de seguro, público o privado, captan la mayor parte de los recursos; los planes privados de seguro incrementan sus primas anualmente, así como los pagos deducibles; limitan la edad, de tal manera que una persona con más de 65 años está impedida para adquirirlo. El Gobierno ha apoyado los seguros médicos privados al otorgarlos de manera gratuita a los funcionarios de niveles medio y superior, con lo que eroga grandes cantidades que podía destinar a mejorar los servicios institucionales.

Las aseguradoras y los servicios médicos particulares tienen garantizada su espléndida condición, con los servicios médicos subrogados, el descrédito del servicio público y la desconfianza creciente de quienes tienen posibilidad de acudir a clínicas y sanatorios privados. Una situación similar afronta el servicio de guarderías.

En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) languidece el seguro de enfermedad y maternidad, en su intento por brindar servicios médicos a toda la población, derechohabiente y solidariohabiente, es decir, unos 47 millones de personas. Los servicios médicos atienden cada día a 700 mil personas, de acuerdo con datos de la exposición de motivos de la Iniciativa de 1995, y dos de cada tres niños mexicanos nacen en estos servicios. Lo anterior provoca que las clínicas, los hospitales, los centros médicos y las recientes unidades médicas de alta especialización estén saturadas, sin el personal suficiente para atender los requerimientos, muchas veces urgentes. De hecho, es común entre los trabajadores hablar de los tres niveles de atención: en el suelo, en las camillas y en las camas.

Es urgente el cambio de políticas que reorienten con sentido social y humano los servicios, que en los últimos años se han basado en criterios financieros, considerándolos un gasto y no una inversión social. La prestación en dinero —subsidio— se otorga sólo a los trabajadores asegurados. Conviene recordar a José Gaos, quien escribió:

El ser humano no sólo es consciente de la finitud de su tiempo, de su vida, sino de la constante inminente de su fin; no sólo está seguro de que tiene que morir, sino que está persuadido de que la muerte puede sobrevenir, sobrecogerlo en todo momento, en el inmediato, y si constantemente le amenaza la muerte, lo que tiene que hacer no sólo tiene que hacerlo en vida, sino que tiene que hacerlo con urgencia.

La *Ley del Seguro Social* (LSS) de 1943 protegía ante todo a los trabajadores y a sus familiares; a los primeros con todas las prestaciones en los diferentes ramos del seguro. La situación financiera del Instituto, que se cuidó en los primeros 30 años de vigencia, permitió que ocasionalmente, cuando lo justificaban condiciones sociopolíticas, de acuerdo con los criterios del Presidente de la República y sin lesionar las finanzas del organismo administrador, se atendiera a grupos reducidos como los henequeneros, candelilleros y algunos no asalariados. La Ley de 1973 amplió el ámbito de protección para incluir a sujetos ajenos a una relación laboral, precisados en los arts. 12 y 13. Estimuló un crecimiento horizontal que llevó, en forma paralela, al otorgamiento de prestaciones, lo que implicó la necesidad de su financiamiento con el seguro de pensiones —invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte (IVCM)—, así como de guarderías. No debe olvidarse que con posterioridad a la expedición de la Ley de 1973, se reformó la fracc. XXIX del Apartado A del art. 123 constitucional, por decreto del 27 de diciembre de 1974 publicado en el *Diario Oficial de la Federación* (DOF) el 31 de ese mes, para incluir a los campesinos, grupos de no asalariados y otros sectores sociales.

Los cálculos actuariales determinan costos, posibilidades de crecimiento, determinación de nuevos grupos y cálculo de cuotas. Sin embargo, los sujetos comprendidos en las fraccs. II y III del art. 12, miembros de sociedades cooperativas y las personas que determine el Ejecutivo Federal a través de decretos, aunados a los trabajadores en el régimen voluntario: no asalariados, campesinos, trabajadores domésticos, patrones, personas físicas y estudiantes universitarios estipulados en el art. 13, han sumado millones de personas, lo que hace imposible estimar actuarialmente costos y prestaciones. Las cuotas eran reducidas y subsidiadas o poco atractivas por su elevado cálculo. Ante este panorama hay que recordar las continuas desviaciones de recursos, así como la forma inadecuada de invertirlos.

Los arts. 263 y 264 de la LSS expresamente prohibieron disponer de los fondos de pensiones para otros fines:

Artículo 263. Los ingresos y egresos de cada uno de los ramos a que se refiere el artículo 11 de esta ley, se registrarán contablemente por separado de los correspondientes a los demás ramos, en las cifras consolidadas.

Los recursos sólo podrán utilizarse para cubrir las prestaciones y reservas que correspondan a cada uno de los respectivos ramos.

En todos los casos, la diferencia del importe de las cuotas del seguro de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte y demás ingresos de dicho ramo, por un lado, y el pago de las prestaciones y demás egresos del mismo, por el otro, se aplicará a incrementar la reserva respectiva en términos de este capítulo.

Artículo 264. Las reservas del seguro de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, deberán invertirse en activos financieros y el producto que se obtenga de su inversión se destinará exclusivamente para cubrir las prestaciones del mencionado ramo del seguro.

La Ley de 1997 mantiene las garantías de calidad a favor del trabajador asegurado:

Artículo 216. El Instituto proporcionará el apoyo necesario a los servicios de solidaridad social que esta Ley le atribuye, sin perjuicio del eficaz otorgamiento de las prestaciones a que tienen derecho los trabajadores y demás beneficiarios del régimen obligatorio.

Artículo 226. No procederá el aseguramiento voluntario, cuando de manera previsible éste pueda comprometer el equilibrio financiero del Instituto o la eficacia de los servicios que proporcione a los asegurados en el régimen obligatorio.

El art. 277 E contiene el supuesto de los arts. 263 y 264 de la Ley anterior:

Sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, los ingresos y gastos de cada seguro se registrarán contablemente por separado. Los gastos indirectos comunes se sujetarán a las reglas de carácter general para la distribución de costos, al catálogo de cuentas y al manual de contabilización y del ejercicio del gasto que al efecto emita el Consejo Técnico a propuesta del Director General, quien deberá contar con la opinión previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

[...]

Los recursos de cada ramo de seguro a que se refiere esta Ley sólo podrán utilizarse para cubrir las prestaciones y pago de beneficios y constitución reservas que correspondan a cada uno de ellos.

Conceptos

El seguro de enfermedad y maternidad no hace distinción —de acuerdo con los arts. 84 a 111—, entre enfermedad y accidente, como sucede en el Seguro de Riesgos de Trabajo, donde la enfermedad “es todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo...” (art. 43) y el accidente de trabajo “es toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o posterior; o la muerte, producida repentinamente en ejercicio, o con motivo del trabajo...” (art. 42). Los cuestionamientos y las dudas que se producen por una interpretación estricta (art. 9) son variados, ya que dejarían fuera los accidentes ajenos al riesgo de trabajo; si bien en la práctica no acontece, es necesaria dicha interpretación dado el carácter fiscal de las normas para que se lleve a cabo la revisión.

Por otra parte, las prestaciones que otorga son de naturaleza médica diversa en la enfermedad y la maternidad, tanto en condiciones y prestaciones como en requisitos.

La invalidez (art. 119), que deriva de una enfermedad o accidente no profesionales, sí se refiere expresamente al accidente y la enfermedad:

Para los efectos de esta ley existe invalidez cuando el asegurado se halle inhabilitado para procurarse, mediante un trabajo igual, una remuneración superior al cincuenta por ciento de su remuneración habitual percibida durante el último año de trabajo y que esa imposibilidad derive de una enfermedad o accidente no profesionales.

La declaración de invalidez deberá ser realizada por el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Sujetos

Por la naturaleza de los servicios, las prestaciones que se otorgan en esta rama comprenden a toda la población protegida de alguna forma, incluso los solidariorhabientes, con algunas condiciones particulares en los casos especiales.

<i>Sujetos</i>	<i>Tipo de seguro</i>	<i>Tipos de asegurados</i>
Asegurados	Seguro obligatorio	Trabajadores Miembros de cooperativas Personas determinadas por decreto presidencial
	Seguro voluntario	No asalariados Campesinos Trabajadores domésticos Patrones personas físicas Trabajadores de administraciones públicas federales
Pensionados	Todos los seguros	En las diversas ramas
Familiares	Seguro para la familia	Que no tengan calidad de beneficiarios
Voluntarios	Seguro voluntario	Sujetos ajenos a los beneficiarios
Solidario- habientes	Seguro solidaridad	Grupos económicamente marginados

De acuerdo con el art. 84 de la LSS, el seguro protege al asegurado, al pensionado por incapacidad permanente total o parcial, a la esposa o concubina del asegurado o del pensionado, al esposo o concubino de la asegurada, a los hijos del asegurado o del pensionado, menores de 16 años, o menores de 25 años si están estudiando o los incapacitados, además del padre y la madre del asegurado y del pensionado que vivan en el hogar de éste.

Tanto el asegurado como el pensionado gozarán de las prestaciones sin limitación. Para los beneficiarios se establecen algunas condiciones:

- Los cónyuges tienen derecho a las prestaciones médicas; a su falta, los concubinos (individualmente) que lo son quienes hayan hecho vida marital o procreado hijos.

- Los hijos menores de 16 años; los mayores de esa edad y menores de 25 años, si estudian en alguna escuela del sistema educativo nacional, y los mayores de esa edad, cuando estén imposibilitados para trabajar.
- Los padres del asegurado y el pensionado que vivan en el domicilio de éste. Bastaría que el contrato de arrendamiento estuviera a nombre del padre o de la madre para no reunir el requisito, sin importar la situación económica.

Conforme a la parte final del precepto, los beneficiarios deberán depender económicamente del asegurado o pensionado. Esta disposición debe precisar, como sucede en otros países, la dependencia, que podría ser total o parcial.

Prestaciones médicas

Las prestaciones son en especie (médicas) y en dinero. Las *médicas* se refieren a asistencia médica, quirúrgica, hospitalaria y farmacéutica.

La atención se otorgará durante 52 semanas (art. 91) y podrá prolongarse por un periodo similar (art. 92). La fecha de iniciación de la enfermedad será aquella en que el Instituto certifique el padecimiento (art. 85). La atención farmacéutica (art. 90) atenderá los cuadros básicos de medicamentos, elaborados por el Instituto. Si el asegurado se niega a hospitalizarse o no sigue el tratamiento médico, se suspenderá el pago del subsidio (art. 99). El asegurado que haya acumulado un mínimo de ocho cotizaciones semanales ininterrumpidas (art. 118) y sea dado de baja, tendrá a su favor una conservación de derechos para recibir prestaciones médicas, por un término igual de ocho semanas. El mismo derecho tendrán sus beneficiarios.

En caso de huelga, los asegurados y sus beneficiarios mantendrán el derecho a las prestaciones médicas durante el tiempo que dure la paralización de actividades en la empresa (art. 109).

El asegurado, el pensionado y sus beneficiarios deberán atender las prescripciones y el tratamiento indicados (art. 86). El Instituto podrá determinar la hospitalización cuando lo exija el padecimiento, con la autorización correspondiente (art. 87).

Forma de prestar los servicios médicos

El Instituto podrá prestar sus servicios directa o indirectamente (art. 89). De manera directa lo realiza por medio de su propio personal e instalaciones. Esta es la forma que ha resultado más adecuada y que permite la atención de las 700 mil consultas diarias en todo el país. Para ello se han construido centros médicos, hospitales, clínicas y unidades móviles.

Las prestaciones médicas se apoyan —o deben apoyarse— en instalaciones adecuadas, modernas, funcionales, que proporcionen al derechohabiente satisfacción y confort. El centro de elaboración de todos los proyectos o realizaciones está en un punto fijo: el propio hombre... La seguridad social se reduciría a simulación intrascendente si no se materializara en servicios y obras eficaces: debe considerarse que quienes necesitan de modo angustioso la protección social no pueden esperar; de ahí que entre los fines que se persiguen y aquello que se crea y edifique precise un paralelismo exacto. Un armónico entendimiento entre quienes trabajan dentro de las unidades médicas y quienes las planean y estructuran conduce a soluciones felices: el diseño arquitectónico entraña una finalidad, y las formas, los volúmenes, los espacios han de ajustarse, de tal suerte que la obra resulte de larga y útil duración y a la vez reduzca sus costos de mantenimiento y operación. En el terreno de las instalaciones y equipo se compaginan el hombre de ciencia y el artista: mientras el primero busca en la técnica el camino del conocimiento y con éste la idea de realización, el segundo satisface las necesidades espirituales creando —en el caso específico que nos ocupa— el ambiente más propicio para el desenvolvimiento de las funciones. Cuando la arquitectura se mezcla al sentido médico, la instalación remata en perfiles de honda repercusión humana.

Las *unidades móviles* atienden a los derechohabientes que, incapacitados para su traslado, ameritan la prestación; imparten vigilancia estrecha en sitios alejados de los centros de población en donde radican pequeñísimos núcleos o grupos nómadas; promueven el criterio práctico de la medicina preventiva; colaboran con eficacia —ya demostrada— en fenómenos naturales que provocan catástrofes: inundaciones, ciclones, incendios de grandes áreas forestales, etcétera.

La *clínica*, distribuida en conveniencia a índices demográficos, se propone atender a una población derechohabiente específica, asignada a su zona de influencia, llegar al diagnóstico de enfermedad, tratar aquellos procesos que resultan ambulatorios o que ameritan reclusión dentro del hogar, impartir un cierto número de especialidades, practicar los análisis de laboratorio y las radiografías indispensables para precisar el diagnóstico requerido, entregar los medicamentos prescritos, proporcionar atención a urgencias en los servicios destinados expresamente para ello, difundir la medicina preventiva en todos sus aspectos.

La *clínica hospital*, más aceptada a medida que la experiencia acredita su bondad, se propone aplicar todos los servicios de una clínica simple; agregar las atenciones quirúrgicas, de acuerdo con su cupo hospitalario; internar a quienes van a ser intervenidos quirúrgicamente o quienes ameritan una estancia corta de hospitalización; proporcionar los cuidados pre y postoperatorios indispensables; añadir determinados servicios inherentes a la atención de internados, por ejemplo, alimentación y ropa de cama; resolver urgencias durante las 24 horas del día; impartir enseñanza, no sólo a su personal, sino también a estudiantes de medicina.

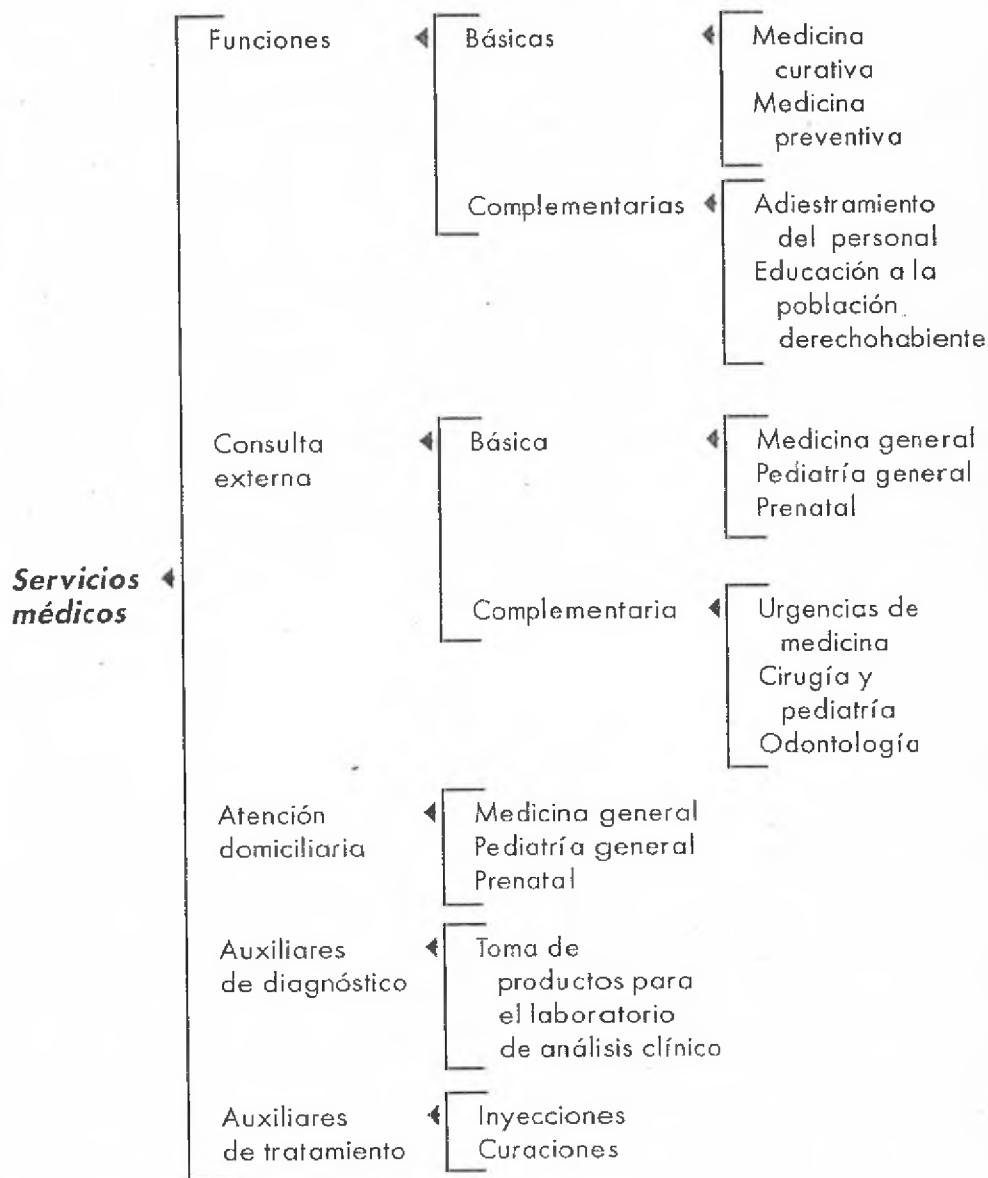
El *hospital*, en función más avanzada de consulta externa e internamiento, recibe a los derechohabientes estudiados previamente por las clínicas o aquellos que ameritan atención de urgencia; atiende al enfermo mediante los mejores elementos técnicos con que cuenta, tratando de lograr una recuperación integral y lo más rápida posible; contribuye a la rehabilitación del paciente; fomenta la medicina preventiva integral; imparte servicios de urgencia durante las 24 horas, sin distinción de personas; precisa los diagnósticos o establece los tratamientos en los casos problema; adiestra al personal médico, técnico y administrativo especializado; centraliza la enseñanza de la medicina mediante programas docentes de validez académica; dirige la carrera hospitalaria progresiva, con internado, subresidencia y residencia de los médicos recién graduados; promueve la investigación científica.

El *centro médico* es el núcleo máximo donde se practica el ejercicio profesional y tiene a su cargo las más delicadas responsabilidades de la institución: realiza la especialización de la medicina; utiliza los adelantos de la ciencia, actualizando procedimientos y mejorando métodos; controla los casos verdaderamente difíciles de diagnóstico; aplica determinados tratamientos que requieren técnicas o equipos especiales; cumple con la investigación en su más alto grado; acrecienta la docencia; encauza al recién egresado de las facultades médicas hacia uno de los campos de la profesión donde se necesiten más sus servicios; programa reuniones científicas, congresos nacionales e internacionales y asambleas; proporciona recursos para la investigación social, con el fin de orientar al derechohabiente.

El *Reglamento Interior del IMSS*, en el art. 2º, fracc. IV, inciso b), menciona a las unidades médicas de alta especialidad (UMAES), sin precisar su creación, y en los arts. 112 a 137 trata las Juntas de Gobierno de dichas unidades con sus atribuciones y representación tripartita. En este reglamento se señala:

El conjunto de unidades médicas existentes en el IMSS amerita una sistematización, un criterio uniforme de acción establecido a través de normas y reglamentos genéricos que tiendan a que la calidad de los servicios se supere. El plan general ha de proveer los medios necesarios para que cada unidad resuelva sus problemas y entre sí todas coordinen sus funciones, de la periferia al centro y viceversa, a través de un programa capaz de determinar las necesidades, las bases de organización y funcionamiento, la calidad y cantidad de las prestaciones médicas. Los procedimientos a practicar han de divulgarse con oportunidad, la planeación ha de ser metódica, la promoción ha de conducir al intercambio de relaciones con organismos nacionales y extranjeros.

Con base en los datos anteriores se presenta gráficamente la estructura genérica de los servicios médicos:



Medicina subrogada

Esta figura se establece en la primera Ley de 1943; la Ley de 1973, en su art. 97, reproduce y amplía la posibilidad de intervención de los organismos médicos particulares. En un inicio se justificó como un complemento para atender situaciones específicas al no contar con las instalaciones necesarias, en vista

de la expansión del seguro social, a efecto de que las prestaciones para atender accidentes y enfermedades pudieran quedar cubiertas. Esta medicina subrogada tendría una presencia efímera, sin desplazar a los servicios institucionales. A pesar de ello, algunos grandes organismos públicos y entidades paraestatales se han opuesto y negado a cumplir las disposiciones de la LSS. Los ferrocarriles, la Comisión Federal de Electricidad, las siderúrgicas y la industria azucarera condicionaron su participación al grado de convenir con el IMSS; Petróleos Mexicanos (Pemex) se ha rehusado a su incorporación, con base en el artículo decimoctavo transitorio de la Ley de 1943, donde se establecía: "La incorporación al régimen obligatorio de los trabajadores de empresas descentralizadas y cuyos contratos colectivos de trabajo consignent prestaciones superiores a las de la presente ley, se efectuará a partir de la fecha de la aprobación del estudio correspondiente."

La situación ha tenido tales repercusiones, que el IMSS tuvo que aceptar los hospitales que habían construido las empresas oficiales para los trabajadores electricistas, ferrocarrileros, los trabajadores de la siderurgia, de los bancos; se han multiplicado contratos con hospitales particulares para la atención de sus trabajadores. Pemex no acata las disposiciones de la LSS y cuenta con instalaciones médicas propias y un sistema de pensiones más adecuado. El ejemplo que brindan las propias entidades de la administración pública trasciende a los particulares.

El art. 89 de la LSS, en su fracc. II, dispone que los servicios médicos del IMSS se pueden proporcionar *indirectamente*. Para ello establece dos formas: mediante convenios que celebre con organismos públicos o particulares (fracc. II), o mediante convenios con quien tenga establecidos servicios médicos y hospitalarios (fracc. III).

La iniciativa presentada por el presidente Ernesto Zedillo proponía modificar el precepto, pero fue rechazada por el Congreso de la Unión, para quedar en los términos del precepto de la Ley de 1973. Esto derivó en opiniones encontradas en cuanto a la participación de servicios médicos particulares. Las aseguradoras incrementaron la venta de seguros médicos mayores; los servidores públicos, en mandos medios y superiores, recibieron un seguro de Aseguradora Hidalgo, organismo oficial; el Instituto obtuvo un crédito indirecto del Banco Mundial, condicionado a alentar la privatización. En este entorno, se presentaron al Congreso de la Unión iniciativas de reforma al art. 89 de la LSS para limitar y suprimir esta participación.

El ser humano tiene derecho a recibir servicios médicos de la mejor calidad, en centros hospitalarios que le garanticen atención adecuada y alivio oportuno. Frente a la amenaza de la muerte se realiza cualquier sacrificio para evitarla. Entonces, por qué la resistencia a la participación de los servicios médicos particulares. La respuesta es evidente: en la medicina del seguro social se tiene en cuenta el principio de solidaridad, que consiste en que cualquier paciente debe recibir el mismo servicio independientemente de

su condición económica. En cambio, en la medicina particular, sólo quienes tienen capacidad de pago pueden acudir a los médicos renombrados y a los hospitales de cinco estrellas. Los seguros, aun con cuotas reducidas o adicionales, atienden los costos, limitan los servicios y buscan clientes atractivos.

La condición de los asegurados es determinante para los servicios médicos particulares; 85% de los más de 10 millones cotizan con base en uno a tres salarios mínimos; menos de 10% cotiza sobre salarios de 10 o más veces el salario mínimo. Las aseguradoras y la medicina privada buscarían a ese millón de asegurados, con lo que se revertirían las cuotas correspondientes.

Los ingresos del IMSS se reducirían y la atención se limitaría a los derechohabientes con menos recursos. Al comprobar la atención que se proporciona en algunos hospitales del IMSS, podría estimarse que esa situación ya está presente; sin embargo, no hay reversión de cuotas. La ausencia real de quienes tienen medianas posibilidades se debe a la baja calidad del servicio, a la promoción negativa y a la actitud de las aseguradoras y de la medicina privada.

Hay que reconocer que los mejores médicos están en el IMSS, así como los esfuerzos que se realizan por mejorar la calidad mediante programas adecuados. La solución no es acabar con las deficiencias, sino realizar el máximo esfuerzo para hacer de ésta una institución cuyo servicio sea cada día más eficiente.

La iniciativa presidencial presentada en 1995 destaca la intención de ampliar el esquema para facilitar la impartición de los servicios por organismos privados:

La Iniciativa establece bases claras para la suscripción de convenios de reversión de cuotas, los cuales están presentes desde la Ley del Seguro Social de 1943. Estos, que han existido desde los orígenes del Instituto, no contaban con la precisión y certidumbre jurídica requerida, fijándose ahora los principios que le garantizan protección total al trabajador. Asimismo, se establece un mecanismo para que con transparencia y sin discrecionalidad, las empresas puedan tener acceso a este tipo de convenios siempre en beneficio de sus trabajadores y sin poner en riesgo el equilibrio financiero del Instituto.

En síntesis, esta propuesta de modificación del ramo de enfermedades y maternidad beneficia a trabajadores y patrones al disminuir las contribuciones promedio, lo que es un fuerte incentivo a la generación de empleos tan indispensable para México como para la seguridad social. Esto se debe a que amplía el financiamiento basado en fondos generales y se desgrava la nómina, lo que permitirá crear más fuentes laborales.

Reitero que el articulado de modificaciones al seguro de enfermedades y maternidad reafirma el compromiso e incrementa la participación del gobierno de la república en la seguridad social, establece un sistema de financiamiento más transparente, permite la ampliación de manera sustancial de la cobertura, acercándonos a la universalidad, y fomenta decididamente la generación de empleos, lo que traerá beneficios sociales indiscutibles.

Las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social adicionaron el art. 89 de la Iniciativa y posteriormente determinaron regresar al texto de la Ley de 1973. En el dictamen presentado en primera lectura el 6 de diciembre de 1995, propone:

Las comisiones que dictaminan, receptivas a las propuestas de distintos sectores sociales para que la reversión de cuotas y la subrogación de servicios médicos quedaran perfectamente aseguradas en beneficio de los derechos de los trabajadores y de la rectoría del Instituto en su otorgamiento, propusieron un nuevo texto para el artículo 89 de la Iniciativa que recoge casi en su totalidad el contenido del artículo 97 de la ley en vigor, sujetando estos convenios a un reglamento que deberá expedir el Consejo Técnico del Instituto y que necesariamente contendrá los principios de integridad de las prestaciones, no discriminación e igualdad para todos los trabajadores de una misma empresa.

Asimismo, se fijan los requisitos para los convenios que permitan al Instituto determinar el monto de la cuota a revertir y, en su caso, dar por terminados dichos convenios atendiendo a la petición de los trabajadores o por sí mismos, cuando el organismo constate que los servicios y prestaciones no se otorgan con la suficiencia, calidad y eficiencia que merecen los trabajadores y que deberá vigilar y exigir el Instituto. Este artículo fue modificado para quedar como sigue:

Artículo 89. El Instituto prestará los servicios que tiene encomendados, en cualquiera de las siguientes formas:

- I. Directamente, a través de su propio personal e instalaciones;
- II. Indirectamente, en virtud de convenios con otros organismos públicos o particulares, para que se encarguen de prestar los servicios del seguro de enfermedades y maternidad y proporcionar las prestaciones en especie y subsidios del seguro de riesgos de trabajo, siempre bajo la vigilancia y responsabilidad del Instituto. Los convenios fijarán el plazo de su vigencia, la amplitud del servicio subrogado, los pagos que deban hacerse, la forma de cubrirlos y las causas y procedimientos de terminación, así como las demás condiciones pertinentes;
- III. Asimismo, podrá celebrar convenios con aquellos patrones que pudieran ofrecer y garantizar servicios médicos y hospitalarios y que cumplan con lo dispuesto en el reglamento para la reversión de cuotas que expida el Consejo Técnico. Estos convenios no podrán celebrarse sin la previa anuencia de los trabajadores o de su representación sindical.

En estos convenios deberán quedar garantizadas para los trabajadores y sus familias todas las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad, para lo cual se deberá establecer en los mismos de manera expresa que se proporcionen servicios médicos en los tres niveles de atención. El reglamento deberá sujetarse a los siguientes principios: integridad de las prestaciones, no discriminación de trabajador alguno e igualdad en prestaciones para todos los trabajadores de una misma empresa. Igualmente se pactará, en su caso, el pago de subsidios mediante un sistema de reembolsos; dichos convenios deberán to-

mar en cuenta el riesgo de la población cubierta, el salario de cotización de la misma y los gastos de administración del Instituto para los efectos de la determinación de los montos de la cuota a revertir.

El Instituto, por sí o a petición de los trabajadores podrá dar por terminados los convenios en el momento en que constate que los servicios y prestaciones no son otorgados con la suficiencia, calidad y eficiencia exigidas por aquél.

En todo caso, las personas, empresas o entidades a que se refiere este artículo, estarán obligadas a proporcionar al Instituto los informes y estadísticas médicas o administrativas que éste les exigiere y a sujetarse a las instrucciones, normas técnicas, inspecciones y vigilancia prescritas por el mismo Instituto, en los términos de los reglamentos que respecto a los servicios médicos se expidan.

El segundo dictamen, presentado en su primera lectura el 7 de diciembre de 1995 fue aprobado por el pleno de la Cámara:

En el curso de las discusiones, como punto de central importancia se debatió sobre la posibilidad de que esta reforma pudiera traer consigo la privatización de alguna de las prestaciones consignadas en la ley vigente, y, en consecuencia, el riesgo del futuro de los asegurados y derechohabientes en el momento de que estos fueran sujetos de recibir una pensión, inquietud que encuentra respuesta al consignarse, como ya lo mencionamos, que el Estado finalmente continuará siendo responsable.

Adicionalmente, el artículo 18 en el segundo párrafo señala que: "El Instituto mismo será el encargado de realizar los trámites administrativos en favor de garantizar los derechos de los asegurados y sus derechohabientes".

Con relación a este tema las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, después de la primera lectura del dictamen de la Ley del Seguro Social han recibido propuestas de diputados de los grupos parlamentarios que integran esta Cámara de Diputados y, en virtud de la trascendencia de la Ley que se discute, han decidido hacerlas suyas, por lo que solicitan se incorporen al decreto que se discute:

1. El trabajo legislativo de las comisiones unidas se desarrolló siempre bajo la perspectiva de la más completa apertura, siendo receptivas en todo momento a las demás demandas de los diversos sectores a los que una iniciativa de esta naturaleza involucra.

Es por ello que ante las inquietudes que han generado las reformas propuestas a los artículos 89 y 213 de la Iniciativa de ley, así como la tergiversación del alcance de éstas y sus fines, la diputación obrera de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional propuso después de diversas consultas y reuniones entre las diputaciones de las distintas fracciones parlamentarias, con los sindicatos de trabajadores del movimiento obrero organizado, así como con otras organizaciones sociales incluidas en el régimen tripartita del seguro social, que estas comisiones unidas retomaran las redacciones de los artículos 97

y 192 de la Ley del Seguro Social que se deroga e incluir estas modificaciones en el decreto respectivo.

Esto se consideró procedente, por lo que las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social las hacen suyas y solicitan se incorporen al decreto que se discute, para quedar en los mismos términos de la ley vigente...

Veamos la trascendencia de lo aprobado por el Congreso:

En todo caso, las personas, empresas o entidades a que se refiere este artículo, estarán obligadas a proporcionar al Instituto los informes y estadísticas médicas o administrativas que éste les exigiere y a sujetarse a las instrucciones, normas técnicas, inspecciones y vigilancia prescritas por el mismo Instituto, en los términos de los reglamentos que respecto a los servicios médicos se expidan.

La iniciativa presentada por el presidente Ernesto Zedillo tuvo modificaciones en el precepto señalado. En la reforma de 2001 presentada por el presidente Vicente Fox se propuso alcanzar un avance en la participación de las empresas privadas, con una nueva reforma al art. 89. El texto finalmente aprobado por el Congreso está vigente:

Artículo 89. El Instituto prestará los servicios que tiene encomendados, en cualquiera de las siguientes formas:

- I. Directamente, a través de su propio personal e instalaciones;
- II. Indirectamente, en virtud de convenios con otros organismos públicos o particulares, para que se encarguen de impartir los servicios del ramo de enfermedades y maternidad y proporcionar las prestaciones en especie y subsidios del ramo de riesgos de trabajo, siempre bajo la vigilancia y responsabilidad del Instituto. Los convenios fijarán el plazo de su vigencia, la amplitud del servicio subrogado, los pagos que deban hacerse, la forma de cubrirlos y las causas y procedimientos de terminación, así como las demás condiciones pertinentes;
- III. Asimismo, podrá celebrar convenios con quienes tuvieren establecidos servicios médicos y hospitalarios, pudiendo convenirse, si se tratare de patrones con obligación al seguro, en la reversión de una parte de la cuota patronal y obrera en proporción a la naturaleza y cuantía de los servicios relativos. En dichos convenios se pactará, en su caso, el pago de subsidios mediante un sistema de reembolso. Estos convenios no podrán celebrarse sin la previa anuencia de los trabajadores o de su organización representativa; y
- IV. Mediante convenios de cooperación y colaboración con instituciones y organismos de salud de los sectores públicos federal, estatal y municipal, en términos que permitan el óptimo aprovechamiento de la capacidad instalada de todas las instituciones y organismos. De igual forma, el instituto podrá dar servicio en sus instalaciones a la población atendida por dichas instituciones y organismos, de acuerdo a su disponibilidad y sin perjuicio de su capacidad financiera.

En todo caso, las personas, empresas o entidades a que se refiere este artículo, estarán obligadas a proporcionar al Instituto los informes y estadísticas médicas o administrativas que éste les exigiere y a sujetarse a las instrucciones, normas técnicas, inspecciones y vigilancia prescritas por el mismo Instituto, en los términos de los reglamentos que respecto a los servicios médicos se expidan.

En relación con la última reforma, los hospitales y sanatorios privados impartirán los servicios médicos y proporcionarán, en su caso, las prestaciones en dinero y los subsidios del ramo de riesgos de trabajo, siempre bajo la vigilancia y responsabilidad del Instituto.

En los términos de la disposición transcrita, en dichos convenios se establecerán los plazos de vigencia, la amplitud del servicio, los pagos que deban hacerse, la forma de cubrirlos, las causas y los procedimientos de terminación, así como las demás condiciones pertinentes.

Convenios con los patrones

La fracc. III del art. 89 faculta al Instituto para celebrar convenios con los patrones a fin de que los servicios médicos sean proporcionados tanto por hospitales y servicios médicos, como por los patrones que cuenten con estos servicios. En este caso se convendrá "la reversión de una parte de la cuota patronal y obrera en proporción a la naturaleza y cuantía de los servicios relativos".

En dichos convenios se pactarán los servicios médicos, la reversión de cuotas, en su caso, y el pago de subsidios mediante el sistema de reembolsos. Se imponen como obligaciones proporcionar al Instituto informes y estadísticas médicas o administrativas y permitir las inspecciones y la vigilancia del mismo, en los términos de los reglamentos.

La condición fundamental consiste en que la Ley no deja al arbitrio del Instituto ni del patrón la determinación de la organización médica particular, ni la naturaleza de los servicios que ha de proporcionar. La estructura de los mismos debe ser consentida por los derechohabientes, de tal forma que conozcan sus términos y condiciones; esta anuencia debe constar por escrito, mediante los acuerdos que al respecto se adopten en cada empresa.

La condición de la *anuencia* es la única garantía que en el caso opera a favor de los trabajadores; debía ser explícita en la Ley, a efecto de no lesionar el derecho de los trabajadores asegurados.

Dos noticias dadas a conocer en 1998, seis meses después de la entrada en vigor del nuevo ordenamiento, incrementan el convencimiento de que los problemas financieros se han reflejado en una deficiente calidad en los servicios, al grado de no contar con los medicamentos, aparatos, instrumentos y la capacidad adecuados para atender a los más de 50 millones de derechohabientes. La insistencia del Banco Mundial para que se adoptara el sistema de cuenta individual y de beneficio indefinido, en sustitución del tradicional

de solidaridad y de reparto, permitió a la banca privada y a las aseguradoras, en manos de instituciones financieras internacionales, captar grandes recursos. En el aspecto médico se permitió, como hemos visto, que hospitales y sanatorios privados otorgaran los servicios. Esto fue de tal magnitud que el *Financial Times* de Londres, Inglaterra, publicó el 23 de octubre de 1997 —conocida en México hasta 1998—, bajo el título "Will social security changes lead to major surgery in medical system?" (¿Conducirán los cambios de la seguridad social a una cirugía mayor en el sistema médico?), la opinión de Klaus Wiegandt, funcionario de Seguros Comercial América. A continuación transcribo la nota en una traducción libre:

Klaus Wiegandt trabaja para la más grande compañía aseguradora de México, Seguros Comercial América, y tiene un proyecto.

Antes de que termine el siglo quiere ver clínicas de salud en los estacionamientos de cada gran supermercado en el país, así como una red de centros quirúrgicos de poca estadia para atender la creciente demanda de servicios privados accesibles de salud en México.

Su sueño será realidad si el Gobierno de Zedillo lleva a cabo los planes para permitir a las grandes empresas subrogar el pago de las cuotas al Seguro Social cuando se pueda proporcionar servicio médico alternativo a sus trabajadores.

La cláusula de subrogación, incluida en una nueva ley del seguro social que entró en vigor en julio, podría abrir la puerta para que organizaciones de servicios de salud como las HMO (Health Maintenance Organizations) comiencen a hacer negocios en México.

Pero el gobierno tiene todavía que publicar los reglamentos donde se establezcan las reglas de la subrogación y, a juzgar por el escándalo político del año pasado sobre la privatización de las pensiones, el Sr. Zedillo va a proceder cautelosamente.

El sistema del Seguro Social, como el gigante petrolero Pemex, es considerado como un pilar del moderno Estado mexicano y muchos políticos, incluso miembros del PRI al que pertenece el Sr. Zedillo, así como de la oposición, ven esta cláusula de subrogación como un intento oculto de dismantelar los servicios de salud que proporciona el Estado.

"Privatizar las pensiones fue la parte fácil", dice el Dr. Gabriel Martínez, Director de Finanzas del IMSS. "Las reformas de salud son más complejas y requieren un planteamiento más cauteloso."

A pesar del silencio de los funcionarios públicos, las compañías de seguros ya están haciendo planes para entrar en el mercado de servicios médicos.

Seguros Comercial América pertenece al Grupo Pulsar, cuyo director Alfonso Romo está midiendo el terreno para encontrar nuevas oportunidades de negocios.

Desde hace varios años, el Sr. Romo ha desarrollado una pasión por la biotecnología y actualmente posee la productora de semillas más grande del mundo, así como varias empresas biotecnológicas en Europa y en Estados Unidos.

El pasado julio el Sr. Romo vendió su compañía cigarrera "La Moderna" a la empresa BAT de Gran Bretaña por 1 700 millones de dólares. Desde entonces sus competidores han estado averiguando cuál sería su siguiente paso.

Parte de la respuesta consiste en el deseo de la empresa Pulsar de incursionar en los servicios médicos privados. El grupo está negociando la compra de Médica Sur, un hospital privado grande en la ciudad de México.

Adicionalmente, el Sr. Wiegandt, que dirige el proyecto de salud de Seguros Comercial América, dice que Pulsar planea construir 20 clínicas de corta estancia y varias clínicas de pacientes externos durante los próximos cinco años.

"Si yo colocara mis clínicas en los estacionamientos de los supermercados, les garantizo que millones de mexicanos estarían deseosos de pagar una pequeña suma por servicios médicos, en lugar de tener que afrontar las largas colas y las instalaciones precarias en las clínicas manejadas por el Gobierno."

Hoy en día las compañías de seguros ofrecen planes privados de salud a una pequeña fracción de la población que puede cubrirlas. Sin embargo, empresas como Seguros Comercial América se han visto restringidas por los costos elevados de los servicios médicos.

"Hay sólo 200 hospitales privados en México", dice el Sr. Wiegandt, y "sólo 82 de ellos tienen más de 50 camas, así que cobran lo que quieren porque hay una gran demanda por los servicios que prestan. Hemos decidido que la única forma de controlar costos y ofrecer cobertura médica al alcance de nuestros consumidores será proporcionar los servicios nosotros mismos."

Otras compañías están siguiendo los pasos de Pulsar.

Seguros Inbursa, propiedad de Carlos Slim, el empresario más rico de México, dice que invertirá en nuevos hospitales pensando en comenzar su propia HMO.

Cuando esto suceda los 110 000 empleados del Sr. Slim Telmex, la compañía de telecomunicaciones, Cigatam, la tabacalera y sus otras empresas, serán los mayores clientes de Inbursa.

"Todas las aseguradoras de México están haciendo planes para entrar en el negocio de servicios de salud", dijo Javier Foncercada de Seguros Inbursa. Habrá más hospitales y más competencia. También creemos que con el tiempo, el Gobierno privatizará sus servicios médicos.

En Seguros Comercial América, el Sr. Wiegandt ha dado una señal de cuidado. Los servicios médicos privados están en sus inicios, según dice, y a fin de atraer a los usuarios de grandes corporaciones, las nuevas empresas como la HMO tendrán que probar primero que son capaces de proporcionar la amplia gama de servicios que ofrece el Seguro Social a un precio menor.

Las grandes corporaciones mexicanas no elegirán la subrogación del sistema del Seguro Social antes de que los servicios privados puedan demostrar que son más efectivos desde el punto de vista de costos.

Leslie Crawford

Financiamiento del Banco Mundial

A principios de 1998 se dieron a conocer las negociaciones que venía realizando el IMSS para obtener del Banco Mundial un financiamiento por 700 millones de dólares con el objetivo de respaldar el mejoramiento en la calidad de los servicios médicos, a seis meses de haber entrado en vigor la nueva Ley. Uno de los objetivos que se perseguían con el ordenamiento legal era dar estabilidad financiera al Instituto y elevar la calidad de sus servicios médicos.

Al respecto, el senador José Ángel Conchello señala en un artículo publicado en *El Universal*:

Estos días aciagos, en que el Gobierno recoge los primeros frutos de 10 años de economía neoliberal, anticipando una crisis sexenal que los tecnócratas parecen no barruntar; existen, sin embargo, indicios de que siguen porfiando en su modelo individualista y extranjerizante de país.- Me refiero a dos créditos internacionales que se formalizaron esta semana. Uno, por 700 millones de dólares, para la privatización del Seguro de Salud; otro por 400 para completar la privatización del Seguro de Retiro. Uno de los créditos es famoso porque el director general del Seguro Social, Genaro Borrego, se empeñó en negar que existía; el otro es casi desconocido porque el negociador Guillermo Ortiz Martínez fue hábil para escondérselo.- En total, fueron cuatro créditos del Banco Mundial. Dos para la privatización de las pensiones, dos para la privatización del Sector Salud. Si no hubiera otras evidencias de la injerencia del Banco Mundial en la siniestra reforma del Seguro Social, estos cuatro préstamos por un total de 2 mil 200 millones de dólares, deberá ser prueba ante la historia de que la reforma se decidió en Washington.- A mí me parecía sorprendente que los representantes de las Afores estuvieran tan firmes en sus convicciones: hace una semana el director de una de ellas declaró que no habría cambio en la legislación, digan lo que digan los diputados.- ¡Claro! Ellos saben que tras la Consar está la Secretaría de Hacienda; que detrás de Hacienda está el Presidente Zedillo; y apoyando a Zedillo está el Banco Mundial y, tras el Banco, está Clinton.- De ahí me explico su altanería.- El primer crédito para las Afores fue otorgado en diciembre de 1996, por un total de 700 millones para un programa que el pueblo de México no conocía ni conoce. El dinero se usaría para un "Programa de Desarrollo de Ahorros Contractuales" (Contractual Saving Development Program. Proyecto ME-0197) encargado —extrañamente— al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, con el aval de Hacienda, es decir del gobierno federal: usted y yo.- El segundo crédito, otorgado, según informe oficial del 16 de junio, fue por 400 millones, con el título de "Segundo Programa de Ahorros Contractuales", continuación del anterior y manejado ahora por la Consar y sus jovencitos deslumbrantes.- En ambos créditos se considera que la privatización de las pensiones necesita de apoyo y se espera que lo brinde el Banco, pero hay una peligrosa frivolidad en los propósitos de am-

bos créditos.- Según dicen, el dinero se destina a ayudar a pagar "el costo fiscal de la transición". Están hablando del costo de las pensiones que, según dijeron, implicarían el desembolso de 39 mil millones de pesos, el 1.5% del PIB este año fiscal. Pero si iban a pagar ese dinero con un crédito exterior ¿por qué nunca nos lo dijeron?- "Diseñar el marco legal para regular los fondos de pensiones, su administración y la inversión". ¿La Consar recibió dinero del extranjero para hacer sus circulares? ¡Pobre país!- "Fortalecer al IMSS en su capacidad de manejar el aspecto operacional del sistema". ¿Qué clase de gastos se hicieron? ¿Quién los hizo?- "Estimular la confianza pública mediante educación? Los folletitos que hizo la Consar ¿también se pagaron con deuda pública?, ¿hasta la propaganda y los editoriales de articulistas del gobierno se hicieron con dinero prestado?- Para "emprender reformas del mercado financiero para promover instrumentos financieros para las inversiones de retiro y asegurar rendimientos adecuados para los fondos de pensiones". ¿Qué carambas quiere decir esto? ¿Que el gobierno ha pedido plata a Washington para crear bonos que rindan buenos frutos Siefores? ¿Se da usted cuenta cómo nos engañan? Para el segundo préstamo se dice que no se lograron todos los objetivos y que necesitan más dinero.- Que quede claro pues que las Afores ya están costando mil cien millones de dólares al pueblo -10 mil millones de pesos al tipo de hoy-. Esa deuda pública, no aprobada por el Congreso, desde luego no tiene nada que ver con el libre mercado que estos tales dicen defender.- Desde otro punto de vista, el gobierno federal, comprometió el aval del pueblo para obtener un préstamo a beneficio de negocios privados, las Afores, a fin de que tengan buenas utilidades.- ¡Si no lo viera, no lo creería!

El documento reservado, elaborado con fecha de enero de 1998, demuestra que los propósitos de la reforma llevada a cabo no se habían logrado; por el contrario, nuevamente se ponía en discusión tanto la calidad en los servicios como la situación financiera de la institución.

Este documento tiene dos partes diversas, una en español, bajo el rubro *Proyecto de Reforma del IMSS*, y la otra en inglés, se titula *Mexico. Health System Reform* (México. Reforma al Sistema de Salud).

Documento en español

La primera parte elaborada por el Instituto precisa en el rubro "Advertencia" que "El presente trabajo ha sido elaborado con el propósito de presentar al Banco Mundial un documento integral que sirva de base para la negociación de un crédito, que apoye la Reforma del Instituto Mexicano del Seguro Social en lo general y la recuperación y desarrollo de la infraestructura médica en lo particular." Dicho proyecto "será un soporte crítico para apoyar las políticas institucionales de seguridad social en razón de que la nueva legislación abre

opciones para ampliar la cobertura y la competencia en el otorgamiento de servicios médicos". Contiene la siguiente "tabla de distribución de recursos por año", en dólares americanos:

	Año fiscal		
	1998	1999	2000
Anual	300	200	200
Acumulado	300	500	700

El costo estimado del proyecto, en millones de dólares se estimó de la manera siguiente:

Subproyecto	Total
1. Médico-financiero	594.70
2. Asistencia técnica	41.67
Costo total de base	636.37
Costo de contingencias de precio	63.63
Costo total del proyecto	700.00

Entre los términos específicos que incluye el documento, en el anexo 7 se mencionan los objetivos específicos siguientes:

- Establecer contratos y guías preliminares entre las organizaciones administradoras de la salud y los proveedores de servicios de atención a la salud que no contradigan las disposiciones legales, administrativas e institucionales.
- Establecer contratos y guías preliminares entre proveedores-proveedores de servicios de atención a la salud. Los proveedores pueden ser gubernamentales, institucionales (IMSS, ISSSTE, Servicios Médicos de Pemex, etc.) o privados. Dichos contratos y guías preliminares tendrán la característica de compatibilidad con aspectos legales, administrativos y reglamentarios de las instituciones involucradas.
- Establecer contratos y guías preliminares entre las organizaciones administradoras de la salud y los proveedores, así como entre proveedores-proveedores que contengan principios éticos en la atención al paciente y a su entorno.
- Realizar contratos y guías preliminares que impulsen la calidad de los servicios de atención a la salud en forma constante y permanente.

A lo largo del documento se destaca la participación de organismos privados en la prestación de los servicios médicos institucionales. En este sentido, en el rubro denominado "Primer nivel de atención", se presentan dos presupuestos con los que justifica la deficiente atención médica que otorga: uno deriva de la rigidez del sistema actual; otro, de la insuficiencia laboral del propio Instituto. En relación con el primero, sostiene:

El primer nivel de atención (prevención de enfermedades y atención a los problemas más comunes de salud que no requieren el uso de tecnología compleja ni de hospitalización) es sensible para el Instituto. Los problemas detectados incluyen largas esperas para recibir la consulta, diferimiento de estudios auxiliares de diagnóstico; falta de medicamentos, escasez y obsolescencia de equipos e insumos para el adecuado funcionamiento de las unidades, falta de motivación del personal, despersonalización en la relación médico-paciente, insatisfacción del usuario y quejas. Los usuarios, así como la rigidez del sistema actual, impiden que los pacientes obtengan los medicamentos con oportunidad.

En cuanto al segundo supuesto, precisa:

... ha de señalarse que la planta directiva de las unidades está bien formada en asuntos médicos, pero muestra bajo nivel de capacidad en materia de efectividad gerencial y administración, con la consiguiente imposibilidad actual de hacer un mejor uso de los recursos disponibles (personal, fondos, tecnología, etc.), debido al bajo nivel de decisión en estos asuntos y a que su alcance, en general, es la aplicación de la norma establecida.

Estos presupuestos van preparando el camino para determinar la incapacidad médica del Instituto, la necesidad de contar con recursos financieros complementarios y la posibilidad de incorporar organismos privados para la prestación de estos servicios. En la Introducción señala que "el Instituto ha emprendido una planeación a largo plazo que puede anticipar resultados significativos si se asocian recursos financieros complementarios, que combinen un alto impacto con una recuperación producto de la competitividad en el mercado de provisión de servicios y economías en diversos rubros de gasto".

En relación con el crédito del Banco Mundial, se condiciona el proceso de reforma a dos subproyectos: uno de carácter médico financiero y el otro de asistencia técnica. El primero reconoce la necesidad de adecuar los marcos de regulación que limitan el accionar institucional en cuanto a la prestación de servicios, lo que implica la participación del sector privado. Al respecto se establece:

A efecto de apoyar el proceso de reforma, el Gobierno y el Banco (Mundial) han acordado que dentro del mismo marco de referencia habrá dos subproyectos

interligados con objetivos y condicionales que contribuirán al alcance de los objetivos del Proyecto de Reforma del IMSS.

El primer subproyecto denominado Subproyecto Médico-Financiero se relaciona con los aspectos medulares de la reforma del IMSS y está estructurado por tres componentes: a) Políticas financieras, b) Cambios estructurales y c) Fortalecimiento de las unidades médicas. Los dos primeros componentes están orientados a desarrollar mecanismos innovadores de presupuestación y políticas acordes con el entorno macroeconómico del país, en las cuales se reconoce la necesidad de adecuar los marcos de regulación que limitan el accionar institucional en cuanto a la prestación de servicios. El tercer componente es orientado al fortalecimiento de las unidades médicas y está dirigido a financiar equipo, mobiliario, instrumental médico y consumibles asociados a ellos, vinculados al proyecto de modernización de la gestión, con el propósito de incrementar los actuales niveles de productividad de los servicios de salud, racionalizar los costos de operación y mantenimiento y ofrecer servicios de salud en cantidad suficiente y de calidad adecuada para cubrir la demanda de servicios en condiciones de eficacia y eficiencia.

El segundo subproyecto denominado Asistencia Técnica ha sido diseñado para facilitar las actividades operacionales del Subproyecto Médico-Financiero, lo que significa para la reforma de los servicios institucionales de salud, el financiamiento de estudios de apoyo, consultorías de soporte en materia de capacitación gerencial, control de procesos, auditorías, así como la asignación de recursos para la creación de plazas y para soportar la creación de una unidad para la coordinación y conducción del proyecto.

En otra parte del documento se establece:

... ante la perspectiva inmediata de que el Instituto asuma un papel de proveedor y comprador de servicios como consecuencia de la nueva legislación y de la subrogación integral de servicios, resulta indispensable que la infraestructura en equipo sea suficiente y de calidad para garantizar un grado de competencia aceptable y que se introduzcan vigorosos instrumentos y capacidades de gestión para generar una mejor estructura administrativa, que sea notoriamente orientada a la satisfacción de las necesidades y demandas de los usuarios de los servicios de salud.

Entre las actividades relevantes que marca el documento destacan:

- Crear un nuevo modelo de gestión institucional que permita establecer una lógica contractual, donde el IMSS aprovechando la disponibilidad y oferta de bienes y servicios, defina, en función de las necesidades de la población, cuáles son los servicios por subrogar, los estándares de productividad esperada, la calidad que comprará al proveedor y el sistema de pago prospectivo por realizar.

- Desarrollar estudios de impacto de aplicación del nuevo modelo de operación de los servicios subrogados de salud, alineando a los objetivos de capacidad resolutive, calidad de la atención, contención del costo de los servicios, imagen institucional y uso adecuado de recursos.

Operatividad

Dentro de las estrategias de instrumentación, el documento que analizamos da lugar a la creación de un fondo de fortalecimiento a las unidades médicas, para cuyo acceso establece dos subprogramas:

El mecanismo de apoyo para el fortalecimiento de las unidades médicas será la creación de un fondo innovativo de inversión al cual tendrán acceso todas las unidades a través de dos subproyectos que contemplen tanto el aspecto de equipamiento de las unidades como el de modernización de gestión. La evaluación y aprobación de los subproyectos será con la asistencia de un Comité Técnico de Evaluación coordinado por el área médica con representantes del nivel central, regional, delegacional, zonal y de unidad de salud, lo cual apoyará y dará congruencia a las reformas de modernización en la gestión del Instituto.

Además del Fondo, y con el propósito de garantizar la capacitación de las áreas operativas, se estableció la creación de una Unidad Coordinadora del Proyecto, que contará con una estructura similar en las regiones donde opere el sistema.

Para este efecto, el IMSS parte de que las políticas tradicionales para la asignación de recursos se habían establecido sobre las bases del gasto histórico, creando de esta forma ineficiencia e inequidad en la prestación de servicios, sin que estas condiciones las hubiera resuelto la nueva Ley de 1997. Una de las consecuencias a partir de la vigencia de la Ley fue la aplicación presupuestal que fortalece la desconcentración e implementación de un sistema de presupuesto capitado. A partir de 1997, con el sistema de capitalización individual se desarrolló el concepto *zona médica presupuestal* (generalmente definida como conjunto de uno a tres hospitales con sus clínicas respectivas, en una zona geográfica determinada), dividiendo al país en 139 zonas dentro de las siete regiones establecidas anteriormente por el IMSS. Algunos de estos recursos fueron asignados en el nivel de las zonas médicas; el presupuesto capitado fue ajustado por factores de riesgo, el cual se definió según edad y sexo. El proceso de desconcentración permite, por una parte, que las decisiones se tomen con mayor celeridad y en forma más adecuada, además de que da las bases para una más fácil subrogación de los servicios.

Las metas del proyecto se estima alcanzarlas en tres años e incluyen, entre otras:

- Desarrollar e implantar una metodología de presupuestación capitada.
- Diseñar e implantar un marco regulatorio de subrogación de servicios de salud a terceros, públicos y privados.
- Contar con la asistencia técnica programada para el desarrollo de sistemas médico-administrativos, apoyo a proyectos de inversión, evaluación tecnológica y modelos alternos de gestión.
- Dotar a la totalidad de las unidades médicas del IMSS con el equipamiento y la tecnología requeridos para el desarrollo de sus actividades.
- Capacitar a la totalidad del personal gerencial y del nivel medio de las unidades médicas para aumentar la eficiencia funcional en los diferentes escalones del sistema.

La clasificación de costos deriva de diagnósticos actuales de las áreas médicas. Considera en ellos, los costos de mercado por parte de agencias o consultores independientes calificados para el desarrollo de estudios específicos, además de los gastos de supervisión, entre los que destaca los destinados al desarrollo de auditorías externas, internas e internacionales. Lo relevante es la participación que se da al Banco Mundial, así como al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), institución que actuará como agente financiero.

En el anexo 1, el IMSS proporciona el salario mensual promedio por derechohabiente, en un cuadro que señala, en tres columnas, el rango salarial, el número de cotizantes en cada uno y el promedio. En este cuadro podemos ver que el número de asegurados con menos de un salario mínimo es cercano a dos millones, lo que representa cerca de 20% de la población total protegida; que de uno a dos salarios mínimos, constituye el grueso de la población del IMSS con cerca de tres y medio millones de cotizantes, lo que representa más de 35% de la población total protegida.

El IMSS ha tomado como base de cálculo atractivo tanto para las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) como para los servicios médicos subrogados, hasta cinco salarios mínimos; esto llevaría a que la población cuyos ingresos son menos atractivos para las instituciones financieras privadas ascienden a 8 015 000, es decir, 85% de la población total asegurada. Esto significa que sólo 15% del total de asegurados recibe un salario superior a \$150 diarios. Una familia difícilmente puede sostenerse con \$4500 al mes; por tanto, como ya se anotó, más de 85% de la población protegida subsiste con ingresos que van de \$906.00 a \$4500.00 mensuales, en 1998.

Subrogación parcial e integral

El Director del Instituto en 1998 ha señalado:

... no debe confundirse la supuesta privatización con la subrogación de los servicios, mecanismo al que ha recurrido el Instituto desde hace 55 años y al que ahora se va a reglamentar. A la fecha —según dijo—, trabajadores de más de mil empresas reciben atención médica a través de la subrogación y de la reversión de cuotas.— Esos trabajadores representan 2.47 por ciento del total de asegurados y por los servicios médicos que se les prestan se erogan 600 millones de pesos. Consideró que aunque no hay ningún interés en ampliar la subrogación, es menester reflexionar que si en algún lugar hay muchas empresas y el dinamismo del empleo es muy grande y gana la carrera al IMSS, será menester acudir a la subrogación de servicios pero bajo ciertas condiciones y respeto a los principios que son irrenunciables.

La parte del documento que estamos analizando, en su anexo 11, relativo a los términos de referencia, contiene las bases para incrementar la subrogación parcial y total de los servicios médicos. Por ello es importante transcribir cada parte que se refiere a resumen, objetivo, etapas, metodología, técnicas e instrumentos, productos a obtenerse, tiempo de ejecución, plan de trabajo y calendario para el programa de ejecución, con sus cronogramas. Se trata de una síntesis donde se detallan los pasos a seguir para incrementar y alentar la colaboración de los particulares en la prestación de los servicios médicos, y fomentar la privatización en áreas consideradas de excepción, justificadas en los inicios del IMSS.

En el apartado "Resumen" se dice:

Para la subrogación parcial e integral de los servicios de atención a la salud, es necesario conocer el estado actual que guardan los proveedores de salud a nivel nacional en los aspectos de calidad de los servicios que se otorgan, accesibilidad, infraestructura disponible, número de proveedores y la capacidad con la que cuentan.

El presente estudio está encaminado a evaluar a los proveedores de servicios de salud, con la finalidad de identificar a aquellos que puedan prestar sus servicios al IMSS por la vía de la subrogación, tanto parcial como integral, a través de procedimientos que proponga el Instituto.

La subrogación de los servicios implica, conforme a la Ley, la intervención de organismos privados que pueden ser contratados por el Instituto o por los patrones con la aprobación de los trabajadores. En este sentido, cuando se incrementa esa participación, los servicios médicos se van privatizando, ya que esto conlleva un procedimiento tendiente a dar más facilidades a los particulares para que realicen actividades reservadas al IMSS.

Por lo anterior resulta importante destacar los aspectos del documento en lo relativo a los diversos apartados de estos términos de referencia.

1. **OBJETIVO.-** El objetivo del estudio es la evaluación de los servicios en los siguientes aspectos:
 - a) Calidad de los servicios que ofrecen.
 - b) Servicios que otorgan.
 - c) Infraestructura disponible.
 - d) Capacidad con la que cuentan.
 - e) Accesibilidad de la población al proveedor de servicios.
 - f) Precio de los servicios otorgados.
 - g) Preparación del personal que labora con el proveedor.
 - h) Personal médico empleado y tipo de contratación.
 - i) Organización del prestador de servicios.
2. **ETAPAS.-** Las etapas que se proponen para el desarrollo del estudio son las siguientes:
 - 2.1. Evaluar la calidad del prestador de servicios.
 - 2.2. Enunciar los servicios que ofrece el proveedor.
 - 2.3. Detallar las características del inmueble y equipamiento.
 - 2.4. Definir cuál es la capacidad de atención del proveedor de acuerdo a sus recursos.
 - 2.5. Definir cuáles son las distancias de los poblados aledaños al prestador de servicios.
 - 2.6. Enlistar los precios de cada uno de sus servicios.
 - 2.7. Enlistar el personal, categoría, tipo de contratación y su nivel de preparación.
 - 2.8. Caracterizar la organización del prestador de servicios.
3. **METODOLOGÍA, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS.-** Los responsables describirán detalladamente la forma como fue pensado y concretado este estudio. Igualmente incluirán tanto las técnicas como los instrumentos utilizados en el desarrollo del trabajo.
4. **PRODUCTOS A OBTENERSE.**
 - 4.1. Estudio de la calidad de los servicios que ofrece el proveedor.
 - 4.2. Relación de los servicios que ofrece el proveedor.
 - 4.3. Texto que incluya las características del inmueble y el equipamiento con que cuenta el proveedor.
 - 4.4. Texto que incluya cuál es la capacidad de atención por parte del proveedor.
 - 4.5. Texto que incluya una descripción de las distancias de los diferentes poblados que se encuentran a su alrededor.
 - 4.6. Relación de los servicios que se prestan y el precio de cada uno.
 - 4.7. Relación del personal, categoría, tipo de contratación y su nivel de preparación.
 - 4.8. Texto donde refiera la organización del prestador de servicios.

5. **TIEMPO DE EJECUCIÓN.**- El tiempo de duración para la realización de las etapas anteriormente planteadas es de 12 meses.
6. **PLAN DE TRABAJO Y CALENDARIO PARA EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN.**
 - a) Estudio de la calidad de los servicios que ofrece el proveedor de servicios.
 - b) Relación de los servicios que ofrece el proveedor.
 - c) Texto que incluya las características del inmueble y el equipamiento con que cuenta el proveedor.
 - d) Texto que incluya cuál es la capacidad de atención por parte del proveedor.
 - e) Texto que incluya una descripción de las distancias de los diferentes poblados que se encuentran a su alrededor.
 - f) Relación de los servicios que se prestan y el precio de cada uno de ellos.
 - g) Relación del personal, categoría, tipo de contratación y su nivel de preparación.
 - h) Texto donde refiera la organización del prestador de servicios.

El anexo 12 de este documento relativo a los términos de referencia para la contratación señala que estas formas de contratación

... de los proveedores de servicios médicos por las organizaciones de administradoras de salud son diversos, entre ellos se encuentran pago por servicio prestado, capitación, pago por caso, pago por salario y presupuesto, cada uno de ellos repercute sobre la calidad de atención, cobertura, costos, nivel de uso de tecnología utilizada y organización.

En otra parte del documento se reconoce:

... el proyecto de reforma del IMSS, con apoyo del Banco Mundial ha identificado la reestructuración corporativa como punto neurálgico en el proceso global de la reforma y ha identificado la necesidad de elaborar un nuevo modelo corporativo que responda a las necesidades actuales de salud de los derechohabientes y que se anticipe a los cambios que en materia de servicios de salud se esperan en el corto plazo en México como consecuencia de la apertura del mercado nacional de salud.

Esto permitirá que:

... el IMSS cuente con modelo propuesto y plan de acción, para la reestructuración del sistema, que incluya un programa detallado de trabajo para identificar las necesidades y requisitos administrativos de la nueva estructura corporativa, acciones principales, calendario de financiamiento, manuales operativos y sistemas de soporte.

Documento en inglés

El documento que en inglés se denomina *Mexico. Health System Reform* (México. Reforma al Sistema de Salud), señala entre los riesgos representados por la reacción, que:

... para disminuir la oposición al cambio, la competencia en el mercado deberá llevarse a cabo en forma gradual y deberá llevarse conjuntamente con soporte financiero y técnico. Para mitigar los riesgos políticos, el proyecto de asistencia técnica se apoyará con una campaña mayor para diseminar información sobre las acciones del programa y sus beneficios para los trabajadores del IMSS y los beneficiarios.

Un segundo riesgo consiste en las dificultades que puedan generarse dentro del IMSS, tanto institucional como políticamente en los esfuerzos para la descentralización. El préstamo de asistencia técnica incluirá importantes recursos para ayudar al IMSS en el proceso de descentralización con soporte técnico adecuado.

En vista de que se trata de un documento en idioma inglés, la “descentralización” puede implicar “sacar del ámbito del Instituto”, es decir, alentar la acción particular. Entre nosotros, *descentralizar* y *desconcentrar* son dos términos jurídicos diversos; el primero significa la creación de organismos distintos al Instituto, dentro de la esfera del poder público, con personalidad y patrimonio propios. *Desconcentrar* lleva a la creación de organismos dependientes del Instituto, como se hace en las delegaciones regionales y estatales, con funciones de decisión, para eficientizar el sistema, sin desvincularlo.

En el apartado “Organización, cobertura y prestación de los servicios de salud” se señala que muchos de los problemas del acceso financiero que se han destacado en la sección anterior son parte del resultado de la existencia de un sistema vertical de servicios (*delivery*). La duplicidad de servicios (*facilities*) y el exceso de capacidad en las áreas urbanas constituyen un problema de mucho tiempo. En su mayor parte, la segmentación del sistema de salud se debe a la naturaleza de la cobertura del seguro, con acceso al sistema de salud garantizado acorde con la situación del empleo y del empleador, más que derivado de los convenios del riesgo (*risk-pooling*) acordes con la población o con el nivel de ingresos. La atención a la salud recae en el sector público, con un crecimiento débilmente regulado del sector privado, con una atención en un mercado no fijo. Recientemente, dos importantes empresas han anunciado planes para invertir alrededor de 100 millones de dólares en clínicas y hospitales a fin de desarrollarse en los próximos cinco años, con base en la expansión potencial del servicio privado en México. Las instituciones del sector público que atienden los servicios de salud incluyen instituciones de seguridad social con distintas características, entre ellas IMSS, Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) y Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena),

y paraestatales (por ejemplo, Pemex), la Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA), IMSS-solidaridad y el Departamento de Salud del Distrito Federal.

El IMSS ha iniciado el proceso de descentralización mediante la creación de siete oficinas regionales, lo que ha permitido que las oficinas centrales reduzcan su personal de 13 mil a 11 mil y el desarrollo de una importante actividad tanto en la contabilidad financiera como en la planeación para estas oficinas regionales.

El sistema privado de salud está creciendo, pero se mantiene relativamente sin desarrollo y con una débil regulación. Los proveedores privados tienden a operar clínicas de escala más pequeña y consultorios médicos con pocos grandes hospitales privados. Sin atender el tamaño, las instituciones privadas normalmente cobran sobre la base de convenio salario por servicio. Sobre todo el sector privado está atomizado como proveedor; aun dentro de los grandes hospitales privados, los médicos operan independientemente y contratan con los hospitales ciertos servicios. La mayor parte de los servicios del sector privado están localizados en áreas urbanas con mayor concentración, como en la ciudad de México. El sector privado de salud incluye Planes de Seguros Privados de Salud, que según estimaciones cubren sólo a 2.4% de la población, además de organizaciones administradas de manera privada en una industria que está en sus primeros pasos en México. Las dos más importantes empresas que aparecieron los últimos cinco años con servicios de Mexican HMOs son Meximed y Premedica. La mayor parte de inversiones para este sector provienen del extranjero, particularmente de España, Chile y Estados Unidos de América.

Un aspecto clave para la reforma del IMSS incluye la extensión para cubrir, mediante un esquema de seguros subsidiarios y competencia, un esquema de acción múltiple a través del cual a los asegurados por el IMSS se les dará la opción de revertir un porcentaje de su cuota para adquirir seguros privados.

El sistema presenta dos opciones: *opting-in* y *opting-out*. La primera consiste en atraer a la población que se encuentra entre la seguridad social y la SSA o entre la seguridad social y el sector privado. Esta población, que es mayoritariamente urbana y no pertenece a la economía formal, tiene capacidad para pagar una mejor atención a la salud. Bajo el viejo sistema no tenía posibilidad de estar incluida en una institución de seguridad social. Con la reforma de opción interna (*opting-in*) las familias del sector informal podrán adquirir el seguro de salud del IMSS a un precio atractivo dentro del seguro de salud para la familia. Además se incluye la posibilidad de un seguro de salud para un grupo de población anteriormente excluido; los cambios en el sistema tienen importantes implicaciones para financiar el seguro de salud en beneficio de los no asalariados y del sector informal de trabajadores. En la anterior LSS de 1973 el seguro voluntario tenía un costo de \$305.00 (38 dólares) por mes, financiado totalmente por las aportaciones de los trabajadores.

Con la nueva Ley los no asalariados y el sector informal de trabajadores pueden ingresar a la cobertura de salud del IMSS con un pago de \$235.00 (24 dólares) por familia al mes y un subsidio del Gobierno de alrededor de \$116.00 (15 dólares) por inscripción directa.

El segundo sistema (*opting-out*) implica una reforma a mayor plazo contenida en la LSS. Este sistema, conocido como *reversión de cuotas*, representa un mayor cambio estructural en el sistema del Seguro Social; introduce la posibilidad de que los asegurados seleccionen al asegurador de salud y abre la puerta para una mayor expansión del seguro privado de salud y la previsión del cuidado de salud. El elemento central de la reforma de reversión de cuotas es conceder el derecho a los asegurados del IMSS de revertir la cuota y quedar protegidos por una entidad privada. El asegurador privado garantizará el otorgamiento de los servicios de salud en subrogación al IMSS. En términos generales, mediante la reversión de cuotas se espera alcanzar los objetivos siguientes:

1. Estimular industrias relativamente con poco desarrollo: seguros y atención privada de salud, así como la competencia en el sector salud, al mismo tiempo que una mayor eficiencia y una mayor calidad en los servicios. En cuanto al aspecto financiero, las aseguradoras privadas de salud competirán para obtener un nuevo mercado masivo en lugar del mercado más limitado de aquellos que tienen capacidad de pagar por dobles seguros. Respecto al proveedor de los servicios, los médicos de primera atención, hospitales, proveedores de laboratorios y tecnología médica, también competirán innovando y aumentando su eficiencia para obtener los contratos de los aseguradores privados.
2. Reducir los costos laborales y estimular el empleo formal; debido a la ineficiencia del sistema del Seguro Social, muchos patrones ofrecen seguros privados de salud adicionales a sus trabajadores. En la medida en que los servicios de reversión de cuotas acrediten ser una alternativa satisfactoria mediante estos seguros, disminuirá el costo para los no asalariados.
3. Incrementar tanto el bienestar para el consumidor al generar una mayor opción entre los proveedores de la atención a la salud, como la calidad de la atención y los servicios médicos.

Como un complemento importante para entender los alcances de estos nuevos programas es conveniente transcribir el anexo I del documento en español, donde se precisa el número de cotizantes, los salarios mínimos y los porcentajes en cada grupo.

Cotizantes por rango salarial	3er. bimestre	1997	Porcentaje
W1	Menos de 1 y hasta 1 sm	1848.732	19.37
W2	Menos de 1 y hasta 2 sm	3375.014	35.37
W3	Menos de 2 y hasta 3 sm	1553.261	16.28
W4	Menos de 3 y hasta 4 sm	863.152	9.04
W5	Menos de 4 y hasta 5 sm	474.842	4.98
W6	Menos de 5 y hasta 6 sm	310.743	3.26
W7	Menos de 6 y hasta 7 sm	220.090	2.31
W8	Menos de 7 y hasta 8 sm	157.859	1.65
W9	Menos de 8 y hasta 9 sm	113.797	1.19
W10	Menos de 9 y hasta 10 sm	90.049	0.94
W11	Menos de 10 y hasta 11 sm	71.943	0.75
W12	Menos de 11 y hasta 12 sm	59.894	0.63
W13	Menos de 12 y hasta 13 sm	48.815	0.51
W14	Menos de 13 y hasta 14 sm	42.444	0.44
W15	Menos de 14 y hasta 15 sm	35.343	0.37
W16	Menos de 15 y hasta 16 sm	30.528	0.32
W17	Menos de 16 y hasta 17 sm	25.562	0.27
W18	Menos de 17 y hasta 18 sm	21.602	0.23
W19	Menos de 18 y hasta 19 sm	18.469	0.19
W20	Menos de 19 y hasta 20 sm	16.531	0.17
W21	Menos de 20 y hasta 21 sm	13.839	0.15
W22	Menos de 21 y hasta 22 sm	15.293	0.16
W23	Menos de 22 y hasta 23 sm	10.299	0.11
W24	Menos de 23 y hasta 24 sm	10.457	0.11
W25	Menos de 24 y hasta 25 sm	114.395	1.20

Total de cotizantes**9 542.953****100.00**

Como puede verse, 85% de los cotizantes reciben menos de cinco salarios mínimos; 35.37% dos salarios mínimos, y 1.20% cotizan sobre la base de 25 salarios mínimos.

Al establecer el documento en inglés que se pagará una sobrecuota adicional, se limita, en el mejor de los casos, a 15% de los cotizantes, 1431442, lo que equivale a:

- Dejar al IMSS con los cotizantes de menores ingresos.
- Mantener con poca calidad los servicios institucionales.
- Incrementar los recursos financieros de las aseguradoras privadas.
- Incrementar la participación de los servicios médicos particulares.

Del breve análisis del documento que sirve de base para el crédito que otorgará el Banco Mundial, se derivan las conclusiones siguientes:

1. La LSS de 1997 fue objeto, supuestamente, de estudios financieros y actuariales para dar solidez tanto a las pensiones como a los servicios médicos que otorga el Seguro Social.
2. El crédito que otorgó el Banco Mundial, de acuerdo con la documentación elaborada, permitiría mejorar los servicios médicos mediante la adquisición de los implementos necesarios y la capacitación al personal del IMSS.
3. A 12 años de vigencia de la Ley se han incrementado las deficiencias de los servicios médicos.
4. La prestación de los servicios médicos se ha confiado en mayor número a organismos privados mediante convenios de servicios y reversión de cuotas.

El periódico *El Universal*, en una nota del 16 de junio de 1998, destaca el avance de la privatización de los servicios médicos:

Debido al creciente interés de la iniciativa privada por adquirir hospitales, cinco grandes grupos programan inversiones por más de trescientos millones de dólares en la compra o construcción de los nosocomios.- Lo anterior, debido a la cada vez más cercana subrogación de servicios de salud por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la necesidad de empresas aseguradoras de tener sus propias unidades médicas.- Entre los inversionistas nacionales que ya han realizado asociaciones con empresas especializadas mexicanas y del extranjero, para participar en este mercado, se encuentran Grupo IUSA, de Carlos Peralta asociado con Harvard Health; Grupo Pulsar, de Alfonso Romo Garza con Médica Sur; Hospital Los Ángeles, de Abel Vázquez Raña que recientemente adquirió el Hospital Metropolitano; Hospital ABC; y el Grupo Nacional Provincial de Alberto Bailleres.- El presidente del Grupo IUSA, Carlos Peralta, señaló que en los próximos 18 meses este consorcio asociado con el grupo estadounidense Harvard Health, tiene planeado invertir 30 millones de dólares en la construcción de un hospital y doce clínicas de primer contacto.- Las instalaciones estarán ubicadas en el Valle de México y se estima alcanzar una población derechohabiente de 120 mil afiliados, una vez madurado el proyecto.- Peralta informó que la primera de las clínicas de especialidades que tendrá el Grupo IUSA abrirá en

un mes, y el resto en el plazo de un año y medio.- El empresario comentó que este nicho de negocios que en México se encontraba rezagado presenta por lo mismo oportunidades interesantes al cambiar el concepto de salud en el país, de correctiva a preventiva.- Dijo que el principal mercado de la sociedad creada con Harvard Health será el centro del país, pero no descartó que un futuro se extienda a las principales ciudades de la República Mexicana.- Peralta rechazó que la subrogación de servicios de salud que podría ser aprobada en la Cámara de Diputados (*sic*) próximamente proponga la privatización del seguro social.- El IMSS seguirá prestando sus servicios normales y las nuevas instituciones prestarán servicios adicionales a los derechohabientes del mismo.- Explicó que los nuevos servicios de salud equivalen al seguro de gastos médicos mayores y dijo que el costo de los servicios en las nuevas unidades médicas será de 2 mil 500 pesos al año por derechohabiente, y 5 mil pesos por cobertura familiar.- Comentó que el esquema de subrogación ya existe con empresas como Alpha, Femsa y Pulsar, las cuales en un acuerdo con el IMSS pagan el 50% de las cuotas a la institución y el restante 50% lo destinan al pago de un servicio privado de medicina para sus empleados.- Sin embargo, voceros del IMSS insistieron en que la institución no tiene entre sus planes subrogar servicios médicos a hospitales privados y dijeron desconocer que compañías aseguradoras estén adquiriendo unidades hospitalarias.- Agregaron que el crédito de 700 millones de dólares que recibirá el IMSS del Banco Mundial, precisamente será destinado a la modernización de la infraestructura hospitalaria.- En tanto, médicos de unidades privadas informaron que entre su gremio se ha generalizado un rechazo de personas con seguro de gastos médicos mayores debido que no es un servicio rentable.- Ante esta realidad aseguradoras como GNP y Comercial América, están interesadas en invertir en hospitales para atender a sus propios clientes y otros grupos ante la expectativa de que el IMSS subrogue servicio como ocurrió en Chile, donde la seguridad social se privatizó después de crearse los fondos de pensiones (Afores).

Cuadro básico de medicamentos

La falta o restricción de equipos y medicamentos hace deficitario el servicio, en detrimento de la salud de la población derechohabiente. Enrique Cárdenas de la Peña destaca la importancia de organizar adecuadamente este servicio:

Sin afectar a la eficacia de los servicios, las instituciones de Seguridad Social deben tender al logro de una economía más plausible. En el terreno de sus prestaciones, la asistencia farmacéutica ha de controlarse convenientemente, de tal suerte que su impartición no repercuta en forma ostensible sobre el renglón de sus egresos. El racionalizar la citada asistencia no significa en modo alguno cohibir al médico en la prescripción del producto que la ciencia y la técnica aconsejan.

El medicamento eficaz debe usarse aunque resulte de costo elevado, ya que los resultados de su administración compensan su valor. En medio de los progresos de la farmacología moderna y el notable desarrollo de la industria farmacéutica, en medio de la complejidad química y la alta especialización de la técnica del análisis farmacodinámico, en medio también del juego de intereses y promociones comerciales de propaganda dirigida, cabe el que dichas instituciones —IMSS entre ellas— establezcan una terapéutica orientada a través de un cuadro básico de medicamentos, estructurado a conciencia dentro de los lineamientos más estrictos, que en resumen contenga aquellos fármacos de mayor prestigio y seguridad. Dentro de la selva de nombres y marcas, es indispensable que el médico esté protegido por una pauta elaborada con rigor científico en la que se precisen los medicamentos realmente útiles, sus nombres químicos o genéricos, las dosis, formas de aplicación e indicaciones. Quedan así descartadas variantes superfluas y drogas de actividad dudosa y aun perjudicial. El sistema está diseñado para proteger a los trabajadores y auxiliar al médico. La supervisión estricta de las normas de calidad en cuanto a la composición del medicamento y a la ética del productor, y a la periodicidad de revisión, garantizan al derechohabiente y al profesional que prescribe, la solvencia moral y la actualización del cuadro. Permitir el uso libre de todos los medicamentos que existen en el mercado lleva no sólo a repercusiones económicas serias, sino a dificultades administrativas, ya que es imposible poder surtir y controlar las grandes y variables cantidades de productos farmacéuticos existentes.

Para conocer la eficiencia del sistema de control de medicamentos sería suficiente preguntar al personal médico y paramédico de la institución, así como a los derechohabientes, directamente afectados. Las quejas internas y externas, ajenas al interés de los laboratorios, son la pauta de un cuadro no actualizado y de limitaciones que producen efectos nocivos en la salud. Desde 1931 las reuniones internacionales están acordes en que es necesario orientar la terapéutica para mejorar su calidad técnica y obtener el mejor medicamento al menor precio posible.

En 1934 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) concluyó que el seguro de enfermedad no puede ofrecer sino aquellas prestaciones médicas y farmacéuticas que fueren absolutamente indispensables y apropiadas a las exigencias de cada caso, suficientes no obstante en calidad como en cantidad: se trata de lograr la máxima eficiencia con el mínimo de gasto. La experiencia, ya larga, de organización de prestaciones médicas y farmacéuticas del seguro de enfermedad, viene demostrando que los criterios de eficacia y de economía no se aplican correctamente.

Prestaciones en dinero

En este seguro sólo se otorga un subsidio para los trabajadores permanentes que reúnan cuando menos cuatro cotizaciones semanales inmediatamente anteriores a la enfermedad, o seis si se trata de trabajadores eventuales (por tiempo determinado), durante los cuatro meses anteriores a la enfermedad (art. 97).

El subsidio equivale a 60% del salario base de cotización (art. 98), que se pagará por periodos vencidos que no excederán de una semana. El subsidio se cubrirá a partir del cuarto día de la inhabilitación y hasta por el término de 52 semanas, que podrá prorrogarse por 26 semanas, en caso de continuar la condición patológica del asegurado (art. 96).

Maternidad

Las personas protegidas por maternidad son (art. 84):

- a) La trabajadora asegurada.
- b) La asegurada que no sea trabajadora.
- c) La pensionada.
- d) La cónyuge o la concubina.
- e) Las hijas del asegurado, hasta los 16 años; las que estudien, hasta los 25 años, y las incapacitadas para trabajar, durante toda su vida.

La mujer trabajadora recibe un subsidio de 100% del salario base de cotización, conforme al art. 102, que cubre a la asegurada que tenga acreditadas un mínimo de 30 cotizaciones semanales, en un lapso continuo o en diferentes periodos, en distintos supuestos de inscripción o en el mismo, siempre que la suma de los periodos de afiliación y los de baja no exceda de un año.

Es posible que la mujer deje de trabajar al contraer matrimonio o que cambie de trabajo. El Instituto comprobará que en el último año, a partir del momento en que se genere el pago del subsidio, tenga a su favor 30 cotizaciones.

El pago de este subsidio está condicionado a que los servicios médicos del Instituto constaten el embarazo y la fecha probable del parto. En vista de que la Ley propone cuidar a la mujer y al producto del embarazo, requiere que ésta no labore durante los periodos pre y posnatales. En el supuesto de que reciba un subsidio por alguna causa diversa, se cancelará el que sea inferior.

Artículo 102. Para que la asegurada tenga derecho al subsidio que se señala en el artículo anterior, se requiere:

- I. Que haya cubierto por lo menos treinta cotizaciones semanales en el periodo de doce meses anteriores a la fecha en que debiera comenzar el pago del subsidio;
- II. Que se haya certificado por el Instituto el embarazo y la fecha probable del parto, y
- III. Que no ejecute trabajo alguno mediante retribución durante los periodos anteriores y posteriores al parto.

Si la asegurada estuviera percibiendo otro subsidio, se cancelaría el que sea por menor cantidad.

La asegurada recibirá el pago de 42 días anteriores y 42 posteriores al parto, por 100% del salario base de cotización. Cuando el momento de parto no coincida y exista un lapso posterior, hasta el alumbramiento, de 42 días al instante del nacimiento, se cubrirá con 60% del salario de cotización (equivalente al subsidio por enfermedad), como lo dispone el art. 101.

La *Ley Federal del Trabajo* (LFT), en la fracc. V del art. 170 dispone que las prórrogas se cubrirán al 50% del salario, por un periodo no mayor de 60 días; cantidad y lapso que, en todo caso, deberá completar el patrón.

El pago del subsidio que lleva a cabo el Instituto exime al patrón de la obligación del pago del salario íntegro que determina el art. 170, fracc. V, de la LFT, sólo hasta los límites de la Ley, como lo establece el art. 103 de la LSS, que añade: "Cuando la asegurada no cumpla con lo establecido en la fracción I del artículo anterior, quedará a cargo del patrón el pago del salario íntegro."

Esto significa que cuando el salario de cotización sea inferior al real, la diferencia la pagará el patrón. También el patrón cubrirá el salario de los periodos de descanso, si la asegurada no reúne las 30 semanas de cotización.

Al respecto la LFT determina:

Artículo 170. Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos:

[...]

II. Disfrutarán de un descanso de seis semanas anteriores y seis posteriores al parto;

III. Los periodos de descanso a que se refiere la fracción anterior se prorrogarán por el tiempo necesario en el caso de que se encuentren imposibilitadas para trabajar a causa del embarazo o del parto;

[...]

V. Durante los periodos de descanso a que se refiere la fracción II, percibirán su salario íntegro. En los casos de prórroga mencionados en la fracción III, tendrán derecho al cincuenta por ciento de su salario por un periodo no mayor de sesenta días;

[...]

VII. A que se computen en su antigüedad los periodos pre y postnatales.

Ayuda para gastos de defunción

A partir de la primera Ley de 1943 se consigna esta prestación en forma limitada en cuanto a los sujetos que contempla: asegurados y pensionados, así como en su monto, que partía del salario base de cotización, para extenderse al salario mínimo general del Distrito Federal. La ayuda fue significativa en sus orígenes y es simbólica en la actualidad.

Las condiciones que se establecen son la presentación del acta de defunción y la cuenta original de los gastos de funeral. El pago se hace preferentemente a los familiares del asegurado fallecido, y sólo ante su ausencia, a cualquier persona que presente los documentos mencionados. La prestación es de dos meses del salario mínimo.

Artículo 104. Cuando fallezca un pensionado o un asegurado que tenga reconocidas cuando menos doce cotizaciones semanales en los nueve meses anteriores al fallecimiento, el Instituto pagará a la persona preferentemente familiar del asegurado o del pensionado, que presente copia del acta de defunción y la cuenta original de los gastos de funeral, una ayuda por este concepto, consistente en dos meses del salario mínimo general que rija en el Distrito Federal en la fecha del fallecimiento.

Régimen financiero del seguro de enfermedad y maternidad

Como se ha señalado, este seguro es el que más prestaciones otorga a la población que comprende, de tal forma que los cálculos actuariales deben ser precisos para mantener e incrementar la calidad en los servicios. Los costos son tan elevados que puede ser difícil preverlos, sobre todo con números crecientes de protegidos y mecanismos variados que van desde la obligatoriedad de la incorporación hasta la celebración de convenios y la expedición de decretos del Ejecutivo Federal.

Los recursos necesarios para otorgar las prestaciones deben distinguir tanto las contingencias como los sujetos. La Ley dispone que los recursos para cubrir las prestaciones en este seguro se obtendrán de las cuotas que cubrirán primordialmente los patrones y los trabajadores:

Artículo 105. Los recursos necesarios para cubrir las prestaciones en dinero, las prestaciones en especie y los gastos administrativos del seguro de enfermedades y maternidad, se obtendrán de las cuotas que están obligados a cubrir los patrones y los trabajadores o demás sujetos y de la contribución que corresponda al Estado.

Ley de 1973

Artículo 114. A los patrones y a los trabajadores les corresponde cubrir para el seguro de enfermedades y maternidad, las cuotas del ocho punto setecientos cincuenta por ciento y tres punto ciento veinticinco por ciento sobre el salario diario base de cotización, respectivamente. Los ingresos por concepto de pensiones quedan exentos del pago de cuotas.

Artículo 115. En todos los casos en que no esté expresamente prevista por ley o decreto la cuantía de la contribución del Estado para el seguro de enfermedades y maternidad, será igual a siete punto ciento cuarenta y tres por ciento del total de las cuotas patronales. La aportación del Estado será cubierta en pagos mensuales iguales, equivalentes a la doceava parte de la estimación que presente el Instituto para el año siguiente a la Secretaría de Programación y Presupuesto, en el mes de julio de cada ejercicio, mensualidades que se incrementarán en el mismo por ciento en que se incrementen los salarios mínimos para el Distrito Federal, a partir del mes siguiente a aquel en que éstos ocurran, formulándose el ajuste definitivo en el mes de enero del año siguiente.

Ley de 1997

Artículo 106. Las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad, se financiarán en la forma siguiente:

I. Por cada asegurado se pagará mensualmente una cuota diaria patronal equivalente al trece punto nueve por ciento de un salario mínimo general diario para el Distrito Federal;

II. Para los asegurados cuyo salario base de cotización sea mayor a tres veces el salario mínimo general diario para el Distrito Federal, se cubrirá además de la cuota establecida en la fracción anterior, una cuota adicional patronal equivalente al seis por ciento y otra adicional obrera del dos por ciento, de la cantidad que resulte de la diferencia entre el salario base de cotización y tres veces el salario mínimo citado;

III. El Gobierno Federal cubrirá mensualmente una cuota diaria por cada asegurado, equivalente a trece punto nueve por ciento de un salario mínimo general para el Distrito Federal, a la fecha de entrada en vigor de esta ley, la cantidad inicial que resulte se actualizará trimestralmente de acuerdo a la variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor.

Analicemos las variantes en las cuotas, con base en el ejemplo siguiente:

Con un salario base de cotización de \$100.00 diarios

Ley de 1973

Patrón	\$ 8.75 - 70%
Trabajador	\$ 3.125 - 25%
Gobierno	
Federal	\$ 0.625 - 05%
Total	\$ 12.50

Ley de 1997

Prestaciones en especie

Patrón	\$ 3.6765
	\$ 1.239
Trabajador	\$ 0.413
Gobierno Federal	\$ 3.676
Subtotal	\$ 9.0045

Prestaciones en dinero

Patrón	\$ 0.70
Trabajador	\$ 0.25
Gobierno Federal	\$ 0.05
Subtotal	\$ 1.00

Totales a cubrir por las tres partes

Patrón	\$ 5.6155 - 56.12%
Trabajador	\$ 0.663 - 6.62%
Gobierno	
Federal	\$ 3.726 - 37.24%
Total	\$10.0045
Diferencia con anterior	-20%

La condición gráfica de la cuota actual deriva en un descenso de la aportación patronal de 13.88% y de la obrera en 18.38%, así como en un incremento en la cuota a cargo del Gobierno Federal en 37.19%. Si se parte de la difícil situación financiera generada por las prestaciones que deben otorgarse, sin reducir la población protegida y ante la expectativa de un eventual mejoramiento en la calidad de los servicios, la cuota de los patrones y de los trabajadores debía haberse mantenido en las mismas condiciones, sin reducción, e incrementar, como se hace, la participación del Gobierno Federal.

Sujetos del régimen voluntario

Por otra parte, debe tomarse en cuenta que los sujetos del art. 13 cotizarán conforme lo establecen los arts. 227 a 230 de la LSS, de acuerdo con los dos grupos siguientes:

1. *No asalariados, campesinos y patrones personas físicas.* Las personas comprendidas en este apartado pagarán el total de la cuota obrero-patronal, con base en un salario mínimo del Distrito Federal, vigente en el momento de la incorporación o de la renovación anual (art. 227, fracc. I), para todas las ramas de seguro, excepto para enfermedades y maternidad, en las que se aplicarán las cuotas ya analizadas para el patrón y el trabajador.

Respecto a los grupos de no asalariados y campesinos, podrá convenirse con instituciones de crédito o entidades públicas o privadas, con las que tengan relaciones comerciales o jurídicas derivadas de su actividad, que les retengan y enteren las cuotas correspondientes; en este caso, las entidades mencionadas serán solidariamente responsables del pago de las cuotas.

2. *Trabajadores domésticos y trabajadores al servicio de las administraciones públicas de la Federación, entidades federativas y municipios, excluidos o no comprendidos en otras leyes o decretos como sujetos de seguridad social.* Para este supuesto, los sujetos de aseguramiento cotizarán sobre la base del salario real integrado en los términos del art. 27 de la Ley y, por tanto, en enfermedad y maternidad tendrán las cuotas que se determinan en el art. 106 mencionado.

Cooperativas

La Ley de 1973 determinaba que las sociedades cooperativas de producción, las administrativas obreras o mixtas, las sociedades locales, los grupos solidarios o las uniones de crédito, cubrirían 50% de las primas totales, y el gobierno federal, el otro 50% (art. 116).

La Ley de 1997, en la fracc. II del art. 12, señala a los socios de sociedades cooperativas como sujetos del régimen obligatorio, en los mismos términos y condiciones que los trabajadores. La figura de las cooperativas está regulada por la *Ley General de Sociedades Cooperativas* (LGSC), ordenamiento que no considera equiparable la condición de los socios cooperativizados con la de los trabajadores. En el art. 57 establece el Fondo de Previsión Social, destinado a constituir reservas para cubrir los riesgos y las enfermedades profesionales y crear fondos de pensiones y haberes de retiro de los socios, así como primas de antigüedad para cubrir gastos médicos y de funeral, subsidios por incapacidad, becas educacionales para los socios o sus hijos, guarderías infantiles, actividades culturales y deportivas, y otras prestaciones de previsión social de naturaleza análoga.

La Ley específica establece un sistema de seguridad social destinado a cubrir contingencias de los socios y los trabajadores. En un acto de abierta contradicción jurídica, el mismo precepto establece que las prestaciones derivadas del Fondo de Previsión Social serán independientes de las que tengan derecho los socios por su afiliación a los sistemas de seguridad social, situación que implica un fuerte gravamen en contra de estas sociedades. Por otra parte, determina que estas sociedades deberán afiliar obligatoriamente a sus trabajadores y socios que aporten su trabajo personal, a los sistemas de seguridad social, e instrumentar las medidas de seguridad e higiene en el trabajo, así como de capacitación y adiestramiento.

A pesar de lo señalado en los preceptos mencionados, tanto de la LSS como de la LGSC, deben distinguirse, para efectos del otorgamiento de prestaciones y cumplimiento de la inscripción al Seguro Social, las sociedades cooperativas de consumidores que pueden dedicarse a actividades de abastecimiento y distribución, así como a la prestación de servicios relacionados con la educación o la obtención de vivienda (art. 26), de las sociedades cooperativas de productores, que son aquellas cuyos miembros se asocian para trabajar en común en la producción de bienes y/o servicios, aportando su trabajo personal, físico o intelectual (art. 27). De aquí se deriva que no pueden imponerse esas obligaciones a las sociedades cooperativas de consumidores.

Las sociedades cooperativas de producción podrán constituir, entre otros, los fondos sociales siguientes: de reserva, de previsión social y de educación cooperativa (art. 57). El Fondo de Previsión Social se constituirá con la aportación anual del porcentaje que sobre los ingresos netos sea determinado por la Asamblea General y se aplicará en los términos del artículo anterior. Este porcentaje podrá aumentar según los riesgos probables y la capacidad económica de la sociedad cooperativa (art. 58).

10

Invalidez y vida

.....

Condiciones previas

La *Ley del Seguro Social* (LSS) contiene en un solo capítulo las pensiones de invalidez y vida, cuando el seguro de invalidez debía formar parte del de enfermedad, en vista de que uno de los requisitos es que la imposibilidad derive de un accidente o enfermedad no profesionales, por lo cual debía entenderse el capítulo relativo sólo para el supuesto de muerte, que de manera confusa se denomina seguro de vida.

Artículo 112. Los riesgos protegidos en este capítulo son la invalidez y la muerte del asegurado o del pensionado por invalidez, en los términos y con las modalidades previstas en esta Ley.

El otorgamiento de las pensiones requiere periodos de espera medidos en semanas de cotización.

Artículo 113. El otorgamiento de las prestaciones establecidas en este capítulo requiere del cumplimiento de periodos de espera, medidos en semanas de cotización reconocidas por el Instituto, según se señala en las disposiciones relativas a cada uno de los riesgos amparados.

Para efectos de este artículo se consideran como semanas de cotización por lo que se refiere al seguro contenido en este capítulo las que se encuentren amparadas por certificados de incapacidad médica para el trabajo.

Es difícil comprender la primera parte de esta disposición debido a que por naturaleza son diferentes tanto las pensiones como las prestaciones que se otorgan. En consecuencia, los periodos de espera para invalidez debían requerir la

misma condición que para el riesgo de trabajo; esto es, que ante la presencia del estado de invalidez, el asegurado pudiera recibir en forma inmediata el beneficio —si cuenta con las semanas que se requieren para el supuesto de enfermedad, es decir, cuatro cotizaciones semanales inmediatamente anterior al riesgo que no sea de trabajo—, ya que en los términos de la Ley, al incrementarse el tiempo de espera se deja en desamparo al accidentado o enfermo, quien se encuentra en forma parcial o definitiva impedido para laborar.

La pensión correspondiente es compatible con otra pensión, para lo cual se tomará en cuenta 100% del salario mayor que sirva de base para determinar la cuantía de las pensiones concedidas. Esto significa una importante limitación que opera en perjuicio del asegurado, si se toma en cuenta que el único cálculo de la pensión existente es diferente a este seguro.

El asegurado que traslade su domicilio a un país extranjero, continuará recibiendo la pensión, siempre que exista un convenio con dicho país o que los gastos administrativos de traslados de los fondos corran por cuenta del pensionado. El monto de la pensión en este seguro se confiere cuando el asegurado quede imposibilitado para obtener un trabajo igual que el anterior a la enfermedad o al accidente no profesionales y que la remuneración sea inferior a 50% de la que percibía; tenga acumuladas 250 semanas de cotización o que en el dictamen respectivo se determine una valoración de 75% o más de la invalidez; así como a la muerte del asegurado o pensionado por invalidez, en términos del capítulo quinto, título segundo de la LSS.

Invalidez

Este tema se trata en los artículos siguientes:

Artículo 119. Para los efectos de esta Ley existe invalidez cuando el asegurado se halle imposibilitado para procurarse, mediante un trabajo igual, una remuneración superior al cincuenta por ciento de su remuneración habitual percibida durante el último año de trabajo y que esa imposibilidad derive de una enfermedad o accidente que no sean de trabajo.

La declaración de invalidez deberá ser realizada por el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Artículo 122. Para gozar de las prestaciones del ramo de invalidez se requiere que al declararse ésta el asegurado tenga acreditado un pago de doscientas cincuenta semanas de cotización. En el caso de que el dictamen respectivo determine que el setenta y cinco por ciento o más de invalidez sólo se requerirá que tenga acreditadas ciento cincuenta semanas.

Veamos los elementos de la pensión de invalidez (art. 141):

Cuantía básica**35% salario promedio 10 años**

Asignaciones familiares	Cónyuge o concubina	15%
	Hijo	10%
	Ascendiente	10%
Ayuda asistencial	De 15 a 20% sobre cuantía básica	

Las pensiones definitivas que se otorgan por invalidez responden a dos criterios:

- Pensión con valoración menor de 75%, requiere 250 semanas de cotización.
- Pensión con valoración superior a 75%, requiere 150 semanas de cotización.

La Ley establece los requisitos en semanas de cotización, pero no precisa, para el segundo supuesto, la referencia porcentual. Mientras que en el primer caso se refiere a la imposibilidad de obtener ingresos, cuando menos de 50%, en una actividad similar a la que tenía antes del accidente o la enfermedad, para el primer supuesto no precisa las bases para estimar el porcentaje de invalidez.

De manera general se señala que para tener derecho al pago de la pensión correspondiente (art. 122) el asegurado debe haber cotizado un mínimo de 250 semanas. Como situación de excepción determina que el número de semanas puede disminuir "en el caso que el dictamen respectivo determine el setenta y cinco por ciento o más de invalidez", para lo cual se requerirá que tenga acreditadas sólo 150 semanas de cotización.

El estudio de los diversos aspectos que integran las prestaciones que se otorgan por invalidez, permite concluir que existe una gran disparidad conforme a las diversas situaciones que puede reunir el asegurado, donde se hace depender la pensión de su posibilidad de obtener ingresos. Si éstos son inferiores a 50% de los que tenía en el último año, se dará la pensión; si son superiores, se pierde este derecho. A continuación se presentan los supuestos donde precisamos las condiciones y los beneficios o perjuicios que en cada uno se señalan para efectos de concreción, así como una más clara visión de los mismos.

Seguro de vida

Por lo que se refiere al *seguro de vida* (muerte), las pensiones se otorgan a los beneficiarios del trabajador asegurado fallecido o del pensionado como una

protección para la familia, ante la muerte de quien ha sido el sostén económico para el cónyuge y los hijos.

Es conveniente distinguir el caso de muerte derivada de riesgo de trabajo, del supuesto contenido en esta tercera rama, donde es necesario que la causa sea ajena al accidente de trabajo o a la enfermedad profesional (art. 128, fracc. II).

Los diversos supuestos se refieren a:

- La muerte de un asegurado (art. 127).
- La muerte de un pensionado por invalidez (art. 127).
- La muerte de un pensionado por incapacidad permanente (art. 129).

Los beneficiarios tendrán derecho a recibir una pensión cuando, en general, al fallecer el asegurado hubiese tenido reconocido el pago de un mínimo de 150 cotizaciones semanales (art. 128, fracc. I). La calidad de pensionado otorga derecho a asistencia médica (art. 127, fracc. V).

Las prestaciones a que se tienen derecho conforme al art. 127 son las siguientes:

- Pensión de viudez.
- Pensión de orfandad.
- Pensión de ascendientes.
- Ayuda asistencial a la pensionada por viudez que lo requiera.
- Asistencia médica.

Pensión de viudez

El monto de la pensión de viudez se calcula a 90% de la que hubiese correspondido al asegurado fallecido, por pensión de invalidez o de la que estuviese disfrutando (art. 131):

- Si el fallecido era pensionado, la viuda o el viudo, en su caso, recibirá 90% de la pensión que tenía asignada.
- Si el asegurado fallece, se calcula el monto de la pensión que le hubiese correspondido, en la forma que se precisó para su cuantificación.

Se niega el otorgamiento de la pensión en los casos siguientes, que quedan sin efecto si hubiera hijos (art. 132):

1. Cuando el asegurado muera antes de cumplir seis meses de matrimonio, sin tomar en cuenta las circunstancias (fracc. I).

2. Cuando al contraer matrimonio, el asegurado fallecido tuviera 55 años de edad, a menos que hubiese transcurrido un año de matrimonio (fracc. II).
3. Cuando la cónyuge se case con un pensionado por invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada, a menos que hubiese transcurrido un año de vivir juntos (fracc. III).

Pensión de orfandad

Los hijos huérfanos del padre o de la madre tienen derecho a recibir una pensión, conforme a los supuestos establecidos en la Ley, limitado por la edad y la condición de los menores (art. 134):

1. Los hijos menores de 16 años tienen derecho, sin limitación alguna; esta pensión es incompatible con un trabajo remunerado que lo haga objeto de aseguramiento.
2. Los hijos mayores de 16 años, menores de 25, cuando no trabajen y estén estudiando en alguna escuela, instituto o centro educativo que forme parte del sistema educativo nacional.
3. Los hijos de cualquier edad que estén médicamente incapacitados para trabajar.

Debido a que el art. 135 mantiene el mismo porcentaje que la Ley de 1973, la pensión para cada uno de los hijos será de 20% de la que hubiere correspondido al padre o a la madre fallecido, por pensión de invalidez. Esta pensión es compatible con otra pensión de orfandad, en el supuesto de que ambos padres hubiesen estado asegurados. Si el hijo es huérfano de padre y madre y uno de éstos no hubiera estado asegurado, aun cuando el deceso del segundo padre ocurriera después de otorgada la pensión, el porcentaje se incrementará a 30%.

Las pensiones de viudez y de orfandad son concurrentes, de manera que se protege y limita el derecho de los sujetos comprendidos en ambas. El art. 144 establece el límite máximo al disponer que la suma de ellas no deberá exceder del monto de la pensión de invalidez que disfrutaba el asegurado o de la que le hubiere correspondido en este supuesto.

Artículo 144. El total de las pensiones atribuidas a la viuda, o a la concubina y a los huérfanos de un asegurado fallecido no deberá exceder del monto de la pensión de invalidez que disfrutaba el asegurado o de la que le hubiera correspondido en el caso de invalidez. Si ese total excediera, se reducirán proporcionalmente cada una de las pensiones.

Cuando se extinga el derecho de alguno de los pensionados se hará una nueva distribución de las pensiones que queden vigentes, entre los restantes, sin que se rebasen las cuotas parciales ni el monto total de dichas pensiones.

Pensión de ascendientes

La pensión de ascendientes se considera como de excepción, condicionada a:

- La falta o existencia de cónyuge, concubina o hijos.
- La dependencia económica del asegurado o pensionado.

El art. 137 dispone:

Si no existieren viuda, viudo, huérfanos ni concubina o concubinario con derecho a pensión, ésta se otorgará a cada uno de los ascendientes que dependían económicamente del asegurado o pensionado por invalidez fallecido, por una cantidad igual a veinte por ciento de la pensión que el asegurado estuviese gozando al fallecer, o de la que le hubiera correspondido suponiendo realizado el estado de invalidez.

La *dependencia económica* es un término muy amplio y de difícil interpretación.

Este seguro contiene otra contradicción que además de confundir implica una seria violación a los derechos de los asegurados y sus beneficios. Por otra parte, el art. 146 de la LSS dispone:

Los recursos necesarios para financiar las prestaciones (pensiones) y los gastos administrativos del seguro de invalidez y vida, así como la constitución de las reservas técnicas, se obtendrán de las cuotas que están obligados a cubrir los patrones, los trabajadores y demás sujetos obligados, así como de la contribución que corresponda al Estado.

De la transcripción no queda duda en relación con las cuotas que son suficientes para atender montos de las pensiones; sin embargo, el art. 120 del mismo ordenamiento insiste en la cuota individual: "para la contratación de los seguros".

Por otra parte, es de considerar que todos los trabajadores y patrones aportan 1% del salario base de cotización para los servicios médicos de los pensionados (art. 28). Como puede verse, la Ley va considerando la cuota adecuada o no, para cubrir tanto las pensiones como las prestaciones médicas, a fin de atender o aligerar las cargas. A pesar de ello, como hemos visto, el ordenamiento resta posibilidades financieras a la institución.

11

Capitales constitutivos

Para las personas poco familiarizadas con los términos y el manejo de asuntos relacionados con el Seguro Social, resulta complicado y difícil entender el término *capitales constitutivos*, denominación que no identifica un objeto específico. El *capital*, en términos generales, se refiere a una cantidad determinada o determinable de dinero, no a prestaciones otorgadas o por otorgarse. Desde la primera Ley se incluyeron las cantidades que se van acumulando en contra del patrón por el valor de las prestaciones médicas y en dinero que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) otorga al trabajador, derivadas de la no inscripción del trabajador o de la inscripción inadecuada, en tiempo o salario.

En vista de la trascendencia que tienen los capitales constitutivos para las empresas, puesto que no todos los trabajadores están inscritos o de que la inscripción se hace con un salario inferior al real, en términos de la fracc. XVIII del art. 5 A de la *Ley del Seguro Social* (LSS), analizaré esta figura como abogado postulante, para dar los elementos tanto de defensa como de resolución para las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, además de los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa.

El capital constitutivo se finca por el IMSS en los seguros de riesgo de trabajo (arts. 77 a 79), de enfermedad y maternidad (art. 88) y de invalidez y vida (art. 149). Iniciaremos nuestro estudio con el seguro de riesgo de trabajo; los supuestos y elementos se aplican a cada uno de los tres seguros mencionados.

Supuestos

Los supuestos de los capitales constitutivos son la no inscripción del trabajador en el IMSS y la inscripción realizada por el patrón de manera que disminuyen las prestaciones que los trabajadores asegurados o sus beneficiarios tienen derecho a recibir. El art. 77 de la LSS, en forma armónica con los arts. 9 y 287 del mismo ordenamiento, determina la naturaleza de los capitales constitutivos y la procedencia de las acciones fiscales del IMSS en cada caso concreto.

Artículo 77. El patrón que estando obligado a asegurar a sus trabajadores contra riesgos de trabajo no lo hiciera, deberá enterar al Instituto, en caso de que ocurra un siniestro, los capitales constitutivos de las prestaciones en dinero y en especie, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley, sin perjuicio de que el Instituto otorgue desde luego las prestaciones a que haya lugar.

La misma regla se observará cuando el patrón asegure a sus trabajadores en forma tal que se disminuyan las prestaciones a que los trabajadores asegurados o sus beneficiarios tuvieran derecho, limitándose los capitales constitutivos, en este caso, a la suma necesaria para completar las prestaciones correspondientes señaladas en la Ley.

Esta regla se aplicará tratándose de recaídas por riesgo de trabajo, con el mismo patrón con el que ocurrió el riesgo o con otro distinto.

Los avisos de ingreso o alta de los trabajadores asegurados y los de modificaciones de su salario, entregados al Instituto después de ocurrido el siniestro, en ningún caso liberarán al patrón de la obligación de pagar los capitales constitutivos, aun cuando los hubiese presentado dentro de los plazos que señalan los artículos 15 fracción I y 34 fracciones II a III de este ordenamiento legal.

El Instituto determinará el monto de los capitales constitutivos y los hará efectivos, en la forma y términos previstos en esta Ley y sus reglamentos.

La no inscripción debe analizarse con mucho cuidado, en vista de que la carga de la prueba corresponde al Instituto, por lo que no es suficiente que finque los capitales constitutivos, sin acreditar ante el patrón de manera fehaciente los elementos que tuvo en cuenta para establecer la relación de trabajo. Invocar la negativa de la relación de trabajo es un elemento que ha resultado suficiente ante los tribunales, en vista de que ésta no fue demostrada al patrón. La forma adecuada de demostración es mediante una revisión de gabinete o una visita, sin que sea suficiente la manifestación del trabajador; la relación laboral debe acreditarse con prueba idónea, la documental admitida por la parte patronal, la revisión de gabinete o la visita fiscal llevada a cabo en libros y documentos que acrediten fehacientemente la prestación de un servicio personal y subordinado (arts. 8, LFT y 5 A, fracc. V, LSS).

Es de llamar la atención el señalamiento contenido en el segundo párrafo del art. 77: "... cuando el patrón asegure a sus trabajadores en forma tal que

se disminuyan las prestaciones a que los trabajadores asegurados o sus beneficiarios tuvieren derecho, limitándose los capitales constitutivos, en este caso, a la suma necesaria para completar las prestaciones correspondientes señaladas en la Ley". El supuesto de que el patrón *asegure* a sus trabajadores en forma tal que se disminuyan las prestaciones que ellos y sus beneficiarios tuvieran derecho, implica la existencia de una intención de afectar las prestaciones médicas, los subsidios y las pensiones, situación que el Instituto debe acreditar ante el patrón. Corresponde al Instituto acreditar la intención del patrón; no basta señalar que el salario base de cotización es superior al que realmente percibe el asegurado, ya que puede tratarse de un error en los datos o de una discrepancia con el Instituto en los renglones integradores del salario, por la confusión que presenta la fracc. XVIII del art. 5 A de la Ley. Es indispensable que el Instituto demuestre que el patrón aseguró a su trabajador de forma tal, o con el propósito de, o bien buscando deliberadamente la disminución de las prestaciones a que los trabajadores o sus beneficiarios tuvieren derecho.

El Formato ST7, al ser llenado por el IMSS con los datos que brinda el trabajador, no es suficiente prueba de la existencia de una relación de trabajo o de un riesgo de trabajo, al ser un documento elaborado unilateralmente. La no afiliación del trabajador que sufrió el siniestro debe comprobarse por medio de otras probanzas, como la inspección, donde se asiente la irregularidad en que pudiera haber incurrido el patrón. Los elementos de prueba quedan a cargo del Instituto, cuando el obligado niegue la existencia de la relación laboral.

Elementos

Los elementos son los siguientes:

- La calificación médica del riesgo de trabajo.
- Fincamiento al inicio de la atención de los capitales constitutivos.
- La cuantificación fundada del importe de las prestaciones que en su caso hubiera otorgado el IMSS.
- El otorgamiento por parte del IMSS de prestaciones médicas y en dinero.
- La notificación legal al patrón del fincamiento de la estimación del capital constitutivo previo y del fincamiento posterior del capital constitutivo final, con respeto a su derecho de oponerse y ofrecer elementos de prueba.

Cada uno de los elementos puede ser motivo de impugnación, si no está fehaciente y exhaustivamente demostrado por el IMSS, en el momento de emitir las cédulas de liquidación, en los términos del art. 40 de la LSS.

Momento del fincamiento

El penúltimo párrafo del art. 79 de la LSS consigna:

De acuerdo a lo señalado en los párrafos anteriores, el Instituto al iniciar la atención del asegurado o, en su caso, del beneficiario, fincará y cobrará los capitales constitutivos, con independencia de que al concluir el tratamiento del asegurado o el beneficiario en su caso, pueda fincar nuevos capitales constitutivos por las prestaciones otorgadas que no hubiesen considerado en los créditos inicialmente emitidos.

Una interpretación estricta de la norma transcrita, como lo ordena el art. 9 de la Ley, debe hacerla el litigante y el juzgador; su aplicación preserva las garantías de legalidad y certeza jurídica, al obligar al organismo fiscal autónomo a dar a conocer al patrón, al inicio del otorgamiento de las prestaciones, que se le está imputando una responsabilidad derivada de que la autoridad considera que:

- a) Omitió inscribir a un trabajador.
- b) Lo hizo en forma extemporánea.
- c) La inscripción la hizo en forma tal que disminuyeron las prestaciones del derechohabiente.

Es suficiente que el patrón no sea notificado y requerido del cobro inicial de los capitales constitutivos o que al hacerlo omita señalar y acreditar la conducta omisa o lesiva del patrón, para que sea improcedente el cobro y no pueda justificarlas al término de la atención. El cobro inicial de las prestaciones no puede estimarse una facultad del Instituto, sino una obligación de que "al iniciar la atención", finque y cobre, lo que implica dar a conocer al patrón la causa; es decir, si se trata de un accidente o de una enfermedad; las circunstancias de tiempo, lugar y modo, donde se acrediten fehacientemente todos los elementos que tuvo en cuenta la autoridad que le permitan la acción impositiva y prevenga al obligado, en términos de Ley, a efectuar el pago. Con esta disposición se elimina la posibilidad, generalmente llevada a cabo y aceptada, de fincar y cobrar los capitales constitutivos al concluir el tratamiento, puesto que tal acción es violatoria del precepto señalado, sin que sea suficiente que la autoridad arguya que se trata de créditos que no fueron "considerados en los créditos inicialmente emitidos", ya que la Ley marca con precisión los dos momentos: "al iniciar la atención del asegurado" en que "fincará y cobrará los capitales constitutivos" y "al concluir el tratamiento" donde sólo puede fincar aquellos nuevos capitales constitutivos por las prestaciones otorgadas "que no hubiesen considerado en los créditos inicialmente emitidos".

Debe estimarse que la Ley ordena que los capitales constitutivos se finquen en el momento de iniciar la atención médica del derechohabiente, para que el patrón pueda tener conocimiento de la causa y las circunstancias que los hayan determinado. Cuando el Instituto notifique y requiera el pago, el patrón tiene oportunidad de demostrar que la persona accidentada o enferma le es ajena o no tiene derecho de interponer los medios de defensa que la Ley dispone (arts. 294 y 295), para oponerse a esa resolución fiscal (art. 287) que tiene el carácter de definitiva. ¿Podrá considerarse posible que la autoridad fiscal estime por anticipado el valor de prestaciones futuras?

Otorgamiento de las prestaciones

Es conveniente distinguir dos aspectos que no pueden condicionarse: el momento de cobro del capital constitutivo y la obligación del Instituto de otorgar al accidentado o enfermo las prestaciones médicas y en dinero. Las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa han rechazado el condicionamiento del Instituto de repetir el cobro de las prestaciones cuando no se acredite la relación laboral, en contra de la persona receptora de los servicios. La parte final del primer párrafo del art. 77 ordena: "sin perjuicio de que el Instituto otorgue desde luego las prestaciones a que haya lugar".

Integración

El art. 79 de la LSS establece limitativamente las 11 prestaciones que debe otorgar el Instituto para que al inicio de la atención pueda fincar los capitales constitutivos. Por ser créditos fiscales cada prestación debe ser específica, precisa y debidamente fundada:

- I. Asistencia médica;
- II. Hospitalización;
- III. Medicamentos y material de curación;
- IV. Servicios auxiliares de diagnóstico y de tratamiento;
- V. Intervenciones quirúrgicas;
- VI. Aparatos de prótesis y ortopedia;
- VII. Gastos de traslado del trabajador accidentado y pago de viáticos en su caso;
- VIII. Subsidios;
- IX. En su caso, gastos de funeral;
- X. Indemnizaciones globales en sustitución de la pensión, en los términos del último párrafo de la fracción III del artículo 58 de esta ley;
- XI. Valor actual de la pensión, que es la cantidad calculada a la fecha del siniestro y que, invertida a una tasa anual de interés compuesto del cinco por ciento, sea suficiente para que el beneficiario disfrute la pensión durante el tiempo a que

tenga derecho a ella, en la cuantía y condiciones aplicables que determina esta Ley, tomando en cuenta las probabilidades de reactividad, de muerte y de reintegro al trabajo, así como la edad y sexo del pensionado, y

se adicionan la suma del valor que se dé por el Instituto a los montos que resulten de los conceptos anteriores, con lo dispuesto por la fracción última de este numeral:

XII. El cinco por ciento del importe de los conceptos que lo integren, por gastos de administración.

Como puede verse, después del análisis llevado a cabo a las disposiciones relativas, un aspecto trascendente que no se toca en la Ley son los montos. Desde luego, es comprensible que los costos de las prestaciones médicas no puedan determinarse en una ley, pero la mención a los mismos, por el carácter fiscal que le da el art. 287, puede dejarse a una norma reglamentaria, como lo señala la última parte del art. 77: "El Instituto determinará el monto de los capitales constitutivos y los hará efectivos, en la forma y términos previstos en esta ley y sus reglamentos", pero no puede quedar al arbitrio de la autoridad fiscal.

Al respecto es conveniente invocar la sentencia que el 7 de enero de 1981 emitió el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, aún referida a la Ley de 1973, y que resulta aplicable a los supuestos de la Ley actual.

El IMSS al fincar un adeudo por concepto de capital constitutivo, debe motivarlo y fundarlo, esto es, señalar la fecha en que ocurrió el accidente, dar a conocer las partidas, y como se fija el monto de las mismas, es decir; que se deben especificar los subsidios pagados y servicios que prestó el Instituto, así como el monto de dichas partidas cuyo reembolso se exige, además de que para fundar el cobro del capital constitutivo no basta que se cite el artículo 96 de la *Ley del Seguro Social*, que señala la obligación del patrón de responder de la responsabilidad derivada de un accidente, sino que es menester que cada renglón individual del cobro que constituye el capital constitutivo encuentre su monto preciso justificado en un precepto legal; es decir, que no basta citar preceptos sino que se debe justificar la cuantificación precisa y exacta de cada renglón del cobro, del calculo actuarial, de la duración de la pensión, pues de lo contrario sería ilegal dejar al arbitrio del Instituto Mexicano del Seguro Social el determinar el costo que fija a sus servicios médicos en forma global sin detallarlos en el texto mismo en que se finca el capital constitutivo. (Juicio 8253178. Sentencia del 7 de enero de 1981, por unanimidad de votos. Magistrada instructora: Silvia Eugenia Díaz Vega. Secretaria: Lic. Ma. Sofía Sepulveda Carmona)

Tanto la fundamentación como la motivación deben estar debidamente satisfechas por el Instituto, en cumplimiento al mandado de los arts. 16 constitucional y 38 del *Código Fiscal de la Federación* (CFF). De esta manera al tratarse de una contribución, por su naturaleza fiscal, cada una de las prestaciones estimadas al iniciar la atención del derechohabientes debe estar cuantificada en un ordenamiento legal, previamente conocido por el sujeto obligado; además de exponer las circunstancias especiales que acrediten de manera fehaciente si se trata de una omisión en la inscripción o de un salario inferior al real. La cédula de liquidación debe estar debidamente motivada para no dejar en estado de indefensión al presunto infractor de la norma. Si la resolución no señala con claridad las circunstancias especiales, razones particulares, datos y antecedentes, así como los motivos que se tuvieron en cuenta para determinarla, carecería de fundamentación y motivación. En esta forma se ha determinado en los juicios fiscales siguientes:

La determinación por parte del IMSS de capitales constitutivos a cargo de un patrón, debe motivarse cuidadosamente en cuanto a su monto, de tal manera que si por ejemplo se especifican rigurosamente las cantidades que correspondieron a asistencia medicoquirúrgica y farmacéutica, distinguiéndose la que correspondió a atención médica, días de hospitalización, medicinas y materiales de curación, si se da la fundamentación requerida, lo que no acontecería cuando por ejemplo tratándose de gastos administrativos, sólo se alude vagamente a erogaciones por "investigación, traslados, papelería, cálculos", pero sin indicar minuciosamente lo que correspondió a cada renglón. (Juicio 162/73/3094/72. Resolución del 6 de julio de 1979)

No está debidamente motivado el acuerdo por el que se determinan las cantidades que integran el capital constitutivo, si en éste no se señalan con claridad las circunstancias especiales, razones particulares, datos y antecedentes así como los motivos que se tuvieron en cuenta para determinarlo. (Juicio 611/77/6 986/76. Resolución del 11 de julio de 1979)

El causante obligado, generalmente el patrón, debe conocer cada uno de los elementos que tuvo en cuenta la autoridad fiscal para determinar los diversos rubros que integran el capital constitutivo fincado en su contra a que se refiere el art. 79 de la Ley, además de tener a su alcance el sistema que el Instituto hubiera utilizado para calcularlos, así como el origen y destino de los mismos. En esta forma se resolvió el juicio fiscal siguiente:

El IMSS no sólo debe dar a conocer a los particulares los elementos necesarios para la determinación de los capitales constitutivos a que se refiere el artículo 48 de la Ley de la materia, sino que también debe señalar el sistema que utiliza para

calcular los gastos administrativos insertos en aquel crédito, así como el origen y destino de los mismos; de lo contrario se deja en estado de indefensión a los patrones afectados. (Juicio 44/73/2955/72. Resolución del 28 de junio de 1973)

El avanzado criterio del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se ha robustecido con las disposiciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que el capital constitutivo es un crédito fiscal, conforme al art. 287 de la LSS. Por tanto, todos los elementos del cobro deben estar determinados en una ley de manera que no queden los elementos de esa fijación al arbitrio de la autoridad exactora. Sería injusto e ilegal pensar que los capitales constitutivos pueden cobrarse como impuestos en la vía economicocoactiva y que pueden determinarse de manera arbitraria por el Instituto, sin fundar precisa y nítidamente en una ley el cobro de cada renglón del cobro. Sería inconstitucional estimar que el Instituto puede, mediante resoluciones interiores, determinar arbitrariamente el monto de lo que debe o puede cobrarse en forma concreta e individual, respecto de cada uno de los renglones en que se hace constar un capital constitutivo. En esta forma lo ha determinado la Suprema Corte de Justicia:

Para fundar el cobro de un capital constitutivo en la vía económico coactiva, sin acudir previamente a los tribunales como lo ordena el artículo 14 constitucional, ello sólo puede hacerse *equiparando* el crédito a los créditos fiscales, y éstos, conforme al artículo 31, fracción IV, de la Constitución, sólo pueden estar fincados constitucionalmente cuando todos los elementos del cobro están determinados en una Ley, de manera que no quedan los elementos de esa fijación al arbitrio de la autoridad exactora. Sería injusto e ilegal pensar que los capitales constitutivos pueden cobrarse como impuestos en la vía económico-coactiva sin acudir a los tribunales, y aceptar, al mismo tiempo, que el monto de esos capitales se pueden determinar arbitrariamente por el Instituto, sin fundar precisa y nítidamente en una Ley el cobro de todos y cada uno de los renglones que integran un capital constitutivo. Por lo demás, el fundar el cobro de un capital constitutivo derivado de un accidente de trabajo, no basta para satisfacer la exigencia del artículo 16 constitucional, es necesario que se citen preceptos legales que en forma genérica definen lo que es un accidente de trabajo o la obligación del patrón de responder de la responsabilidad derivada de ese accidente, etc., sino que es menester que en cada renglón individual del cobro que constituye el capital constitutivo, encuentre su monto preciso justificado en un precepto legal. Pues sería inconstitucional estimar que el Instituto puede, mediante resoluciones interiores, determinar arbitrariamente el monto de lo que debe o puede cobrarse en forma concreta e individual, respecto de cada uno de los renglones en que se hace constar un capital constitutivo. O sea que no basta citar preceptos que hablan de prestar atención medica, o de pensiones, sino que hay que justificar con apoyo en la Ley, y no en una

determinación arbitraria de la autoridad, la cuantificación precisa y exacta de cada renglón del cobro, del cálculo actuarial, de la duración de la pensión, etc., pues de lo contrario sería inconstitucional dejar al arbitrio del Instituto el determinar el costo que fija a sus servicios médicos, o el cobro de dichos servicios en forma global, sin detallarlos, o el fijar a su albedrío la posible duración del otorgamiento de la pensión o el cobrar gastos no previstos en ninguna Ley, etc. (Amparo directo 871/80, Autoservicio La Quemazón, S.A. de C.V., 26 de octubre/81. Amparo directo 1/75. Promotora Constructora, S.A., 30 de julio 1975. Amparo en revisión 514175. Alfonso Hidalgo Jiménez, 4 de mayo/74. Amparo directo 477/76, Industria Mexicana de Reactores, S.A., 9 de agosto 1977. Amparo directo 451/78, Implax, S.A., 29 de agosto/79)

Es incuestionable, aunque se preste a discusión, que los capitales constitutivos, al ser créditos fiscales, tienen su origen en la fracc. XXIX del art. 123 A constitucional, sin que puedan derivar de la fracc. XIV de ese numeral, puesto que esta última fracción expresamente ordena que el patrón cubra una indemnización, en los términos consignados en la *Ley Federal del Trabajo* (LFT). Tampoco puede invocarse como fundamento la fracc. IV del art. 31 de la Constitución Federal. Al respecto invoco la siguiente tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

Los capitales constitutivos contenidos en el artículo 48 de la Ley referida no tienen su origen en la fracción VII del artículo 73 de la Constitución Federal, sino que su fundamento se encuentra en el artículo 123, fracciones XIV y XXIX de la propia Constitución; la primera se relaciona con deberes a cargo del patrón de indemnizar a sus trabajadores por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales; la segunda, a la obligación del Estado de establecer el régimen de seguridad social. En consecuencia, el pago de los capitales constitutivos no tiene ninguna relación con el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, que consigna la obligación de los mexicanos de contribuir a los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes y, por ello, no rigen para los citados capitales los principios en el contenidos de proporcionalidad y equidad, los cuales son exclusivos de las prestaciones fiscales, en cuyo concepto no se incluyen los capitales constitutivos. En efecto, las cuotas que se recaudan en concepto de los capitales no son para que el Estado cubra los gastos públicos, sino que directamente pertenecen a los trabajadores o a sus beneficiarios. (Amparo en revisión 5976/69, Anderson Clayton y Co. S.S., 11 de enero de 1972, unanimidad de 17 votos. Amparo en revisión 8112/68, Empresas Longoria, S.A., 23 de enero de 1972, unanimidad de 15 votos. Amparo en revisión 2679/70, Triturados y Concretos, S.A., 23 de febrero/72, unanimidad de 15 votos. Amparo en revisión Grancor Internacional, S.A., 23 de febrero/72, unanimidad de 15 votos. Amparo en revisión 3490/71, Sociedad Kyle de México, S.A., 23 de febrero/72, unanimidad de 15 votos. Informe del Presidente de la Suprema Corte de Justicia 1972, jurisprudencia del Pleno, pp. 265 y 266)

Una vez más afirmo que las cuotas obrero-patronales y los capitales constitutivos no tienen carácter de contribuciones porque no se apoyan en la fracc. IV del art. 31 de la Constitución, sino, como hemos visto, en la fracc. XXIX del art. 123 de la Carta Magna. La finalidad del establecimiento de las aportaciones al Seguro Social es distinta de la de los tributos; las primeras tienen un objetivo específico determinado en cada seguro, de manera que sólo se destinan a cubrir las prestaciones médicas y en dinero que en forma distinta se establecen, por lo que se trata de una verdadera contraprestación a favor de los trabajadores contra los riesgos y las eventualidades que pudieran suceder en el desempeño de sus labores; en cambio, los tributos tienen como objetivo contribuir a los gastos públicos de la Federación, de los estados o de los municipios. Esto no disminuye la obligatoriedad de cubrir las cuotas precisadas en la LSS y, cuando proceda, los capitales constitutivos, a quienes se les confiere el carácter fiscal, como una aseveración puramente práctica.

Las cuotas obrero-patronales que se pagan al Instituto Mexicano del Seguro Social no tienen carácter de contribuciones, porque no se apoyan en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución, sino en las fracciones XIV y XXIX del artículo 123 de la Carta Magna, y la finalidad del establecimiento de las primas es distinta a la de los tributos; pues, mientras las primeras tienen como objetivo una protección a favor de los trabajadores contra los riesgos y eventualidades que pudieran suceder en el desempeño de sus labores, los segundos tienen como objetivo contribuir a los gastos públicos de la Federación, de los estados o de los municipios, con independencia de que el artículo 267 de la Ley del Seguro Social establezca que el pago de las cuotas, los recargos y los capitales constitutivos tienen carácter fiscal, pues tal aseveración es, por una parte, puramente práctica, y por la otra, el término fiscal es genérico y puede aplicarse tanto a los impuestos como a cualquiera otra prestación o contraprestación a favor del Estado o de un organismo descentralizado que, por estar prevista en la ley como obligación a cargo de los particulares, puede ser exigida coactivamente, sin que ello signifique, por necesidad, que se trata de las contribuciones a que alude el artículo 31, fracción IV, constitucional. (Amparo en revisión 763788.- Prolimp, S.A.- 7 de julio de 1988.- Ponente: Fernández Doblado.- Secretaria: Olga Estrever Escamilla. Sostiene la misma tesis: Amparo en revisión 303/88.- Reckttand Colman de México, S.A. de C.V., 23 de agosto de 1988.- Ponente: Raúl Cuevas Mantecón.- Secretaria: Rosa María Temblador Vidrio.

NOTA: El mismo criterio ha sostenido en los asuntos de amparo en revisión 1308/87, Encajes Mexicanos, S.A.; amparo en revisión 5001/87, Mundo viviente S.A., y amparo en revisión 4774/87, Compañía Industrial de Orizaba, S.A. y Acabados Río Blanco.

Liberación al patrón

El art. 78 de la LSS dispone que el pago de los capitales constitutivos traerá como consecuencia liberar a los patrones del cumplimiento de las obligaciones que establece la LFT; disposición que no puede pasar por alto lo ordenado por la fracc. XIV del apartado A del art. 123 constitucional:

Los patrones que cubrieren los capitales constitutivos determinados por el Instituto, en los casos previstos por el artículo anterior, quedarán liberados, en los términos de esta ley, del cumplimiento de las obligaciones que sobre responsabilidad por riesgos de trabajo establece la Ley Federal del Trabajo, así como de enterar las cuotas que prescribe la presente ley, por el lapso anterior al siniestro, respecto al trabajador accidentado y al seguro de riesgos de trabajo; subsistiendo para todos los efectos legales la responsabilidad y sanciones que en su caso fijen la Ley y sus reglamentos.

Cuando el trabajador o su beneficiario reclaman las indemnizaciones que conforme a la LFT les corresponden, pueden reclamar, además, las prestaciones que determina la LSS, y en caso de ser procedente el Instituto tiene la facultad de exigir a los patrones el pago de capitales constitutivos. La indemnización laboral se apeg a lo dispuesto en la fracc. XIV del art. 123 A constitucional y el subsidio o la pensión están determinados en la fracc. XXIX de ese numeral, por lo que existe una obligación independiente y no se trata de un acto de liberación de la obligación patronal. Este aspecto que pudiera estar en discusión, parte de que en el primer caso se trata de una prestación laboral, independiente del crédito del Seguro Social, relacionado con el cumplimiento de la afiliación de los trabajadores por la empresa, dispuesto en la LSS.

Las indemnizaciones que se entregan a los deudos de trabajadores fallecidos con motivo de riesgos de trabajo ante las autoridades laborales, no liberan a las empresas el pago de capitales constitutivos, ya que la primera se trata de una prestación laboral que en este caso es independiente de lo dispuesto por el artículo 84 de la Ley del Seguro Social, toda vez que este último crédito tiene como hecho generador el cumplimiento en la afiliación de los trabajadores por la empresa y la indemnización se trata de una prestación laboral. (Juicio 862/77. Resolución del 25 de marzo de 1977)

Capital constitutivo en enfermedad y maternidad, e invalidez y vida

En cuanto a los capitales constitutivos, la Ley los condiciona a dos figuras jurídicas previas:

- a) La existencia de daños y perjuicios al trabajador asegurado o a sus beneficiarios.
- b) La subrogación legal en los derechos del trabajador.

No corresponde a la LSS determinar lo que debe entenderse por *daño* o *perjuicio*, figuras del Derecho Civil. Por la subrogación el Instituto queda obligado a demostrar al patrón su existencia legal, sin que pueda la autoridad fiscal determinarlos a su criterio; no hay que olvidar que estamos con figuras de aplicación estricta. Al respecto, si bien los arts. 88 y 149 establecen la responsabilidad del patrón por los daños y perjuicios que se causaren al trabajador o a sus familiares derechohabientes, cuando por falta de cumplimiento de la obligación de inscribirlo o de avisar su salario real o los cambios que sufriera éste, no pudieran otorgarse las prestaciones consignadas en el seguro de enfermedad y maternidad o de invalidez y vida, o cuando dichas prestaciones se vieran disminuidas en su cuantía, no exime al Instituto de la obligación legal de acreditar previamente en qué consistió el daño o cuál fue el perjuicio que hubiera resentido el asegurado o su beneficiario. El art. 88 se refiere al seguro de enfermedades y maternidad:

Artículo 88. El patrón es responsable de los daños y perjuicios que se causaren al asegurado, a sus familiares derechohabientes o al Instituto, cuando por incumplimiento de la obligación de inscribirlo o de avisar los salarios efectivos o los cambios de éstos, no pudieran otorgarse las prestaciones en especie o en dinero del seguro de enfermedad y maternidad, o bien cuando el subsidio a que tuvieran derecho se viera disminuido en su cuantía.

El Instituto, se subrogará en los derechos de los derechohabientes y concederá las prestaciones mencionadas en el párrafo anterior. En este caso, el patrón enterará al Instituto el importe de los capitales constitutivos. Dicho importe será deducible del monto de las cuotas obrero patronales omitidas hasta esa fecha que correspondan al seguro de enfermedades y maternidades, del trabajador de que se trate.

No procederá la determinación del capital constitutivo, cuando el Instituto otorgue a los derechohabientes las prestaciones en especie y en dinero a que tengan derecho, siempre y cuando los avisos de ingreso o alta de los trabajadores asegurados y los de modificaciones de su salario, hubiesen sido entregados al Instituto dentro de los plazos que señalan los artículos 15, fracción I y 34 de este Ley.

El art. 149 se refiere al seguro de invalidez y vida:

Artículo 149. El patrón es responsable de los daños y perjuicios que se causaren al trabajador o a sus familiares derechohabientes, cuando por falta de cumplimiento de la obligación de inscribirlo o de avisar su salario real o los cambios que sufriera éste, no pudieran otorgarse las prestaciones consignadas en este capítulo o bien dichas prestaciones se vieran disminuidas en su cuantía.

El Instituto se subrogará en sus derechos y le otorgará las prestaciones que le correspondan. En este caso, el patrón está obligado a enterar al Instituto los capitales constitutivos respectivos.

Las disposiciones del artículo 79 de esta Ley y demás relativas para la integración, determinación y cobro de los capitales constitutivos son aplicables al seguro de invalidez y vida.

Del primer párrafo de estos preceptos se desprende la responsabilidad del patrón por daños y perjuicios, como sujeto pasivo, ya que debe esperar la acción de la autoridad fiscal donde se acredite fehacientemente tanto la existencia y cuantificación del daño y del perjuicio, como la responsabilidad directa que se le atribuye. El IMSS debe acudir a la autoridad judicial civil federal competente, para demostrar, en los términos que establece el *Código Civil Federal* (CCF), el daño que consiste en la pérdida o el menoscabo del patrimonio del derechohabiente, así como el perjuicio, que es la privación de una ganancia lícita que correspondía al derechohabiente; o al Instituto en el seguro de enfermedad y maternidad, no así en el seguro de invalidez y vida:

Artículo 2108. Se entiende por daño la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación.

Artículo 2109. Se reputa perjuicio la privación de cualquiera ganancia lícita que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación.

Artículo 2110. Los daños y perjuicios deben ser consecuencia inmediata y directa de la falta de cumplimiento de la obligación, ya sea que se hayan causado o que necesariamente deban causarse.

Una vez determinado el daño y perjuicio en los términos de los preceptos transcritos, el Instituto debe acreditar la existencia de la figura de la subrogación, aun sin la intervención y el consentimiento del derechohabiente, en virtud del interés legítimo que la autoridad fiscal tiene tanto para el cumplimiento de la obligación por parte del patrón, como en el deber de otorgar las prestaciones en dinero y en especie. Esta obligación surge del segundo párrafo de los arts. 88 y 149, al determinar que el Instituto se subrogará en los derechos de los derechohabientes y concederá las prestaciones mencionadas. El daño o el perjuicio deben haber sido ocasionados en forma dolosa por el

patrón, ya que la no inscripción o la inscripción con un salario menor fueron llevadas a cabo a efecto de que disminuyeran las prestaciones que por Ley corresponden al derechohabiente. El pago que efectúe será deducible del monto de las cuotas obrero-patronales omitidas hasta esa fecha, como lo dispone el art. 88. La subrogación debe apegarse a lo establecido en el art. 2058 del CCF:

Artículo 2058. La subrogación se verifica por ministerio de la Ley y sin necesidad alguna de los interesados:

- I. Cuando el que es acreedor paga a otro acreedor preferente.
- II. Cuando el que paga tiene interés jurídico en el cumplimiento de la obligación.
- III. Cuando un heredero paga con sus bienes propios alguna deuda de la herencia.
- IV. Cuando el que adquiere un inmueble paga a un acreedor que tiene sobre él un crédito hipotecario anterior a la adquisición.

La complejidad de los problemas que se derivan de los capitales constitutivos, analizados en este apartado de manera somera, deben llevar al convencimiento de su readecuación en la Ley, desde la denominación correcta, para estimarla como el pago de las prestaciones otorgadas por el IMSS al trabajador asegurado y a sus beneficiarios, hasta la determinación de la naturaleza de las prestaciones, para no lesionar los principios de certeza, coherencia, comodidad, unidad y sencillez, que debe reunir toda norma fiscal.

Derechos del trabajador

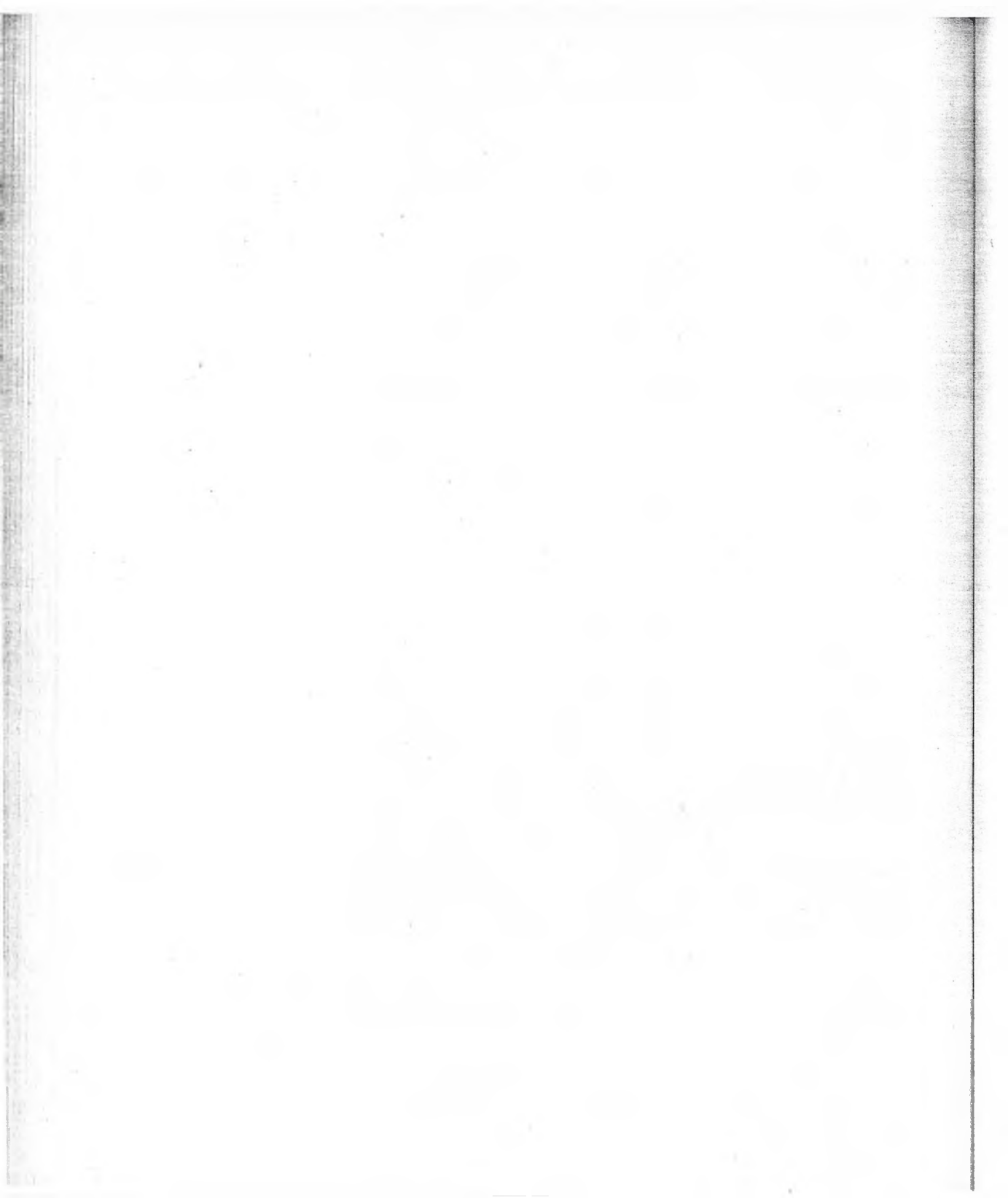
En todos los casos, el derechohabiente puede hacer valer varios medios de defensa, cuando existe negativa o negligencia de los servicios médicos por falta o demora en la atención. El Instituto tiene obligación de brindar sus servicios o responder ante la negligencia o culpa. Los procedimientos a favor del afectado no son excluyentes:

Queja. La LSS establece la posibilidad de acudir en vía de queja para responsabilizar al servicio médico y exigir el reembolso de los gastos que pueda haber efectuado por su cuenta, conforme al reglamento expedido.

Recurso de inconformidad. Los arts. 294 y 295 de la Ley permiten que pueda interponer un recurso de inconformidad ante el Consejo Consultivo Delegacional por la negativa demostrada de servicio o el silencio de la petición; para ello es necesario formular el recurso en términos del Reglamento de Inconformidad, en el plazo de 15 días hábiles.

Juicio laboral. Puede también y sin necesidad de agotar el recurso de inconformidad, acudir ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, en un plazo de 15 días hábiles, para demandar su atención o el reembolso de los gastos efectuados.

Demanda de amparo. En cualquier momento puede acudir a un Juez de Distrito, sólo si acredita que ha formulado la reclamación o queja ante el Instituto y no ha tenido respuesta, para lo cual debe haber transcurrido el plazo de tres meses, cuando menos, suponiendo una respuesta de negativa ficta.



12 Guarderías y prestaciones sociales

Guarderías

En un seguro carente de justificación se englobó desde las leyes anteriores a las guarderías, de gran relevancia en el Seguro Social; sin embargo, tiene más adecuación con la maternidad por ser una prestación que resulta de ésta; además, las prestaciones sociales son importantes pero ajenas a las guarderías, por tratarse del esfuerzo que ha llevado a cabo el Seguro Social por dar capacitación para el trabajo y esparcimiento. Este seguro protege a los hijos de las madres aseguradas, los viudos, divorciados o los que judicialmente conserven la custodia de sus hijos, mientras no contraigan nuevamente matrimonio o se unan en concubinato (art. 205, LSS), durante las horas de su jornada de trabajo, en la forma y los términos establecidos en la *Ley del Seguro Social* (LSS) y el reglamento relativo: *Reglamento para la Prestación de los Servicios de Guardería* (RPSG). Este derecho se genera a partir de que el trabajador sea dado de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) –art. 207–; cuando sea dado de baja en el régimen obligatorio, los hijos podrán continuar en las guarderías durante las cuatro semanas posteriores a dicha baja.

El objeto del seguro de guarderías contenido en el art. 201 de la LSS parte de dos supuestos:

1. Por una parte, reconoce la necesidad de que la madre y el padre soltero no puedan proporcionar el cuidado debido para la formación integral de los hijos menores; no se trata de tener un simple lugar de guarda, como puede hacerse con algún objeto, sino de una atención completa que permita al menor un desarrollo adecuado y a los padres la orientación necesaria, además de la confianza de dejarlo en manos calificadas durante las horas dedicadas al trabajo.

2. Por otra parte, se cubre el "otorgamiento de las prestaciones" del cuidado y la fortaleza de la salud del niño y su buen desarrollo futuro (art. 202, LSS), así como la formación de sentimientos de adhesión familiar y social, poniendo especial énfasis en la adquisición de conocimientos que promuevan la comprensión, el empleo de la razón y de la imaginación y la obtención de hábitos higiénicos y de sana convivencia y cooperación en el esfuerzo común con propósitos y metas comunes, todo ello de manera sencilla y acorde con su edad y con la realidad social y con absoluto respeto a los elementos formativos de estricta incumbencia familiar. Además se proporcionarán el aseo, la alimentación, el cuidado de la salud, la educación y la recreación de los menores a que se refiere el art. 201 de la LSS. Por lo anterior, es más adecuado denominar a este servicio como estancias para el bienestar y desarrollo infantil, como se hace en el *Reglamento del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado* (ISSSTE).

El seguro de guardería será proporcionado por el Instituto en los términos de las disposiciones que al efecto expida el Consejo Técnico, en los turnos matutino y vespertino, pudiendo tener acceso a alguno de estos turnos, el hijo del trabajador cuya jornada de labores sea nocturna, sin mayor limitación que solicitar los servicios. Con tal motivo el Instituto establecerá instalaciones especiales, por zonas convenientemente localizadas en relación con los centros de trabajo y de habitación, y en las localidades donde opere el régimen obligatorio (art. 204, LSS). Los servicios de guardería se proporcionarán a los menores desde la edad de 43 días hasta que cumplan cuatro años (art. 206, LSS).

No es posible que con el pretexto de la falta de recursos se dejen de otorgar las prestaciones mencionadas y menos aún que ésta se tome como un justificante para limitar la atención directa y alentar la subrogación a organismos o personas particulares que pueden carecer de la formación y/o del personal adecuados para los servicios que contrate. La guardería infantil no es una unidad médica para los menores, sino un servicio especial que comprende la guarda, la custodia, el aseo, la alimentación, el cuidado de la salud, la educación y la recreación de los hijos de los asegurados (art. 6º, RPSG). A los menores se les practicarán los exámenes que en la unidad médica institucional correspondiente se estimen necesarios (art. 8º, RPSG), sujetándose los mismos a las disposiciones y políticas que para el efecto señale el Instituto. Estos servicios se prestarán en las instalaciones de la guardería (art. 10, RPSG), con excepción de aquellas actividades que conforme al programa educativo sea necesario realizar fuera de la unidad, en cuyo supuesto deberá avisarse previamente al trabajador, quien podrá, en su caso, autorizar por escrito la salida del menor.

Sólo podrán recoger al menor el trabajador o la persona autorizada por éste dentro de los 60 minutos posteriores al cierre de la guardería; pasado ese

tiempo, cuando no haya aviso justificado, se considerará que ha sido abandonado, por lo que una vez agotadas las instancias de localización del trabajador o las personas autorizadas, se procederá, previa notificación de las autoridades de la guardería a los servicios jurídicos institucionales, a presentar al menor ante el Ministerio Público para iniciar el acta correspondiente. Es importante la responsabilidad contenida en el art. 13 del RPSG, en la que se encomienda a la dirección de la guardería tanto la vigilancia como el cumplimiento de las normas técnicas o administrativas que rijan la prestación del servicio de guardería.

Existe además un número importante de obligaciones que debe cumplir el trabajador, entre ellos, informar a la guardería los cambios en sus días de descanso, vacaciones, número telefónico, domicilio, ubicación de su centro de trabajo, horario de labores o cualquier otro dato relacionado con las personas autorizadas para recoger al menor. Asimismo, a más tardar al día siguiente, avisará al personal de la guardería los datos relacionados con el menor, que desde el punto de vista biológico, psíquico o social, considere necesario que el personal de la guardería deba tener conocimiento; informará al personal de la guardería las causas que hayan originado las lesiones físicas que presente el menor y que hubieren sido detectadas por el personal de la misma en su recepción o durante su estancia, según la gravedad de las lesiones, y en caso de que éstas se apreciaran reiteradamente en el cuerpo del menor, la dirección de la guardería tomará las medidas médicas, administrativas o legales que correspondan, solicitándose en este último caso el apoyo de los servicios jurídicos delegacionales (art. 20, RPSG). Cuando se deba administrar algún medicamento o alimento especial al menor durante su estancia en la guardería, entregará la receta médica correspondiente en el momento de presentar al menor en la guardería, misma que deberá tener fecha de expedición no mayor a siete días anteriores a su presentación, con el nombre, la matrícula o el número de cédula profesional y la firma del médico responsable. La administración del medicamento o alimento especial será siempre a solicitud del trabajador en la forma que señale la receta respectiva y de acuerdo con los horarios establecidos en la guardería. La falta de presentación de la receta médica para la administración de medicamentos o alimentos especiales al menor, será causa de su no admisión por ese día, así como cuando la receta prescriba la aplicación de inyecciones, gotas óticas u oftálmicas, las cuales tuvieran que administrarse al menor durante su estancia en la guardería (art. 21, RPSG).

El trabajador deberá acudir a la guardería cuando sea requerida su presencia por motivos de salud del menor, así como cuando se trate de trámites administrativos, y participará activamente en los programas educativos y de integración familiar del menor. En caso de inasistencia se deberá avisar con anticipación al personal de la guardería, especificando las causas que la motiven. En el supuesto de que se trate de inasistencia del menor por padecer una enfermedad infectocontagiosa, para ser readmitido se presentará la hoja de

valoración médica que le será proporcionada por el personal de la guardería, misma que deberá ser llenada por la unidad médica que le corresponda. Si la inasistencia del menor no se justifica por más de ocho días, para su readmisión deberá seguirse el trámite indicado.

Por su parte, el personal autorizado de la guardería informará al trabajador las indicaciones de tipo médico-preventivo que estará obligado a observar con el fin de que los menores sean sometidos a exámenes médicos, en la forma y en los plazos que establezca el Instituto. Dichos exámenes se realizarán en las unidades médicas institucionales que se les asignen o en la que estén adscritos (art. 17, RPSG). El trabajador o la persona autorizada informará diariamente al personal de la guardería el estado de salud del menor durante las últimas 12 horas; en caso de que se informe que durante este lapso el menor sufrió algún accidente o presentó alteraciones en su estado de salud, el trabajador o la persona autorizada deberá esperar el resultado del filtro sanitario que se haga para su aceptación o rechazo; en este último caso, se encargará de trasladar al menor a la unidad médica que le corresponda. El menor que durante su estancia en la guardería requiera atención médica de urgencia será trasladado de la guardería a la unidad médica correspondiente por el personal de la guardería, quien tiene la obligación de permanecer con el menor hasta que llegue el trabajador o las personas autorizadas, para lo que se informará al trabajador o las personas autorizadas la situación, a efecto de que se presenten en la unidad médica para conocer el estado de salud del menor y permanecer con él (art. 25, RPSG).

Los menores no llevarán algún objeto que les pueda causar daño a su persona o a la de los otros menores; asimismo, no podrán llevar alimentos, alhajas o juguetes; sólo se permite el acceso de estos últimos el día en que el programa educativo lo requiera (art. 18, RPSG).

Una gran discusión han motivado las guarderías particulares que han celebrado contrato de subrogación de servicios de guardería y reversión de cuota. La disposición en la LSS está en el art. 213, que permite a los patrones tener instaladas guarderías en sus empresas o establecimientos, siempre que reúnan los requisitos señalados en las disposiciones relativas; éstos dependerán de los convenios con el Consejo Técnico y la Dirección General, ya que no hay mención de ello en el RPSG.

Prestaciones sociales

Las prestaciones sociales han tenido reformas a partir de la primera Ley, por lo que se entiende que el IMSS haya construido y sostenga cines, centros deportivos, centros vacacionales, además de centros sociales y familiares. La LSS determina que comprenderán prestaciones sociales institucionales y de solidaridad social (art. 208). Las primeras tienen como finalidad fomentar

la salud, prevenir enfermedades y accidentes y contribuir a la elevación general de los niveles de vida de la población (art. 209); para ello, el Instituto proporcionará atención a sus derechohabientes mediante servicios y programas de prestaciones sociales que fortalezcan la medicina preventiva y el autocuidado de la salud y mejoren su economía e integridad familiar. Con ese fin, fortalecerá la coordinación y concertación con instituciones de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal o con entidades privadas y sociales que hagan posible el acceso de los trabajadores a preferencias, prerrogativas y servicios que contribuyan a su bienestar.

El Instituto establecerá y desarrollará los programas y servicios para los derechohabientes en términos de la disponibilidad financiera de los recursos destinados a prestaciones sociales de este seguro, que consistirán en (art. 210) la promoción de la salud, difundiendo los conocimientos necesarios a través de cursos directos, conferencias y campañas de bienestar, cultura y deporte, y del uso de medios masivos de comunicación; la educación higiénica, materno infantil, sanitaria y de primeros auxilios; la prevención de enfermedades y accidentes; el mejoramiento de la calidad de vida a través de estrategias que aseguren costumbres y estilos de vida saludables, que propicien la equidad de género, desarrollen la creatividad y las potencialidades individuales, y fortalezcan la cohesión familiar y social; el impulso y desarrollo de actividades culturales y deportivas, recreativas y de cultura física y, en general, de todas aquellas tendientes a lograr una mejor ocupación del tiempo libre; la promoción de la regularización del estado civil; los cursos de adiestramiento técnico y de capacitación para el trabajo, a fin de propiciar la participación de la población en el mercado laboral, de lograr la superación del nivel de ingresos para los capacitados y contribuir a la satisfacción de las necesidades de la planta productiva —dichos cursos podrán ser susceptibles de validación oficial—; los centros vacacionales; la superación de la vida en el hogar, a través de un adecuado aprovechamiento de los recursos económicos, de mejores prácticas de convivencia, y el establecimiento y la administración de velatorios, así como de otros servicios similares.

Las instalaciones deportivas, sociales, culturales, recreativas y vacacionales están a disposición de toda la población, ya sea por sí o en cooperación con instituciones de los sectores público o social, con prioridad a los derechohabientes, estableciendo en todos los casos las cuotas de recuperación de costos correspondientes, a fin de generar recursos para apoyar el financiamiento de su operación y mantenimiento, y de colaborar con la sociedad en general en la promoción de ese tipo de actividades. El monto y destino de los recursos que se obtengan se informará al Congreso de la Unión y al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

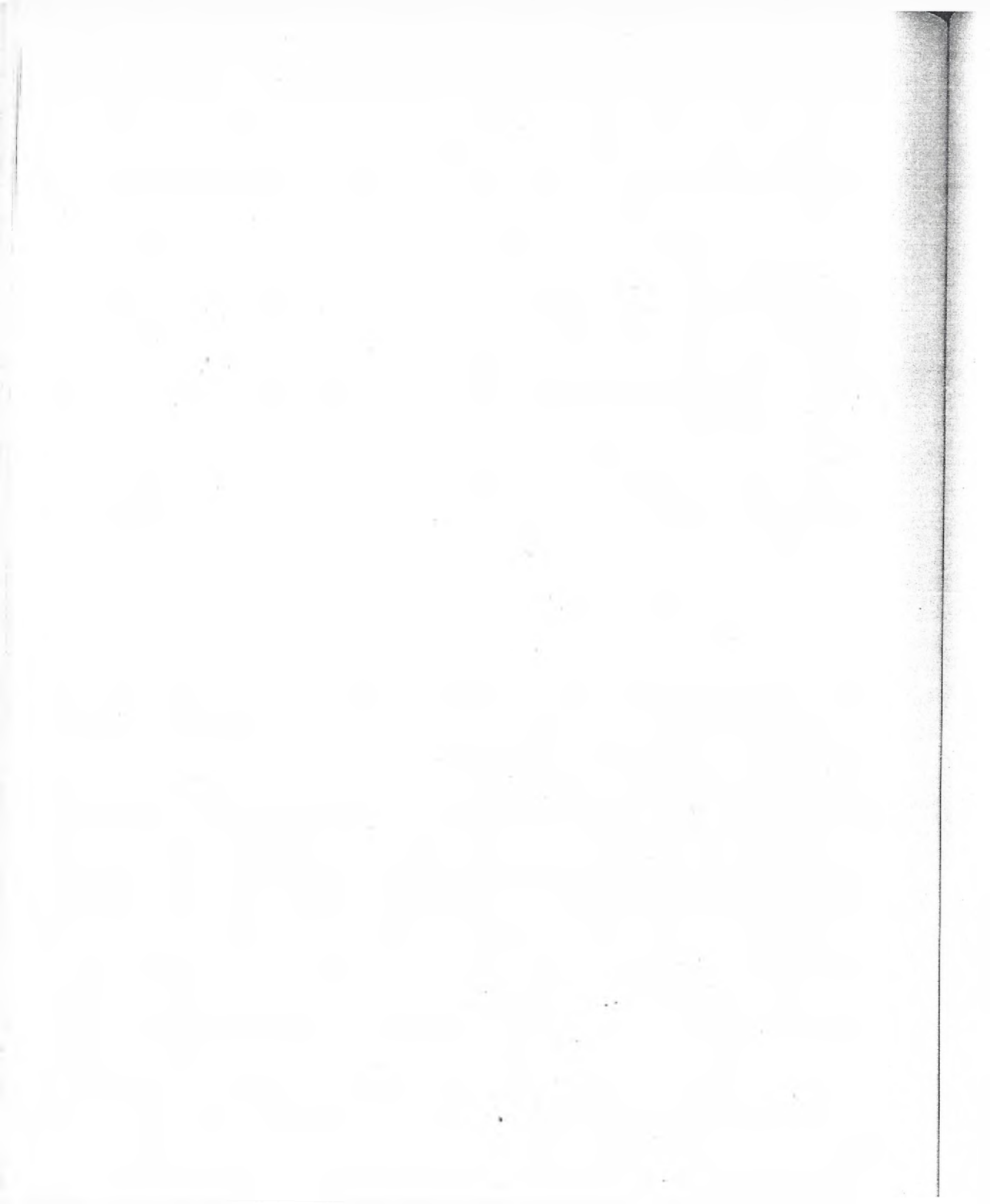
Régimen financiero

El costo de las prestaciones es muy elevado en relación con el monto de la prima para este seguro, sin que ello justifique el número de guarderías privadas, ajenas a la supervisión permanente que tienen las clínicas, los hospitales y los centros médicos que el Instituto proporciona directamente. La cuota que se aportará por este seguro es de 1% sobre el salario base de cotización; de esta cuota, 20% se destina a prestaciones sociales y 80% a las guarderías.

La prima para el financiamiento de las prestaciones de este capítulo la cubrirán los patrones, independientemente de si tienen a su servicio o no a trabajadores como los señalados en el art. 201.

Quinta parte

El derecho
mercantil regulador
del Seguro Social



13 Las sociedades mercantiles en el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez

Administración compartida

En los capítulos anteriores hemos visto la intervención de los organismos privados en las esferas antes reservadas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), organismo fiscal autónomo. La reforma llevada a cabo por el Congreso de la Unión, a iniciativa del presidente Carlos Salinas de Gortari, en 1992 a la *Ley del Seguro Social* (LSS), con la integración del seguro de retiro en el art. 11, fue el primer paso para permitir la incursión de los bancos, como sociedades anónimas, reguladas por el Derecho Mercantil, para administrar las aportaciones. El banco seleccionado por el patrón recibía 2% del salario del trabajador y sin cobrar comisión integraba la cuenta individual y transfería los recursos al Banco de México, para que éste los pusiera a disposición del Gobierno Federal en forma de crédito, a nombre del Instituto. Si bien esta primera reforma no permitió el cobro de las comisiones, limitando la administración de los fondos al cuarto día hábil bancario siguiente, se obtuvo una doble ventaja: por una parte, se familiarizó el término *cuentas individuales*, al hacer al trabajador partícipe de un recurso acumulado del cual podría parcialmente disponer en el supuesto de quedar desempleado; por otra, conformó la base para ampliar la participación de organismos privados, en la administración de las aportaciones. La regulación del seguro de retiro fue alejada de las estructuras del Instituto, con la creación de un comité técnico integrado con representación plural, bajo la égida del Secretario de Hacienda y Crédito Público.

El segundo paso llevado a cabo fue la reforma de 1993, donde se incorporan elementos ajenos a la seguridad social, a fin de dotar al IMSS, como organismo fiscal autónomo, de facultades adicionales de sanción; se crea la figura delictiva equiparable al fraude fiscal por la no inscripción de los trabajadores y la falta de pago de las cuotas. Esta reforma reafirmó la fama del

Instituto como un organismo opresor de los sujetos obligados y poco dotado para dar servicio eficiente a los derechohabientes.

El tercer paso fue la reforma de 1994; desapareció el comité técnico regulador del seguro de retiro, se sentaron las bases para la conformación de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), alejado definitivamente de las estructuras de gobierno del IMSS, confiando su constitución a la *Ley para la Coordinación de los Sistemas de Ahorro para el Retiro*. Esta reforma acentuó la división de la administración del IMSS; continuó el seguro de retiro acumulando fondos que, eventualmente, en más de 33%, carecerían de posibilidad de reclamación por la multiplicidad de cuentas y ausencia de los datos precisos del trabajador. En 2001, el Ejecutivo Federal solicitó de la Cámara de Diputados la autorización para disponer de 20 mil millones de esos fondos, con los cuales creó la Financiera Rural (11 mil).

En abril de 2005 se dio a conocer el Dictamen del IMSS, en el que se destaca la falta de reservas para hacer frente al pago de pensiones, lo que obligaba a buscar alternativas que atenuaran la situación financiera y dieran posibilidad de cubrir a largo plazo las pensiones. El andamiaje se había construido para facilitar la participación de las instituciones financieras privadas en el manejo e inversión de las aportaciones, consideradas contribuciones; faltaba el paso final.

El cuarto paso definitivo se dio con la LSS de 1995. El cambio afecta a cada uno de los seguros, así como a la administración del Instituto; establece que las pensiones sean pagadas por la aseguradora que determine el trabajador, previa celebración de dos contratos mercantiles, de renta vitalicia y de sobrevivencia; en el art. 175 se faculta a las administradoras de fondos de pensiones para que, en atención al derecho del trabajador, integren las cuentas individuales y reciban las aportaciones del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, cobren comisiones, así como que trasladen los fondos a las sociedades de inversión especializadas; en su momento efectuarán el pago de la suma asegurada a la aseguradora seleccionada por el trabajador.

La Consar, constituida en la reforma de 1994, recibe en la LSS nuevas facultades de control, regulación y supervisión de las pensiones; se conforman las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore), las Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro (Siefore) y las aseguradoras. Se otorgan facultades a la *Ley para la Coordinación de los Sistemas de Ahorro para el Retiro* (que perdió la palabra *Coordinación* y el plural). Este ordenamiento considera a las administradoras como entidades financieras, dedicadas a administrar las cuentas individuales y canalizar los recursos de las subcuentas que las integran en términos de la Ley, a la sociedad especializada de inversión. Las Afore, las Siefore, las empresas operadoras de la base de datos nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) y las aseguradoras son las nuevas figuras jurídicas, constituidas como sociedades anónimas de capital variable, reguladas por el Derecho Mercantil.

Es evidente que las reformas y las leyes expedidas son resultado de la oposición entre el Derecho Social y el Derecho Mercantil, pero lo más importante, las nuevas disposiciones contrarían las garantías consignadas en el art. 123 de la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos* (CPEUM) y sujetan al trabajador a contratos leoninos, donde lo único que puede esperar es la pérdida de las aportaciones, cuyo monto desconoce, porque apenas se hace referencia a él en los estados de cuenta que recibe de la Afore. Cuando pretende conocer su situación o interponer algún recurso, la confusión de las leyes le impide un fácil acceso. A pesar de la evidencia de las violaciones, sin modificar la Constitución para adecuarla al nuevo sistema, finalmente se estructuró el de capitalización individual, donde las financieras privadas participan en el Seguro Social. El trabajador asume la responsabilidad de fondear su pensión, corre los riesgos derivados del mercado de valores y libera al IMSS de la responsabilidad de contar con reservas para este fin.

En este sentido, la nueva legislación responde al ideario neoliberal, como escribe Asa Cristina Laurell:

Desde los años ochenta se ha dado un intenso debate sobre cómo concebir y organizar la política social en prácticamente todo el mundo. El renovado interés por esta temática nació de la reestructuración de las sociedades en la era de la globalización y bajo la influencia del ideario del proyecto político-ideológico neoliberal. La intensidad de la discusión y de las confrontaciones alrededor de la puesta en práctica de las nuevas políticas obedece al hecho de que incluyen un conjunto de derechos sociales, conquistados hace décadas, y que han sido consolidados progresivamente durante el período de posguerra. No resulta exagerado sostener que estamos presenciando no sólo una profunda ruptura de la compleja institucionalidad dirigida a generar beneficios y servicios sociales, sino, incluso, un intento de suprimir valores muy arraigados respecto a la justicia social y al derecho universal a la satisfacción de las necesidades humanas. En su lugar se está retrocediendo a una concepción decimonónica según la cual el bienestar es un asunto privado, responsabilidad de los individuos, por lo que la acción pública debe reducirse a programas mínimos y discrecionales para los pobres.¹

El trabajador, ajeno a la lucha ideológica y económica, no ha valorado la trascendencia de las reformas llevadas a cabo y como tampoco conoce detalles de la globalización económica, origen de estos cambios, manifiesta su inconformidad con las nuevas decisiones que son expresión de que:

Las fuerzas detrás del cambio económico global —que exaltan la desregulación, complacen a las corporaciones, socavan las estructuras sociales e ignoran las

1 En María Luisa Mussot L. (coord.), *Alternativas de reforma de la seguridad social*, Fundación Friedrich Ebert, México, 1996, pp. 52 y 53.

preocupaciones populares— no se pueden sostener. La globalización está dejando tras de sí una estabilidad peligrosa y una creciente desigualdad. Está dañando a demasiados y ayudando a muy pocos. Como lo planteó el mismo presidente Clinton, si el mercado global ha de sobrevivir, debe beneficiar a las familias trabajadoras. Un primer paso hacia esa meta consiste en incluir los derechos laborales, la protección ambiental y los criterios sociales dentro de los acuerdos comerciales y los protocolos de las instituciones financieras internacionales, y hacer cumplir estas medidas con el mismo vigor con el que actualmente se aplican los derechos de propiedad.

Ante la resistencia que encontró en distantes regiones,

... el Banco Mundial recomendó un modelo de aplicación universal que estaría apoyado en tres pilares: el primero, público, de asistencia, obligatorio, administrado por el Estado y financiado con impuestos; el segundo, privado, de ahorro obligatorio, administrado por el sector privado y prefinanciado en su totalidad, es decir, que las sumas destinadas al pago de pensiones se capitalizarían. En fin, el tercer pilar sería el ahorro voluntario, administrado por el sector privado e igualmente prefinanciado. De esta manera se cumpliría una función de ahorro para los individuos que tienen la capacidad de hacerse de ingresos adicionales para la jubilación.²

Así, pese a la creciente inconformidad, a los amparos interpuestos y a estudios científicos y jurídicos que acreditan la inviabilidad del sistema, éste se ha fortalecido en México con la expedición de la *Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado* (LISSSTE) en 2007 y las constantes reformas a la LSS y a la *Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro* (LSAR).

Las reformas nos ubican en un sistema mixto, donde sólo las aportaciones de pensiones por cesantía en edad avanzada y vejez son administradas por las sociedades mercantiles y las pensiones en todos los seguros son pagadas por las aseguradoras privadas. Al permitir esta intervención se ha lesionado el sistema tradicional de reparto y beneficio definido, administrado por una sola institución pública y sometido a las garantías del derecho del trabajo, para dar espacio al sistema de capitalización individual, lo que permite la regulación por el Derecho Mercantil, que no sólo reglamenta a las sociedades anónimas de capital variable, sino también el contrato celebrado entre el trabajador y la Afore, así como los contratos de renta vitalicia y sobrevivencia, celebrados por el derechohabiente con la aseguradora. Para el año 2008, el monto de las aportaciones entregado a estas sociedades anónimas de capital variable era superior al billón de pesos, con utilidades promedio anual de 100 000 millones de pesos.

2 Banco Mundial, *Informe de 2001*.

Por haber sido Chile el primer país en implantar el sistema y entregar recursos a las administradoras de fondos de pensiones, los distinguidos maestros de la Universidad de Chile, Eduardo Miranda Salas, economista, y Eduardo Rodríguez Silva, actuuario, escribieron: "... erróneamente los críticos del sistema anterior (de solidaridad) han sostenido que él constituía un régimen financiero de reparto, y que fue esta circunstancia la causa principal de que se generaran bajos niveles en los valores de las prestaciones y se registraran estados deficitarios en su funcionamiento institucional".

El elevado costo de los servicios privados no acredita beneficio alguno para los derechohabientes. Patrones y empresas asumen un costo que va de 70 a 100% de la cuota.

En la actualidad, aún sin tener en cuenta la parte financiada por el fisco, cada uno de nosotros paga los diversos seguros con que hemos envuelto nuestra existencia, mediante una deducción del orden del 35% de su propio salario. Cabe temer que, si tuviese que aumentar aún más este porcentaje, no aumentaría, sino que se reduciría, el beneficio neto del individuo.³

Toda la lucha ideológica se estrella frente al art. 123 constitucional y las garantías que consigna. La alternativa del legislador es modificar la Constitución o adecuar los ordenamientos legales a su imperio, al ser la única base donde se fundamenta el sistema de la seguridad social, más correctamente, de los seguros sociales. El precepto ordena que "Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley", con lo que las leyes expedidas para regular el sistema de pensiones, su control, administración, inversión, base de datos y pago, no responden a la organización social del trabajo y lesionan la dignidad y utilidad social de su producto: el salario. El precepto impone al Congreso de la Unión la obligación de no "contravenir a las bases siguientes" al expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán entre "los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo", con lo que impide la celebración de contratos de carácter mercantil, lesivos al contrato de trabajo.

En relación con la seguridad social:

- a) Limita la jornada de los menores de 16 años, con prohibición de que realicen labores insalubres o peligrosas, así como trabajo nocturno industrial y cualquier otro después de las 10 de la noche.

3 Valéry Giscard d'Estaing, *El poder y la vida*, vol. 1: "La reunión París: Compagnie 12", 1988, p. 147.

- b) Durante el embarazo las mujeres no pueden realizar trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación, además de contar con un descanso de seis semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y seis semanas posteriores al mismo, con salario íntegro.
- c) En un accidente del trabajo y la enfermedad profesional, los patronos deberán pagar la indemnización correspondiente (fracc. XIV), sin que se libere de esta obligación mediante la incorporación al IMSS.
- d) El patrón debe observar los preceptos legales sobre higiene y seguridad, así como adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las máquinas, los instrumentos y materiales de trabajo, garantizando la salud y la vida de los trabajadores.

Son condiciones nulas y no obligarán a los contrayentes (fracc. XXVII), aunque se expresen en el contrato, las que constituyan renuncia hecha por el obrero de las indemnizaciones a que tenga derecho por accidente del trabajo y enfermedades profesionales; además, todas aquellas estipulaciones que impliquen renuncia de algún derecho consagrado a favor del obrero en las leyes de protección y auxilio a los trabajadores.

En forma especial determina el sistema que regula al Seguro Social (fracc. XXIX) que, conforme a la Ley, comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y el bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares. El precepto constitucional no da espacio para la intervención de empresas privadas en la administración de alguno de los seguros, por lo que el Derecho Mercantil resulta ajeno a las garantías y disposiciones constitucionales.

Por lo que se refiere a las relaciones laborales entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores (Apartado B, fracc. XI), utiliza por primera vez el término seguridad social y ordena que se organice para cubrir los accidentes y las enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y maternidad, y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte. El precepto es más preciso para sentar las bases que dan vida al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), organismo encargado de la seguridad social, que se regula en su Ley.

En cuanto a los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes. El art. 123 constitucional faculta a las autoridades del orden federal, estatal, del Distrito Federal y municipal, que dicten los ordenamientos para propiciar el fortalecimiento del sistema de seguridad social del personal del Ministerio Público, de las corporaciones policiales y de los servicios periciales, de sus familias y dependientes.

La filosofía del precepto constitucional considera al Estado administrador de los recursos y único obligado a prestar los servicios. El art. 3 de la LSS limita la realización de la seguridad social a las entidades o dependencias públicas, federales o locales y de organismos descentralizados. El art. 5 dispone que la organización y administración del Seguro Social están a cargo del organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, de integración operativa tripartita, denominado Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual tiene también el carácter de organismo fiscal autónomo. Es evidente que no hay espacio constitucional o legal para las empresas privadas, por lo que su participación en la administración de los recursos atenta contra los principios de la seguridad social. En caso de estimarse conveniente, debe reformarse la Constitución con la adición de un numeral, donde se dé cabida a las figuras que se han conformado en las diversas leyes y reglamentos.

De las pensiones

Al inicio de este capítulo mencioné la polémica que había desatado el sistema de cuenta individual, tanto por dejar solo al trabajador para que mediante sus aportaciones y ahorros obtenga como pensión la cantidad que resulte al término de su carrera laboral, como por cuanto a que estos fondos son administrados por una empresa mercantil, constituida como sociedad anónima. Existe una opinión casi generalizada respecto del sistema, implantado en nuestro país desde 1997 (de aportaciones voluntarias), con antecedentes en 1992, en el sentido de que no ha dado los resultados propuestos y las ventajas de los trabajadores son menores a las estimadas con la Ley de 1973 (esquema de beneficio definido). En este sentido, el actuario Francisco Aguirre ha escrito recientemente:

Durante las últimas dos décadas ha habido una gran polémica sobre el tipo de pensiones que se debe aplicar. Algunos especialistas ven mayores ventajas en el esquema de beneficio definido, según el cual el trabajador conoce el monto de los beneficios a que tendrá derecho desde que ingresa a trabajar. Otros prefieren el esquema de contribución definida, en el que el trabajador solamente conoce el monto de las aportaciones, pero no el de los beneficios. Algunos más piensan que el esquema mixto es mejor pues, a su juicio, utiliza las ventajas de ambos esquemas, principalmente la solidaridad del primero, así como la transparencia y portabilidad del segundo. Esta polémica se justificó durante algunos años, pero ahora la discusión sobre los tipos de sistemas de pensiones solamente distrae la atención y retrasa el objetivo fundamental que es su reforma, para darle certidumbre y viabilidad social y financiera.

Con el otorgamiento de las pensiones de cesantía en edad avanzada y vejez, donde no se otorga en retiro, veremos la necesidad de estructurar sobre nuevas bases financieras una pensión universal digna que proteja a las personas que por su edad no puedan laborar, sin limitarlo al trabajo remunerado.

Es conveniente entender que la base para el otorgamiento de las pensiones se determina en las tasas de reemplazo, que se refiere "al porcentaje que representa el monto de la pensión respecto del último salario percibido por el trabajador a su retiro". La Consar, por su parte, entiende "el porcentaje que representa el monto de la pensión en relación con el salario promedio del trabajador, considerando toda su carrera laboral". Al trabajador le interesa el monto que pueda recibir de su pensión, referido al último salario percibido y no al promedio de los salarios obtenidos en 25 o 30 años laborados. De esta forma, con la aplicación de las tasas de reemplazo a la cuenta individual administrada por las Afore, en el momento de recibir la pensión el trabajador lo valora en cuanto a lo que recibía como último salario.

Con lo anterior se pone de manifiesto que los resultados previsibles apuntan hacia una necesaria revisión y eventual adecuación de la estructura del sistema, al igual que al establecimiento de un mecanismo de evaluación periódico, confiable y transparente a cargo de una institución que tome en cuenta, en forma equilibrada, los aspectos financieros y sociales que involucra.

El actual sistema ha demostrado ser inequitativo, no confiable y desequilibrado. El objetivo es que el trabajador acerque más la tasa de reemplazo al último salario y que las personas que reciben medio salario mínimo obtengan la cantidad adecuada para mantener una vida decorosa. Como hemos visto, el sistema se basa en las aportaciones estimadas sobre el salario de los trabajadores, sin posibilidad de alcanzar una revisión integral.

La LSS comprende en un mismo capítulo los seguros de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, para hacerlos coparticipes, en cuanto a las aportaciones del sistema de cuentas individuales. Las sucesivas reformas de 1992 a 1994 constituyeron la base para las reformas posteriores.

Artículo 152. Los riesgos protegidos por este capítulo son el retiro, la cesantía en edad avanzada y la vejez del asegurado, así como la muerte de los pensionados por este seguro, en los términos y con las modalidades previstas en esta Ley.

Seguro de retiro

El seguro de "retiro" fue constituido en la reforma a la LSS de 1992. En la misma fecha se modificaron y adicionaron la *Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores* y la *Ley del Impuesto Sobre la Renta*. La reforma inicia la ruptura del sistema tradicional de solidaridad, mantenido desde 1943 y la publicidad del "sistema de ahorro para el retiro".

En la reforma de 1992 se estructuró en el art. 11 el seguro de "retiro". Los patrones pagaban la cuota correspondiente al 2% sobre nómina (art. 183 A), en la institución de crédito de su elección (art. 183 C), para lo cual llevaban a cabo la apertura de la cuenta individual de cada trabajador. Las instituciones de crédito abrían las cuentas individuales (art. 183 H), actuando por cuenta y orden del IMSS. Las cuotas que recibían estas instituciones se trasladaban al Banco de México, en la cuenta que éste le llevaba al IMSS; el Banco invertía los recursos en créditos a cargo del Gobierno Federal (art. 183, fracc. I); los créditos causaban intereses a una tasa no inferior a 2% anual, pagaderos mensualmente por medio de su reinversión en las respectivas cuentas, sin tener derecho al cobro de una comisión.

El trabajador, al cumplir 65 años de edad o al ejercer su derecho al disfrute de alguna pensión del Seguro Social, tenía derecho a que la institución de crédito que llevara su cuenta le entregara los fondos de la subcuenta de retiro. En caso de incapacidad temporal del asegurado, con duración mayor a la consignada en la Ley (art. 183 P) o cuando quedara sin empleo (art. 183 Q, fracc. II), podía retirar 10% del saldo de su subcuenta de retiro, si no fuera por lapsos mayores a una vez cada cinco años. En caso de fallecimiento del trabajador, sus beneficiarios tendrían derecho a recibir el saldo de la subcuenta de retiro, cuando el titular hubiera designado por escrito a los mismos (art. 183 S).

La Ley vigente permite que los fondos acumulados en retiro, cesantía en edad avanzada y vejez se adicionen cuando el trabajador quede desempleado y pueda retirar un mínimo del monto acumulado (art. 191, fracc. II); para ello debe formular una solicitud por escrito. El cálculo se estimará entre la menor cantidad que resulte de la suma de 75 días de su salario base de cotización, manifestado en las últimas 250 semanas (cinco años) o 10% del saldo de la propia subcuenta. La solicitud se formula a partir del cuadragésimo sexto día natural contado desde el día en que quedó desempleado, y el monto sólo podrá tenerlo el trabajador cuando acredite con los estados de cuenta correspondientes no haber efectuado retiros durante los cinco años inmediatos anteriores a la fecha citada.

Artículo 191. Durante el tiempo en que el trabajador deje de estar sujeto a una relación laboral, tendrá derecho a:

- I. Realizar aportaciones a su cuenta individual, y
- II. Retirar de su subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez la cantidad que resulte menor entre setenta y cinco días de su propio salario base de cotización de las últimas doscientas cincuenta semanas o el diez por ciento del saldo de la propia subcuenta, a partir del cuadragésimo sexto día natural contado desde el día en que quedó desempleado.

El derecho consignado en esta fracción sólo podrán ejercerlo los trabajadores, que acrediten con los estados de cuenta correspondientes, no haber efectuado retiros durante los cinco años inmediatos anteriores a la fecha citada. El trabajador deberá presentar la solicitud correspondiente.

En un ejemplo, con un salario de 100 pesos diarios, la aportación a este seguro es de \$6.50 diarios, a la semana \$45.00, en las 250 semanas \$11 375.00; y 75 días \$487.50. El 10% del saldo de la propia subcuenta serían \$1 137.50, a partir del cuadragésimo sexto día natural contado desde el día en que quedó desempleado; como el derecho de retirar se refiere a la cantidad inferior, corresponderían \$487.50.

Seguros de cesantía en edad avanzada y vejez

Disposiciones comunes

El sistema de pensiones se estructuró en la primera Ley de 1943, en el seguro de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte (IVCM). En los primeros años el número de pensionados era muy bajo, por lo que los fondos se acumularon. El segundo Director General, Ignacio García Téllez, ordenó que se abrieran las clínicas en algunos edificios acondicionados, ya que las cuotas de riesgos de trabajo, de enfermedades y maternidad eran insuficientes para hacer frente al crecimiento de la población derechohabiente. La Ley ordenaba que las diferencias del importe de las cuotas del seguro de IVCM, así como los demás ingresos de dicho ramo, por un lado, y el pago de las prestaciones y demás egresos del mismo, se aplicaran a incrementar las reservas, en las mejores condiciones de seguridad, rendimiento y liquidez, mediante activos financieros. El producto obtenido de la inversión se destinaría exclusivamente para cubrir las pensiones, como se ha visto. Específicamente, las reservas del seguro de IVCM deberán invertirse en activos financieros y el producto que se obtenga de su inversión se destinará exclusivamente para cubrir las prestaciones del mencionado ramo del seguro. Estas claras disposiciones se encuentran contrariadas en la propia Ley, que ordena tomar como referencia la cuenta individual para calcular las pensiones en riesgos de trabajo e invalidez y vida.

Artículo 259. La inversión de las reservas debe hacerse en las mejores condiciones de seguridad, rendimiento y liquidez.

Artículo 260. Al concurrir similitud de circunstancias sobre seguridad y rendimiento, se preferirá la inversión que garantice mayor utilidad social.

Artículo 263. Los ingresos y egresos de cada uno de los ramos a que se refiere el artículo 11 de esta Ley, se registrarán contablemente por separado de los correspondientes a los demás ramos, en las cifras consolidadas. Los recursos citados sólo podrán utilizarse para cubrir las prestaciones y reservas que correspondan a cada uno de los respectivos ramos.

En todos los casos, las diferencias del importe de las cuotas del seguro de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte y demás ingresos de dicho ramo

por un lado, y el pago de las prestaciones y demás egresos del mismo, por el otro, se aplicará a incrementar la reserva respectiva en términos de este capítulo.

Artículo 264. Las reservas del seguro de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, deberán invertirse en activos financieros y el producto que se obtenga de su inversión se destinará exclusivamente para cubrir las prestaciones del mencionado ramo del seguro.

En abril de 1995 se presentó el diagnóstico del IMSS y en diciembre se aprobó la LSS, por el Congreso de la Unión. El reflejo inmediato se sintió en la modificación a las condiciones para el otorgamiento de pensiones de cesantía en edad avanzada y vejez. La Ley establece el mismo cálculo para estas pensiones; mantiene las edades de 60 y 65 años, la disposición e integración en una cuenta individual son las mismas. La Ley de 1973 fijaba a las pensiones un tiempo de espera de 500 semanas de cotización; la de cesantía en edad avanzada se estimaba como una pensión disminuida de vejez, donde se otorgaba un porcentaje que iba de 85 a 95%, según la edad, del cálculo de la pensión que podría corresponderle por vejez; el art. 171 establecía las bases para el cálculo de la pensión de cesantía en edad avanzada, siempre que se reunieran las 500 cotizaciones semanales; el porcentaje se modificaba cuando la edad excediera a los seis meses.

La Ley vigente distingue entre el seguro de cesantía en edad avanzada y el seguro de vejez sólo en cuanto a edad. Existe cesantía cuando el trabajador asegurado cuente con 60 años de edad, reúna 1 250 semanas de cotización, sea despedido de su trabajo o termine la relación laboral. El incremento de las semanas es desproporcionado en relación con las leyes anteriores; se justifica por la necesidad de integrar las reservas de pensiones; sin embargo, "las transformaciones del mercado de trabajo, la flexibilidad laboral y los contratos por obra determinada hacen cada vez más difícil cubrir el requisito de aportar durante 1 250 semanas para tener derecho a una pensión".

En el supuesto de no reunir las semanas de cotización, el trabajador puede optar por continuar voluntariamente en el régimen del seguro, pagando la cuota obrero-patronal o retirar el saldo de la cuenta individual en una sola exhibición, sin posibilidad posterior a recibir pensión. Si ha acumulado 750 semanas (15 años), tendrá derecho a recibir atención médica en el seguro de enfermedad y maternidad. Con la pensión, el asegurado tiene derecho a recibir las mismas prestaciones médicas que en vejez.

Artículo 154. Para los efectos de esta Ley existe cesantía en edad avanzada cuando el asegurado quede privado de trabajos remunerados a partir de los sesenta años de edad.

Para gozar de las prestaciones de este ramo se requiere que el asegurado tenga reconocidas ante el Instituto un mínimo de mil doscientas cincuenta cotizaciones semanales.

El trabajador cesante que tenga sesenta años o más y no reúna las semanas de cotización señaladas en el párrafo precedente, podrá retirar el saldo de su cuenta individual en una sola exhibición o seguir cotizando hasta cubrir las semanas necesarias para que opere su pensión.

En este caso, si el asegurado tiene cotizadas un mínimo de setecientas cincuenta semanas tendrá derecho a las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad, en los términos del capítulo IV de este Título.

Cesantía en edad avanzada

El art. 156 de la LSS establece que esta pensión puede hacerse valer desde el día en que el asegurado cumpla con ciertos requisitos, siempre que haya solicitado el otorgamiento de dicha pensión y comprobado haber quedado privado de trabajo, ya sea por rescisión justificada o no, así como por terminación voluntaria de las relaciones de trabajo; el acreditamiento de alguna de estas circunstancias queda a cargo del trabajador, si el patrón no presentó un aviso de baja al Instituto.

Artículo 156. El derecho al goce de la pensión de cesantía en edad avanzada comenzará desde el día en que el asegurado cumpla con los requisitos señalados en el artículo 154 de esta Ley, siempre que solicite el otorgamiento de dicha pensión y acredite haber quedado privado de trabajo, si no fue recibido en el Instituto el aviso de baja.

Cuando satisfagan los requisitos para la pensión se confiere a los asegurados ejercer alguno de dos derechos: por una parte, pueden contratar con la institución de seguros de su elección una renta vitalicia, que se actualizará anualmente en febrero conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, o mantener el saldo de su cuenta individual en una Afore y efectuar con cargo a éste retiros programados; por otra parte, mantener la cuenta individual y efectuar el pago de las cuotas. En esta última opción puede en cualquier momento contratar una renta vitalicia; en cambio, cuando se opte por la renta mensual vitalicia no podrá convenirse en una pensión si la renta es inferior a la pensión garantizada. Para ejercer alguno de estos dos derechos, el trabajador debe tener conocimiento del mercado de valores, de las posibilidades futuras de los movimientos financieros y de los posibles riesgos de su capital pensionario.

Artículo 157. Los asegurados que reúnan los requisitos establecidos en esta sección podrán disponer de su cuenta individual con el objeto de disfrutar de una pensión de cesantía en edad avanzada. Para tal propósito podrá optar por alguna de las alternativas siguientes:

1. Contratar con la institución de seguros de su elección una renta vitalicia, que se actualizará anualmente en el mes de febrero conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, y

II. Mantener el saldo de su cuenta individual en una Administradora de Fondos para el Retiro y efectuar con cargo a éste, retiros programados.

Ambos supuestos se sujetarán a lo establecido en esta Ley y de conformidad con las reglas de carácter general que expida la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.

El asegurado que opte por la alternativa prevista en la fracción II podrá, en cualquier momento, contratar una renta vitalicia de acuerdo a lo dispuesto en la fracción I. El asegurado no podrá optar por la alternativa señalada si la renta mensual vitalicia a convenirse fuera inferior a la pensión garantizada.

Al no establecer distinción entre este seguro y el de vejez, en cuanto al cálculo del monto de la pensión, resulta ocioso el art. 160, que limita la pensión de cesantía a reclamar la pensión de vejez cuando el asegurado cumpla 65 años. Debería establecerse una pensión superior y señalar el derecho a percibirla.

En el supuesto de que el trabajador quede en estado de invalidez, no tendría derecho a recibir la pensión por cesantía o vejez; sin embargo, conforme a la Ley, al tratarse de cuentas diferentes que se manejan contablemente por separado, el trabajador es propietario de la cuenta individual, por lo que puede reclamar el saldo acumulado en dicha cuenta cuando le sea otorgada la pensión de invalidez.

Artículo 160. El pensionado que se encuentre disfrutando de una pensión de cesantía en edad avanzada, no tendrá derecho a una posterior de vejez o de invalidez.

Conceptos

En este seguro se contienen las definiciones aplicables a las distintas pensiones, por lo que su ubicación debía ser en los conceptos generales: la cuenta individual, que se abre a cada asegurado en las Afore, ya sea que lo hagan directamente por medio de un contrato mercantil o lo lleve a cabo el IMSS, sin intervención del trabajador. En esta cuenta se depositan las cuotas obrero-patronales y estatal por concepto del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, así como los rendimientos. Se subdivide en las subcuentas: de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; de vivienda y de aportaciones voluntarias. Es evidente que la mención a la cuenta individual, en los seguros de riesgos de trabajo, invalidez y vida, no implica disposición de la suma acumulada.

Artículo 159. Para efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. Cuenta individual, aquella que se abrirá para cada asegurado en las Administradoras de Fondos para el Retiro, para que se depositen en la misma las cuotas obrero-patronales y estatal por concepto del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, así como los rendimientos. La cuenta individual se integrará por las subcuentas: de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; de vivienda y de aportaciones voluntarias.

Respecto de la subcuenta de vivienda las Administradoras de Fondos para el Retiro deberán hacer entrega de los recursos al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en los términos de su propia Ley.

II. Individualizar, el proceso mediante el cual se identifica la parte que se abona a las subcuentas correspondientes a cada trabajador de los pagos efectuados por el patrón y el estado, así como los rendimientos financieros que se generen.

III. Pensión, la renta vitalicia o el retiro programado.

IV. Renta vitalicia, el contrato por el cual la aseguradora a cambio de recibir los recursos acumulados en la cuenta individual se obliga a pagar periódicamente una pensión durante la vida del pensionado.

V. Retiros programados, la modalidad de obtener una pensión fraccionando el monto total de los recursos de la cuenta individual, para lo cual se tomará en cuenta la esperanza de vida de los pensionados, así como los rendimientos previsibles de los saldos.

VI. Seguro de sobrevivencia, aquél que se contrata por los pensionados, por riesgos de trabajo, por invalidez, por cesantía en edad avanzada o por vejez, con cargo a los recursos de la suma asegurada, adicionada a los recursos de la cuenta individual a favor de sus beneficiarios para otorgarles la pensión, ayudas asistenciales y demás prestaciones en dinero previstas en los respectivos seguros, mediante la renta que se les asignará después del fallecimiento del pensionado, hasta la extinción legal de las pensiones.

VII. Monto constitutivo es la cantidad de dinero que se requiere para contratar los seguros de renta vitalicia y de sobrevivencia con una institución de seguros.

VIII. Suma asegurada es la cantidad que resulta de restar al monto constitutivo el saldo de la cuenta individual del trabajador.

La renta vitalicia y el seguro de sobrevivencia que otorguen las instituciones de seguros, de acuerdo con lo previsto en los seguros de riesgos de trabajo, invalidez y vida y retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, se sujetarán a las reglas de carácter general que expida la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, oyendo previamente la opinión de la Consar.

Vejez

Los conceptos que se han propuesto para determinar la vejez de las personas han sido un fracaso frente a expectativas de vida cada vez más mayores, de manera que el cálculo que determina la Ley corresponde a una tradición iniciada en 1943, sin que pueda servir de base cuando los promedios de vida se determinan entre los 74 y 75 años. Sin embargo, las dificultades para una persona con más de 50 años son difíciles en un mercado de empleo donde se prefiere a los jóvenes por una energía y supuesta capacidad aprendida en las aulas, a la gran experiencia de los mayores. Los supuestos son falsos, ya que el mayor de 55 años puede fácilmente superar al joven. Deben aprovecharse los mayores

para enseñar a los menores y transmitirles el mayor valor que da la vida; debe existir una adecuada complementación.

Sin emitir un concepto de vejez, la Ley se limita a consignar prestaciones para quienes cuentan con una edad mínima de 65 años. El art. 162 condiciona el derecho a tener una pensión de vejez al asegurado que con esa edad tenga reconocidas por el IMSS un mínimo de 1 250 cotizaciones semanales.

Artículo 162. Para tener derecho al goce de las prestaciones del seguro de vejez, se requiere que el asegurado haya cumplido sesenta y cinco años de edad y tenga reconocidas por el Instituto un mínimo de mil doscientas cincuenta cotizaciones semanales.

En caso que el asegurado tenga sesenta y cinco años o más y no reúna las semanas de cotización señaladas en el párrafo precedente, podrá retirar el saldo de su cuenta individual en una sola exhibición o seguir cotizando hasta cubrir las semanas necesarias para que opere su pensión. Si el asegurado tiene cotizadas un mínimo de setecientas cincuenta semanas tendrá derecho a las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad, en los términos del capítulo IV de este Título.

En el primer caso, el trabajador pierde la posibilidad de obtener la pensión.

Artículo 164. Los asegurados que reúnan los requisitos establecidos en esta sección podrán disponer de su cuenta individual con el objeto de disfrutar de una pensión de vejez. Para tal propósito podrá optar por alguna de las alternativas siguientes:

- I. Contratar con una compañía de seguros pública, social o privada de su elección una renta vitalicia, que se actualizará anualmente en el mes de febrero conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, y
- II. Mantener el saldo de su cuenta individual en una Administradora de Fondos para el Retiro y efectuar con cargo a éste, retiros programados.

Ambos supuestos se sujetarán a lo establecido en esta Ley y de conformidad con las disposiciones administrativas que expida la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.

El asegurado que opte por la alternativa prevista en la fracción II podrá, en cualquier momento, contratar una renta vitalicia de acuerdo a lo dispuesto en la fracción I. El asegurado no podrá optar por la alternativa señalada si la renta mensual vitalicia a convenirse fuera inferior a la pensión garantizada.

En este seguro las prestaciones son similares a las de cesantía en edad avanzada, como lo precisa el art. 161: pensión, asistencia médica, asignaciones familiares y ayuda asistencial, previa solicitud del asegurado, y se le cubrirá a partir de la fecha en que haya dejado de trabajar, siempre que cumpla con los requisitos señalados en el art. 162. Asimismo, debe contratar con una compañía de seguros pública, social o privada de su elección, una renta vitalicia, que se actualizará anualmente en febrero conforme al Índice Nacional de Precios

al Consumidor, y mantener el saldo de su cuenta individual en una Afore y efectuar con cargo a éste, retiros programados.

El art. 158 de la LSS, como norma común para ambos seguros, determina que el trabajador, antes de cumplir las edades establecidas, puede pensionarse, cuando la pensión que se le calcule en el sistema de renta vitalicia sea superior en más de 30% de la pensión garantizada, una vez cubierta la prima del seguro de sobrevivencia para sus beneficiarios. En el supuesto de contar con el 30%, tendrá también derecho a recibir el excedente de los recursos acumulados en su cuenta individual en una o varias exhibiciones, una vez cubierta la prima del seguro de sobrevivencia para sus beneficiarios.

Régimen financiero

Corresponde a los patrones tanto retener la cuota de los trabajadores como efectuar su entero al IMSS. El art. 167 los responsabiliza con el Gobierno Federal, en la parte que les corresponde, de enterar al Instituto el importe de las cuotas. Esta disposición olvida el derecho de los trabajadores a determinar si optan por una cuenta individual, al ordenar que se depositen en la supuesta cuenta, para lo cual atenderá los términos previstos en la LSAR. En caso de que el trabajador no ejerza su derecho de opción, el Instituto es responsable del manejo de las cuotas, sin lesionar al trabajador.

Artículo 167. Los patrones y el Gobierno Federal, en la parte que les corresponde están obligados a enterar al Instituto el importe de las cuotas obrero patronales y la aportación estatal del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Dichas cuotas se recibirán y se depositarán en las respectivas subcuentas de la cuenta individual de cada trabajador, en los términos previstos en la Ley para la Coordinación de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

El art. 168 precisa en cuatro fracciones el importe de las cuotas: en la primera, señala la aportación del patrón en el seguro de retiro de 2% del salario base de cotización; en la segunda, la correspondiente a los patrones y trabajadores en los seguros de cesantía en edad avanzada y vejez; los patrones cubrirán 3.150% y los trabajadores 1.125%; la tercera y la cuarta, a las aportaciones del Gobierno Federal. Los patrones aportan 5.15% del salario base de cotización, los trabajadores 1.125%, lo que obliga al patrón a enterar 6.27% del salario base de cotización. El Gobierno Federal contribuye con 7.150% del total de las cuotas patronales, equivalente a 3.68%. Además, se consigna la cuota social a cargo del Gobierno en una cantidad inicial de 5.05% del salario mínimo general para el Distrito Federal, por cada día de salario cotizado, cuyo valor se actualizará trimestralmente conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, en marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año. Estos porcentajes, superiores al 10% del salario, se enteran al

Instituto, el cual los traslada a la Afore correspondiente para invertir las en la Siefore que el trabajador elija. Aquí empieza una complicación legal que nos va a conducir al estudio de las sociedades mercantiles, empresas legalmente facultadas para obtener utilidades, conforme a su naturaleza. En este caso, están autorizadas para lucrar con las cuotas pensionarias que por una parte son contribuciones (art. 2º, fracc. II, CFF) y por otra son propiedad del trabajador (art. 169, LSS), integrante del salario y, por tanto, no sujeto a pérdidas,

Artículo 168. Las cuotas y aportaciones a que se refiere el artículo anterior serán:

- I. En el ramo de retiro, a los patrones les corresponde cubrir el importe equivalente al dos por ciento del salario base de cotización del trabajador.
- II. En los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez, a los patrones y a los trabajadores les corresponde cubrir las cuotas del tres punto ciento cincuenta por ciento y uno punto ciento veinticinco por ciento sobre el salario base de cotización, respectivamente.
- III. En los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez la contribución del Estado será igual al siete punto ciento cuarenta y tres por ciento del total de las cuotas patronales de estos ramos, y
- IV. Además, el Gobierno Federal aportará mensualmente, por concepto de cuota social, una cantidad inicial equivalente al cinco punto cinco por ciento del salario mínimo general para el Distrito Federal, por cada día de salario cotizado, la que se depositará en la cuenta individual de cada trabajador asegurado. El valor del mencionado importe inicial de la cuota social, se actualizará trimestralmente de conformidad con el Índice Nacional de Precios al Consumidor, en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año.

Gasto público

El último párrafo del art. 168 contiene una disposición de especial trascendencia: "Estas cuotas y aportaciones al destinarse, en su caso, al otorgamiento de pensiones, se entenderán destinadas al gasto público, en materia de seguridad social." Al considerar el destino de las cuotas y aportaciones cuando tengan por objeto cubrir el pago de las pensiones como gasto público, incurre en un concepto delicado, tanto por su manejo legal como en cuanto a su aplicación práctica. El término *gasto público* tiene desde implicaciones constitucionales hasta consideraciones en leyes específicas. La fracc. IV del art. 31 de la CPEUM determina como obligación de los mexicanos contribuir a los gastos públicos, así de la Federación como del Estado y municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes, sin que se observe que el mismo pueda referirse a la "materia de seguridad social".

Las implicaciones que tiene el gasto público, conforme a la *Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público*, hasta la *Ley de Ingresos* y el Presupuesto de Egresos de la Federación, tiene características especiales. De esta

forma, la administración y disposición del gasto público, en cualquiera de sus formas, no puede dejarse al ámbito del organismo descentralizado, el IMSS, a un órgano desconcentrado, la Consar, y menos a entidades particulares, Afore, Siefore, aseguradoras, empresas operadoras de la base nacional de datos; sin embargo, tampoco puede considerarse propiedad de los trabajadores, como veremos a continuación. Además, se ocasiona un conflicto legal que no es simplemente doctrinario, puesto que al ser parte del salario, su disposición puede ser discrecional para el propietario con las modalidades que dicte la Ley, la cual no puede contrariar alguna disposición laboral.

En relación con esta disposición de la LSS, debemos analizar sus repercusiones. Los fondos depositados, parten así de dos supuestos:

1. Son propiedad de los trabajadores, aun cuando:
 - Sean administrados por el IMSS y las Afore.
 - Tengan limitaciones en su manejo, en cuanto a las modalidades legales.
2. Corresponden al gasto público y, en consecuencia:
 - Están afectos al art. 31, fracc. IV, de la CPEUM.
 - No pueden pertenecer al patrimonio de los trabajadores.
 - El Congreso de la Unión tiene injerencia en cuanto a su recepción (ingreso) y a su disposición (gasto).

Propiedad del trabajador

El art. 169 de la LSS consigna la propiedad del trabajador en relación con los fondos depositados en la cuenta individual, con lo que le permite disponer de esos recursos cuando reciban una pensión por riesgos de trabajo o por invalidez y vida, puesto que no existe en la Ley modalidad alguna que lo limite. Si bien la aportación es contribución para fines del pago y exigencia del cobro, en todo momento es parte del salario del trabajador y cuenta con los derechos y las garantías que le confiere la *Ley Federal del Trabajo* (LFT). Hay que cuidar que el “gasto público” no atente contra la supremacía que tiene la propiedad de los recursos depositados en la cuenta individual del trabajador, ni contra la protección de los ingresos del trabajador, consignadas en los arts. 98 a 116 de la LFT. La esencia del salario es la libre disposición que establece el primero de los preceptos mencionados, de tal suerte que “Cualquier disposición o medida que desvirtúe este derecho será nula”; es decir, las modalidades que establece la LSS no pueden contravenir sus disposiciones, además de que “Es nula la cesión de los salarios en favor del patrón o de terceras personas, cualquiera que sea la forma o denominación que se le dé” (art. 104), por lo que esto le resta valor a los contratos con las Afore e impide que lleven a cabo la administración e inversión, así como evita que los salarios (cuotas) puedan ser objeto de pérdidas. Ningún derecho público o privado, ni siquiera el del gasto público, puede estar por encima del que se consigna a favor de los trabajadores.

Asimismo, la cuenta individual parte del salario del trabajador, por lo que tiene las garantías consignadas en el art. 123 constitucional y la LFT; en consecuencia, es inembargable, no puede ser objeto de descuentos o retenciones y no podrá otorgarse como garantía. Al ser propiedad del trabajador no puede tener la naturaleza de contribución, como lo indica el art. 2º del *Código Fiscal de la Federación* (CFF); la naturaleza fiscal impide que pueda ser objeto de propiedad particular o de transacción alguna, ya que formaría parte del gasto público, consignado en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Estas contradicciones legales le restan seriedad a una figura tan importante como el monto de la cuenta individual, cuyo destino único es atender las disposiciones legales relativas a las pensiones que hemos visto con anterioridad.

Artículo 169. Los recursos depositados en la cuenta individual de cada trabajador son propiedad de éste con las modalidades que se establecen en esta Ley y demás disposiciones aplicables.

Estos recursos son inembargables y no podrán otorgarse como garantía. Lo anterior no será aplicable para los recursos depositados en la subcuenta de aportaciones voluntarias.

Cálculo de las pensiones

Cuenta individual

Después de analizar cada uno de los seguros es conveniente, para una adecuada orientación, señalar con precisión los supuestos y efectos a menudo relacionados con la cuenta individual, ya que es ésta la que en todos los casos se pretende tomar en cuenta para calcular el monto de las pensiones, tanto en este seguro de cesantía en edad avanzada y vejez, como en el de riesgo de trabajo e invalidez y vida. La oportunidad se presenta antes de pasar al siguiente capítulo, relativo a las diversas sociedades mercantiles que administran los fondos de la cuenta para el pago de las pensiones. La suma de las aportaciones enteradas a las administradoras, al 2009, asciende a más de un billón de pesos.

La naturaleza de la cuota, conforme la fracc. II del art. 2º del CFF, tiene el carácter de contribución. Parte de esa contribución (6.5% del s.b.c.), cuando se integra a las cuentas individuales, varía su naturaleza tanto al ser propiedad del trabajador como al estar administrada por sociedades anónimas de capital variable mediante un contrato mercantil; entonces la contribución se transforma en acciones mercantiles, cuya suerte dependerá del mercado de valores. La *Ley General de Sociedades Mercantiles*, la LSAR y las reglas de la Consar controlan estas operaciones, con lo que predomina el Derecho Mercantil, parte del Derecho Privado, sobre la teoría de las contribuciones fiscales de la cuota y la aplicación de los principios laborales que derivan de la Constitución.

El trabajador tiene a su favor derechos fundamentales para disponer de los fondos que bimestralmente entera su patrón al IMSS. Por desgracia, en general no cuenta con la orientación y los conocimientos adecuados para ejercerlos. La publicidad es engañosa e impide que el trabajador se entere de esos derechos, de sus consecuencias y de contar con los elementos que le permitan asegurar su futuro pensionario. Los jóvenes no piensan en el momento en que llegarán a viejos, y el viejo es por lo general indolente y conformista. El trabajador sufre el abuso de las grandes financieras internacionales, que se aprovechan de la suma ignorancia en la materia, de su notoria inexperiencia y obtienen un lucro legal excesivo, que es evidentemente desproporcionado. El trabajador, por su parte, tiene el derecho de reclamar la nulidad del contrato celebrado con la Afore y el pago de los correspondientes daños y perjuicios. El principio de derecho, consignado en el art. 17 del *Código Civil Federal* (CCF), en una interpretación correcta, implica que el término de un año corre a partir de que el trabajador tiene conocimiento de que se ha llevado a cabo una operación fraudulenta en su contra.

Artículo 17. Cuando alguno, explotando la suma ignorancia, notoria inexperiencia o extrema miseria de otro, obtiene un lucro excesivo que sea evidentemente desproporcionado a lo que él por su parte se obliga, el perjudicado tiene derecho a elegir entre pedir la nulidad del contrato o la reducción equitativa de su obligación, más el pago de los correspondientes daños y perjuicios.

El derecho concedido en este artículo dura un año.

En todo caso, el trabajador tendrá la propiedad de las cuotas que por retiro o cesantía en edad avanzada se enteren al Instituto, lo que implica el traslado de la cuota a su patrimonio, con todas las protecciones que se consigna en el art. 123 constitucional y en la LFT, entre otras, no ser embargables o poder otorgarse como garantía ni por el recaudador, el administrador, la sociedad inversora, la aseguradora o una autoridad judicial, fuera del marco de los preceptos laborales.

La LSAR, en su art. 74 reconoce el derecho de los trabajadores a tener una cuenta individual, en los términos de la LSS y seleccionar una administradora. Al abrir las cuentas, el IMSS les asignará una clave de identificación. Las cuentas se integrarán por las subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; de vivienda; aportaciones voluntarias y aportaciones complementarias de retiro. Las subcuentas se regirán por esta Ley; sin embargo, la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez se regulará por la LSS y la *Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores*.

En cualquier caso, ya sea que el trabajador ejerza o no su derecho, la cuenta individual tiene como único destino cubrir las pensiones de cesantía en edad avanzada y vejez, sin que se autorice tomar estos fondos para financiar las pensiones de otros seguros; la de riesgo de trabajo se cubrirá con los

recursos aportados por el patrón (art. 70); las de invalidez y vida, con las aportaciones tripartitas (art. 146). Está prohibido por el art. 277 E disponer de los recursos en la cuenta individual para financiar otras pensiones; hacerlo sería violar el precepto. Dicho artículo también estipula que los ingresos y gastos de cada seguro se registrarán contablemente por separado, sin perjuicio de lo dispuesto por la *Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal*, por lo que "sólo podrán utilizarse para cubrir las prestaciones y pago de beneficios y constitución reservas que correspondan a cada uno de ellos".

Artículo 277 E. Sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, los ingresos y gastos de cada seguro se registrarán contablemente por separado. Los gastos indirectos comunes se sujetarán a las reglas de carácter general para la distribución de costos, al catálogo de cuentas y al manual de contabilización y del ejercicio del gasto que al efecto emita el Consejo Técnico a propuesta del Director General, quien deberá contar con la opinión previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El catálogo de cuentas y el manual de contabilización y del ejercicio del gasto deberán tomar como base los equivalentes que al efecto se establezcan por las autoridades competentes para las entidades de la administración pública federal, adecuándolos a las características y necesidades del Instituto.

Los recursos de cada ramo de seguros a que se refiere esta Ley sólo podrán utilizarse para cubrir las prestaciones y pago de beneficios y constitución reservas que correspondan a cada uno de ellos.

Este sistema de cuentas individuales es "de inspiración neoliberal que se basa en la apertura de la economía y en la integración de los procesos de globalización, en el repliegue del Estado en su función de regulación, producción y redistribución relegando la dirección a los mecanismos del mercado, con lo cual se establecen nuevas reglas del juego".⁴ El sistema incrementa "la renuncia del Estado a su papel regulador predominante (que) abre a la negociación y (auto) regulación entre los actores 'civiles', las empresas y los sindicatos" y rompe el principio de solidaridad que es el régimen tradicional, el de reparto, para sustituirlo por el de capitalización individual; releva al gobierno de la responsabilidad constitucional de administrar los recursos y otorgar las prestaciones de servicio público, como lo determinan los arts. 3 y 5 de la Ley. El IMSS queda limitado a ser un organismo fiscalizador (arts. 261, fracc. XII, y 291) y a prestar servicios médicos en riesgos de trabajo, enfermedad y maternidad, invalidez y vida, guarderías y prestaciones sociales, salud para la familia y adicionales (art. 251, fracc. I). Con esta alteración cambian los métodos de cálculo, administración y forma de pago de las pensiones, que se condicionan

4 Balassa *et al.*, 1986, y Sunkel y Zuleta, 1990.

a la celebración de contratos mercantiles; se rompe el concepto tradicional de seguridad social colectiva para incorporarse al naciente modelo de economía de mercado, donde la capacidad del individuo para enfrentar los riesgos sociodemográficos depende, principalmente, de la generación de sus propios ingresos y del espíritu de ahorro y previsión para hacer frente al devenir.

El trabajador elige Afore

Cuando el trabajador determina contar con una cuenta individual tiene el derecho a seleccionar una Afore y que las cuotas obrero-patronales y estatal por concepto del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, así como los rendimientos, se depositen en su subcuenta; además, tiene la subcuenta de vivienda y otra con las aportaciones voluntarias que llegue a realizar. Las aportaciones de vivienda se entregan al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), sin que sean propiedad del trabajador.

La LSS consigna en el art. 174 el derecho del trabajador a contar con una cuenta individual:

Artículo 174. Para los efectos de este seguro, es derecho de todo trabajador asegurado contar con una cuenta individual, la que se integrará en los términos señalados en el artículo 159 fracción I de esta Ley.

Con esto deja al arbitrio del trabajador optar por la cuenta individual. Como resultado del ejercicio de este derecho, el art. 176 de la LSS consigna el derecho de elegir la administradora que mejor convenga a sus intereses y remite a la LSAR su instrumentación:

Artículo 176. El trabajador asegurado tendrá, en los términos de las leyes respectivas, el derecho de elegir la Administradora de Fondos para el Retiro que operará su cuenta individual.

La Ley para la Coordinación de los Sistemas de Ahorro para el Retiro determinará los mecanismos, procedimientos y términos aplicables a los recursos de las cuentas individuales de aquellos trabajadores que no elijan la Administradora de los Fondos para el Retiro que deba operar sus respectivas cuentas.

Como afirma Norahenid Amezcua: "La LSS y la LSAR, en sus artículos 176 y 174, respectivamente, señalan que es un derecho de los trabajadores elegir Afore. Derecho que en realidad se compone de dos opciones: elegir o no Afore, y además elegir la Afore de su preferencia." El Instituto, la autoridad administrativa y los juzgadores están obligados a respetar y preservar los derechos de los trabajadores.

El trabajador puede estimar conveniente tener sus fondos del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez en una cuenta individual o no ejer-

cer su derecho; en el último caso, las cuotas que se enteran al IMSS hacen a este organismo responsable de su custodia e inversión. El art. 167 de la LSS dispone que el Instituto deposite las cuotas de este seguro en las subcuentas de la cuenta individual de cada trabajador, en los términos previstos en la LSAR, sin que implique hacer a un lado la responsabilidad que tiene el Instituto para con el trabajador que no opte por la cuenta individual.

Artículo 167. Los patrones y el Gobierno Federal, en la parte que les corresponde están obligados a enterar al Instituto el importe de las cuotas obrero patronales y la aportación estatal del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Dichas cuotas se recibirán y se depositarán en las respectivas subcuentas de la cuenta individual de cada trabajador, en los términos previstos en la Ley para la Coordinación de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

Cuando el trabajador, con su expresión o sin ella, no señala que los fondos queden en una cuenta individual, el IMSS, como organismo fiscal receptor de los recursos, es el responsable de la guarda, custodia, inversión de los fondos y pago de la pensión; en atención al art. 75 de la LSAR, traslada el importe de la cuota tripartita a la cuenta concentradora que a nombre del Instituto abrirá el Banco de México. Los fondos se invertirán en valores o créditos a cargo del Gobierno Federal, "hasta en tanto se lleven a cabo los procesos de individualización", sin precisar en qué puedan consistir éstos.

Artículo 75. El Instituto Mexicano del Seguro Social tendrá abierta a su nombre en el Banco de México, una cuenta que se denominará concentradora, en la cual se podrán depositar los recursos correspondientes a las cuentas obrero patronales, contribuciones del Estado y cuota social del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, manteniéndose en dicha cuenta hasta en tanto se lleven a cabo los procesos de individualización necesarios para transferir dichos recursos a las administradoras elegidas por los trabajadores.

Los recursos depositados en la cuenta concentradora se invertirán en valores o créditos a cargo del Gobierno Federal, y otorgarán el rendimiento que determinará la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, misma que establecerá las demás características de esta cuenta.

El art. 76 advierte que esos recursos serán enviados a una administradora que indique la Junta de Gobierno de la Consar para su inversión en una Siefore. El trabajador, como puede observarse, es ajeno a este movimiento. En su momento legal puede reclamar del Instituto el pago de la pensión correspondiente.

Artículo 76. Las cuentas individuales de los trabajadores que no hayan elegido administradora, serán asignadas a las administradoras que hayan registrado un

mayor rendimiento neto, de conformidad con los criterios que para tales efectos determine la Junta de Gobierno.

Los trabajadores a los que se les designe administradora de conformidad con lo dispuesto en este artículo podrán traspasar sus recursos a otra administradora, en los términos previstos en el artículo 74.

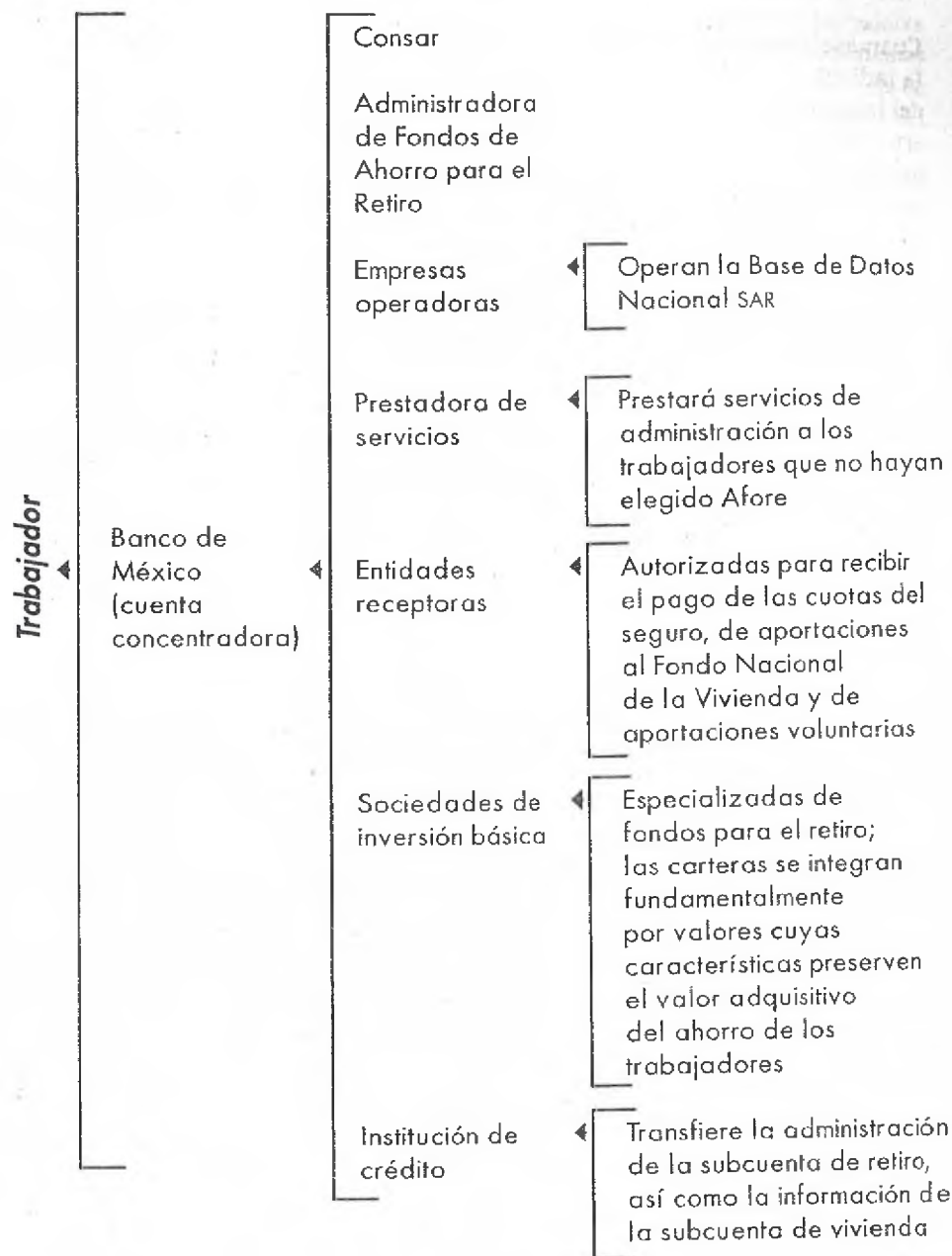
El artículo 7º transitorio de la LSAR de 2006 disponía que la cuenta concentradora estaría en operación únicamente cuatro años posteriores a la vigencia del ordenamiento; al término de este plazo, la Consar haría efectivo el derecho del art. 76 y efectuaría la elección de la Afore, para que los fondos acumulados en la cuenta concentradora se trasladaran.

El art. 29 del Reglamento de la LSAR, en una supuesta protección de los intereses de los trabajadores que no elijan administradora, resolvió el envío de los recursos a las Afore que cobren las comisiones más bajas. Si individualizan las cuentas, les dan la naturaleza de propiedad de los trabajadores, como lo ordena el art. 169 de la LSS. En atención al precepto, el Banco de México envió más de 10 millones de estas "cuentas". El numeral menciona que para brindar "seguridad jurídica al trabajador", respecto de la Afore a la que enviaron sus recursos, las empresas operadoras deberán tener disponible para consulta de las Afore y de la Consar una base de datos que contenga los nombres de los trabajadores, de conformidad con los criterios de la Junta de Gobierno de la Consar. Las Afore que reciban los recursos aplicarán las mismas condiciones de contratación y comisiones vigentes para las demás cuentas individuales, lo que implica una violación al derecho de los trabajadores que no eligieron Afore.

La intervención de la Consar cuando no existe manifestación expresa del trabajador implica, como afirma Norahenid Amezcua:

La amenaza se está cumpliendo. Todos aquellos trabajadores que no han optado por una Administradora de Fondos para el Retiro (Afore), por la fuerza serán enviados a una Afore. Nada de pensar, de conciencia, de rebeldía. No importa que se violente a la LSS y la del Sistema de Ahorro para el Retiro (LSAR), por tanto a la Constitución, y hasta a los principios del derecho. Son entre 2.5 a tres millones de asegurados, quienes disfrutaban de los beneficios de la cuenta concentradora (quizá más ante las deficiencias en la afiliación de las Afores). Pero su libertad es negada por normativas inferiores: el Reglamento de la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro (RLSAR) y la circular de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) 27-1. Es una masa gigantesca de dinero que las Afores no iban a permitir que quedaran libres de sus comisiones. Pero siendo tan exitosas y formidables las Afores, ¿por qué se tiene que usar la fuerza para que los trabajadores entren a ellas?

En el cuadro sinóptico siguiente se presenta la ruta de la cuota del trabajador cuando no selecciona Afore y cómo su administración se entrega a organismos privados:



Cuenta concentradora

Cuando el trabajador no ejerza el derecho de elegir la Afore que operará su cuenta individual, el IMSS enviará los recursos a la cuenta individual que a nombre del Instituto opera el Banco de México, como lo dispone el segundo párrafo del art. 176 de la LSS: "La Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro determinará los mecanismos, procedimientos y términos aplicables a los recursos de las cuentas individuales de aquellos trabajadores que no elijan la Administradora de Fondos para el Retiro que deba operar sus respectivas cuentas."

En cumplimiento a lo ordenado por la LSS, la LSAR en su art. 75 determina que los recursos de aquellos trabajadores que no elijan Afore sean trasladados por el IMSS a una cuenta concentradora que a nombre del Instituto abrirá el Banco de México, así como que los fondos de dicha cuenta se invertirán en valores o créditos a cargo del Gobierno Federal; situación que condiciona hasta en tanto se lleven a cabo los procesos de individualización, sin precisar en qué puedan consistir éstos. Por su parte, en el art. 76 se advierte que esos recursos serán enviados a una administradora que indique la Consar, en los términos de las disposiciones reglamentarias, para que sean invertidos por una Siefore.

El art. 7º transitorio de la LSAR completa el círculo, al disponer que la cuenta concentradora estará en operación únicamente cuatro años posteriores a la vigencia del ordenamiento. Al término de este plazo, la Consar hará efectivo el derecho que le confiere el art. 76 transcrito y, en sustitución a la voluntad del trabajador, efectuará la elección de la Afore para que los fondos acumulados en la cuenta concentradora sean trasladados por el IMSS a la Afore que la Consar determine. Los fondos causarán intereses a una tasa de 2% anual pagaderos mensualmente. En este precepto se establece un sistema completo de manejo y disposición de la cuenta individual que derive de la cuenta concentradora.

ARTÍCULO SÉPTIMO. Los recursos correspondientes a la subcuenta del seguro de retiro prevista en la Ley del Seguro Social vigente hasta el 31 de diciembre de 1996, así como los correspondientes a la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez prevista en la Ley del Seguro Social que entrará en vigor el día primero de enero de 1997, de los trabajadores que no hayan elegido administradora, se abonarán en la cuenta concentradora a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social prevista en la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, durante un plazo máximo de cuatro años contados a partir del día primero de enero de 1997. Transcurrido el plazo a que se refiere éste párrafo, la Comisión, considerando (*sic*) la eficiencia de las distintas administradoras, así como sus estados financieros, buscando (*sic*) el balance y equilibrio del sistema, dentro de los límites a la concentración del mercado establecidos por la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, señalará el destino de los recursos correspondientes a los trabajadores que no hayan elegido administradora.

Los recursos de los trabajadores que no hayan elegido administradora dentro del plazo a que se refiere el párrafo anterior, deberán ser colocados en sociedades de inversión cuya cartera se integre fundamentalmente por los valores a que se refiere el artículo 43, fracción II, inciso e) de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, así como por aquellos otros que a juicio de la Junta de Gobierno permitan alcanzar el objetivo de preservar el valor adquisitivo del ahorro de los trabajadores.

La cuenta concentradora será una cuenta abierta a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social que llevará el Banco de México, en la cual se depositarán las cuotas obrero patronales y las aportaciones del Gobierno Federal del seguro de retiro y del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, correspondientes a los trabajadores que no hayan elegido administradora.

Los recursos depositados en la cuenta concentradora se invertirán en valores o créditos a cargo del Gobierno Federal, y otorgarán un rendimiento que determinará la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, misma que establecerá las demás características de esta cuenta.

Durante el año de 1997, la cuenta concentradora causará intereses a una tasa de dos por ciento anual, pagaderos mensualmente mediante su reinversión en las cuentas individuales. El cálculo de estos intereses se hará sobre el saldo promedio diario mensual de las cuentas individuales, ajustado en una cantidad igual a la resultante de aplicar a dicho saldo, la variación porcentual del Índice Nacional de Precios al Consumidor publicado por el Banco de México, correspondiente al mes inmediato anterior al del ajuste.

El trabajador podrá solicitar información sobre sus recursos de conformidad con el Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

A propósito de la cuenta concentradora, el senador José Ángel Conchello Dávila envió un escrito al Gobernador del Banco de México para que le informara la manera y los términos en que se administraba la cuenta concentradora. En oficio del 21 de abril de 1997, Ref. MM/97C-90, suscrito por el Gobernador del Banco de México, dirigido al senador señala:

Me refiero a su atento escrito del 14 de abril de 1997, en el que, en relación con la copia del boletín de prensa de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro que a él adjunta, solicita se le informe si por llevar la cuenta denominada "Concentradora" del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Banco de México cobrará comisiones sim de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, [...] en la cuenta "concentradora" podrán depositarse los recursos correspondientes a las cuentas obrero patronales, contribuciones del Estado y cuota social del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, manteniéndose en ella hasta en tanto se lleven a cabo los procesos de individualización previstos en la propia Ley;

2) [sic] De acuerdo con lo señalado en artículo Séptimo transitorio de la mencionada ley, el Banco México, por cuenta del IMSS, debe invertir en valores o créditos a cargo del Gobierno Federal, la totalidad de los recursos depositados en la cuenta "concentradora", los cuales otorgarán el rendimiento que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la que también establecerá las demás características de dicha cuenta, y

3) El citado artículo transitorio prevé que los trabajadores podrán solicitar información sobre los recursos depositados en la aludida cuenta "concentradora", de conformidad con lo que señale el Reglamento de la Ley de los Sistemas del Ahorro para el Retiro.

A este respecto, el artículo Tercero transitorio de tal Reglamento, establece que la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) podrá autorizar a instituciones de crédito y administradoras de fondos para el retiro para que, entre otros, presten a los trabajadores que no se encuentren registrados en una de dichas administradoras, el servicio de emisión de estados de cuenta respecto de los recursos mencionados, siendo aquellas las facultadas para cobrar las comisiones que la CONSAR determine mediante disposiciones de carácter general.

Sin embargo, por determinación de la Consar, se autorizó a algunas Afore para que lleven a cabo la individualización de la cuenta e informen de su estado al trabajador, por lo que cobrarán una comisión.

Transferencia de cuentas individuales

Los trabajadores pueden determinar el cambio de Afore. La LSS en su art. 178 les confiere el derecho de cambiar de Afore una vez al año calendario, sin que se requiera existencia de causa alguna.

Artículo 178. El trabajador podrá, una vez en un año calendario contado a partir de la última ocasión que se ejercite este derecho, solicitar directamente a la Administradora de Fondos para el Retiro el traspaso de los recursos de su cuenta individual a otra Administradora.

Las Afore estarán obligadas a abrir la cuenta individual o a aceptar el traspaso de dicha cuenta, de aquellos trabajadores afiliados que cumpliendo con las disposiciones aplicables soliciten su apertura de cuenta. En ningún caso podrán hacer discriminación de trabajadores. El art. 74 de la LSAR establece, a su vez, que los trabajadores afiliados podrán solicitar a su administradora que se traspasen sus cuentas individuales que se hayan abierto conforme al régimen previsto en la LSS de 1973. Esta parte limita a los trabajadores que tengan una cuenta individual en términos de la Ley anterior, sin considerar que el patrón seleccionaba al banco; esta institución abría cuentas individuales a nombre del trabajador.

Debe recordarse que el derecho de traspaso lo determina la LSS, y la LSAR en el art. 74 sólo consigna los supuestos operativos. Se tendrá derecho a traspasar su cuenta individual de una administradora a otra una vez transcurrido un año, contado a partir de que el trabajador se registró o de la última ocasión en que haya ejercitado su derecho al traspaso. Podrá hacerlo antes del año, a una administradora cuyas sociedades de inversión hubieren registrado un mayor rendimiento neto, en el periodo de cálculo inmediato anterior, para lo cual la Junta de Gobierno determinará el mínimo de diferencia que debe haber entre los rendimientos netos observados para que se pueda ejercer el derecho de traspaso de una administradora a otra. Los trabajadores que ejerzan este derecho que haya registrado un rendimiento neto mayor, deberán permanecer al menos 12 meses en la última administradora elegida.

Sin embargo, la Junta de Gobierno de la Comisión, atendiendo a las circunstancias del mercado, la competencia entre Afore y otros factores que permitan propiciar las mejores condiciones de competitividad en beneficio de los trabajadores, podrá establecer un plazo menor al del año para que éstos ejerzan su derecho al traspaso. También se podrá traspasar la cuenta cuando se modifique el régimen de inversión o de comisiones, la Afore entre en estado de disolución o se fusione con otra Afore. En caso de fusión, el derecho de traspaso sólo corresponderá a los trabajadores afiliados que se encuentren registrados en la administradora fusionada. Estas situaciones salen de la esfera de conocimiento del trabajador.

Cada Afore cuenta con cinco Siefore y dispone el envío de los recursos conforme a su criterio, sin tomar en cuenta el parecer de los trabajadores, por lo que es otro absurdo suponer que tenga el conocimiento para determinar, como lo pretende el precepto, que sus recursos sean invertidos en otra Siefore, operada por la misma Afore. Este derecho podrá ser ejercitado en cualquier tiempo, siempre que reúnan los requisitos para invertir en dicha sociedad de inversión.

Las limitaciones al trabajador para efectuar el traspaso de su cuenta a otra Afore o a una Siefore obligan a la Afore que lleva la cuenta a cumplir con la voluntad expresada, por lo que será responsable de efectuar los trámites para el traspaso de cuentas individuales.

Independiente de la obligación del envío, los trabajadores podrán solicitar en cualquier tiempo a la Afore, en las oficinas de ésta, sus estados de cuenta.

Las aportaciones complementarias de retiro sólo podrán retirarse cuando el trabajador tenga derecho a disponer de las aportaciones obligatorias, ya sea para complementar, cuando así lo solicite, los recursos destinados al pago de su pensión o para recibirlas en una sola exhibición.

El art. 37 de la LSAR, en sus últimos párrafos, limita el derecho de la Afore a cobrar comisiones por el traspaso a otra Afore o a retirarlas, en caso de modificación a la estructura de comisiones, siempre que esté previsto en el contrato mercantil celebrado con la administradora y en los prospectos de

información, de conformidad con lo que establezca al efecto la Consar. La administradora tampoco cobrará comisiones por el traspaso de las cuentas individuales o de recursos entre sociedades de inversión, ni por entregar los recursos a la institución de seguros que el trabajador o sus beneficiarios hayan elegido, para la contratación de rentas vitalicias o del seguro de sobrevivencia. La Consar informará periódicamente a través de los medios a su disposición las comisiones que cobren las administradoras, procurando que dicha información sea expresada en lenguaje accesible y permita a los trabajadores comparar las comisiones que cobran las distintas administradoras. Además, la Consar determinará la forma y los términos en que las administradoras deberán dar a conocer a los trabajadores sus estructuras de comisiones.

El art. 51 del Reglamento de la LSAR hace responsable a la administradora receptora del traspaso indebido, por lo que resarcirá el monto de los rendimientos que debieron generarse en la cuenta individual, calculados desde la fecha de liquidación del traspaso indebido, así como las comisiones que le hubieren cobrado al trabajador que acredite haber sido objeto de un traspaso indebido, sin perjuicio de las sanciones que conforme a la Ley u otros ordenamientos legales fueren aplicables. El trabajador podrá manifestar por escrito ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros o ante la administradora transferente, que se efectuó el traspaso de su cuenta sin que hubiera otorgado su consentimiento, dentro de los 180 días hábiles siguientes a que tenga conocimiento que fue inscrito en la Base de Datos Nacional SAR. Los promotores dedican una parte de sus esfuerzos a cometer esta serie de irregularidades. El trabajador que fuere objeto de un traspaso indebido podrá solicitar el traspaso de su cuenta individual a otra administradora, sin necesidad de que transcurra el periodo mínimo de permanencia que le hubiera sido aplicable. La instrumentación del traspaso en la forma establecida limita y condiciona el derecho para proteger a las Afore.

Condiciones para el otorgamiento de la pensión

El sistema que la LSS, al ser de aplicación estricta, establece para el cálculo de las pensiones es complicado, requiere de un estudio minucioso en cuanto a sus disposiciones legales, para no lesionar los derechos del trabajador. Por una parte, el otorgamiento de la pensión se condiciona a la celebración de dos contratos de naturaleza mercantil –de renta vitalicia y de sobrevivencia– con la aseguradora que elija el trabajador o, en su caso, sus beneficiarios; por otra, obliga a estimar las fluctuaciones del mercado de valores para determinar el monto de la pensión.

Para seleccionar una aseguradora, el trabajador o sus beneficiarios deben conocer el manejo financiero con las variantes del mercado de valores; en caso de que el trabajador no ejerza el derecho de selección, la LSS en su art. 189 faculta a la Afore que tenga la administración de los recursos para adquirir a

nombre del trabajador o de sus beneficiarios un seguro de sobrevivencia, en los términos que determine la Comisión de Seguros y Fianzas:

Artículo 189. Con cargo a los recursos acumulados de la cuenta individual del trabajador, la Administradora de Fondos para el Retiro adquirirá a nombre de éste y en favor de sus beneficiarios legales, en el momento de otorgarse la pensión, un seguro de sobrevivencia, en los términos que al efecto determine la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, oyendo a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, en los mismos porcentajes y condiciones que para tal efecto establece el Capítulo V Sección Quinta de este Título.

La intervención de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas no se justifica para determinar las bases de la contratación del seguro de sobrevivencia; no se trata de un seguro privado, por lo que la regulación por el Derecho Mercantil atenta contra los principios del Seguro Social.

La fracc. V del art. 159 de la LSS permite que el trabajador opte por los retiros programados, como una modalidad en lugar de una pensión, para lo cual se fracciona el monto total de los recursos de la cuenta individual, con base en su esperanza de vida, así como en los rendimientos previsibles de los saldos. El retiro programado calculará, cada año, una anualidad que será igual al resultado de dividir el saldo de su cuenta individual entre el capital necesario para financiar una unidad de renta vitalicia para el asegurado y sus beneficiarios, por lo menos, igual al valor correspondiente a la pensión garantizada de un salario mínimo (art. 194). La pensión mensual, es decir, el importe del retiro programado, corresponderá a la doceava parte de dicha anualidad; esto es, al cálculo de una pensión mensual. La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas elaborará anualmente las tablas que serán utilizadas para calcular la unidad de renta vitalicia.

La Ley, al disponer la contratación con las instituciones aseguradoras, condiciona el retiro programado al *saldo acumulado* en la cuenta individual del trabajador, que sirve de base para el *monto constitutivo*, cantidad que se estima necesaria para la contratación, y la suma asegurada, que es la diferencia positiva que resulta de restar al monto constitutivo el saldo acumulado.

En el art. 159 se considera la *suma asegurada* como el monto necesario para que el trabajador o su beneficiario puedan contratar algún seguro. En la fracc. VII se define: "Suma asegurada es la cantidad que resulta de restar al *monto constitutivo* el saldo de la cuenta individual del trabajador." Por su parte, el monto constitutivo es "la cantidad de dinero que se requiere para contratar los seguros de renta vitalicia y de sobrevivencia con una institución de seguros" (fracc. VII).

Si las cantidades que se enteran al IMSS por concepto del pago de cuotas y los resultados financieros que arroje la inversión de las cuotas que se trasladan a la Afore no fueren suficientes para atender los cálculos que se hagan, cuyo

manejo se deja discrecionalmente al Instituto y a la aseguradora, no podría celebrarse el contrato con la aseguradora; en consecuencia, el pensionado podría ver reducida su pensión a la mínima garantizada.

La suma asegurada es la cantidad que se entrega a la institución de seguros para que lleve a cabo la inversión de los fondos y efectúe el pago de las mensualidades correspondientes a la pensión. La situación de los trabajadores y su familia depende de que la suma asegurada resulte suficiente para cubrir la pensión que se determina en cada seguro. En caso de que esta suma asegurada sea insuficiente o se extinga, se cubrirá la pensión garantizada con fondos complementarios del Gobierno Federal.

Los asegurados tienen derecho a recibir la diferencia que exista entre el monto constitutivo y las cantidades acumuladas, cuando la diferencia opere a su favor. En caso de que no retiren esa diferencia, podrán convenir en un aumento de las cantidades estimadas como pensión a su favor.

El cálculo del monto constitutivo, condicionante para la contratación de los seguros de renta vitalicia y de sobrevivencia, se hará conforme a las disposiciones de un comité, integrado por 11 miembros, como lo determina el art. 81 de la LSAR, sin que queden precisadas en esta Ley las normas a las que habrá de ajustarse dicho comité:

Artículo 81. Los procedimientos relativos al cálculo del monto constitutivo para la contratación de las rentas vitalicias y de los seguros de sobrevivencia, estará a cargo de un comité integrado por once miembros de la siguiente forma: tres por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, quien lo presidirá, dos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dos por el Instituto Mexicano del Seguro Social, dos por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y dos por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.

Esta disposición pone en duda diversos preceptos contenidos en la LSS, donde se precisa que el IMSS efectuará el cálculo del monto constitutivo necesario para contratar con la aseguradora los seguros de renta vitalicia y de sobrevivencia. La LSAR carece de fundamento para determinar que los procedimientos relativos al cálculo del monto constitutivo para la contratación de las rentas vitalicias y de los seguros de sobrevivencia estarán a cargo de un comité. Las normas relativas al comité están en contradicción con lo dispuesto en la LSS.

Artículo 58. [...]

II. La pensión, el seguro de sobrevivencia y las prestaciones económicas a que se refiere el párrafo anterior se otorgarán por la institución de seguros que elija el trabajador. Para contratar los seguros de renta vitalicia y sobrevivencia, el Instituto calculará el monto constitutivo necesario para su contratación. Al monto constitutivo se le restará el saldo acumulado en la cuenta individual del

trabajador y la diferencia positiva será la suma asegurada, que deberá pagar el Instituto a la institución de seguros elegida por el trabajador para la contratación de los seguros de renta vitalicia y de sobrevivencia...

Artículo 64. Si el riesgo de trabajo trae como consecuencia la muerte del asegurado, el Instituto calculará el monto constitutivo al que se le restará los recursos acumulados en la cuenta individual del trabajador fallecido, a efecto de determinar la suma asegurada que el Instituto deberá cubrir a la institución de seguros, necesaria para obtener una pensión, ayudas asistenciales y demás prestaciones económicas previstas en este capítulo a los beneficiarios.

Artículo 120. [...]

II. [...]

La pensión y el seguro de sobrevivencia a que se refiere esta fracción, se contratarán por el asegurado con la institución de seguros que elija. Para la contratación de los seguros de renta vitalicia y de sobrevivencia, el Instituto calculará el monto constitutivo necesario para su contratación...

La LSAR incrementa las posibilidades de una interpretación confusa, al señalar en su art. 80:

El saldo de la cuenta individual, una vez deducido el importe de los recursos provenientes de la subcuenta de aportaciones voluntarias, será considerado por el Instituto Mexicano del Seguro Social para la determinación del monto constitutivo, a fin de calcular la suma asegurada que se entregará a la institución de seguros elegida por el trabajador o sus beneficiarios para la contratación de las rentas vitalicias o seguros de sobrevivencia en los términos previstos en la Ley del Seguro Social. En cada caso, el trabajador o sus beneficiarios decidirán libremente si los recursos de la subcuenta de aportaciones voluntarias los reciben en una sola exhibición o los utilizan para incrementar los beneficios de la renta vitalicia y seguro de sobrevivencia.

Se denomina de *renta vitalicia* al contrato que el asegurado o su beneficiario celebre con la aseguradora de su elección. El contrato, por la naturaleza jurídica de la aseguradora, tiene el carácter de mercantil, con lo que se pretende privar al pensionado de los derechos laborales, para sujetarlo al Derecho Mercantil. La fracc. IV del art. 159 consigna: "Renta vitalicia, el contrato por el cual la aseguradora a cambio de recibir los recursos acumulados en la cuenta individual se obliga a pagar periódicamente una pensión durante la vida del pensionado."

Existen dos condiciones para contratar un seguro de renta vitalicia. Una la debe cumplir el asegurado: celebrar un contrato con la aseguradora, en los supuestos de riesgos de trabajo, invalidez, vida, cesantía en edad avanzada o vejez; otra, la del IMSS o de las Afore: transferir los recursos. Se reitera que la

aseguradora no corre riesgo alguno, pues debe limitarse a lo establecido en el contrato de seguro que celebre con el asegurado o con el beneficiario, con la intervención del IMSS, y va a pagar sobre los recursos que reciba: se entrega a la aseguradora la suma asegurada, calculada por el Instituto, adicionada a los recursos de la cuenta individual.

El contrato de sobrevivencia también debe celebrarse con la aseguradora privada, para que cubra las pensiones de viudez, orfandad o ascendientes, en los diversos seguros que establece la Ley, con cargo a los recursos de la suma asegurada, adicionada a los recursos de la cuenta individual, mediante la renta que se les asignará después del fallecimiento del pensionado, hasta la extinción legal de las pensiones (art. 159, fracc. VI).

En los diversos supuestos hemos visto que la Ley ordena que las prestaciones en cada seguro se cubrirán únicamente con las aportaciones que se establecen, sin que puedan tomarse recursos de un seguro para atender prestaciones de otro; sin embargo, las fraccs. IV y VI del art. 159 violentan este principio protector.

El art. 120 señala que en caso de que el trabajador tenga una cantidad acumulada en su cuenta individual mayor al necesario para integrar el monto constitutivo a fin de contratar una renta vitalicia, que a su vez sea superior a la pensión a que tenga derecho, así como para contratar el seguro de sobrevivencia, podrá optar por:

- a) Retirar la suma excedente en una sola exhibición de su cuenta individual;
- b) Contratar una renta vitalicia por una cuantía mayor; o
- c) Aplicar el excedente a un pago de sobre prima para incrementar los beneficios del seguro de sobrevivencia.

Con estos antecedentes, la Ley vigente, en el art. 154 en su tercer párrafo, determina que el "trabajador cesante que tenga sesenta años o más y no reúna las semanas de cotización [1 250]... podrá retirar el saldo de su cuenta individual en una sola exhibición o seguir cotizando hasta cubrir las semanas necesarias para que opere su pensión". La misma situación se determina para el trabajador que tenga 65 años o más y no reúna las 1 250 semanas de cotización, en el segundo párrafo del art. 162.

Pensión garantizada

La LSS no hace distinción entre las diferentes pensiones de riesgos de trabajo e invalidez y vida, y las relativas a cesantía en edad avanzada y vejez, cuyas condiciones son claramente distintas. Las primeras cuentan con cuotas propias, estimación de montos y su pago depende de la contratación con las aseguradoras privadas; las segundas dependen de las cuentas individuales. La distinción debe efectuarse en cada caso para evitar abusos que lesionen el derecho de los

trabajadores y afecten las finanzas públicas. Cabe recordar que las pensiones del primer caso se cubren con las aportaciones que tanto patrones como trabajadores llevan a cabo conforme a la Ley. Una afectación al derecho de los trabajadores puede dar lugar al juicio laboral, como lo indican los arts. 294 y 295 del ordenamiento legal.

La pensión garantizada se otorga únicamente a los sujetos de los arts. 154 y 162 de la LSS; es decir, a quienes hayan cumplido 60 o 65 años de edad (art. 170), acreditado 1250 semanas cotizadas y el fondo acumulado en su cuenta individual resulte insuficiente para celebrar con la aseguradora privada de su elección el contrato de renta vitalicia o un retiro programado, sin especificar el monto o si se refiere a la suma asegurada. En una interpretación integral del precepto (art. 172) debe entenderse que si la suma asegurada no alcanza el salario mínimo, el Gobierno Federal hará una aportación complementaria a la cuenta individual administrada por la Afore, para el pago de las pensiones correspondientes de renta vitalicia y de sobrevivencia (a la viuda 90%, al huérfano 20 o 30%; a falta de éstos, a cada uno de los ascendientes, 20%). El resultado promedio actuarial obtenido y estimado, prevee que:

... habrá un gran número de pensiones garantizadas, las cuales deben estimarse con la mayor precisión posible, ya que con la información hasta ahora disponible, el costo fiscal que representan los diferenciales de estas pensiones corre a cargo del gobierno federal, los que sumados al costo de transición pueden resultar, para las finanzas públicas, una carga mucho mayor que la esperada. Además puede ser considerable el número de trabajadores que no cumplan con los requisitos para tener derecho a una pensión de retiro por mínima que sea, haciendo que el sistema de pensiones no cumpla, en gran medida, con los objetivos propuestos, por lo que será indispensable acudir a otro tipo de esquemas que solucionen este problema.

La pensión (art. 172) debe solicitarse al Instituto y corresponde al trabajador asegurado acreditar que reúne las condiciones para su otorgamiento. La Afore está obligada a proporcionar la información que el propio Instituto le requiera para este efecto. En el momento en que se acaben los fondos de la cuenta individual, la Afore notificará al Instituto para que con fondos del erario público continúe otorgando la pensión mínima garantizada.

La Ley confiere la facultad al IMSS para que, cuando no lo hayan hecho, en sustitución de la voluntad de los beneficiarios, contrate con la aseguradora de su elección el pago de las pensiones de viudez, orfandad o de ascendientes (art. 172 A). El Instituto informará del fallecimiento a la Afore; para el retiro que, en su caso, estuviere pagando la pensión, y ésta entregará al Instituto los recursos que todavía hubiere en la cuenta individual del trabajador, los cuales, a su vez, se entregarán a la Afore para el pago de la pensión a los beneficiarios, y el Instituto, con apoyo en el erario federal, aportará los recursos faltantes para el pago del monto constitutivo de la mencionada renta vitalicia.

El Instituto suspenderá el pago de la pensión cuando el pensionado reintgrese a un trabajo sujeto al régimen obligatorio, sin que pueda después recibir otra pensión garantizada (art. 173). En una interpretación adecuada implica que sí podrá recibir una pensión mayor o adicionalmente otra por riesgos de trabajo o invalidez. La pensión que corresponda a los beneficiarios del pensionado fallecido se entregará a éstos aun cuando estuvieran gozando de otra pensión de cualquier naturaleza.

El trabajador y sus beneficiarios tienen derecho a recibir el acuerdo donde se conceda, rechace o modifique una pensión. En el acuerdo deberán exponerse los motivos y preceptos legales en que se funden; además, se precisará la cuantía de la prestación, los métodos de cálculo empleados para determinarla y la fecha a partir de la cual tendrá vigencia (art. 292). En el oficio en que se comunique el acuerdo relativo se hará saber el término en que puede interponer el recurso de inconformidad o presentar demanda laboral, con fundamento además del art. 292 en los numerales 294 y 295 de la LSS.

El sistema de cuentas individuales que analizamos, derivado de estas pensiones, fue motivo de una gran discusión entre los neoliberales y los sostenedores del sistema del Estado de Bienestar. Desde la década de 1980 el Banco Mundial pugnó por su establecimiento. Esta discusión ha dividido a los especialistas; algunos

... ven mayores ventajas en el esquema de beneficio definido, según el cual el trabajador conoce el monto de los beneficios a que tendrá derecho desde que ingresa a trabajar. Otros prefieren el sistema de contribución definida... Algunos más piensan que el esquema mixto es mejor pues, a su juicio, utiliza las ventajas de ambos esquemas, principalmente la solidaridad del primero, así como la transparencia y portabilidad del segundo. Esta polémica se justificó durante algunos años, pero ahora la discusión sobre los tipos de sistemas de pensiones solamente distrae la atención y retrasa el objetivo fundamental, que es su reforma para dar certidumbre y viabilidad social y financiera.⁵

Conservación de derechos

El Seguro Social parte del principio de que las semanas cotizadas no se pierden, a favor del asegurado, ni se ven afectadas por los cambios de empresa ni por los intervalos entre una baja y una nueva inscripción. Esto implica que el derecho a recibir prestaciones del Seguro Social se mantiene en todos los casos sujeto a condiciones accesibles para los asegurados. Podemos dividir esta conservación de derechos en inmediata y mediata.

5 Francisco Aguirre Farías, *Evaluación y tendencias de los sistemas de pensiones en México*, Porrúa, México, 2009, p. 93.

El art. 109 dispone que el asegurado conservará su derecho a recibir prestaciones médicas por ocho semanas después de la fecha de la baja, siempre que hubiese cotizado por un lapso igual, dentro de la rama de enfermedades y maternidad. De este derecho gozarán también los beneficiarios. Los trabajadores que se encuentren en estado de huelga recibirán prestaciones médicas durante el tiempo que dure dicha situación.

Los asegurados que dejen de pertenecer al régimen obligatorio conservarán los derechos que hubieren adquirido en las pensiones de invalidez y vida, cesantía en edad avanzada y vejez, por una cuarta parte del tiempo que hubieran cotizado, en ningún caso inferior a 12 meses.

El art. 151 dispone que si el tiempo que media entre la baja y el reingreso es inferior a tres años, se le reconocerán de inmediato las semanas cotizadas, en el momento en que se lleve a cabo la reincorporación. Cuando el lapso entre la baja y la nueva inscripción sea de más de tres hasta seis años, tendrá que cotizar nuevamente un mínimo de 26 semanas para que en forma automática opere el reconocimiento de las semanas anteriores. Si el asegurado está fuera del régimen del Seguro por más de seis años, deberá reunir un mínimo de 52 semanas para que le sean computadas las anteriores.

Ayuda para gastos de matrimonio

Esta ayuda, llamada en sus orígenes la "prestación color de rosa", ha perdido atractivo por su escaso monto. Debe reconocerse que no responde a una contingencia, pero cuando se trata de una cantidad adecuada, estimula la regularización de las parejas que se encuentran en concubinato.

El art. 165 determina la cuantía de esta ayuda en una cantidad equivalente a 30 días del salario mínimo del Distrito Federal, la cual provendrá de la cuota social aportada por el Gobierno Federal. Para tener derecho a la ayuda, el asegurado acreditará un mínimo de 150 cotizaciones semanales, a la fecha de la celebración del matrimonio, en el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; que la cónyuge no ha sido registrada con anterioridad como esposa, y, en su caso, el fallecimiento de la esposa anterior (con cuyo matrimonio no recibió ayuda). Se otorga una sola vez al asegurado.

El análisis de las condiciones carece de trascendencia, en tanto no se mejore la prestación. Para ese supuesto debe suprimirse la limitante de inscripción de la concubina como esposa y estimular la regularización de la situación jurídica de la pareja. También debería otorgarse en todos los matrimonios, con el propósito de atender su objetivo: dar soporte a los primeros gastos de la unión conyugal.

El art. 166 en su segundo párrafo dispone que en el supuesto de proporcionar datos falsos en relación con su estado civil, el asegurado perderá el derecho a la ayuda. El derecho se conserva durante 90 días, con posterioridad

a la fecha de la baja (art. 166). El art. 279 de la Ley de 1973, en su fracc. II, señalaba el término de prescripción para reclamar la ayuda para gastos de matrimonio, contados a partir de la fecha de la celebración de éste. La nueva Ley de 1997 suprime esta fracción, con lo que se remite a la regla general contenida en el primer párrafo del art. 300, que la extiende a un año, contado a partir de que se ocurre el supuesto del matrimonio.

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar)

El presente capítulo tiene una relación de continuidad con el anterior; en razón de su importancia, estimé adecuado dedicar una sección a la Consar. El nombre de este organismo es incorrecto ya que, como vimos en el capítulo anterior, el retiro no genera derecho a pensión, se refiere estrictamente a una aportación de 2% sobre el salario de los trabajadores que se va a sumar a las aportaciones de cesantía en edad avanzada y vejez para el otorgamiento de estas pensiones. Por ser el órgano regulador de todo el sistema debía llamarse, en todo caso, Comisión Nacional del Sistema de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, puesto que de él dependen las autorizaciones, la vigilancia y los sistemas de control de las empresas privadas constituidas como sociedades anónimas de capital variable, las administradoras, las de inversión de la cuenta individual, las operadoras de Base Nacional de Datos SAR y las aseguradoras.

Ley del Seguro Social

La Consar tiene como antecedente la reforma a la *Ley del Seguro Social* (LSS) de 1992, donde se incluye, en el art. 11, el seguro de retiro; los arts. 183 A a 183 M disponen la aportación patronal adicional de 2% sobre nómina, directamente al banco seleccionado por el patrón, además de la cuota de 5% sobre el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). El banco tendría la obligación de individualizar las cuentas a favor de cada trabajador con los datos aportados por el patrón. La institución bancaria se obligaba a informar al trabajador, por medio del patrón o de la representación sindical, el estado de cuentas, además de que transfería los recursos al Banco

de México, sin cobro de comisión, dentro de los cuatro días hábiles bancarios siguientes. Esta institución oficial abría dos subcuentas: una por retiro a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y otra de vivienda a nombre del Infonavit. Los fondos los ponía a disposición del Gobierno Federal, en forma de créditos. El Gobierno resultaba deudor de las instituciones de seguridad social de la administración e inversión de los recursos que al 2002 sumaba más de 100 mil millones de pesos.

Para la instrumentación de estos procedimientos y su vigilancia, la reforma de 1992 creó el Comité Técnico, como parte de los órganos de gobierno del Instituto. Este Comité se integraba por nueve personas; tres representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dos del Banco de México, uno de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y tres del IMSS. La Cámara de Diputados dispuso que, para mantener el carácter tripartita del Instituto, uno representaría a las organizaciones de trabajadores, otro a las organizaciones de patrones y el tercero al propio Instituto. Al Comité se le confieren atribuciones para emitir disposiciones relativas al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), sin sujetarlas a la consideración del Consejo Técnico o de la Asamblea General del IMSS. El Comité tenía autonomía de gestión.

La reforma de 1994 eliminó el Comité Técnico y conformó la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar). Al mismo tiempo se expidió la *Ley para la Coordinación de los Sistemas de Ahorro para el Retiro*, ordenamiento en el que se da a la Comisión la naturaleza de órgano desconcentrado de la SHCP.

La reforma a la LSS vigente a partir del 1 de julio de 1997 ratifica la creación de la Comisión como órgano desconcentrado de la SHCP, lo que genera una confusión legislativa que parte de la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos* (CPEUM), la *Ley Orgánica de la Administración Pública Federal* (LOAPF), la *Ley Federal de las Entidades Paraestatales*, la LSS y de su propia Ley. El art. 90 de la Constitución dispone:

La Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación que estarán a cargo de las Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación.

Las leyes determinarán las relaciones de las entidades paraestatales y el Ejecutivo Federal, o entre éstas y las Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos.

La LOAPF precisa en su art. 17 que los órganos desconcentrados de la Administración Pública Federal estarán jerárquicamente subordinados a la Secretaría de Estado correspondiente "y tendrán facultades específicas para resolver sobre la materia y dentro del ámbito territorial que se determine", para "la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su competencia".

El art. 31 de la LOAPF precisa el ámbito de competencia de la SHCP. En sus 35 fracciones no se encuentra elemento para derivar en la competencia en relación con los SAR o para intervenir en forma alguna en los seguros sociales. En todo caso, puede alegarse que la *Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro* (LSAR) tiene la misma jerarquía que la Ley Orgánica y puede dotarle de facultades, lo que es discutible si se considera lo ordenado en el art. 90 constitucional. El art. 2º de la LSAR dispone:

La coordinación, regulación, supervisión y vigilancia de los sistemas de ahorro para el retiro están a cargo de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro como órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dotado de autonomía técnica y facultades ejecutivas, con competencia funcional propia en los términos de la presente ley.

Es conveniente que la Consar, por la experiencia vivida en estos años, pudiera conformarse como un organismo público descentralizado, sin depender de la SHCP, con quien puede tener una adecuada coordinación.

La LSS dispone en su art. 175 que "la individualización y administración de los recursos de las cuentas individuales para el retiro estará a cargo de las Administradoras de Fondos para el Retiro". Estas administradoras, conforme al mismo precepto, "deberán contar para su constitución y funcionamiento, con autorización de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro". De especial relevancia es el art. 195 de este ordenamiento al disponer:

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, atendiendo a consideraciones técnicas y asegurando los intereses de los trabajadores, mediante la expedición de disposiciones administrativas podrá autorizar mecanismos, procedimientos, formas y términos relacionados con el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, conforme a lo establecido en esta Ley y la Ley para la Coordinación de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

También llama la atención el art. 200 de esta Ley:

Para los efectos de esta Sección, la Ley para la Coordinación de los Sistemas de Ahorro para el Retiro preverá las disposiciones administrativas que sean necesarias para lograr el eficaz cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Ley.

La LSS marca la pauta a seguir tanto por la Consar como por las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore), sobre todo en el art. 200 transcrito. Por tanto, la LSS es la norma sustantiva al precisar la forma, el modo y las condiciones en que debe operar el órgano desconcentrado, al que no da ese carácter. La LSAR sería en esta forma un ordenamiento adjetivo que cumple con lo preceptuado por la LSS y hace operativas sus disposiciones.

Si este supuesto se admite, la norma sustantiva tiene que estar vigente para que la adjetiva opere. El legislador dispuso al aprobar la LSS que entraría en vigor el 1 de enero de 1997 (art. 1 transitorio). Por iniciativa del Ejecutivo Federal, el Congreso de la Unión ordenó reformar este art. 1 transitorio a efecto de que la entrada en vigor fuera el 1 de julio de ese año. La LSAR entró en vigor al día siguiente de su publicación, el 24 de mayo de 1996, conforme a su art. 1 transitorio. Si bien este asunto no ha merecido consideración de los juristas, es conveniente plantearlo por las acciones que a partir del 26 de mayo llevó a cabo la Consar.

La LSS dispone que la administración de los recursos de las cuentas individuales se entregue a las Afore, y la inversión la lleven a cabo las Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro (Siefore), dedicadas a "La individualización y administración de los recursos de las cuentas individuales para el retiro" (art. 175, LSS). Éstas "son entidades financieras que se dedican de manera exclusiva, habitual y profesional a administrar las cuentas individuales y canalizar los recursos de las subcuentas que las integran en términos de las leyes de seguridad social" (art. 18, LSAR).

Competencia de la Consar

Con base en los párrafos precedentes, veamos las atribuciones que para este órgano desconcentrado le confiere la LSS y la LSAR.

En cuanto a las atribuciones administrativas, la LSS en su art. 40 establece que la Consar debe recibir información del IMSS en relación con las prórrogas otorgadas a los patrones relativas a cuotas por retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. El IMSS libremente, con base en la solicitud del patrón, determina el otorgamiento de prórrogas para el pago de cuotas.

El art. 157 señala como atribución de regulación de la Consar expedir reglas de carácter general a las que se sujetarán los contratos de renta vitalicia y los retiros programados.

La LSS en el art. 185 marca los límites que conforme a la LSAR debe ejercer la Comisión; entre ellos, expedir las disposiciones de carácter general conforme a consideraciones técnicas que aseguren los intereses de los trabajadores y autorizar mecanismos, procedimientos, formas y términos relacionados con el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Además, la facultad para expedir las disposiciones relativas a la disolución y liquidación de las Afore y Siefore para salvaguardar los derechos de los asegurados.

El art. 195 del mismo ordenamiento autoriza a la Consar a expedir disposiciones administrativas, en atención a consideraciones técnicas y asegurando los intereses de los trabajadores, mecanismos, procedimientos, formas y términos relacionados con el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, conforme a lo establecido en esta Ley y la LSAR. Dada su amplitud, es inconveniente el precepto que implica una delegación discrecional de fa-

cultades y obligaciones, por la afectación que en estos años hemos visto a los derechohabientes, puesto que se le faculta para afectar los recursos de las cuentas individuales de los trabajadores que no elijan la Afore que operará su cuenta individual (art. 176), regular la unificación o traspaso de las cuentas individuales (art. 177) y normar la forma en que se realicen las aplicaciones específicas a cada subcuenta de la cuenta individual (art. 179). Estas situaciones que afectan a los derechohabientes en su posibilidad de pensión, no pueden dejarse al ámbito de disposiciones administrativas, ajenas a la condición de trabajador y de salario, objetos de amplia protección en las leyes laborales. También se le confiere a la Consar, para la disolución y liquidación de las Afore y Siefore, la expedición de disposiciones administrativas para salvaguardar los derechos de los asegurados, en los términos de esta Ley. La propia Ley desconoce que se ha autorizado a las Afore a adquirir, con el dinero "propiedad" de los trabajadores, acciones de las Siefore, con lo que ha desaparecido la protección para los trabajadores.

Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro

Con estas bases, la *Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro* (LSAR), en su capítulo segundo, autoriza a la Consar para controlar la recepción, el depósito, la transmisión y administración de las cuotas y aportaciones; además de dictar las reglas a las que se sujetan las Afore, los Siefore, las operadoras y aseguradoras, como instituciones privadas de crédito, para su constitución, organización, funcionamiento, operaciones, participación en los SAR y su revocación. La Consar emitirá las disposiciones para la operación y el pago de los retiros programados, supervisará a los participantes en los SAR e impondrá multas y sanciones. La supervisión se lleva a cabo conjuntamente por la Consar, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. A la Consar corresponde administrar y operar, en su caso, la Base de Datos Nacional SAR; además, contará con un sistema donde publicará estadísticas y documentos relacionados con los SAR. Asimismo, rendirá un informe semestral al Congreso de la Unión sobre la situación que guardan los SAR, en el que deberá considerar un apartado específico donde se mencionen las carteras de inversión de las sociedades de inversión.

Órganos de gobierno

Los órganos de gobierno de la Consar serán la Junta de Gobierno, la Presidencia y el Comité Consultivo y de Vigilancia. La Junta de Gobierno estará integrada por el Secretario de Hacienda y Crédito Público, quien la presidirá, el Presidente de la Comisión, dos vicepresidentes de la misma y otros 13 vocales (el Secretario del Trabajo y Previsión Social, el Gobernador del Banco de México, el Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, el Director General

del IMSS, el Director General del Infonavit, el Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y el Presidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas; los cinco restantes serán designados por el Secretario de Hacienda y Crédito Público, debiendo ser cuatro representantes de las organizaciones nacionales de trabajadores y uno de los correspondientes a los patrones, que formen parte del Comité Consultivo y de Vigilancia y que ostenten la mayor representatividad). En ausencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público, lo suplirá el Presidente de la Comisión. Por cada propietario se nombrará un suplente, el cual podrá ser removido libremente por las dependencias, entidades o instituciones que los hayan designado. Los representantes suplentes de las organizaciones obreras y patronales serán designados en los mismos términos que los miembros propietarios. La Junta de Gobierno contará con un Secretario, el cual podrá expedir constancias de los acuerdos de los órganos colegiados de la propia Comisión.

Las facultades principales de la Junta de Gobierno son otorgar, modificar o revocar las autorizaciones para la organización, la operación, el funcionamiento y la fusión de las administradoras y sociedades de inversión, las autorizaciones para la adquisición de acciones de las administradoras y del capital fijo de las sociedades de inversión, en los términos de esta Ley, y las autorizaciones para que las administradoras realicen actividades análogas o conexas a su objeto social. También expedirá reglas de carácter general relativas a los aspectos siguientes:

- a) El régimen de inversión al que deberán sujetarse las sociedades de inversión, previa opinión favorable del Comité Consultivo y de Vigilancia.
- b) Las relativas al régimen de las comisiones que las instituciones de crédito, administradoras o empresas operadoras, podrán cobrar por los servicios que presten en materia de los SAR, previa opinión favorable del Comité Consultivo y de Vigilancia.
- c) Los términos y las condiciones a los que deberán sujetarse las administradoras, respecto a los gastos que genere el sistema de emisión, cobranza y control de aportaciones, los cuales deberán cubrir al IMSS, así como respecto a cualquier otro servicio que este Instituto le preste a las referidas administradoras.

Conocerá de las violaciones de los participantes en los SAR a esta Ley, reglamentos y disposiciones generales aplicables, e impondrá las sanciones correspondientes.

Es facultad exclusiva del Secretario de Hacienda y Crédito Público nombrar al Presidente de la Comisión, quien deberá ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad y estar en pleno goce de sus

derechos civiles y políticos; contar con reconocida experiencia en materia económica, financiera, jurídica o de seguridad social; no tener nexos patrimoniales con los accionistas que formen el grupo de control de los participantes en los SAR sujetos a la supervisión de la Comisión, ni con los funcionarios de primer y segundo nivel de los mismos, así como no ser cónyuge ni tener relación de parentesco consanguíneo dentro del segundo grado con dichas personas; no haber sido inhabilitado para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público o en el sistema financiero mexicano y gozar de reconocida solvencia moral, y no desempeñar cargo de elección popular, ni ser accionista, consejero, funcionario, comisario, apoderado o agente de los participantes en los SAR.

El Presidente de la Consar es la máxima autoridad administrativa de ésta y el representante legal, por lo que ejercerá las facultades que le otorga la Ley y las que le delegue la Junta de Gobierno, directamente, o a través de los servidores públicos de la Comisión, en los términos del reglamento interior de ésta o mediante acuerdos delegatorios que deberán ser publicados en el *Diario Oficial de la Federación* (DOF). Tiene la facultad de dirigir administrativamente a la Comisión; presentará a la Junta de Gobierno un informe semestral sobre la situación que guardan los SAR y un informe anual sobre las labores desarrolladas por la Comisión; de igual forma, supervisará a los participantes en los SAR. Por su dependencia de la SHCP, le informará anualmente y cuando ésta se lo solicite, sobre su actuación y sobre casos concretos que la misma requiera. De este funcionario dependen los asuntos administrativos.

La Comisión contará con un órgano tripartito denominado Comité Consultivo y de Vigilancia, integrado por los sectores obrero, patronal y del Gobierno, que tiene por fin velar por los intereses de las partes involucradas, a efecto de que siempre se guarde armonía y equilibrio entre los intereses mencionados para el mejor funcionamiento de los SAR. Los miembros del Comité Consultivo y de Vigilancia tendrán conocimientos en materia financiera, jurídica o de seguridad social. Este Comité Consultivo y de Vigilancia estará integrado por 19 miembros: seis representantes de los trabajadores y seis representantes de los patrones, el Presidente de la Comisión y uno por cada una de las dependencias y entidades siguientes: la SHCP, la Secretaría del Trabajo, el Infonavit y el Banco de México. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), fijará las bases para determinar la forma de designar a los representantes de las organizaciones nacionales de patrones. Los miembros representantes de estas organizaciones se designarán de la manera siguiente: cinco, de acuerdo con las formas utilizadas por la propia STPS, conforme a los usos y las costumbres en Comités análogos, y el sexto representante será designado por la Federación de Sindicatos de los Trabajadores al Servicio del Estado. Un representante de las organizaciones nacionales de trabajadores o de patrones presidirá, alternativamente, por periodos anuales, el Comité que se reunirá, a convocatoria de quien lo presida, en sesiones ordinarias por lo menos cada dos

meses y en sesiones extraordinarias cuando sea conveniente, a convocatoria de su Presidente.

El Comité Consultivo y de Vigilancia se encargará, entre otros, de los asuntos que le someta el Presidente de la Comisión, relativos a la adopción de criterios y políticas de aplicación general en materia de los SAR; vigilará el desarrollo de los SAR para prevenir posibles situaciones que presenten conflicto de intereses y prácticas monopólicas; conocerá lo referente a la administración de cuentas individuales y sobre las autorizaciones para la constitución de las administradoras y sociedades de inversión; aprobará los nombramientos de los contralores normativos y de los consejeros independientes de las administradoras y de las sociedades de inversión.

Los cargos de los miembros de la Junta de Gobierno y del Comité Consultivo y de Vigilancia serán honorarios y no devengarán salario o remuneración alguna por su desempeño.

La Junta de Gobierno está en manos de la SHCP, dependencia que la preside y tiene la mayor representación por medio del Subsecretario, del Presidente y dos vicepresidentes de la misma Consar. Los sectores obrero y patronal están representados; el primero por la Confederación de Trabajadores de México, con dos lugares; la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos y de la Confederación Regional Obrera Mexicana; el segundo, por conducto de la Confederación de Cámaras Industriales.

Junta de Gobierno	
Sector Gobierno	
Secretario de Hacienda y Crédito Público	
Subsecretario de Hacienda y Crédito Público	Director General del IMSS
Director General del Infonavit	Director General del ISSSTE
Secretario del Trabajo y Previsión Social	Gobernador del Banco de México
Presidente de la CNSF	Presidente de la CNEV
Presidente de la Consar	Vicepresidente de la Consar
Vicepresidente de la CNSF	

Comité Consultivo y de Vigilancia

<u>Sector Gobierno</u>		<u>Sector Obrero</u>	<u>Sector Patronal</u>
SHCP	IMSS	CTM	Concamin
ISSSTE	Infonavit	CTM	Concanaco
Banco de México	STPS	CTM	Coparmex
Consar		FSTSE	ABM
		CROC	AMIS
		CROM	AMIB

<u>Sector Obrero</u>	<u>Sector Patronal</u>
Confederación de Trabajadores de México (CTM)	Confederación de Cámaras Industriales (Concamin)
Confederación de Trabajadores de México (CTM)	
Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC)	
Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM)	

Obligaciones de la Consar

Entre sus obligaciones, la Consar velará en todo momento por que los SAR presenten condiciones adecuadas de competencia y eficiencia (art. 25). Se obliga a la Consar a actuar en concordancia con la *Ley Federal de Competencia Económica* para establecer los mecanismos necesarios a efecto de que no se presenten prácticas monopólicas absolutas o relativas como resultado de la conducta de los participantes o por una concentración del mercado. Los mecanismos señalados se aplicarán previa opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Comité Consultivo y de Vigilancia.

Es evidente que la Consar rebasa sus facultades legales y emite verdaderos reglamentos que afectan a las sociedades mercantiles y a los derechohabientes, pero más grave es el control que en materia de pensiones tiene sobre el IMSS, el ISSSTE y el Infonavit. Las constantes reglas de carácter general, publicadas en el DOF, así lo acreditan; por ejemplo, la publicación del 28 de mayo de 2008, relativa a las obligaciones de las Afore y de las empresas operadoras de Base de Datos Nacional SAR, para el traspaso de cuentas individuales de los trabajadores. Las reglas emitidas por un organismo desconcentrado no cuentan con sanción de otra autoridad.

Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore)

El art. 175 de la LSS determina que la individualización y administración de las cuotas enteradas al IMSS por el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez serán llevadas en cuentas individuales a nombre de cada trabajador, por las Afore. Con esta disposición se les traslada una parte de la contribución que aportan los patrones, los trabajadores y el mismo Gobierno Federal. Este movimiento varía la naturaleza jurídica de la contribución, al encomendarle además la inversión en la sociedad especializada en dichos fondos. La Consar autoriza la celebración de contratos de naturaleza mercantil con cada trabajador y la aportación (contribución) se transforma en una acción de esta segunda sociedad mercantil. El sistema que se estructura de cuentas individuales implica que “únicamente se base en aportaciones definidas, cuenta individual y administración privada, se traduce en implicaciones sociales y desafíos nacionales que pueden agravar las condiciones de inseguridad social, de sustentabilidad fiscal, de baja cobertura y de alto costo”.¹

1 Berenice Ramírez López, *Evaluación y tendencias de los sistemas de pensiones en México*, Porrúa, México, 2009, p. 274.

El precepto 175 remite a la LSAR para que establezca los requisitos de constitución, entre los que se incluirán las disposiciones relativas a impedir el conflicto de intereses sobre el manejo de los fondos, respecto de la participación de las asociaciones gremiales del sector productivo y de las entidades financieras. La autorización respectiva deberá solicitarse a la Consar, que emitirá las reglas para su funcionamiento.

Artículo 175. La individualización y administración de los recursos de las cuentas individuales para el retiro estará a cargo de las Administradoras de Fondos para el Retiro.

Las Administradoras de Fondos para el Retiro deberán contar, para su constitución y funcionamiento, con autorización de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, sujetándose en cuanto a su contabilidad, información, sistemas de comercialización y publicidad a los términos de la Ley para la Coordinación de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

En todo caso, dicha Ley dispondrá los requisitos de constitución, entre los que se incluirán las disposiciones relativas a impedir el conflicto de intereses sobre el manejo de los fondos respecto de la participación de las asociaciones gremiales del sector productivo y de las entidades financieras.

El art. 175 de la LSS es motivo de reflexión jurídica, ya que los recursos que manejan las Afore son, por una parte, contribuciones, en términos del art. 2º, fracc. II, del *Código Fiscal de la Federación* (CFF), pero por otra, son propiedad del trabajador y como tal, parte del salario sujeto a la *Ley Federal del Trabajo* (LFT). Como contribución podía otorgarse una concesión; como salario no puede sujetarse a descuentos en forma de comisiones. En ambos casos no pueden reducirse a acciones mercantiles, sujetas a los vaivenes de las bolsas de valores. Las sociedades mercantiles deben cumplir las disposiciones de la LSAR para el manejo de su contabilidad, información, sistemas de comercialización y publicidad, pero además deben observar las normas aplicables de la LSS, de la LFT, de la *Ley General de Sociedades Mercantiles* (LGSM) y del CFF.

El art. 26 del Reglamento de la LSAR determina que en caso de que un trabajador abra una cuenta individual conforme al art. 74 de la Ley y ya contara con una cuenta individual abierta conforme a los arts. 74 o 74 bis de la Ley, los recursos correspondientes a la subcuenta de ahorro a largo plazo se acumularán en la subcuenta de aportaciones complementarias de retiro, siempre que la primera no otorgue derecho a efectuar retiro parcial o total de los recursos antes de que su titular tenga derecho a una pensión. En caso contrario se podrán mantener las subcuentas separadas, y los recursos correspondientes a la subcuenta de aportaciones voluntarias se acumularán en la misma subcuenta de la cuenta individual unificadora.

Responsabilidades de las Afore

Las Afore, empresas privadas, constituidas como sociedades anónimas de capital variable, reciben la cuota de 6.5% de la nómina salarial de los trabajadores, la individualizan y trasladan los recursos a las Siefore, también sociedades anónimas de capital variable; éstas invierten los recursos en la forma y los términos que establece la Consar. Ambas empresas están sujetas a la autorización que emitirá la Consar. En 2008 el IMSS les había trasladado más de 800 mil millones de pesos, lo que sumado a vivienda superaba el billón de pesos.

Son muy precisas las disposiciones de la LSS, como ordenamiento sustantivo: la Afore tiene la obligación de identificar la parte que corresponde a cada trabajador, a efecto de individualizarla, sobre la base de que al ser propiedad de cada asegurado pueda, conforme lo determina la LSAR, realizar las aplicaciones específicas a cada subcuenta de la cuenta individual.

En primera instancia, el IMSS es responsable de la cuota, tanto de recibirla como de aplicar los medios necesarios para su cobro, además de trasladar los recursos a la Afore seleccionada por el trabajador o por el Instituto. En segundo término de responsabilidad está la Consar, de quien depende la expedición de las reglas que norman el sistema. En tercer lugar, la Afore que es responsable de la individualización de la cuenta, de la constitución de las Siefore y del traslado de los fondos, sin cobrar comisión por flujo. En cuarto lugar, la Siefore, que debe invertir los fondos y determinar la comisión sobre utilidad. Las sociedades anónimas deben cumplir tanto con la *Ley de Sociedades Mercantiles e Instituciones de Crédito*, como con la LSAR y las reglas que emita la Consar para su constitución y manejo, las que emita la Comisión de Seguros y Fianzas, entre otras.

Los organismos públicos (IMSS y Consar) deben responder del traslado, la inversión adecuada y, en su caso, la reclamación que pueda formular el asegurado o sus derechohabientes, por lo que no pueden quedar exentos por la intervención de las sociedades mercantiles, quienes igualmente resultan responsables. Por tratarse de una contribución, la responsabilidad resulta fiscal, por los contratos privados, civiles; laboral, por la afectación al salario, propiedad de los trabajadores, y penal, por algún manejo indebido de la contribución y del salario.

Artículo 179. Al efectuarse el entero de las cuotas obrero patronales, la Administradora de Fondos para el Retiro identificará la parte que corresponde a cada trabajador, a efecto de que con dicha información, en los términos que establezca la Ley para la Coordinación de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, se realicen las aplicaciones específicas a cada subcuenta de la cuenta individual.

Cada Afore puede solicitar de la Consar la constitución de una Siefore, cuyo número fue incrementándose hasta llegar a cinco, conforme fue creciendo el número de cuentas y el capital que se entregaba a las Afore, hasta lograr ubicar los fondos a conveniencia de las Afore, de tal forma que una persona joven cuenta con inversión a largo plazo para incrementar la utilidad de la inversión de riesgo, en beneficio de la Siefore. En reconocimiento a la propiedad del trabajador que consigna a su favor el art. 169 de la LSS, la Afore debe informar pormenorizada y claramente al trabajador en los términos, la periodicidad y la forma que determine la LSAR. El trabajador tiene el derecho de solicitar a la Afore, cuando lo estime pertinente, la situación que guarda su fondo. Desde luego tendrá que ver las reglas que al respecto establecen la LSAR y las reglas de la Consar. El art. 181 contiene la obligación y el derecho.

Artículo 181. La Administradora de Fondos para el Retiro deberá informar a cada trabajador titular de una cuenta individual, el estado de la misma, en los términos, periodicidad y forma que al efecto establezca la Ley para la Coordinación de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, sin perjuicio de que el asegurado en todo tiempo tenga el derecho a solicitar cualquier tipo de información, relacionada con su cuenta individual, a la administradora.

El desconocimiento de la situación financiera le impide al trabajador estimar si los patrones han cumplido o no con el pago de las cuotas y, en forma especial, con el del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; además de que carece de elementos para saber a qué autoridad debe dirigirse, si al Instituto, a la SHCP o a la Consar, por lo que resulta ocioso lo señalado en el art. 185. Corresponde a la autoridad vigilar que las cuotas se enteren puntual y correctamente, así como actuar conforme a la Ley.

Artículo 185. El trabajador podrá notificar el incumplimiento de las obligaciones a cargo de los patrones, establecidas en este capítulo, al Instituto, directamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o a través de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.

El Instituto o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrán, indistintamente, la facultad de practicar inspecciones domiciliarias y, en su caso, determinar créditos y las bases de su liquidación, así como la actualización y recargos que se generen en los términos de los artículos 15 fracción V, 251 fracciones XIV y XVIII, y demás relativos de esta Ley.

Este precepto resulta confuso si se toma en cuenta que el art. 187 impone a los trabajadores titulares y a los beneficiarios presentar sus reclamaciones por conducto del sindicato o cualquier organización que lo represente. Estas quejas se entenderán por actos de la Afore, de la Siefore o de la aseguradora

ante la Consar y también se amplía a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), que carecen de facultades investigadoras y sancionadoras, por lo que llaman a la conciliación.

Artículo 187. Los trabajadores titulares de las cuentas individuales, y, en su caso, sus beneficiarios, deberán presentar directamente o a través de sus sindicatos o cualquier otra organización representativa, sus reclamaciones en contra de las Administradoras de Fondos para el Retiro o entidades financieras autorizadas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, ante esta misma Comisión. El procedimiento correspondiente ante la Comisión se sujetará a lo dispuesto en la Ley para la Coordinación de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

La Ley hace responsable al patrón del pago de daños y perjuicios que éste cause al trabajador o a sus beneficiarios. En todo caso, corresponde a la autoridad actuar y garantizar al derechohabiente el cálculo y pago de sus prestaciones. Además, la Ley no establece alguna definición de daño o perjuicio, por lo que es necesario acudir al Código Civil Federal (CCF) y demandar ante un Juzgado Civil, lo que hace tardado y caro el procedimiento.

Artículo 186. El patrón es responsable de los daños y perjuicios que se causaren al trabajador o a sus beneficiarios, cuando por falta de cumplimiento de la obligación de inscribirlo o de avisar su salario real o los cambios que sufriera éste, no pudieran otorgarse las prestaciones consignadas en este capítulo, o bien dichas prestaciones se vieran disminuidas en su cuantía. En este caso el Instituto fincará los capitales constitutivos respectivos, en los términos del artículo 79 de esta Ley.

Las Siefore, administradas y manejadas por las Afore, contrario a lo que puede estimarse, son las directamente responsables de la inversión de los recursos de las cuentas individuales de los trabajadores. Estas sociedades se sujetarán para su constitución, organización, funcionamiento, régimen de inversión, tipos de valores, publicidad, sistemas de comercialización y contabilidad, a lo establecido por la Ley para la Coordinación de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Su inspección y vigilancia, al igual que las Afore, será realizada por la Consar. Las preguntas surgen de inmediato: ¿quién le responde al trabajador?, ¿el IMSS que recauda y traslada los fondos, la Afore que recibe el monto pensionario, la Siefore que invierte, la Consar que autoriza, la aseguradora que paga?

Artículo 188. Las Administradoras de Fondos para el Retiro, operarán las Sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, éstas serán las responsables de la inversión de los recursos de las cuentas individuales de los trabajadores.

Las Sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro se sujetarán para su constitución, organización, funcionamiento, régimen de inversión, tipos de valores, publicidad, sistemas de comercialización y contabilidad, a lo establecido por la Ley para la Coordinación de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

La inspección y vigilancia de las Administradoras de Fondos para el Retiro y de las Sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro será realizada por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.

Facultades y prohibiciones de las Afore

Las disposiciones de la LSS son ampliadas por la LSAR. En su art. 18 les da el carácter de entidades financieras que se dedican de manera habitual y profesional a administrar las cuentas individuales y canalizar los recursos de las subcuentas que las integran en términos de la presente Ley, así como a administrar sociedades de inversión. Además, deberán efectuar

... todas las gestiones que sean necesarias, para la obtención de una adecuada rentabilidad y seguridad en las inversiones de las sociedades de inversión que administren. En cumplimiento de sus funciones, atenderán exclusivamente al interés de los trabajadores y asegurarán que todas las operaciones que efectúen para la inversión de los recursos de dichos trabajadores se realicen con ese objetivo.

El precepto les confiere facultades expresas como abrir, administrar y operar cuentas individuales de los trabajadores inscritos en el ISSSTE, en las que se reciban recursos de los trabajadores no afiliados, que así lo deseen, destinados a la contratación de rentas vitalicias, seguros de sobrevivencia o retiros programados; cuentas en las que se reciban recursos de los trabajadores no afiliados de las dependencias o entidades públicas de carácter estatal o municipal, cuando proceda. Por tanto, recibirán las cuotas y aportaciones de seguridad social correspondientes a las cuentas individuales, de conformidad con las leyes de seguridad social, así como las aportaciones voluntarias y complementarias de retiro y los demás recursos en las cuentas individuales, y administrarán los recursos de los fondos de previsión social. Enviarán, por lo menos dos veces al año, al domicilio que indiquen los trabajadores, sus estados de cuenta y demás información sobre sus cuentas individuales y el estado de sus inversiones, destacando en ellos las aportaciones patronales, del Estado y del trabajador, y el número de días de cotización registrado durante cada bimestre que comprenda el periodo del estado de cuenta, así como las comisiones cobradas por la administradora y las sociedades de inversión que administre. Asimismo, se deberán establecer servicios de información y atención al público. El art. 7º del Reglamento de la LSAR olvida que, como veremos con el contrato, las Afore no invierten los fondos pensionarios, sino sólo los trasladan en una operación de compraventa a la Siefore,

la que invierte sus propios recursos, derivados de la venta de sus adquisiciones, por lo que el rendimiento que obtienen y el riesgo de la inversión queda limitado por la LSAR y por las disposiciones de la Consar.

Artículo 7o. Las Administradoras deberán invertir los recursos de los Trabajadores de manera oportuna, profesional y con la finalidad de que otorguen un mejor rendimiento a los Trabajadores.

Para tal efecto, las Administradoras que cobren comisiones sobre saldo, sólo podrán cobrar éstas cuando los recursos se encuentren efectivamente invertidos en las Sociedades de Inversión y se hayan registrado las provisiones diarias necesarias en la contabilidad de las Sociedades de Inversión. Las provisiones de las comisiones sobre saldo podrán cobrarse con cargo a los activos de las Sociedades de Inversión.

La LSAR establece un catálogo de prohibiciones a las Afore, en su art. 38, por lo que, entre otras, no podrán emitir obligaciones, gravar de cualquier forma su patrimonio, otorgar garantías o avales, adquirir acciones representativas del capital social de otras administradoras, salvo que obtengan para ello autorización de la Consar; obtener préstamos o créditos, con excepción de los expresamente autorizados por la Consar, y adquirir el control de empresas.

Organización y autorización

La LSAR establece los requisitos para que las Afore puedan organizarse y operar, para lo cual cumplirán con los requisitos que además de la Ley fije la Consar, entre ellos, presentar la solicitud respectiva, propuestas viables económica y jurídicamente, así como el proyecto de estatutos sociales a autorización de la Consar, que será otorgada de manera discrecional, oyendo previamente la opinión de la SHCP. Las Afore deberán presentar un programa general de operación y funcionamiento, de divulgación de la información y de reinversión de utilidades.

Las administradoras serán sociedades anónimas de capital variable, y deberán utilizar en su denominación o a continuación de ésta la expresión "Administradora de Fondos para el Retiro" o su abreviatura "AFORE". No deberán utilizar en su denominación expresiones en idioma extranjero o el nombre de alguna asociación religiosa o política, ni utilizar símbolos patrios o religiosos que sean objeto de devoción o culto público. Las escrituras y reformas deberán ser aprobadas por la Consar; una vez aprobadas se inscribirán en el Registro Público de Comercio. En todo caso, deberán proporcionar a la Consar copia certificada de las actas de asamblea y, cuando proceda, testimonio notarial en el que conste la protocolización de las mismas. Los accionistas que detentan el control de la administradora deberán presen-

tar un estado de su situación patrimonial que abarque un periodo de cinco años anteriores a su presentación. El consejo de administración constará de no menos de cinco administradores, cuyo nombramiento se informará a la Consar, así como el del director general, los funcionarios de los dos niveles inmediatos siguientes y sus comisarios. La Consar aprobará el Comité Consultivo y de Vigilancia, los nombramientos de los consejeros independientes y del contralor normativo.

Capital mínimo y reservas

El capital social mínimo deberá estar íntegramente suscrito y pagado. El capital social estará formado por acciones de la serie "A" que representarán cuando menos 51% de dicho capital; el 49% restante del capital social podrá integrarse indistinta o conjuntamente por acciones de las series "A" y "B". Las acciones representativas de la serie "A" únicamente podrán ser adquiridas por personas físicas mexicanas y personas morales mexicanas cuyo capital sea mayoritariamente propiedad de mexicanos y sean efectivamente controladas por los mismos. Las acciones representativas de la serie "B" serán de libre suscripción. No podrán participar en forma alguna en el capital social de las administradoras personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad. Sin embargo, se permite la participación, directa o indirecta, de las instituciones financieras del exterior en el capital social de las administradoras, de conformidad con lo establecido en los tratados y acuerdos internacionales aplicables y en las disposiciones que emita la SHCP para proveer a la observancia de los mismos.

Las inversiones de este capital mínimo exigido de las administradoras, no excederá de 40% el importe de las inversiones en mobiliario y equipo, en inmuebles, en derechos reales que no sean de garantía o en gastos de instalación, más el importe de las inversiones en el capital de las empresas que les presten servicios complementarios o auxiliares. Además, el importe restante deberá invertirse en acciones de las sociedades de inversión (Siefore) que administren. Estas limitaciones son relativas, ya que la Consar podrá autorizar un porcentaje mayor al establecido para la adquisición de bienes muebles e inmuebles, sin que pueda exceder de 60%. El resto del capital que reciben, miles de millones de pesos, lo obtienen de las aportaciones por el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez que les traslada el IMSS.

La reserva especial que deben conservar las Afore en las Siefore será establecida por la Junta de Gobierno de la Consar mediante disposiciones de carácter general, con base en el capital suscrito y pagado por los trabajadores, tomando en cuenta la naturaleza de cada Siefore. Cuando el monto y la composición de la reserva especial se encuentre por debajo del mínimo requerido, la administradora que la opere estará obligada a reconstituirla dentro del plazo

que determine la Consar, que no podrá exceder de 45 días naturales. Esta reserva deberá constituirse sin perjuicio de integrar la reserva legal establecida por la LGSM.

Adquisición de acciones

El art. 22 condiciona la autorización para que los intermediarios financieros puedan participar en el capital accionario de las administradoras, a cumplir con las leyes financieras aplicables. No se autorizará la participación a un grupo financiero o a las entidades financieras que lo integren, cuando alguna de ellas no cumpla con los niveles de capitalización previstos en los ordenamientos legales mencionados. El precepto brinda la propia concepción de incumplimiento, cuando se encuentren pendientes de cubrir apoyos financieros del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.

El conocimiento y control se alejan definitivamente del ente recaudador de las aportaciones (IMSS) y de la Consar. El trabajador es accionista, como se verá en el contrato con la Afore, de alguna de las cinco Siefore, sin tener posibilidad de intervenir en la administradora que recibe y dispone de los fondos pensionarios.

Artículo 23. La adquisición de acciones de cualquier serie de una administradora o la incorporación de nuevos accionistas a ésta, que implique la participación del adquirente en 5% o más del capital social de dicha administradora, así como la fusión de administradoras, deberán ser autorizadas por la Comisión, siempre y cuando estas operaciones no impliquen conflicto de interés.

La autorización para la adquisición de acciones que representen el 5% o más del capital social de una administradora, también se requerirá para el caso de personas físicas o morales que la Comisión considere para estos efectos como una sola persona, de conformidad con lo que disponga el reglamento de esta ley.

Cuando la adquisición de acciones sea menor al 5% de su capital social, la administradora de que se trate deberá dar aviso a la Comisión con diez días hábiles de anticipación a que surta efectos el acto y proporcionarle la información que ésta determine. Asimismo, una vez efectuada la operación deberá hacerlo del conocimiento de la Comisión.

Estas operaciones son ajenas al conocimiento del trabajador, quien se ha limitado a seleccionar una Afore y celebrar con ésta un contrato, sin posibilidad de conocer o medir el manejo interno de la administradora de sus fondos.

Las administradoras deberán contar permanentemente con un capital fijo (art. 2), sin derecho a retiro totalmente pagado, el cual deberá ser por lo menos igual al capital mínimo exigido que indique la Consar mediante disposiciones de carácter general. Para el supuesto de que ese capital se

redujera por debajo del mínimo exigido, estarán obligadas a reconstituirlo dentro del plazo que determine la Consar, sin que exceda de 45 días naturales. Con el fin de mantener un adecuado balance y equilibrio en los sistemas de ahorro para el retiro, ninguna administradora podrá tener más de 20% de participación en el mercado de los SAR. Sin embargo, la Consar podrá autorizar, previa opinión del Comité Consultivo y de Vigilancia, un límite mayor a la concentración de mercado, siempre que esto no represente perjuicio a los intereses de los trabajadores.

El criterio para estimar personas autorizadas por la Comisión para adquirir acciones que representen 5% o más del capital social de una Afore, está consignado en el Reglamento.

Artículo 5o. Se requerirá autorización previa de la Comisión para que personas físicas o morales adquieran acciones que representen el cinco por ciento o más del capital social de una Administradora.

Para efectos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 23 de la Ley, se considerará como una sola persona a:

- I. La persona moral que sea accionista de una Administradora, las personas físicas o morales que, a su vez, participen directamente en un cinco por ciento o más del capital social de dicha persona moral accionista de la Administradora y a las personas morales subsidiarias de las personas que participen directamente en el capital social de la Administradora, y
- II. El cónyuge o las personas que tengan relación de parentesco civil, por consanguinidad o afinidad dentro de cualquier grado en la línea recta, o hasta el segundo grado en la colateral, con algún accionista de una Administradora.

Esta redacción confusa se presta a diversas interpretaciones, ya que debía excluirse a quienes tengan relación cercana con algún accionista de la Afore.

Órganos de las Afore

La LSAR determina que las administradoras estarán sujetas, como toda sociedad mercantil, a una Asamblea General integrada conforme a los estatutos autorizados. Para cumplir las disposiciones de la Asamblea, de la Ley y de la Consar, contarán con un consejo de administración. Entre sus consejeros, tendrán consejeros independientes, quienes serán expertos en materia financiera, económica, jurídica o de seguridad social; tendrán limitación en su actuación, de tal forma que se les impide tener algún nexo patrimonial con las administradoras; tampoco serán trabajadores de los accionistas que detentan el control o con los funcionarios de dichas administradoras. Los asuntos que se programen en el orden del día deberán ser aprobados por la mayoría de los accionistas y de los miembros del consejo de administración.

Los asuntos que requieren del voto aprobatorio de los consejeros independientes se refieren al programa de autorregulación de la administradora: los contratos que la administradora celebre con las empresas con las que tenga nexos patrimoniales o de control administrativo y los contratos tipo de administración de fondos para el retiro que las administradoras celebren con los trabajadores, los prospectos de información y las modificaciones a éstos. Este último aspecto es muy relevante. La Ley determina que los contratos que se celebren con los trabajadores especificarán su objeto, el tipo de trabajador con el que se celebra conforme a las definiciones contenidas en el art. 3º de la presente Ley, las obligaciones específicas de la administradora, la elección de las sociedades de inversión que haya elegido el trabajador, la estructura y el cobro de comisiones por los servicios prestados, la responsabilidad de la administradora por sus actos y los de las sociedades de inversión que administren, así como la vigencia del contrato y sus causas de terminación.

Para vigilar que los funcionarios y empleados cumplan con la normatividad externa e interna que sea aplicable, cada administradora contará con un contralor normativo responsable. La Afore dotará al contralor de los recursos humanos y materiales que requiera para el buen desempeño de las funciones a su cargo. El contralor será nombrado por la asamblea de accionistas de la Afore, la cual podrá suspenderlo, removerlo o revocar su nombramiento, debiéndose notificar de este hecho a la Consar. Este contralor reportará únicamente al consejo de administración y a la asamblea de accionistas; no está subordinado a ningún otro órgano social ni funcionario de la administradora.

El contralor normativo verificará que se cumpla el programa de autorregulación de la Afore, el cual contendrá las actividades de los principales funcionarios y las normas a las que éstos habrán de sujetarse, así como las acciones correctivas aplicables en caso de incumplimiento. Este programa estará orientado a garantizar el cumplimiento de la normatividad, la eficiente operación de la administradora y la protección de los intereses de los trabajadores, así como a evitar todo tipo de operaciones que impliquen conflictos de interés y uso indebido de información privilegiada. También propondrá al consejo de administración de la administradora modificaciones al programa de autorregulación de la misma, a efecto de establecer medidas para prevenir conflictos de interés y evitar el uso indebido de la información. Además, recibirá los informes del comisario y los dictámenes de los auditores externos para su conocimiento y análisis, e informará a la Comisión mensualmente del cumplimiento de las obligaciones a su cargo, así como en cualquier momento de las irregularidades de que tenga conocimiento en el ejercicio de sus funciones.

El contralor normativo incluirá en el programa de autorregulación su plan de funciones con las actividades de evaluación y las medidas para preservar su cumplimiento; asistirá a las sesiones de consejo de administración de la Afore, de las Siefore y a las sesiones del comité de inversión; participará

con voz, pero sin voto; será responsable por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones previstas en esta Ley, pudiendo ser sancionado, de conformidad con lo previsto en la misma. Ejercerá sus funciones sin perjuicio de las que correspondan al comisario y al auditor externo de la administradora de que se trate, de acuerdo con la legislación aplicable.

Las Afore contratarán auditores externos, que presentarán sus dictámenes a la Afore, y a la Consar la información que ésta les solicite sobre la situación de las entidades financieras, además de las irregularidades graves que encuentren en el desempeño de su labor. Estos auditores serán responsables de las Siefore, les prestarán servicios de administración. Derivado de los contratos celebrados por las Afore con los trabajadores, éstas prestarán servicios de distribución y recompra de acciones representativas del capital de las sociedades de inversión que administren.

Si bien es cierto que en el texto inicial de la LSAR y en sus reformas se ha procurado crear los organismos de control adecuados, no se clarifica si el gasto que implica el órgano de gobierno de las Afore y las Siefore es con cargo al capital inicial de las Afore, de las utilidades de las inversiones con cargo a las empresas mercantiles o de los fondos pensionarios que son salario de los trabajadores.

En un exagerado e indebido exceso, fuera del marco que compete a un reglamento, el Reglamento de la LSAR establece un código moral en el art. 4º, al señalar los requisitos de solvencia moral, así como de capacidad técnica y administrativa que deben satisfacer los consejeros independientes y el controlador normativo de las administradoras. Considera que una persona tiene solvencia moral cuando no esté inhabilitada para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público o en el sistema financiero mexicano; no haya sido condenada por sentencia firme por delito doloso, y goce de reconocido prestigio profesional. En cambio, me parece adecuado el señalamiento de este precepto al determinar el requisito de capacidad técnica y administrativa, experiencia profesional, cuando se tenga cuando menos cinco años en cargos directivos relacionados con la materia financiera, de seguridad social, jurídica o económica; este requisito se acreditará ante la Consar. La Asamblea de Accionistas y el Consejo de Administración serán responsables, en el ámbito de su competencia, de vigilar que las personas designadas cumplan con los requisitos para desempeñar dichos cargos. Sin embargo, el Comité Consultivo y de Vigilancia de la Consar podrá objetar los nombramientos, a su criterio, sin precisar los elementos objetivos que pudiera haber analizado y sin que conste el derecho de defensa de los afectados; simplemente se dice que cuando dichas personas no cumplan con los requisitos señalados en el presente artículo y en las disposiciones de carácter general que para tal efecto emita la Comisión.

Por otra parte, el art. 33 de la LSAR consigna que las Afore deberán cubrir, con cargo a sus ingresos, todos los gastos de establecimiento, organización y demás necesarios para la operación de las Siefore que administren. Las Afore pueden requerir de otras empresas que les presten servicios complementarios, para lo cual, conforme al numeral 34, requieren autorización de la Consar. En caso de tener participación accionaria, estarán sujetas a la regulación y supervisión de la Consar, sin perjuicio de que la administradora sea la responsable de la debida prestación de los servicios, además de ser solidariamente responsable de las sanciones que correspondan a dichas empresas con motivo de su supervisión.

En consecuencia, las Afore responderán directamente de todos los actos, las omisiones y operaciones que realicen las sociedades de inversión que operen, con motivo de su participación en los SAR (art. 35), así como de los actos realizados tanto por sus consejeros, directivos y empleados, como de los realizados por los consejeros y directivos de las sociedades de inversión que administren, en el cumplimiento de sus funciones relativas a los SAR y la operación de la Afore y las Siefore, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales en que ellos incurran personalmente. Cuando hayan cometido actos dolosos contrarios a esta Ley, que como consecuencia directa produzcan una afectación patrimonial a los trabajadores, estarán obligadas a reparar el daño causado, por tanto, responderán directamente de los actos realizados por sus agentes promotores, ya sea que éstos tengan una relación laboral con la administradora o sean independientes. La Consar llevará un registro de los agentes promotores de las administradoras, quienes tendrán que cumplir con los requisitos que señale, y en caso de no hacerlo, la Comisión estará facultada para cancelarlos por incumplimiento (art. 36).

Comisiones

El art. 195 de la LSS autoriza a la Consar a expedir disposiciones administrativas donde autorice mecanismos, procedimientos, formas y términos relacionados con el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, conforme a lo establecido en esta Ley y la LSAR, atendiendo a consideraciones técnicas y asegurando los intereses de los trabajadores. Este ordenamiento no determina el cobro de comisiones, lo que realiza la Ley adjetiva. Se entiende que la naturaleza de una sociedad mercantil es la obtención de ganancias que aquí se denominan *comisiones*, pero que afectan al dinero pensionario de los trabajadores o sus beneficiarios.

Las comisiones se fijan unilateralmente, sin tomar en cuenta los intereses y la opinión del trabajador. La LSAR en su art. 37 determina que el cobro se hará con cargo a la cuenta, conforme a las reglas de carácter general que expida la Consar, y sólo podrán cobrarse mediante cuotas fijas por los servicios que se señalen en el reglamento de esta Ley, y en ningún caso por la adminis-

tración de las cuentas. Sin embargo, se autoriza su cobro por cada una de las sociedades de inversión que opere la Afore.

Las comisiones se determinarán sobre bases uniformes, de manera que se cobren las mismas comisiones por servicios similares prestados en sociedades de inversión del mismo tipo, sin discriminar a trabajador alguno. Éstas serán independientes de los incentivos o las bonificaciones que realicen a las subcuentas de las cuentas individuales de los trabajadores por su ahorro voluntario o por utilizar sistemas informáticos para realizar trámites relacionados con su cuenta individual o recibir información de la misma.

Las comisiones estarán condicionadas a la aprobación de la Junta de Gobierno de la Consar, por lo que las Afore deben presentar la estructura de comisiones para su autorización. Una vez analizada la solicitud, la Junta podrá exigir aclaraciones, adecuaciones o, en su caso, denegar la autorización respectiva si las comisiones sometidas a su autorización son excesivas conforme a los criterios que determine para los intereses de los trabajadores o se encuentran fuera de los parámetros del mercado. La propia Junta de Gobierno de la Comisión emitirá criterios o recomendaciones sobre el nivel y la estructura de las comisiones. Asimismo, deberá resolver expresamente, con fundamento, sobre la autorización solicitada dentro del plazo previsto en el art. 119 de esta Ley. Las nuevas comisiones comenzarán a cobrarse una vez transcurridos 60 días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el DOF cuando se trate de incrementos. En el caso de una disminución de comisiones, éstas podrán aplicarse a partir de que se le notifique la autorización correspondiente a la Afore.

En el supuesto de que una Afore modifique la estructura de sus comisiones, los trabajadores registrados en la misma tendrán derecho a traspasar los recursos de su cuenta individual a otra Afore, siempre que dicha modificación implique un incremento en las comisiones que se cobren al trabajador. Así, se facilita la labor de los promotores que mediante engaños llevan a cabo los cambios, sin conocimiento adecuado del asegurado. Lamentablemente, el derecho al traspaso o retiro de recursos, en caso de una modificación a la estructura de comisiones, deberá preverse en los contratos de administración de fondos para el retiro y en los prospectos de información, de conformidad con lo que establezca al efecto la Comisión.

Siempre que se fusionen dos o más Afore deberá prevalecer la estructura de comisiones más baja, conforme a los criterios que al efecto expida la Junta de Gobierno de la Comisión. En ningún caso, las Afore podrán cobrar comisiones por el traspaso de las cuentas individuales o de recursos entre Siefore, ni por entregar los recursos a la institución de seguros que el trabajador o sus beneficiarios hayan elegido, para la contratación de rentas vitalicias o del seguro de sobrevivencia.

Con la finalidad de que los trabajadores puedan tener información oportuna sobre las comisiones que se cobren con cargo a sus cuentas individuales,

la Comisión deberá informar periódicamente a través de los medios a su disposición las comisiones que cobren las distintas administradoras, procurando que dicha información sea expresada en lenguaje accesible y permita a los trabajadores comparar las comisiones que cobran las distintas afore. Asimismo, la Comisión determinará la forma y los términos en que las Afore deberán dar a conocer a los trabajadores sus estructuras de comisiones.

Por su parte, el Reglamento de la LSAR determina, en términos del art. 37 de la Ley, que las Afore sólo podrán cobrar comisiones por cuota fija a los trabajadores por la expedición de estados de cuenta adicionales a los previstos en la Ley; reposición de documentación de la cuenta individual, y gestión de trámites ante autoridades o instancias distintas a los institutos de seguridad social, exclusivamente relacionados con su cuenta individual, siempre que lo solicite o autorice el trabajador o sus beneficiarios.

Para proteger los recursos de los trabajadores, las Afore sólo podrán cobrar comisiones por cuota fija por el depósito de recursos en las subcuentas de aportaciones voluntarias y complementarias de retiro, cuando los depósitos no se efectúen a través del proceso de recaudación de cuotas y aportaciones. Las comisiones por cuota fija que pretendan cobrar las Afore deberán detallarse por conceptos específicos e incluirse en la estructura de comisiones que sometan previamente a la autorización de la Junta de Gobierno de la Comisión, estando condicionada su procedencia a esta autorización. Las Afore, además de las comisiones que cobren a los trabajadores en términos del art. 37 de la LSAR, podrán percibir ingresos por la administración de los recursos de los fondos de previsión social.

El actuario Alberto Valencia Armas estima que al referirnos al rendimiento de los fondos “se trata de un rendimiento financiero que obtienen las sociedades que invierten, por cuenta de las Afores, los recursos de los trabajadores”. Estos rendimientos varían entre las distintas opciones que hay en el mercado y a lo largo del tiempo; por nivel salarial, “el fondo que llegue a acumular dependerá del nivel salarial de cada trabajador, ya que determina la cantidad que pueda destinar, de manera regular para el ahorro individual”.² Es importante destacar que el sistema no prevé algún mecanismo que proteja la integridad de los fondos en caso de quiebra de las administradoras o de una pérdida súbita y significativa del valor adquisitivo de los fondos, supuesto el último que confrontamos en 2009.

2 Alberto Valencia Armas, *Evaluación y tendencias de los sistemas de pensiones en México*, México, 2009, p. 28.

Contrato con la Afore

El instrumento jurídico fundamental para la estructura del sistema de cuentas individuales que modifica al Seguro Social es el contrato que la Consar ha autorizado a las Afore para que lo celebre con cada trabajador, de tal forma que las disposiciones de la LSS y la LSAR quedan sujetas a este contrato, cuyo estudio analítico merece el mayor cuidado por las violaciones que contiene. Es indispensable conocer su naturaleza y alcances. Para empezar, no está suscrito por un apoderado legal de la sociedad mercantil, sino por un empleado “promotor”.

El primer aspecto es la naturaleza mercantil del contrato. En la Declaración Primera, el trabajador manifiesta que conoce su derecho de elegir libremente la Afore que operará su cuenta individual, así como que este derecho lo está ejerciendo voluntariamente al firmar o plasmar su huella digital en el documento. Asimismo, reconoce de manera expresa que por “la naturaleza de sus inversiones en acciones de la(s) Siefore(s) y de aquellas inversiones que esta(s) última(s) realiza(n) en el mercado de valores, inclusive sobre instrumentos de deuda”, no es posible garantizar rendimientos y que, por tanto, sus inversiones se encuentran sujetas a pérdidas o ganancias que en lo general provienen de fluctuaciones en el mercado. Como bien dice el doctor Ángel Guillermo Ruiz Moreno, esta cláusula del contrato permite que “no se hable nunca de ganancias, al estar sujetas éstas a la libre especulación en el mercado financiero interno (y externo); de suyo más bien se alude a las posibles pérdidas, como está aconteciendo a mediados del complicadísimo año 2008 para la economía y finanzas nacionales e internacionales”.³

El contrato desconoce los derechos más elementales del trabajador, al reconocer que su capital es un capital de riesgo y, por tanto, renuncia expresamente a sufrir pérdidas. Los fondos pensionarios derivan del salario base de cotización, por lo que la cantidad acumulada en la cuenta individual es de su propiedad. La Constitución en su art. 123, fracc. XXVII, destaca que serán nulas las renunciaciones que haga el trabajador, aun cuando consten por escrito, de los beneficios que a su favor consagran las leyes para su protección y auxilio.

Cláusulas sustantivas

A partir de la cláusula segunda, la Afore se adjudica muchas ventajas que disfruta como “beneficios” para el trabajador, como administrar y operar los recursos de su cuenta individual. Es evidente que el trabajador desconoce la forma y los términos de esa prestación de servicios, como la compra y venta

3 Ángel Guillermo Ruiz Moreno, *Las Afore. El sistema de ahorro y pensiones mexicano*, Porrúa, México, 2009, p. 139.

de acciones de las Siefore que la Afore opera, donde actúa en nombre y por cuenta del trabajador, así como los servicios de guarda y administración relativos a tales acciones. En esta cláusula se varía la naturaleza de la cuota que ha recibido la Afore, sin tomar en cuenta que se trata de una contribución y de su naturaleza fiscal; convierte la cuota en una acción mercantil. En la misma cláusula, el trabajador se obliga a pagar, como contraprestación por los referidos servicios, las comisiones autorizadas por la Consar que se determinen en la estructura de comisiones de la Afore, lo que es un absurdo jurídico.

El art. 32 de la LSAR permite a las Afore “prestar a las sociedades de inversión los servicios de distribución y recompra de sus acciones”. Así, como una supuesta obligación para con el trabajador, la Afore administra y opera los recursos de su cuenta individual y paradójicamente le presta los servicios de compra y venta de acciones de las Siefore. La Afore, actuando en nombre y por cuenta del trabajador, le presta también los servicios de guarda y administración relativos a tales acciones; dichos títulos se deben guardar en una institución para el depósito de valores. A cambio de los servicios que absurdamente recibe el trabajador, sin su expreso consentimiento, se obliga a pagar, como contraprestación, una suma no determinada, conocida ni consentida que fija arbitrariamente la Consar en la estructura de comisiones que le propone la Afore.

La cláusula tercera confiere a las Afore, más que facultades específicas, facultades amplísimas para abrir, administrar y operar la cuenta individual del trabajador afiliado al IMSS, de los trabajadores inscritos en el ISSSTE, de trabajadores no afiliados al IMSS o que no estén inscritos en el ISSSTE, o bien que se encuentren sujetos a dos o más regímenes de seguridad social y de trabajadores de las dependencias o entidades públicas de carácter estatal o municipal. Dichas cuentas se sujetarán a las disposiciones de las leyes de seguridad social aplicables y sus reglamentos, así como a lo establecido en los términos previstos en la Ley. Respecto de la subcuenta de vivienda, la Afore deberá individualizar las aportaciones y los rendimientos correspondientes con base en la información que le proporcionen los institutos de seguridad social.

En consecuencia, la Afore recibirá las cuotas y aportaciones de seguridad social correspondientes a las cuentas individuales, de conformidad con las leyes de seguridad social, así como las aportaciones voluntarias y complementarias de retiro, y los demás recursos que en términos de la Ley puedan ser recibidos en las cuentas individuales. Esto ha permitido que las Afore, dependientes de instituciones financieras —en su mayoría extranjeras—, hayan recibido en 2009 una cantidad muy superior al billón de pesos, del dinero pensionario de los trabajadores.

En beneficio de las sociedades mercantiles y no de los trabajadores, como veremos en la cláusula quinta, las Afore individualizarán las cuotas y aportaciones destinadas a las cuentas individuales, así como los rendimientos derivados de la inversión de las mismas y enviarán, por lo menos dos veces al año al domicilio que le indique el trabajador o al mal llamado trabajador

no afiliado, sus estados de cuenta y demás información sobre sus cuentas individuales y el estado de sus inversiones, así como las comisiones cobradas por la Afore y las Siefore que administre. Así, se permite un mayor control a las Afore al prestar servicios de administración a las Siefore.

Como entidades financieras las Afore deben conservar el dinero recibido y retenerlo, por lo que se les autoriza, cuando el trabajador no solicite pensión, a operar y pagar, bajo las modalidades que la Consar autorice, los retiros programados, así como pagar los retiros parciales con cargo a la cuenta individual, en los términos de las leyes de seguridad social. El beneficio para las instituciones financieras se redondea, ya que recibirán por medio de los seguros que manejan los recursos para la contratación de una renta vitalicia o de un seguro de sobrevivencia, en su caso, que, desde luego, hayan elegido los derechohabientes.

La cláusula cuarta se relaciona con las obligaciones del trabajador, quien pagará a la Afore comisiones por los servicios que ésta le preste, sin que se precise el monto o la forma en que el asegurado pueda calcularlas, ya que lo deja a la determinación de las Afore, cuya estructura sólo merecerá la autorización de la Consar. En consecuencia, este contrato consensual queda sin que el asegurado pueda convenir el pago, sin ser suficiente la remisión a los términos previstos por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Otra obligación confusa que se le impone al trabajador es informar a la Afore cualquier modificación de la información consignada en el contrato. La poca claridad hace pensar que el contrato podría ser modificado o que en el supuesto de duda el asegurado puede manifestarla para aclaración; para ello, deberá usar el formato de usos múltiples que la Afore ponga a su disposición. Sin duda, primero debe solicitar el formato y después la modificación a la información; esto merece mejor redacción.

En esta cláusula el trabajador se obliga a actualizar su domicilio particular y/o el domicilio donde desea que le sea enviada la correspondencia relacionada con su cuenta individual, el número de teléfono de su domicilio y el cambio de beneficiarios sustitutos. Al respecto, deberá designar beneficiarios respecto de la subcuenta de aportaciones voluntarias, subcuenta de aportaciones complementarias de retiro y/o subcuenta de ahorro a largo plazo.

La actualización de la información deberá comunicarse a la Afore a más tardar dentro de los 30 días naturales siguientes a la realización de los hechos que dieron origen a la modificación.

La cláusula quinta es la joya de la corona porque consolida el cambio jurídico de la cuota para convertir las operaciones legales de este seguro en parte del Derecho Mercantil. Consigna que el sujeto contratante otorga a la Afore comisión mercantil "para que ésta por su cuenta y orden, adquiera, enajene, mantenga en custodia y administre acciones representativas del capital social de las Siefore operadas por la Afore, relacionadas con la cuenta individual". Por tanto, el fondo pensionario se convierte en acciones de la Siefore, cuya

suerte desconoce el contratante que se convierte en comitente. El destino de las acciones dependerá del juego de la Bolsa de Valores, por lo que, conforme a la declaración primera del trabajador, estará sujeto tanto a pérdidas como a utilidades. Además, de acuerdo con la cláusula segunda, la Afore adquirirá acciones de alguna de las Siefore que opera, así como la guarda y custodia de las mismas.

El dinero producto de la operación de compraventa de acciones queda sujeto, por lo que se refiere al trabajador, al valor que en el momento de su pensión valgan sus acciones; por lo que hace a la Siefore, con su propio dinero, lo invierte en otras acciones autorizadas por la Consar y en valores gubernamentales, sin que implique mayor beneficio para el trabajador que el posible incremento del valor de las acciones que la Afore en su nombre, por su cuenta y riesgo adquirió de su propia Siefore.

Para completar la lesión al trabajador, éste confiere de manera específica la facultad de "hacerse representar por la Afore, en las asambleas de las Siefore, de las que sea accionista, respecto de las acciones que son objeto del servicio de guarda y administración". A fin de que el trabajador pueda asistir a alguna asamblea tiene que manifestar por escrito su interés, cuando menos con ocho días hábiles de anticipación a la celebración de la misma, con lo que se violan las reglas de mandato; es suficiente que el poderdante se presente, en este caso sin registrar acciones, por lo indebido de la facultad que se arroga la Afore, en vista del registro accionario que debe llevar la Siefore, para que pueda asistir con pleno derecho como accionista minoritario, hablar y votar. Además, en caso de no asistir a la asamblea, el trabajador tiene el derecho de solicitar por escrito a la Afore los acuerdos adoptados, los cuales deberán proporcionarse de inmediato, sin que se fije plazo para ello.

Paradójicamente, la cláusula concluye: "La ejecución de la Comisión Mercantil se apegará en todo momento a la Ley, las Leyes de Seguridad Social, al Reglamento y al presente contrato, así como las demás disposiciones que les sean aplicables." Ni la LSS, ni la LSAR o algún reglamento regulan la comisión mercantil que es un acto de comercio.

La cláusula sexta contiene las supuestas instrucciones que da el trabajador a la Afore cuando se le niega la posibilidad de conocer y discutir previamente éstas, así como el total del contrato por adhesión. Sin embargo, estas instrucciones se limitan a "las operaciones y servicios materia de este contrato, (que) podrán ser escritas, verbales, electrónicas o bien transmitidas a través de fax".

La siguiente cláusula tiene especial importancia ya que la Afore puede a su elección determinar cualquiera de las cinco Siefore que opera, conforme la "distinta composición de su cartera, atendiendo a los diversos grados de riesgo y a los diferentes plazos, orígenes y destinos de los recursos invertidos en ellas". Para completar el cuadro siniestro se dice que el trabajador tendrá

derecho a invertir los recursos de su cuenta individual en cualquiera de las Siefore operadas por la Afore, determinando la inversión de recursos de una subcuenta de manera exclusiva o de diversas subcuentas conjuntamente, "siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en el respectivo prospecto de información", expedidos por la Afore y que "los recursos que pretende invertir correspondan a la subcuenta o subcuentas respecto de las cuales la Siefore que elija esté autorizada para recibir e invertir recursos y no se exceda de los límites de inversión que determine la Consar".

La cláusula décima se refiere a la figura del traspaso de la cuenta individual del trabajador a otra Afore, una vez transcurrido un año calendario, contado a partir de que el trabajador se registró o de la última ocasión en que se haya ejercitado este derecho. Asimismo, podrá hacerlo cuando se modifique el régimen de inversión o comisiones, o la Afore entre en estado de disolución, se fusione con otra o el trabajador elija una administradora que cobre comisiones más bajas, conforme a los criterios y las condiciones previstos en el Reglamento de la Ley. En el caso de fusión entre Afore, el derecho de traspaso sólo corresponderá al trabajador que se encuentre registrado en la Afore fusionada. Esta cláusula sigue los lineamientos de la LSAR y su Reglamento, como sigo observando, al determinar que en el caso de modificaciones al régimen de inversión de alguna de las cinco Siefore operadas por la Afore, el trabajador no tendrá derecho al traspaso cuando la modificación derive de una orden de la Consar, o bien cuando este organismo haya modificado las disposiciones generales a las que debe sujetarse el régimen de inversión, de conformidad con lo establecido por la Ley. La culminación al supuesto derecho condiciona al trabajador a que presente su solicitud de traspaso a la Afore que haya elegido, quien será la responsable del seguimiento y de efectuar los trámites correspondientes para el traspaso. Asimismo, el trabajador podrá solicitar el traspaso de su cuenta individual de una Afore a otra a través de medios electrónicos.

Estos elementos deben valorarse. Si derivado de una comisión mercantil la Afore adquirió acciones de una de sus Siefore, además de contar con su guarda y custodia, los fondos de la cuenta individual no son en numerario, sino en papel accionario. Por tanto, es un absurdo y una incongruencia que el contrato se refiera a la "cuenta individual"; en todo caso, el derecho se limita a determinar otra Afore para que reciba las acciones y, en lo sucesivo, el fondo de su cuenta se entregue a la nueva. Siempre debe estimarse que los formatos de los contratos y su contenido son los mismos en cualquier Afore, por tratarse de un contrato por adhesión autorizado por la Consar.

Las aportaciones voluntarias, conforme a la cláusula decimotercera, pueden referirse a aportaciones complementarias de retiro y/o aportaciones a largo plazo. Los recursos de las subcuentas serán invertidos en la o las Siefore elegidas por el trabajador, siempre que estén operadas por la Afore que recibió la cuenta.

La cláusula decimoctava reconoce el derecho del trabajador a designar y cambiar a los beneficiarios sustitutos, por escrito, para el caso de que faltaren los beneficiarios legales previstos en la LSS, con lo que deja la posibilidad de que pueda ser cualquier persona. En este caso, deberá precisar el porcentaje de los recursos acumulados en su cuenta individual que le corresponderá a cada uno de ellos. En su defecto, los recursos se asignarán por partes iguales entre todos los beneficiarios sustitutos designados.

Como hemos visto, en cada seguro las prestaciones que se consignan se cubrirán con las aportaciones que en cada caso se otorguen; en riesgos de trabajo, corresponde al patrón y en los otros, la cuota es tripartita. Esto nos ha permitido asegurar, con base en la LSS, que, por una parte, se tiene derecho a la pensión y, por otra, a reclamar el monto total de la cuenta individual. La cláusula vigésimo tercera establece que el trabajador o sus beneficiarios podrán solicitar por escrito el monto de su cuenta total o en parcialidades en los supuestos de incapacidad permanente, invalidez permanente, muerte, cesantía en edad avanzada, vejez, matrimonio, desempleo y demás previstos en las leyes de seguridad social, para lo cual deberán presentar la solicitud ante los institutos de seguridad social a efecto de que emitan una resolución sobre la procedencia del retiro. La condición es absurda ya que debe tratarse de un trámite sencillo, sin necesidad de que el Instituto emita una resolución y que ésta sea favorable. La Afore tiene obligación, cuando la solicitud sea admitida, de ordenar a la Siefore el retiro de los fondos, sin que puedan ser los "que procedan" y de enterarlos. La única situación sujeta a resolución es cuando los beneficiarios lo soliciten, en términos de las leyes de seguridad social. Los recursos de la subcuenta aportaciones voluntarias podrán permanecer invertidos durante el plazo que el trabajador o sus beneficiarios consideren conveniente.

Respecto a las disposiciones correspondientes, la Afore responderá ante la Consar, el Instituto y el trabajador, directamente de todos los actos, las omisiones y operaciones que ella realice; además, lo hará por las Siefore y por los promotores a su servicio (cláusula vigésimo cuarta), pero no será responsable por actos previos al traspaso de los recursos de la cuenta individual a la misma, ni por actos posteriores a dicho traspaso que tengan su origen o se deriven de tales actos previos.

Cláusulas de procedimiento

En la cláusula decimoséptima se cumple con lo dispuesto por la normatividad aplicable; reconoce el derecho del trabajador a recibir de la Afore información sobre el estado de su cuenta individual y el estado de sus inversiones; seguramente se refiere a las acciones que adquirió a nombre y por cuenta del trabajador de la Siefore. El envío se efectuará a la dirección de correo electrónico señalado por el trabajador, por lo menos dos veces al año.

En caso de no contar con correo electrónico se enviará de manera impresa al domicilio indicado por éste. Se podrá suspender el envío cuando la dirección proporcionada no exista o éste no tenga su domicilio en el lugar indicado. La Afore conservará el estado de cuenta a disposición del trabajador y se le entregará sin costo alguno, recabando previamente la información actualizada relativa a su dirección de correo electrónico. La Afore está obligada a remitir al domicilio del trabajador el estado de cuenta final cuando haya sido traspasada a otra Afore o por disposición de la totalidad de los recursos. Desde luego, el trabajador podrá requerir en cualquier tiempo a la Afore le informe el estado de su cuenta, de conformidad con lo previsto en el art. 7º, fraccs. I y II, del Reglamento y con las disposiciones generales emitidas por la Consar; estas últimas varían constantemente y carecen de valor jurídico.

Como vimos al analizar este seguro, se le confiere a la Afore, en forma absurda, la guarda y administración de las acciones representativas del capital social de las Siefore, para lo cual deberá mantener depositados dichos títulos en una institución para el depósito de valores concesionada de acuerdo con la *Ley del Mercado de Valores*. La Afore se obliga a efectuar en relación con dichas acciones los actos necesarios para la conservación de los derechos que los referidos títulos confieran o *impongan* al trabajador, olvidando que los derechos se ejercen, no se imponen.

Cuando haya que ejercer derechos o efectuar exhibiciones de cualquier clase en relación con las acciones respecto de los cuales la Afore esté prestando el servicio de guarda y administración, se estará sujeto a lo siguiente (cláusula vigésima):

- a) La Afore ejercerá el derecho de opción o preferencia, en caso de que el trabajador haya girado instrucciones, siempre que haya sido provista de los recursos suficientes por lo menos con dos días hábiles antes del vencimiento del plazo señalado para efectuar el pago del derecho opcional o de preferencia.
- b) La Afore ejercerá los derechos patrimoniales correspondientes a las acciones por cuenta del trabajador y acreditados a éste en la subcuenta de aportaciones voluntarias, para ser aplicadas a la compra de la acción o las acciones representativas del capital social de la Siefore correspondiente.
- c) A pesar de que no corresponde al trabajador sino al IMSS entregar los recursos, el contrato pretende que éstos sean entregados por el trabajador, con lo cual busca se exima a la Afore de cualquier responsabilidad por la inejecución de los actos mencionados, lo que constituye un absurdo y un atentado.

La cláusula vigésimo segunda constituye un atentado más en contra del trabajador, a favor de la Afore y de la Siefore, al atribuirse la facultad, a nombre del asegurado, de que la sociedad de inversión le recompre al precio de valuación vigente el día en que se lleven a cabo las operaciones correspondientes, hasta el 100% de su tenencia de acciones en que se encuentren invertidos sus recursos. Queda clara la falsedad de los estados de cuenta que se envían al asegurado, ya que el valor pensionario dependerá de la valuación que determine el mercado de valores, en relación con las acciones que la Afore haya adquirido e invertido, cuando tenga derecho a gozar de una pensión o alguna otra prestación en los términos de la LSS. Esta recompra se llevará a cabo en el supuesto de alguna modificación al régimen de inversión de la Siefore o a las comisiones que cobre la Afore; cuando el trabajador solicite el traspaso de su cuenta individual en los plazos que la Consar establezca, lo que lo sujeta a los caprichos de ese organismo; cuando solicite el traspaso de su cuenta individual asignada a otra Afore; cuando solicite el retiro de recursos de su subcuenta de aportaciones voluntarias y/o aportaciones a largo plazo, y cuando la Afore entre en estado de disolución y liquidación el orden de prelación que le corresponda como accionista de la Siefore respectiva, lo que lo llevaría a un tiempo no precisado.

Para los supuestos anteriores se requiere que el trabajador presente una solicitud a la Afore y que ésta sea calificada de procedente, en cuyo caso la Afore efectuará la compra de las acciones en un plazo máximo de 30 días naturales. El trabajador podrá por una sola vez autorizar que se prorrogue el plazo primeramente citado por otros 30 días naturales.

Esta cláusula acentúa las maniobras que en colusión llevan a cabo las Afore y las Siefore contra el trabajador y su familia.

Comisiones

La cláusula vigésimo primera está dedicada a la fijación y el cobro de comisiones en contra del trabajador, con cargo a su cuenta individual, las cuales atenderán los parámetros que establezcan las reglas que expida la Consar. Con la finalidad de que se promueva un mayor rendimiento neto a favor de los trabajadores, las comisiones por administración sólo podrán cobrarse como un porcentaje sobre el valor de los activos administrados. La Afore únicamente podrá cobrar cuotas fijas por los servicios señalados en el Reglamento de esta Ley y en ningún caso por la administración de las cuentas. Las comisiones serán percibidas por la Afore en los términos previstos por la Ley y su Reglamento.

Sin embargo, la Afore podrá cobrar comisiones distintas por cada una de las Siefore que opere, pero en ningún caso podrá cobrar comisiones por el traspaso de la cuenta individual o por transferencia de recursos entre Siefore,

ni por entregar los recursos a la institución de seguros que el trabajador o sus beneficiarios elijan para la contratación de rentas vitalicias o del seguro de sobrevivencia.

Las comisiones sobre activos se cobrarán por mensualidades vencidas a más tardar dentro de los primeros cinco días hábiles del mes inmediato posterior al periodo de que se trate, mediante un cargo directo a la cuenta individual, siempre y cuando se hayan registrado en las cuentas individuales los movimientos de utilidad. Las comisiones sobre flujos se han suprimido por una reforma a la LSAR. Las comisiones por cuota fija se cobrarán directamente al trabajador solicitante, en el momento en que se preste el servicio de que se trate, conforme a los supuestos analizados y en ningún caso se podrán descontar de la cuenta individual, ni de las aportaciones destinadas a la misma; en todo caso, la Afore aplicará los descuentos previstos.

Vigencia del contrato

En la cláusula vigésimo quinta se determina que el contrato será por tiempo indefinido (indeterminado) y surtirá efectos legales a partir de la inscripción de su solicitud (contrato) en la Base de Datos Nacional SAR; a partir de ese momento se tendrá por manifestado el consentimiento de la Afore para obligarse en los términos del contrato.

El contrato podrá darse por terminado cuando el trabajador traspase sus recursos a otra Afore, a partir del momento en que la Empresa Operadora inscriba el registro en la nueva Afore elegida; también cuando se cancele la cuenta individual, con motivo del retiro de la totalidad de sus recursos, como consecuencia de la adquisición de una renta vitalicia y seguro de sobrevivencia por agotarse los seguros programados, o en una sola exhibición en el supuesto en que no cubra el número de semanas de cotización requeridas para que opere su pensión en los términos de la LSS. Cuando la Afore proceda a la disolución o liquidación los recursos se traspasarán a la nueva Afore que elija el trabajador, y en los casos de fallecimiento, presunción de muerte del trabajador, en los supuestos previstos en el CCF y los Códigos Civiles de las diversas entidades federativas y del Distrito Federal en que no sea necesaria la ausencia, o bien en el supuesto de declaración legal de la ausencia.

Tribunales competentes en el contrato

Para cualquier controversia derivada de la interpretación, el cumplimiento o la ejecución del presente contrato, las partes se someten de manera expresa a las leyes aplicables y los tribunales competentes del Distrito Federal o de la ciudad capital de la entidad federativa en que tenga establecido su domicilio el trabajador y que se encuentra señalado en la solicitud de registro y/o de

traspaso correspondiente, renunciando al fuero o jurisdicción que por cualquier causa pudiera corresponderles, sin perjuicio del derecho que la *Ley de Protección* otorga al trabajador y sus beneficiarios para presentar sus reclamaciones ante la Condusef. Las reclamaciones se podrán presentar ante la Condusef en sus oficinas centrales o en sus delegaciones regionales, o, en su caso, estatales o locales de ubicación más próxima a su domicilio, dentro del término que no exceda de tres meses contados a partir de que suscite el hecho que motiva la reclamación. En este caso, la Afore estará obligada a sujetarse únicamente al procedimiento conciliatorio previsto en los arts. 68, 69, 70 y 71 de la *Ley de Protección*, quedando a libre elección de cada una de las partes el sometimiento o declinación del arbitraje ante la Condusef.

En realidad no estamos en presencia de una autoridad que pueda resolver alguna controversia, ya que las facultades se agotan en una conciliación que puede o no agotarse en un arbitraje. Si bien la Afore puede haber dado lugar a la lesión de derechos contra el trabajador, el contrato realiza esfuerzos inútiles para darle una naturaleza jurídica distinta a la esencia del sistema, pero no puede olvidarse que en cada caso se trata de un trabajador o sus beneficiarios, situación diversa a la de una persona que no es trabajador. También hay que tomar en cuenta que no se trata de aportaciones que de su peculio haya contratado, sino de cuotas obligatorias por la LSS que se aportan tripartitamente. El origen de la aportación es el salario base de cotización, y éste es el salario, como lo determinan los arts. 5 A, fracc. XVIII, y 27 de la LSS y el ordenamiento legal del art. 123 A, fracc. XXIX, de la Constitución, además de ser considerado por el CFF en su art. 2º, fracc. II. Por tanto, debe partirse de la base de que el contrato analizado además de ser nulo de pleno derecho conforme a la fracc. XXVII, inciso e) de la Ley Fundamental, no puede lesionar derechos laborales ni darle un giro a la contribución que atenta contra su naturaleza.

Debe considerarse que todos los actos jurídicos que realiza el trabajador deben estar en el marco de protección que emana del art. 123 constitucional, de la Ley reglamentaria a este precepto y de los principios establecidos en la LSS, originados en las fraccs. XIV y XXIX de la Constitución. Cualquier norma que salga de este marco es violatoria y los actos que puedan imponerse o ser voluntarios de los trabajadores adolece de nulidad de pleno derecho.

Son 13 las garantías constitucionales que se relacionan con el seguro social y no pueden trastocarse. A partir del enunciado del art. 123, al estimar la dignidad del trabajador: "Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley", por lo que sólo con base en estas normas el Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán "Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo." Conforme a estas normas se protege a las mujeres durante el embarazo (fracc. V) para impedirles realizar "trabajos que exijan un

esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación”, lo que se relaciona con el seguro de maternidad y de guarderías. Si bien la protección al salario se refiere al mínimo, sus normas protectoras se aplican a todos los salarios, y sin distinción de sexo o nacionalidad, queda exceptuado de embargo, compensación o descuento, excepto lo determinado en la LFT, por lo que deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal (fracc. X), sin tener permitido hacerlo efectivo con mercancías, ni con vales, fichas o cualquier otro signo representativo con que se pretenda sustituir la moneda. Los accidentes y las enfermedades de trabajo tienen un trato especial, no referido en la fracc. XXIX; se hace responsable a los empresarios de accidentes o enfermedades (fracc. XIV) “sufridas con motivo o en ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten”, por lo que “deberán pagar la indemnización correspondiente, según que haya traído como consecuencia la muerte o simplemente incapacidad temporal o permanente para trabajar, de acuerdo con lo que las leyes determinen. Esta responsabilidad subsistirá aún en el caso de que el patrono contrate el trabajo por un intermediario”. Como resultado de esta disposición, al “liberar” la LSS de responsabilidad al patrón cuando inscriba a sus trabajadores, es obvio que el pago de la pensión no puede confiarse a empresas aseguradoras privadas.

Estos aspectos me parecen fundamentales para sostener la nulidad del contrato analizado en esta parte. Por si lo anterior no fuera convincente, recordemos que la fracc. XXVII establece la nulidad de pleno derecho, por lo que no obligarán a los contrayentes, aunque se expresen en el contrato, aquellas condiciones que “constituyan renuncia hecha por el obrero de las indemnizaciones a que tenga derecho por accidente del trabajo y enfermedades profesionales”, así como “todas las demás estipulaciones que impliquen renuncia de algún derecho consagrado a favor del obrero en las leyes de protección y auxilio a los trabajadores”. La única duda a que nos lleva el contrato es a cuál autoridad debe dirigirse el trabajador frente a algún acto derivado de este contrato nulo, celebrado con la Afore.

En cuanto a los tribunales competentes, por tratarse de un asunto meramente laboral, es procedente aplicar la fracc. XX a efecto de que las “diferencias o los conflictos entre el capital y el trabajo, se sujetarán a la decisión de una Junta de Conciliación y Arbitraje”. La LSS, en consonancia, respeta el mismo principio en los arts. 294 y 295.

He destacado los peligros que representa el contrato para el trabajador, a pesar de la publicidad desplegada por las Afore ante la situación difícil de un mercado de valores que no le garantiza una pensión decorosa. Las grandes utilidades, como veremos, son para las Afore y las Siefore, y las pérdidas son contra los trabajadores, quienes sólo en 2008 resintieron una minusvalía de 90 mil millones de pesos, que sólo será pérdida para los que se pensionen en pocos años. Además de que entre 75 y 80% del capital de las Siefore se destina a la compra de papel de gobierno y se ha convertido en deuda pública.

El panorama de las Afore se concentra en un billón treinta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y nueve millones de pesos, en valor de mercado, lo que equivale a un billón cincuenta mil ciento noventa y seis millones de pesos, con treinta y nueve puntos dos millones de cuentas. El rendimiento neto es de 5.35%. Los traspasos acumulados son más de un millón de pesos; la inversión en renta variable nacional es de 7.7%; la inversión en renta variable internacional, de 4.69%; la inversión en deuda privada nacional, de 15.05%; la inversión en deuda internacional, de 4.69%, y la inversión en valores gubernamentales, de 67.69%. Estas cifras son administradas por 17 Afore.

Panorama general del SAR (cifras al cierre de julio de 2009)

Concepto	Datos
	Datos al cierre de julio de 2009
Recursos administrados por las Afore*	\$1 039 459 millones (valor a mercado) \$1 050 196 millones (valor a costo)
Cuentas administradas por las Afore	39.2 millones
Rendimiento neto promedio en el sistema	5.35%
Traspasos acumulados	\$1 693 603
Afore	17
Inversión en renta variable nacional*	7.7%
Inversión en renta variable internacional*	3.98%
Inversión en deuda privada nacional*	15.95%
Inversión en deuda internacional*	4.69%
Inversión en valores gubernamentales*	67.69%

* Incluye recursos de PensionISSSTE.

Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro (Siefore)

La LSS hace mención de las sociedades de inversión. Por su parte, la LSAR, responsabiliza a las Afore de la constitución, la administración y el manejo de estas sociedades de inversión y precisa las reglas para la constitución de las Afore y de las Siefore. Como hemos visto, en el contrato celebrado con la Afore, autorizado por la Consar, el trabajador autoriza a la Afore, mediante un contrato de comisión mercantil, a celebrar por su cuenta y riesgo un contrato de compraventa de acciones de alguna Siefore. Por tanto, las regulaciones de esta sección brindan oportunidad para hacer imperar sus preceptos sobre las determinaciones de un contrato leonino. Sin embargo, mientras subsistan estos instrumentos debemos tomar en cuenta al revisar la presente sección que las inversiones y los rendimientos se refieren a las ganancias que obtienen las Siefore de esa operación, sin que impliquen ventaja alguna para el derechohabiente por

... las altas comisiones que cobran las administradoras de fondos de pensión no sólo disminuyen la rentabilidad que podrían obtener los trabajadores, sino que se transforman en un mecanismo adicional de extracción de riqueza del trabajador mediante su ahorro para el retiro, y del Estado, por las diversas ventajas que pudiese obtener al administrar directamente estos recursos, pero tendrán que pagarlos como deuda pública. Todo ello sin que este sistema incentive el aumento de la cobertura. Lo que se cuantifica es que ésta ha caído y que la causa principal es la falta de creación de empleos en el contexto de un débil crecimiento económico. La tendencia que se avizora sería la imposibilidad de lograr una mayor cobertura si el empleo protegido no aumenta, si la rentabilidad se ubica sólo como producto de las rentas financieras y no de la competitividad productiva y si el derecho a la seguridad social sigue atado al mercado laboral, con poca creación de empleos formales con un alto incentivo a la informalidad.⁴

La LSS deja el cumplimiento de las normas sustantivas a la LSAR. En su art. 39 reconoce que las Siefore, administradas y operadas por las Afore, "tienen por objeto invertir los recursos provenientes de las cuentas individuales que reciban en los términos de las leyes de seguridad social". Podrán invertir las aportaciones destinadas a fondos de previsión social, las aportaciones voluntarias y complementarias de retiro que reciban de los trabajadores y patrones, así como los demás recursos que en términos de esta Ley pueden ser depositados en las cuentas individuales.

4 Berenice Ramírez López, *op. cit.*, p. 272.

La autorización de la Consar (art. 40) será otorgada de manera discrecional, oyendo primero la opinión de la SHCP. Los solicitantes presentarán propuestas económica y jurídicamente viables, con el proyecto de estatutos sociales; un programa general de operación y funcionamiento de la sociedad, que cumpla con los requisitos que establezca la Consar y las escrituras constitutivas; las reformas, que deberán ser aprobadas, previo a su inscripción en el Registro Público de Comercio, para lo cual le proporcionarán copia certificada del testimonio de las actas de asamblea y, cuando proceda, testimonio notarial en el que conste su protocolización.

Estas sociedades de inversión deberán conformarse como sociedades anónimas, de capital variable y utilizar en su denominación, o a continuación de ésta, la expresión "Sociedad de Inversión Especializada en Fondos para el Retiro" o su abreviatura "SIEFORE". No deberán utilizar en su denominación expresiones en idioma extranjero o el nombre de alguna asociación religiosa o política, ni utilizar símbolos patrios o religiosos que sean objeto de devoción o culto público. El capital mínimo exigido de la sociedad que establezca la Consar, que aportará la Afore, estará íntegramente suscrito y pagado. El capital se representa por acciones de capital fijo que sólo pueden transmitirse previa autorización de la Consar, a menos que se transmitan a la Afore que las opere. Las Siefore no estarán obligadas a constituir el fondo de reserva a que se refiere el art. 20 de la LGSM.

La administración de esta singular sociedad dependiente estará a cargo de los mismos integrantes del Consejo de Administración de la Afore que las opere, con lo que se consolida el que sean no solidariamente responsables, sino una entidad que la Afore utiliza con un doble propósito legal: eludir responsabilidades y llevar a cabo con el dinero pensionario una operación de compraventa de sus propias acciones que les permita una mayor ventaja económica. Como resultado, la Afore y sus socios participan en forma exclusiva en el capital social fijo de las sociedades de inversión. En ningún caso la participación accionaria de las administradoras en el capital fijo de las sociedades de inversión que operen podrá ser inferior a 99% de la parte representativa del capital social fijo. En cambio, en el capital variable únicamente participarán los trabajadores que inviertan sus recursos mediante la aplicación del contrato de comisión mercantil, que se han dejado a la guarda y custodia de las Afore.

En caso de aumento de capital las acciones se pondrán en circulación, sin que rija el derecho de preferencia establecido por el art. 132 de la LGSM. Las sociedades de inversión podrán adquirir las acciones que emitan, procediendo a la disminución de su capital variable de inmediato. Podrán mantener acciones en tesorería, que serán puestas en circulación en la forma y los términos que señale el consejo de administración. La fusión de sociedades debe llevarse a cabo cumpliendo con la *Ley de Sociedades Mercantiles y Operaciones de Crédito*, en la forma que determine la Afore, previa autorización de la Consar.

Estas sociedades de inversión deberán contar con un comité de inversión cuyo objeto será determinar la política y estrategia de inversión y la composición de los activos de la sociedad, así como designar a los operadores que ejecuten la política de inversión (art. 42). El comité deberá integrarse cuando menos con un consejero independiente, el director general de la administradora que opere a la sociedad de inversión y los demás miembros que designe el consejo de administración de la sociedad de inversión de que se trate. No podrán ser miembros de este comité aquellas personas que sean miembros del comité de riesgos de la sociedad, con excepción del director general de la administradora, quien deberá participar en ambos comités. La designación de los operadores de las sociedades de inversión deberá contar con el voto favorable de los consejeros independientes que sean miembros del comité de inversión. El comité sesionará cuando menos una vez al mes, y sus sesiones no serán válidas sin la presencia de cuando menos un consejero independiente. Se levanta acta pormenorizada, la cual deberá estar a disposición de la Consar.

Para complicar el sistema se determina que las sociedades de inversión contarán con un comité de riesgos, cuyo objetivo será administrar los riesgos a que se encuentren expuestas, así como vigilar que la realización de sus operaciones se ajuste a los límites, las políticas y los procedimientos para la administración de riesgos aprobados por su consejo de administración, en cuidado a la inversión del capital de las Siefore, producto de la venta de sus acciones a la Afore, con la cuota aportada por el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez (art. 42 bis). La composición de este nuevo comité deberá ser determinada por la Consar mediante disposiciones de carácter general. En todo caso deberán ser integrantes del mismo un consejero independiente y uno no independiente de la sociedad de inversión de que se trate, los cuales no deberán ser miembros del comité de inversión de la misma sociedad de inversión, y el director general de la administradora que opere a la sociedad de inversión. Con esto se incrementan los gastos que repercutirán contra el fondo pensionario, al afectar el valor de las acciones.

Parece un exceso que llega al absurdo que se establezca en la LSAR que el régimen de inversión "deberá tener como principal objetivo otorgar la mayor seguridad y rentabilidad de los recursos de los trabajadores" (art. 43), quienes están a expensas del valor que a sus acciones determine el mercado de valores. Este régimen de inversión tenderá a incrementar el ahorro interno y el desarrollo de un mercado de instrumentos de largo plazo acorde con el sistema de pensiones.

El mismo art. 43 ordena, sin atender sus disposiciones, que los recursos, cuyo curso hemos visto, se canalicen preponderantemente a través de su colocación en valores por fomentar:

- a) La actividad productiva nacional.
- b) La mayor generación de empleo.
- c) La construcción de vivienda.
- d) El desarrollo de infraestructura estratégica del país.
- e) El desarrollo regional.

Si el más de un billón de pesos recibido por las Afore y trasladado a las Siefore se invirtiera en los cinco rubros anotados, disminuiría la crisis económica tan acentuada en estos días, se atenuaría el desempleo y se alentaría la producción en el campo. Sin embargo, como el precepto se contradice, estos fondos "deberán operar con valores, documentos, efectivo y los demás instrumentos que se establezcan en el régimen de inversión que mediante reglas de carácter general establezca la Consar, oyendo previamente la opinión del Banco de México, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y del Comité Consultivo y de Vigilancia, debiendo ser favorable esta última". Podemos ver cómo el sistema se sigue complicando de tal forma que impide a los trabajadores conocer el destino y los efectos de su fondo pensionario, por lo que es importante recordar la nulidad del sistema.

Las suposiciones de esta Ley podían contenerse en la LGSM al tratarse de regulación al régimen de inversión de los instrumentos derivados del manejo de sus acciones; los instrumentos de deuda, emitidos por personas jurídicas distintas al Gobierno Federal, deberán estar evaluados por empresas calificadoras de reconocido prestigio internacional. Las acciones deberán reunir los requisitos de bursatilidad y las demás características que establezca la Consar. Sin perjuicio de lo anterior, la Consar, oyendo la opinión del Comité de Análisis de Riesgos, podrá prohibir la adquisición de valores cuando a su juicio representen riesgos excesivos para la cartera de las sociedades de inversión. Igualmente, la Consar, basándose en la opinión del Comité de Análisis de Riesgos, podrá emitir reglas para recomponer la cartera de las Siefore cuando se incumpla el régimen de inversión y fijará el plazo en que éstas deben recomponer su cartera de valores.

La Consar queda facultada para establecer límites a las inversiones cuando se concentren en un mismo ramo de la actividad económica, o se constituyan riesgos comunes para una Siefore. También podrá implantar dentro del régimen de inversión los requisitos que deberán reunir los trabajadores para invertir en determinadas Siefore, sin conocimiento del movimiento ni de las disposiciones de la Consar.

Cuando una Siefore haya adquirido valores entre los porcentajes previstos en el régimen de inversión que le sea aplicable y con motivo de variaciones en los precios de los valores que integran su activo no cubra o se exceda de tales porcentajes, podrá solicitar a la Consar autorización para mantener temporalmente el defecto o exceso correspondiente, la cual se otorgará con la condición de que no lleven a cabo nuevas adquisiciones o venta de los va-

lores causantes de los mismos hasta en tanto se restablezcan los porcentajes aplicables. Las Siefore que incumplan con el régimen de inversión autorizado deberán recomponer su cartera en el plazo que fije la Consar, teniendo en cuenta la opinión del Comité de Análisis de Riesgos, el que no podrá ser mayor de seis meses, a fin de ajustarse al régimen ordenado por la Ley. En caso de que una Siefore haya adquirido un valor que cumpla con los requisitos de calificación y posteriormente se degrade la calificación de éste, podrán conservar dicho valor hasta su amortización.

El Comité de Análisis de Riesgos tendrá por objeto el establecimiento de criterios y lineamientos para la selección de los riesgos crediticios permisibles de los valores que integren la cartera de las sociedades de inversión. Estará integrado por tres representantes de la Consar, uno de los cuales a designación de ésta, lo presidirá, dos de la SHCP, dos del Banco de México, dos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y dos de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. La valuación de los documentos y valores susceptibles de ser adquiridos por las Siefore se sujetará a los criterios técnicos que establezca un Comité de Valuación, el cual estará integrado por tres representantes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, uno de los cuales, a designación de ésta, lo presidirá, dos de la SHCP, dos del Banco de México, dos de la Consar y dos de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Dicho Comité dará a conocer los criterios de valuación, así como los procedimientos y las técnicas a que deberán sujetarse las administradoras en la valuación de los valores que integran las carteras de las sociedades de inversión.

El art. 44 de la LSAR establece que en el supuesto de minusvalías, que para el trabajador accionista se traduce en pérdidas,

... derivadas del incumplimiento al régimen de inversión autorizado por efectos distintos a los de valuación, o en el caso de falta de presentación de la solicitud a que se refiere el primer párrafo de este artículo, la administradora que opere la sociedad de inversión de que se trate, las cubrirá con cargo a la reserva especial constituida en los términos previstos en esta ley, y en caso de que ésta resulte insuficiente, lo deberá hacer con cargo a su capital social.

Por su parte, el art. 47 contiene una serie de supuestos que no tienen conexión. En primer lugar, se refiere a que las Afore podrán operar varias Siefore, las que tendrán una distinta composición de su cartera, atendiendo a los diversos grados de riesgo y a los diferentes plazos, orígenes y destinos de los recursos invertidos en ellas. Sin perjuicio de lo anterior, las Afore estarán obligadas a operar, en todo caso, una Siefore cuya cartera estará integrada fundamentalmente por los valores cuyas características específicas preserven el valor adquisitivo del ahorro (de las acciones) de los trabajadores, así como por aquellos otros que a juicio de la Junta de Gobierno se orienten al propósito mencionado.

En un segundo supuesto, las Siefore podrán recibir e invertir recursos correspondientes a una subcuenta en forma exclusiva, o a diversas subcuentas conjuntamente, y deberán establecer en los prospectos de información los requisitos que mediante reglas de carácter general determine la Consar que deberán cumplir los trabajadores para que sus recursos se inviertan en la Siefore de que se trate, de conformidad con su régimen de inversión, lo que les está impedido, ya que la Afore determina a cuál de las cinco Siefore van los recursos de la compraventa de acciones.

En un tercer supuesto, a pesar de los supuestos elementos de valoración, se sanciona cuando los trabajadores no cumplan con los requisitos exigidos para invertir en una Siefore, con lo que los recursos se deberán traspasar a otra Siefore en la que sea admisible la inversión de los recursos, conforme a las reglas que al efecto expida la Consar. Esta Comisión podrá determinar, mediante disposiciones de carácter general, el porcentaje máximo de recursos de cada subcuenta de los trabajadores que podrá invertirse en las Siefore que por su naturaleza así lo ameriten.

Los trabajadores tendrán derecho a invertir sus recursos en cualquiera de las Siefore que sean operadas por la Afore que les lleve su cuenta individual, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en el respectivo prospecto de información, los recursos que pretendan invertir correspondan a la subcuenta o subcuentas respecto de las cuales la Siefore que elijan esté autorizada para recibir e invertir recursos, y no excedan los límites de inversión que, en su caso, determine la Consar.

Sin que se pueda entender plenamente su finalidad, de nuevo la LSAR incurre en diversos supuestos que parten de prospectos e información elaborados por las Siefore que someterán a la Consar, "que revelen razonablemente la información relativa a su objeto y a las políticas de operación e inversión" que siguen (art. 47 bis). Estos prospectos deberán precisar, por lo menos, los trabajadores a que esté dirigida y los requisitos que deben cubrir éstos, o en su caso, la mención de que estará dirigida a la inversión de fondos de previsión social; la subcuenta o subcuentas cuyos recursos puedan ser invertidos en la Siefore; "la advertencia sobre los riesgos que pueden derivarse de la clase de portafolios y carteras que compongan la sociedad de inversión, atendiendo a las políticas y los límites que se sigan conforme a las disposiciones aplicables", los que repercutirán en contra del capital pensionario, como las llamadas "minusvalías"; el sistema de valuación de las acciones, de conformidad con los criterios expedidos por el Comité de Valuación.

Todavía sin hacer comprensible el precepto, los prospectos de información señalarán los trabajadores afiliados con derecho a que la Siefore, a través de la Afore, les recompre las acciones que ha mantenido en resguardo, a precio de valuación hasta 100% de su tenencia accionaria, siempre sujeto a regulaciones de la Consar que operan en contra de los trabajadores, cuando tengan

—conforme a la LSS— derecho a gozar de una pensión o a alguna otra prestación que les otorgue el derecho a disponer de los recursos de su cuenta individual, así como cuando se presente una modificación a los parámetros de inversión previstos en el prospecto, o a la estructura de comisiones.

Por otra parte, el art. 47 bis prohíbe a los trabajadores ejercer este derecho —que nunca han tenido— cuando por orden de la Consar la Afore haya modificado el régimen de inversión de alguna de las Siefore que opera; cuando la Consar haya modificado las disposiciones a las cuales debe sujetarse el régimen de inversión; cuando designe la Afore en caso de que no hubieren firmado contrato; cuando soliciten el traspaso de su cuenta individual, en los plazos que la Consar establezca, y cuando la Afore que opera a la Siefore de que se trate se fusione, si la Afore es la sociedad fusionada.

Los prospectos de información contendrán los supuestos en los que los recursos podrán retirarse o traspasarse, así como los derechos y las obligaciones de los titulares de los mismos, y señalarán en forma detallada el concepto e importe de las comisiones que se cobrarán y explicarán la forma de cálculo.

Finalmente, el art. 47 bis se refiere a los prospectos de información y ordena que las Siefore elaboren

... folletos explicativos que traten cuando menos los puntos básicos de los prospectos de información, los que deberán estar redactados en forma clara, sencilla y en un lenguaje accesible a los trabajadores. Tanto los prospectos como los folletos explicativos deberán estar en todo tiempo a disposición de los trabajadores, en las administradoras [Afore] y sociedades de inversión [Siefore].

[...]

La Comisión, al autorizar los prospectos de información a que se refiere este artículo, podrá ordenar, en atención al tipo de recursos de cada subcuenta que se pretendan invertir, que se incorporen a los prospectos las previsiones respecto a las políticas de inversión, liquidez, selección y diversificación de activos, revelación de información, calidad crediticia, riesgo de mercado y bursatilidad que considere prudente para la mayor protección de los trabajadores.

La elección de la Afore por los trabajadores o por la persona que contrate la inversión de recursos de un fondo de previsión social, implica su aceptación expresa de los prospectos de información emitidos por las Siefore, sin conferir procedimiento alguno para aclarar u oponerse.

Prohibiciones de las Siefore

Se prohíbe a las Siefore (art. 48) llevar a cabo la emisión de obligaciones; recibir depósitos de dinero; adquirir inmuebles, que sólo puede hacer la Afore; dar u otorgar garantías o avales; gravar de cualquier forma su patrimonio,

por estar integrado con acciones que han vendido a los trabajadores, por conducto de la Afore; adquirir o vender las acciones que emitan a precio distinto al que resulte de aplicar los criterios que dé a conocer el Comité de Valuación; practicar operaciones activas de crédito, excepto préstamos de valores y reportos sobre valores emitidos por el Gobierno Federal, así como sobre valores emitidos, aceptados o avalados por instituciones de crédito, los cuales se sujetarán a las disposiciones que expida el Banco de México. En cuanto a las operaciones de reporto o de préstamo de valores que en su caso se autoricen, las sociedades de inversión únicamente podrán actuar como reportadoras o prestamistas.

Además, no podrán obtener préstamos o créditos, salvo aquellos que reciban de instituciones de crédito, intermediarios financieros no bancarios y entidades financieras del exterior, para satisfacer la liquidez que requiera la operación normal de acuerdo con lo previsto en esta Ley. La obtención de estos préstamos y créditos se sujetará a las disposiciones de carácter general que expida el Banco de México, a propuesta de la Comisión. Asimismo, no podrán adquirir el control de empresas que se reserva a la Afore, ni celebrar operaciones en corto, con títulos opcionales, futuros y derivados y demás análogas a éstas, así como cualquier tipo de operación distinta a compraventas en firme de valores, salvo cuando lo autorice el Banco de México, a propuesta de la Comisión.

Las prohibiciones impiden celebrar operaciones que de manera directa o indirecta tengan como resultado adquirir valores, por más de 5% del valor de la cartera de la sociedad de inversión de que se trate, emitidos o avalados por personas físicas o morales con quienes tenga nexos patrimoniales o de control administrativo. En casos excepcionales y atendiendo a las consideraciones del caso concreto, la Consar podrá autorizar la adquisición de dichos valores hasta por 10%.

Se ha admitido que las Siefore adquieran valores extranjeros, siempre que estén autorizados por la Consar. Estos valores no deberán exceder 20% del activo total de la sociedad de inversión, porcentaje que se va incrementando conforme a las exigencias de las instituciones financieras en manos de extranjeros. El art. 22 del Reglamento de la LSAR ordena que las Siefore respetarán el límite máximo del parámetro de control de riesgo que determinen en su prospecto de información y que se ajuste a las disposiciones que en materia de régimen de inversión expida la Consar. En caso de que se encuentre fuera del parámetro de riesgo aplicable, por causas imputables a la Afore que la opera, y no por efectos de la variación de precios, deberá cubrir las minusvalías que se presenten con cargo a la reserva especial, y si ésta resulta insuficiente, con cargo a su capital social, de conformidad con las reglas que emita la Consar.

Liquidación de las Afore y de las Siefore

Conforme el art. 188 de la LSS, la Afore es la responsable de la inversión de los recursos de las cuentas individuales de los trabajadores. Esta responsabilidad implica la conformación de un marco jurídico que brinde protección absoluta a los trabajadores en su calidad de propietarios de las acciones que forman parte del capital de las Siefore.

Los aportes relativos a la subcuenta de retiro y de la cesantía en edad avanzada y vejez, los patrones contribuyen con 5.5 por ciento del sueldo base de cada trabajador, con lo que el total de su aportación (incluida la de vivienda) llega a 10.15 por ciento. Los trabajadores contribuyen únicamente con 1.125 por ciento de su propio sueldo y el Estado complementa con 0.225 por ciento para la cesantía y vejez, más 5.5 por ciento de un salario mínimo como cuota social.⁵

El art. 199 de la LSS establece que la disolución y liquidación de las Afore y Siefore se sujetará a la legislación aplicable, así como a las disposiciones administrativas que expida la Consar, para salvaguardar los derechos de los asegurados. La LSAR en su art. 56 señala condiciones para la disolución y liquidación de estas sociedades anónimas de capital variable, aun cuando remite a los capítulos X y XI de la LGSM y, según el caso, al capítulo I del título VII de la *Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos*. Los jueces están obligados a oír la opinión de la Consar, previo a la declaración de concurso mercantil. El cargo de síndico o liquidador corresponderá a alguna institución de crédito. La Consar ejercerá, respecto a éstos, las mismas funciones de vigilancia que tiene atribuidas en relación con las Afore y podrá solicitar la declaración de concurso mercantil en las condiciones y los casos previstos por la LGSM.

En el caso de disolución, la Consar deberá tomar todas las medidas necesarias para la protección de los intereses de los trabajadores. Antes de proceder a la disolución y liquidación, se traspasarán los recursos de las Siefore que administre a la cuenta concentradora que el IMSS tendrá abierta a su nombre en el Banco de México. Los recursos de esta cuenta concentradora se invertirán en valores o créditos a cargo del Gobierno Federal y otorgarán el rendimiento que determinará la SHCP, la cual establecerá las demás características de esta cuenta (art. 75).

El traspaso de esos recursos a otra Afore se realizará de conformidad con las disposiciones que expida la Consar, salvaguardando los derechos de los trabajadores, sin perjuicio del derecho de éstos para elegir la Afore

5 *Ibidem*, p. 25.

a la que se traspasará su cuenta individual y la Siefore para invertir sus recursos.

Como señala el distinguido actuario Alberto Valencia Armas, antes de la liquidación de estas empresas,

Sin duda es importante conocer la evolución de las comisiones, aunque para los ahorradores es más relevante el rendimiento que resulta de restar esas comisiones a la rentabilidad de las inversiones. Al respecto y con datos también de Consar (2008) se advierte que el rendimiento neto real que han obtenido los trabajadores en forma acumulada desde el inicio del sistema y que Consar denomina tasa de rendimiento neto observado (TRNO), durante el periodo de 2001-2007 se ha reducido de 3.63 a 2.97 por ciento, por lo que, en términos generales, los trabajadores han recibido prácticamente 40 por ciento del rendimiento obtenido por las Siefores.⁶

Empresas operadoras

Por disposición de la LSAR los fondos de los trabajadores que no hayan elegido administradora serán enviados, después del plazo de cuatro años de vigencia del ordenamiento, a una sociedad de *inversión*, Siefore, que constituye una persona jurídica diferente a la administradora, Afore. El Reglamento de la LSAR varía la disposición al conferir a la Consar una facultad no prevista en las leyes del Seguro Social y de los SAR (art. 35), al facultarla para enviar a la Afore que determine los recursos de los trabajadores que no elijan Afore. Con tal motivo, la Consar atenderá la eficiencia de las Afore, su situación financiera, su ubicación geográfica y los rendimientos de las Siefore que operen, buscando el balance y equilibrio del sistema, a fin de que coadyuve a proteger los derechos de los trabajadores. Las empresas operadoras ordenarán por cuenta y orden del IMSS la transferencia de los recursos de la cuenta concentradora a las instituciones de crédito liquidadoras, para su entrega a las administradoras designadas por la Consar.

Las empresas operadoras notificarán a los trabajadores las transferencias de recursos que se realicen, mediante el envío a los patrones de una lista de los nombres de los trabajadores cuyos recursos fueron objeto de la operación mencionada. Las Afore receptoras de los recursos deberán exhibir en sus oficinas una lista de los nombres de los trabajadores cuyos recursos les fueron asignados. La Afore receptora de la cuenta deberá aplicar a los recursos que le sean transferidos las mismas condiciones de contratación y comisiones vigentes establecidas para las demás cuentas que tenga

6 Alberto Valencia Armas, *op. cit.*, p. 25.

registradas, operaciones que le resultan ajenas al trabajador que optó por no seleccionar Afore.

Se da participación a las empresas operadoras como instituciones condicionantes de la selección que efectúe la Consar, al conferirles la facultad de ordenar por cuenta y orden del IMSS la transferencia de los recursos de la cuenta concentradora a las instituciones de crédito liquidadoras, para su entrega a las Afore. Con esta disposición se complica el sistema ya que la empresa ordenadora actúa como mandante del IMSS. La orden se da a una nueva figura, que son las empresas liquidadoras y éstas hacen la transferencia a las Afore que determine la Consar.

Ante este panorama complicado, el trabajador que no haya seleccionado Afore se ve sustituido en su determinación por dos organismos públicos, el IMSS y la Consar, así como por dos organismos privados, las empresas operadoras y las instituciones de crédito liquidadoras. Norahenid Amezcua sostiene:

Todos aquellos trabajadores que no han optado por una Administradora de Fondos para el Retiro (Afore), por la fuerza serán enviados a una Afore. Nada de pensar, de conciencia, de rebeldía. No importa que se violente a la Ley del Seguro Social (LSS) y la del Sistema de Ahorro para el Retiro (LSAR), por tanto a la Constitución, y hasta a los principios del derecho. Son entre 2.5 a tres millones de asegurados, quienes disfrutaban de los beneficios de la cuenta concentradora (quizá más ante las deficiencias en la afiliación de las Afores). Pero su libertad es negada por normativas inferiores: el Reglamento de la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro (RLSAR) y la circular de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) 27-1. Es una masa gigantesca de dinero que las Afores no iban a permitir que quedaran libres de sus comisiones. Pero siendo tan exitosas y formidables las Afores, ¿por qué se tiene que usar la fuerza para que los trabajadores entren a ellas?

En resumen, debe valorarse que el trabajador asegurado celebrará tres contratos de carácter mercantil; uno con la Afore de su elección, para la administración de los fondos derivados de las cuotas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y dos con la aseguradora privada, para el pago de las pensiones, de renta vitalicia y de sobrevivencia, conforme a los cálculos que en cada caso se efectúen conforme a la Ley.

Contingencia	Tipo de pensión	Instituciones
Riesgos de trabajo	• Incapacidad permanente total • Incapacidad permanente parcial • MUERTE → Pensión de viudez → Pensión de orfandad → Pensión de ascendientes	Administra Otorga IMSS Aseguradora IMSS Aseguradora IMSS Aseguradora IMSS Aseguradora IMSS Aseguradora
*Invalidez *Vida	• Invalidez • MUERTE → Pensión de viudez → Pensión de orfandad → Pensión de ascendientes	IMSS Aseguradora IMSS Aseguradora IMSS Aseguradora IMSS Aseguradora
*Cesantía en edad avanzada *Vejez	• Pensión • Pensión	Afore Aseguradora Afore Aseguradora

El esquema muestra algunos problemas que afectan:

- La naturaleza del contrato de seguro, de carácter mercantil y a cuyas regulaciones se condiciona la pensión de los asegurados y sus beneficiarios.

- Los derechos de los trabajadores asegurados, al sacarlos del ámbito laboral de protección para hacerlos parte de una negociación mercantil que les resulta ajena.
- La dependencia de las prestaciones que por Ley corresponden a los derechohabientes sujetas a la suerte que tenga un contrato de seguro.
- La intermediación tanto del IMSS como de las Afore implica un doble manejo administrativo.
- Las cuotas de los trabajadores por el cobro de diversas comisiones, tanto de las administradoras como de las aseguradoras.

Los contratos que los trabajadores asegurados y, en su caso, sus beneficiarios celebren tanto con las instituciones privadas de seguro como con las Afore tienen carácter mercantil, regulados por la LSS, como ordenamiento sustantivo y las disposiciones que norman a estas instituciones financieras. Las Afore transfieren el capital a las sociedades de inversión a efecto de que éstas lleven a cabo las inversiones correspondientes, conforme a la Ley y las determinaciones de la Consar para el retiro.

El sistema es una colusión de intereses que sujeta al trabajador y a sus beneficiarios a los resultados de una inversión que puede dar pérdidas o utilidades en el mercado de valores, como se consigna en las declaraciones de los trabajadores al firmar los contratos con las Afore. Con razón señaló José Ángel Conchello Dávila, de grata memoria, en un artículo publicado en *El Universal*:

Ayer se cumplió un año de haber iniciado la privatización de las pensiones del Seguro Social. Este primer año de ajuste y reajuste le da la razón a quienes se opusieron a esta privatización pues por un lado se está creando un tremendo poderío económico en manos de la banca extranjera que estos tecnócratas se empeñan en negar confiando en la bondad de los inversionistas americanos, y se ha prefigurado, dibujado en el horizonte, que las pensiones que reciban todos aquellos que ganan menos de tres salarios mínimos no van a alcanzar ni para darles un salario mínimo del día en que se retiren.- 1. Creación de un torvo poderío económico sobre la industria lo puede ver quien quiera que haya leído sobre la desaparición de Afores, la consolidación de dos o más Afores, y el hecho de que gigantes financieros gringos sean dueños de dos o más Afores al mismo tiempo. Allá en Chile, desde el año de 1990, los expertos denunciaron que las AFP de aquel país tenían tal poder que nombraban y despedían a los directores de empresas en las que había invertido, fueran bancos, industrias o comercios; que esas AFP estaban dictando la política de las empresas en las que habían invertido, con lo cual resultaba que los ahorros de los obreros chilenos estaban sirviendo para que administradoras extranjeras manejaran la economía de aquel país. Ante esa situación recuerdo a Ovidio cuando

dijo: "No te rías, cambiando de nombre, de ti habla la fábula."- 2. En la otra punta del asunto están las pensiones de los asegurados. Estas pensiones dependerán de los rendimientos de las sociedades de inversión, que a un año de comienzo pretenden hacernos creer que el rendimiento de los ahorros obreros anualizado es de 21% nominal. Usted puede estar seguro de que esa afirmación es falsa pero ya hasta el gobierno salió en defensa de la mentira. (Incluso el señor Peters, presidente de las Afores, se atrevió a decir que el rendimiento de las inversiones de las Siefores era superior al rendimiento de los demás instrumentos de inversión. Esperan que sigamos creyendo en aquella gran trampa de que allá en Chile el rendimiento de los fondos de inversión de los obreros llegó a ser hasta de 19% arriba de la inflación, sin que nadie haya aclarado que eran fondos especialmente protegidos por el gobierno precisamente con propósitos de hacer creer que, por milagro de la Escuela de Economía de Chicago, el dinero de los obreros rendía más que el dinero de los campesinos o que el de los comerciantes). Sin embargo, al aceptar que este primer año sus inversiones dieron un rendimiento de 21% nominal, están aceptando que el obrero perdió dinero.- En este año, según cifras oficiales, la inflación ha sido de 15% y, por tanto, para mantener el poder de compra que usted ha entregado a una Afore necesitaba tener 15% más. Eso sería para salir "tablas", ni perder, ni ganar. En consecuencia, la ganancia sería de 6% al año. Pero, ¡mucho ojo!: esa no es la utilidad de lo que usted le entregó a la Afore. No señor, es la utilidad de lo que ellos le apuntaron en su cuenta. Si usted recuerda que de cada peso que le descuentan para el retiro, las Afores le quitan 25% y sólo le apuntan en su cuenta 75 centavos, el rendimiento que le dan es sobre ese monto.- Repito para que seamos más claros. Si un Afore le cobra (contra lo que marca la ley) el 1.7% de su salario básico como comisión de flujo, simplemente por aceptarle su dinero, le está cobrando la cuarta parte de lo que usted está aportando y sólo le apunta en su cuenta el resto; o sea, 75 centavos de cada peso. Sobre ese resto le dan ese orgulloso 21% que dicen que tuvieron, es decir, le dan 16 centavos, los cuales se los agrega usted a los otros 75 centavos originales. Al final de un año va a tener 91 centavos. ¡Menos de lo que puso a principio de año!- Pero eso no es todo, si la inflación fue de 15%, usted debía tener al menos 115 centavos para quedar a mano con lo que metió al principio, o sea, que ni siquiera conservó usted lo que metió a la Afore en ese primer año. Salió "cajeado" casi con más de un 25%. Por eso es que al final de la carrera, si es que vive y cotiza durante 1,250 semanas, su cuenta individual no alcanzará ni para darle un salario mínimo de pensión vitalicia. Sin embargo, este gobierno y sus tecnócratas y sus banqueros y sus intelectuales están muy contentos del resultado. Dios les dé lo que merezcan.

A continuación se presenta información reciente sobre las Afore y Siefore.

Cuentas administradas por las Afores
(Cifras al cierre de julio de 2009)

Afore	Trabajadores registrados ¹	Trabajadores asignados ²	Cuentas totales	
			Número de cuentas	Porcentaje del total
Afirme				
Bajío	39 242	673 870	713 112	1.8
Ahorra				
Ahora	2 337	360 492	362 829	0.9
Argos	22 266	13 682	35 948	0.1
Azteca	214 713	786 112	1 000 825	2.6
Banamex	5976 698	233 713	6 210 411	15.8
Bancomer	3 685 272	806 570	4 491 842	11.4
Banorte				
Generali	2 642 264	891 574	3 533 838	9.0
Coppel	1 143 650	174 302	1 317 952	3.4
HSBC	1 139 001	515 055	1 654 056	4.2
Inbursa	1 223 038	2 120 951	3 343 989	8.5
ING	3 942 538	1 106 148	5 048 686	12.9
Invercap	874 849	499 226	1 374 075	3.5
Metlife	270 502	957 189	1 227 691	3.1
Principal	1 500 262	1 368 420	2 868 682	7.3
Profuturo				
GNP	2 653 562	442 547	3 096 109	7.9
Scotia	64 934	15 279	80 213	0.2
XXI	1 526 486	1 346 230	2 872 716	7.3
Total	26 921 614	123 113 60	39 232 974	100.0

- 1 Registrados: Trabajadores que se registraron en alguna Afore. Incluye trabajadores independientes y cotizantes al ISSSTE.
- 2 Asignados: Trabajadores que no se registraron en alguna Afore y la Consar los asignó a una, de acuerdo con las reglas vigentes.

Afore	Recursos administrados por las Afore			
	Recursos de los trabajadores		Capital de las Afore ³	Total de recursos administrados por las Afore
	RCV ¹	Ahorro voluntario y previsión social ²		
Afirme Bajío	4 215.3	16.1	62.9	4 294.3
Ahorra Ahora	1 154.1	0.4	27.6	1 182.1
Argos	634.0	59.7	18.9	712.7
Azteca	10 092.9	4.4	172.6	10 269.9
Banamex	179 410.4	575.0	1 825.9	181 811.3
Bancomer	153 770.2	8 274.2	1 329.4	163 373.7
Banorte Generali	63 348.8	82.4	610.7	64 041.9
Coppel	16 317.6	5.1	169.3	16 492.0
HSBC	32 288.5	18.0	327.0	32 633.6
Inbursa	103 336.4	251.9	1 022.8	104 611.1
ING	126 676.4	189.6	1 069.9	127 935.9
Invercap	40 480.3	77.4	340.4	40 898.1
Metlife	21 033.1	69.9	231.7	21 334.8
Pension ISSSTE	52 679.6	0.0	971.8	53 651.4
Principal	41 026.4	28.2	362.4	41 417.0
Profuturo GNP	107 124.9	208.1	1 086.0	108 419.0
Scotia	2 858.7	13.6	46.8	2 919.2
XXI	62 601.9	292.6	566.5	63 461.0
Total	1 019 049.7	10 166.8	10 242.4	1 039 458.9

Bono de Pensión ISSSTE ⁴	Vivienda ⁵	Total de recursos registrados en las Afore
21.5	2 213.4	6 529.2
0.7	699.4	1 882.3
89.6	286.0	1 088.3
81.5	4 922.5	15 273.9
4 501.3	84 545.2	270 857.8
3 663.7	73 969.7	241 007.1
1 321.9	31 872.7	97 236.5
96.8	8 431.2	25 020.0
672.8	15 675.3	48 981.7
1 487.2	43 858.9	149 957.3
3 215.3	61 387.7	192 538.9
289.8	15 865.2	57 053.0
1 335.3	11 243.3	33 913.4
137 064.7	87 714.0	278 430.0
1 057.5	20 611.2	63 085.7
2 683.3	48 582.2	159 684.6
14.4	1 511.7	4 445.3
2 024.4	29 252.7	94 738.1
159 621.7	542 642.3	1 741 722.9

Montos calculados con los precios de las acciones de las Siefore registrados en la Bolsa Mexicana de Valores el 31 de julio de 2009.

1 Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez de trabajadores cotizantes al IMSS y al ISSSTE. Incluye los fondos de Retiro del SAR 92 de los trabajadores cotizantes al IMSS y los recursos del SAR ISSSTE.

2 Incluye Aportaciones Voluntarias, Aportaciones Complementarias de Retiro, Ahorro a Largo Plazo, Ahorro Solidario de Trabajadores Cotizantes al ISSSTE y 7 777.1 millones de pesos administrados por las Afores de recursos de Previsión Social de entidades públicas y privadas.

3 Recursos de las Afore que, conforme a las normas de capitalización, deben mantener invertidos en las Siefore.

4 Conforme a la Ley del ISSSTE, las Afore llevan el registro del valor actualizado del Bono de Pensión ISSSTE en las cuentas individuales de los trabajadores.

5 Los recursos de Vivienda son registrados por las Afore y administrados por el Infonavit y por el FOVISSSTE.

La suma de las cifras parciales puede no coincidir con el total por redondeo.

Rendimientos brutos de las Siefore Básicas¹
(Últimos 36 meses. Al cierre de julio de 2009)

Afores	Siefore Básica 1	Siefore Básica 2	Siefore Básica 3	Siefore Básica 4	Siefore Básica 5
Afirme Bajío	8.05	7.24	7.15	6.78	7.58
Ahorra Ahora	7.07	4.22	3.99	3.20	3.75
Argbs	7.77	7.32	7.51	7.54	7.19
Azteca	6.59	6.98	6.69	6.85	6.32
Banamex	9.71	7.36	7.11	6.98	7.06
Bancomer	7.83	5.99	5.85	5.38	5.29
Banorte Generali	5.76	6.33	5.11	5.29	5.41
Coppel	7.80	7.93	7.64	7.78	7.37
HSBC	7.94	7.23	7.33	7.08	7.14
Inbursa	8.12	7.58	7.42	6.94	6.78
ING	9.20	8.27	8.08	7.94	7.52
Invercap	6.78	6.06	5.40	4.83	4.68
Metlife	7.67	6.87	6.42	6.10	6.08
Principal	8.17	7.19	6.83	6.30	5.76
Profuturo GNP	7.30	7.84	8.17	7.74	5.67
Scotia	10.48	7.91	7.58	7.55	7.91
XXI	8.73	7.98	7.37	6.75	6.29
Promedio del sistema²	8.29	7.26	7.00	6.71	6.32

Cifras preeliminares.

NOTA: Debido a que Ahorra Ahora inició operaciones en agosto de 2006, Scotia en noviembre de 2006 y Argos en diciembre de 2006, el cálculo de los rendimientos tomó en cuenta las cifras



**Comisiones de las Siefore Básicas
(Al cierre de julio de 2009)**

Afore	Porcentaje anual sobre saldo
Afirme Bajío	1.70
Ahorra Ahora	1.94
Argos	1.17
Azteca	1.96
Banamex	1.75
Bancomer	1.47
Banorte Generali	1.71
Coppel	1.94
HSBC	1.77
Inbursa	1.18
ING	1.74
Invercap	1.93
Metlife	1.89
Principal	1.94
Profuturo GNP	1.92
Scotia	1.88
XXI	1.45



observadas para cada Afore desde su inicio de operaciones y para los meses restantes se consideró la metodología descrita en la Circular CONSAR 71-1.

1 Es el rendimiento que obtuvieron los activos de las Siefore antes del cobro de comisiones.

2 Promedio ponderado por el valor de los activos netos de las Siefore.

NOTAS: Las cifras son porcentajes de rendimientos nominales en términos anualizados. El rendimiento observado en el pasado no es garantía del desempeño futuro.

De los 39 millones de cuentas de ahorro para el retiro que operan las Afore sólo están activas 14 millones, que representan aproximadamente 40%, mientras el resto están inactivas, con cotizaciones irregulares o nulas.

El presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore) dijo que las cuentas inactivas —aquellas a las que sólo se aporta una o dos veces al año o no tienen ninguna cotización— crecen al doble que las activas. Señaló que esto es resultado de un crecimiento más acelerado del empleo informal, en comparación con el formal, y de que no se crea el millón de plazas laborales necesarias cada año, no obstante que durante el sexenio la nómina creció un poco más respecto a los años previos.

Las cuentas inactivas crecen como el doble que las activas, en un año seguramente tendremos un millón más de inactivas y 500 mil más de activas, y ese es un tema que está pendiente aunque (el tema del empleo) va en decremento; cada año se agregan 1.5 millones de nuevas cuentas de trabajadores que se dan de alta en el IMSS y entran por primera vez al sector formal, pero muchos dejan de laborar a los tres o cuatro meses.

En evidente, como afirma el reconocido actuario Carlos Soto Pérez:

El sistema de ahorro para el retiro mediante cuentas individuales, no tomó en cuenta la precariedad laboral, los bajos sueldos, el empleo informal y los periodos de desempleo impiden a los trabajadores realizar los aportes necesarios para tener una pensión suficiente. No van a lograr un monto suficiente de ahorro para financiar una pensión garantizada (mínima) en su vejez; otros trabajadores ni siquiera alcanzarán a cumplir con el requisito de 1 250 semanas de cotización que como mínimo se requieren para tener derecho a una pensión garantizada.⁷

El programa del primer empleo no ha funcionado y a la economía mexicana le falta ese crecimiento. Se requiere la revisión integral del sistema, como condición para que la economía prospere y aumenten las plazas laborales. Concretadas las reformas a las leyes del ISSSTE y del SAR, así como la aplicación del régimen de inversión, es evidente su fracaso y lo que sigue para lograr mejores pensiones es cambiar todo el sistema a fin de que las aportaciones de los trabajadores, patrones y del gobierno puedan traducirse en incremento de fuentes de trabajo, abatimiento de la economía informal y aumento del monto de las pensiones.

El principal problema de las malas pensiones es la mala administración y el elevado costo de las comisiones. Además, por los pésimos servicios se desalienta la cotización y las personas no asalariadas dentro del sector informal no cotizan. Como puede verse, la solución está en mejorar los servicios y las pensiones para que patrones y trabajadores coticen con base en su salario real.

7 Citado en Berenice Ramírez López, *op. cit.*, p. 37.

En los países con el sistema de cuentas individuales, incluido Chile, se trabaja en buscar alternativas donde con base en un esquema de aportes fiscales se avance a una seguridad social integral en la que se incorpore a todos los trabajadores activos y a las personas que están en la economía informal. Eso es lo que tendremos que estar trabajando con congresistas, sindicatos, partidos políticos, para lograr que se den estas aprobaciones, pues los 14 millones de cuentas activas actuales podrían duplicarse con este esquema.

Se pone de manifiesto que los resultados previsibles apuntan hacia una necesaria revisión y eventual adecuación de la estructura del sistema, al igual que al establecimiento de un mecanismo de evaluación periódico, confiable y transparente a cargo de una institución que tome en cuenta, en forma equilibrada, los aspectos financieros y sociales que involucra.⁸

Se debe buscar que todos los mexicanos estén en el sistema del Seguro Social porque, de lo contrario, el gobierno tendrá que aportar el dinero fiscal, como se hace actualmente en algunos estados. Es más sano que esa parte la ponga el gobierno y parte el trabajador, a esperar que éste tenga 65 años de edad y darle un donativo. Hay que entender que:

Los resultados del sistema de ahorro para el retiro en México son muy similares a los observados en Chile, Argentina y Uruguay, aunque todavía no tan notorios en sus deficiencias, ya que estamos a diez años de su entrada en operación... Un estudio del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE, 2006) determina que establecer una pensión mínima universal (668 pesos mensuales en 2005) para la población de 70 años o más ayudaría a eliminar la pobreza de las personas de la tercera edad y sería fiscalmente sostenible en el próximo medio siglo bajo una trayectoria razonable de crecimiento económico. El costo se incrementaría paulatinamente de 0.35 por ciento a un máximo de 0.37, 0.52 o 0.8 por ciento del PIB, si el crecimiento de éste es de 4, 3 o 2 por ciento, respectivamente.⁹

8 Alberto Valencia Armas, *op. cit.*, p. 19.

9 *Ibidem*, pp. 39 y 49.

Sexta parte

Organización del Instituto Mexicano del Seguro Social. Medios de defensa

15 Organización y facultades del IMSS

.....

El título cuarto de la *Ley del Seguro Social* (LSS) está dedicado a la organización y el funcionamiento del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en su doble función: como organismo encargado de proporcionar servicios y como organismo fiscal autónomo. Se parte de atribuciones para concluir en las facultades de comprobación fiscal; para ello deben especificarse sus prerrogativas, patrimonio y órganos de gobierno y administración, así como la posibilidad de recibir el pago, fincarlo y disponer de él, para que pueda otorgar las prestaciones que hemos visto en cada uno de los seguros que integran el sistema.

Atribuciones y responsabilidades

El art. 251 de la LSS le confiere las atribuciones que al cumplir se convierten en obligaciones. Las divido en administrativas y fiscalizadoras. Entre las primera está administrar los seguros de riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, guarderías y prestaciones sociales, salud para la familia, adicionales y otros. Si bien no menciona el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, su consideración no deja lugar a duda. En las obligaciones fiscalizadoras están cobrar las cuotas y ejercer facultades económico-coactivas, así como trasladar el importe de la cuota a las Administradoras de Fondos par el Retiro (Afore) que hubiera contratado el trabajador y disponer de su importe cuando no hubiera selección de la Afore.

Conforme a las facultades de comprobación fiscal, el IMSS puede determinar la existencia, el contenido y el alcance de las obligaciones incumplidas

por los patrones y demás sujetos obligados en los términos de esta Ley, con base en los datos o hechos que conozca —derivados de sus facultades como autoridad fiscal—, o bien apoyándose en expedientes proporcionados por otras autoridades fiscales, pudiendo ratificar o rectificar la clase y la prima de riesgo de las empresas para definir las cuotas correspondientes al seguro de riesgos de trabajo. Uno de los rubros más discutidos en la doctrina y ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es determinar y hacer efectivo el monto de los capitales constitutivos, que ni son capitales ni tiene justificación que sean constitutivos. De este modo, los términos deficientes y la falta de fundamento exponen al Instituto a perder los juicios fiscales o le impiden sostenerlos con argumentos ilógicos.

Otra facultad muy discutida y discutible es la eminentemente fiscal, reservada a la autoridad hacendaria, que consiste en ordenar y practicar visitas domiciliarias (fracc. XVIII) para requerir la exhibición de libros y documentos a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones que establece la Ley y demás disposiciones aplicables; además de poder ordenar y practicar las investigaciones correspondientes en los casos de sustitución patronal y de responsabilidad solidaria previstos en la LSS y en el *Código Fiscal de la Federación* (CFF). Asimismo, el Instituto podrá requerir a los patrones, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, sin que medie visita domiciliaria, para que exhiban en las oficinas del propio Instituto, a efecto de llevar a cabo la revisión, sus libros contables, así como que proporcionen los datos, otros documentos o informes que se les requieran. Por tanto, puede revisar los dictámenes formulados por contadores públicos sobre el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Ley y sus reglamentos, así como imponer a dichos contadores públicos, en su caso, las sanciones administrativas establecidas en el reglamento respectivo.

Por una reforma del 20 de diciembre de 2001, el Instituto tiene una facultad primero reservada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y después, con la creación de las Oficinas para Cobros, concurrente entre la dependencia y la entidad, para aplicar el procedimiento administrativo de ejecución para el cobro de las liquidaciones que no hubiesen sido cubiertas oportunamente, con sujeción a las normas del CFF y demás disposiciones aplicables. En consecuencia, también puede autorizar el registro a los contadores públicos para dictaminar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Ley y comprobar que cumplan con los requisitos exigidos en el reglamento respectivo. Todavía está en discusión si estas facultades, reservadas a la SHCP, puede ejercerlas un órgano descentralizado. En mi opinión, dar acceso a una Secretaría de Estado cuando el Titular del Ejecutivo Federal carece de ella, es violatorio de los arts. 89 y 90 constitucionales, por lo que en la nueva concepción de la administración pública debe reconocerse que el IMSS, al igual que el Instituto Federal Electoral, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Banco de México y la Universidad Nacional Autónoma de México, goza de plena autonomía; es decir,

al tener sus propios órganos de gobierno y al ser la Asamblea General, como lo señala el art. 258, la autoridad suprema, no puede admitir, fuera de sus normas, la intervención de una Secretaría de Estado.

Un absurdo injustificable, al ser receptor de todas las cuotas, es que se le den atribuciones especiales para emitir y notificar (fracc. XXVI) las cédulas de determinación de las cuotas del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, conjuntamente con las liquidaciones de las aportaciones y los descuentos correspondientes al fondo nacional de la vivienda, previo convenio de coordinación con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

Las facultades fiscales del IMSS se han ampliado peligrosamente en demérito de su naturaleza de prestador de servicios para los trabajadores y su familia, al grado de poder hacer efectivas las fianzas que se otorguen a su favor para garantizar obligaciones fiscales a cargo de terceros, caso en que se estará exclusivamente a lo dispuesto por el CFF. Como una alternativa, el Instituto podrá celebrar convenios de reconocimiento de adeudos y facilidades de pago, relativos a cuotas obrero-patronales, capitales constitutivos, actualización, recargos y multas; aprobar el cambio de garantía de dichos convenios, y cancelar, de conformidad con las disposiciones aplicables, créditos fiscales a favor del Instituto y a cargo de patrones no localizados o insolventes, de acuerdo con los montos autorizados por el Consejo Técnico del Instituto. En caso de desacuerdo con un patrón o derechohabiente, éste podrá interponer el recurso de inconformidad, lo que obliga al Instituto a conocerlo y resolverlo, con base en el art. 294 de la Ley; es decir, tiene facultades para conocer y resolver los recursos administrativos. Existe la posibilidad de que el patrón interponga un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en contra del procedimiento administrativo de ejecución; por lo que se refiere al trabajador, puede acudir a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

El patrimonio del Instituto está constituido (art. 253) por los bienes muebles e inmuebles de cualquier naturaleza, con excepción de aquellos provenientes de adjudicación o dación en pago por adeudo de cuotas obrero-patronales, capitales constitutivos y accesorios, así como cualquier otro que afecte expresamente a las reservas que el Instituto deba constituir en términos de esta Ley; los derechos de propiedad y posesión de bienes muebles e inmuebles, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que por justo título obren en su poder; los derechos de cualquier naturaleza que el Instituto obtenga o pueda obtener; las donaciones, las herencias, los legados, las adjudicaciones, los subsidios y las transferencias que se hagan a su favor en que no se preestablezca el destino de los bienes o derechos correspondientes; los intereses, dividendos, realización de activos, alquileres, rentas, rendimientos, utilidades, frutos y productos de cualquier clase que generen los bienes y derechos afectos a su patrimonio, y cualesquier otros ingresos que le señalen las leyes y los reglamentos. Los bienes que forman parte del patrimonio del

Instituto deben estar destinados al servicio público de carácter nacional del Seguro Social a que se refiere el art. 4 de esta Ley. Los inmuebles tendrán, además, el carácter de bienes del dominio público de la Federación.

En cuanto a los bienes materiales, debe adquirir aquellos bienes muebles e inmuebles sólo para los fines que le son propios, derivados de los diversos seguros, para lo cual establecerá unidades médicas, guarderías infantiles, farmacias, velatorios, así como centros de capacitación, deportivos, culturales, vacacionales, de seguridad social para el bienestar familiar y los establecimientos necesarios para el cumplimiento de los fines que le son propios.

Por su naturaleza, la LSS (art. 254) excluye al Instituto, sus dependencias y servicios, del pago de contribuciones federales, estatales y municipales. La Federación, los estados, el Gobierno del Distrito Federal y los municipios no podrán gravar con impuestos su capital, ingresos, rentas, contratos, actos jurídicos, títulos, documentos, operaciones o libros de contabilidad, aun en el caso de que las contribuciones, conforme a una ley general o especial, estuvieran a cargo del Instituto como organismo público o como patrón. En estos supuestos se consideran comprendidos los impuestos indirectos y el franqueo postal. El Instituto y demás entidades que formen parte o dependan de él estarán sujetos únicamente al pago de los derechos de carácter municipal que causen sus inmuebles en razón de pavimentos, atarjeas y limpia, así como por el agua potable de que dispongan, en las mismas condiciones en que deben pagar los demás causantes. Igualmente estarán sujetos a los derechos de carácter federal correspondientes a la prestación de servicios públicos. En consecuencia, se considera de acreditada solvencia y no estará obligado, por tanto, a constituir depósitos o fianzas legales, ni aun tratándose de un juicio de amparo. Los bienes del Instituto afectos a la prestación directa de sus servicios serán inembargables y no podrá contar con otros bienes que no se relacionen con esos servicios.

Conforme al art. 256, las relaciones entre el Instituto y sus trabajadores se regirán por lo dispuesto en el Apartado A del art. 123 constitucional, la *Ley Federal del Trabajo* (LFT) y el contrato colectivo de trabajo.

El Ejecutivo Federal ha expedido los reglamentos que norman al Instituto desde su creación, sin tener más facultades que las derivadas de una interpretación inadecuada de la segunda parte de la fracc. I del art. 89 constitucional. La LSS no puede otorgar facultades que no consigne la Constitución. El artículo mencionado determina las facultades y obligaciones del Presidente de la República; en la fracc. I dispone la de "Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia." En una interpretación estricta, ésta, como todas las facultades, es limitativa, sólo referida a los organismos que dependen de él para la distribución de las facultades conforme a la *Ley Orgánica de la Administración Pública Federal*, lo que lleva a considerar si existe facultad u obligación alguna contenida en la Ley Fundamental, como lo limita la fracc. XX del numeral constitucional:

“Las demás que le confiere expresamente esta Constitución”; al no existir disposición alguna en el art. 123 de la Constitución, único del que emana el Seguro Social, es necesario concluir que tanto el Presidente de la República como sus dependencias carecen de facultad.

Órganos de Gobierno

El art. 257 de la LSS determina los órganos superiores del Instituto: la Asamblea General, el Consejo Técnico, la Comisión de Vigilancia y la Dirección General. En la reforma de 1992 se adicionó el Comité Técnico para el manejo del Seguro de Retiro, que fue sustituido por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) y eliminado de los órganos del Instituto. La Asamblea General es la autoridad suprema del Instituto (art. 258), a ella están sometidos los otros órganos y es responsable única de la administración, la organización y el funcionamiento tanto de la estructura interna como de las empresas con las que se celebran los contratos de subrogación. La Asamblea está integrada en forma tripartita por 30 miembros, 10 designados por el Ejecutivo Federal, 10 nombrados por las organizaciones patronales, conforme a los lineamientos que señale el Presidente de la República, y 10 por las organizaciones de trabajadores, con una permanencia en su encargo seis años, con la oportunidad de reelegirse. A pesar de lo señalado, el Ejecutivo Federal establecerá las bases para determinar las organizaciones de trabajadores y de patrones que deban intervenir en la designación de los miembros de la Asamblea General (art. 259), injerencia indebida que atenta contra el principio de autonomía de las organizaciones.

Al ser un organismo descentralizado, el IMSS no está regulado por la *Ley Federal de Organismos Descentralizados*. En caso contrario, como lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia, el Director General estaría impedido para presidir la Asamblea General, como lo determina el art. 260: “será presidida por el Director General y deberá reunirse ordinariamente una o dos veces al año y extraordinariamente en cuantas ocasiones sea necesario, de acuerdo con lo que disponga el reglamento relativo”.

Las atribuciones de la Asamblea General restringen cualquier posibilidad de intervención efectiva, al limitarse a discutir anualmente, para su aprobación o modificación, el estado de ingresos y gastos, el balance contable, el informe financiero y actuarial, el informe de actividades presentado por el Director General, el programa de actividades y el presupuesto de ingresos y egresos para el año siguiente, así como el informe de la Comisión de Vigilancia, además de examinar cada año la suficiencia de los recursos para todos y cada uno de los seguros de riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, y guarderías y prestaciones sociales, así como de salud para la familia y adicionales, al realizar el informe financiero y actuarial.

En el supuesto de que el balance actuarial acuse superávit, éste se destinará a constituir un fondo de emergencia hasta el límite máximo de 50% de los ingresos anuales respectivos. Después de alcanzar este límite, el superávit se aplicará, según la decisión de la Asamblea General, a mejorar las prestaciones de los seguros que se encuentren en este supuesto (arts. 261 y 262).

Es evidente que las asambleas semestrales se han limitado a una ceremonia a la que asiste el Presidente de la República, se escuchan los informes del Director General que presenta por conducto del Secretario General, lo aprueban sin discusión, se escucha el mensaje del Director General y del Presidente de la República, quien aprovecha para hacer señalamientos y dar instrucciones. En vista de que no existe superávit desde hace años, la intervención en este aspecto es nula.

Consejo Técnico

Integración

El Consejo Técnico es el órgano efectivo de gobierno dotado de amplias facultades (art. 263), que lo convierten en representante legal y administrador del Instituto. Su integración es menor, en forma tripartita por 12 miembros, cuatro de los cuales designan los representantes patronales en la Asamblea General, cuatro los representantes de los trabajadores y cuatro los representantes del Estado, con sus respectivos suplentes. Cuando lo estime conveniente, el Ejecutivo Federal podrá disminuir a la mitad la representación estatal. Por el Ejecutivo Federal participan el Secretario de Hacienda y Crédito Público, el Secretario de Salud, el Secretario del Trabajo y Previsión Social y el Director General del Instituto, quien preside el Consejo. Los sectores representativos de los patrones y los trabajadores propondrán sus representantes. Cada consejero propietario tendrá un suplente. Los consejeros durarán en su cargo seis años, con la posibilidad de ser reelectos. Sin embargo, la designación puede revocarse cuando lo determine el sector que lo hubiese propuesto; en este caso la Asamblea General oírán en defensa al Consejero y resolverá conforme al reglamento.

Sólo los consejeros representantes patronales y de los trabajadores recibirán los emolumentos y las prestaciones que al efecto determinen los consejeros representantes del Ejecutivo Federal, a propuesta del Director General, sin que por ello tengan el carácter de trabajadores, asegurados, derechohabientes del Instituto ni algún otro derecho adicional.

Los consejeros no pueden promover o participar directa o indirectamente, a título personal, en la atención de solicitudes, planteamientos o recursos que patrones o derechohabientes expongan ante el Instituto. El Consejo Técnico esbozará lineamientos sobre los cuales sus integrantes podrán ejercer funciones de representación y gestoría ante el Instituto, respecto de los sectores y las organizaciones que representen, a fin de evitar conflictos de intereses.

Atribuciones

El Consejo Técnico tendrá atribuciones de representación legal, administrativas y de dominio (art. 264) para llevar a cabo las facultades que la Ley confiere al Instituto, pero estará sujeto a las disposiciones de este ordenamiento y de los reglamentos. Como podemos ver, la Asamblea General es el órgano superior del Instituto; sin embargo, el Consejo Técnico cuenta con facultades para convocarla a reunión ordinaria o extraordinaria (fracc. V). En este sentido, discutirá y, en su caso, aprobará el programa de actividades que someta a su consideración el Director General, así como conocerá y resolverá de oficio o a petición del Director General aquellos asuntos que por su importancia, trascendencia o características especiales lo ameriten.

En esta forma, el Consejo Técnico decide sobre las inversiones de las reservas y todos los recursos del Instituto. De acuerdo con la reforma de 1995, se exceptúan los recursos provenientes del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Para ello discutirá y aprobará el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos del Instituto que someta a su consideración el Director General (fracc. VI), y autorizará adecuaciones al presupuesto. Por lo que se refiere al pago de cuotas, podrá autorizar la celebración de convenios, pudiendo encomendar esta facultad a los delegados y otras unidades administrativas, conforme al Reglamento Interior. Respecto de los convenios celebrados para la subrogación de servicios, emitirá disposiciones de carácter general sobre reversión de cuotas, así como para los seguros que expresamente establece esta Ley (fracc. VII).

Para una adecuada administración de los recursos, será responsable de vigilar y promover el equilibrio financiero de cada uno de los seguros comprendidos en la Ley, incluido el de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez (fracc. II). Por tanto, resolverá sobre las operaciones del Instituto, excepto aquellas que por su importancia ameriten acuerdo expreso de la Asamblea General, de conformidad con lo que al respecto determine esta Ley y el reglamento. Aprobará la estructura orgánica básica del Instituto, en apego al Reglamento Interior, así como la estructura ocupacional correspondiente y sus modificaciones, los niveles salariales, las prestaciones y los estímulos de desempeño de los trabajadores de confianza B, los que se determinarán conforme a los tabuladores que al efecto expida la SHCP, sin perjuicio de los derechos de los trabajadores de base, sujetos al contrato colectivo y a un sistema de valuación de puestos. Además, designará a los trabajadores de confianza que ocupen el nivel jerárquico inmediato inferior al Director General del Instituto. Por lo que se refiere a los trabajadores clasificados como de confianza A en el contrato colectivo de trabajo, aprobará las bases para el establecimiento, la organización y el funcionamiento de un sistema de profesionalización y desarrollo. De acuerdo con el sindicato, establecerá los términos en que ese sistema podrá hacerse extensivo a los trabajadores clasificados como de base y de confianza B en el

contrato colectivo de trabajo, y se encargará de la aplicación de los reglamentos derivados del mismo.

En relación con los patrones y derechohabientes, sus facultades le permiten conceder, rechazar y modificar las pensiones, que conforme a esta Ley le corresponde otorgar al Instituto, pudiendo delegar estas facultades a las dependencias competentes, así como aprobar las bases para la celebración de convenios de incorporación voluntaria al régimen obligatorio a que se refiere la Ley. En casos excepcionales, previo estudio socioeconómico, concede a derechohabientes el disfrute de prestaciones médicas y económicas previstas por esta Ley, cuando no esté plenamente cumplido algún requisito legal y el otorgamiento del beneficio sea evidentemente justo o equitativo. También como excepción, puede extender hasta los 25 años de edad los derechos a las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad, que se otorgarán dentro del territorio nacional, a los hijos de trabajadores mexicanos asegurados que laboren en el extranjero y que se encuentren estudiando fuera del país en planteles educativos equiparables a los del sistema educativo nacional, para lo cual requiere expedir bases especiales.

Admite la existencia de trabajadores que, por sus actividades profesionales, la naturaleza de su trabajo, sus especiales condiciones de tiempo y lugar o por la índole de sus procesos productivos, no se adecuen a los requisitos generales del régimen obligatorio de esta Ley; para ellos puede establecer las condiciones de aseguramiento y cotización a fin de hacerlos equitativos, respetando los elementos de sujeto, objeto, base, cuota, primas de financiamiento y época de pago de las cuotas, conforme a lo establecido en la Ley (fracc. XV).

Comisión de Vigilancia

La fiscalización de todos los actos del Instituto que afecten sus finanzas depende de los seis miembros de este cuerpo colegiado, que al ser designado por la Asamblea debía integrarse por especialistas financieros, por lo que cada uno de los sectores representativos que la constituyen, al proponer a sus dos miembros propietarios y dos suplentes, tienen la responsabilidad de seleccionar a las personas más calificadas para esta labor que durará seis años, con posibilidad de ser reelectos. La elección puede recaer en personas que no formen parte de dichos sectores; sin embargo, al menos uno de los miembros designados por el Ejecutivo Federal deberá estar adscrito a la Secretaría de la Función Pública y cuando lo estime conveniente puede disminuir a la mitad la representación estatal. La designación será revocable, siempre que la pidan los miembros del sector que hubiese propuesto al representante de que se trate o porque medien causas justificadas para ello. En todo caso, el acuerdo definitivo corresponde a la Asamblea General, la que resolverá lo conducente por medio de un procedimiento en que oiga la defensa del miembro cuya remoción se solicite, en términos de lo señalado en el Reglamento Interior (art. 265).

Las atribuciones de la Comisión de Vigilancia señaladas en el art. 266 le imponen vigilar que las inversiones se hagan de acuerdo con las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos; realizar la auditoría de los balances contables y al informe financiero y actuarial, así como comprobar los avalúos de los bienes materia de operaciones del Instituto. Puede sugerir a la Asamblea General, al Consejo Técnico y a la Consar la adopción de las medidas que juzgue convenientes para mejorar el funcionamiento de los seguros que señala la Ley.

Presentará ante la Asamblea General un dictamen sobre el informe de actividades y los estados financieros presentados por el Consejo Técnico, los cuales le serán dados a conocer con la debida oportunidad. Sólo en casos graves y bajo su responsabilidad, citará a Asamblea General Extraordinaria.

Estas funciones, de gran relevancia con un debido ejercicio, deben impedir las graves desviaciones que tiene el Instituto en su desempeño tanto en abasto de medicamentos como material de curación e instalaciones. No es posible que frente a un pasivo de más de un billón de pesos, los altos funcionarios —desde el Director General, los directores y coordinadores en las oficinas centrales— reciban, según reiteradas menciones, salarios y prestaciones elevados que multiplican el salario convenido en el tabulador de los trabajadores sindicalizados, además de seguir propiciando el incremento de servicios subrogados.

Dirección General

El Director General es la máxima autoridad del Instituto, limitado sólo por el Presidente de la República. La Asamblea General, el Consejo Técnico y la Comisión de Vigilancia son organismos atentos a obsequiar sus propuestas, como sucede en muchos organismos públicos. Quienes hemos tenido oportunidad de laborar en las oficinas centrales, comprobamos el enorme poder que ejerce el Director General. Este cargo se ha convertido en oportunidad política para que el Presidente designe, con base en el art. 267, a la persona que estime, sin necesidad de atender la capacidad o experiencia. Hemos tenido directores generales que se han preocupado por organizar y fomentar servicios adecuados, pero otros han aprovechado el puesto como antesala para ocupar otros cargos en la administración pública o en los estados.

Las atribuciones que la Ley confiere al Director General le permiten el ejercicio de la máxima autoridad (art. 268). Por tanto, preside las sesiones de la Asamblea General y del Consejo Técnico, y ejecuta los acuerdos del propio Consejo, sin que se obligue expresamente a cumplir los acuerdos de la Asamblea, pero tiene derecho de veto sobre las resoluciones del Consejo Técnico, en los casos que fije el reglamento. Este veto suspende la aplicación de la resolución del Consejo, hasta que resuelva en definitiva la Asamblea General. Presentará anualmente ante el Consejo el informe de actividades, el programa de labores, el presupuesto de ingresos y egresos para el siguiente periodo, el balance

contable y el estado de ingresos y gastos, el informe financiero y actuarial; le propone la designación o destitución de los trabajadores de confianza B; puede nombrar y remover a los trabajadores de confianza A, quienes deben contar con la capacidad, experiencia y demás requisitos que se determinan en el Estatuto, donde se contiene el régimen específico, los procesos y otras características del Sistema de profesionalización y desarrollo. Esta facultad podrá ser delegada en los términos que establezca el Reglamento Interior del Instituto, que señala las unidades administrativas del mismo y su circunscripción geográfica.

Además, el Director General representa legalmente al Instituto, con todas las facultades que corresponden a los mandatarios generales para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio, y otras que requieran cláusula especial conforme al *Código Civil Federal* (CCF) o cualquiera otra Ley, así como ante todas las autoridades. Estas amplias facultades hacen factible que pueda a su arbitrio disponer de los bienes del Instituto, así como realizar toda clase de actos jurídicos necesarios para cumplir con los fines del Instituto y ejercer las funciones en materia de presupuesto, conforme a lo dispuesto en esta Ley. La única limitante que se establece es que debe presentar anualmente al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión los informes antes mencionados.

Para cumplir con sus funciones, el Director General será auxiliado por los servidores públicos de mando, personal de base y de confianza que se establezcan en el Reglamento Interior del Instituto, que a propuesta del Consejo Técnico expida el Ejecutivo Federal, considerando lo que al efecto se estipule en el contrato colectivo de trabajo suscrito con los trabajadores del Instituto.

El IMSS como organismo fiscal autónomo

Discusión

Desde su creación, dos aspectos fundamentales en la vida del Instituto han producido una discusión inacabada: las facultades para el cobro de las cuotas y la posibilidad de cobro coercitivo cuando las cuotas dejen de enterarse. Recordemos que en 1943 se estimaba que el pago tenía carácter mercantil, por lo que había que acudir a un juez para dirimir las controversias. La reforma promovida por el presidente Manuel Ávila Camacho en 1944 genera por primera vez la figura *sui generis* de *organismo fiscal autónomo*. Conforme a esta Ley, el IMSS carecía de facultades para llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución.

Originalmente, el artículo 135 de la Ley del Seguro Social de 1942, dispuso que el título donde conste la obligación de pagar las aportaciones tenía el carácter de título ejecutivo, lo que hacía que el IMSS tuviera que demandar ante los tribunales a los patrones que no pagaban las cuotas oportunamente.¹

1 Sergio Francisco de la Garza, *Derecho financiero mexicano*, Porrúa, México, 2003, p. 361.

Esta naturaleza jurídica se enlaza a la evolución de la aportación, donde se ha discutido si la obligación deriva sólo del art. 123 constitucional o de la fracc. IV del numeral 31 de ese ordenamiento y, por tanto, sin encontrar la calidad de la obligación por la contraprestación de dichos servicios. La tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitida en el expediente de Revisión 373/1947 señala:

Con anterioridad a la reforma del artículo 135 de la Ley del Seguro Social, el mencionado organismo carecía del carácter de autoridad en todos los casos, pero a partir de dicha reforma asumió el carácter de organismo fiscal autónomo y, por ende, de autoridad, cuando actúa dentro de los términos de la citada reforma, o sea, cuando hace la determinación de los créditos fiscales a su favor, por concepto de cuotas, o bien cuando da las bases para su liquidación. Más con posterioridad a la reforma, el Instituto mencionado carece del carácter de autoridad cuando realiza cualquier otro acto no comprendido dentro de las prevenciones del nuevo texto reformado...

La reforma de 1944 confirió al Instituto facultades para determinar los créditos a su favor y las bases para su liquidación, fijar la cantidad líquida y su percepción y cobro (art. 135). Sin embargo, carecía de atribuciones para hacer efectivos dichos créditos, así como para emitir requerimientos de pago, mandamientos de ejecución y llevar a cabo el embargo, lo que conforme al mismo numeral "se realizará por conducto de las Oficinas Federales de Hacienda que corresponda, con sujeción a las normas del Código Fiscal de la Federación, que regulan las fases oficiosas y contenciosas del procedimiento fiscal".

La H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el informe del presidente de 1970, consideró que las cuotas

... son verdaderos tributos o contribuciones en sentido genérico, en la terminología constitucional que los patrones y obreros pagan obligatoriamente al Estado, al beneficiarse de una manera especial por la implantación del servicio público administrativo de la seguridad social, servicio que a la vez reporta beneficio colectivo. Estos tributos tienen su fundamento jurídico, además de la sujeción a la potestad de imperio del Estado para imponer las contribuciones necesarias para hacer frente a los gastos públicos, en lo dispuesto por el artículo 123, fracción XXIX, de la Constitución Política, pues el Seguro Social constituye un servicio público nacional, establecido con carácter obligatorio.²

2 Informe del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 1970. Presidencia. Pág. 304. AR 4547/67. Carlos Delgado Andrade. Unanimidad 17 votos. Ponente: Mtro. Carlos del Río Rodríguez.

Los estudiosos del Derecho nos resistimos a considerar la obligatoriedad de la cuota con la naturaleza de contribución. Si bien algunos autores reconocían las facultades de la SHCP para llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución, me parece que al ser parte del Ejecutivo Federal, debe modificarse la Constitución para darle participación primero en este procedimiento y posteriormente como regulador de las pensiones. En cambio, el IMSS puede determinar en cantidad líquida el monto, aun cuando algunos consideran que no le compete realizar los actos coactivos, al estimarlo como facultad hacendaria. Estas dificultades se eliminan si se le reconoce la naturaleza de organismo autónomo constitucional, al igual que el Instituto Federal Electoral, el Banco de México, la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otros.

La discusión en torno a la cuota continuaba a pesar de las tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el informe de su Presidente, de 1972,³ se reconoce el carácter fiscal únicamente al pago:

Ello ha inspirado indudablemente, al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito para que sustente la siguiente tesis: "Seguro Social, Cuotas del.- No tienen el carácter de créditos fiscales. La circunstancia de que el artículo 135 de la Ley del Seguro Social prevenga que el capital constitutivo, entre otras cuotas que deban pagarse al Instituto, tienen el carácter de fiscal, no significa, porque no se expresa así en el régimen fiscal mexicano, que sea un impuesto, derecho, producto o aprovechamiento, y la indicación de que el deber de pagar los aportes, los intereses moratorios y los capitales tengan el carácter de fiscal, sólo quiere decir que se asimila a este tipo de crédito, para los efectos del cobro únicamente, y no para darles en esencia naturaleza fiscal en los términos del artículo 31 fracción IV, de la Constitución Federal, y artículos 2, 3, 4 y 5 del Código Fiscal de la Federación."

Facultad para fijar créditos

La LSS de 1973 reitera, en su afán de dar prioridad a los créditos a favor del Instituto, además de su naturaleza de organismo fiscal autónomo (art. 268), las facultades de "determinar los créditos y las bases para su liquidación, así como para fijarlos en cantidad líquida, cobrarlos y percibirlos", pero el procedimiento administrativo de ejecución "se realizará por conducto de la Oficina Federal de Hacienda que corresponda, con sujeción a las normas del Código Fiscal de la Federación".

3 4ª Parte, 1er. Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Pag. 64. DA-561-71. Revisiones 2679/70, 3490/714607/55, 706/72, 2129/73.

La reforma a la LSS publicada en el *Diario Oficial de la Federación* (DOF) el 31 de diciembre de 1981 determina una facultad concurrente entre la SHCP y el IMSS:

Artículo 271. El procedimiento administrativo de ejecución de las liquidaciones que no hubiesen sido cubiertas oportunamente al Instituto Mexicano del Seguro Social se aplicará por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o por el propio Instituto a través de Oficinas para Cobros del citado Instituto Mexicano del Seguro Social.

Puede decirse que no fue sino hasta 1982, año en que se expidió el CFF vigente, cuando éste tomó una actitud más definida acerca de la naturaleza de las aportaciones o cuotas de seguridad social, y aun así los criterios han sido opuestos, de manera que la doctrina de los tributos y las resoluciones o tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se manifestaron en relación con dicho asunto.

En 1983, finalmente la reforma al art. 2º, fracc. II, del CFF determinó:

Las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, las que se definen de la siguiente manera:
[...]

II. Aportaciones de seguridad social son las contribuciones establecidas en ley a cargo de personas que son substituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social o a las personas que se benefician en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado.

Esta reforma incrementó la discusión en torno a las facultades fiscales del Instituto, sin considerar que la misma sea meramente doctrinal, pues repercute en las facultades ejecutoras del organismo fiscal autónomo y en la determinación de la exigibilidad del crédito.

Oficinas para cobros

La Ley en vigor a partir del 1 de julio de 1997 reproduce en su art. 291 el precepto en los términos de la Ley de 1973; confiere a las oficinas para cobros la facultad de llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución, con lo que la intervención de la SHCP pasó a un plano complementario. El segundo párrafo señala:

Las oficinas para cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social aplicarán el procedimiento administrativo de ejecución, con sujeción a las normas del Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones aplicables. Las propias oficinas

conocerán y resolverán los recursos previstos en el Código Fiscal de la Federación relativos al procedimiento administrativo de ejecución que se lleve a cabo...

En el tercer párrafo se permite a estas oficinas hacer efectivas las fianzas que se otorguen.

El art. 270 de la LSS amplía el espectro al determinar que ejercerá "las atribuciones que la misma le confiere de manera ejecutiva, con autonomía de gestión y técnica, en los ámbitos regulados en la presente Ley"; de manera que, por reforma del 20 de diciembre de 2001, en materia de recaudación y administración, el Instituto ejerce las facultades inherentes al art. 2º, fracc. II y penúltimo párrafo, del CFF, por lo que recaudará, administrará y, en su caso, determinará y liquidará las cuotas correspondientes a los seguros establecidos en la LSS, aplicando al efecto lo dispuesto en la misma, y en lo no previsto expresamente en ella contará con todas las facultades que ese Código confiere a las autoridades fiscales, las que ejecutará el Instituto sin la participación de ninguna otra autoridad fiscal (art. 271).

Lo anterior conduce necesariamente a revisar la facultad de los órganos centrales de la Administración Pública frente a los organismos descentralizados o paraestatales, derivada de los mandamientos constitucionales. Si bien la LSS y la *Ley del Infonavit* confieren a los institutos la naturaleza de organismos fiscales autónomos y poder llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución, "tal reconocimiento se limita a los solos efectos de la liquidación y cobro no forzado de las cuotas establecidas a su favor", por lo que no pueden

... requerir el cumplimiento de ella por los medios de apremio, aplicar sanciones y realizar acciones de investigación y comprobación, porque éstos son actos típicos de la soberanía, aspectos operativos del gobierno que sólo los órganos de la administración centralizada pueden ejercitar, en tanto que se trata de órganos del Estado.⁴

Presupuesto

El nuevo ordenamiento controla aspectos de presupuesto, gasto y contabilidad del Instituto, que se regirá por lo dispuesto en esta Ley, al darle injerencia, en lo no previsto expresamente en ella, a la *Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal* y disposiciones que de ella emanen. Los servidores públicos del Instituto serán los responsables de cualquier daño o perjuicio estimable en dinero que afecte a la hacienda pública federal o el patrimonio del propio Instituto, sin perjuicio de lo dispuesto en

4 Hugo Carrasco Iriarte, *Derecho fiscal constitucional*, Oxford University Press México, 1999, p. 56.

la *Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos* y en la *Ley de Fiscalización Superior de la Federación*. En el art. 271 se faculta a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo para vigilar por sí o a través del órgano interno de control en el propio Instituto el ejercicio de las atribuciones que en materia de control, inspección, vigilancia y evaluación le confieren la *Ley Orgánica de la Administración Pública Federal* y demás ordenamientos legales aplicables, sin perjuicio de las facultades que corresponden a la Auditoría Superior de la Federación.

Acorde con esta amplitud en las atribuciones del Instituto, con las limitaciones señaladas, formulará su proyecto de presupuesto y ejercerá el gasto correspondiente con estricto respeto a los criterios de disciplina, productividad, ahorro, austeridad, eficacia, eficiencia, desregulación presupuestaria y transparencia, debiendo aplicar los recursos en forma tal que no afecte la atención a sus derechohabientes. Con tal motivo, planeará su gasto de manera que contribuya a mantener su estabilidad y equilibrio financiero en un horizonte de mediano y largo plazos, conforme a las tendencias demográficas y epidemiológicas de su población beneficiaria. Para que se cuente con el tiempo adecuado, el Director General propondrá al Consejo Técnico (art. 274) el anteproyecto de presupuesto e ingresos del Instituto. El Consejo deberá aprobarlo o modificarlo a efecto de que a más tardar 45 días naturales antes de que la SHCP pueda elevarlo a consideración del Presidente de la República, remita al Congreso de la Unión la iniciativa de *Ley de Ingresos* y el *Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación*. El anteproyecto incluirá los gastos de operación y el flujo de efectivo, tomando en cuenta los criterios de política económica y presupuestaria del Gobierno Federal, así como la evolución de los ingresos de éste y lineamientos del control del gasto. El Consejo Técnico aprobará, en cualquier etapa del ejercicio fiscal, las adecuaciones que requiera el presupuesto del Instituto para el mejor cumplimiento de los objetivos de sus programas, siempre que con ello no se afecten las reservas aprobadas en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación ni la estabilidad del Instituto y que, respetando los programas relativos a la prestación oportuna y suficiente de sus servicios en beneficio de los derechohabientes, sean congruentes a juicio del propio Consejo con las políticas de ingreso-gasto de la Administración Pública Federal.

El anteproyecto de presupuesto contendrá un reporte de la Dirección General que incluya el análisis del impacto que el presupuesto tenga para el Instituto en un horizonte de mediano plazo; el presupuesto asignado por programas, señalando prioridades, objetivos, metas y unidades responsables de su ejercicio, así como su valuación estimada por programa, y los mecanismos e indicadores de evaluación para cada programa; en estas unidades se considerarán las unidades médicas de alta especialización, organismos descentralizados; el señalamiento expreso de los programas que por su naturaleza y características deban abarcar más de un periodo presupuestario anual,

sujetos para los fines de ejecución y pago a la disponibilidad presupuestal de los años subsecuentes; los ingresos totales y en flujo de efectivo, expresados como devengados, por cuotas de trabajadores y patrones, cuotas, contribuciones y aportaciones del Gobierno Federal —estas aportaciones responderán a los cálculos actuariales suficientes para atender las prestaciones señaladas en cada seguro—; los ingresos financieros de las reservas, y cualesquiera otros; los gastos totales y por capítulo de gasto, expresados como devengados y en flujo de efectivo; los excedentes de operación; los excedentes de flujo de efectivo, antes y después de la creación; el incremento o decremento del Fondo para el Cumplimiento de Obligaciones Laborales de Carácter Legal y Contractual; los montos en que se proponga el incremento, decremento o, en su caso, la reconstrucción de las Reservas Financieras y Actuariales, y la Reserva General Financiera y Actuarial para cada seguro, así como el Fondo para Cumplimiento de Obligaciones Laborales de Carácter Legal y Contractual, además del respaldo de inversiones financieras que se dará al mismo; los ingresos y gastos totales por seguro expresados como devengados; las plazas de personal totales a ocupar, incluyendo permanentes y temporales, así como la contratación de servicios profesionales por honorarios; los pasivos laborales totales, detallando obligaciones legales y contractuales, y el efecto que sobre dichos pasivos tendría la creación de nuevas plazas de personal en el ejercicio y en un plazo de 28 años; el Programa de Inversiones Físicas, indicando las principales obras y equipamiento. El Programa deberá especificarse por seguro y deberá incluir el análisis de los pasivos y gastos operativos de todo tipo generados por la inversión, así como el presupuesto de las áreas de administración central del Instituto. El informe contendrá una situación detallada sobre el estado que guardan las instalaciones y los equipos del Instituto, particularmente los dedicados a la atención médica, para poder dar un buen servicio a sus derechohabientes.

Este anteproyecto, una vez aprobado por el Consejo Técnico (art. 276), será remitido a la SHCP, a más tardar 25 días naturales antes de que conforme a lo establecido en la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos* (CPEUM) el Ejecutivo Federal remita al Congreso de la Unión la iniciativa de *Ley de Ingresos* y el *Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación*, con el fin de que ésta lo analice y, en su caso, modifique y apruebe. En caso de modificación, el Instituto realizará los ajustes necesarios para remitirlos a la Secretaría a fin de que ésta los incluya en la Iniciativa de *Ley de Ingresos* y en el *Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación* que se sometan a la aprobación del Congreso de la Unión. El Instituto no tiene facultad para oponerse a las alteraciones indicadas por la Secretaría; sin embargo, la Cámara de Diputados, al aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación, considerará el informe y el reporte con amplitud de facultades, porque puede modificar definitivamente el Presupuesto. El Consejo Técnico y el Director General serán responsables, en el ámbito de sus respectivas competencias, de que el Instituto cumpla con lo aprobado por el Congreso de la Unión.

Las cuotas, contribuciones y aportaciones que conforme a lo dispuesto en cada seguro de la Ley deba enterar el Gobierno Federal al Instituto, se manifestarán de manera expresa, por lo que señalará su destino específico, en un apartado individual del correspondiente decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación que anualmente se apruebe, hará referencia al gasto total que se prevea habrá de ejercer el propio Instituto y señalará, en su caso, las reglas para su control y seguimiento.

La facultad limitada de autorregulación deberá contar con un informe dictaminado por auditor externo, que incluya al menos la situación financiera de cada uno de los seguros ofrecidos por el Instituto y actuarial de sus reservas, aportando elementos de juicio para evaluar si las primas correspondientes son suficientes para cubrir los gastos actuales y futuros de los beneficios derivados de cada seguro; los posibles riesgos, contingencias y pasivos que se están tomando en cada seguro y la capacidad financiera del Instituto para responder a ellos en función de sus ingresos y las reservas disponibles. Además de lo anterior, dicho informe también deberá contener las estimaciones sobre las posibles modificaciones a las cuotas obrero-patronales y a las cuotas, contribuciones y aportaciones del Gobierno Federal de cada seguro, en su caso, que se puedan prever para mantener la viabilidad financiera del Instituto, y de las fechas estimadas en que dichas modificaciones puedan ser requeridas, así como la situación de sus pasivos laborales totales y de cualquier otra índole que comprometan su gasto por más de un ejercicio fiscal. Más aún, el informe debe prever la condición del Instituto para evitar desvíos y la actual situación de un pasivo cercano a los 900 mil millones de pesos.

Para lograr una mejor atención y un posible crecimiento, el Instituto informará sobre las tendencias demográficas de su población beneficiaria, incluyendo modificaciones en la esperanza de vida; tendencias en la transición epidemiológica, y cambios en la composición de género de la fuerza laboral, entre otros factores. La estimación de riesgos, a su vez, considerará factores derivados del ciclo económico, de la evolución del costo de los tratamientos y medicamentos, los costos laborales de la situación macroeconómica, así como de cualquier otro factor que afecte la capacidad del Instituto para cumplir con sus compromisos. En todos los casos, la estimación sobre riesgos y pasivos laborales y de cualquier otro tipo se formulará con estricto apego a los principios de contabilidad generalmente aceptados por la profesión contable organizada en México.

La Ley da los elementos necesarios para que el Instituto sea autosuficiente y pueda ejercer su presupuesto evaluando los ingresos recibidos y el gasto efectuado en periodos trimestrales, a efecto de constatar su desarrollo conforme a lo presupuestado (art. 277). Cuando en cualquiera de los trimestres del año los ingresos obtenidos sean superiores a los previstos, o los gastos resulten inferiores a lo planeado y el Consejo Técnico tenga una expectativa razonablemente fundada de que el excedente en ese periodo tendrá un efecto positivo neto al

cierre del ejercicio anual, una vez cumplida la meta trimestral de incremento o reconstitución de las reservas y fondos, el Instituto podrá disponer de esos recursos para aplicarlos en el trimestre siguiente al fortalecimiento de su Reserva de Operación para Contingencias y Financiamiento, y con el acuerdo expreso del Consejo Técnico, a sus programas prioritarios.

A pesar de lo dispuesto en la Ley, ninguno de estos principios, consignados en la reforma de 2001, se han cumplido. En los arts. 277 A a 277 G se regulan aspectos financieros importantes. Destaco los relevantes para los propósitos de esta obra. En el primero se establece la posibilidad de que para el resto del ejercicio se pueda necesitar de los recursos considerados excedentes en algún trimestre anterior, conforme al presupuesto aprobado. El art. 277 B observa que el Instituto no está autorizado a contraer pasivos financieros para pagar las prestaciones correspondientes a los seguros que esta Ley establece; que sólo podrá contraer pasivos derivados de cartas de crédito o coberturas cambiarias a plazos inferiores a un año sin revolvencia, que se destinen a liquidar compromisos con proveedores de insumos, previa autorización de la SHCP. El art. 277 C libera al Instituto de la obligación de concentrar en la Tesorería de la Federación sus ingresos, con excepción de los remanentes de subsidios y transferencias de programas de solidaridad social y otros financiados directamente por el Gobierno Federal, por lo que manejará y erogará sus recursos por medio de sus unidades administrativas competentes.

Trabajadores de confianza

En una invasión contraria a su naturaleza y a la LFT, el art. 277 D sujeta a la aprobación del Consejo Técnico los sueldos y las prestaciones de los trabajadores de confianza, así como la contratación de servicios profesionales por honorarios que resulten estrictamente necesarios, conforme a las bases de observancia obligatoria que el mismo emita. Los salarios se determinarán considerando los tabuladores que para las dependencias y entidades del sector público federal expida la SHCP y las condiciones imperantes en el mercado. El Consejo Técnico podrá crear, sustituir o contratar plazas basándose en criterios de productividad, eficiencia y calidad de servicio, así como en el aumento de la recaudación, siempre que cuente con los recursos aprobados en su respectivo presupuesto y pueda cubrir el costo anual de sus repercusiones, ya que al crear, sustituir o contratar plazas se deberán depositar en el Fondo a que se refiere la Ley los recursos necesarios para cubrir los costos futuros derivados del Régimen de Jubilaciones y Pensiones, con el fin de que en todo momento se encuentre plenamente financiado. El Director General del Instituto no podrá recibir percepciones superiores a las de un Secretario del Despacho en la Administración Pública Federal Centralizada.

El Instituto tiene la obligación de publicar en el DOF, a más tardar el 30 de junio del ejercicio fiscal correspondiente, el informe analítico de todos los puestos y las plazas, incluyendo temporales, sustitutos, residentes y análogas; los sueldos, las prestaciones y los estímulos de todo tipo de sus servidores públicos, agrupados por nivel, grado y grupo de mando, y los cambios autorizados a su estructura organizacional por el Consejo Técnico, así como el número, las características y remuneraciones totales de la contratación de servicios profesionales por honorarios.

El art. 277 E ratifica la suficiencia e independencia de cada seguro al determinar que sus ingresos y gastos se registrarán contablemente por separado; los gastos indirectos comunes se sujetarán a las reglas de carácter general para la distribución de costos, al catálogo de cuentas y al manual de contabilización y del ejercicio del gasto que al efecto emita el Consejo Técnico a propuesta del Director General, quien deberá contar con la opinión previa de la SHCP. Los recursos de los seguros a que se refiere esta Ley sólo podrán utilizarse para cubrir las prestaciones y el pago de beneficios, y constituir reservas para cada tipo de seguro.

16 Medios de defensa contra el IMSS

Naturaleza jurídica de la cuota

Los diferentes medios de defensa por parte del patrón conducen a los recursos administrativos, y por parte del trabajador se inician con la queja. Para analizarlos, debemos partir de la naturaleza jurídica de la cuota; es decir, se hace indispensable retomar lo que en el capítulo respectivo dije sobre la naturaleza jurídica de la aportación. Recordemos que cada seguro toma en cuenta el salario base de cotización y éste parte necesariamente del concepto de salario; de ahí la exigencia de preservar las garantías del art. 123 constitucional, relativas al salario, y de la *Ley Federal del Trabajo* (LFT), así como la posibilidad de vincular con la causa que motiva la interposición del recurso.

En relación con las deudas que por concepto de cuotas hubieren contraído a favor de sus patronos o de capitales constitutivos, los trabajadores sólo serán responsables por la cantidad excedente de su sueldo en un mes (fracc. XXIV). La fracc. XXVII determina:

Serán condiciones nulas y no obligarán a los contrayentes, aunque se expresen en el contrato:

[...]

g) Las que constituyan renuncia hecha por el obrero de las indemnizaciones a que tenga derecho por accidente del trabajo, y enfermedades profesionales, perjuicios ocasionados por el incumplimiento del contrato o despedírsele de la obra.

h) Todas las demás estipulaciones que impliquen renuncia de algún derecho consagrado a favor del obrero en las leyes de protección y auxilio a los trabajadores.

El inciso g) permite convalidar la vigencia de la fracc. XIV del mismo precepto y estimar el derecho inequívoco de los trabajadores a percibir la

indemnización, con independencia del seguro de riesgos de trabajo. El inciso h) nulifica a favor del trabajador la manifestación, en el contrato con la Administradora de Fondos para el Retiro (Afore), de que su capital pensionario (salario) puede ser objeto de pérdidas, la autorización para el cobro (descuento) de comisiones y el contrato de comisión mercantil contenido en la cláusula quinta.

Desde luego, hay que reiterar que la única fuente nutricia del Seguro Social está contenida en la fracc. XXIX del Apartado A del art. 123 constitucional. Este precepto, al señalar que la expedición de la *Ley del Seguro Social* (LSS) es de utilidad pública, impone la obligatoriedad de la cuota. El *Código Fiscal de la Federación* (CFF) que emana de la fracc. IV del art. 31 constitucional, además del numeral 73, resulta ajeno a la fracc. XXIX del art. 123, por lo que es discutible que en su art. 2º otorgue a la cuota del Seguro Social el carácter de contribución. La cuota es una prestación adicional al salario del trabajador, por lo que coincidimos con la opinión de Adolfo Arrijo Vizcaíno: "En nuestra opinión las aportaciones de seguridad social, en esencia, no deben formar parte de la relación jurídico tributaria, puesto que persiguen, como su mismo nombre lo indica, finalidades diversas de los tributos."¹

Cédulas de determinación

Por lo que se refiere al patrón, la LSS en sus arts. 39 a 40 F contiene una serie de reglas para efectuar los enteros al Instituto. El art. 39 dispone que las cuotas obrero-patronales se causan por mensualidades vencidas; impone al patrón la obligación de determinar los importes, en los formatos impresos o usando el programa informático autorizado por el Instituto. Con este fin, el Consejo Técnico emitió las reglas para limitar a cinco los trabajadores que pueden incluirse en los formatos; cuando se exceda, deberán utilizarse los medios electrónicos. Los patrones tienen la obligación de presentar ante el Instituto las cédulas de determinación de cuotas del mes de que se trate y realizar el pago respectivo a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente. Esta obligación subsiste para el supuesto de que no se realice el pago correspondiente dentro del plazo señalado; sin embargo, tiene carácter vinculatorio. El precepto otorga la naturaleza de definitivos a los capitales constitutivos, a partir del momento de notificarse y deben pagarse al Instituto, en los términos y plazos previstos en esta Ley. En mi opinión, estos capitales carecen de sustento legal, por lo que la interposición adecuada de una demanda de nulidad garantizaría su nulidad lisa y llana.

1 Adolfo Arrijo Vizcaíno, *Derecho fiscal*, Themis, México, 1985, p. 66.

Respecto a la cédula de determinación, el Instituto está facultado para entregarla como propuesta a los patrones. Esta cédula se elabora con los datos de los movimientos afiliatorios comunicados al Instituto por los propios patrones y, en su caso, por sus trabajadores, en los términos de la Ley. El patrón puede efectuar el pago u optar por modificar dicha cédula, en cuyo caso será vinculatoria, o simplemente ignorarla. La propuesta podrá entregarse al patrón en documento impreso, o bien, previa solicitud por escrito del patrón o su representante legal, en medios magnéticos, digitales, electrónicos o de cualquier otra naturaleza.

Cédulas de liquidación

Es frecuente que el patrón no elabore la cédula de determinación; en este supuesto que recomiendo, el Instituto podrá determinarlas presuntivamente. El término *presuntivo* es importante, pues implica que puede haber prueba en contra, y el Instituto estaría obligado a analizarla y emitir resolución. Lamentablemente, la prueba se denomina aclaración (art. 39 D). Así, las aclaraciones, debidamente sustentadas, deben presentarse ante la oficina que corresponda a su registro patronal. Sólo podrán versar sobre errores aritméticos, mecanográficos, avisos afiliatorios presentados previamente por el patrón al Instituto, certificados de incapacidad expedidos por éste o situaciones de hecho que no impliquen una controversia jurídica. La aclaración no suspende o interrumpe el plazo establecido para efectuar el pago hasta por la suma reconocida. El Instituto resolverá la aclaración en un plazo de 20 días; pero de no hacerlo en este lapso, lo hará sin límite de tiempo.

Esta fijación en cantidad líquida la elabora con base en los datos con que cuente o con apoyo en los hechos que conozca con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación de que goza como autoridad fiscal; es decir, por medio de una visita o revisión de gabinete. También puede establecerla a través de los expedientes o documentos proporcionados por otras autoridades fiscales. La determinación considerará tanto los saldos a favor del Instituto como los que pudiera haber a favor del patrón debido a errores en lo presentado por este último. Las cédulas deberán pagarlas los patrones dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos su notificación.

El patrón o sujeto obligado puede espontáneamente optar por regularizar su situación fiscal, conforme a los programas de regularización que en su caso se establezcan. El Instituto podrá proporcionarle, si así lo ha solicitado, la resolución correspondiente, sea de manera impresa o a través de medios magnéticos, digitales, electrónicos, ópticos, magneto ópticos o de cualquier otra naturaleza.

Las cédulas de liquidación que emita el Instituto por concepto de cuotas, capitales constitutivos, actualización, recargos o multas, se notificarán

a los patrones personalmente. El Instituto podrá optar, a solicitud del patrón, por realizar las notificaciones a través de medios magnéticos, digitales, electrónicos, ópticos, magneto ópticos o de cualquier otra naturaleza. En sustitución de la firma autógrafa se emplearán medios de identificación electrónica, y producirán los mismos efectos que la notificación firmada autógrafamente y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio que las disposiciones legales aplicables otorgan a ésta. Las notificaciones surtirán efecto al día hábil siguiente a aquel en que sean realizadas.

Cuando no se enteren las cuotas o los capitales constitutivos dentro del plazo establecido, se le fincarán al patrón, además de los créditos, la actualización y los recargos, así como las sanciones correspondientes. En este caso es mejor esperar que el Instituto notifique para que con base en los créditos pueda interponerse algún recurso o demanda. Es importante analizar los documentos recibidos, desde los fundamentos a la notificación, para que su combate pueda hacerse en la mejor forma para el patrón.

El Instituto está obligado a aceptar cualquier forma de pago directamente o por medio de compensación con las notas de crédito que expida para la devolución de cantidades enteradas sin justificación legal, o como resultado de algún recurso o juicio de nulidad. Estas notas de crédito serán válidas dentro de los cinco años siguientes a su expedición; si no se aplican, prescribirán a los 15 días de transcurrido el término.

Prórroga

El art. 40 establece que el Consejo Técnico del Instituto por el voto de al menos las tres cuartas partes de sus integrantes podrá autorizar, de manera excepcional y previa solicitud del patrón, el pago a plazos o diferido de las cuotas a su cargo, que se generen hasta por los seis periodos posteriores a la fecha de su solicitud, siempre que no tenga adeudos en los dos últimos ejercicios anteriores a la fecha de solicitud; que el Instituto no haya determinado y notificado diferencias en el pago de cuotas en los dos ejercicios anteriores, o bien que éstas hayan sido aclaradas o, en su caso, pagadas. Se deberá cubrir al menos 10% de la emisión del periodo respectivo solicitado. El plazo no excederá de 12 meses, a partir del último periodo a que se refiera la solicitud correspondiente. Deben demostrarse a satisfacción del Instituto las razones económicas excepcionales por las cuales no puede cumplir con sus obligaciones, y se garantizará el interés fiscal mediante embargo administrativo, bien inmueble o póliza de fianza. El Instituto emitirá y notificará la resolución correspondiente.

Artículo 40 C. El Instituto a solicitud de los patrones podrá conceder prórroga para el pago de los créditos adeudados por concepto de cuotas, capitales

constitutivos, actualización, recargos y multas. Durante el plazo concedido se causarán recargos sobre el saldo insoluto actualizado en los términos que establece el Código. Se podrá solicitar plazo para el pago en parcialidades, el cual no excederá de cuarenta y ocho meses; su trámite se realiza por medio del Subdelegado; en caso de negativa podrá recurrirlas y de no haber respuesta en tres meses podrá demandar por negativa ficta. También podrá solicitarse el pago diferido, para lo cual se celebrará un convenio para determinar el tiempo de pago, pero en el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, se podrá autorizar sólo por periodos completos adeudados, sin condonación de accesorios, además de que el Instituto informará a la Consar, así como a las Afore, mediante reglas generales determine la misma Comisión.

Recurso administrativo

La LSS determina en los arts. 294 y 295 que las controversias surgidas entre la administración y los derechohabientes o los patrones podrán dirimirse ante el Consejo Técnico Delegacional mediante los recursos de inconformidad. En relación con los derechohabientes, se consigna la posibilidad de que pueda interponerse demanda ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. En cuanto a los patrones, existe la opción de hacer valer el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. El recurso de inconformidad se llevará conforme al procedimiento que establece el reglamento respectivo.

El recurso de inconformidad, contenido en el art. 133 de la LSS de 1943, establecía un catálogo de asuntos que podrían ser motivo de interposición, por parte tanto de los patrones como de los derechohabientes. La LSS de 1973, en su art. 274, estipulaba la condición de agotar el recurso de inconformidad ante el Consejo Técnico del IMSS, contra actos definitivos; lo mismo sucedía con la Ley vigente a partir del 1 de julio de 1997, en el art. 294. La reforma del 20 de diciembre de 2001 elimina la condición necesaria de agotar el recurso de inconformidad, en los términos anotados.

El Reglamento vigente aplica supletoriamente el CFF, la LFT y el *Código Federal de Procedimientos Civiles* (CFPC), con lo que contraría al art. 9 de la Ley, que marca en primer lugar la LFT. El recurso se tramita ante los consejos consultivos delegacionales, quienes lo resuelven. El Secretario del Consejo tramita el recurso con apoyo de los Servicios Jurídicos Delegacionales y está facultado para dejar sin efecto el acto impugnado en aquellos casos en que se advierta notoriamente que el mismo encuadra en alguna de las causales que señalan los arts. 38 o 238 del CFF. En caso de que en el recurso presentado surja una controversia del orden familiar, el Secretario declarará incompetente al Consejo Consultivo Delegacional, dejando a salvo los derechos del inconforme. El Consejo Técnico resolverá los recursos que se interpongan

en contra de dichas resoluciones. El Secretario General del Instituto gozará de las mismas facultades que en materia de tramitación del recurso y formulación del proyecto de resolución, están conferidas al Secretario del Consejo Consultivo Delegacional.

El escrito en que se interponga el recurso de inconformidad (art. 4º), deberá contener lo siguiente:

- I. Nombre y firma del recurrente; domicilio para oír y recibir notificaciones, así como el número de su registro patronal o de seguridad social como asegurado, según sea el caso. En caso de que el promovente no sepa o no pueda firmar o estampar su huella digital, lo podrá realizar otra persona en su nombre;
- II. Acto que se impugna y, en su caso, número y fecha de la resolución, número de crédito, periodo e importe, fecha de su notificación y autoridad emisora del mismo;
- III. Hechos que originan la impugnación;
- IV. Agravios que le cause el acto impugnado;
- V. Nombre o razón social del patrón o, en su caso, del sindicato de trabajadores titular del contrato colectivo de trabajo, así como el domicilio en donde puedan ser notificados, para los casos previstos en el artículo 7 de este Reglamento, y
- VI. Pruebas que se ofrezcan, relacionadas con el acto impugnado.

Si el escrito por el cual se interpone el recurso de inconformidad fuere oscuro, irregular o no cumpliera con los requisitos señalados, el Secretario del Consejo Consultivo Delegacional prevendrá al recurrente, por una sola vez, para que lo aclare, corrija o complete de acuerdo con las fracciones anteriores, y señalará en concreto sus defectos u omisiones, con el apercibimiento de que, si el recurrente no cumple dentro del término de cinco días, lo desechará de plano.

El recurso de inconformidad se interpondrá dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que surta efecto la notificación del acto definitivo que se impugne y se dirigirá al Consejo Consultivo Delegacional, presentándose directamente en la sede delegacional o subdelegacional que corresponda a la autoridad emisora del acto impugnado. Si el recurso se interpone extemporáneamente será desechado de plano.

En los casos de inconformidades interpuestas por los patrones contra valuaciones actuariales de sus contratos colectivos (art. 7º), hechas por el Instituto en los términos de la parte final del art. 23 de la LSS, el Secretario del Consejo Consultivo Delegacional dará vista a los sindicatos titulares de los contratos valuados para que, en el término de ocho días, manifiesten su anuencia u oposición con los puntos de vista patronales y, en su caso, aporten pruebas y expresen lo que a su interés convenga. Tratándose de inconformidades que interpongan los asegurados o sus beneficiarios para reconocimiento de prestaciones en efectivo, mayores que las concedidas por el Instituto o de derechos

que pudieran afectar los intereses del patrón, se correrá traslado con la promoción respectiva a este último para que intervenga en el procedimiento.

El recurso es improcedente (art. 13) cuando se haga valer contra actos administrativos:

- I. Que no afecten el interés jurídico del recurrente;
- II. Que sean resoluciones dictadas en recursos administrativos o en cumplimiento de sentencias, laudos o de aquellas;
- III. Que hayan sido impugnados ante el Tribunal Fiscal de la Federación;
- IV. Que sean materia de otro recurso o juicio pendiente de resolución ante una autoridad administrativa u órgano jurisdiccional;
- V. Que se hayan consentido, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promovió el recurso en el plazo y términos señalados en el artículo 6 de este Reglamento;
- VI. Que sea conexo a otro que haya sido impugnado a través de algún recurso o medio de defensa diferente;
- VII. Que hayan sido revocados administrativamente por la autoridad emisora;
- VIII. Cuando de las constancias del expediente se desprenda que no existe el acto reclamado, o que el mismo se ha dejado sin efectos, y
- IX. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición legal o reglamentaria.

El sobreseimiento procede (art. 14):

- I. Por desistimiento expreso del recurrente;
- II. Cuando durante el procedimiento aparezca o sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior, y
- III. En el caso de que el recurrente muera durante el procedimiento si su pretensión es intransferible o si su muerte deja sin materia el recurso.

Admitido el recurso, el Secretario del Consejo Consultivo Delegacional pedirá de oficio los informes conducentes a las dependencias del Instituto, las cuales deberán rendirlos en el término de 10 días naturales. Concluido el término de desahogo de pruebas, el Secretario del Consejo Consultivo Delegacional elaborará, dentro del término de 30 días, los proyectos de resolución.

La suspensión del procedimiento administrativo de ejecución será ordenada por el Secretario General del Instituto o el Secretario del Consejo Consultivo Delegacional, si se solicita desde la interposición del recurso o durante la tramitación del mismo. El Secretario del Consejo recibe la solicitud de suspensión del procedimiento administrativo de ejecución y la remitirá al Jefe de la Oficina para Cobros que corresponda, quien calificará la garantía, informando al Secretario para que dicte el acuerdo procedente.

La suspensión se sujetará a las normas aplicables del CFF y deberán otorgarse las garantías que el referido ordenamiento establece, quedando las mismas en custodia de los servicios de tesorería que correspondan.

El recurso administrativo constituye, cuando se tramita en apego a las normas estrictas de la Ley, una oportunidad para que la autoridad administrativa revise sus propios actos en una instancia superior, los reconsidere y los revoque, cuando sean contrarios a la Ley. Esto permite que la administración pública sea "celosa guardiana del interés general". El recurso interpuesto, como afirma Alfonso Nava Negrete, "significa la garantía de un buen régimen de organización administrativa, lo que le permite revisar sus propios actos, si éstos carecen de legalidad o de oportunidad".²

El maestro Antonio Carrillo Flores sostiene que la autotutela

... de la administración pública deriva de la posibilidad en que la Administración se encuentra... para revocar, o reformar, anular o suspender una decisión administrativa sin que estas medidas sean la consecuencia de un derecho subjetivo hecho valer por un particular frente a la Administración, sino, o bien de una acción espontánea, oficiosa, de ésta o de una simple denuncia del particular, que puede ser un interesado en el caso, pero titular... (del) interés simple; interés al que el derecho objetivo no ha asociado como consecuencia jurídica la posibilidad de una pretensión individualizada. La denuncia puede existir o no; lo característico en esto que se llama la auto tutela de la Administración, es que el Estado obra preponderantemente por lo que él juzga un interés público y sólo en forma secundaria para la salvaguarda de un interés privado.³

Además,

... frente a los actos de tal naturaleza se ha reconocido la necesidad, para evitar un recargo en las labores de los órganos jurisdiccionales y por considerarse que los actos de los inferiores deben estar sujetos a revisión por las autoridades superiores, de dotar a los particulares de recursos o medios de defensa ante la propia administración pública, por virtud de los cuales pueda lograrse la nulificación de los actos o resoluciones dictadas con violación a la ley aplicada.⁴

- 2 Alfonso Nava Negrete, *Derecho administrativo mexicano*, Fondo de Cultura Económica, México, 1995, p. 66.
- 3 Antonio Carrillo Flores, *La defensa jurídica de los particulares frente a la administración en México*, Colección de Obras Clásicas, t. I, Tribunal Fiscal de la Federación, México, 2000, p. 93.
- 4 Emilio Margáin Manatou, *El recurso administrativo en México*, Porrúa, México, 2008, p. 27.

En este sentido, el doctor Manuel Hallivis Pelayo sostiene:

... cuando los derechos de los contribuyentes han sido violados por la autoridad es necesaria la existencia de medios legales de defensa que permitan a su titular la anulación o modificación del acto de autoridad. Como lo dice la maestra Villalobos, "ante una actuación administrativa irregular, ha de buscarse que sea corregida dentro del orden existente con aquellos remedios legales que sean idóneos para el restablecimiento de la situación vulnerada", de ahí que nuestra legislación prevea la existencia del recurso de revocación y del juicio de nulidad, además de la vía de amparo ante el poder judicial.⁵

A pesar de las bondades que debía tener el recurso de inconformidad, su planteamiento es complicado porque está sujeto a las disposiciones del Reglamento de Inconformidades, cuya observancia es rigurosa, de tal forma que la ausencia de algún elemento da lugar a una prevención o al desechamiento. El recurso debía ser de fácil acceso, sin necesidad de acudir a un abogado, lo que en la práctica no acontece. Es recomendable, en consecuencia, acudir al juicio de nulidad, como veremos en el apartado siguiente.

Para mayor apoyo de los litigantes hago de su conocimiento el formato en la página siguiente.

Juicio fiscal

La impartición de justicia por parte del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, derivada de la competencia que le confiere el art. 14 de su Ley Orgánica, no se limita a revisar y declarar, cuando procede, la nulidad de los actos administrativos, sino a impartir justicia, condenando a hacer o dejar de hacer, cuando procede.

Los juicios que se promuevan ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se registrarán por las disposiciones de la *Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo* (LFPCA), sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales de que México sea parte. A falta de disposición expresa se aplicará supletoriamente el CFPC. El art. 295 de la LSS dispone que las controversias entre patrones y el Instituto se dirimen ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

La demanda se presentará por escrito directamente ante la sala regional competente, dentro de los 45 días siguientes a aquel en el que haya surtido efecto la notificación de la resolución impugnada, haya iniciado su vigencia el

5 Manuel Hallivis Pelayo, *Tratado de derecho fiscal y administración*, Tax Editores Unidos, México, 2000, p. 110.

RECURSO DE INCONFORMIDAD
REGISTRO PATRONAL. ()**H. CONSEJO CONSULTIVO DELEGACIONAL EN ()**
DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.
P R E S E N T E.

(), por mi propio derecho, señalo como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado (

), autorizo para oír las al Lic. Alberto Briceño Ruiz, así como al pasante Miguel Ángel Alejo Olivares, comparezco para exponer:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 294 y 295 de la Ley del Seguro Social, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Recurso de Inconformidad interpongo en tiempo y forma, recurso de inconformidad en contra de las cédulas de liquidación que se me notificaron el día () de () de este año, donde me fincan los créditos números _____ y por los periodos _____.

Para dar cumplimiento a lo ordenado por el artículo 4° del Reglamento de Inconformidad de la Ley del Seguro Social, proporciono los siguientes datos:

1. Nombre, domicilio y registro patronal del Recurrente.-
2. Acto que se impugna.-
3. Autoridad emisora y fecha de notificación.-

HECHOS.

- 1.- (...)
- 2.- (...)
- 3.- (...)

AGRAVIOS

(...)

Por lo expuesto y fundado, a usted C. Subdelegado, atentamente pido:

PRIMERO.- Tenerme por presentada en los términos del presente escrito, por el que interpongo recurso de inconformidad.

SEGUNDO.- Ordenar que, con fundamento en lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 6 del Reglamento de Recurso de Inconformidad, se turne el presente al H. Consejo Consultivo Delegacional.

TERCERO.- En el momento procesal oportuno, y dadas las consideraciones apuntadas, dejar sin efecto las cédulas de liquidación que he descrito en el presente recurso.

México, Distrito Federal, a ____ de octubre de 200__.

(...)

Anexos: copia de las cédulas de liquidación.

decreto, acuerdo, acto o resolución administrativa de carácter general impugnada cuando sea autoaplicativa; 45 días siguientes a aquel en el que surta efecto la notificación de la resolución de la sala o sección que habiendo conocido una queja, decida que la misma es improcedente y deba tramitarse como juicio. Para ello deberá prevenir al promovente para que presente demanda en contra de la resolución administrativa que tenga carácter definitivo.

Cuando el demandante tenga su domicilio fuera de la población donde esté la sede de la Sala, la demanda podrá enviarse por el Servicio Postal Mexicano, mediante correo certificado con acuse de recibo, siempre que el envío se efectúe en el lugar en que resida el demandante; en este caso puede señalar como domicilio para recibir notificaciones, el ubicado en cualquier parte del territorio nacional, salvo cuando tenga su domicilio dentro de la jurisdicción de la Sala Competente, en cuyo caso, el domicilio señalado para tal efecto deberá estar ubicado dentro de la circunscripción territorial de la Sala.

Artículo 14. La demanda deberá indicar:

- I. El nombre del demandante y su domicilio para recibir notificaciones en cualquier parte del territorio nacional, así como su Dirección de Correo electrónico, cuando opte porque el juicio se substancie a través del Sistema de Justicia en Línea.
- II. La resolución que se impugna. En el caso de que se controvierta un decreto, acuerdo, acto o resolución de carácter general, precisará la fecha de su publicación.
- III. La autoridad o autoridades demandadas o el nombre y domicilio del particular demandado cuando el juicio sea promovido por la autoridad administrativa.
- IV. Los hechos que den motivo a la demanda.
- V. Las pruebas que ofrezca.
- VI. Los conceptos de impugnación.
- VII. El nombre y domicilio del tercero interesado, cuando lo haya.
- VIII. Lo que se pida, señalando en caso de solicitar una sentencia de condena, las cantidades o actos cuyo cumplimiento se demanda.

Se podrá ampliar la demanda, dentro de los 20 días siguientes a aquel en que surta efecto la notificación del acuerdo que admita su contestación, cuando se impugne una negativa ficta; contra el acto principal del que derive la resolución impugnada en la demanda, así como su notificación, cuando se den a conocer en la contestación; cuando con motivo de la contestación, se introduzcan cuestiones que no sean conocidas por el actor al presentar la demanda; cuando la autoridad demandada plantee el sobreseimiento del juicio por extemporaneidad en la presentación de la demanda (art. 17).

Admitida la demanda se correrá traslado de ella al demandado, emplazándolo para que la conteste dentro de los 45 días siguientes a aquel en que surta efecto el emplazamiento. El plazo para contestar la ampliación de la demanda será de 20 días siguientes a aquel en que surta efecto la notificación del

acuerdo que admita la ampliación. Si no se produce la contestación a tiempo o ésta no se refiere a todos los hechos, se tendrán como ciertos los que el actor impute de manera precisa al demandado, salvo que por las pruebas rendidas o por hechos notorios resulten desvirtuados.

En su contestación y en la contestación de la ampliación de la demanda, el demandado expresará los incidentes de previo y especial pronunciamiento a que haya lugar, las consideraciones que, a su juicio, impidan que se emita decisión en cuanto al fondo o demuestren que no ha nacido o se ha extinguido el derecho en que el actor apoya su demanda. Se referirá concretamente a cada uno de los hechos que el demandante le impute de manera expresa, afirmándolos, negándolos, expresando que los ignora por no ser propios o exponiendo cómo ocurrieron, según sea el caso; los argumentos por medio de los cuales se demuestra la ineficacia de los conceptos de impugnación y los que desvirtúen el derecho a indemnización que solicite la actora; además de las pruebas que ofrezca. En la contestación de la demanda no podrán cambiarse los fundamentos de derecho de la resolución impugnada.

Artículo 80. Es improcedente el juicio ante el Tribunal en los casos, por las causales y contra los actos siguientes:

- I. Que no afecten los intereses jurídicos del demandante.
- II. Que no le competa conocer a dicho Tribunal.
- III. Que hayan sido materia de sentencia pronunciada por el Tribunal, siempre que hubiera identidad de partes y se trate del mismo acto impugnado, aunque las violaciones alegadas sean diversas.
- IV. Cuando hubiere consentimiento, entendiéndose que hay consentimiento si no se promovió algún medio de defensa en los términos de las leyes respectivas o juicio ante el Tribunal, en los plazos que señala esta Ley.
- V. Que sean materia de un recurso o juicio que se encuentre pendiente de resolución ante una autoridad administrativa o ante el propio Tribunal.
- VI. Que puedan impugnarse por medio de algún recurso o medio de defensa, con excepción de aquéllos cuya interposición sea optativa.
- VII. Conexos a otro que haya sido impugnado por medio de algún recurso o medio de defensa diferente, cuando la ley disponga que debe agotarse la misma vía.
- VIII. Que hayan sido impugnados en un procedimiento judicial.
- IX. Contra reglamentos.
- X. Cuando no se hagan valer conceptos de impugnación.
- XI. Cuando de las constancias de autos apareciere claramente que no existe la resolución o acto impugnados.
- XII. Que puedan impugnarse en los términos del artículo 97 de la Ley de Comercio Exterior, cuando no haya transcurrido el plazo para el ejercicio de la opción o cuando la opción ya haya sido ejercida.

xiii. Dictados por la autoridad administrativa para dar cumplimiento a la decisión que emane de los mecanismos alternativos de solución de controversias a que se refiere el artículo 97 de la Ley de Comercio Exterior.

xiv. Que hayan sido dictados por la autoridad administrativa en un procedimiento de resolución de controversias previsto en un tratado para evitar la doble tributación, si dicho procedimiento se inició con posterioridad a la resolución que recaiga a un recurso de revocación o después de la conclusión de un juicio ante el Tribunal.

xv. Que sean resoluciones dictadas por autoridades extranjeras que determinen impuestos y sus accesorios cuyo cobro y recaudación hayan sido solicitados a las autoridades fiscales mexicanas, de conformidad con lo dispuesto en los tratados internacionales sobre asistencia mutua en el cobro de los que México sea parte.

xvi. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de esta Ley o de una ley fiscal o administrativa.

Artículo 9o. Procede el sobreseimiento:

i. Por desistimiento del demandante.

ii. Cuando durante el juicio aparezca o sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior.

iii. En el caso de que el demandante muera durante el juicio si su pretensión es intransmisible o, si su muerte, deja sin materia el proceso.

iv. Si la autoridad demandada deja sin efecto la resolución o acto impugnados, siempre y cuando se satisfaga la pretensión del demandante.

v. Si el juicio queda sin materia.

vi. En los demás casos en que por disposición legal haya impedimento para emitir resolución en cuanto al fondo.

El sobreseimiento del juicio podrá ser total o parcial.

Diez días después de que haya concluido la sustanciación del juicio y no existiere ninguna cuestión pendiente que impida su resolución, el Magistrado Instructor notificará por lista a las partes, que tienen un término de cinco días para formular alegatos por escrito. Los alegatos presentados en tiempo deberán ser considerados al dictar sentencia.

Artículo 49. La sentencia se pronunciará por unanimidad o mayoría de votos de los magistrados integrantes de la Sala, dentro de los sesenta días siguientes a aquél en que se dicte el acuerdo de cierre de instrucción en el juicio. Para este efecto el Magistrado Instructor formulará el proyecto respectivo dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a aquél en que se dictó dicho acuerdo. Para dictar resolución en los casos de sobreseimiento por alguna de las causas previstas en el art. 9o. de esta Ley, no será necesario que se hubiese cerrado la instrucción.

Artículo 50. Las sentencias del Tribunal se fundarán en derecho y resolverán sobre la pretensión del actor que se deduzca de su demanda, en relación con una resolución impugnada, teniendo la facultad de invocar hechos notorios.

Cuando se hagan valer diversas causales de ilegalidad, la sentencia de la Sala deberá examinar primero aquéllas que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana. En el caso de que la sentencia declare la nulidad de una resolución por la omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, o por vicios de procedimiento, la misma deberá señalar en qué forma afectaron las defensas del particular y trascendieron al sentido de la resolución.

La sentencia definitiva podrá reconocer la validez de la resolución impugnada y declarar la nulidad de dicha resolución para determinados efectos, debiendo precisar con claridad la forma y los términos en que la autoridad ha de cumplirla, obligándose a reponer el procedimiento, en su caso, desde el momento en que se cometió la violación.

Las autoridades demandadas y cualquiera otra autoridad relacionada están obligadas a cumplir las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte.

Artículo 58.

[...]

1. La Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere pronunciado la sentencia podrá de oficio, por conducto de su Presidente, en su caso, requerir a la autoridad demandada que informe, dentro de los tres días siguientes, respecto al cumplimiento de la sentencia. Se exceptúan de lo dispuesto en este párrafo las sentencias que hubieran señalado efectos, cuando la resolución impugnada derive de un procedimiento oficioso.

Concluido el término anterior con informe o sin él, la Sala Regional, la Sección o el Pleno de que se trate, decidirá si hubo incumplimiento injustificado de la sentencia, en cuyo caso procederá como sigue:

a) Impondrá a la autoridad demandada responsable una multa de apremio que se fijará entre trescientos y mil veces el salario mínimo general diario que estuviere vigente en el Distrito Federal, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento y las consecuencias que ello hubiere ocasionado, requiriéndola a cumplir con la sentencia en el término de tres días y previniéndole, además, de que en caso de renuencia se le impondrán nuevas multas de apremio en los términos de este inciso, lo que se informará al superior jerárquico de la autoridad demandada.

b) Si al concluir el plazo mencionado en el inciso anterior persistiere la renuencia de la autoridad demandada a cumplir con lo sentenciado, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá requerir al superior jerárquico de aquélla para que en el plazo de tres días la obligue a cumplir sin demora.

De persistir el incumplimiento, se impondrá al superior jerárquico una multa de apremio de conformidad con lo establecido en el inciso a).

c) Cuando la naturaleza del acto lo permita, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá comisionar al funcionario jurisdiccional que, por la índole de sus funciones estime más adecuado, para que dé cumplimiento a la sentencia.

d) Transcurridos los plazos señalados en los incisos anteriores, la Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere emitido el fallo pondrá en conocimiento de la Contraloría Interna correspondiente los hechos, a fin de [que] ésta determine la responsabilidad del funcionario responsable del incumplimiento.

II. A petición de parte, el afectado podrá ocurrir en queja ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que la dictó, de acuerdo con las reglas siguientes:

a) Procederá en contra de los siguientes actos:

1. La resolución que repita indebidamente la resolución anulada o la que incurra en exceso o en defecto, cuando se dicte pretendiendo acatar una sentencia.

2. La resolución definitiva emitida y notificada después de concluido el plazo establecido por los artículos 52 y 57, fracción I, inciso b), de esta Ley, cuando se trate de una sentencia dictada con base en las fracciones II y III del art. 51 de la propia Ley, que obligó a la autoridad demandada a iniciar un procedimiento o a emitir una nueva resolución, siempre y cuando se trate de un procedimiento oficioso.

3. Cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia.

4. Si la autoridad no da cumplimiento a la orden de suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo federal.

Respecto del incumplimiento a la orden de suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado, procederá la queja mediante escrito interpuesta en cualquier momento ante el instructor. El mismo art. 58 establece en la fracc. III:

El magistrado pedirá un informe a la autoridad a quien se impute el incumplimiento de la sentencia interlocutoria que hubiese otorgado la suspensión definitiva, que deberá rendir dentro del plazo de cinco días, en el que, en su caso, se justificará el acto o la omisión que provocó la queja. Vencido dicho plazo, con informe o sin él, el magistrado dará cuenta a la Sala, la que resolverá en un plazo máximo de cinco días.

Si la Sala resuelve que hubo incumplimiento de la suspensión otorgada, declarará la nulidad de las actuaciones realizadas en violación a la suspensión.

La resolución a que se refiere esta fracción se notificará también al superior del funcionario responsable, entendiéndose por éste al que incumpla la suspensión decretada, para que proceda jerárquicamente y la Sala impondrá al funcionario responsable o autoridad renuente, una multa equivalente a un mínimo de quince días de su salario, sin exceder del equivalente a cuarenta y cinco días del mismo.

La trascendencia que tiene la seguridad social en el ámbito de competencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa implica "emprender el análisis preliminar de ciertas nociones fundamentales, así como lanzar una mirada de conjunto sobre la trayectoria que sigue la Administración (Pública) en el Estado contemporáneo", como nos ilustra el maestro Antonio Carrillo Flores.⁶

A continuación se presenta el formato de demanda:

DEMANDANTE:

(...)

AUTORIDADES DEMANDADAS:

- Subdelegado en _____ del Instituto
Mexicano del Seguro Social
- Delegado en _____ del Instituto
Mexicano del Seguro Social
- y Director General del Instituto
Mexicano del Seguro Social.

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL.

C. C. MAGISTRADOS DE LA SALA REGIONAL

**_____ DEL TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.
P R E S E N T E S.**

(...) promoviendo en representación de (...), personería que acredito en términos del testimonio notarial que en copia certificada acompaño como **Anexo 1**, señalo como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en (...), autorizo para tal efecto al señor licenciado (...), con cédula expedida por la Dirección General de Profesiones No. ____; a los pasantes en derecho (...) respetuosamente comparezco para exponer:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14, fracciones II y XIV, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 14 y 15 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, **vengo a demandar lo siguiente:**

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 14 y 15 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, **vengo a demandar lo siguiente:**

- a) (...)
- b) (...)
- c) (...)

⁶ Antonio Carrillo Flores, *op. cit.*, p. 23.

En cumplimiento a lo ordenado por el artículo 14 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a continuación preciso los siguientes datos:

1. Nombre del demandante y su domicilio para oír notificaciones.-
(...)
2. Las resolución que se impugna.-
(...)
3. Las autoridades demandadas.-
(...)
4. Tercero Interesado.-
(...)

Conforme a lo ordenado por el artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se acompañan:

1. Cinco copias de la demanda y de los documentos anexos para las demandadas.
2. El documento en que consta la fecha de presentación de la solicitud formulada ante la Subdelegación del IMSS en _____.
3. Las pruebas documentales que debidamente relacionadas ofrezco y anexo a la presente demanda.

Lo demás lo expreso en los siguientes:

HECHOS:

1. (...)
2. (...)

Atento a lo anterior, me permito elevar a su consideración los siguientes conceptos de impugnación tendientes a combatir el fondo del asunto planteado, es decir, acreditar que mi representada tiene derecho al pago que reclama, sin que exista justificación legal, por la declaratoria de nulidad, para que el organismo fiscal demandado conserve en su patrimonio la garantía que fue otorgada.

CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN.

PRIMERO.

Preceptos violados:

De la Ley del Seguro Social:

Del Código Fiscal de la Federación:

SEGUNDO.

Preceptos violados:

De la Ley del Seguro Social:

Del Código Fiscal de la Federación:

RAZONAMIENTOS LÓGICO JURÍDICOS.

P R U E B A S

1.- DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en copia certificada del escrito...

2.- DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en copia de la...

Por lo expuesto y fundado,

A USTEDES CC. MAGISTRADOS DE LA SALA REGIONAL DE _____
_____, atentamente pido:

PRIMERO.- Tenerme por presentada en los términos del presente libelo, y por acreditada la personería con que me ostento.

SEGUNDO.- Admitir a trámite la presente Demanda de Nulidad, en los términos que han quedado expuestos; por señalado el domicilio para oír y recibir notificaciones y, por autorizadas a las personas mencionadas para tales efectos.

TERCERO.- Tener por ofrecidas las pruebas que se mencionan en el presente escrito, las cuales por ser documentales públicas se desahogan por su propia y especial naturaleza.

CUARTO.- Declarar la nulidad lisa y llana de la negativa ficta impugnada y, en consecuencia, ordenar al Instituto Mexicano del Seguro Social devuelva la garantía del interés fiscal de los créditos, con la actualización y los recargos correspondientes, en los términos de la fracción V, inciso a), del artículo 52 en relación con la fracción II del artículo 57 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

México, D.F. a ____ de _____ de 200,____

(...)

Anexos: Copia certificada poder notarial.
 Copia certificada de las resoluciones combatidas.
 Copia certificada de cada prueba.

Bibliografía

.....

- Acharan Balv, Boris, "La evolución de la seguridad social", vol. II de *Memorias de Derecho del Trabajo*, Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 1950.
- Barnes, H.E. y H. Becker, *Historia del pensamiento social*, t. 1, Fondo de Cultura Económica, México.
- Beveridge, William, *Las bases de la seguridad social*, Fondo de Cultura Económica, México, 1987.
- Bowen Herrera, Alfredo, *Introducción a la seguridad social*, 3ª ed. actualizada, Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 1992.
- Briceño Ruiz, Alberto, *Derecho mexicano de los seguros sociales*, Harla, México, 1987.
- _____, *Derecho individual del trabajo*, Harla, México, 1985.
- Carrasco Iriarte, Hugo, *Derecho fiscal constitucional*, Oxford University Press México, 1999.
- Cazares García, Gustavo, *Derecho de la seguridad social*, Porrúa, México, 2007.
- Cordini, Miguel A., *Derecho de la seguridad social*, Eudeba, Buenos Aires, 1966.
- De la Garza, Sergio Francisco, *Derecho financiero mexicano*, Porrúa, México, 2003.
- Evaluación y tendencias de los sistemas de pensiones en México*, Porrúa, México, 2009.
- Flores Álvarez, Marcos, *Actas del Primer Congreso Iberoamericano de Seguridad Social*.
- García Cruz, Miguel, *La seguridad social*, México, 1951.

- Gómez, Ramón, *Convivencias Interamericanas de Reciprocidad de Prestaciones de Seguridad Social. Contribución a la Tercera Reunión de la Conferencia Internacional de Seguridad Social*, México, 1951.
- González Gales, José, *Previsión social*, Academia de Ciencias Económicas, Ediciones Especiales, núm. 11, Losada, Buenos Aires, 1964.
- González Roaro, Benjamín, *La seguridad social en el mundo, Siglo XXI*, México, 2003.
- Los derechos del pueblo mexicano*, Porrúa, México, 1978.
- Macías Santos, Eduardo *et al.*, *El sistema de pensiones en México dentro del contexto internacional*, Themis, México, 1993.
- Martone, Francisco José, *Seguro social obligatorio*, Buenos Aires, 1951.
- Massa, Sergio Tomás y Miguel A. Fernández Pastor, *De la exclusión a la inclusión social*, Prometeo Libros, Buenos Aires, 2007.
- México y la seguridad social*, Stylo, México, 1952
- Monzón, Máximo Daniel, "El seguro social moderno", en *Revista del Instituto Nacional de Previsión Social*, núm. 3, diciembre de 1946.
- Mussot L., María Luisa (coord.), *Alternativas de reforma de la seguridad social*, Fundación Friedrich Ebert, México, 1996.
- Poblete Troncoso, Moisés, *El derecho del trabajo y la seguridad social en Chile*, Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 1949.
- Radbruch, Gustav, *Los fines del derecho*, UNAM, México, 1981.
- Ruezga, Antonio (compilador), *El nuevo derecho de las pensiones en América Latina*, Biblioteca CIESS 3, México, 2005.
- Ruiz Moreno, Ángel Guillermo, *Nuevo derecho de la seguridad social*, Porrúa, México, 1997.
- _____. *Las Afore. El sistema de ahorro y pensiones mexicano*, Porrúa, México, 2009.
- Sierra López, Miguel A., "Inseguridad, seguridad jurídica y seguridad social", en *Boletín de Información Jurídica*, IMSS, núm. 15, septiembre-octubre de 1985.

Índice onomástico

.....

Acharan Balv, Boris, 15
Acuña, Nelda E., 77
Adriano, 32
Aguirre, Francisco, 273, 302
Alatriste, Saltiel, 96
Alemán Valdés, Miguel, 94
Amescua, Norahenid, 137, 288,
290, 351
Anaxágoras, 31
Arce Cano, Gustavo, XIV
Arias, Pablo C., 77
Arrijoa Vizcaína, Adolfo, 386
Ávila Camacho, Manuel, XVI, 90-91, 374

Bacon, Francis, 37
Bailleres, Alberto, 226
Bakunin, Mijail, 46
Barnes, Harry Elmer, 36
Basave, Agustín, 7
Bebel, 46
Becker, Howard, 36
Bene, Francisco del, 35
Benítez de Lugo, 35
Bentham, Jeremias, 7
Bernardone, Pedro, 34
Bernoulli, Jacob, 40
Beveridge, William, XV, 52-53
Bismarck, Otto von, XV, 47, 53
Booth, Charles, 51

Borrego, Genaro, 110, 212
Bougle, 41
Boulton, Mateo, 41
Briceño Ruiz, Alberto, XIII-XVIII
Burckhardt, Jacobo, 31

Calderón, E.B., 81
Campanella, Tommaso, 37
Cantlon, Axel, 77
Caracalla, 32
Cárdenas, Lázaro, XIV, 89
Cárdenas de la Peña, Enrique, 227
Cardona, Francesc Ll., 44
Carlos I, 37
Carnelutti, 158
Carranza, Venustiano, 80
Carrasco Iriarte, Hugo, 378
Carrillo Flores, Antonio, 392, 400
Castorena, Jesús, XIV
Castorena, Maclovio, XIV
Cazares García, Gustavo, 70
Cerdà, Ildefonso, 44-45
Chalmers, Tomas, 41
Chamberlain, Joseph, 51
Churchill, Winston Spencer, XV, 51-53
Cirigo Barrón, Rosa H., 136
Clinton, Bill, 212, 270
Conchello Dávila, José Ángel, 212-213, 293,
353-354

- Coppola, 4
 Coquet, Benito, 96
 Cordini, Miguel A., 12
 Crawford, Leslie, 211

 D'Ángelo, Jorge Isaac, 77
 De la Cueva, Mario, XIV
 De la Garza, Sergio Francisco, 374
 De la Torre, Jesús, 81
 De los Ríos, Rafael, 81
 Delano Roosevelt, Franklin, 69
 Despercieux, Antoine, 40
 Dewitt, John, 39
 Díaz, Porfirio, 79
 Díaz Ordaz, Gustavo, 94, 96
 Dorador, Silvestre, 81

 Echeverría Álvarez, Luis, XVI, 96-97
 Eduardo II, 37
 Engels, Friedrich, 44-46
 Enrique VIII, 36-37

 Felipe II, 36-37
 Fernández Pastor, Miguel A., 74-75
 Figueroa, Laureano, 45
 Flores Álvarez, Marcos, 12
 Foncercada, Javier, 211
 Fox Quezada, Vicente, 208
 Fusinato, 151

 Galvez Betancourt, Carlos, 96
 Gamietea, Jorge Alfredo, 77
 Gaos, José, 196
 García Corachan, M., 151-152
 García Cruz, Miguel, 13
 García Téllez, Ignacio, XIV, 95, 276
 Gide, 41
 Gioia, Gustavo Daniel, 77
 Giscard d'Estaing, Valéry, 271
 Gómez, Ramón, 13
 Góngora, Victorio E., 81
 González, Felipe, 3
 González Blanco, Salomón, XIV
 González de Gante, Diego, 36
 González Gale, José, 14
 González Roaro, Benjamín, 68-69, 77
 Greenwood, Arthur, 52
 Guillermo I, XV, 47
 Graunt, John, 39

 Halley, Edmund G., 39-40
 Hallivis Pelayo, Manuel, 393
 Hasenclever, 46
 Hasselman, 46
 Herófilo, 32
 Hidalgo, Miguel, XVI
 Hill, Octavia, 41
 Hobson, 41
 Hori Robaina, Guillermo, XIV

 Inocencio III, 34

 Jarach, Dino, 12
 Josserand, 151

 Kerseboom, 40
 Kuapp, Ludwig, 7
 Kuczynski, 44

 Laplace, Pierre-Simon, 40
 Lasalle, Fernando, 48
 Laurell, Asa Cristina, 269
 León XIII, 49
 Lewery Blackley, William, 51
 Liebknecht, W., 46, 49
 Llevellyng Smith, Hubert, 52
 Lloyd George, David, XV, 51-52
 López Mateos, Adolfo, 94
 López Rayón, Ignacio, 79
 Lula da Silva, 76

 Macías, José Natividad, 81
 Madaguar, Nicolás, 98
 Margáin Manatou, Emilio, 392
 Martínez, Gabriel, 210
 Martínez Villalba, Luis José, 75
 Martone, Francisco José, 14
 Marx, Karl, 44-47
 Massa, Sergio Tomás, 74-75
 Megee, John H., 39
 Miranda Salas, Eduardo, 72-73, 271
 Mitterrand, François, 3
 Mommsen, 33
 Monzón, Máximo Daniel, 15
 Morelos, José María, XVI, 79
 Moreno Padilla, Javier, 118
 Moro, Tomás, 36-37, 44
 Morones Prieto, Ignacio, 96
 Muñoz Ledo, Porfirio, 96

Nápoli, Rodolfo, 149-150
Nava Negrete, Alfonso, 136, 392
Newton, Isaac, 39

Obregón, Álvaro, 82
Ojeda Paullada, Pedro, XVIII
Ortega y Gasset, José, 4
Ortiz Martínez, Guillermo, 212
Ortiz Mena, Antonio, 95

Pareto, Vilfredo, 32
Pascal, Blas, 39
Patten, 41
Peralta, Carlos, 226-227
Pérez de Herrera, Cristóbal, 38
Pío, Antonino, 33
Pitágoras, 31
Platón, 32, 37
Poblete Troncoso, Moisés, 13

Radbruch, Gustav, 7-8
Ramírez López, Berenice, 314, 341
Rodríguez Silva, Eduardo, 72-73, 271
Rojas, Luis Manuel, 81
Romo Garza, Alfonso, 210-211, 226
Rouaix, Pastor, 81
Rousseau, Juan Jacobo, 44
Ruiz Cortines, Adolfo, 94
Ruiz Moreno, Ángel Guillermo, XIV, 15, 329

Sachet, 158
Saleilles, 151
Salinas de Gortari, Carlos, 98, 267
San Agustín, 4

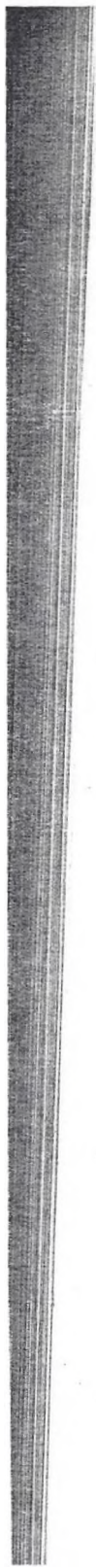
San Benito, 34
San Francisco de Asís, 34
Sánchez, Carlos, 84
Sánchez Alvarado, Alfredo, XIV
Santamaría García, Jorge, 133, 137
Santos Guajardo, Vicente, 95
Schaffle, 41, 48
Schmoller, 41
Schwarzer, Helmut, 76
Slim, Carlos, 211
Small, 41
Sócrates, 31
Soto Pérez, Carlos, 360
Süssmilch, Johann Peter, 40

Tolcke, 46
Trueba Urbina, Alberto, XIV

Unsain, Alejandro M., 152

Vaillant, Edouard, 54
Valencia Armas, Alberto, 328, 350, 361
Vargas, Getulio, 75
Vázquez Raña, Abel, 226
Villada, 79
Wagner, Adolfo, 41, 48
Waltzing, J.P., 33
Wait, James, 41
Webb, 41
Wiegandt, Klaus, 210-211

Zavala, Dionisio, 81
Zedillo, Ernesto, XVI, 110, 204, 208, 210, 212



Índice analítico

.....

- Accidente de trabajo, 198
 - imputable al patrón, 184
 - prestaciones en caso de, 58
- Acciones, 344
 - adquisición de, 322-323
- Activos, comisión sobre, 337
- Actuaría, 18
- Administración
 - comisión por, 336
 - compartida, 267
 - de las pensiones, 168
 - Pública Federal, 306
- Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore), 307, 309, 314, 350
 - autorización de las, 320-321
 - contrato con la, 329
 - vigencia del, 337
 - elección de, por el trabajador, 288-290
 - facultades de las, 319
 - liquidación de las, 349
 - organización de las, 320-321
 - órganos de las, 323-326
 - prohibiciones de las, 320
 - responsabilidades de las, 316-317
 - trabajador elije, 288-290
- Adquisición de acciones, 322-323
- Afiliación, 127-128
- Ahorro interno, 116
- Amparo, demanda de, 257
- Análisis de Riesgos, Comité de, 345
- Anteproyecto de presupuesto, 379-380
- Apoyo financiero, 117
- Asamblea(s)
 - General, 369-371, 373
 - extraordinaria, 373
 - semestrales, 370
- Ascendientes, pensión de, 177-178, 242
- Asegurado(s), 21, 118, 123-124
 - inconformidad del, 185
- Aseguramentum*, 35
- Asignación, 25
- Asociación Internacional de Seguridad Social, 55
- Ausencias del trabajador, 139-140
- Autorregulación, facultad limitada de, 381
- Ayuda(s), 25
 - para gastos de
 - defunción, 183, 231
 - matrimonio, 303-304
- Banco Mundial, financiamiento del, 212
- Beneficiarios, 21, 118, 123, 126, 199-200, 240
- Beveridge, Plan, 53-54
- Bienes materiales, 368
- Cajas de seguro popular, 81-82
- Cálculo(s)
 - actuariales, 196
 - de las pensiones, 285
 - del monto constitutivo, 298

- Capital(es), 243
 - constitutivos, 243, 251, 254, 366
 - fincamiento de los, 246-247
 - pago de los, 253
 - supuestos de los, 244-245
 - social mínimo, 321
- Carácter obligatorio, 92
- Causante obligado, 249
- Cédulas
 - de determinación, 386-387
 - de liquidación, 249, 387
- Centro médico, 202
- Cesantía en edad avanzada y vejez, 278-279
 - pensión de, 274, 277, 281
 - seguro de, 276-277
- Cláusulas
 - de procedimiento, 334-336
 - sustantivas, 329-334
- Clínica, 201
 - hospital, 201
- Cobro(s)
 - coercitivo, 374
 - de las cuotas, 374
 - oficinas para, 377-378
- Código
 - Civil Federal*, 155
 - para el Distrito Federal*, 155
 - de Comercio*, 37
 - del Trabajo*, 83
 - Federal de Procedimientos Civiles*, 389
 - Fiscal de la Federación*, 119
- Comisión(es), 326-327, 336
 - de Vigilancia, 372-373
 - Nacional
 - de Seguros y Fianzas, 289
 - del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), 19, 305-309, 320, 326
 - obligaciones de la, 314
 - órganos de la, 309-310, 369
 - por administración, 336
 - por cuota fija, 337
 - sobre activos, 337
 - sobre flujos, 337
 - Tripartita para el Fortalecimiento y Modernización de la Seguridad Social, 115-116
- Comité
 - Consultivo y de Vigilancia, 311-312, 321, 323
 - de Análisis de Riesgos, 345
 - de riesgos, 343
 - de Valuación, 346, 348
 - Técnico, 306
- Concubinato, 173-175
- Congreso(s)
 - de la Unión, 90, 114
 - reformas al, 94
 - Internacional Socialista, 54
 - socialistas, 46-47
- Consejeros, 370
- Consejo
 - Consultivo Delegacional, 389-390
 - Secretario del, 390-391
 - Técnico, 370, 373, 382-383
 - atribuciones, 371
 - Delegacional, 389
- Conservación de derechos, 302-303
- Constitución, 80-81, 114
 - Federal, 250
- Contralor normativo, 324
- Contrato(s), 324, 353
 - colectivo, 141
 - de trabajo, 368, 372
 - con la Afore, 329
 - vigencia del, 337
 - tribunales competentes en los, 337-339
- Convenio(s)
 - con los patrones, 209
 - sobre la seguridad social, 55-66
- Conyuges, 173-175
- Cooperativas, 93, 234-235
- Costo(s)
 - clasificación, 218
 - de las prestaciones, 62
- Cotización, salario base de, 133-135
- Crecimiento, 93
 - horizontal, 94
 - vertical, 94
- Crédito(s), 144-145
 - exigibilidad del, 377
 - facultad para fijar, 376
 - fiscal, 250
- Cuadro básico de medicamentos, 227-228
- Cuenta(s)
 - concentradora, 290, 292-293
 - individual(es), 267, 275, 285-288, 297, 309, 319, 333-334, 361
 - transferencias de, 294-295
 - unificadora, 315
- Culpa aquiliana, 149
- Cuota(s), 275, 376, 381
 - cobro de las, 374

- fija, comisión por, 337
 - naturaleza jurídica de la, 141-142, 385-386
 - obrero-patronales, 386
 - pago de las, 144, 297
 - patronales, 282
 - pensionarias, 283
 - reversión de, 224
- Daño, 254-255
- Demanda de amparo, 257
- Defunción, ayuda para gastos de, 183, 231
- Dependencia económica, 242
- Derecho(s)
- a la seguridad social, 5
 - civil, 149, 153
 - conservación de, 302-303
 - de traspaso, 295
 - del seguro social, 11, 17
 - del trabajador, 256-257
 - Mercantil, 267-268
 - Romano, 32
- Derechohabiente, 20, 123-124, 256
- Descentralizar, 222
- Desconcentrar, 222
- Desempleo, prestaciones de, 56
- Desfasamiento a corto plazo, 117
- Despesas, 136
- Determinación, cédulas de, 386-387
- Economía, 18
- Edad avanzada y vejez, cesantía en, 278-279
- pensión de, 274, 277, 281
 - seguro de, 276-277
- Empresas operadoras, 350-351
- Enfermedad(es), 198
- profesional, prestaciones en caso de, 58
 - seguro obligatorio de, 48
 - y maternidad, seguro de, 123, 195, 198, 243
 - régimen financiero del, 231-233
- Esquemas modificados, 117
- Estadística, 18
- Estado, 38
- socialismo de, 41
- Facultad(es), 375
- fiscales, 367, 377
 - limitada de autorregulación, 381
 - para fijar créditos, 376
- Fincamiento de los capitales constitutivos, 246-247
- del Banco Mundial, 212
- Financiera rural, 268
- Finanzas, 17
- Finiquito, 25
- Flujos, comisión sobre, 337
- Fondo de Previsión Social, 234-235
- Garantías constitucionales, 338
- Gasto público, 283-284
- Gerontocracia, 31
- Gobierno
- Junta de, 310-311
 - órganos de, 309-310, 369
- Grupos sociales, 17
- Guarderías
- seguro de, 109-110, 259-262
 - y prestaciones sociales, seguro de, 123
- Homologación de las normas legales, 18
- Hospital, 202
- clínica, 201
- Incapacidad
- permanente, 163
 - parcial, 163, 168, 181
 - total, 163, 167
 - temporal, 163
- Inconformidad
- del asegurado, 185
 - recurso de, 256, 389-390, 393
- Indemnización(es), 25, 164, 171, 253
- pago de la, 166
 - por riesgos de trabajo, 165
- Índice
- de frecuencia, 190
 - de gravedad, 191
 - de siniestralidad, revisión del, 189-190
- Inseguridad, 6-7
- causas de la, 6
 - biológicas, 6
 - físicas, 6
 - sociales, 6
- Instituto
- de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 19
 - del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), 305

- Mexicano del Seguro Social (IMSS), 19, 195
proyecto de reforma del, 213-221
- Interés
público, 92
social, 91
- Invalidez, 238
pensión de, 108, 237-239
prestaciones de, 60
seguro de, 123, 183, 243
- Inversión, régimen de, 344
- Juicio(s)
fiscal(es), 249-250, 393, 395-398
laboral, 257
- Junta
de Conciliación y Arbitraje, 185
de Gobierno, 310-311
- Ley(es)*, 82, 95-96, 269
de Ingresos, 380
de los grandes números, 40
de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, 19, 101, 270, 307, 309
de Pobres, 37
de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, 287, 378
de Protección, 338
de Sociedades Mercantiles e Instituciones de Crédito, 316
del Impuesto Sobre la Renta, 274
del Infonavit, 274
del ISSSTE, 21, 101, 131, 272
del Mercado de Valores, 335
del Seguro Social, 13, 15, 20-21, 82, 84, 98, 113, 131-132, 153-155, 157, 196, 237, 305, 365
del Trabajo, 80, 83
para el Distrito y Territorio Federal, 82
- Federal
de Competencia Económica, 314
de Procedimiento Contencioso Administrativo, 393
del Trabajo, 90, 127, 131-132, 153, 155-156, 251, 284, 315, 385
- General
de Pensiones Civiles de Retiro, 83
de Sociedades Cooperativas, 234
- de Seguros, 89
Mercantiles, 315
- Orgánica de la Administración Pública Federal*, 368
para la Coordinación del Sistema de Ahorro para el Retiro, 100, 268, 306
- Liquidación
cláusulas de, 334-336
de las Afore, 349
de las Siefore, 349
- Maestro, seguro federal del, 83
- Mandato constitucional, 153
- Maternidad, 229-230
seguro de enfermedades y, 123, 195, 198, 243
régimen financiero del, 231-233
- Matrimonio, ayuda para gastos de, 303-304
- Medicamentos, cuadro básico de, 227-228
- Medicina
particular, 205
subrogada, 203-204
- Modificación de los salarios, 140
- Monto
constitutivo, 297
cálculo del, 298
de la prima, 189-192
- No asalariados, 125
- Normas legales, homologación de las, 18
- Obligaciones, 365
administrativas, 365
fiscalizadoras, 365
- Oficinas para cobros, 377-378
- Onus probandi*, 149,
- Ordenamiento(s)
abrogado, 159
civiles, 155
- Ordenanzas, 36
- Orfandad, pensión de, 175-177, 241
- Organismo(s)
administradores, 17
fiscal, 119
autónomo, 374
privados, 205
público descentralizado, 143
- Organización(es), 26
de caridad, 34
Internacional del Trabajo (OIT), 55, 228
religiosas, 34

- Órganos
de la Consar, 309-310, 369
de las Afore, 323-326
- Pago
de la indemnización, 166
de las cuotas, 144, 297
de las prestaciones, 256
de los capitales constitutivos, 253
- Pater familiae*, 32
- Patrón(es)
accidente de trabajo imputable al, 184
convenios con los, 209
existencia de varios, 141
- Pensión(es), 25, 77, 167, 273
administración de las, 168
cálculo de las, 285
condiciones para el otorgamiento de,
296-297
de ascendientes, 177-178, 242
de cesantía en edad avanzada y vejez,
274, 277, 281
de invalidez, 108, 237-239
de orfandad, 175-177, 241
de viudez, 173, 175, 240-241
fondos de las, 197
garantizada, 300-302
incremento de las, 181
mensual, 297
por muerte, 172
por riesgo de trabajo, 171
Sistema de Fondos de, 72-73
- Pensionados, 21
- Perjuicio, 254
- Personas, 123
- Plan Beveridge, 53-54
- Política económica y social, 116
- Póliza, 9
- Premios por asistencia y puntualidad, 136
- Prestaciones, 24, 164, 166, 240
costo de las, 62
de desempleo, 56
de invalidez, 60
de sobrevivientes, 60
de vejez, 57
económicas, 25
en caso de accidente de trabajo
y de enfermedad profesional, 58
en dinero, 229
familiares, 58-59
médicas, 25, 166, 200-201
normales, 132
ordinarias, 132
otorgamiento de las, 247-248
pago de las, 256
periódicas, 132
sociales, 26, 110-111, 262-263
seguro de guarderías y, 123
- Presupuesto, 378-379
anteproyecto de, 379-380
- Prima, 9
monto de la, 189-192
- Principios del seguro social, 18
- Probabilidades, teoría de las, 40
- Procedimiento, cláusulas de, 334-336
- Producción, sociedades cooperativas de, 235
- Propiedad del trabajador, 284-285
- Prórroga, 388
- Protección, 8
al salario, 91
- Proyecto de reforma del IMSS, 213-221
- Queja, 256
- Real cédula, 37
- Recurso
administrativo, 392
de inconformidad, 256, 389-390, 393
- Reforma(s), 269-270
al Congreso de la Unión, 94
del IMSS, proyecto de, 213-221
- Régimen
adicional, 122
de inversión, 344
facultativo, 121-122
financiero, 264, 282
del seguro de enfermedades
y maternidad, 231-233
en el seguro de riesgos de trabajo,
186-189
obligatorio, 120
voluntario, 120-121
sujetos del, 233-234
- Renta vitalicia, 280, 299
seguro de, 299-300
- Rerum Novarum*, 49
- Retiro(s)
programados, 25
seguro de, 103-106, 123, 274-275
- Reversión de cuotas, 224
- Riesgo(s), 34-35
clasificación por, 93
- Comité de, 343
Análisis de, 345

- creado, 153
 - teoría del, 151
- de trabajo, 149, 156-157, 172
 - efectos del, 162-163
 - excepciones al, 160-162
 - indemnización por, 165
 - orígenes del, 158-159
 - pensiones por, 171
 - seguro de, 109, 122, 198
 - régimen financiero en el, 186-189
- teoría del, 150
 - objetiva, 91
- Salario(s)
 - base de cotización, 133-135
 - fijo, 138
 - mixto, 139
 - modificación de los, 140
 - protección al, 91
 - variable, 138
- Saldo acumulado, 297
- Sanción, 128-129
- Seguridad, 3, 5-6
 - biológica, 4
 - ecológica, 4
 - económica, 4
 - educativa, 4
 - física, 4
 - jurídica, 5
 - laboral, 5
 - médica, 5
 - militar, 5
 - pública, 5
 - religiosa, 5
 - social, 4, 7, 10-16, 271-272
 - convenio sobre la, 55-66
 - derecho a la, 5
- Seguro(s), 8, 92, 97, 199
 - adicional, 23-24
 - de cesantía en edad avanzada y vejez, 276-277
 - de enfermedades y maternidad, 123, 195, 198, 243
 - régimen financiero del, 231-233
 - de guarderías, 109-110, 259-262
 - y prestaciones sociales, 123
 - de invalidez, 123, 183, 243
 - de renta vitalicia, 299-300
 - de retiro, 103-106, 123, 274-275
 - de riesgos de trabajo, 109, 122, 198
 - régimen financiero en el, 186-189
 - de sobrevivencia, 280, 300
 - de vida, 39, 41, 239-240
 - facultativo, 23
 - federal del maestro, 83
 - marítimo, 35
 - obligatorio, 22
 - de enfermedades, 48
 - popular, 22, 26
 - cajas de, 81-82
 - privado(s), 41, 223
 - social, 8-12; 15-16, 102, 142, 163, 235
 - derecho del, 11, 17
 - elementos comunes al, 19
 - en Alemania, 43-44, 50
 - en América, 69
 - en Inglaterra, 50-52
 - fundamentos del, 17
 - principios del, 18
 - voluntario, 22-23
- Servicio(s)
 - médicos, 195, 202, 226
 - particulares, 205
 - público, 92
- Siniestralidad, 189-190
 - revisión del índice de, 193
- Sistema
 - de Ahorro para el Retiro (SAR), 27
 - de Fondos de Pensiones, 72-73
- Situación financiera, 116
- Sobrevivencia, seguro de, 280, 300
- Sobrevivientes, prestaciones de, 60
- Socialismo de Estado, 41
- Sociedad(es), 6
 - cooperativas de producción, 235
 - de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro (Siefore), 308-309, 317, 341-347
 - liquidación de las, 349
 - prohibiciones de las, 347-348
- Solidaridad social, 12, 14, 26, 69, 85
- Solidariohabiente, 21
- Subrogación, 254, 256
 - integral, 219
 - parcial, 219
 - total, 219
- Subsidios, 25, 166-167
 - cruzados, 107
- Sujetos, 20, 198-199
 - del régimen voluntario, 233-234
 - obligados, 20, 127-128
- Suma asegurada, 170, 297-298
- Sustitución patronal, 144-145

- Teoría
 de la culpa subjetiva, 150-151
 de las probabilidades, 40
 del riesgo, 150
 creado, 151
 objetiva, 91
- Tiempo extraordinario, 137
- Trabajador(es),
 ausencias del, 139-140
 de confianza, 382
 derechos del, 256-257
 dignidad del, 338
 elección de Afore, 288-290
 propiedad del, 284-285
- Trabajo
 accidente de, 198
 imputable al patrón, 184
 prestaciones en caso de, 58
 contrato colectivo de, 368, 372
 riesgo(s) de, 149, 156-157, 172
 efectos del, 162-163
 excepciones al, 160-162
 indemnización por, 165
 orígenes del, 158-159
 pensiones por, 171
 seguro de, 109, 122, 198
 régimen financiero en el, 186-189
- Transparencia, 17
- Traspaso, derecho de, 295
- Tribunal(es)
 competentes en los contratos, 337-339
 Federal de Justicia Fiscal
 y Administrativa, 248, 250, 398, 400
- Unidades móviles, 17, 201
- Valuación, Comité de, 346, 348
- Vejez, 280-281
 cesantía en edad avanzada y, 278-279
 pensión de, 274, 277, 281
 seguro de, 276-277
 prestaciones de, 57
- Vida, seguro de, 39, 41, 239-240
- Vigilancia
 Comisión de, 372-373
 Comité Consultivo y de, 311-312,
 321, 323
- Viudez, pensión de, 173, 175, 240-241
- Zona médica presupuestal, 217

La seguridad social es tan antigua como la humanidad, pues la sociedad se ha preocupado en distintas épocas, en mayor o menor medida, por combatir la inseguridad que enfrenta la existencia humana.

Debido a que la seguridad social es un tema vigente y de interés general, para resaltar su importancia y ofrecer un panorama general de ella, en el presente libro se analiza desde los antecedentes del seguro social y las diversas leyes que han regido las formas de seguridad social en nuestro país hasta la situación actual de la materia.

El autor examina de manera didáctica los aspectos principales de la seguridad social, como los diversos tipos de seguros que ampara el sistema de seguridad social mexicano: riesgos de trabajo; enfermedad y maternidad; invalidez y vida; capitales constitutivos; guarderías y prestaciones sociales, y retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.

También expone los lineamientos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), las Administradoras del Fondo de Retiro (Afore) y las Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro (Siefore), así como la organización, las facultades y los medios de defensa del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Esta obra es un valioso aporte al tema del seguro social del licenciado Alberto Briceño Ruiz, fundador y presidente de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social, A.C., quien —como apunta el prologuista Pedro Ojeda Paullada— “ha participado intensamente en el análisis y estudio de las muchísimas modificaciones que ha tenido el Derecho de la Seguridad Social en México y el mundo”.

OXFORD
UNIVERSITY PRESS

derecho@oup.com
www.oup.com.mx



ISBN 978-607-426-095-3



9 786074 260953